

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
EDUARDO LAMY

**COMENTÁRIOS
AO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL** | **IX**

ARTIGOS 539 AO 673

LUIZ GUILHERME MARINONI
DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART
DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS
**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

2019 - 04 - 06

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

PRIMEIRAS PÁGINAS

COMENTÁRIOS AO CPC - V. IX - MARINONI - ED. 2018

ARTIGOS 539 AO 673

Autores

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA

EDUARDO LAMY

© desta edição [2018]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono

Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda

Tel.: 11 3613-8400 - Fax: 11 3613-8450

CEP 01136-000 - São Paulo

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal) com pena de prisão e multa, busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

Visite nosso site: www.rt.com.br

Central de Relacionamento RT
(atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)

Tel. 0800.702.2433

e-mail de atendimento ao
consumidor: sac@rt.com.br

Fechamento desta edição:
[14.08.2018]



ISBN 978-85-5321-180-7

© desta edição [2018]

2019 - 04 - 06

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais **Juliana Mayumi Ono**

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A. M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Beatriz Brandão Belo Bicker, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Chrisley Figueiredo

Adaptação de capa: Linotec

Projeto gráfico: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

Analista de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis

2019 - 04 - 06

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha Catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Silva, Ricardo Alexandre da

(arts. 539 ao 673) / Ricardo Alexandre da Silva, Eduardo Lamy. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. -- (Coleção comentários ao código de processo civil ; v. IX / direção Luiz Guilherme Marinoni ; coordenação Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero)

6 Mb ; e-Pub

2. ed. e-book baseada na 2. ed. impressa rev. e atual.

Bibliografia

ISBN 978-85-5321-180-7

1. Processo civil - Legislação - Brasil

I. Lamy, Eduardo. II. Marinoni, Luiz Guilherme. III. Arenhart Sérgio Cruz. IV. Mitidiero, Daniel. V. Título. VI. Série.

18-19280 CDU-347.9(81)(094.46)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Código de Processo Civil Comentado

347.9(81)(094.46)

2. Código de Processo Civil : Comentários : Brasil

347.9(81)(094.46)

Maria Paula C. Riyuzo - Bibliotecária - CRB-8/7639

2019 - 04 - 06

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE OS AUTORES

Sobre os Autores

Ricardo Alexandre da Silva

Doutor e Mestre em Processo Civil na UFPR. Professor em vários cursos de especialização *lato sensu*. Membro do IAP – Instituto dos Advogados do Paraná. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Autor de livros e diversos artigos sobre direito processual civil publicados em coletâneas e em revistas especializadas. Advogado nas áreas contenciosa e consultiva.

Eduardo Lamy

Doutor e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor Adjunto de Direito Civil e Processual Civil da Universidade Federal de Santa Catarina nos cursos de Graduação, Pós-Graduação *lato sensu* e *stricto sensu* (mestrado). Professor da Escola da Magistratura e das Escolas do Ministério Público de Santa Catarina e do Distrito Federal e Territórios, bem como professor convidado permanente da Escola Superior da Advocacia Catarinense. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Sócio do Escritório Mello e Souza & Associados Advogados e Consultores. Tem obras publicadas em Direito Civil e Processual Civil atuando, principalmente, nas seguintes áreas: Direito Civil (contratos, direitos reais, direito imobiliário e direito de família), Direito Ambiental, Terrenos de Marinha. Processo Civil e Arbitragem. Advogado.

2019 - 04 - 06

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos

Minha esposa Silvia Daniele Araki não apenas me incentivou ao longo da redação, mas revisou o texto e auxiliou na pesquisa jurisprudencial. Foi, além disso, uma excelente interlocutora, com quem discuti várias questões polêmicas. Sua paciência e carinho foram imprescindíveis e foi ela, como sempre, minha fonte de inspiração. Muito obrigado, meu amor!

Agradeço ao Prof. Dr. Luiz Guilherme Marinoni pelo diálogo franco. Nossa troca de ideias, mais que uma honra, sempre foi um grande estímulo para mim. Sou grato ao grande mestre pela convicção de que o processo deve servir à tutela dos direitos, sob pena de degenerar em técnica estéril.

A redação foi aprimorada após a cuidadosa leitura de Anissara Toscan, a quem também devo valiosas sugestões sobre temas especialmente desafiadores. Foi muito importante contar com suas contribuições, fundamentadas em profundo conhecimento sobre o processo civil. Gratíssimo!

Danielle Fernanda da Silva leu os originais e fez indicações jurisprudenciais oportunas. Ao carinho de irmã, somou a generosidade da crítica.

Renato Lisboa Altemani e Luís Felipe Canever fizeram valiosos apontamentos aos comentários às ações possessórias.

Leandro José Rutano auxiliou na elaboração do índice alfabético-remissivo e discutiu diversas questões processuais relacionadas aos procedimentos que comentei.

Aos meus pais, José Bosco e Madalena da Silva, e a minha irmã, Fabiane Cristina, agradeço por todo apoio e peço desculpas pela ausência. Espero que essa obra, agora em segunda edição, ajude a justificá-la!

Por fim, *in memoriam*, certo de que o mundo é um lugar bem pior sem eles, faço minha saudosa referência aos queridos avós Fredolin e Orlanda Haskel, Vendelino e Elvira da Silva.

Curitiba, inverno de de 2018.

Ricardo Alexandre da Silva

Este livro foi resultado de um trabalho em equipe. Desde os meus orientandos e alunos de graduação até os colegas de escritório e os familiares, todos tiveram imensa participação.

Por isso agradeço enfaticamente, antes de mais nada, ao amigo Luiz Guilherme Marinoni, cujo convite para participar destes comentários muito me honrou.

Agradeço, ainda, ao Pedro Henrique Reschke e à Adriana Buchmann, sensacionais alunos do curso de Mestrado em Direito da UFSC, que auxiliaram sobremaneira e incansavelmente em diversas fases da obra.

Agradeço, também, aos colegas do PPGD/UFSC, aos familiares e aos amigos, bem como à família do meu escritório de advocacia, cujo apoio é sempre imprescindível: Anna Carolina Faraco Lamy, Luíza Boscato Raimundo, Eduardo de Brida Alves, Samir Alves Junior e Gianluca Moser.

Por fim, dedico a obra e agradeço calorosamente à minha esposa, Anna Carolina Faraco Lamy, pelo amor, pela luta, pela paciência e também pelo incentivo, dos quais esta obra resultou.

Florianópolis, primavera de 2016.

Eduardo Lamy

© desta edição [2018]

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

Título III - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

CAPÍTULO I - Da Ação de Consignação em Pagamento [Art. 539 a 549]

CAPÍTULO II - Da Ação de Exigir Contas [Art. 550 a 553]

CAPÍTULO III - Das Ações Possessórias [Art. 554 a 568]

CAPÍTULO IV - Da Ação de Divisão e da Demarcação de Terras [Art. 569 a 598]

CAPÍTULO V - Da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade [Art. 599 a 609]

CAPÍTULO VI - Do Inventário e da Partilha [Art. 610 a 673]

TÍTULO III - Dos PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

1. Introdução

Para que as relações obrigacionais, tão difundidas na contemporaneidade, possam cumprir com eficiência seu objetivo de permitir a circulação de bens, é necessário que o Direito discipline não apenas o inadimplemento do devedor, mas, igualmente, a inviabilidade de pagamento em decorrência de conduta atribuível ao credor.

Assim como o credor tem o direito de receber, o devedor o tem de pagar. Caso o pagamento não possa se concretizar por força da recusa do credor em receber o preço ou em dar quitação, ou por conta de algum outro elemento relacionado à pessoa do credor, o devedor poderá se liberar da obrigação por meio da consignação em pagamento.¹

Trata-se, como se verá, de meio substitutivo ao pagamento, podendo ser caracterizado como forma de adimplemento da obrigação. Desde que o devedor deposite a coisa ou a quantia devida, em conformidade com os demais requisitos para a validade do pagamento, será exonerado da obrigação. Essa forma substitutiva de pagamento não se aplica às obrigações de fazer e de não fazer.

No mais corriqueiro dos casos de consignação, consistente na recusa do credor, ao devedor caberá realizar a oferta da prestação, para somente então, diante da resistência do titular do crédito, consigná-lo, a fim de obter a liberação por meio substitutivo. Quando a consignação estiver motivada por desconhecimento sobre a pessoa do credor, não será necessário, nem mesmo seria possível, realizar a oblação. O devedor ignora quem seja o titular do crédito, o que lhe permite deflagrar a demanda consignatória sem antes oferecer a coisa devida.

Admite-se no Brasil, em se tratando de obrigações pecuniárias, que a consignação seja realizada extrajudicialmente, perante instituição financeira, a qual mediará a interpelação do credor para o recebimento do crédito e a liberação do devedor. Não se aplica ao direito brasileiro, portanto, a ideia de que o pagamento em consignação seria caracterizado pela necessária intervenção do Judiciário.² Nas obrigações pecuniárias há possibilidade de exoneração do devedor sem que para isso se exija a provocação de qualquer juízo. Lamenta-se que o direito brasileiro não tenha estendido o pagamento em consignação extrajudicial para outras situações além das prestações em pecúnia.

O Código de Processo Civil prevê, nos arts. 539 a 549, a demanda consignatória. Considerada a especificidade da pretensão, caracterizada pelo reconhecimento da regularidade do depósito e sua capacidade de desconstituir a obrigação, elaborou-se procedimento especial. Com efeito, a pretensão liberatória somente com alguma dificuldade seria enquadrável no procedimento comum. É essencial, para a compreensão do instituto, perceber que a extinção da obrigação é efeito do depósito válido e adequado, limitando-se a sentença a declarar sua regularidade. A eficácia preponderante, portanto, é declaratória.

Ao dispor sobre a demanda de consignação o Código de Processo Civil se baseou na disciplina que o Código Buzaid concedia ao instituto. Nada obstante, houve modificações em pontos

sensíveis. O exame das mudanças e a interpretação daquilo que prossegue tal como previra o código revogado será realizado a seguir. Não se pode esquecer, contudo, que o novo código realizou mudanças estruturais no processo civil brasileiro, de modo que mesmo as proposições normativas que foram mantidas, podem trazer soluções que o sistema anterior não permitia.

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1.º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.

§ 2.º Decorrido o prazo do § 1.º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3.º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa.

§ 4.º Não proposta a ação no prazo do § 3.º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.

1. Adimplemento por consignação

O pagamento é o meio típico para a extinção da obrigação. Em determinadas situações, porém, inviabiliza-se o cumprimento da prestação pelo devedor, ainda que ele disponha de meios e tenha interesse em cumpri-la.³ Para assegurar que mesmo nesses casos a obrigação seja extinta, com a exoneração do obrigado, o Código Civil prevê o pagamento em consignação, realizado mediante depósito da coisa ou quantia devida. Tratando-se de prestação pecuniária, admite-se o depósito em estabelecimento bancário.⁴

Discute-se, na doutrina, se essa modalidade de exoneração do devedor caracteriza verdadeiro pagamento ou se constitui modo substitutivo de extinção da obrigação.⁵ Considerando que a liberação do obrigado ocorrerá por meio diverso do que fora avençado, é mais correto concluir que se trata de forma substitutiva de extinção da obrigação.

No Código Civil o tema é tratado em título concernente ao adimplemento, o que poderia corroborar a conclusão de que se trata de pagamento. Ocorre, como afirma Judith Martins-Costa, que adimplemento significa não apenas o cumprimento da prestação precisamente na forma pactuada, mas também, em acepção mais ampla, qualquer modo de satisfação pelo devedor. Desse modo, a previsão do pagamento em consignação no título que regula o adimplemento é insuficiente para caracterizar o instituto como verdadeiro pagamento. Trata-se, como já dito, de forma substitutiva de extinção da obrigação.

O depósito no pagamento em consignação poderá ter como objeto dinheiro, bens móveis e até imóveis.⁶ A possibilidade de depósito de imóvel não pode causar perplexidade.⁷ Nas relações locatícias, encerrado o contrato, se o locador resistir à devolução do bem, poderá o locatário requerer que seja ele consignado.⁸ O instituto não se aplica às obrigações de fazer e de não fazer, pois a prestação, nessas relações obrigacionais, corresponde a uma conduta ou a uma omissão, não havendo o que se depositar.⁹

No Capítulo I do Título III (“Dos Procedimentos Especiais”) do Livro I (“Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença”) da Parte Especial, arts. 539 a 549, o Código de Processo Civil traz a disciplina da demanda consignatória, instrumento por meio do qual a obrigação será extinta, liberando-se o devedor, mediante depósito da coisa devida. No art. 539, §§ 1.º a 4.º, reiterando o tratamento dispensado ao tema no art. 890, §§ 1.º a 4.º, do CPC/1973, é disciplinado o depósito extrajudicial de prestações pecuniárias. Os demais dispositivos se referem

a diferentes aspectos da ação de consignação.

Convém esclarecer que, sob o ponto de vista da técnica processual, não se confundem as “ações” com as “demandas”. Pode-se conceituar “ação” como o direito subjetivo público, uno e abstrato, previsto no art. 5.º, XXXV, da CF/1988, concedido indistintamente a todos os cidadãos. Quando o autor provoca o Judiciário, postulando tutela contra lesão ou ameaça a direito, exerce a ação. Esse exercício consiste no pedido de tutela jurisdicional, com o qual o processo é instaurado, submetendo-se ao juiz a pretensão qualificada pela causa de pedir, delimitando o objeto litigioso. O ato de provocar o Poder Judiciário, deflagrando o processo, é denominado demanda.¹⁰ Advirta-se que os termos “ação” e “demanda”, apesar da nítida distinção conceitual, podem vir a ser empregados como sinônimos ao longo destes comentários, a fim de evitar a repetição de palavras em uma mesma oração, o que não significa que se esteja a suprimir a diferença conceitual entre os institutos.

É imprescindível, para a adequada aplicação do instrumento processual disponibilizado ao devedor, a compreensão das hipóteses previstas em lei para que ocorra o pagamento por consignação. Em linhas gerais, as hipóteses de cabimento da consignação podem ser concentradas em duas categorias: mora do credor e impossibilidade de pagamento decorrente de alguma circunstância relacionada à pessoa do credor. A seguir, serão analisadas as hipóteses previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

1.1. Impossibilidade ou recusa injusta do credor em receber o pagamento ou dar quitação

No art. 335, I, do CC/2002, é prevista a consignação quando o credor se recusar a receber o pagamento ou a dar quitação ou, ainda, quando não puder fazê-lo.¹¹ Para que se caracterize a recusa do credor é necessário que antes ocorra a oblação.¹² Com efeito, não se poderá conceber a recusa sem que antes o devedor tenha realizado a oferta.

É digno de nota que o dispositivo se refere à recusa injusta, caracterizada nas hipóteses em que o credor se negar a receber o pagamento ou a dar quitação apesar de o devedor oferecê-lo em estrita conformidade com o que fora pactuado. Não é difícil imaginar que o credor, imbuído de má-fé, possa rejeitar a oferta a fim de postular a incidência de multa pelo descumprimento. Essa recusa injusta em receber o pagamento ou em dar quitação caracteriza a *mora accipiendi* e autoriza o pagamento em consignação. Precedente firmado sob o CPC/1973 assentou corretamente que a propositura de demanda consignatória não purga a mora do credor, de modo que poderia ser exigida a multa por inadimplemento estipulada no contrato firmado entre as partes.¹³

Será justa a recusa quando o devedor oferecer o pagamento em desconformidade com o que fora estipulado. Nos termos do art. 394 do CC/2002, estará em mora o credor que se recusar a receber o pagamento no termo, lugar e forma estabelecidos em lei ou pactuados pelos interessados.¹⁴ Assim, se houver oferta em quantidade ou qualidade diversas, ou em momento no qual a prestação, embora na quantia pactuada, já não tenha utilidade ao credor, este poderá se recusar justamente a receber o pagamento.¹⁵

A questão se torna mais complexa diante da mora do devedor. Mencionou-se que o credor pode se recusar justamente a receber o pagamento quando este já não lhe trouxer utilidade, tal como assenta o art. 395, parágrafo único, do CC/2002.¹⁶ Isso não significa, contudo, que a mora do devedor impeça o pagamento por consignação, como sugere renomado jurista.¹⁷ A consignação pode ocorrer sempre que a prestação não for inútil para o credor.¹⁸ Tratando-se de obrigação pecuniária, é descabido falar em perda de utilidade.¹⁹

Para verificar se a recusa foi justa é necessário diferenciar a mora do inadimplemento. Haverá mora quando o recebimento da prestação ainda for possível, caracterizando-se o inadimplemento absoluto quando o cumprimento da prestação não mais se viabilizar em decorrência da falta de interesse do credor.²⁰

O inadimplemento é modalidade de descumprimento da obrigação na qual, conquanto seja possível o cumprimento, ele não interessa mais ao credor. O grupo de músicos contratado para

tocar na festa poderá fazê-lo em outra data. Porém, o credor não terá qualquer interesse nessa prestação. Diga-se o mesmo do fornecedor dos itens de decoração para o casamento. Depois da festa nenhum interesse haverá no recebimento da prestação. Quando, porém, ultrapassado o prazo avençado, o pagamento ainda conservar interesse para o credor, será possível, diante da injusta recusa, promover o pagamento por consignação.

Aponta-se em doutrina ainda outra forma de inadimplemento, designada como violação positiva do contrato, na qual a prestação é cumprida, mas de forma inadequada.²¹ Há, na hipótese, cumprimento defeituoso do objeto do contrato. Ocorreria violação positiva quando o fornecedor de bebidas entregasse rótulos em desconformidade com as especificações do restaurante que lhe contratara. Nesse caso, diante da prestação defeituosa, poderia o contratante se recusar a receber a prestação, pois seria justa sua recusa.

Realizado o depósito liberatório e proposta a demanda, a justiça ou injustiça da recusa será ponto controvertido no processo. Caracterizando-se a legitimidade da rejeição da prestação, a demanda consignatória terá de ser julgada improcedente. A recusa injusta do credor é fato constitutivo do direito do autor, recaindo sobre ele o ônus de comprová-la,²² na forma do art. 373, I, do CPC/2015.²³

Como já dito, o depósito da prestação será possível não somente quando o credor se recusar a receber o pagamento, mas também se ele se negar a dar a respectiva quitação. O art. 319 do CC/2002 estabelece a quitação como um dos direitos do devedor adimplente.²⁴ É certo que de nada adiantaria ao devedor cumprir a prestação se ela não ensejasse a concessão de quitação regular, pois nesse caso ele não teria como comprovar o cumprimento da obrigação e a consequente liberação. Assim, as recusas em dar quitação ou em receber a prestação, equivalem como motivos ensejadores do pagamento em consignação.

O art. 335, I, do CC/2002, inova em relação ao art. 973, I, do CC/1916. Neste dispositivo inexistia referência à impossibilidade de o credor receber o pagamento ou dar quitação, ao passo que o artigo vigente se inicia com a locução “se o credor não puder”. À medida que o inc. III do mesmo artigo se refere à incapacidade, a impossibilidade aludida no inc. I não equivale à falta de capacidade. Trata-se de cláusula aberta, aplicável sempre que não for possível ao credor aceitar o pagamento ou dar quitação e não se caracterizar outras das hipóteses previstas no art. 335 do CC/2002.

1.2. Inércia do credor e dívida quesível

As dívidas são classificadas em quesíveis e portáteis. No primeiro caso, cabe ao credor deslocar-se ao domicílio do devedor para receber a prestação. No segundo, compete ao devedor realizar a oferta da prestação no domicílio do credor ou onde ele tenha determinado.²⁵ Em doutrina se reconhece ainda outra modalidade de dívida, designada como mista, caracterizada pela necessidade de que o credor e o devedor se dirijam para local que não corresponda aos seus respectivos domicílios.²⁶

Em regra, nos termos do art. 327 do CC/2002 será realizado o pagamento no domicílio do devedor, podendo as partes convencionar outro local. De acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo, se dois ou mais lugares houverem sido designados, a escolha caberá ao credor.²⁷

A hipótese ora analisada, prevista no art. 335, II, do CC/2002, diz respeito às dívidas quesíveis.²⁸ Quando ao credor couber buscar a prestação e ele se omitir, ficará caracterizada a inércia autorizadora da consignação em pagamento.²⁹ Não é necessário que o credor formalmente se recuse a receber o pagamento. Basta não se desonerar do encargo de buscar a prestação no lugar, tempo e condição devidos para que o devedor esteja autorizado a realizar o pagamento em consignação.

Recai sobre o devedor, autor da demanda consignatória, o ônus de comprovar a inércia do credor. Para tanto, poderá se valer de quaisquer meios de prova. Trata-se de situação curiosa, pois o autor da demanda terá de provar fato negativo, qual seja, a omissão do credor em buscar a

prestação. Sabe-se que fatos negativos absolutos não podem ser comprovados, mas podem sê-lo os relativamente negativos. Não se pode comprovar que o credor jamais fora ao domicílio do devedor. Mas será possível demonstrar que no dia e hora aprazados o credor deixou de buscar a prestação a que tinha direito ou a mandar buscá-la mediante procurador munido dos poderes necessários para esse fim. Se a comprovação da mora do credor for demasiadamente difícil, será possível inverter o ônus da prova em conformidade com o art. 373, § 1.º, do CPC/2015.³⁰

1.3. Credor incapaz, desconhecido, ausente ou residente em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil

A incapacidade do credor impede que seja outorgada quitação regular na forma do art. 319 do CC/2002, razão pela qual o devedor fica autorizado a realizar o pagamento em consignação se não houver representação adequada.³¹ Como se sabe, o incapaz pode ser assistido ou representado. Quando houver assistente ou representante, o pagamento será realizado normalmente, não se caracterizando hipótese para a consignação. Contudo, quando o incapaz não contar com assistente ou representante, o devedor poderá realizar a consignação (art. 335, III, do CC/2002).³²

O juiz deve nomear curador especial ao incapaz, em conformidade com o art. 72, I, do CPC/2015.³³ Note-se que a nomeação de curador especial tem como premissa a inexistência de assistente ou de representante para o incapaz. Se já houvesse assistência ou representação, poderia o devedor realizar o pagamento sem necessidade de consignar. O curador especial, contudo, não poderá levantar o bem depositado, pois essa atribuição recai sobre o curador ou tutor do incapaz.³⁴

Nos termos do art. 178, II, do CPC/2015, impõe-se, ainda, a participação do Ministério Público, sob pena de nulidade do processo.³⁵

O art. 335, III, do CC/2002 também autoriza o pagamento em consignação quando o credor for desconhecido. Além da hipótese mais comum, de morte do credor sem que o devedor saiba quem são seus sucessores, os títulos ao portador³⁶ e as ofertas ao público, como a promessa de recompensa e os concursos públicos, são exemplos de cabimento da demanda por desconhecimento do credor.³⁷ Saliente-se que os concursos a que se refere a doutrina são as conhecidas promoções por meio das quais se concede prêmios mediante vale-brinde, inexistindo inscrição prévia dos concorrentes.³⁸ Nesses casos, para liberar-se da obrigação, o estabelecimento que instituiu o concurso pode efetuar o pagamento em consignação.

A declaração de ausência do credor é outra hipótese a autorizar o pagamento em consignação (art. 335, III, do CC/2002). De acordo com o art. 22 do CC/2002, desaparecendo a pessoa de seu domicílio, sem deixar representante ou procurador para a administração dos bens, o juiz declarará a ausência e nomeará curador.³⁹ Como o devedor em regra não terá ciência dos poderes outorgados ao curador, faculta-se o pagamento em consignação.⁴⁰ Ademais, é possível que o devedor desconheça o curador ou os poderes que lhe foram outorgados, de modo que também nesse caso a consignação se revela como técnica adequada para a obtenção da liberação do devedor.⁴¹

O art. 335, III, do CC/2002 contempla ainda a hipótese de pagamento em consignação quando o credor residir em lugar incerto ou de acesso difícil ou perigoso. Qualquer que seja a hipótese de incidência (declaração de ausência, incerteza ou inacessibilidade da residência do credor), o pagamento em consignação só terá lugar se se tratar de dívida portátil, ou seja, de débito cuja prestação deve ser levada até o credor. Se a dívida for quesível, caberá ao credor buscá-la, de modo que a incerteza ou as dificuldades de acesso à sua residência serão irrelevantes. A consignação, tratando-se de dívida quesível, seria possível quando o credor se omitisse (art. 335, II, do CC/2002).⁴²

A doutrina adverte que deve ser concedida acepção mais ampla ao verbo “residir”, a fim de que ele signifique o local onde o credor se encontra. Interpretação mais restrita inviabilizaria a consignação quando o devedor conhecesse a residência do credor, mas não soubesse onde ele se

encontra no vencimento da obrigação.⁴³ Suponha-se que o credor esteja no exterior a negócios ou em ano sabático. O devedor conhece sua residência no Brasil, mas a ausência do credor impede a outorga de quitação. A interpretação restrita do verbo residir impediria o pagamento em consignação, pois o devedor sabe onde o credor reside. Mas a impossibilidade de depósito impediria que o devedor se liberasse da obrigação, embora a ele não restasse alternativa, ante a ausência do credor, além da consignação. Correta, portanto, a interpretação mais ampla do verbo residir.

A incerteza sobre a residência do credor se confunde com o desconhecimento a respeito do local onde ele reside. Nessa hipótese, o devedor sabe a quem deve, porém ignora onde resida. Sendo portátil a dívida, o desconhecimento sobre a residência do credor inviabiliza o pagamento. A fim de extinguir a obrigação, caberá ao devedor consignar a coisa devida.

O Código Civil utilizou cláusula aberta ao se valer da locução “acesso perigoso ou difícil”. Para a incidência do dispositivo (art. 335, III), não se há de exigir dificuldade excessiva, do mesmo modo como periculosidade ou dificuldade diminutas não legitimarão o pagamento em consignação.⁴⁴ Na prática será difícil separar a dificuldade da periculosidade. Ambas se misturam. Determinada situação poderá apresentar grau maior de perigo, ao passo que em outra ficaria mais nítida a dificuldade de acesso.

Haverá inacessibilidade quando a residência do credor se localizar em área atingida por fortes cheias, tornada inacessível em razão de deslocamentos de terra nas vias de acesso. É evidente que ao se dirigir para o local de pagamento o devedor estaria arriscando sua incolumidade, mas parece bastante claro que a situação encerra hipótese em que a inacessibilidade é superior ao perigo. Por outro lado, o pagamento em local no qual tenha sido diagnosticada certa epidemia caracteriza hipótese de submissão do devedor a situação de perigo. Conquanto haja dificuldade de acesso, pode-se afirmar que neste caso a nota caracterizadora da impossibilidade de adimplemento na forma regular é o perigo a que se submete o devedor. No cotidiano forense a distinção perde importância, pois as duas hipóteses autorizam o pagamento em consignação.

Registre-se que as hipóteses previstas no art. 335, III, devem ser posteriores à estipulação da relação obrigacional, ou desconhecidas do devedor à época da celebração. Estando ciente da periculosidade, inacessibilidade ou da incerteza da residência, o devedor terá assumido os riscos inerentes ao pagamento de dívida portátil, de modo que a extinção da obrigação não poderá ocorrer por meio da consignação.⁴⁵ Comprovada a ciência prévia do devedor quanto às dificuldades intrínsecas ao pagamento, impõe-se a improcedência da demanda consignatória.

1.4. Dúvida sobre quem deva receber o pagamento

No art. 335, IV, o Código Civil prevê o pagamento em consignação quando houver dúvida sobre quem deva receber o pagamento. O dispositivo compreende tanto a dúvida sobre a pessoa do credor, quanto a incerteza sobre os poderes, para outorgar quitação, daquele que se apresenta como tal.⁴⁶

A dúvida que autoriza o pagamento em consignação pode ser objetiva ou subjetiva. Será objetiva quando se apresentarem dois ou mais postulantes para o recebimento da prestação, portando documentos que não permitam concluir qual deles pode dar quitação, exonerando o devedor da obrigação. A dúvida será subjetiva quando se originar do próprio devedor, incapaz de determinar o credor legítimo.⁴⁷ Exige-se que a dúvida subjetiva apresente razoabilidade.⁴⁸ Caso a dúvida não seja razoável, mas originária de mero capricho do devedor, deverá ser julgada improcedente a demanda. A dúvida, seja objetiva, seja subjetiva, pode ocorrer tanto em dívidas quesíveis, quanto em dívidas portáteis. Será irrelevante, portanto, a natureza da dívida para o ajuizamento da demanda consignatória baseada na dúvida sobre o titular do pagamento.

Se ao longo da tramitação do processo ocorrer a identificação do credor, deve ocorrer o julgamento do mérito, sendo aberrante a decretação de carência de ação por falta de interesse processual. É suficiente a dúvida no momento da propositura da ação para que se concretize o interesse.⁴⁹

Ao devedor cabe ajuizar a demanda contra todos os supostos credores, caracterizando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário (art. 547 do CPC/2015). Proposta a demanda, se nenhum pretendente comparecer, o depósito será convertido em arrecadação de coisas vagas (art. 548, I, do CPC/2015). Comparecendo apenas um, decidirá de plano o juiz (art. 548, II, do CPC/2015). Se surgir mais de um postulante, será declarada extinta a obrigação, mas o juiz, observando o procedimento comum, decidirá, ainda, sobre o credor legitimado a receber o pagamento (art. 548, III, do CPC/2015).

1.5. Existência de litígio sobre o objeto do pagamento

No art. 335, V, o Código Civil dispõe sobre a possibilidade de consignação quando houver litígio sobre o objeto do pagamento. Nessa hipótese, litiga o credor com terceiro sobre o objeto da consignação. Se o devedor pagar a qualquer dos postulantes, ciente do litígio entre ambos, assumirá o risco do pagamento, conforme assenta o art. 344 do CC/2002.⁵⁰

Diferencia-se essa hipótese daquela versada no art. 335, IV, do CC/2002. Com efeito, na hipótese prevista no art. 335, V embora o devedor esteja certo sobre quem é o credor, a existência de litígio entre o credor e terceiro viabiliza o pagamento em consignação.⁵¹ Trata-se de circunstância objetiva, qual seja, a pendência de processo judicial no qual se litigue sobre o objeto do pagamento. Na hipótese de dúvida sobre quem deva receber o pagamento (art. 335, IV, do CC/2002), circunstâncias objetivas ou subjetivas deixam o devedor incerto sobre a titularidade do crédito. O devedor não sabe a quem deve pagar. Situação muito distinta daquela disciplinada no art. 335, V, em que o devedor conhece a quem deve pagar, mas consigna a prestação em razão da pendência de litígio sobre o crédito. Como se verá adiante, nos comentários ao art. 548, se o devedor indicar na demanda consignatória todos os participantes do outro processo, limitar-se-á a atividade jurisdicional à extinção da obrigação e à liberação do autor, inexistindo necessidade de se definir, na consignatória, sobre o titular do crédito, pois essa questão integra o objeto litigioso do primeiro processo.

Afirmava Adroaldo Furtado Fabrício, ao analisar a ação de consignação sob a disciplina do CPC/1973, que o art. 984 do Código Civil de 1916, reproduzido no art. 345 do Código Civil vigente,⁵² encerrava hipótese peculiar, na qual o devedor poderia ser obrigado a consignar em razão do requerimento de qualquer credor.⁵³ Para o jurista, tratava-se de ação condenatória, a ser ajuizada por qualquer um dos postulantes ao crédito.⁵⁴

Todavia, é mais correto conceber como mandamental a demanda ajuizada por um dos pretendentes ao crédito. Pretende-se que o devedor realize uma conduta, qual seja, a consignação da prestação. Trata-se de um fazer. Para obtê-lo, o juiz poderá se valer de meios de coerção, como a aplicação de multa. A sentença mandamental certamente é mecanismo mais adequado à obtenção do depósito da obrigação litigiosa que a condenação seguida por execução forçada. Não se vislumbra, na hipótese, ajuizamento de ação de cobrança, como defende Adroaldo Furtado Fabrício. O próprio litígio sobre o objeto da consignação impede que se veja a demanda de um dos pretensos credores como de cobrança. O que se pede não é o pagamento, mas a consignação da prestação vencida enquanto perdurar o litígio entre os diversos postulantes do crédito.

1.6. Inércia do credor na especificação do objeto da prestação

O art. 342 do CC/2002 prevê o cabimento da demanda consignatória nas obrigações alternativas ou de gênero, na hipótese em que, recaiando a especificação do objeto da prestação sobre o credor, deixar ele de escolher, inviabilizando o pagamento com sua omissão. Crê-se que a hipótese seja específica o suficiente para não se confundir com a recusa do credor em aceitar o pagamento ou em dar quitação (art. 335, I, do CC/2002).

No art. 543, o Código de Processo Civil prevê essa hipótese de consignação judicial, sendo o tema tratado mais minudentemente nos comentários a esse dispositivo.

1.7. Pagamento em consignação de obrigações tributárias

O Código Tributário Nacional assinala, no art. 156, VII, que o pagamento em consignação é forma extintiva da obrigação tributária.⁵⁵ Julgada procedente a demanda consignatória, considera-se realizado o pagamento, convertendo-se em renda a importância depositada (art. 164, § 2.º, primeira parte, do CTN). Decretada a improcedência da demanda, parcial ou integralmente, ao crédito cobrado serão acrescidos juros moratórios e cominadas as sanções cabíveis (art. 164, § 2.º, segunda parte, do CTN). A consignação se refere apenas ao crédito que o contribuinte se propõe a pagar (art. 164, § 1.º, do CTN).

As hipóteses de cabimento da consignação estão previstas no art. 164, I a III, do CTN.⁵⁶ O inc. I dispõe sobre a possibilidade de pagamento quando houver recusa da autoridade tributante em recebê-lo ou quando a aceitação do pagamento for condicionada ao adimplemento de outro tributo, penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. A demanda consignatória, nessa hipótese, é instrumento fundamental para evitar que o contribuinte seja prejudicado pelo fisco. Considerada a disparidade de forças, o contribuinte terminaria por ceder a arbitrariedades do órgão fazendário se não pudesse contar com meio adequado para se exonerar da obrigação tributária.

A finalidade do art. 164, II, é idêntica àquela que instrui o inc. I do mesmo dispositivo. Procura-se impedir que o contribuinte ceda ao arbítrio do fisco, possibilitando-lhe consignar o débito em juízo quando o recebimento do tributo for condicionado ao atendimento de exigências administrativas ilegítimas.

No art. 164, III, o Código Tributário Nacional prevê o cabimento da demanda consignatória quando mais de uma pessoa jurídica de direito público postular tributo idêntico, fundamentando-se sobre o mesmo fato gerador.⁵⁷ Trata-se de hipótese de pluralidade de pretendentes ao crédito, tal como a disciplinada no art. 335, IV, do CC/2002. Contudo, contrariamente ao que ocorre na hipótese disciplinada na lei civil, não se admite a dúvida *subjéctiva* do contribuinte como fundamento para a consignação.⁵⁸

A jurisprudência erigida sob o CPC/1973 repeliu o emprego da demanda consignatória como sucedâneo ao parcelamento do débito fiscal.⁵⁹ De acordo com esse entendimento, a consignação não pode substituir a lei instituidora do parcelamento. Todavia, tendo sido deferido o parcelamento de acordo com a lei adequada, a eventual recusa do fisco em receber as prestações ensejará a propositura de demanda consignatória com fulcro no art. 541 do CPC/2015. O que a jurisprudência proibiu, reiterar-se, foi o emprego da consignação em pagamento como substituto das leis de parcelamento de débito fiscal. Existente lei e deferido o parcelamento, eventual recusa do ente tributante propicia o ajuizamento da consignatória.

1.8. Consignação de aluguéis

No art. 67, da Lei 8.245/1991, é previsto procedimento para a consignação de aluguéis e demais encargos locatícios. Não é excessivo salientar que o dispositivo se aplica somente às locações de imóveis urbanos, processando-se as outras hipóteses de demanda consignatória em conformidade com o procedimento descrito no Código de Processo Civil.

Impõe-se especificar a incidência do artigo da Lei de Locações de Imóveis e do procedimento nele previsto: quando a pretensão do locatário consistir na consignação de aluguéis e outros encargos, a demanda atenderá ao disposto no art. 67 e seus incisos. Contudo, tratando-se de consignação do imóvel dado em locação ou das chaves, deve-se adotar o procedimento disciplinado no Código de Processo Civil. O mesmo ocorre quando o locatário estiver em dúvida a respeito do credor dos aluguéis.⁶⁰ Com efeito, como a Lei de Locações não disciplina a formação de litisconsórcio passivo, nem as consequências que decorrem do comparecimento dos réus, aplicam-se à espécie os arts. 547 e 548 do CPC/2015.

Na Lei 8.245/1991, art. 24, é prevista outra hipótese de depósito judicial. Tratando-se de habitação coletiva multifamiliar, poderão os locatários ou sublocatários depositar judicialmente o valor dos aluguéis quando o Poder Público considerar a construção precária.⁶¹ O objetivo é coagir o locador a regularizar o imóvel, mediante indisponibilização das prestações locatícias. Enquanto

não ocuparem o imóvel, os locatários ou sublocatários estarão isentos dos aluguéis (Lei de Locações, art. 24, § 2.º). O levantamento do montante depositado ocorrerá apenas depois da comunicação, pela autoridade pública, sobre a regularização do imóvel (Lei de Locações, art. 24, § 1.º). Os depósitos também poderão ser levantados, mediante autorização judicial, para a realização de obras necessárias à regularização (Lei de Locações, art. 24, § 3.º). Conquanto o dispositivo se refira somente às “obras e serviços”, poderão os valores depositados se destinarem ao pagamento de despesas, perante o Poder Público, para a regularização do imóvel.

O art. 24 da Lei 8.245/1991 compreende modalidade de depósito judicial. Não consiste, contudo, em modalidade de ação de consignação, pois o objetivo não é a extinção da obrigação com a liberação do devedor. Trata-se, isso sim, de meio de coação do locador desidioso, que tenha descumprido com seus deveres de conservação do bem. A demanda em questão será processada em conformidade com o procedimento comum.⁶²

A consignação de aluguéis apresenta algumas diferenças fundamentais em relação à demanda consignatória genérica, prevista no Código de Processo Civil. Nos termos do art. 67, II, o prazo para depósito é de 24 (vinte e quatro horas) a contar da intimação.⁶³ Na consignatória genérica, o prazo para depósito é de 5 (cinco) dias (art. 542, I, do CPC/2015). Em ambos os casos, a omissão do devedor acarreta a extinção do processo.

Prevê-se expressamente, no art. 67, III,⁶⁴ a limitação dos depósitos à prolatação da sentença, ao passo que a omissão do legislador sobre o tema, nas demandas consignatórias genéricas, leva ao dissídio jurisprudencial, como se verá nos comentários ao art. 541. Ademais, o art. 67, III, determina que o depósito das parcelas ocorra no vencimento, ao passo que o art. 541 do CPC/2015 concede ao devedor o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o depósito das prestações vincendas.

No art. 67, IV, em disposição semelhante à do art. 897 do CPC/1973, prevê-se que a revelia levará à procedência da demanda, com a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor do depósito, além das custas.⁶⁵ No Código de Processo Civil inexistia disposição análoga, reconhecendo-se que a revelia é incapaz, por si só, de acarretar a procedência da demanda. Ademais, a Lei de Locações prevê expressamente o cabimento de reconvenção no art. 67, VI. No Código de Processo Civil, essa modalidade de resposta não é prevista especificamente para a demanda consignatória, embora decorra das linhas gerais do sistema.⁶⁶

Outra diferença reside no prazo deferido ao autor para complementar o depósito. O Código de Processo Civil prevê 10 (dez) dias, ao passo que a Lei de Locações, no art. 67, VII, concede apenas 5 (cinco), determinando, ainda, que haja acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença, sendo o autor condenado ao pagamento das custas e de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor dos depósitos.⁶⁷

A análise detalhada da demanda consignatória de aluguéis supera os limites deste trabalho, cujo foco é a demanda genérica, disciplinada nos arts. 539 a 549 do CPC/2015. Por esse motivo, nestes comentários foi feita análise sumária, restrita às mais evidentes diferenças entre a demanda consignatória especial, prevista para o depósito de aluguéis e encargos, e a geral, regulada no Código de Processo Civil.

1.9. Consignação e débito de origem cambiária

No art. 42, a Lei Uniforme de Genebra assinala que a não apresentação do título no dia do pagamento ou em um dos dois dias úteis seguintes (LUG, art. 38), autoriza o depósito do valor perante a autoridade competente, sob a responsabilidade e às custas do portador.⁶⁸ Esse depósito ocorrerá no âmbito da demanda de consignação.⁶⁹ Caracterizando-se alguma das hipóteses previstas no Código Civil, o pagamento em consignação poderá ser realizado, não sendo obstáculo a origem cambiária do crédito.⁷⁰

2. Legitimidade ativa e passiva

No CPC/2015 não há menção à possibilidade jurídica do pedido. Com efeito, os arts. 17,⁷¹ 330, II e III,⁷² 337, XI,⁷³ e 485, VI,⁷⁴ restringem-se a indicar o interesse processual e a legitimidade. Diante da omissão do texto, é lícito concluir que a possibilidade jurídica perdeu sua autonomia no direito positivo. O código vigente também não faz referência expressa à categoria “condições da ação”, razão pela qual o interesse e a legitimidade devem ser considerados como pressupostos processuais.

Se da narrativa realizada na petição inicial resultar a falta de interesse ou de legitimidade, o juízo deverá determinar a correção do equívoco, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 330, II e III). A ilegitimidade pode ser alegada na resposta, ocasionando a substituição do réu ou a inserção do terceiro, por ele indicado como legitimado passivo, na condição de litisconsorte (CPC, art. 339, §§ 1º e 2º).

Há hipóteses em que a falta de legitimidade ou de interesse será averiguada no curso do processo. Serão raras, contudo, as ocasiões em que se proferirá autêntica sentença terminativa após a instrução. Nesses casos, o princípio da primazia do mérito (CPC, arts. 4º e 488) determina que o objeto litigioso seja apreciado, a fim de evitar novo acesso ao Judiciário.

São frequentes os casos em que o mérito é analisado, mas são proferidas, incorretamente, decisões terminativas. É o que ocorre quando se extingue o processo, por ilegitimidade passiva *ad causam*, na sentença, ao argumento de que o devedor é terceiro, não o réu. Ora, se o réu nada deve ao autor, então este tem pretensão contra o demandado, razão pela qual tal provimento encerra hipótese de improcedência. Por outro lado, em se tratando de legitimidade extraordinária exclusiva, se a demanda for proposta por um dos titulares do direito, não pelo legitimado extraordinário (substituto processual), o mérito não deve ser apreciado. É o que ocorrerá se um dos debenturistas propuser demanda no lugar do agente fiduciário, legitimado extraordinário exclusivo à luz do art. 68, § 3º, da Lei 6.404/76.

O mesmo vale para o interesse processual. Situações há, nas quais existe pretensão, mas óbice meramente processual impede sua propositura. É o que ocorre com o pedido de revisão de cláusulas contratuais no âmbito das ações de exigir contas. O autor realmente espoca a pretensão revisional, mas não poderá exercê-la na referida demanda. Por outro lado, a dívida de jogo ou o débito não vencido, hipóteses tradicionalmente identificadas como carentes de interesse, encerram julgamento de mérito. Em relação à dívida de jogo, o art. 814 proíbe sua cobrança, de modo que não há pretensão. Do mesmo modo, se a dívida não tiver vencido, o autor não tem pretensão naquele momento. Superveniente inadimplemento autoriza a procedência da demanda. Essa breve introdução tem o objetivo de demonstrar que as decisões terminativas autênticas são bem menos frequentes do que se imagina.

O Código Civil, no art. 304, assenta que qualquer interessado poderá pagar a dívida, valendo-se dos meios conducentes à liberação do devedor, caso o credor se oponha. No parágrafo único do dispositivo, concede-se o direito de pagamento também ao terceiro não interessado, desde que o faça em nome e à conta do devedor, a não ser que este se oponha.⁷⁵ Este preceito é fundamental para a compreensão do tratamento distinto concedido aos terceiros, assim como para a definição da legitimidade ativa *ad causam*.

Os terceiros interessados poderão adimplir, sendo-lhes concedido o direito de se valer da demanda consignatória se o credor se recusar a receber.⁷⁶ Havendo interesse jurídico, a resistência do credor caracteriza *mora accipiendi*.⁷⁷ Ao realizarem o pagamento, fazem-no os interessados sem necessitar da anuência do credor ou do devedor, o que decorre de sua responsabilidade conjunta pelo débito ou da possibilidade de exercerem direitos em desfavor do devedor beneficiado com o adimplemento.⁷⁸

O terceiro não interessado poderá cumprir a prestação em nome e à conta do devedor, desde que este não se oponha (art. 304, parágrafo único, do CC/2002). Trata-se de inovação do diploma civil vigente em relação ao art. 931, parágrafo único, do Código Beviláqua, no qual não havia

ressalva sobre a oposição do devedor. Por esse motivo, autorizada voz da doutrina, à luz do CC/1916, defendeu a possibilidade de pagamento por terceiro não interessado, em nome e à conta do devedor, ainda que este se manifestasse contrariamente ao adimplemento.⁷⁹

Sob o direito vigente, pode-se afirmar que o terceiro não interessado terá legitimidade para o ajuizamento de demanda consignatória somente se realizar o pagamento em nome e à conta do devedor e este não manifestar qualquer insurgência.⁸⁰ Havendo oposição, não poderá ocorrer o pagamento, conforme assenta o art. 304, parágrafo único, do CC/2002. Nesse caso, o terceiro não terá legitimidade para a propositura de ação consignatória. Se a propuser, haverá extinção mediante sentença terminativa.

A propósito, a legitimidade do terceiro não interessado que realizasse pagamento em nome e por conta do devedor era entendimento adotado pela maioria da doutrina erigida sob o CC/1916 e o CPC/1973. Como o art. 931 do Código Beviláqua não aludia à possibilidade de emprego de meios liberatórios pelo terceiro não interessado que pagasse em seu próprio nome, inviabilizava-se a pretensão consignatória deste. Apenas o terceiro não interessado que pagasse em nome e por conta do devedor poderia propor ação de consignação.⁸¹ O preceito contido no art. 931 do CC/1916 foi reproduzido no art. 305 do CC/2002 vigente, de modo que o posicionamento adotado sob aquele diploma civil deve ser mantido à luz do atual. Nada no Código de Processo Civil autoriza modificar essa conclusão.

Afirmou-se, até o momento, que o terceiro interessado poderá ajuizar ação consignatória. Aduziu-se que o juridicamente desinteressado não poderá fazê-lo, a não ser que tenha realizado o pagamento em nome e à conta do devedor. Resta, ainda, definir a natureza dessa legitimidade. Seria ordinária ou extraordinária? Em outras palavras, impõe-se verificar se o terceiro juridicamente desinteressado seria substituto processual – legitimado extraordinário – do devedor.

Como se sabe, a legitimidade ordinária é atribuída, no plano processual, aos partícipes do litígio que se desenvolve no plano material (art. 17 do CPC/2015). A não ser que o ordenamento jurídico autorize, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015).⁸² Quando isso ocorrer, ou seja, se terceiro pleitear direito alheio em nome próprio, caracteriza-se a legitimidade extraordinária, também denominada substituição processual. A legitimidade extraordinária não pode ser convencionada (art. 18 do CPC/2015). O legitimado extraordinário é parte no processo, não mero representante do substituído.⁸³

Consideradas as características da legitimação extraordinária, pode-se afirmar que o terceiro não interessado que realize pagamento em nome e à conta do devedor será substituto processual deste. Esse posicionamento era sufragado pela doutrina erigida sob a vigência do Código Civil de 1916 e do Código de Processo Civil revogado, sendo também corretamente defendido à luz do código vigente.⁸⁴

Em síntese, os terceiros interessados sempre terão legitimidade para propor a ação consignatória e o farão em nome próprio.⁸⁵ Em relação aos não interessados, se o devedor não se opuser, poderão propor demanda de consignação, na qualidade de legitimados extraordinários. Os terceiros não interessados que tenham realizado pagamento em nome próprio não têm legitimidade, sequer extraordinária, para a propositura da demanda. Ocorre que o art. 305 do CC/2002, que disciplina o pagamento feito por terceiro desinteressado em nome próprio, não possui disposição semelhante ao art. 304 do mesmo código, no qual é expressamente prevista a possibilidade de emprego dos “meios conducentes à exoneração do devedor”.

Desse modo, se o autor da demanda afirmar na inicial sua condição de terceiro desinteressado, bem como a realização de pagamento em nome próprio, deve ocorrer extinção do processo sem resolução do mérito. Trata-se de hipótese na qual o demandante não terá como corrigir a inconsistência que atinge a demanda, pois o pagamento em nome próprio, na condição de terceiro não interessado, não lhe dá legitimidade. Ainda assim, antes de indeferir a inicial, deve o juiz ouvir o autor, a fim de que sejam prestados esclarecimentos. Por outro lado, se a condição de terceiro desinteressado, que realizou pagamento em nome próprio, for apreciada após o recebimento da resposta, ocorrendo exame do tema à luz das provas, constatar-se-á a inexistência

de pretensão, o que leva à improcedência.

O CPC prestigia o julgamento com resolução de mérito, conforme decorre dos arts. 4º e 488. Após a resposta, analisando os documentos trazidos pelas partes, o juízo poderá decidir o mérito, afirmando que o autor, terceiro desinteressado que realizara o pagamento em nome próprio, não tem a pretensão consignatória. Percebe-se que não ocorre na hipótese nada diferente daquilo que ordinariamente acontece em relação à legitimidade ativa. Desde que verificada a inconsistência narrativa na própria inicial, pode o juízo indeferi-la. Prosseguindo o feito, viabiliza-se, no mais das vezes, julgamento com apreciação do *meritum causae*.

A legitimidade passiva, por sua vez, recai sobre o credor. Saliente-se que se o credor não for conhecido, ou o lugar em que se encontrar for ignorado, incerto ou inacessível, a citação terá de ser realizada por edital (art. 246, IV, c/c art. 256, I e II, do CPC/2015).⁸⁶ Havendo dúvida sobre a legitimidade de quem deve receber o crédito (art. 335, IV, do CC/2002), deverá o autor arrolar no polo passivo da demanda todos os possíveis credores, caracterizando-se litisconsórcio passivo necessário. Se afirmar na inicial que o credor não é o réu, mas terceiro, a ilegitimidade passiva *ad causam* levará ao indeferimento da inicial, após a oitiva do autor, na forma do art. 330, inc. II, do CPC. Se essa circunstância for desvendada com base nas provas, após a instrução, a primazia do julgamento de mérito determina que o juízo profira sentença extintiva, examinando o *meritum causae* (CPC, arts. 4º e 488). Reitere-se que a resposta pode ensejar a correção da ilegitimidade passiva, seja por meio da substituição do réu, seja pela inclusão do terceiro, indicado pelo demandado na resposta, como litisconsorte passivo (CPC, art. 339, §§1º e 2º, do CPC).

3. Interesse processual

O interesse processual do demandante, ao promover a demanda consignatória, é extinguir a obrigação, evitando que lhe sejam imputadas as consequências do inadimplemento. Note-se que se não trata, aqui, do interesse na realização de pagamento, o qual pode ser titularizado inclusive por terceiros não interessados. O interesse a que se alude é, naturalmente, condição da demanda consignatória.

Se o autor promover demanda consignatória antes do vencimento, deve ser decretada a improcedência, pois ele ainda não tem pretensão, embora ela possa surgir caso haja superveniente recusa do credor em receber a prestação após o vencimento. Trata-se de hipótese análoga àquela em que o credor cobra dívida ainda não vencida. Se não há vencimento, inexistente pretensão. Afirmei, na primeira edição destes comentários, que a propositura de consignação antes do vencimento caracterizaria falta de interesse.⁸⁷ Todavia, antes do vencimento não há a própria pretensão. Se a não ocorrência do vencimento for verificada pela leitura da inicial, após a oitiva do demandante o juízo a indeferirá (CPC, art. 330, inc. III). Se o tema vier à tona após a resposta, a primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º e 488) autorizará a emissão de sentença extintiva, com exame do objeto litigioso. Nesse caso, como se vê, há julgamento de mérito.

Saliente-se que além do vencimento, para a procedência da demanda consignatória devem se materializar os elementos constituintes da hipótese específica de pagamento em consignação. Se a ausência desses componentes for verificada à luz da inicial, haverá sentença terminativa após a oitiva do autor (CPC, art. 330, inc. III). Se a constatação da falta de um requisito ocorrer no curso do processo, há de se proferir sentença extintiva, em atenção à primazia do mérito (CPC, art. 4º e 488).

A demanda ajuizada com fundamento na recusa do credor (art. 335, I, do CC/2002) deverá ser promovida depois do vencimento e da negativa de aceitação do pagamento ou de concessão da quitação. Tratando-se de dívida quesível (art. 335, II, do CC/2002), o interesse processual será configurado quando ao vencimento se agregar a inércia do credor.

Se o motivo para a consignação for a incapacidade ou a declaração de ausência (art. 335, III, do CC/2002), o interesse processual se concretizará, respectivamente, com a caracterização da incapacidade do credor e com a decretação judicial de ausência. É possível, na hipótese de

incapacidade, que o credor não tenha sido judicialmente declarado incapaz. Caberá ao autor indicar ao juiz os elementos que formam sua convicção sobre a incapacidade. Ao contrário do que ocorre na hipótese de ausência, em que é necessário provimento jurisdicional prévio, o interesse processual na consignação judicial por incapacidade se concretiza mesmo que inexistir decisão sobre o tema.

Quando o fundamento da consignatória for o desconhecimento do credor (art. 335, III, do CC/2002), é requisito para a configuração do interesse processual a ocorrência do fato que leva à insciência sobre o titular da prestação. Assim, se a causa da consignatória for a morte do credor, evidentemente é este fato que caracterizará o interesse processual na consignação. Cuidando-se de título ao portador, que tem na circulação uma de suas características, a transmissão consolidará o interesse processual. Com efeito, a partir da circulação o devedor não mais terá ciência sobre o titular da obrigação, nascendo o interesse na propositura da consignatória. Nas hipóteses de concurso público⁸⁸ ou promessa de recompensa, o interesse surgirá quando for realizado o sorteio ou praticado o ato ensejador da retribuição.

Quanto às hipóteses de residência em lugar incerto ou de difícil acesso (art. 335, III, do CC/2002), a caracterização do interesse processual ocorrerá assim que se consubstanciar, a par do vencimento da obrigação, o fato delineador da incerteza ou da dificuldade. Como indicado no item 1.3, o verbo “residir” deve ser interpretado de modo amplo, a fim de abranger as situações em que o devedor, conquanto conheça a residência do credor, não saiba onde ele se encontra no momento do vencimento.

Em relação à dificuldade de acesso, é bastante claro que o interesse do devedor em consignar nascerá quando surgir o fato a dificultar a entrega da prestação, trate-se de uma cheia, um deslizamento de terra ou uma epidemia. Se a dificuldade era conhecida pelo devedor à época em que contraiu a obrigação, inexistirá interesse na consignação, ressalvada a hipótese de agravamento da condição prévia.

Se o motivo ensejador da propositura da consignatória for a dúvida do obrigado sobre o titular da prestação (art. 335, IV, do CC/2002), o interesse se concretizará, tratando-se de dúvida objetiva, a partir do momento em que mais de um pretendente avocar para si a condição de credor. Se houver dúvida subjetiva, virá a lume o interesse no momento em que se consolidar no devedor a imprecisão sobre o titular do crédito.

Por fim, tratando-se de consignação fundada na pendência de litígio sobre o objeto do pagamento (art. 335, V, do CC/2002), consolidar-se-á o interesse com a propositura de demanda por terceiro, reivindicando para si a prestação, contra o credor. É certo que a citação válida concretiza a litispendência, conforme assenta o art. 240, *caput*, do CPC/2015.⁸⁹ Todavia, não se crê que para o ajuizamento da demanda consignatória seja imprescindível a citação do credor na demanda que terceiro promove reivindicando o objeto da prestação. Percebe-se facilmente que a mera propositura da demanda, ainda que a citação não tenha se perfectibilizado, trará riscos ao pagamento. Já no ajuizamento da demanda por terceiro, passa a existir interesse na consignação judicial ante o risco de pagamento incorreto, conforme estabelece o art. 344 do Código Civil. Assim, basta a propositura de ação por terceiro na qual se postule o objeto da obrigação, para que surja o interesse do devedor na consignatória.

É certo que a mora do devedor, qualquer que seja a hipótese versada, não lhe retira o interesse em consignar. Como afirmado no item 1.1 dos comentários ao art. 539 do CPC/2015, apenas quando o pagamento já não trouxer utilidade ao credor, nos termos do art. 395, parágrafo único, do CC/2002, haverá motivo para a justa recusa. Desde que a oferta da prestação seja possível, haverá interesse processual na consignação. Pode-se afirmar que a mora do devedor jamais conduzirá à carência da demanda. Sendo justa a recusa, haverá julgamento do mérito, com decretação de improcedência.

Em todas essas hipóteses, se a constatação da falta de um dos elementos ensejadores da consignação for percebida com fundamento na própria inicial, ocorrerá extinção sem resolução de mérito, mediante sentença terminativa de indeferimento, após a oitiva do demandante (CPC, art.

330, inc. III). Se a verificação da ausência de um dos requisitos ocorrer após a resposta, o princípio da primazia do mérito (CPC, arts. 4º e 488) leva à prolação de decisão extintiva, na qual o *meritum causae* é examinado, chegando-se à conclusão de que o autor não tem a pretensão de consignar.

É preciso atentar para a peculiaridade da ação consignatória e seu processamento em conformidade com procedimento especial. Assim, mesmo que a inicial apresente de forma consistente a legitimidade e o interesse, ocorrerá prolação de sentença terminativa, sem exame do mérito, se o autor não realizar o depósito no prazo de cinco dias, em razão de perda superveniente de interesse processual (CPC, art. 542, inc. I, par. ún.). É nítido, nesse caso, que o autor detém pretensão, mas obstáculo estritamente processual – falta de depósito no prazo assinalado em lei – inviabiliza o prosseguimento do feito.

4. O problema dos contratos bilaterais

Nos contratos bilaterais, também denominados sinalagmáticos, os contratantes devem realizar determinada prestação, ao mesmo tempo em que são credores de outra. Cada contraente é simultaneamente credor e devedor. O art. 476 do CC/2002 prescreve que nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da prestação até que cumpra sua própria obrigação.⁹⁰

Sob o código processual revogado a possibilidade de consignação no âmbito de contratos bilaterais gerou intenso debate na doutrina. Defendeu-se a possibilidade de pagamento em consignação suspensivamente condicionado, de modo que o credor só poderia levantar a coisa depositada depois de cumprir a obrigação que assumira.⁹¹ Argumentou-se que o processo não poderia tolher a iniciativa do devedor de evitar o risco do inadimplemento, sendo esta, precisamente, a finalidade da demanda consignatória.⁹²

Por outro lado, sustentou-se que na demanda consignatória não é possível pleitear a liberação condicional, restringindo-se o devedor a depositar a prestação devida e pleitear a liberação.⁹³ Não seria possível a propositura de demanda consignatória submetida a condição, nem, tampouco, a prolação de sentença condicionada.⁹⁴

Crê-se que esteja correta a posição restritiva. Depósito liberatório condicionado seria uma contradição em termos. Ao depositar, o contratante pretende liberar-se da obrigação, não lhe sendo possível condicionar o depósito ao adimplemento da outra parte. Além de não ser possível o depósito liberatório condicionado, não é admissível que o juiz profira sentença condicionada, autorizando a liberação na hipótese de cumprimento da prestação pelo credor.⁹⁵ A liberação, objeto da demanda consignatória, não se coaduna com a condição suspensiva que se implementaria na hipótese de depósito condicionado.

Certamente poderá um dos contratantes pagar em consignação. Mas, ao fazê-lo, está cumprindo a prestação, liberando-se da relação obrigacional. O que não lhe é permitido é condicionar a liberação da quantia depositada ao cumprimento da prestação pela contraparte. Ao depositar, exonera-se, não podendo estabelecer condição suspensiva. Destarte, nos contratos bilaterais, embora seja possível a um dos contratantes depositar sua prestação, não lhe será lícito condicionar o levantamento ao adimplemento do outro contraente. A finalidade para a qual foi projetada a ação de consignação inadmitte que seja proposta demanda com pedido condicional, do mesmo modo que o sistema repele a prolação de sentenças condicionais.

5. Eficácia da sentença

Segundo o art. 337 do CC/2002, com o depósito ocorre a exoneração do devedor em relação aos riscos e aos juros da dívida,⁹⁶ acrescentando a doutrina, corretamente, que o depositante também se libera das despesas e da correção monetária.⁹⁷ A ressalva contida ao final do dispositivo deixa claro que com a improcedência da demanda não terão cessado os riscos, a correção monetária, os juros e as despesas. O depósito terá sido ineficaz, pois a improcedência da demanda decorre da

inidoneidade da pretensão ao pagamento em consignação.

A sentença de procedência da demanda de consignação em regra terá eficácia declaratória.⁹⁸ Pretende-se, com o ajuizamento, que seja reconhecido como eficaz o depósito liberatório. É ele que faz cessar os riscos inerentes à prestação e que extingue a obrigação, desde que tenha sido realizado regularmente, conforme assenta o art. 336 do CC/2002.⁹⁹ À medida que a sentença declara a eficácia extintiva do depósito, não é correto visualizá-la como um provimento constitutivo negativo. A desconstituição da obrigação, reitere-se, decorre do depósito.¹⁰⁰

Em síntese, ao julgar procedente a ação de consignação, profere o juiz provimento declaratório, no qual reconhece a eficácia do depósito regularmente realizado. Na hipótese de improcedência da demanda, emite-se sentença declaratória negativa, a assentar a irregularidade do depósito. Em consequência, não terão cessado os riscos intrínsecos à obrigação, nem a correção monetária e os juros.

Todavia, a sentença proferida na ação de consignação pode apresentar eficácia condenatória. Isso ocorrerá quando o juiz reconhecer a insuficiência do depósito, hipótese em que lhe caberá determinar o valor devido sempre que possível, constituindo a sentença título executivo, na forma do art. 545, § 2.º do CPC/2015. Mais que declarar, a sentença condenará o autor ao pagamento do montante devido.¹⁰¹ O tema será retomado adiante, quando dos comentários ao dispositivo citado.

6. Desnecessidade de liquidez e certeza da dívida

Sob a vigência do código revogado era comum a menção à existência de obrigações líquidas e certas como requisito para o pagamento em consignação.¹⁰² Contudo, o que incumbe ao autor alegar é que há dívida e que ela perfaz determinado montante.¹⁰³ Seria impossível conciliar a liquidez e certeza do débito com a possibilidade de complementação do depósito, prevista no art. 545, *caput*, do CPC/2015.¹⁰⁴ Tampouco poderia o réu alegar a insuficiência do depósito (art. 544, IV, do CPC/2015), se o valor depositado tivesse de ser líquido e certo.

A oblação poderá ocorrer em *quantum* inferior ao devido, ocasião na qual o réu alegará a insuficiência do depósito e indicará a quantia correta. Nesse caso, acolhida a alegação do réu, a sentença será título executivo em relação ao *quantum* faltante (art. 545, § 2.º, do CPC/2015). Fica clara, portanto, a desnecessidade de que a dívida seja líquida e certa. É a oferta que deverá ser certa quanto ao objeto e determinada em relação à quantidade.¹⁰⁵

7. Amplitude da cognição

Para a análise mais adequada da amplitude cognitiva desenvolvida no âmbito da ação consignatória, há de se considerar os planos vertical e horizontal. No plano horizontal, a cognição pode ser plena ou parcial. No vertical, será sumária ou exauriente.¹⁰⁶

Quando se menciona que em determinado procedimento a cognição é parcial, faz-se alusão à restrição de matérias que podem ser apreciadas pelo juiz. O exemplo comum são as ações possessórias, nas quais não é admitida a discussão sobre o domínio.¹⁰⁷ Por outro lado, na cognição ampla, admite-se alegação de toda e qualquer matéria de defesa, não ficando qualquer tema reservado para apreciação em outra demanda.

No que se refere ao plano vertical, tem-se que a convicção do juiz não é critério seguro para a distinção entre a cognição sumária e a exauriente. É concebível que ao sentenciar o juiz tenha de fazê-lo com fundamento na regra de ônus da prova, o que demonstra que a instrução não foi suficiente para o convencimento. O procedimento é o critério mais adequado para separar a cognição sumária da exauriente. Quando for possível ampla instrução e debate, a cognição é exauriente.¹⁰⁸ Em outras palavras, a condição psicológica do juiz ao sentenciar não é suficiente para indicar o grau de cognição.

Os provimentos concedidos no âmbito da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015) se baseiam

em cognição sumária. É certo que o juiz poderá ampliar a instrução para formar seu convencimento, de modo que alguém poderia supor que a decisão seria exauriente, à medida que o juiz pode aprofundar a instrução, embora não o faça, à semelhança do que ocorre no julgamento antecipado baseado na revelia. Ocorre que após amplo debate e produção de provas a decisão proferida terá como fundamento cognição exauriente. Ao decidir, levando em conta a urgência, o juiz profere decisão amparada em cognição sumária. Trata-se de juízo de verossimilhança.¹⁰⁹

Não há dúvida de que a sentença proferida na demanda consignatória se baseia em cognição exauriente, apta a formar coisa julgada material. Contudo, em relação ao plano horizontal, encontra-se aceso debate na doutrina erigida sob o CPC/1973. Discutiu-se se a cognição na consignatória seria plena ou parcial. Em outras palavras, debateu-se sobre a possibilidade de discussão sobre o crédito quando o réu alegasse justa recusa ou insuficiência do depósito (art. 544, II e IV, do CPC/2015; art. 896, II e IV, do CPC/1973).

Defendeu-se a sumariiedade da demanda de consignação, na qual seria possível debater somente sobre a pretensão liberatória. Salientou-se, nessa linha, que se na ação de consignação fosse possível discutir sobre a validade do negócio jurídico e sobre o *quantum debeatur*, tais questões seriam efetivamente decididas, não apenas conhecidas pelo magistrado.¹¹⁰ Afirmou-se, levando em conta as limitações à matéria de defesa (art. 896, I a IV, do CPC/1973; art. 544, I a IV, do CPC/2015), que a sentença seria prolatada “sob reserva”, podendo o réu discutir em outra demanda as pretensões que transcendessem os limites da ação de consignação.¹¹¹

Sustentou-se, por outro lado, que a impertinência de discussões estranhas à liberação não impossibilitaria a discussão sobre a origem e natureza do débito, que seria imprescindível para que se pudesse averiguar a justiça do pedido de consignação.¹¹² Em outras palavras, a restrição do mérito à liberação do devedor não inviabilizaria a discussão sobre o crédito e o negócio jurídico que lhe é subjacente. O pronunciamento sobre essas questões seria necessário para que pudesse haver decisão sobre a justa recusa ou a insuficiência do depósito. Ocorre que essas questões – *quantum debeatur* e validade do negócio jurídico, por exemplo – seriam “razões de decidir”, de modo que não fariam coisa julgada nos termos do art. 469, I a III, do CPC/1973.¹¹³

É dado incontroverso que a liberação do devedor por meio do depósito constitui o mérito do processo. A declaração judicial sobre sua aptidão para substituir o pagamento e extinguir a obrigação é o que se persegue judicialmente. Mas o “objeto do processo”, como sabido, não se confunde com o “objeto litigioso do processo”.¹¹⁴ Nesta locução estão compreendidas todas as matérias submetidas à apreciação do juiz. Naquela, faz-se referência somente ao mérito, delimitado pelo pedido. Como o objeto do processo é a liberação do devedor, são pertinentes discussões sobre a validade do negócio jurídico do qual se origina a obrigação ou a discussão sobre o *quantum debeatur*. Essa questão, a propósito, será bastante comum e sua análise é imprescindível para que o juiz possa apreciar o mérito do processo. Ciente disso, a jurisprudência firmada sob o Código de Processo Civil de 1973 era pacífica sobre a possibilidade de exame do débito no âmbito da ação consignatória.¹¹⁵

Sob o Código de Processo Civil de 1973 podia-se afirmar que a apreciação de questões prejudiciais não ficava coberta pela coisa julgada material, por expressa determinação do art. 469, III. Não é o que ocorre no código vigente, cujo art. 503 admite a formação de coisa julgada de questão prejudicial incidentalmente decidida, desde que sobre ela tenha havido contraditório, o juiz seja competente e inexistam restrições probatórias ou limitações à cognição.¹¹⁶

Para que a coisa julgada atinja questão prejudicial decidida no âmbito da ação consignatória, não podem existir barreiras à cognição do juiz. Conquanto o art. 544 do CPC/2015 procure limitar a amplitude da defesa, a cognição não será parcial, mas plenária. Para investigar se houve justa recusa (art. 544, II, do CPC/2015), o juiz em regra terá de analisar a validade do negócio jurídico. Ademais, sempre que for discutida a suficiência do depósito, o valor do crédito terá de ser averiguado. Poderão as partes apresentar quaisquer alegações referentes a esses temas, de modo que a cognição não será parcial.

A sentença proferida na demanda consignatória não o é “sob reserva”. Todas as alegações

concernentes à suficiência do depósito e à validade do negócio jurídico poderão ser examinadas no processo. É algo muito diferente do que ocorre nas ações possessórias, em que é vedado discutir sobre a propriedade. Nas ações consignatórias poderão ser invocadas quaisquer razões conducentes à justa recusa. Claro que estarão afastadas questões que não digam respeito à correção do depósito. Mas toda e qualquer questão que a ele se refira poderá ser apreciada. O conflito de interesses sobre o pagamento é inteiramente resolvido na ação consignatória, nada remanescendo para ser julgado em outra demanda, razão pela qual a cognição não é parcial, mas plena ou total.

Destarte, pode-se afirmar que no código vigente a questão prejudicial submetida à apreciação jurisdicional fará coisa julgada. O art. 503 ampliou os limites objetivos da coisa julgada, de modo que a questão prejudicial decidida em contraditório, por juiz competente, ficará coberta pela coisa julgada. Afastada a alegação de invalidade do negócio jurídico – cujo acolhimento levaria à justa recusa da oferta – não poderá ser discutida em outro processo, pois atingida pela coisa julgada material.

Poder-se-ia refutar essa conclusão ao argumento de que no art. 545, § 2.º, o CPC/2015 estabelece que ao decretar a insuficiência do depósito a sentença determinará, “sempre que possível”, o *quantum debeatur*, permitindo a deflagração do cumprimento de sentença por execução no mesmo processo. Ora, se o débito é decretado sempre que possível, então não o seria em todas as ocasiões. E, sempre que não o fosse, a questão haveria de ser analisada em outra demanda.

O disposto no art. 545, § 2.º, reproduz o conteúdo do art. 899, § 2.º, do CPC/1973. Haverá condenação ao pagamento do valor remanescente quando ele puder ser apurado na demanda de consignação. Mas pode ocorrer que à época de propositura não estejam presentes todos os elementos para a apuração do saldo, de modo que a questão deverá ser apreciada em outro processo. Ademais, ainda que a apuração fosse possível, as provas produzidas podem ser incapazes de determinar o *quantum*, embora seja viável apontar desde logo a insuficiência do depósito.¹¹⁷

Mas isso, contudo, não transforma a ação consignatória em demanda parcial. Em regra, o próprio réu indicará o valor devido, conforme determina o art. 544, IV, e parágrafo único, do CPC/2015. Trata-se de ônus, de modo que a omissão do réu acarretará a desconsideração da alegação de insuficiência.¹¹⁸ A necessidade de apuração do *quantum debeatur* em outra demanda é fato meramente contingente e, portanto, incapaz de caracterizar como parcial a cognição desenvolvida na ação consignatória.

8. Julgamento antecipado parcial do mérito

À medida que se estabeleceu a possibilidade de exame de questões prejudiciais, concernentes à validade do negócio jurídico e ao *quantum debeatur*, impõe-se averiguar se será possível o julgamento antecipado parcial do mérito, em conformidade com o disposto nos arts. 355¹¹⁹ e 356¹²⁰ do CPC/2015.¹²¹

O pedido na ação consignatória se limita à declaração de correção do depósito. Se não houver efetivação do depósito no quinquídio indicado no art. 542, I, do CPC/2015, ocorre extinção do processo sem resolução de mérito (art. 542, parágrafo único, do CPC/2015). Se o depósito não ocorrer no lugar do pagamento, o equívoco do devedor pode ser alegado em contestação (art. 544, III, do CPC/2015). Ao impedir a exoneração do devedor, a contestação do credor leva à improcedência da demanda. Em nenhum dos casos se caracteriza hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito.

Contudo, quando alegada a insuficiência do depósito, ocasião na qual pode o réu levantar desde logo a quantia depositada, prosseguindo o processo em relação ao montante controvertido (art. 545, § 1.º, do CPC/2015), haverá julgamento antecipado parcial do mérito. A propósito, a incontrovérsia é hipótese de fracionamento do mérito expressamente prevista no art. 356, I. Se o réu aponta a insuficiência do depósito, a parcela depositada se torna incontroversa, impondo a

prolação de decisão interlocutória que julga parcela do pedido, exonera parcialmente o devedor e permite a liberação do montante depositado. Não seria razoável, com efeito, que o réu tivesse de esperar o julgamento sobre a quantia controversa para que somente então levantasse a quantia consignada.

Nessa hipótese o processo prosseguirá para que se apure a pertinência da alegação de insuficiência do depósito. Somente depois da produção de prova será possível decidir sobre a correção da oferta. Decretando-se a insuficiência do depósito, deve ser julgada parcialmente procedente a demanda consignatória. Reconhecida a suficiência, o pedido será acolhido, julgando-se procedente a ação.

A demanda consignatória baseada na dúvida sobre a titularidade do crédito também permite o fracionamento do mérito. Nos termos do art. 548, III, do CPC/2015, se mais de um postulante ao crédito comparecer ao processo, o juiz decretará extinta a obrigação e liberará o devedor, prosseguindo o feito em relação aos sedizentes credores. O acolhimento da pretensão consignatória, com a exoneração do devedor, é premissa para o julgamento sobre a titularidade do crédito. Sendo assim, a decisão que decreta a extinção da obrigação e exonera o devedor constitui julgamento antecipado parcial do mérito. Com efeito, parcela do objeto litigioso é resolvida, remanescendo apenas a questão concernente à titularidade do crédito.

Como se verá nos comentários sobre o art. 548, não é possível enquadrar esta decisão em alguma das hipóteses previstas nos arts. 355 e 356 do CPC/2015, o que não impede a caracterização do provimento como decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC/2015). Não interposto recurso, a decisão transitará em julgado, podendo ser rescindida (art. 966 do CPC/2015).

À medida que o cúmulo de pedidos é permitido na ação consignatória, é possível que a incontrovérsia (art. 356, I, CPC/2015), a desnecessidade de produção de outras provas além da documental (art. 356, II, do CPC/2015 c/c o art. 355, I, do CPC/2015) e a revelia que gera presunção de veracidade das alegações, sem que o revel especifique provas (art. 356, II, do CPC/2015 c/c o art. 355, II, CPC/2015), conduzam ao julgamento antecipado parcial de um dos pedidos cumulados.

Suponha-se que à consignação tenham sido cumuladas pretensões de revisão de contrato e de condenação por dano moral. Nesse caso, o credor pode levantar o depósito, de modo que será julgada procedente a demanda consignatória. Ao concordar com o valor depositado, o réu também anui com a revisão do contrato, pois o depósito é realizado pelo devedor em conformidade com as cláusulas que reputa válidas e eficazes e que, portanto, não devem ser desconstituídas. A impugnação do réu pode se limitar à alegação de danos morais, de modo que o processo continuará em relação a este pedido, mas os dois outros serão julgados mediante decisão interlocutória, proferida, nessa hipótese, com fundamento no art. 356, I, do CPC/2015, dada a incontrovérsia.

A mesma hipótese poderia suscitar outra interessante questão. É possível que o credor impugne o depósito, reputando-o insuficiente (art. 544, IV, do CPC/2015). Mesmo nesse caso, ser-lhe-á permitido levantar o montante depositado (art. 545, § 1.º, do CPC/2015). O levantamento de valor que o credor considera insuficiente para o pagamento do débito não caracteriza anuência ao pedido de revisão de cláusula contratual. Ainda assim, ao permitir a exoneração parcial do devedor, a decisão caracteriza julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do art. 356, I, do CPC/2015.

9. Depósito extrajudicial

O art. 539, §§ 1.º a 4.º, reproduz substancialmente o disposto no art. 890, §§ 1.º a 4.º, do CPC/1973. Antes que a Lei 8.951/1994 acrescentasse os §§ 1.º a 4.º ao art. 890 do Código Buzaid, permitindo a consignação extrajudicial, essa possibilidade já era prevista no art. 33 da Lei 6.766/1979, referente ao parcelamento do solo urbano. O depósito, contudo, deve ocorrer no próprio Registro de Imóveis.

No art. 539, §§ 1.º a 4.º, é prevista a possibilidade de oferta extrajudicial quando o objeto da prestação for dinheiro. Assim, nas obrigações pecuniárias o devedor poderá depositar o valor devido em estabelecimento bancário, localizado no lugar de pagamento, sendo notificado o credor, mediante correspondência com aviso de recebimento, para que manifeste sua recusa no prazo de 10 (dez) dias (art. 539, § 1.º).

O texto emprega a locução “poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver”. Há melhoria em relação ao que prescrevia o art. 890, § 1.º, do CPC/1973, em que constava a expressão “em estabelecimento bancário oficial, onde houver”. Isso levou a que se defendesse a impossibilidade de oblação extrajudicial quando no lugar de pagamento não houvesse estabelecimento oficial.¹²² Trata-se de posição inadmissível, mesmo à luz do código revogado.

Com efeito, não se pode conceber que a adoção de técnica efetiva e adequada à liberação do devedor seja obstaculizada pela inexistência de banco oficial no lugar de pagamento.¹²³ Em inumeráveis localidades há somente a presença de bancos privados. Não há qualquer razoabilidade em impedir os cidadãos desses lugares de se valerem da consignação extrajudicial. Haveria, na hipótese, cerceamento à liberdade individual, a violar também a igualdade, vez que seria dispensado tratamento desigual a cidadãos na mesma situação, sem que houvesse motivo a justificá-lo. A malha bancária brasileira é dispersa e atinge comunidades longínquas. Essa circunstância favorável deve ser usada em benefício de devedores que pretendam se exonerar da obrigação, fazendo-o sem acessar a sobrecarregada estrutura do Poder Judiciário brasileiro.

Considerada a redação atual, é inequívoco que o depósito poderá ser realizado em estabelecimentos bancários privados quando não houver bancos oficiais no local de pagamento. Ocorre que essa preferência concedida aos bancos estatais também não encontra qualquer justificativa. Trata-se de mais um reflexo, no direito positivo, da cultura estatista brasileira, a conceder privilégios injustificáveis ao Estado.¹²⁴ O fato é que inexiste qualquer motivo para a concessão desse privilégio aos bancos oficiais. Nada leva a crer que os bancos privados sejam mais inseguros ou tornem menos eficiente a consignação extrajudicial. O que há é a conhecida desconfiança em relação ao empreendedorismo privado, alimentada pela ideia de que o Estado é o principal e mais confiável agente econômico.¹²⁵

Crê-se que o privilégio concedido aos bancos oficiais resvala na inconstitucionalidade, pois a livre concorrência é protegida no art. 170, IV, da Constituição. Com efeito, considerando que nada indica que os bancos privados prestariam o serviço de forma menos eficiente ou confiável que os públicos, a primazia concedida a esses viola a livre concorrência. Assim, se a oferta fosse realizada em banco privado, apesar da existência de banco oficial no lugar de pagamento, à alegação de inadequação do depósito, eventualmente deduzida pelo réu, contrapor-se-ia a afirmação de inconstitucionalidade do art. 539, § 1.º, do CPC/2015.

Na realidade, o depósito realizado em valor correto pelo devedor, perante estabelecimento bancário não oficial, não pode ser enquadrado como motivo para justa recusa, de modo que a previsão contida no dispositivo em análise, conquanto revele nocivo vezo estatista, não trará maiores consequências no plano processual.

A consignação extrajudicial não pode ocorrer nas hipóteses em que o devedor desconheça o credor, em que este se encontre em lugar de difícil acesso ou seu endereço seja ignorado.¹²⁶ Também não será possível quando houver litígio sobre o objeto do pagamento, dúvida sobre o credor, ou, ainda, quando este for incapaz ou declarado ausente.¹²⁷

Não há dúvida que tanto o devedor, quanto o terceiro juridicamente interessado, poderão realizar o depósito extrajudicial. O terceiro não interessado também poderá fazê-lo, desde que o depósito ocorra em nome e à conta do devedor e não haja oposição do devedor, nos termos do art. 304, parágrafo único, do CC/2002.

Nada obsta o depósito extrajudicial de aluguéis e encargos locatícios.¹²⁸ Quanto aos débitos tributários, a consignação terá de ser judicial, sendo inviável o depósito na forma dos §§ 1.º a 4.º

do art. 539. Ocorre que o lançamento de obrigações tributárias pressupõe atuação do fisco, sendo certo, por outro lado, que a extinção das referidas obrigações não se coaduna com o reduzido prazo de dez dias indicado no art. 539, § 1.º, do CPC/2015.¹²⁹

9.1. Procedimento do depósito extrajudicial

Realizado o depósito, o credor será notificado, mediante correspondência, para que manifeste a recusa no prazo de dez dias, contado a partir do retorno do aviso de recebimento (art. 539, § 1.º, do CPC/2015). No art. 4.º da Resolução 2.814/2001 do Banco Central, é previsto o prazo de dois dias úteis para que a instituição bancária expeça correspondência ao credor.¹³⁰ Fica nítido, portanto, que compete ao banco expedir a cientificação, não ao devedor depositante.

Se o credor for pessoa física, o aviso de recebimento deverá ser subscrito por ele, tendo em vista o gravíssimo efeito de liberação do devedor que decorrerá de sua eventual omissão. Tratando-se de pessoa jurídica, admite-se que o aviso de recebimento seja assinado por funcionário, à medida que a correspondência dificilmente chegará diretamente às mãos do representante legal.¹³¹

Transcorrido o decêndio em aberto, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, disponibilizando-se ao credor o valor depositado (art. 539, § 2.º, do CPC/2015). Tenha-se presente, contudo, que se o depósito tiver ocorrido em valor inferior ao devido, pode o juiz não decretar a liberação do devedor, a despeito da inércia do credor regularmente notificado.¹³² Entendimento contrário caracterizaria locupletamento ilícito. Também será extinta a obrigação se o devedor comparecer durante o decêndio e levantar a quantia depositada. Manifestada pelo credor recusa por escrito, poderá ser ajuizada a demanda consignatória.

Apresentada a recusa, o prazo para a propositura da demanda será de um mês, conforme assenta o art. 539, § 3.º. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 6.º da Resolução 2.814/2001, de acordo com o qual o banco deve notificar o devedor, sobre a recusa, no prazo de um dia útil a partir do recebimento.¹³³ O procedimento de consignação extrajudicial transcorre perante a instituição bancária. Ela media a relação entre o devedor depositante e o credor. Quando recebe a recusa, deverá comunicar o devedor, a fim de que ele ajuíze a demanda judicial. Assim, até que o obrigado seja cientificado pelo banco, o prazo de um mês para ajuizamento da ação consignatória não começará a correr.

O código não obriga o credor a motivar a recusa, razão pela qual ele está dispensado de fazê-lo.¹³⁴ Todavia, no art. 4.º, parágrafo único, III, da Resolução 2.814/2001 do Banco Central, é previsto que a correspondência a ser enviada ao credor deve reservar espaço para que ele possa se justificar.

Tendo optado pela consignação extrajudicial, ao devedor caberá instruir a inicial com a prova do depósito e da rejeição de pagamento. Se a demanda não for proposta no prazo de um mês, contado a partir da cientificação do devedor, pelo banco, sobre a recusa do credor, o depósito não gerará o efeito de liberação do devedor e de cessação dos riscos da obrigação (art. 539, § 4.º).¹³⁵

Com o ajuizamento da ação consignatória o depósito receberá da instituição financeira o tratamento dispensado aos depósitos judiciais, recaindo sobre o depositante o ônus de comprovar a propositura da demanda, nos termos do art. 6.º, parágrafo único, da Resolução 2.814/2001.¹³⁶

O Código de Processo Civil não traz qualquer regra referente às despesas com a consignação extrajudicial. No art. 8.º da Resolução 2.814/2001, consta que a instituição financeira poderá cobrar do depositante as despesas relativas à postagem, elaboração de documentos e quaisquer outras que tenham sido desempenhadas na realização das atividades que lhe competem. No § 1.º do mesmo artigo, faculta-se ao banco a cobrança de tarifa relacionada à manutenção da conta, a partir de sessenta dias contados depois do esgotamento do prazo de dez dias para a recusa do credor.¹³⁷

Se o devedor teve de se valer da consignação extrajudicial, isso se deveu à recusa do credor.

Não tivesse ela ocorrido, o pagamento se daria na forma preconizada no contrato. Não se pode esquecer que o § 1.º obviamente deve ser interpretado em conformidade com o *caput* do art. 539. Antes de depositar extrajudicialmente o devedor deve tentar pagar na forma convencionada, de modo que o depósito extrajudicial pressupõe a recusa do credor. Por esse motivo, as despesas com correspondência e demais atividades realizadas pela instituição bancária deverão ser cobradas do credor.

Poder-se-ia criticar a ideia de que a consignação extrajudicial pressupõe prévia oferta ao credor, com base na sistemática instituída nos §§ 1.º a 4.º do art. 539. À medida que o credor já teria se recusado, não faria sentido notificá-lo a receber o valor na instituição financeira. Ocorre que a consignação extrajudicial é meio de pagamento indireto. Em razão da recusa do credor, o devedor realizou o depósito extrajudicial. Deixando o credor de apresentar recusa formal à instituição financeira, será extinta a obrigação, com a exoneração do devedor. É flagrante, portanto, a utilidade do procedimento previsto no art. 539, §§ 1.º a 4.º, o que demonstra o desacerto da crítica.

Ademais, o procedimento previsto pelo Código de Processo Civil não tem o escopo de modificar o que fora celebrado entre as partes. Pretende-se somente permitir que o devedor se libere da obrigação sem ter de recorrer ao Judiciário. Mas a premissa para que ocorra o adimplemento por consignação é a prévia ocorrência de uma das hipóteses previstas em lei. Do contrário, o pagamento terá de se realizar na forma estipulada pelas partes. Em suma, o depósito extrajudicial não descaracteriza a consignação como meio substitutivo de extinção da obrigação e liberação do devedor.

Sendo as despesas antecipadas pelo devedor, ser-lhe-á lícito ressarcir-se, posteriormente, junto ao credor, que deu causa à consignação extrajudicial. Se jamais tiver sido realizada a oferta, ou seja, se o depósito extrajudicial ocorrer sem que antes tenha sido realizada a oblação ao credor, não poderá o devedor pleitear qualquer indenização.

Resta claro que o depósito extrajudicial é uma faculdade do devedor, cuja não realização não tolhe seu direito à propositura de demanda consignatória. Em outras palavras, a ação poderá ser ajuizada diretamente, sem prévia consignação extrajudicial, hipótese em que o autor requererá o depósito em juízo da quantia devida, o qual deve se realizar no prazo de cinco dias contados a partir do deferimento pelo juiz.

Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.

1. Dívidas portáteis, quesíveis e competência

O dispositivo em análise repete o contido no art. 337 do CC/2002.¹³⁸ Na primeira parte do texto é disciplinada a competência para o julgamento da demanda consignatória, a qual recai sobre o juízo do lugar de pagamento. O adimplemento será realizado no domicílio do devedor, a não ser que o contrário decorra de convenção, da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias, conforme assinala o art. 327 do CC/2002.¹³⁹

Avulta no exame do tema a importância da distinção entre dívidas quesíveis e portáteis. As primeiras são definidas como dívidas de ir buscar, de modo que seu traço caracterizador é a definição do domicílio do devedor como lugar de pagamento. Trata-se da hipótese prevista no art. 327 do CC/2002. Competindo ao credor buscar a prestação no domicílio do devedor, este será o lugar do pagamento. Por outro lado, dívidas portáteis são aquelas nas quais incumbe ao devedor levar a prestação, razão pela qual o lugar de pagamento será o domicílio do credor.¹⁴⁰

Na definição do lugar de pagamento se aplica, ainda, o art. 329 do CC/2002, de acordo com o qual, se houver motivo grave, poderá o devedor realizá-lo em local diverso, sem prejuízo para o credor.¹⁴¹ Trata-se de cláusula aberta. À luz do caso concreto caberá aferir a possibilidade de pagamento em lugar diferente do que fora determinado, sem que isso resulte na constituição em

mora do devedor.¹⁴²

O art. 341 do CC/2002 assinala que se o objeto da prestação for imóvel ou corpo certo,¹⁴³ cuja entrega deva acontecer no lugar em que está, o devedor pode citar o credor para que busque a coisa devida, sob pena de depósito.¹⁴⁴ Deve-se destacar que se trata de faculdade do autor, não de dever. Esse dispositivo deve ser conciliado com o art. 542, I, do CPC/2015, de acordo com o qual o depósito do bem ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento da inicial.

A finalidade do art. 341 do CC/2002 é permitir o levantamento sem que o bem seja depositado, conforme resulta da locução “sob pena de depósito”. Esse dado é relevante e não pode ser desconsiderado na interpretação do dispositivo. Assim, quando o objeto da prestação consistir em imóvel ou corpo certo, o devedor pode requerer a citação do credor para buscar o bem ou mandar recebê-lo, antes que ocorra o depósito.

Defende-se na doutrina a ideia de que haveria duas citações quando a prestação fosse imóvel ou corpo certo.¹⁴⁵ Com a primeira, fundamentada no art. 542, II (art. 893, II, do CPC/1973), o réu seria convocado a integrar o processo, na forma do art. 238 do CPC/2015.¹⁴⁶ Pela segunda, seria interpelado para buscar o bem ou mandar retirá-lo. Discorda-se desse posicionamento. Só há uma citação na demanda consignatória, destinada a convocar o réu a integrar o processo, mesmo nos casos em que a obrigação tenha como objeto imóvel ou corpo certo.

Para que o art. 341 do CC/2002 possa atingir o objetivo a que se propôs – permitir o levantamento do bem antes que ele seja depositado – deve-se aplicar na consignação de imóveis ou de corpo certo o procedimento previsto para as obrigações de entrega de coisa indeterminada, no qual se concede ao réu o prazo de cinco dias para escolher a prestação, sob pena de a especificação ser atribuída ao autor (art. 543 do CPC/2015). Aplicando essa sistemática para a consignação de imóveis ou de corpo certo, o prazo para o depósito, pelo autor, começa a ser contado a partir do escoamento do quinquídio concedido ao réu para buscá-lo. Inexistindo regra específica sobre o prazo a ser concedido ao credor para buscar o bem, há de se aplicar o art. 218, § 3.º, do CPC/2015,¹⁴⁷ de modo a se outorgar cinco dias. Somente depois do transcurso desse prazo deve começar a correr o quinquídio atribuído devedor (art. 542, II, do CPC/2015), para que deposite o bem.

No despacho que recebe a petição inicial o juiz deve deixar claro que a contagem de prazo para o depósito somente se iniciará após o decurso do quinquídio atribuído ao credor para que busque o bem. As partes deverão ser esclarecidas sobre o procedimento. Assim, no recebimento da inicial, após dar ao réu o prazo de cinco dias para buscar o bem, sob pena de depósito, o juiz deve assinalar que o transcurso em aberto leva à imediata abertura do quinquídio para o depósito pelo autor. Não é necessário intimar o autor sobre a omissão do réu. Como o bem deve ser buscado no lugar em que está, o devedor, autor da demanda, necessariamente saberá se houve ou não entrega do objeto da prestação. Realizado o depósito, com a intimação do credor começa a ser contado o prazo para que levante o bem ou apresente contestação (art. 542, II, do CPC/2015).

No mandado citatório deve constar a concessão do quinquídio para que o credor busque o bem antes que ele seja depositado pelo devedor. O mandado também assinalará que o prazo para oferecimento de resposta ou levantamento do bem depositado começará a correr a partir da intimação do réu sobre a realização do depósito.¹⁴⁸

Nota-se que a conciliação aqui proposta, entre o art. 341 do CC/2002 e o art. 542, I, do CPC/2015, baseia-se na interpretação extensiva do art. 543 do diploma processual. Procurou-se interpretar a regra do direito material de modo a permitir que atingisse seu objetivo, consistente na possibilidade de entrega do bem antes que ele seja depositado, medida que evita gastos com o depósito. Ocorre que interpretação literal do art. 341 do CC/2002 termina por transformá-lo em dispositivo de escassa utilidade.

Com efeito, se se entender que o credor deve buscar o bem, sem que o prazo para depósito seja suspenso, chega-se à conclusão de que o demandado deverá fazê-lo em momento anterior ao escoamento do quinquídio previsto no art. 542, I, do CPC/2015. Nesse caso, como até o quinto dia

após a intimação do deferimento da inicial, o autor deve depositar o bem, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 542, parágrafo único, do CPC/2015), caberia ao réu buscá-lo antes que o depósito ocorresse. Todavia, seria mais do que provável que, no momento da citação, já tivesse ocorrido o depósito. Mas ainda que a citação acontecesse antes do transcurso de cinco dias (art. 542, I, do CPC/2015), ao recebê-la o réu jamais teria segurança sobre a realização do depósito. Igualmente inseguro ficaria o autor, que malograria a extinção do processo (art. 542, parágrafo único, do CPC/2015), caso não fizesse o depósito no quinquídio que o código lhe assinala.

Aplicar o art. 341 do CC/2002, sem suspender o prazo para depósito, torna o dispositivo inútil. Logo, embora a interpretação aqui proposta se baseie na aplicação extensiva do art. 543 do CPC/2015, trata-se de exercício hermenêutico idôneo a assegurar que o dispositivo alcance sua finalidade.

Saliente-se que a contagem dos prazos atenderá ao disposto no art. 219 do CPC/2015, de modo que serão computados apenas os dias úteis.¹⁴⁹ Se o credor buscar o bem antes do depósito, não terá de arcar com essas despesas, o que constitui incentivo à sua conduta. Ainda assim, terá de arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, pois a premissa da demanda consignatória é que a conduta do credor não tenha permitido o adimplemento na forma convencionada. Nessa hipótese, não tendo ocorrido o depósito, a sentença se limitará a reconhecer o pagamento, circunstância da qual decorre a extinção da obrigação.

Caso o credor levante o bem depois do depósito, a demanda será julgada procedente, na forma preconizada no art. 546, parágrafo único, do CPC/2015. Nesse caso, diversamente do que ocorre quando o bem é buscado antes de ser depositado, a sentença declaratória reconhece a idoneidade do depósito e sua aptidão para extinguir a obrigação. O réu é condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

É digno de encômios que o código vigente não tenha repetido a proposição contida no art. 891, parágrafo único, do CPC/1973, que tantos embaraços trouxe à doutrina.¹⁵⁰ Crê-se que no dispositivo aludido o legislador tenha procurado reeditar a regra contida no art. 980 do CC/1916 (art. 341 do CC vigente). Todavia, o emprego da palavra “foro”, em vez de “lugar”, trazia enorme dificuldade para a compreensão do texto.¹⁵¹ Fosse qual fosse o sentido que deveria ser atribuído à proposição normativa, com a vigência do CPC/2015 a questão está superada. O que se há de fazer, tratando-se de corpo certo ou de imóvel, é harmonizar, na forma acima preconizada, o art. 341 do CC/2002 com o art. 542, I e II, do CPC/2015.

Como o art. 540 do CPC/2015 versa sobre competência territorial, incumbe ao réu, ante a propositura da demanda em foro inadequado, invocar, preliminarmente ao mérito, a incompetência, consoante assentam os arts. 64, *caput*,¹⁵² e 337, II, ambos do CPC/2015.¹⁵³ Omitindo-se o réu quanto a essa alegação, o juízo em que fora proposta a demanda terá prorrogada a competência, nos termos do art. 65, *caput*, do CPC/2015.¹⁵⁴ O credor pode preferir contestar, invocando a inadequação do lugar do depósito (art. 544, III, do CPC/2015).

2. Cessação, para o devedor, dos riscos e dos juros

Na segunda parte, o art. 540 determina a cessação, para o devedor, dos riscos e dos juros, assim que for realizado o depósito. Como já dito, o dispositivo reproduz o art. 337 do CC/2002.

É preciso retomar a ideia de que a sentença proferida na demanda consignatória apresenta eficácia declarativa, restringindo-se a apontar a validade do depósito.¹⁵⁵ Destarte, como já assinalado no item 5, dos comentários ao art. 539, o provimento jurisdicional que decide a demanda se limita a declarar a eficácia do depósito para a liberação do devedor. Por essa razão, ressalvada a hipótese de improcedência, a partir do depósito cessam para o devedor os riscos inerentes à prestação, bem como os juros. Em outras palavras, com o depósito regular o devedor estará exonerado da obrigação, sendo essa liberação reconhecida na sentença declaratória de procedência. Se a demanda for rejeitada, reconhece-se que o depósito não produziu o efeito liberatório almejado, de modo que não terá ocorrido a transferência dos riscos para o credor, nem,

tampouco, terão cessados os juros, recaindo sobre o obrigado as despesas com o depósito.

No tocante aos juros, a cessação ocasionada pelo depósito abrange não apenas os moratórios, mas igualmente os compensatórios.¹⁵⁶ Os juros que incidiram antes do depósito deverão ser observados na quantia consignada.¹⁵⁷

As despesas com o depósito correrão por conta do credor, ressalvada a hipótese de improcedência da demanda consignatória, conforme assenta o art. 343 do CC/2002.¹⁵⁸ Até que a demanda seja decidida deverão ser pagas as despesas com o depósito. Nesse caso, a fim de evitar prejuízos ao autor cuja pretensão consignatória seja verossímil, poderá o juiz determinar que os custos com o depósito sejam arcados pelo réu ao longo do processo. A questão deverá ser analisada com cuidado, para que o demandado não seja injustamente onerado com os encargos concernentes ao depósito enquanto tramitar o processo, os quais poderão ser elevados quando for difícil a conservação do bem.

Outro dos efeitos do depósito é a transferência dos riscos, compreendidos como a possibilidade de caracterização de dano.¹⁵⁹ Os riscos se referem à coisa, à prestação e à contraprestação e o preceito normativo abrange os dois primeiros.¹⁶⁰ Os arts. 540 do CPC/2015 e 337 do CC/2002 transferem para o credor, a partir do depósito, os riscos pela perda da coisa objeto da prestação. Sendo acolhida judicialmente a pretensão consignatória, concretiza-se a transferência dos riscos. A improcedência, reitere-se, é sinal de irregularidade do depósito, de modo que os riscos continuarão correndo por conta do devedor, que responderá se o objeto da prestação se perder.

Na análise da assunção de riscos deve ser aplicado o art. 400 do CC/2002, segundo o qual a mora do credor retira a responsabilidade do devedor pela conservação da coisa, obrigando o devedor a ressarcir as despesas com a conservação, desde que o devedor não tenha agido dolosamente.¹⁶¹ Caracterizada a mora do credor, embora o devedor esteja isento das consequências do inadimplemento, permanecerá vinculado à obrigação.¹⁶²

Quando se tratar de prestação pecuniária a consignação judicial assegura a correção monetária do *quantum* depositado. O verbete 271 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que a correção de depósitos judiciais não depende de demanda específica contra o banco depositante.¹⁶³

Também serão transferidas ao credor eventuais taxas e comissões bancárias, as quais, todavia, deverão ser acrescidas ao valor do depósito se já tiverem vencido à época de consignação.¹⁶⁴

A procedência parcial da demanda, decorrente da insuficiência do depósito, acarreta a cessação dos juros somente em relação à quantia depositada. Sobre o valor que deveria ter sido depositado, mas não foi, incidirão juros moratórios e compensatórios, pois o depósito não terá gerado efeito liberatório em relação a essa quantia.

Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.

1. Depósito de prestações sucessivas

O art. 541 reproduz, com melhor redação, o disposto no art. 892 do Código Buzaid. Ocorre que este dispositivo se referia a “prestações periódicas” e à consignação da “primeira” delas. Todavia, demonstrava a doutrina que o mais correto seria mencionar prestações sucessivas, sendo desnecessário que a primeira delas fosse depositada.¹⁶⁵ O alvitre foi seguido no código vigente, que faz menção a “prestações sucessivas, consignada uma delas”.

A doutrina justifica a possibilidade de consignação das prestações sucessivas com fundamento na ideia de pedido implícito,¹⁶⁶ o qual estaria autorizado no art. 290 do CPC/1973, cujo conteúdo foi reproduzido no art. 323 do código vigente.¹⁶⁷ Não é esta, contudo, a melhor forma de visualizar a

consignação de prestações sucessivas. Trata-se, em verdade, de hipótese de dispensa de pedido.¹⁶⁸ A noção de pedidos implícitos não se amolda ao processo civil contemporâneo, pautado pelo contraditório efetivo. Os arts. 323 e 541 do CPC/2015 dispensam pedidos.

Não será necessário que o devedor, na hipótese de dívida portátil, ofereça extrajudicialmente as prestações vincendas ao credor, após a recusa de uma das prestações. Tampouco será aberto prazo, a cada depósito, para que o credor apresente resposta.¹⁶⁹ É certo, contudo, que o réu deverá ser intimado a cada depósito, a fim de que possa se manifestar. Essa prerrogativa resulta dos arts. 7.º e 9.º do CPC/2015, que exigem o contraditório efetivo, compreendido como a possibilidade concreta de influenciar a convicção do juiz.

Nas demandas consignatórias os réus poderão alegar a insuficiência da prestação vincenda ou o esgotamento do prazo de cinco dias. Qualquer que seja a alegação, a premissa é de que sejam intimados para se manifestar após o depósito.

2. Prazo de cinco dias

O art. 541 estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, contado da data de vencimento, para que ocorra o depósito da prestação sucessiva. Esse prazo não se aplica à consignação de prestações locatícias, pois o art. 67, III, da Lei de Locações prescreve que as prestações vincendas deverão ser consignadas na data do vencimento.¹⁷⁰ Conquanto o Código de Processo Civil seja lei posterior, a Lei 8.245/1991 é especial, de modo que não é derogada por legislação mais recente, mas genérica. Esse entendimento é respaldado no art. 2.º, § 2.º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.¹⁷¹

A previsão do quinquídio é salutar para evitar que o devedor seja prejudicado por algum contratempo, como a queda do sistema de energia ou eventual paralisação da serventia judicial que fornece as guias de depósito ou da agência bancária em que o depósito é realizado. Será ineficaz requerer o depósito no prazo aludido, pois como já visto, é dispensável o pedido de depósito das prestações vincendas. Incumbe ao devedor depositar.

Caso o depósito não seja realizado no quinquídio, o devedor poderá fazê-lo desde que promova nova consignação judicial. Não decai o direito de consignar. O art. 541 do CPC/2015 apenas inviabiliza que o depósito ocorra na mesma relação processual.¹⁷² Poder-se-ia criticar essa posição, acusando-a de excessivo formalismo. Seria possível imaginar que o depósito realizado intempestivamente ainda geraria efeitos, principalmente quando não houvesse resistência pelo credor, tal como ocorre quando o interesse processual se implementa supervenientemente, em razão da modificação do direito positivo.

Nada obstante, tal modo de visualizar a questão olvida que o pagamento em consignação é hipótese substitutiva de adimplemento, cuja eficácia pressupõe o atendimento dos requisitos definidos em lei. Ademais, o código concede ao devedor a possibilidade de consignar em até cinco dias depois do vencimento da prestação, dando-lhe a oportunidade de evitar contratempos. Essa liberalização deve ser acompanhada de sanção ao autor desidioso, que deixa transcorrer o prazo. A sanção, na hipótese, corresponde à necessidade de propositura de nova demanda consignatória, na qual, a partir de então, serão realizados os depósitos sucessivos. Enquanto não promover nova demanda, assume o devedor os riscos da prestação e voltam a correr os juros moratórios e compensatórios.

É importante enfatizar que o prazo de cinco dias para o depósito não é prescricional, nem decadencial. Tanto não decai o direito de depositar, nem prescreve a pretensão de fazê-lo, que o devedor poderá consignar a prestação, desde que promova nova demanda. Trata-se de prazo submetido à preclusão, instituto a ensejar a inviabilidade de depósito intempestivo. A contagem do prazo de cinco dias para o depósito deve ocorrer em conformidade com o art. 219 do CPC/2015, não sendo considerados dias não úteis.

3. Prestações vincendas, prolatação de sentença e trânsito em julgado

A possibilidade de depósito de prestações vincendas após a prolação da sentença é questão controversa, mostrando-se vacilante a jurisprudência.¹⁷³ Fundamenta-se a negativa na eficácia declaratória do *decisum*, a qual não poderia ser projetada para o futuro, à medida que a sentença evidentemente não se pronunciou sobre a regularidade dos depósitos posteriores à prolação.¹⁷⁴

Por outro lado, defende-se o prosseguimento dos depósitos, mesmo depois da sentença, invocando-se, para tanto, o princípio da economia processual.¹⁷⁵ O raciocínio subjacente ao argumento é bastante claro: caso sejam admitidos depósitos após a sentença, será desnecessário ajuizar nova demanda.

Primeiramente, afasta-se a possibilidade de que o devedor prossiga depositando prestações vincendas após o trânsito em julgado. Sequer existiria, nesse caso, processo em relação ao qual os depósitos pudessem ser realizados. Essa circunstância afasta a viabilidade de depósitos depois de findo o processo.

No tocante ao prosseguimento após a prolação da sentença, crê-se que a impossibilidade de impugnação, pelo credor réu, seja óbice suficiente a impedir que os depósitos continuem a ocorrer na mesma relação processual. O tribunal não poderia se pronunciar sobre a regularidade desses depósitos, sob pena de supressão de instância. Do mesmo modo, seria inoportuna a impugnação dirigida diretamente ao tribunal, à medida que o juiz *a quo* não teria decidido o tema. Ainda menos adequada seria eventual impugnação formulada enquanto o processo pendesse de julgamento em Corte Superior.

Além desse obstáculo procedimental, há ainda outro, teórico, a impedir que os depósitos prossigam depois da sentença: os provimentos declaratórios se limitam a certificar a regularidade dos depósitos realizados até sua prolação. Sua eficácia não pode se projetar para prestações futuras, pois conceitualmente só é reconhecido como regular o depósito que tenha sido apreciado pelo juízo.

Por fim, a limitação imposta no art. 67, III, da Lei de Locações, sinaliza, em aplicação analógica, que para prestações não locatícias a sentença deve ser considerada como limite temporal, após o qual incumbe ao devedor ajuizar nova demanda.

Conquanto a economia processual seja elemento norteador do processo civil contemporâneo, não se trata de valor absoluto, que possa prevalecer sobre o princípio do contraditório. Nos arts. 7.º e 9.º, o CPC/2015 é enfático ao erigir o contraditório efetivo como elemento imprescindível do processo. Como o depósito de prestações vincendas, depois da sentença, impossibilita a impugnação pelo réu credor, o qual, quando menos, será privado de decisão em duplo grau sobre a validade da consignação, tem-se que a sentença deve ser considerada como o limite após o qual caberá promover nova demanda, a fim de que sejam consignadas as prestações por vencer.

Em apenas uma hipótese seria possível admitir depósito quando pendente recurso em segunda instância. Se o tribunal, modificando a sentença, reconhecer a insuficiência do depósito, nada impede que o autor possa complementá-lo.¹⁷⁶ Nesse caso, a economia processual, cristalizada como valor do sistema na alusão do art. 8.º do CPC/2015 à eficiência, não solaparia o contraditório. A possibilidade de complementação atenderia aos interesses do credor e do réu, sem que houvesse obstáculo à realização de contraditório efetivo.

Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá:

I – o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3.º;

II – a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito.

1. Petição inicial e requerimento de depósito

O artigo em análise se aplica às ações consignatórias caracterizadas pela *mora accipiendi*, incidindo nas hipóteses em que o devedor conheça o credor, mas o pagamento não tenha ocorrido por ato atribuível ao sujeito ativo da obrigação ou em decorrência de algum elemento objetivo.¹⁷⁷ Como se vê, não é apenas na hipótese de recusa do credor que o artigo deve ser observado.

A petição inicial observará os requisitos elencados no art. 319 do CPC/2015, à exceção do contido no inc. VII,¹⁷⁸ pois a audiência de conciliação ou de mediação, disciplinada no art. 334, não se compatibiliza com o procedimento especial das demandas consignatórias. Além dos genéricos, há requisitos específicos, quais sejam: o requerimento de depósito da quantia ou da coisa devida, dispensável somente quando já tiver ocorrido o depósito extrajudicial, na forma do art. 539, § 3.º, do CPC/2015, e o requerimento de citação do réu para o levantamento do depósito ou oferecimento de resposta, quando a consignatória se fundamentar na recusa ao recebimento do crédito. Essa, segundo autorizada doutrina, seria a característica mais singular da petição inicial da demanda de consignação.¹⁷⁹

Por outro lado, quando se tratar de obrigação alternativa ou de gênero, cabendo a escolha ao credor, o ato citatório conterá interpelação para que ele especifique o objeto da prestação (art. 543 do CPC/2015). Na consignatória baseada na dúvida sobre a pessoa do credor, os réus serão citados para comprovar o crédito (art. 547 do CPC/2015).

Saliente-se que a coisa devida deve ser depositada, não sendo admissível a substituição da prestação, cuja ocorrência violaria o que fora estipulado entre as partes. O depósito de prestação diversa da convencionada é incapaz, portanto, de permitir a desoneração do devedor.¹⁸⁰

Incumbe ao autor juntar os documentos indispensáveis à propositura da demanda, na forma do art. 320 do CPC/2015.¹⁸¹ Na ação consignatória, além da procuração, será imprescindível a prova documental do ato jurídico do qual se origina a obrigação. É neste documento, em regra, que o juiz verificará os sujeitos da obrigação, a prestação, o lugar, o tempo e o modo de pagamento. É certo que se admitirá a prova testemunhal para a comprovação de algum dos elementos da obrigação, na forma dos arts. 442,¹⁸² 444¹⁸³ e 445¹⁸⁴ do CPC/2015. Contudo, caso o devedor aluda ao documento na inicial, não poderá deixar de juntá-lo, a não ser que alegue extravio e requeira sua exibição pelo réu, em conformidade com o art. 397 do CPC/2015.¹⁸⁵

Verificada alguma das hipóteses para o indeferimento previstas no art. 330, ou ausente algum dos requisitos genéricos (arts. 319 e 320) ou específicos (art. 542, I e II), poderá ser indeferida a petição inicial quando o autor, instado pelo juiz a emendá-la ou a completá-la, deixar de fazê-lo.

2. Prazo para depósito e consequência do descumprimento

O requerimento do depósito, realizado na inicial, será inútil se o autor não efetivá-lo em até cinco dias do deferimento da inicial. O prazo será contado na forma do art. 219 do CPC/2015, computando-se somente os dias úteis, e o marco inicial será a intimação do autor sobre o despacho que recebe a inicial. Não é necessário que o juiz autorize expressamente o depósito, estando o deferimento implícito na determinação de citação do réu.¹⁸⁶

No art. 542, parágrafo único, é cominada a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando o autor deixar transcorrer em aberto o quinquídio para a realização do depósito. Pode-se visualizar essa consequência sob dois prismas.

Primeiramente, é possível compreender o depósito como pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo de consignação, de modo que sua falta inviabiliza o prosseguimento do feito, acarretando a prolatação de sentença terminativa, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.¹⁸⁷ Em outras palavras, a falta de pressuposto impede que o mérito da demanda seja apreciado. Também se pode conceber a falta de depósito como elemento caracterizador da perda superveniente de interesse processual. Para exonerar-se da obrigação o devedor deve promover o

depósito. Como já visto, a sentença que decide o processo é declaratória, limitando-se a certificar a validade do depósito e sua aptidão para extinguir a obrigação, transferir os riscos para o credor e fazer cessar os juros e demais encargos sobre a prestação. Ao se omitir, deixando de depositar o bem, o autor perde o interesse processual, pois a falta de depósito inviabiliza qualquer dos objetivos perseguidos com a consignação. Faltando o interesse processual, impõe-se a carência da demanda, proferindo-se, também nesse caso, sentença terminativa, com base no art. 485, VI, do CPC/2015.¹⁸⁸ Trata-se de particularidade das ações consignatórias. Assim, mesmo que a inicial seja coerente e demonstre a presença de legitimidade e interesse, a omissão do depósito ocasiona a emissão de sentença terminativa. Como já dito, a omissão do autor, ao deixar correr em aberto o prazo, ensejará a extinção do processo sem exame do mérito.¹⁸⁹ Se o autor o realizar intempestivamente, terá ocorrido preclusão da possibilidade de depositar, aplicando-se ao caso o art. 223 do CPC/2015, segundo o qual, esgotado o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual.¹⁹⁰ Ressalvada a hipótese de justa causa, não lhe socorrerá outra possibilidade além da propositura de nova demanda. Inexiste, nessa solução, formalismo imoderado.

O autor, para se exonerar, deverá depositar em estrita conformidade com o disposto em lei. Autoriza-se que o depósito seja feito em até cinco dias contados da intimação sobre o deferimento da petição. Este quinquídio tem como objetivo viabilizar o depósito mesmo quando haja alguma intercorrência a impedi-lo. Concomitantemente à liberdade outorgada ao devedor, incide sanção se for desatendido o tempo previsto no código para o depósito. A situação é semelhante à que se verificaria caso o autor interpusesse apelação um dia após o esgotamento do prazo. Ainda que o apelado anuísse sobre o conhecimento do recurso, inexistiria saída além da negativa de seguimento.

Conforme assenta a parte final do art. 542, I, o autor estará dispensado de realizar o depósito se já houver depositado extrajudicialmente, na forma preconizada no art. 539, § 1.º, do CPC/2015. Nesse caso, ao propor a demanda, comprovará o depósito e a recusa do credor (art. 538, § 3.º, do CPC/2015).

3. Citação e lugar do levantamento

Como já visto, o juiz deferirá o depósito ao despachar a inicial, impulsionando o feito. O autor deve ser intimado dessa decisão, a fim de que deposite a quantia ou coisa devida no prazo de cinco dias (art. 542, I, do CPC/2015). Ao juiz cabe designar o lugar em que o credor deve buscar a coisa depositada. Tratando-se de obrigação pecuniária, o levantamento ocorrerá na agência bancária em que a quantia foi depositada, frequentemente localizada na própria unidade jurisdicional. Bens de pequena dimensão também poderão ser depositados em juízo. O magistrado pode determinar que o depósito se realize junto ao depositário oficial ou perante alguém especialmente designado para a guarda e conservação do bem.¹⁹¹ Nesse caso, deverá constar no mandado citatório o local em que o bem foi consignado.

Já foi analisado, no item 1 dos comentários ao art. 540, que se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, o devedor pode requerer a citação do credor para buscá-la no lugar em que se encontra, conforme assinala o art. 341 do CC/2002. Nesse caso, a citação ocorre antes que o bem seja depositado, pois o dispositivo preconiza que a omissão do credor ensejará o depósito. Deixando de buscar o bem, o que oportuniza a realização do depósito pelo devedor, o credor será intimado para oferecer contestação ou levantar o bem depositado (art. 542, II, do CPC/2015).

O procedimento previsto para a consignação de imóvel ou corpo certo (art. 341, do CC/2002, c/c art. 541, I e II, do CPC/2015) impõe que seja ponderada a afirmação segundo a qual o depósito deve ser realizado impreterivelmente antes da citação.¹⁹² O depósito, nesse caso, é decorrência da omissão do credor. Também inexistirá depósito, antes da citação, na consignação de obrigações alternativas ou de gênero (art. 543 do CPC/2015). Nesse caso, o credor é citado para escolher o bem, recaindo a escolha sobre o devedor, caso o réu se omita. É evidente que não poderá ser realizado o depósito até que tenha sido selecionado o bem a ser entregue. O art. 543 indica o parâmetro para a aplicação conjugada do art. 341 do CC/2002 com o art. 542, I e II, do código processual.

O mandado citatório, quando houver pedido do devedor para que o credor busque o imóvel ou o corpo certo, sob pena de depósito, deve apontar o prazo de cinco dias para que o réu realize a conduta, findo o qual se inicia a contagem do quinquídio estabelecido no art. 542, I, do CPC/2015, no qual incumbe ao devedor depositar o bem.

A citação, nas demandas consignatórias, é realizada de acordo com o meio mais adequado ao caso concreto. Tratando-se de ação entre particulares, nada obsta que ocorra pelo correio (art. 246, I, do CPC/2015). Se a demanda tiver como objeto débito tributário, o ato citatório será realizada por meio eletrônico (art. 246, V, §§ 1.º e 2.º, do CPC/2015).¹⁹³ Se o credor for incapaz, deverá ser citado por oficial de justiça (art. 246, II, do CPC/2015 c/c art. 247, II, do CPC/2015).¹⁹⁴ Nas hipóteses em que o credor não for conhecido, ou o lugar em que se encontrar for ignorado, incerto ou inacessível, a citação acontecerá por edital (art. 246, IV, do CPC/2015 c/c art. 256, I e II, do CPC/2015).¹⁹⁵

Independentemente do objeto da prestação, o credor poderá levantar o depósito pessoalmente ou mediante interposta pessoa, desde que esta, seja procurador ou preposto, apresente recibo assinado pelo credor.¹⁹⁶

Em síntese, a decisão de recebimento da inicial indicará o lugar em que o réu deve buscar o bem depositado, sendo fundamental que essa informação conste no mandado citatório, no qual também será indicada a possibilidade de oferecimento de resposta. Apesar de o art. 542, II, mencionar somente a contestação, o réu também poderá reconvir e peticionar alegando impedimento ou suspeição.¹⁹⁷

4. Cumulação de pedidos

O autor poderá cumular pedidos na demanda consignatória. O art. 327, § 2.º, do CPC autoriza a cumulação entre pretensões subordinadas aos procedimentos especiais e aquelas cujo processamento siga o procedimento comum, desde que este seja aplicado.¹⁹⁸

São corriqueiras, na prática forense, as cumulações do pedido de consignação com os de revisão de contratos.¹⁹⁹ A eficácia das decisões proferidas nas demandas denominadas “revisórias” é declaratória negativa, quando for reconhecida a invalidade de determinada cláusula, podendo, ainda, ser desconstitutiva quando for judicialmente determinado o desfazimento da avença. Considerada sua finalidade precípua, consistente na desoneração do devedor, a demanda consignatória se relaciona, por conexidade, com pedidos referentes à relação obrigacional.

Saliente-se que depois do oferecimento de resposta, o procedimento comum será adotado nas ações de consignação, o que reforça a possibilidade de cumulação de pedidos. A propósito, o art. 548, III, é expresso a respeito da aplicação do procedimento comum na consignatória motivada por dúvida sobre quem deve receber a prestação. Conquanto o código se refira expressamente apenas a esta hipótese, é certo que em todas as demais, depois da manifestação do réu, será adotado o procedimento comum. Assim, o juiz deverá proceder na forma prevista no art. 357 do CPC/2015, resolvendo questões processuais pendentes, delimitando as questões de fato e de direito, fixando o ônus da prova e designando, se necessário, audiência de instrução e julgamento.²⁰⁰

O depósito e a citação do credor para que faça o levantamento da quantia ou da coisa depositada inviabilizam a realização da audiência prevista no art. 334 do CPC/2015.²⁰¹ Com efeito, o procedimento especial da demanda consignatória não se compatibiliza com a audiência de conciliação ou de mediação. O réu não é citado para participar de atividade conciliatória, mas para levantar o bem depositado e, desse modo, permitir a liberação do devedor, ou para oferecer resposta.

Em razão da incompatibilidade procedimental, a impedir a prática da audiência referida, o prazo para resposta evidentemente não será contado em conformidade com o art. 335, I, do CPC/2015.²⁰² A ênfase do código na conciliação não se sobrepõe à falta de compatibilidade entre a audiência conciliatória e o procedimento especial previsto para a tramitação das demandas

consignatórias.²⁰³

5. Tutela de urgência

A especialidade do procedimento de consignação, a exigir o depósito do bem e a citação do credor para levá-lo ou oferecer resposta, é incompatível com o requerimento de tutela antecipada antecedente, disciplinado no art. 303 do CPC/2015, donde resulta a inviabilidade do regime de estabilização previsto no art. 304 do mesmo código.

Considerando que na demanda consignatória o pedido se limita à declaração de regularidade do depósito, da qual resulta a extinção da obrigação, não seria razoável que o autor peticionasse se limitando a expor a lide e a requerer a tutela antecipada, a fim de que o juiz deferisse o depósito liminarmente. Essa providência deve ser adotada pelo juiz ao receber a petição inicial, de modo que o requerimento antecedente de tutela antecipada será medida inócua, com a qual sequer há ganho de tempo, pois ao apreciar o pedido de depósito o juiz realiza a mesma atividade cognitiva, quer ela ocorra no âmbito de pedido antecedente, quer se realize na petição inicial da demanda consignatória. Não há, portanto, razoabilidade no requerimento de depósito em caráter antecedente.

Sob o Código Buzaid, a doutrina controverteu sobre a possibilidade de “depósito prévio”. De um lado, admitia-se a existência de situações urgentes, nas quais o devedor tivesse de adimplir no dia do vencimento, a fim de que não ocorresse o acréscimo de encargos, de modo que o depósito tivesse de ser antecipado.²⁰⁴ O “estado de necessidade” do devedor autorizaria, segundo esse entendimento, o depósito do bem ou da quantia devida.²⁰⁵ Por outro, afirmava-se que a presença do devedor era dispensável, de modo que o “estado de necessidade” não justificaria o depósito prévio. Ademais, a antecipação do depósito suscitaria controvérsia sobre o momento de transferência dos riscos e de suspensão dos encargos. Ao autor, em circunstâncias excepcionais, incumbiria realizar o depósito mediante demanda cautelar.²⁰⁶

A discussão está superada no ordenamento jurídico brasileiro desde a vigência da Lei 8.951/1994. Com efeito, a partir de então, não mais se determina a entrega do bem em dia e lugar designados pelo juiz, sob pena de depósito. Em regra, serão a coisa ou a quantia depositadas antes da citação do credor. A discussão é útil, todavia, para demonstrar que a doutrina admitia o depósito cautelar da prestação. No código vigente, contudo, a medida cautelar seria desnecessária. Como já dito, o deferimento do depósito ocorre no despacho que recebe a demanda consignatória. Trata-se de ato judicial anterior à citação. Tão logo o juiz defira, poderá o autor consignar o objeto da prestação.

O “depósito prévio” não encontraria justificativa sequer quando o devedor pretendesse evitar a incidência de encargos decorrentes da mora. Tome-se a hipótese mais comum de pagamento em consignação, decorrente da recusa do credor em receber a prestação (art. 335, I, CC/2002). A premissa para que o pagamento não ocorra na forma convencionada é a resistência do credor em receber a prestação e emitir o consequente recibo. A fim de se exonerar da obrigação, outra saída não há ao devedor, senão o pagamento em consignação. Pois bem. Baseando-se a consignação na injusta recusa do credor, o devedor depositará em juízo a prestação, sem acrescentar-lhe os encargos decorrentes da mora.

Não se pode olvidar que antes de consignar a quantia ou o bem, o devedor tentara pagar, fracassando em seu intento por conta do comportamento ilícito do réu, o qual, injustamente, recusou-se a receber o pagamento. Ora, nesse caso não faria sentido que o devedor tivesse de pagar encargos e multas, cuja incidência decorreu de comportamento ilícito do credor. Por outro lado, nem é preciso dizer que quando o devedor já estiver em mora deverá acrescentar os encargos ao valor do depósito. Não se vislumbra, portanto, hipótese em que seria pertinente o depósito antecipado para fim de extinção de obrigação.

Em ao menos uma hipótese, no entanto, é possível a concessão de tutela de urgência no âmbito da ação consignatória. Já foi visto que o Código Civil, no art. 343, determina que as despesas com o

depósito sejam arcadas pelo credor, exceto se a demanda for julgada improcedente. É possível, principalmente quando o objeto da prestação exigir cuidados especiais, que a guarda e conservação se mostre onerosa. Nesse caso, poderá o autor requerer que as despesas com o depósito sejam desde logo suportadas pelo credor. Trata-se de clara antecipação dos efeitos da futura sentença de procedência, a qual deverá, nos termos do art. 343 do CC/2002, determinar que o credor arque com as despesas do depósito.

Destarte, poderá o autor, com fundamento no art. 300 do CPC/2015,²⁰⁷ requerer provimento liminar urgente e antecipatório, com o qual será desde logo determinado que as despesas com o depósito correrão por conta do credor cuja atitude inviabilizara o pagamento na forma convencionada.

6. Valor da causa

Como em todas as demandas, deverá o autor da consignatória indicar o valor da causa. Segundo o art. 292, II, do CPC/2015, o valor da causa, nas ações consignatórias, corresponderá ao valor da prestação que o devedor pretende adimplir.²⁰⁸ Com efeito, o dispositivo menciona que na demanda que tiver por objeto o cumprimento do ato jurídico, o valor da causa equivalerá ao do ato ou ao da parte controvertida.

Conforme o art. 292, § 2.º, tratando-se de prestações sucessivas, caberá ao autor indicar o valor de uma prestação anual, se a obrigação for estipulada por tempo indeterminado ou por superior a um ano. Sendo inferior o prazo, o valor corresponderá à soma das prestações.²⁰⁹

Art. 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 (cinco) dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito.

1. Coisa indeterminada e escolha pelo credor

O art. 543 do CPC/2015 reproduz preceito contido no art. 342 do CC/2002,²¹⁰ de acordo com o qual, nas hipóteses em que incumbir ao credor a escolha de coisa indeterminada, será ele citado para fazê-lo, sob pena de perder o direito, o qual será, então, exercido pelo devedor.

Nas obrigações de gênero, previstas no art. 244 do CC/2002,²¹¹ a escolha, denominada concretização, em regra compete ao devedor. Todavia, como resulta inequívoco do próprio dispositivo, poderá ter ocorrido estipulação diversa no ato jurídico do qual se origina a obrigação. O mesmo ocorre nas obrigações alternativas, nas quais a escolha, designada como concentração, também compete ao devedor, ressalvada a existência de estipulação em sentido contrário, como assenta nitidamente o texto do art. 252 do CC/2002.²¹²

A finalidade dos arts. 543 do CPC/2015 e 342 do CC/2002 é permitir a extinção da obrigação, com a exoneração do devedor, nos casos em que o credor, a quem cabe realizar a concentração ou a concretização, deixar de fazê-lo. A mora do credor inviabiliza o pagamento, de modo que a consignação judicial é a técnica adequada para permitir a liberação do devedor.

2. Citação do credor para realizar a escolha

O credor será citado para realizar a escolha que lhe cabe, sendo-lhe deferido o prazo de cinco dias para fazer a concretização ou a concentração. O art. 543 menciona que a escolha poderá ocorrer em prazo diferente do quinquídio se houver estipulação no ato jurídico do qual se origina a obrigação. Todavia, o ajuizamento da demanda consignatória tem como premissa a mora do credor, de modo que o prazo diverso para a escolha, eventualmente estipulado em contrato, já terá se escoado. Desse modo, excetuada a remota hipótese de estipulação de dois prazos para a escolha, o credor deverá selecionar a prestação no prazo de cinco dias após a juntada aos autos do ato

citatório cumprido.²¹³

Diferentemente do que ocorre na hipótese mais comum, de mora do credor, em que há recusa ao pagamento, a citação é realizada não para que o bem depositado seja levantado, mas para que o objeto da prestação seja selecionado. O ato citatório, a par de integrar o réu na relação processual, interpela-o, a fim de que realize a concentração, tratando-se de obrigação alternativa, ou a concretização, caso se trate de obrigação de gênero.²¹⁴

Se o credor deixar de fazer a especificação, extinguir-se-á seu direito de fazê-lo. A consequência da inércia do credor, portanto, é a perda do direito de escolha, de modo que não há interesse processual no pedido de cominação de multa para forçar o credor a escolher o objeto da prestação. Omissa o credor, incumbe ao devedor realizar a escolha.²¹⁵ Para que o devedor se desincumba desse encargo, impõe-se sua intimação acerca da omissão do credor.²¹⁶ Cabendo-lhe, nas obrigações de gênero, a concretização, não pode entregar a coisa pior, nem é obrigado a dar a melhor, conforme aponta o art. 244 do CC/2002.

3. Procedimento

Determina o art. 543 que o juiz, simultaneamente à citação do credor para realizar a escolha, designe lugar, dia e hora para a oferta, sob pena de depósito. Essa determinação gera alguma perplexidade em relação ao procedimento a ser adotado. Para melhor compreendê-la, convém analisar as possibilidades de desdobramento do problema.

Se o credor, citado para escolher a coisa, selecioná-la no prazo de cinco dias previsto no art. 543 do CPC/2015, o devedor será intimado sobre a escolha, a fim de que possa cumprir a prestação. Com efeito, de nada adiantaria que o juiz, ao despachar a inicial, determinasse lugar, data e hora para a entrega, se o devedor não soubesse o que deveria prestar. Ciente da escolha do credor, o autor da demanda comparecerá ao lugar, dia e hora designados pelo juiz, a fim de realizar a oferta real e, desse modo, exonerar-se da obrigação. Não comparecendo o credor, o bem será depositado. Incidirão à hipótese os arts. 396²¹⁷ e 400 do CC/2002, de modo que o devedor não incorrerá em mora, nem responderá pela conservação da coisa, pois o inadimplemento decorre de conduta atribuível ao credor.

Se o credor, citado para escolher a coisa, omitir-se, o devedor será intimado, cabendo-lhe realizar a concentração ou a concretização, conforme a obrigação seja, respectivamente, alternativa ou de gênero. No lugar, dia e hora designados pelo juiz, o devedor realizará a entrega da coisa. Ausentando-se o credor, restando inviabilizada a entrega, ocorrerá o depósito judicial, a partir do qual será contado o prazo para resposta, sem que o devedor incida em mora ou seja responsabilizado pela conservação da coisa. Comparecendo o credor e consumando-se a entrega do bem, a obrigação será extinta.

Caso o devedor não compareça ao ato de entrega, inviabilizando a consignação, aplica-se extensivamente à hipótese o art. 542, I, parágrafo único, do CPC/2015, decretando-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Tal como ocorre quando o devedor deixa de depositar, sua falta ao ato designado para a oblação deve acarretar perda do interesse no processo, da qual resulta a carência da demanda. A partir desse momento o devedor estará em mora, de modo que sobre ele incidirão os encargos moratórios e os riscos da prestação. Note-se que nesse caso é possível visualizar com clareza a pretensão do autor. Mas sua omissão acarreta perda de interesse processual, autorizando a prolação de sentença terminativa no curso do processo, apesar do princípio da primazia do mérito (CPC, arts. 4º e 488).

Se o devedor comparecer, mas pretender entregar bem diferente da prestação escolhida pelo credor, caracteriza-se motivo para justa recusa, de modo que o depósito de coisa diversa da escolhida deflagrará a abertura de prazo para resposta, na qual o réu invocará a correção de sua recusa (art. 544, II, do CPC/2015). Justifica-se a diferença de tratamento em relação à hipótese em que o autor nada leve consigo, a qual enseja extinção do processo sem resolução de mérito. Quando o réu discordar da entrega do bem levado pelo autor, a discussão sobre a adequação deve

ser dirimida pelo juiz. Todavia, quando o réu nada leva consigo, há de se extinguir o processo sem julgamento de mérito.

Ao designar o dia e hora para a entrega, o juiz deverá considerar o tempo necessário para o devedor realizar a oblação. É possível que o objeto da prestação, sobretudo quando tiver sido escolhido pelo credor, ofereça dificuldades ao devedor. Quando a escolha houver sido realizada pelo próprio devedor, certamente serão selecionadas as coisas que permitirem mais fácil cumprimento, embora, mesmo nesse caso, em razão da distância em que porventura se encontrem, possa haver dificuldade para a oferta real. Assim, o juiz, ao despachar a inicial, deverá conceder prazo hábil para a oferta. Diga-se o mesmo em relação ao lugar, que deve ser designado pelo juiz em atenção à facilidade de cumprimento.

O demandante, ciente das dificuldades em que pode incorrer para realizar o pagamento em consignação, deverá indicar, na petição inicial, o tempo e o lugar adequados para o cumprimento. Quanto mais elementos forem apresentados pelo autor, mais adequado será o despacho do juiz.

Com a citação, como já visto, o réu é interpelado a escolher o objeto da prestação e a comparecer ao lugar de entrega no dia e na hora designados pelo juiz.²¹⁸ O credor poderá desde logo oferecer contestação, em vez de selecionar o objeto da prestação, alegando, por exemplo, a realização de escolha ou a justiça de sua omissão (art. 544, I e II, do CPC/2015). Ser-lhe-á possível, ademais, invocar preliminarmente quaisquer alegações conducentes ao indeferimento da inicial (art. 330 do CPC/2015). Não seria razoável, nesse caso, que o credor tivesse de aguardar a data designada pelo juiz para somente então contestar. É certo que o prazo para resposta fica suspenso até a realização do depósito. Todavia, é possível que o credor tenha escolhido extrajudicialmente a prestação, mas o devedor, imbuído de má-fé, proponha a demanda consignatória. Assim, ao receber a citação para realizar a escolha, pode o devedor contestar, a fim de demonstrar a mora do autor da demanda.

Sob o CPC/1973 a doutrina preconizou a suspensão do prazo para contestar, até que houvesse escolha do bem pelo credor e oferta pelo devedor.²¹⁹ Poder-se-ia criticar esse entendimento ao argumento de que a suspensão não seria necessária, pois se o bem for escolhido e não houver entrega, o processo será extinto sem resolução de mérito (art. 542, parágrafo único, do CPC/2015). Por outro lado, a escolha e a entrega do bem ensejam a procedência da demanda (art. 546, parágrafo único, do CPC/2015), de modo que também nesse caso não haveria necessidade de suspender o prazo para resposta.

Contudo, há de se notar que o credor pode especificar o bem, mas o autor, em vez de entregar o que fora escolhido, pode pretender dar outro em seu lugar. Em outras palavras, é possível que o devedor descumpra a escolha do réu, ocasião na qual há justo motivo para a recusa, justificando-se a contestação (art. 544, II, do CPC/2015). Por esse motivo, nas obrigações alternativas ou nas de gênero, o prazo para contestar deve ficar suspenso até que ocorra o depósito, pois é possível que o autor da demanda descumpra a especificação realizada pelo credor, o que dará ensejo à contestação. Se não fosse suspenso o prazo para resposta, o réu não poderia se defender quando o autor não entregasse o objeto que fora selecionado.

4. Mandado citatório

Considerado o intrincado procedimento da demanda consignatória fundamentada na inércia do credor em especificar o objeto da prestação (art. 342 do CC/2002; art. 543 do CPC/2015), o mandado citatório deverá ser cuidadosamente redigido. Primeiramente, deve interpelar o credor a especificar os bens que constituirão a prestação, sob pena de a escolha recair sobre o devedor, autor da demanda. Deve, ainda, comunicá-lo sobre o lugar, dia e hora em que se dará a oferta real. Por fim, deve assinalar que a contagem de prazo para resposta se iniciará apenas a partir do depósito.

Os prazos para escolha do objeto da prestação e para oferecer resposta são contados na forma preconizada no art. 219 do CPC/2015, de modo que não são considerados os dias não úteis.

Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I – não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II – foi justa a recusa;

III – o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV – o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.

1. Cognição na demanda consignatória

Como demonstrado no item 7 dos comentários ao art. 539, a cognição na demanda consignatória não é parcial, de modo que será possível debater sobre a origem do débito e a validade da relação obrigacional. Desse modo, quaisquer alegações que controvertam sobre o débito poderão ser apreciadas no âmbito da consignação. Essa é a premissa que deve orientar a interpretação do art. 544 do CPC/2015.

2. Resposta do réu

Tal como ocorria com o art. 896 do CPC/1973, o artigo em análise não se aplica apenas às demandas consignatórias fundamentadas na recusa do credor em receber o pagamento ou em dar quitação. Independentemente da causa de pedir, poderá o réu invocar o art. 544, III e IV.²²⁰ Por outro lado, os dois primeiros incisos, logo se vê, ficam adstritos à consignatória baseada na recusa do credor (art. 335, I, CC/2002).

Conquanto o dispositivo, assim como o art. 542, II, faça referência apenas à contestação, o réu também poderá reconvir, desde que haja conexão com a demanda principal ou com fundamento da defesa, conforme aponta o código no art. 343.²²¹ A doutrina já admitia a reconvenção sob o Código Buzaid e inexistia motivo para a modificação desse entendimento à luz do diploma vigente.²²² Com efeito, considerada a identidade substancial entre o art. 343 do código vigente e o art. 315 do diploma revogado, não há razão para tolher a propositura de reconvenção na demanda consignatória.

Além da reconvenção, que pode ser veiculada na própria contestação (art. 343, CPC/2015), o réu pode invocar, preliminarmente ao mérito, as matérias alegadas no art. 337. A alegação de incompetência relativa, prevista no inc. II do dispositivo referido, traz à tona interessante questão. Afirmou-se, sob o código revogado, que em relação ao tema o réu poderia optar: ser-lhe-ia possível apresentar exceção de incompetência ou contestar.²²³

Ao alegar a incompetência territorial do juízo, sem se insurgir, no mérito, contra o lugar em que foi realizado o depósito, o réu realmente sinaliza sua intenção de receber, desde que o depósito seja transferido para o foro competente. O acolhimento da alegação de incompetência relativa ensejará a remessa dos autos e do bem ou da quantia depositados ao juízo competente, no qual o réu receberá o depósito, exonerando o devedor. A omissão do demandado em invocar, preliminarmente, a incompetência do juízo, acarreta a prorrogação, nos termos do art. 65 do CPC/2015. Se o réu somente contestar, trazendo o tema como matéria meritória, a improcedência da demanda manterá o autor vinculado à obrigação.

Se o depósito em lugar incorreto for alegado tanto em preliminar, a fim de que o processo seja encaminhado ao juízo competente, quanto no mérito, com o escopo de que a demanda seja julgada improcedente, crê-se que o acolhimento da alegação de incompetência, com a remessa dos autos e da coisa ou quantia depositada ao juízo competente, ensejará, neste juízo, a procedência da demanda desde que o réu tenha invocado somente a incorreção do lugar. Se a resposta contiver

apenas alegação preliminar, o acolhimento ensejará a remessa ao juízo competente.

Também poderá o réu se valer da arguição de impedimento ou de suspeição, mediante petição específica, em conformidade com os arts. 146 e ss. do CPC/2015. A arguição deve ser suscitada em quinze dias a partir do conhecimento do fato, sendo certo que à época da resposta o réu pode desconhecer o motivo caracterizador da suspeição ou do impedimento, nada obstando que a alegação ocorra posteriormente.²²⁴

Quanto à contestação, ainda que o objeto litigioso se limite à regularidade do depósito, com a consequente exoneração do devedor, é certo que poderão ser invocadas questões jurídicas que se refiram ao crédito e à validade da obrigação. Assim, a despeito da especificação prevista no art. 544, poderão ser invocadas outras matérias além das indicadas no dispositivo, não havendo dúvida, por outro lado, que os incisos permitem grande amplitude na discussão sobre o débito.²²⁵

Como já visto nos comentários ao art. 542 (item 4), a audiência conciliatória regulada no art. 334 do CPC/2015 é incompatível com o procedimento especial projetado para as demandas consignatórias, de modo que a contagem do prazo para resposta obviamente não atenderá ao disposto no art. 335, I, do CPC/2015.

3. Citação e contagem do prazo para resposta

Tendo a citação se realizado pelo correio ou por oficial de justiça, o prazo para resposta começa a ser contado no primeiro dia útil subsequente à juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, I e II, do CPC/2015 c/c art. 224, *caput* e § 1.º, do CPC/2015).²²⁶ Quando a citação ocorrer mediante ato do escrivão, iniciar-se-á a contagem do prazo no dia útil seguinte à realização do ato (art. 231, III, do CPC/2015 c/c art. 224, *caput* e § 1.º, do CPC/2015).

Citado o réu por edital, o começo do prazo será o dia útil seguinte ao fim da dilação concedida pelo juiz (art. 231, IV, do CPC/2015 c/c art. 224, *caput* e § 1.º, do CPC/2015).²²⁷ Desse modo, será primeiramente contabilizado na contagem de prazo o dia útil posterior ao do começo, como preconiza o art. 224, *caput*, do CPC/2015. Atente-se para a modificação em relação ao que dispunha o art. 241, V, do CPC/1973, de acordo com o qual o prazo se iniciaria assim que se encerrasse o lapso temporal assinado pelo juiz. De acordo com o disposto no código vigente, se o fim da dilação cair na segunda-feira, considerar-se-á a terça-feira como o dia do começo do prazo. Assim, realizada a exclusão determinada no art. 224, *caput*, o prazo para resposta começará a ser contado na quarta-feira, salvo se um dos dias não for útil, ocasião na qual haverá prorrogação até o dia útil seguinte.

No art. 246, § 1.º,²²⁸ o código prevê a citação eletrônica se o réu for empresa pública ou privada, ocasião na qual o dia do começo será o dia útil subsequente à consulta da citação ou do término do prazo assinalado para a consulta (art. 231, V, do CPC/2015 c/c art. 224, *caput* e § 1.º, do CPC/2015). Nesse caso, a contagem do prazo se iniciará no dia útil seguinte ao dia do começo, conforme preconiza o art. 224, *caput*. Em outras palavras, realizada a consulta ao ato citatório na segunda-feira, o dia do começo do prazo será terça-feira, iniciando-se a contagem do prazo na quarta, em razão da exclusão do dia do começo, determinada no art. 224 do CPC/2015. Essa modalidade citatória não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte.

Realizando-se a citação por carta precatória ou rogatória, o começo do prazo corresponderá à data de juntada aos autos do comunicado eletrônico, pelo juízo deprecado ao juízo deprecante (art. 232 do CPC/2015), ou à data de juntada aos autos da própria carta, quando inoportunizar a comunicação eletrônica (art. 231, VI, do CPC/2015). Será computado para apresentação da resposta o primeiro dia útil posterior ao dia do começo, como assenta o Código de Processo Civil no art. 224, *caput* e § 1.º.

Qualquer que tenha sido a modalidade de citação, o prazo de quinze dias será contado à luz do art. 219 do CPC/2015, sendo excluídos do cômputo os dias não úteis.

Já se viu nos comentários ao art. 543 que nas hipóteses de obrigação alternativa ou de gênero, até que ocorra o depósito, ficará suspenso o prazo para contestar. Isso decorre da necessidade de que o credor realize a concentração ou a concretização da prestação, caso se trate, respectivamente, de obrigações alternativas ou de gênero. Ressalvado esse caso, nas demais hipóteses de demanda consignatória o prazo para resposta começará a ser contado em conformidade com o disposto no art. 231 do CPC/2015.

4. Inexistência de recusa ou mora em receber a prestação

Quando a demanda consignatória tiver sido proposta com fundamento na recusa (art. 335, I, do CC/2002; art. 164, I e II, do CTN), o réu pode alegar na contestação não ter resistido ao recebimento da prestação.

Na análise do tema avulta em importância a caracterização do débito como quesível ou portátil. Como já visto, dívidas quesíveis são aquelas que o credor deve receber junto ao domicílio do devedor. Portáteis, são as dívidas que devem ser adimplidas no domicílio do credor. Em regra, serão as dívidas quesíveis, pois o pagamento será realizado no domicílio do devedor (art. 327 do CC/2002). Todavia, admite-se convenção em sentido contrário.

Recai sobre o devedor, autor da demanda, o ônus de comprovar a recusa do credor em receber a prestação ou em dar quitação quando a dívida for portátil. Se a dívida for quesível, o demandante alegará a omissão do réu, a quem compete demonstrar que se dirigiu ao devedor para receber a prestação.²²⁹

Sequer será possível ao autor, quando a dívida for quesível, comprovar a recusa. Caber-lhe-á, nesse caso, alegar a omissão do credor em buscar a prestação. Assim, incumbe ao credor, réu na demanda, demonstrar que se não omitiu. Consideradas as especificidades da questão, sendo nítida a maior facilidade do credor em demonstrar que se dirigiu ao réu, ao passo que este dificilmente conseguiria comprovar que o credor não fora até ele, cabe a inversão prevista no art. 373, § 1.º, a fim de que sobre o réu recaia o ônus de comprovar que se dirigiu até o devedor, não tendo este realizado a oferta.

5. Justa recusa

O autor pode alegar a recusa e o réu reconhecê-la, reputando-a justa, entretanto. É essa a hipótese prevista no art. 544, II, do CPC/2015. “Justa recusa” é cláusula aberta, sendo possível ao réu invocar quaisquer alegações conducentes à impossibilidade de aceitar o pagamento. A demanda consignatória, como assinalado alhures, é plenária, inexistindo limitação sob o plano do direito material. Não ocorre, no âmbito dessas ações, limitação semelhante à que ocorre nas possessórias, em que é proibido discutir com fundamento no domínio.

Esse entendimento, contudo, não era pacífico sob o código revogado. Sustentou-se que o credor somente poderia invocar as razões indicadas no Código Civil para a recusa, de modo que nem sempre seria possível debater sobre a validade da obrigação, o que levaria à prolatação de sentença “sob reserva”.²³⁰ Em outras palavras, afirmava-se que alguns temas, cuja cognição não pudesse ocorrer na ação consignatória, seriam passíveis de análise em outra demanda.

No item 7 dos comentários ao art. 539, já se defendeu a ideia que a cognição nas demandas de consignação é ampla. Isso significa que a “justa recusa”, cláusula aberta, poderá ensejar discussão sobre a validade do contrato. Em sintético rol de matérias cognoscíveis na demanda consignatória, pode-se indicar a inexistência da relação obrigacional que embasaria o pagamento, a não caracterização do réu como credor, a novação, a realização de oferta antes do vencimento da obrigação e a nulidade do ato jurídico.²³¹ Pode-se acrescentar a esse elenco a ocorrência de compensação ou de remissão, ocasião na qual, extinto o direito creditório, seria justa a recusa da oferta.

Em resumo, pode o réu invocar questões jurídicas atinentes aos planos da existência, validade e

eficácia da relação obrigacional. A sentença fará coisa julgada nos limites do objeto litigioso e das questões prejudiciais porventura enfrentadas (art. 503, *caput* e § 1.º, do CPC/2015). Ficando coberta pela coisa julgada material, a questão não poderá ser reapresentada em outra demanda, razão pela qual deve ser afastada a tese de que a sentença, nas demandas consignatórias, seria proferida “sob reserva”.

Como se verá no item 7, o STJ, sob o código anterior, pacificou a tese de que a insuficiência do *depósito* enseja a procedência parcial da demanda, com a exoneração não integral do devedor. O acolhimento parcial da demanda era decorrência, sob o código anterior, da locução “com a consequente liberação parcial do autor”, reproduzida no art. 545, § 1.º, do código vigente. Como a finalidade do autor, ao promover a demanda consignatória, é ser liberado da obrigação, tem-se que a exoneração de parcela da prestação equivale à parcial procedência do pedido. Correto, portanto, o posicionamento do STJ. Mas a questão ainda exige maiores considerações.

Se, proposta demanda consignatória, for comprovada a *oferta* em valor insuficiente, caberá ao devedor, autor da demanda, arcar com as custas e honorários advocatícios, pois fora justa a recusa do credor, que tem direito a receber a prestação na íntegra. Esse entendimento tem como premissa a *oferta extrajudicial* em valor insuficiente, mas o *depósito* no valor correto. A procedência da sentença extinguirá a obrigação, mas será incabível a condenação do réu ao pagamento das custas, pois fora justa a recusa do credor.

Se o *depósito* for insuficiente, impõe-se a decretação de parcial procedência da demanda. O devedor não somente continuará vinculado à obrigação pelo saldo remanescente, como sofrerá cumprimento por execução nos mesmos autos, em razão da constituição de título executivo, na forma do art. 545, § 2.º, do CPC/2015. Também nesse caso o devedor, autor da ação, arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, pois sua conduta, ao depositar em valor inferior ao devido, deu margem à contestação do credor. Saliente-se, todavia, que o devedor poderá complementar o depósito.

6. Depósito no lugar incorreto ou fora do prazo

No art. 544, III, é prevista a alegação de que o *depósito* ocorreu em lugar incorreto ou foi realizado intempestivamente. Não se trata, aqui, da oferta de pagamento, mas do *depósito*.

Em relação ao tempo, o art. 542, I, concede cinco dias para que o depósito seja realizado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 542, parágrafo único, do CPC/2015). Quer seja a questão analisada sob o aspecto da superveniente falta de interesse processual, quer o seja sob o da ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular, o resultado será sempre a extinção do processo mediante sentença terminativa, não sendo apreciado o mérito da demanda consignatória (art. 485, IV e VI, do CPC/2015).

No tocante à intempestividade da *oferta* de pagamento, convém reiterar que a mora do devedor não a inviabiliza enquanto a prestação ainda tiver utilidade para o credor, conforme resulta do art. 395, parágrafo único, do CC/2002. Esse dispositivo permite visualizar a diferença entre mora e inadimplemento. Na mora o pagamento ainda é possível, ao passo que no inadimplemento não mais o é, quer a impossibilidade seja material, quer decorra exclusivamente do desinteresse do credor.

Adverte-se, na doutrina, que a prestação pecuniária jamais se torna inútil ao credor, de modo que a mora do devedor não inviabilizará a consignação, mas ensejará o depósito com os acréscimos decorrentes do atraso.²³² Esse entendimento deve ser ressalvado nas hipóteses em que o credor tiver aplicado cláusula resolutória ou, por qualquer outra forma, tenha inviabilizado a purga da mora pelo devedor.²³³ Quando isso não ocorrer, ou seja, quando a prestação ainda for útil ao credor e a mora do devedor for passível de emenda, deve-se admitir a consignação em pagamento.²³⁴

No item 2 dos comentários a este art. 544, foi assinalado que o réu poderá escolher entre alegar

a incorreção do lugar do depósito em preliminar ou como matéria de mérito. Se invocar o tema preliminarmente, sua intenção se restringirá a submeter o processo ao juízo territorialmente competente. Com a remessa dos autos, poderá levantar o depósito e, desse modo, exonerar o devedor. Todavia, invocando o tema no mérito da demanda, o réu pleiteia sua improcedência, de modo a manter o devedor vinculado à obrigação.

Se o réu se insurgir contra a inadequação do lugar da *oferta* de dívida portável, deverá alegar justa recusa, caracterizando-se a hipótese prevista no art. 544, II, do CPC/2015.²³⁵ Saliente-se que o erro na indicação do dispositivo evidentemente não inviabiliza a apreciação da matéria.

7. Depósito insuficiente

Note-se que no art. 544, IV, tal como ocorre no inc. III, a referência não é à *oferta*, mas ao *depósito*. Se a oferta de pagamento tiver ocorrido em valor parcial, caberá ao credor alegar a justiça da recusa (art. 544, II, do CPC/2015).

O pagamento deve ocorrer no valor correto, não sendo o credor obrigado a aceitar prestação diversa da que fora pactuada nem mesmo quando for mais valiosa, conforme se depreende do art. 313 do CC/2002.²³⁶ Quando se tratar de obrigação pecuniária, regra expressa do Código Civil determina que o pagamento ocorra pelo valor nominal.²³⁷ O mesmo vale para as demais obrigações, que deverão ser pagas na quantia exata, não sendo o credor obrigado a aceitar menos do que fora pactuado.

Quando a contestação se fundar na insuficiência do depósito, recai sobre o credor o ônus de indicar o valor devido, sob pena de não ser admitida sua alegação (art. 544, parágrafo único).²³⁸ Indicado, pelo réu credor, o valor considerado correto, poderá o autor complementá-lo, sendo lícito ao credor levantar a parte incontroversa, constituindo a sentença, que reconhecer a não integralidade, título executivo em favor do réu (art. 545, §§ 1.º e 2.º, do CPC/2015).

O STJ, sob o código revogado, consolidou entendimento segundo o qual, quando a recusa fosse injusta, em razão da abusividade de encargos, mas o depósito ocorresse em valor insuficiente, haveria procedência parcial da demanda.²³⁹ A parcial procedência da demanda decorria, sob o código anterior, da expressão “com a consequente liberação parcial do autor”, reproduzida no art. 545, § 1.º, do diploma vigente. Ora, liberação parcial significa procedência parcial do pedido do devedor, autor da demanda consignatória. O acolhimento parcial do pedido não desobriga integralmente o devedor, que pode ser executado pelo saldo remanescente nos mesmos autos, consoante aponta o art. 545, § 2.º, do CPC/2015.

8. Rol exemplificativo

Admitindo-se que a cognição nas demandas consignatórias é ampla, conclui-se, sem dificuldade, que o rol de matérias alegáveis na contestação, previsto no art. 544, é meramente exemplificativo. Ainda quando considerada a amplitude da locução “justa recusa”, mencionada no inc. II, é necessário reconhecer que o elenco do art. 544 não exaure as matérias passíveis de arguição.

Assinala-se, na doutrina, que o réu poderá alegar a incorreção da afirmação de que o lugar em que está é incerto ou de acesso difícil. Pode ser invocada, ademais, a ciência prévia do devedor sobre a dificuldade de acesso, bem como sua anuência com a entrega da dívida no local, a despeito das dificuldades. Também é passível de arguição a inexistência de dúvida sobre quem deva receber o pagamento.²⁴⁰ Ademais, pode o réu questionar sua alegada incapacidade, ou, ainda, a inexistência de litígio sobre o objeto do pagamento. Diante do caso concreto caberá ao credor apresentar as alegações conducentes à improcedência da demanda, reconhecendo a incompletude do rol trazido no art. 544.

9. Revelia

O art. 897, do CPC/1973 determinava que o não oferecimento de contestação, desde que se concretizassem os efeitos da revelia, ensejava a procedência do pedido.²⁴¹ O dispositivo foi parcialmente repetido no art. 546 do código vigente, sendo excluída, contudo, a primeira parte, precisamente a que continha a problemática locução que vinculava a revelia à procedência da demanda.

Ao atrelar a revelia ao acolhimento da pretensão consignatória, o art. 897 causava perplexidade, gerando aceso debate na doutrina. Por um lado, sustentou-se que o juiz não estava adstrito a uma aplicação mecânica do dispositivo, sendo possível decretar a improcedência da demanda quando não estivesse convencido sobre os argumentos do autor.²⁴² De outro, afirmou-se que o silêncio do credor faria presumir sua anuência com o pagamento em consignação, de modo que a dilação probatória não atenderia aos interesses de quaisquer das partes.²⁴³

Reconhecer que a pretensão liberatória, objeto da consignação, deve ser analisada em procedimento especial, atento às especificidades do direito material discutido, não significa defender o atrelamento do juiz aos excessos a que poderia levar a aplicação literal do art. 893 do Código Buzaid. Assim, sempre que as alegações do autor se mostrassem frágeis, incapazes de formar a convicção do juiz, a revelia não poderia, por si só, ensejar o acolhimento do pedido. O julgador poderia não apenas determinar a produção de provas, mas, ao final da instrução, julgar improcedente a demanda.

Como o CPC/2015 não reproduz a regra que tantos problemas suscitou sob a vigência do código revogado, a revelia, na demanda consignatória, produzirá os mesmos efeitos que sua ocorrência gera nas demandas processadas pelo procedimento comum. Desse modo, tendo o réu deixado de oferecer contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato deduzidas pelo autor,²⁴⁴ ressalvadas as hipóteses previstas no art. 345 do CPC/2015.²⁴⁵ A despeito da revelia, poderá o juiz determinar a produção de provas e julgar improcedente a demanda, cabendo-lhe, igualmente, extinguir o processo sem resolução de mérito.²⁴⁶

É digno de nota que o réu, de acordo com o art. 343, § 6.º, do CPC/2016, pode se limitar a reconvir.²⁴⁷ Nesse caso, se a reconvenção houver contrastado o fato constitutivo do direito do autor, não poderá ser presumida a veracidade das alegações de fato. Em outras palavras, a impugnação ao fato constitutivo impede a presunção de veracidade das alegações do autor ainda que o réu tenha apenas oferecido reconvenção. Esse posicionamento, válido para o procedimento comum, aplica-se também ao procedimento especial de consignação em pagamento.

10. Procedimento comum

Apresentada a resposta, serão adotadas as regras do procedimento comum.²⁴⁸ Desse modo, cabe ao juiz, nos termos do art. 357 do CPC/2015, resolver questões processuais pendentes, delimitar questões de fato e de direito, fixar o ônus da prova e, se necessário, realizar audiência de instrução e julgamento. As partes poderão realizar o saneamento compartilhado, previsto no art. 357, § 2.º, do CPC/2015.²⁴⁹ Também será possível, desde que as partes sejam plenamente capazes, a celebração de convenções processuais, na forma prevista no art. 190 do código processual.²⁵⁰ Os elementos do caso concreto é que permitirão verificar a conveniência da medida.

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1.º No caso do *caput*, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2.º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

1. Complementação do depósito

O art. 545 concede ao autor da demanda consignatória a possibilidade de complementar o depósito, no prazo de dez dias, contado a partir da intimação sobre a manifestação do credor acerca da insuficiência do montante depositado.²⁵¹ Viu-se, nos comentários ao dispositivo anterior, que a incompletude do depósito é uma das matérias cuja possibilidade de alegação é expressamente prevista (art. 544, IV, do CPC/2015). Quando invocá-la, deve o credor indicar o valor que entende devido (art. 544, parágrafo único, do CPC/2015), sob pena de inadmissibilidade de sua alegação.

O dispositivo concede ao autor o prazo de dez dias para complementar o depósito. Trata-se de prazo preclusivo, findo o qual será extinto o direito de complementar. Ultrapassado o decêndio, a complementação poderá ser objeto de composição entre as partes, mas deixará de ensejar a automática exoneração do devedor.²⁵² O credor pode recusar a complementação, ultrapassado o prazo de dez dias, caso pretenda manter o autor vinculado à relação obrigacional pelo valor remanescente.

A complementação não é dever do autor, mas ônus.²⁵³ Recusando-se a depositar o valor apontado pelo réu, o devedor assume os riscos de sua conduta. Considerado insuficiente o depósito, a demanda será julgada parcialmente procedente, inviabilizando-se sua exoneração integral, como visto nos itens 5 e 7 dos comentários ao art. 544. Por se tratar de prerrogativa do autor cuja não descumprimento pode lhe causar prejuízo, é mais correto conceber a complementação como um ônus, não como uma faculdade processual, em que a liberdade da parte em exercer o ato é máxima, não gerando, a omissão, qualquer consequência.²⁵⁴ Caracteriza-se como ônus relativo, pois a não complementação não prejudicará o autor da demanda nos casos em que a alegação do réu for impertinente. É certo que ultrapassado o prazo de 10 dias o autor não mais poderá complementar o depósito. Todavia, é possível que a quantia depositada seja correta, tendo se equivocado o réu credor, de modo que a omissão do autor não lhe causará qualquer gravame.

No que diz respeito ao *quantum*, deve ser depositado o montante indicado pelo réu, sendo o depósito a menor obviamente incapaz de propiciar a liberação integral do devedor. Doutrina autorizada preconizava a inadmissibilidade de complementação em valor inferior ao apontado na resposta.²⁵⁵ Com esse entendimento não se pode concordar. Embora a consignação de valor insuficiente não libere o devedor, indeferi-la não é a melhor medida, pois mesmo que não cubra todo o débito, o complemento beneficia o réu, que poderá levantá-lo (art. 545, § 1.º, do CPC/2015).

O dispositivo não se aplica somente às obrigações de pagar, mas também às obrigações de dar. Assim, é indiferente que o bem a ser complementado seja dinheiro ou qualquer mercadoria quantificável. Poderá o réu, por exemplo, afirmar na contestação que fora avençada a entrega de cento e dez sacas de soja, não de cem. Nesse caso, sobre o autor recairia o ônus de complementar o depósito.

2. Complementação e julgamento do processo

Ao realizar a complementação, o autor reconhece a insuficiência do que fora depositado, de modo que sua conduta, conquanto acarrete a procedência da demanda consignatória, extinguindo a obrigação, não o isenta do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.²⁵⁶ A solução não é contraditória. Se o depósito foi complementado, então o credor, réu na demanda, tinha razão em recusá-lo. Ocorre que a complementação acarreta a liberação do devedor, de modo que a demanda deve ser acolhida. Não se pode olvidar que a sentença apenas se limita a reconhecer a idoneidade do depósito, de modo que, consignado o valor integral do débito, impõe-se declarar a regularidade do depósito, extinguindo a obrigação.

A sentença proferida com esteio na complementação do depósito é dificilmente enquadrável nas hipóteses elencadas no art. 487 do CPC/2015. Trata-se, indubitavelmente, de julgamento de mérito. Porém, examinada mais detidamente a questão, vê-se que o pedido foi alterado depois da

resposta, em reconhecimento à alegação do réu quanto à insuficiência do depósito.²⁵⁷ À falta de melhor solução, pode-se considerar a sentença em análise como hipótese de procedência do pedido (art. 487, I, do CPC/2015), com a notável especificidade de o acolhimento decorrer de modificação do pleito original em acatamento de alegação apresentada na resposta do réu.

Se, além de invocar a insuficiência do depósito, tiver o credor apresentado outras alegações, o juiz, antes de sentenciar, terá de enfrentá-las, ainda que o autor tenha reconhecido a insuficiência e complementado o depósito.

3. Inadimplemento, resolução do contrato e inviabilidade da complementação

Reproduzindo erro terminológico já contido no dispositivo análogo do código revogado, o art. 545 do CPC/2015 indica a impossibilidade de complementação do depósito quando o inadimplemento acarretar a “rescisão” do contrato. Trata-se, na realidade, de *resolução*.²⁵⁸ Além dos pactos comissórios, de controvertida aplicação, a doutrina indica como exemplo de inadimplemento, a inviabilizar a complementação do depósito, em decorrência da inutilidade da prestação, as roupas de estação ou a entrega de coisa em determinado evento, ultrapassado o qual, a prestação não terá mais qualquer interesse ao credor.²⁵⁹

Em situações nas quais o inadimplemento acarrete a resolução do contrato, sequer será cabível a consignação em pagamento com vistas à exoneração do devedor. O elemento norteador deve ser a utilidade da prestação para o credor. Sempre que ela inexistir, o devedor não poderá ser liberado mediante consignação, sendo igualmente incabível complementar depósito porventura realizado, pois o inadimplemento terá levado à resolução do contrato.

4. Alegação de insuficiência e levantamento da parcela incontroversa

Alegada a insuficiência do depósito, poderá o credor levantar a quantia ou a coisa depositada, sendo o devedor parcialmente exonerado (art. 545, § 1.º). Trata-se, aqui, de julgamento antecipado parcial do mérito, com fundamento no art. 356, I, do CPC/2015, em decorrência da incontrovérsia do valor depositado. Caberá definir, no curso do processo, o valor total do débito, mas sobre o montante depositado não há controvérsia, o que permite o levantamento pelo réu, sem que se caracterize preclusão lógica no tocante à alegação de insuficiência.

O réu poderá realizar o levantamento ao longo do processo, desde que inexistir incompatibilidade com alguma das matérias de defesa, como, exemplificativamente, a alegação de que o crédito inexistente.²⁶⁰

Embora o art. 545, §1º, faça referência expressa apenas à insuficiência do depósito (CPC, art. 544, inc. IV), o levantamento do valor depositado pelo autor pode ocorrer em outras hipóteses, desde que a demanda consignatória seja julgada improcedente. Assim, exemplificativamente, se houver reconhecimento da alegação de justa recusa (CPC, art. 544, inc. II), a improcedência da demanda autoriza o levantamento do valor depositado, mediante aplicação extensiva do art. 545, §1º, do CPC. Ao depositar, o autor reconhece que ao menos aquele valor é devido. A posterior improcedência da demanda, com o reconhecimento da legitimidade da recusa, autoriza o levantamento da quantia depositada logo após a prolação da sentença, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.²⁶¹

5. Apuração do débito, execução e possibilidade de liquidação

O juiz deve procurar determinar o *quantum debeatur* quando for reconhecida a insuficiência do depósito. Determinado o montante devido, será proferida sentença condenatória, podendo o credor, réu na demanda, deflagrar o cumprimento de sentença por execução. Trata-se de situação curiosa, na qual o réu terá a constituição de título executivo em seu favor sem ter apresentado reconvenção.²⁶² Aliás, o réu sequer tem interesse em reconvir, pois o título executivo é constituído em atenção ao que dispõe o art. 545, § 2.º, do CPC/2015, sendo desnecessária a reconvenção.²⁶³

Para a satisfação do direito creditório objeto da condenação, poderá o credor se utilizar dos meios atípicos. Com efeito, o art. 139, IV, do CPC/2015, permite que o juiz, ao cumprir ordem judicial, empregue técnicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, inclusive nas demandas que tenham por objeto prestação pecuniária.²⁶⁴ Prevista a atipicidade das técnicas executivas, para a satisfação do direito creditório do réu o juiz não está limitado à técnica da condenação seguida de execução por sub-rogação.²⁶⁵ A fase destinada à satisfação do direito creditório ocorrerá na mesma relação processual.

Não se admitia a liquidação de sentença no CPC/1973, de modo que a última locução do art. 545, § 2.º, introduz importante modificação em relação ao que dispunha o código revogado.²⁶⁶ Com efeito, a possibilidade de liquidação decorre da expressão “facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária”. Assim, se não for possível a apuração do *quantum debeatur* até a prolação da sentença, pode o juiz proferir condenação genérica, desde que a prova lhe permita constatar a insuficiência do depósito, sendo determinado o valor remanescente em liquidação de sentença, da qual se seguirá o cumprimento por execução.

6. Prestações sucessivas e complementação

O art. 542 do CPC/2015, como já visto, permite a consignação de prestações sucessivas, desde que realizada em até cinco dias do vencimento. Crê-se que seria possível, tal como ocorre quando se trata de uma só prestação, complementá-las em conformidade com o que foi apontado pelo credor na contestação.²⁶⁷ Seria pouco razoável tratar diferentemente situações que são essencialmente iguais. Assim, intimado o réu sobre a prestação depositada, poderá o autor complementá-la, contando, para tanto, com o prazo de dez dias assinalado no art. 545, *caput*, do CPC/2015.

Art. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação.

1. Procedência do pedido e exoneração do devedor

A sentença proferida na ação de consignação é declaratória.²⁶⁸ Limita-se a reconhecer a regularidade do depósito e sua aptidão para exonerar o devedor. Não é a sentença que desconstitui a relação obrigacional, liberando o depositante. A exoneração é efeito do depósito regular e o provimento jurisdicional se limita a declará-lo válido e eficaz, donde resulta sua aptidão para extinguir a obrigação. Contra a sentença proferida na demanda consignatória cabe apelação (art. 1.009 do CPC/2015).

2. Condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios

Julgada procedente a demanda, reconhece-se que a conduta do réu caracterizou resistência injustificada ao adimplemento, o que autoriza sua condenação ao pagamento das custas e honorários, conforme assenta o art. 546, parágrafo único, do CPC/2015. Nos comentários ao art. 545, foi visto que essa regra comporta uma exceção: quando houver complementação do depósito, em conformidade com a contestação do credor, embora a demanda seja julgada procedente, caberá ao devedor demandante arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Por outro lado, quando o pedido de consignação não for acolhido, reconhece-se que não havia motivo para que o pagamento se realizasse de forma diferente da que fora convencionada, de modo que o autor deverá ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

3. Levantamento do depósito e quitação

De acordo com o art. 546, parágrafo único, se o credor, réu da demanda, comparecer ao juízo,

levantar o depósito e der quitação, também será proferida sentença de procedência, extinguindo-se a obrigação e liberando-se o devedor. Trata-se, como assinala a doutrina, de hipótese análoga ao reconhecimento do pedido.²⁶⁹ Considerando que o dispositivo determina a extinção do processo com resolução de mérito, não é admissível extingui-lo como se houvesse perda de objeto, a qual caracteriza ausência superveniente de interesse processual e leva à carência da demanda.

Da recusa em juízo de levantar o depósito não se pode depreender que o credor tenha igualmente se recusado a receber a oferta extrajudicial.²⁷⁰ Como sabido, a citação, na demanda consignatória, cumpre a finalidade de integrar o credor à relação processual e a de interpelá-lo para, querendo, realizar o levantamento da coisa ou quantia depositada, no dia e lugar indicados pelo juiz.²⁷¹ Assim, o réu pode comparecer e não levantar o depósito, conduta da qual nada se pode inferir. A recusa da oferta, realizada antes da propositura da ação, é tema que será dirimido por meio da produção de provas.²⁷² A despeito de não levantar o depósito, o réu pode não ter se recusado a receber a prestação. Se isso ficar demonstrado, a demanda terá de ser julgada improcedente.

Segundo o art. 338 do CC/2002, enquanto não houver aceitação do depósito pelo credor ou impugnação, poderá o devedor requerer seu levantamento, arcando com as despesas decorrentes do depósito, permanecendo a obrigação para todas as consequências jurídicas.²⁷³ Em outras palavras, se levantar o depósito que fizera, o devedor volta a assumir os riscos da prestação, tendo ainda de arcar com eventuais encargos decorrentes da mora. O arrependimento do devedor ocasiona o retorno à situação precedente ao depósito.²⁷⁴ Todavia, embora o depósito seja desconsiderado com a retirada pelo devedor, sua realização caracteriza a interrupção da prescrição.²⁷⁵

Note-se que a relação obrigacional não é extinta se o credor, ao contestar, tiver alegado a insuficiência do depósito. Nesse caso, o levantamento ensejará apenas exoneração parcial do devedor, prosseguindo o processo a fim de que seja apurado o valor restante.

Art. 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito.

1. Dúvida e litisconsórcio necessário passivo

O dispositivo se aplica quando o devedor desconhecer o credor, quando houver dúvida sobre quem deva receber ou quando existir litígio sobre o objeto do pagamento, hipóteses respectivamente contempladas no art. 335, III, IV e V, do CC/2002. Admite-se, portanto, a propositura de demanda baseada em dúvida subjetiva ou objetiva.²⁷⁶ Tratando-se de obrigação tributária, a exigência, por mais de um ente tributante, de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador, também permite a consignação (art. 164, III, do CTN).

A redação do art. 547 é superior à do art. 895 do CPC/1973, cuja locução “requererá o depósito e a citação dos que o disputam” aparentemente limitava a consignação à hipótese de litígio sobre o objeto do pagamento. A crítica que a doutrina fizera ao dispositivo resultou em proposição normativa mais esboçada, na qual o alcance da consignatória motivada por dúvida não sofre restrições.²⁷⁷

Como a demanda se fundamenta na dúvida sobre o titular do direito de crédito, nessa modalidade de consignação o devedor não precisa realizar, previamente à propositura da demanda, a oferta do bem.²⁷⁸ Nem seria possível que isso ocorresse, pois a premissa para a consignação em comento é o desconhecimento sobre o credor, de modo que não há um sujeito definido a quem a prestação possa ser oferecida.

Já foi mencionado nos comentários ao art. 539 que a dúvida deve ser razoável.²⁷⁹ Se não for, a demanda consignatória será julgada improcedente. Pouco importa, para o ajuizamento da demanda consignatória, que a dívida seja quesível ou portátil, pois as duas modalidades admitem a consignação.

Na dicção do dispositivo em comento, será requerida a citação dos “possíveis titulares do crédito”. Com essa expressão, aponta-se para a necessidade de que sejam citados todos os possíveis credores.²⁸⁰ Caracteriza-se, portanto, litisconsórcio passivo necessário, incumbindo ao devedor dirigir a demanda contra qualquer sujeito que ele repute como possível credor.²⁸¹ Mesmo que haja processo entre os postulantes ao crédito, o autor pode indicar, no polo passivo da demanda consignatória, terceiro que não figure na relação processual já instaurada. Deve prevalecer a tutela ao direito de exoneração do devedor, o que lhe permite ampliar o rol de possíveis interessados, os quais serão réus na demanda consignatória.

A necessariedade é plenamente visível se já houver sido instaurado litígio entre os possíveis credores, mas poderia ser questionada quando a dúvida fosse meramente subjetiva. Contudo, mesmo nesta hipótese, o carácter necessário do litisconsórcio é indiscutível. Ao expor sua dúvida sobre a titularidade de “A” ou de “B”, incumbe ao devedor arrolar ambos no polo passivo da demanda, donde resulta a inequívoca necessariedade do litisconsórcio.

2. Citação e depósito

Quando o devedor não ignorar os possíveis credores, a citação deve ser pessoal. Ignorando-os, incumbe-lhe requerer citação por edital (art. 246, IV, do CPC/2015 c/c art. 256, I e II, do CPC/2015).²⁸² Nota-se, assim, que a modalidade de citação dependerá do fundamento da demanda consignatória.

Realizada a citação pelo correio ou por oficial de justiça, conta-se o prazo para resposta a partir do primeiro dia útil seguinte à juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, I e II, do CPC/2015 c/c art. 224, *caput* e § 1.º, do CPC/2015). Na citação por edital, o começo do prazo será o dia útil subsequente ao fim da dilação assinada pelo juiz (art. 231, IV, do CPC/2015 c/c art. 224, *caput* e § 1.º, do CPC/2015). O primeiro dia a ser contado será o dia útil posterior ao do começo, na forma preconizada no art. 224, *caput*, do CPC/2015. Todos os prazos serão contados em consonância com o art. 219 do CPC/2015.

Reitere-se que a citação não tem como objetivo interpelar os possíveis credores para que realizem o levantamento do depósito. Havendo dúvida sobre o legítimo titular do direito creditório, obviamente não seria possível que um dos credores levantasse. A citação tem como escopo não somente integrá-los ao processo, mas intimá-los para que comprovem sua titularidade.

O depósito deve ser realizado pelo autor em atenção ao disposto no art. 542, I, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 542, parágrafo único). Conquanto os possíveis credores não sejam citados para levantar o depósito, mas para comprovar a titularidade do crédito, não seria razoável que o devedor arcasse com os riscos da prestação ou com os juros e encargos decorrentes da mora.²⁸³

Art. 548. No caso do art. 547:

I – não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas;

II – comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano;

III – comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum.

1. Considerações gerais

Em evidente conexão com o dispositivo anteriormente comentado, o art. 548 dispõe sobre o procedimento quando não houver comparecimento de nenhum dos réus, quando somente um deles comparecer e quando mais de um deles o fizer. O termo “comparecendo” se refere à

apresentação de resposta pelos demandados e dele não se pode extrair a ideia de que seria necessário realizar audiência de oblação. Não haveria sentido na designação de audiência de oferta, nem em estabelecimento de data para o pagamento, pois a dúvida sobre o verdadeiro credor impede a entrega da prestação.²⁸⁴ Melhor seria se, em vez de se referir ao comparecimento dos postulantes, tal como fizera o art. 898 do código revogado, o dispositivo em análise aludisse à resposta dos demandados.

O dispositivo se situa imediatamente depois da previsão de demanda consignatória quando houver dúvida sobre o legítimo credor. Acatou-se, na ordem dos artigos, crítica realizada pela doutrina à disposição constante no CPC/1973, a mesclar dispositivos sobre a consignação fundada na recusa do credor com outros, relacionados à dúvida sobre o titular da prestação.²⁸⁵

Houve sensível mudança em relação ao texto do art. 898 do código revogado. O inc. I, referindo-se ao não comparecimento de nenhum dos possíveis credores, determina que se proceda em conformidade com o procedimento previsto para as coisas vagas. O estatuto anterior, em lamentável imprecisão, referia-se à arrecadação de bens de ausentes, procedimento em tudo inaplicável à espécie. Com esse avanço, manteve-se, lamentavelmente, a referência ao procedimento comum no inc. III, quando seria melhor que se aludisse ao concurso de credores.²⁸⁶

2. Procedimento em duas fases

Na contestação, modalidade usual de resposta nas ações consignatórias motivadas pela dúvida sobre o credor, os réus devem comprovar sua condição de titulares do crédito. Se restringirem sua manifestação a isso, deixando de impugnar o pedido de consignação, o juiz poderá, logo após a resposta, julgar procedente o pedido consignatório, exonerando o devedor.²⁸⁷

Os demandados também podem apresentar matéria tipicamente de defesa, como as alegações de que não há dúvida razoável, de que o depósito foi realizado intempestivamente, em lugar indevido ou em valor insuficiente (art. 544, III e IV, do CPC/2015). Nesse caso, antes que seja definida a titularidade do crédito, com a análise dos fundamentos invocados pelos postulantes, incumbe ao juiz decretar extinta a obrigação e liberar o devedor. Em outras palavras, somente depois da procedência do pedido consignatório, resolve-se a questão concernente à titularidade.²⁸⁸

O procedimento da demanda consignatória fundamentada na dúvida sobre o titular do crédito se divide em duas fases: na primeira, julga-se o pedido de consignação; na segunda, define-se quem é o credor. Não pode haver julgamento sobre a titularidade do crédito sem que antes seja acolhida a pretensão consignatória.²⁸⁹ Caracteriza-se hipótese de fracionamento do mérito.

Se se basear na inexistência de impugnação ao pedido consignatório, o julgamento será proferido com fundamento no art. 356, I, do CPC/2015, em razão da incontrovérsia sobre o tema. Mas basta que um dos postulantes impugne o pedido de consignação, para que a matéria se torne controvertida. Nesse caso bastante peculiar, embora esteja perfeitamente delineado o julgamento antecipado parcial do mérito, com a resolução, antes que a etapa cognitiva seja encerrada, de uma das pretensões que constituem o objeto do processo, dificilmente a decisão pode ser enquadrada em alguma das hipóteses previstas nos arts. 355 e 356 do CPC/2015.

Cuida-se, portanto, de hipótese *sui generis* de julgamento antecipado parcial, não subsumível à previsão contida nos referidos dispositivos. Apesar da impossibilidade de enquadramento da decisão na tipologia prevista nos arts. 355 e 356 do CPC/2015, trata-se, inequivocamente, de decisão interlocutória, assim como o são os outros provimentos por meio dos quais o julgamento do mérito é fracionado. Contra essa decisão, portanto, cabe agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC/2015). Após o trânsito em julgado, referido provimento é rescindível (art. 966 do CPC/2015).

A decisão que julga a primeira fase, ao acolher o pedido do autor, deve lhe ressarcir das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme assenta o art. 546, *caput*, do CPC/2015, desde que tenha havido resistência ao pedido de consignação. O depósito será subtraído do valor necessário à satisfação do autor. A sentença que extinguir o processo, julgando a segunda fase e

atribuindo o crédito a um dos postulantes, realizará nova condenação em honorários advocatícios e custas processuais.²⁹⁰

Admite-se, em tese, que na resposta os postulantes ofereçam reconvenção, conquanto seja difícil conceber hipótese em que um dos postulantes ao crédito reconvenha. Saliente-se que não é necessário reconvir para pleitear a condição de credor. Para tanto, basta se manifestar na demanda consignatória. Os réus também podem arguir a suspeição ou impedimento do juiz, fazendo-o mediante petição específica, na forma preconizada pelo art. 146 do CPC/2015.

3. Omissão dos pretendentes e arrecadação de coisas vagas

A hipótese versada no art. 548, I, diz respeito à omissão dos pretendentes. Encerrado o prazo para resposta, contado em conformidade com o art. 219 do CPC/2015, omitem-se os réus. Nesse caso, após o julgamento do pedido consignatório, será deflagrado o procedimento de arrecadação de coisas vagas (art. 746 do CPC/2015; arts. 1.233 e ss. do CC/2002).

Há, quanto ao tema, considerável avanço em relação ao art. 898 do CPC/1973, o qual se referia à arrecadação de bens de ausentes, procedimento inaplicável à espécie, em razão do desconhecimento sobre a identidade do credor.²⁹¹ Com efeito, como a premissa da demanda consignatória, fundamentada no art. 547, é a ignorância sobre quem seja o legítimo credor, a arrecadação de bens de ausentes é de todo inaplicável, pois se baseia no conhecimento sobre a identidade do ausente.

4. Resposta de apenas um pretendente

Se apenas um dos pretendentes oferecer resposta, o código preconiza que o juiz julgue “de plano”. Também nesse caso terá de ser decidida previamente a questão prejudicial, concernente à procedência da consignação e liberação do devedor, ainda que a resolução ocorra no mesmo ato processual. Considerando fundamentada a pretensão de recebimento formulada pelo réu, o juiz lhe facultará o levantamento do depósito.

Adverte-se que o julgamento de plano só ocorrerá se, ouvido o autor, esse concordar com a entrega do bem ao único comparecente.²⁹² A oitiva é imprescindível. A dúvida sobre o titular do crédito ensejou a propositura de demanda consignatória, na qual foram arrolados dois ou mais possíveis credores. Tendo apenas um deles se manifestado, o autor deve ser ouvido sobre a plausibilidade das alegações do suposto credor.

O pagamento incorreto, conquanto respaldado em sentença, não evitará que terceiro, não arrolado entre os possíveis credores, ajuíze demanda para cobrar o crédito. A coisa julgada, como decorre do art. 506 do CPC/2015, não pode prejudicar terceiros.²⁹³ É evidente, contudo, que os réus omissos não poderão posteriormente cobrar a prestação, pois são atingidos pela coisa julgada.

Se o juiz considerar pouco fundamentadas as alegações do pretendente, o autor será exonerado, mas nesse caso o réu não poderá levantar o depósito, impondo-se, tal como ocorre quando nenhum dos réus comparece, a deflagração do procedimento de arrecadação de coisas vagas.²⁹⁴ Também na jurisprudência se reconheceu que se apenas um dos supostos credores comparecer, o juiz não está obrigado a lhe deferir o levantamento do depósito.²⁹⁵

5. Resposta de vários pretendentes e recurso cabível contra a decisão de primeira fase

Se dois ou mais postulantes apresentarem resposta, será reconhecida a extinção da obrigação, com a exoneração do devedor. O processo continuará em primeira instância, sendo aplicadas as regras do procedimento comum, mas envolverá apenas os pretendentes ao crédito²⁹⁶. Caracteriza-se hipótese *sui generis* de duplicidade, pois nenhum dos remanescentes no processo propôs a demanda.²⁹⁷

Pode ocorrer que terceiro repute a si próprio como credor. Como já dito no item precedente, julgada a demanda consignatória, poderá o terceiro promover ação de cobrança. Embora a hipótese seja admissível em tese, será rara sua ocorrência. O juiz não pode decidir sem estar convencido. Para se convencer, deve determinar a produção de provas, podendo fazê-lo inclusive de ofício, nos termos do art. 370, *caput*, do CPC/2015.²⁹⁸ Assim, tendo o órgão jurisdicional se pronunciado em favor de um dos pretendentes, somente na hipótese de erro judicial o crédito poderia ser titularizado por terceiro.

O terceiro pode intervir no processo, disputando o crédito, por meio de oposição.²⁹⁹ Essa é a modalidade de intervenção de terceiros adequada, quer o postulante intervenha na primeira fase, quer o faça na segunda.³⁰⁰ A decisão que reconhece extinta a obrigação e exonera o devedor não é sentença, pois não encerra a etapa de conhecimento do processo. Ainda terá de ser decidida a questão concernente à titularidade do crédito. Assim, não é óbice à oposição o contido no art. 682 do CPC/2015, de acordo com o qual essa modalidade de intervenção só cabe até a sentença. A decisão que exonera o devedor e o exclui do processo é interlocutória.

É possível que à época de propositura da consignatória já exista processo no qual se litigue sobre a titularidade do crédito. Se o devedor, autor da consignação, incluir nesta demanda apenas os participantes do outro processo e estes não oferecerem contestação, a atividade jurisdicional se limitará à extinção da obrigação, com a liberação do consignante, sendo despicienda a segunda fase da demanda, pois a titularidade do crédito caracteriza o objeto litigioso de outro processo.³⁰¹

Nos termos do art. 55, § 3.º, do CPC/2015, os processos serão reunidos, a fim de se evitar decisões conflitantes.³⁰² Prevalecerá, nesse caso, a competência do juízo em que tiver sido proposta a outra demanda na qual se litiga sobre a titularidade do crédito objeto do processo de consignação.³⁰³

A definição do recurso cabível contra a decisão de encerramento da primeira fase da consignatória, proposta com fundamento no art. 547 do CPC, merece algumas considerações. Quando a demanda for ajuizada sob o fundamento de que há dúvida sobre a titularidade do crédito, sem que penda processo judicial entre os pretendentes (CC, art. 335, inc. IV), será proferida decisão interlocutória, contra a qual caberá agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, inc. II). O processo continuará em primeira instância, entre os credores pretendentes, o que inviabiliza a classificação do provimento como sentença, vez que não encerrada a fase cognitiva (CPC, art. 203, §1º).

Como visto, se o ajuizamento da consignatória ocorrer após a pendência de demanda envolvendo os credores, na qual se disputa a titularidade do crédito consignado (CC, art. 335, inc. V), o provimento que encerra a primeira fase extinguirá a obrigação e liberará o autor. A definição sobre a titularidade do crédito, contudo, acontecerá no processo já pendente. Nesse caso, como não haverá mais atividade cognitiva na consignação, o provimento que a encerra deve ser caracterizado como sentença. A titularidade do crédito será apurada na demanda proposta entre os credores. Contra esse provimento, caberá apelação. É possível, contudo, que o juízo não extinga a consignatória, mas aguarde para decidi-la conjuntamente com a primeira demanda. Nesse caso, como será proferida sentença, ainda que em outro processo, pode-se considerar a decisão de encerramento da primeira fase como interlocutória.

Parece mais correto extinguir o processo, já na primeira fase, quando todos os réus da consignatória litigarem na primeira demanda. Como a titularidade do crédito será discutida na ação pendente, não haverá risco de decisões conflitantes. Manter o processo de consignação suspenso, sem que haja prática de qualquer ato entre o provimento que encerra a primeira fase e a sentença que extingue simultaneamente a ação primeiramente proposta – na qual os credores discutem – e a própria consignatória, não parece ser a medida mais adequada. Contudo, se isso acontecer, ter-se-á de classificar a decisão que encerra a primeira fase como interlocutória, cabendo o recurso de agravo de instrumento.

Uma terceira hipótese é possível: a dúvida do devedor abrange não somente os litigantes da primeira demanda, mas ainda outros. Nesse caso, terá de ser proferida sentença na consignação,

de modo que o provimento de encerramento da primeira fase é decisão interlocutória, a desafiar agravo de instrumento. A suspensão, nesse caso, deve atingir a demanda primeiramente proposta, pois a consignação, embora posterior, revela nítido caráter prejudicial, tal como ocorre com a oposição (CPC, art. 686). Fala-se em prejudicialidade nítida, porque de nada adiantaria julgar a primeira demanda antes da consignatória, já que é neste processo que se encontram todos os litigantes. A sentença que decidir a consignação, resolverá também a primeira demanda.

Essas situações, inegavelmente intrincadas, caracterizam dúvida objetiva e exigem a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de que os litigantes não sejam prejudicados. Destarte, interposta apelação no lugar de agravo, deverá ser conhecida. Do mesmo modo, interposto agravo em vez de apelação, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Art. 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste Capítulo, no que couber, ao resgate do aforamento.

1. Aforamento ou enfiteuse

O dispositivo em análise assinala o cabimento da consignação para o resgate do aforamento, uma das denominações por meio das quais é conhecido o vetusto instituto da enfiteuse. No aforamento o *domínio eminente* é titularizado pelo senhorio direto, ao passo que o enfiteuta ou foreiro, detém o *domínio útil*.³⁰⁴ Trata-se do mais amplo dos direitos reais sobre coisa alheia, podendo o enfiteuta ou foreiro, usar, gozar e dispor do imóvel, o qual necessariamente será terreno inculto ou não edificado.³⁰⁵

O art. 2.038 do CC/2002 proíbe a constituição de novas enfiteuses e subenfiteuses, determinando que as já existentes se subordinem à disciplina que o Código Civil de 1916 concedia ao instituto. O dispositivo também proíbe a cobrança de laudêmio sobre o valor de construções ou plantações.³⁰⁶ O art. 49 do ADCT-CF assinalara que a enfiteuse sobre imóveis urbanos seria objeto de lei, acrescentando que na hipótese de extinção do instituto, aos enfiteutas estaria assegurada a remição do aforamento mediante aquisição do domínio direto.³⁰⁷

2. Resgate do aforamento

Como já visto, nos termos do art. 2.038 do CC/2002, as enfiteuses já constituídas devem ser disciplinadas pelas regras do CC/1916, cujo art. 693 prevê o resgate do aforamento, desde que tenham transcorrido dez anos de sua constituição, mediante pagamento de laudêmio correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da propriedade plena, além de dez pensões anuais.³⁰⁸ Aplica-se à espécie o art. 2.038, I, do CC/2002, o qual proíbe que o laudêmio seja cobrado sobre as construções ou plantações.

Pelo direito de resgate, pretende-se viabilizar a desoneração do imóvel. Trata-se de direito potestativo, de modo que o senhorio direto não pode se opor.³⁰⁹ Desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 693 do Código Beviláqua, quais sejam, constituição há dez anos, pagamento de dez pensões anuais e pagamento de laudêmio correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da propriedade plena, no qual não serão consideradas as construções e plantações (art. 2.038, I, do CC/2002).³¹⁰

O resgate da enfiteuse propicia a consolidação do domínio na pessoa do enfiteuta, sendo o imóvel desonerado. Como se trata de direito potestativo, a perpetuidade da enfiteuse não é obstáculo para que ela seja extinta, desde que o foreiro cumpra os requisitos previstos em lei para o resgate.

3. Consignação em pagamento

O art. 549, do CPC dispõe que será aplicável ao resgate da enfiteuse, no que couber, o procedimento de consignação em pagamento. Afirmou-se, acertadamente, que a previsão contida

no art. 900 do CPC/1973 (reproduzido no art. 549 do código vigente) é imprescindível para o cabimento da demanda consignatória no resgate do aforamento, pois não há relação obrigacional entre o senhorio direto, titular do domínio eminente, e o enfiteuta.³¹¹ Como inexistente obrigação, se não houvesse previsão legal específica, a demanda de consignação não poderia ser ajuizada.

Segundo a doutrina, a demanda consignatória proposta para o resgate do aforamento versa sobre direito real imobiliário,³¹² de modo que a propositura exige a anuência do cônjuge, devendo ser citado o senhorio direto e sua consorte, nos termos do art. 73, § 1.º, I, do CPC/2015.³¹³ A competência recai sobre o foro de situação do imóvel.³¹⁴ Pode haver cumulação de pedidos, de modo que sejam consignados o laudêmio, as dez pensões anuais voltadas ao resgate, bem como aquelas que porventura tenham vencido. A cumulação só não se viabilizará se já houver sido proposta demanda de comisso pelo senhorio direito.³¹⁵

Reconheceu-se, em aresto proferido sob a vigência do código processual anterior, que a omissão do enfiteuta em conceder direito de preferência ao senhorio direto é fato caracterizador de justa recusa no recebimento do laudêmio a ser pago na hipótese de alienação do imóvel gravado com enfiteuse.³¹⁶ Admitiu-se, identicamente, que o laudêmio, na inércia do enfiteuta alienante, fosse pago ao senhorio direto pelo adquirente, ao qual se reconheceu legitimidade ativa para o ajuizamento da demanda consignatória.³¹⁷

Controverte-se sobre a eficácia da sentença. Afirma-se, por um lado, que a pretensão diz respeito à extinção da enfiteuse, mediante resgate, de modo que a eficácia da sentença seria constitutiva.³¹⁸ Por outro lado, reitera-se que a eficácia desconstitutiva decorre do depósito, de modo que a sentença seria declaratória, apesar de ser o título capaz de extinguir a enfiteuse,³¹⁹ nos termos do art. 250, I, da Lei de Registros Públicos.³²⁰

Conquanto a sentença sirva como título para a remição do aforamento junto ao registro imobiliário, é o depósito regular que extingue a enfiteuse, de modo que a sentença, tal como ocorre nas outras hipóteses de demanda de consignação, tem eficácia declaratória.

NOTAS DE RODAPÉ

1

João de Matos Antunes Varela, *Das obrigações em geral*, vol. II, p. 189: “São duas as categorias de situações que legitimam a consignação: uma é a da *mora* do credor; outra a da impossibilidade de o devedor, sem culpa sua, efectuar a prestação (ou efectuá-la com a necessária segurança) por qualquer *outro* motivo relativo à pessoa do credor”.

2

João de Matos Antunes Varela. Op. cit, p. 187-188.

3

Judith Martins-Costa, *Comentários ao novo código civil*, vol. V, t. I, p. 356-357, afirma que certas prestações não podem ser cumpridas sem que haja mínima cooperação do credor. Para essas hipóteses, a fim de que a obrigação possa ser extinta e o devedor liberado, o ordenamento jurídico disponibiliza a técnica do pagamento em consignação, cujos fundamentos são “a quebra do dever de cooperação, por parte do credor, e a facilitação do adimplemento, para o devedor” (p. 357). Conquanto se reconheça a importância

do dever de cooperação no âmbito obrigacional, crê-se que a falta de colaboração do credor não possa fundamentar o pagamento em consignação nas hipóteses de dúvida sobre quem deva receber o objeto (Código Civil, art. 335, IV) ou de litígio sobre o objeto de pagamento (Código Civil, art. 335, V). No primeiro caso, dificilmente se poderia imputar a dúvida do devedor a algum comportamento não colaborativo do credor. No segundo, a pendência de litígio também não pode ser considerada como reflexo da ausência de cooperação do credor. Desse modo, pode-se afirmar que o principal fundamento para o pagamento em consignação seja a facilitação do adimplemento, motivo subjacente a todas as hipóteses previstas em lei.

4

Dispõe o art. 334 do CC/2002: “Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”. Advirta-se que o devedor poderá optar pelo depósito judicial de prestação pecuniária. Por outro lado, nos estabelecimentos bancários não será possível depositar prestações não pecuniárias.

5

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XIII, p. 18, afirma que se trataria de forma sub-rogada de pagamento: “Não se trata de pagamento, mas de uma modalidade que o substitui, uma forma sub-rogada de pagamento, por meio da qual o obrigado pode liberar-se antes ou independentemente do fato de haver o credor recebido o pagamento”. Judith Martins-Costa, *Comentários... cit.*, p. 354, assinala que o pagamento indireto deve ser considerado como forma de extinção da obrigação, na qual é cumprida prestação diversa daquela devida. A jurista destaca com grande precisão a distinção entre adimplemento em sentido estrito e em sentido lato, de que seria exemplo o pagamento indireto: “Daí a distinção, também antes já apontada, entre o sentido estrito, ou técnico, do adimplemento, e o sentido lato: na primeira acepção, o termo indica o cumprimento da prestação devida de modo voluntário, exato e segundo a boa-fé, pelo devedor, com a satisfação do credor. Já em sentido lato, o termo é utilizado para designar qualquer *modo de satisfação do credor*, aí se insere o pagamento indireto (...)”.

6

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários ao código de processo civil*, vol. VIII, t. III, p. 63: “O que se deposita é importância em dinheiro ou coisa corpórea, objeto da prestação a que está o autor obrigado”.

7

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários ao código de processo civil*, vol. XI, t. I, p. 21, entendia que somente bens móveis poderiam ser objeto de depósito: “A consignação em pagamento somente tem lugar quando o objeto da prestação devida for coisa móvel”.

8

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários... cit.*, p. 21-22.

9

Judith Martins-Costa, Op. cit., p. 362, sustenta a impossibilidade de pagamento em consignação nas obrigações de fazer e de não fazer. Todavia, admite que essa técnica de extinção da obrigação será possível quando as obrigações de fazer estiverem relacionadas a alguma obrigação de dar. Washington de Barros Monteiro, *Curso de direito civil*, vol. IV, p. 279, destaca a impossibilidade de consignação nas obrigações de fazer e de não fazer: “Só nas obrigações de fazer, ou de não fazer, pela sua natureza, descabe a consignação. Numa palavra, a consignação só é compatível com a prestação de coisas”.

10

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. II, p. 102. Textualmente: “O ato de vir a juízo pedindo tutela jurisdicional, chamado demanda, tem por conteúdo uma pretensão de quem o realiza. Pretensão é a exigência de subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio”.

11

Art. 335. A consignação tem lugar: I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma.

12

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 45: “A recusa supõe oblação, oferecimento, ainda que simbólico ou verbal, sem a efetiva apresentação da coisa ou do dinheiro. Sem a oferta, não se terá aberto ao credor a opção de aceitar ou recusar o pagamento”.

13

STJ, REsp. 796.714/MG, 3ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 14.05.2007, p. 286: “Recurso especial. Acordo. Obrigação de receber prestações. Multa pelo descumprimento. Inadimplência do credor. Consignatória ajuizada pelo devedor. A inadimplência do credor que se recusa a receber prestação nos termos de acordo firmado não cessa com a consignação em pagamento, pelo devedor, do valor recusado. A consignação não purga a mora *accipiendi*. A inércia do credor justifica a cobrança da multa por inadimplemento, prevista no contrato. A cláusula penal, ainda que nominada multa diária por descumprimento do contrato, não pode exceder ao máximo da obrigação principal (Art. 920 do CC/1916)”.

14

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

15

Arnaldo Marmitt, *Consignação em pagamento*, p. 54, indica as hipóteses nas quais haveria justa recusa: “A recusa capaz de ensejar a consignatória deve repousar em motivo que a justifique. São causas justificadoras, v.g., a oblação realizada em local diferente daquele em que deveria ter sido feita; a mora *debitoris* já acontecida, de molde a fazer com que a prestação seja inservível para o credor; a insuficiência do *quantum debeatur*, ou a diversidade de qualidade da coisa ofertada face à efetivamente devida”.

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

Clóvis do Couto e Silva, Op. cit., p. 44: “O princípio é o de que o devedor pode consignar durante o período em que o credor estiver em mora. Estando em mora o devedor, deixa de estar o credor, aplicando-se o princípio de que *posterior mora nocet*”. Prossegue o autor na página 46 da mesma obra: “É preciso, portanto, que verifique se o depósito se efetuou no prazo e no lugar do pagamento. O prazo do pagamento comporta certa particularidade, uma vez que o devedor pode prestar a qualquer tempo, desde que não esteja em mora”.

Ovidio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 20: “Mas o devedor, ainda em mora, tem direito e pretensão a liberar-se da obrigação, para forrar-se das consequências da mora. O que impede a consignação não é a mora, mas a inutilidade da prestação tornada sem interesse para o credor, em virtude do retardamento por parte do obrigado no cumprimento da obrigação. Tem-se, portanto, de distinguir mora e inadimplemento do contrato”. Na página 21 do mesmo livro o autor acrescenta: “A mora em geral admite a emenda, sendo possível ao obrigado purgá-la, desde que ofereça ao credor a prestação mais o valor da indenização pelos prejuízos a que ela deu causa. (...) Se a demora na execução da obrigação não tornou inútil para o credor a prestação, este não poderá enjeitá-la e a purga da mora é, neste caso, sempre possível”. No mesmo sentido se manifesta Judith Martins-Costa, Op. cit., p. 380: “Não será injusta a recusa, por outro lado, se o devedor estiver em *mora debitoris*, desde que a mora tenha atingido a utilidade da prestação para o credor. Não é, pois, qualquer mora que justifica a recusa, mas a que pode ser qualificada nos termos do parágrafo único do art. 395 do Código Civil”. Também Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 45, afirma que apenas a mora que tornar a prestação imprestável autoriza a recusa pelo credor: “Para dar lugar à consignação, há de ser a recusa *injusta (verbis, ‘sem justa causa’, no texto do Código Civil)*. Justificam-na circunstâncias como a *mora debitoris* já configurada de modo a tornar inservível para o credor a prestação; (...)”. A *contrario sensu*, quando a mora não tornar a prestação inservível, não será justa a recusa do credor.

Antônio Carlos Marcato, *Procedimentos especiais*, p. 88.

Agostinho Alvim, *Da inexecução das obrigações e suas consequências*, p. 47: “Diante do exposto, podemos justificar a fórmula que aventamos para classificar o inadimplemento absoluto e a mora, a saber: há inadimplemento absoluto quando não mais subsiste para o credor a possibilidade de receber a prestação; há mora quando persiste essa possibilidade”.

21

Heloísa Helena Barboza, Maria Celina Bodin de Moraes e Gustavo Tepedino, *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*, vol. I, p. 693: “O devedor não deixa de prestar, mas o faz mal. Diferentemente do que se dá no inadimplemento absoluto e na mora, em que o devedor omite-se, deixando de cumprir a obrigação ou de cumpri-la no tempo, forma ou local ajustados, nesta hipótese tem lugar a *ação positiva* do devedor, porém sem satisfazer adequadamente o interesse do credor, exigível por força do título”.

22

Antônio Carlos Marcato, *Ação de consignação em pagamento*, p. 21.

23

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

24

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

25

Antônio Carlos Marcato, *Procedimentos especiais*, p. 71.

26

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários... cit.*, p. 46-47.

27

Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Parágrafo único. Designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles.

28

Art. 335, II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos.

29

TJSP, Ap. civ. 1002692-12.2014.8.26.0568, 14ª Câmara de Direito Privado, rel. Lígia Araújo Bisogni, *DJ* 02.12.2015 “Consignação em pagamento. Configurada uma das hipóteses do art. 335 do CC. Credor que não foi, nem mandou receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Devedora que recebia em sua residência os boletos para pagamento do débito, conforme acordo firmado. Instituição financeira que injustificadamente deixou de assim proceder. Necessidade da consignatória, para se evitar os efeitos da mora. Sentença de procedência da consignatória mantida. Condenação do banco no ônus da

sucumbência”.

30

Art. 373, § 1.º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do *caput* ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

31

Judith Martins-Costa, Op. cit., p. 383-384. Orosimbo Nonato, *Curso de obrigações*, p. 23, salienta que a consignação será cabível se não houver representante ou se, havendo, ele não tiver poderes para dar a quitação.

32

Art. 335. A consignação tem lugar: III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil.

33

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I – incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade.

34

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 54: “É bem claro que, no próprio processo, se há de dar curador especial ao demandado (art. 9.º), mas o levantamento do depósito terá de aguardar a nomeação de tutor ou curador propriamente dito: o recebimento de dinheiro ou coisa, em caráter definitivo, excederia o limitado âmbito das atribuições do curador especial”.

35

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: II – interesse de incapaz.

36

TJRS, Ap. Cív. 70066846619, 19ª Câmara Cível, rel. Mylene Maria Michel, DJ 25.11.2015: “Negócios jurídicos bancários. Ação de consignação em pagamento. Cheques sem fundos. Credor desconhecido. Cabimento da consignatória. Desconstituída a sentença de extinção do feito. Deferida a antecipação de tutela para cancelamento da inscrição negativa, condicionada ao depósito do valor do débito, acrescido dos encargos legais. Apelação provida, por decisão monocrática”.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 30: “Em todos os casos de ofertas feitas ao público, o credor é normalmente desconhecido pelo devedor. O mesmo se dará se o título for endossável, pois neste caso é evidente que o devedor poderá ignorar quem seja o portador dele na data do vencimento, caso em que a citação na ação de consignação em pagamento haverá de ser feita por edital”. No mesmo sentido se manifestou Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 48, enfatizando com grande acuidade a possibilidade de formação de relação obrigacional com pessoas desconhecidas: “De resto, é erro supor-se impossível a contração de obrigação com pessoa desconhecida, indeterminada, incerta. Basta lembrar a promessa de recompensa e o concurso público, casos em que no momento mesmo de constituição da obrigação o sujeito passivo desconhece a identidade do sujeito ativo”. Em trecho lançado na página anterior da mesma obra, o jurista defendera a possibilidade de pagamento em consignação nas hipóteses de títulos ao portador. Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 46, t. XIII, fora referido por Adroaldo Furtado Fabrício em passagem na qual cita a promessa de recompensa e o concurso público como situações autorizadoras do depósito: “Quando o credor é desconhecido, porém existe, ou é possível que exista, ou é determinável, porém ainda não se determinou (e.g., *unus ex publico*), como se observa nas promessas de recompensa e nos concursos públicos, a falta de exata ou completa cognição do credor permite a consignação ‘a quem de direito’”.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 48.

Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador.

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 23: “Acontece que nem sempre o devedor está ciente dos exatos poderes conferidos ao representante legal do ausente, nem se lhe impõe tal conhecimento, daí o motivo pelo qual poderá realizar o pagamento por consignação”.

Judith Martins-Costa, *Op. cit.*, p. 385.

Antônio Carlos Marcato, *Op. cit.*, p. 23, escrevendo sob a vigência do Código Civil de 1916, esclareceu a questão, destacando que o desconhecimento do devedor sobre a residência do credor ou as dificuldades de acesso a ela só serão pertinentes para a consignação quando a dívida for portátil: “Ressalve-se, entretanto, o seguinte: quando ignorado ou inacessível o lugar onde resida o credor, justificar-se-á a consignação fundada no inc. III do art. 973 somente se e quando portátil a dívida; sendo quesível e configurada a mora *accipiendi*, a razão do depósito será a inércia do credor em receber ou mandar que

alguém receba o pagamento em seu nome (inc. II)”.

43

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 49: “*Residir*, no texto, deve ser tomado no sentido amplo de estar, achar-se, e não na acepção restrita de ter morada habitual. De outro modo, limitar-se-ia por demais a incidência da norma e vedar-se-ia a liberação mediante consignação em casos de verdadeira impossibilidade de pagamento – como o de, no momento em que se deveria dar a oblação, estar o credor, cuja residência é conhecida e certa, ausente dela em lugar a que não se possa chegar pelos meios comuns (...). É bem de ver que, em casos assim, se tomada a palavra *residir* no sentido mais usual de *morar*, restaria injustificavelmente desprotegido o interesse do devedor na liberação. Impõe-se, pois, tomar o verbo na sua significação mais ampla, que, aliás, também está na linguagem comum e nos dicionários”.

44

Judith Martins-Costa, Op. cit., p. 385: “A lei não gradua a periculosidade ou a dificuldade de acesso, razão pela qual há de exigir-se a dificuldade normal de acesso, o termo médio: nem a extrema dificuldade ou periculosidade, nem a mínima”.

45

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 50, assinala que o devedor, ciente das dificuldades do pagamento no momento em que celebra a obrigação, não poderá liberar-se pela consignação, a não ser que se agrave o risco reconhecido no momento da pactuação: “É o que ocorre se, em tal momento, a situação já existia e era conhecida do devedor, e este ainda assim se obrigou a levar o pagamento. Os riscos e percalços envolvidos no ir levar, então, foram aceitos e assumidos contratualmente pelo devedor, e não seria jurídico, em tais circunstâncias, admitir-se a liberação por forma diversa da convencionada. Admissível seria, contudo, a consignação, no caso em que intercorresse agravação do perigo ou da dificuldade, porque então as condições fáticas consideradas seriam diversas, no momento do pagamento, daquelas que o devedor conhecia e aceitara quando da formação do débito”.

46

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 31: “Este preceito compreende a dúvida quanto à pessoa do credor e a dúvida sobre se a pessoa que se apresenta para receber tem poderes para dar quitação”. No mesmo sentido se manifestou Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação em pagamento*, p. 24: “Por outras palavras, pode o credor efetuar o pagamento por consignação quando esteja incerto a respeito de quem seja o legítimo titular do crédito, bem como quando, mesmo reconhecendo em alguém tal titularidade, ignore se está legitimado a receber”.

47

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 50: “Assim, nada importa que a dúvida seja objetiva (v.g., dois pretendentes ao recebimento da coisa apresentam títulos conflitantes e com igual aparência de autenticidade) ou subjetiva, existente só no espírito do devedor (como no caso de interpretação dúbia do negócio jurídico)”.

Judith Martins-Costa, Op. cit., p. 387. Pronunciou-se, na mesma linha, Antonio Carlos Marcato, Op. cit., p. 24: “A dúvida pode referir-se tanto a quem seja o legítimo credor (*incerteza subjetiva*), quanto à legitimação para receber (*incerteza objetiva*), mesmo reconhecendo o devedor, neste último caso, a qualidade do credor”.

STJ, REsp. 1.526.494/MG, 3ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 29.05.2015: “Processual civil. Ação de consignação em pagamento. Dúvida quanto à titularidade do crédito. Existência. Inexistência de interesse de agir afastada. 1. A ação de consignação em pagamento é cabível em caso de dúvida sobre quem tenha legitimidade para receber determinado pagamento. 2. Afasta-se o fundamento adotado pelo acórdão recorrido que extinguiu a ação consignatória pela falta de interesse de agir, quando o fez após proclamar o efetivo credor das quantias e afirmar que a ele os pagamentos deveriam ter sido realizados. 3. Existindo fundada dúvida, no momento do ajuizamento da ação, acerca de quem deve legitimamente receber, há interesse de agir para propor a consignação em pagamento. 4. A consignatória não tem por finalidade apurar eventuais responsabilidades do credor com relação a contrato firmado com terceiro e do qual não participou o devedor. Todavia, o comportamento das partes envolvidas e a existência da disputa judicial pode lançar dúvida sobre quem deve receber os valores; assim, o devedor, para afastar o risco do pagamento indevido, poderá exonerar-se mediante consignação. 5. Recurso especial provido”.

Art. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento.

Ovidio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 31: “A existência de litígio sobre o objeto da prestação, ainda que o devedor nenhuma dúvida tenha sobre a pessoa que esteja legitimada a receber, autoriza o depósito judicial em pagamento”. Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação em pagamento*, p. 24, analisa o tema de forma esclarecedora: “O litígio referido não é pertinente, por óbvio, à titularidade do crédito, mas, sim, ao objeto do pagamento: o credor é conhecido, mas entre ele e terceiro trava-se disputa sobre o objeto mencionado, agindo culposamente o devedor que, antecipando-se ao provimento jurisdicional, paga a um dos litigantes”.

Art. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 52: “Contudo, a modalidade do inc. V aparenta uma originalidade, qual seja a de poder o devedor ser *compelido* a depositar, por via judicial. É que o art. 984 do CC atribui a qualquer dos sedizentes credores em litígio a faculdade de ‘requerer a consignação’; isso só pode significar que, vencida a dívida sem se haver solvido a questão da titularidade do crédito, os

pretendentes a ela, e cada qual isoladamente, têm o poder jurídico de compelir o devedor ao depósito”.

54

Idem, p. 53: “Nessa perspectiva, a apontada originalidade é só aparente: a posição do devedor, resultante do uso da faculdade outorgada aos supostos credores pelo citado art. 984, é a de réu em ação de cobrança, não a de autor de uma ação consignatória a cuja propositura tenha sido ‘provocado’ ou compelido”.

55

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: VII – a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2.º do art. 164.

56

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: I – de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; II – de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; III – de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. § 1.º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar. § 2.º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

57

TJMG, Ap. Cív. 1.0702.13.004846-6/001, 4ª Câmara Cível, rel. Ana Paula Caixeta, *DJ* 04.03.2015 “Direito Tributário. Ação de Consignação em Pagamento. ISSQN. Prestação de Serviços. Competência. Local do Estabelecimento. REsp. 1.117.121 DO STJ. Quando o tributo é exigido por mais de um ente tributante, pode o contribuinte ajuizar ação de consignação em pagamento do crédito tributário, na forma do art. 164, III, do Código Tributário Nacional, visando obter o efeito liberatório do pagamento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do REsp. 1.117.121/SP, julgado na sistemática de recurso repetitivo, decidiu que a competência para cobrança do ISSQN é do Município onde se situa o estabelecimento prestador dos serviços”.

58

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 56.

59

STJ, AgRg nos EREsp. 690.478/RS, rel. Min. Humberto Martins, 1ª Seção, *DJe* 26.05.2008: “Execução fiscal. Ação de consignação em pagamento. Parcelamento do débito tributário. Impossibilidade. 1. A ação consignatória, que é de natureza meramente declaratória, tem por objetivo apenas liberar o devedor de sua obrigação com a quitação de seu débito, por meio de depósito judicial, quando o credor injustificadamente se recusa a fazê-lo. 2. Recolher parceladamente o valor do débito fiscal na seara da

ação consignatória é desviar-se da finalidade por ela pretendida. 3. De acordo com o Min. Luiz Fux, a referida ação não pode ser servil à obtenção de parcelamento do débito tributário, sob pena de se estar fazendo da legislação, que prevê o referido benefício, letra morta. Agravo regimental improvido”.

60

José da Silva Pacheco, *Tratado das locações, ações de despejo e outras*, p. 559, escrevendo sob o código processual revogado, esclareceu a questão: “Assim, quando se objetivar o pagamento de aluguéis ou acessórios da locação, o procedimento adequado é o do art. 67 da Lei 8.245/1991; quando se pedir a consignação do imóvel ou das respectivas chaves, ainda que referentes ao término da locação, o procedimento é o dos arts. 890 e ss. do CPC/1973, o qual é pertinente, ademais, se ocorrer dúvida sobre quem deva, legitimamente, receber o pagamento, quando o procedimento pode ser o dos arts. 895 e 898 CPC/1973”.

61

Art. 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos se a construção for considerada em condições precárias pelo Poder Público. 1.º O levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação, pela autoridade pública, da regularização do imóvel. 2.º Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. 3.º Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados, mediante ordem judicial, para realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel.

62

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 60.

63

Art. 67, II – determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de vinte e quatro horas, efetuar o depósito judicial da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo.

64

Art. 67, III – o pedido envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover os depósitos nos respectivos vencimentos.

65

Art. 67, IV – não sendo oferecida a contestação, ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido, declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários de vinte por cento do valor dos depósitos.

66

Art. 67, VI – além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral.

67

Art. 67, VII – o autor poderá complementar o depósito inicial, no prazo de cinco dias contados da ciência do oferecimento da resposta, com acréscimo de dez por cento sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor-reconvindo a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor dos depósitos.

68

Art. 42. Se a letra não for apresentada a pagamento dentro do prazo fixado no art. 38, qualquer devedor tem a faculdade de depositar a sua importância junto da autoridade competente, a custa do portador e sob a responsabilidade deste.

69

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 57: “Sustentamos que mesmo o depósito de que cuida o art. 42 da Lei Uniforme não pode ser feito senão no bojo de uma ação consignatória. Com efeito, não se dispõe de qualquer outra regulamentação procedimental que o possa reger nessa especial hipótese”.

70

STJ, REsp. 849.539/MG, 4ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, *DJ* 09.10.2006, p. 3101: “Conforme já decidiui esta Corte, é cabível a ação de consignação em pagamento nos casos de dívida representada por título cambiário. (...)”.

71

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

72

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) II – a parte for manifestamente ilegítima; III – o autor carecer de interesse processual.

73

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) XI – ausência de legitimidade ou de interesse processual.

74

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.

STJ, REsp. 85.551/PB, 3ª Turma, rel. Min. Nilson Naves, DJ 08.03.1999, p. 215 “Ação de consignação em pagamento. Legitimidade. Quem deve pagar. 1. Qualquer interessado pode pagar a dívida (Código Civil, art. 930). Pode também o terceiro requerer a consignação (Código de Processo Civil, art. 890). 2. Em caso de compromisso de compra e venda, verificada a morte de um dos contratantes, é lícito ao descendente-sucessor valer-se da ação de consignação em pagamento. É, portanto, parte legítima. 3. Recurso especial conhecido e provido”.

Judith Martins-Costa, Op. cit., p. 106. Na passagem seguinte, a jurista elenca diversos interessados: “São também interessados, além do fiador, o coobrigado, em todo ou em parte (art. 346, III), o sucessor, o sócio, o credor do devedor (art. 346, I), o que garante a dívida de terceiro por hipoteca ou outro direito real de garantia, bem como o terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel (art. 346, II), o cessionário da posição contratual ou a pessoa a quem a dívida foi transmitida, nos termos dos arts. 286 a 303 do CC, e o subinquilino, entre outros”.

Pontes de Miranda, *Tratado...* cit., t. XXIV, p. 93-94: “Poderia parecer que se não admite o pagamento *pro alio*, se o devedor se manifestou contrário a ele; mas a sistemática jurídica cedo afastou que se vedasse a alguém pagar, se a prestação não é ligada ao próprio devedor: ‘Pagando alguém por outrem, ainda que seja contra a vontade alheia (*invito*) e ignorando-o o devedor (*ignorante*), libera-o. Mas o que se deve a alguém, outrem não o pode reclamar em direito (*iure exigere*) sem a vontade daquele. Porque a razão natural e, à semelhança, a civil persuadem que se pode fazer melhor a condição alheia, ainda que não no saiba ou seja contra sua vontade, porém não pior’ (GAIO, na L. 39, D., *de negotiis gestis*, 3, 5)”.

Judith Martins-Costa, Op. cit., p. 107: “Se o terceiro não interessado paga em nome do devedor, sem oposição deste, terá, também, legitimação ativa para ‘usar dos meios conducentes à exoneração do devedor’ (p. ex., ação de consignação), na hipótese de ilegítima recusa do credor a receber. Em regra, o terceiro não interessado age por liberalidade”. A jurista prossegue no enfrentamento do tema na página 108 da mesma obra: “Se o terceiro não interessado pagar em seu nome, já não haverá a possibilidade de ‘usar dos meios conducentes à exoneração do devedor’. Recai-se, então, na regra do art. 305”.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 66: “O que se precisa ter na devida conta é que o terceiro ‘indiferente’ (e bem assim o interessado não juridicamente, que àquele se iguala para o que aqui importa),

se bem que possa pagar até em seu próprio nome, não se legitima, nesse caso, à ação de consignação. Por outras palavras, o credor pode recusar tal pagamento, se lhe convém manter ou colocar o devedor em mora, e a recusa não se há de considerar injusta. Com efeito, a hipótese vem prevista no art. 931 do CC, que, ao contrário do artigo anterior, *nenhuma referência faz* aos ‘meios conducentes à liberação do devedor’. Assim, o terceiro desinteressado admitido não só ao pagamento, mas também ao emprego daqueles meios (um dos quais é a consignação), é apenas aquele que oferece pagamento *em nome e por conta do devedor*. Aí se compreendem situações como a do procurador, gestor de negócios, preposto ou quem quer que pague em lugar do devedor, como se este mesmo fosse”.

82

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

83

Fredie Didier Jr., *Pressupostos processuais e condições da ação*, p. 253-254, realiza análise cuidadosa e precisa sobre as características da legitimação extraordinária.

84

Antônio Carlos Marcato, *Ação de consignação em pagamento*, p. 48-49: “O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome (CC, art. 931) não terá, evidentemente, legitimidade ativa para a ação de consignação e nem mesmo interesse jurídico. A lei, contudo, legitima extraordinariamente esse terceiro quando a oferta de pagamento seja feita em nome e por conta do devedor (CC, art. 930, parágrafo único). (...) Deve-se atentar, portanto, para a natureza do pagamento feito por tal terceiro: sendo por sua conta e com o intuito de posteriormente exigir reembolso, falta-lhe legitimidade ativa ordinária, pois nesse caso o devedor não se liberaria da dívida, já que continuaria devendo ao terceiro consignante (CC, art. 931, *caput*); sendo a oferta de pagamento feita por conta do devedor, daí, sim, a lei confere-lhe legitimidade ativa extraordinária (art. 930, parágrafo único)”. Extrai-se idêntico posicionamento, à luz dos códigos revogados, de Arnaldo Marmitt, *Consignação em pagamento*, p. 32: “Pena de carência, a ação consignatória precisa ser feita em nome e por conta do devedor, e não em nome próprio, salvo comprovante do seu interesse na quitação do débito”. Sob o código vigente, adotaram este entendimento Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 589: “O terceiro juridicamente desinteressado pode pagar em nome e à conta do devedor (art. 304, parágrafo único, CC). Tem legitimação extraordinária – pode figurar na ação de consignação em pagamento como substituto processual do devedor (art. 18, CPC). O terceiro juridicamente desinteressado não pode propor ação de consignação em pagamento em nome próprio – é ilegítimo para a causa”.

85

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 26-27, adotava essa posição em texto escrito sob o CPC/1973 e o CC/1916: “Tanto o devedor quanto o terceiro, segundo o art. 890, estão ativamente legitimados para requerer o depósito judicial em consignação. Segundo dispõe o Código Civil, tanto podem pagar o devedor quanto os terceiros, sejam estes interessados ou não na solução da dívida, desde que o façam em nome e por conta do devedor (art. 930 do CC); e o art. 436 do CCo contém dispositivo similar. (...) Contudo, se o

terceiro que a lei considera ‘desinteressado’, mas legitimado para realizar o pagamento, o fizer em nome e por conta do devedor, estará legitimado para a ação de consignação em pagamento”.

86

Art. 256. A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...).

87

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 60-61: “O nascimento da pretensão a consignar é concomitante ao vencimento, ao qual se some a ocorrência de algum dos permissivos legais”.

88

Os concursos públicos a que se alude são realizados mediante vale-brinde e não exigem inscrição prévia, como visto no item 1.4 dos comentários a este art. 539.

89

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

90

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

91

Pontes de Miranda, *Comentários...* cit., p. 28: “Se ocorre que o devedor tem direito a contraprestação, nada obsta a que se faça o depósito com a cláusula de só ser levantado se o credor a satisfizer”.

92

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 24: “Esta possibilidade é consequência da própria natureza da consignatória, concebida como instrumento liberatório, de que o devedor se vale sempre que lhe pareça oportuno livrar-se dos encargos e riscos inerentes ao dever de prestar. Não se negará que, no plano do direito material, o contratante que deva prestar mediante contraprestação, a ser feita pelo outro, tem idêntica pretensão a liberar-se da obrigação, não sendo lícito que o direito processual lhe oponha barreiras sob a alegação de dificuldades procedimentais”.

93

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 69: “A consignação para liberação tem de ser pura e simples, inadmitindo condição suspensiva, pois a estipulação desta não caberia de modo algum no

procedimento especial dos arts. 890 e ss. Implicaria um tal pedido verdadeira cumulação; ao pedido de declaração liberatória juntar-se-ia um outro, de condenação do réu à satisfação de sua própria obrigação, com a complicação adicional da condicionalidade da declaração e da condenação”. Na página seguinte, arrematava o jurista: “Mesmo que se cuide, portanto, de obrigação do tipo *do ut des*, ao devedor só é lícito postular, por via da ação de consignação em pagamento, a liberação pura e simples, sem condição ou reserva. O depósito em consignação é, necessariamente, *pro soluto*”.

94

Clóvis do Couto e Silva, Op. cit., p. 27, adotava o mesmo posicionamento, apontando a impossibilidade de prolatação de uma sentença condicionada: “Se a dívida resultar de um contrato bilateral, submetido às regras a respeito do sinalagma, tal como previsto no Código Civil, art. 1.092, e se o devedor pretender obter a contraprestação deverá ofertar em primeiro lugar, ou seja, deverá efetuar o pagamento ou consignação em pagamento, para, posteriormente, exigir o adimplemento da outra parte. Se ele assim não proceder, ou se pretender consignar e, ao mesmo tempo, obter uma sentença condicionada, ou seja, que se determine também na mesma ação que a eficácia do depósito ficaria dependente da contraprestação, tal pedido não é possível nas ações de consignação em pagamento no nosso sistema jurídico. A ação de consignação terá que ser proposta sem nenhuma condição, porque tem procedimento especial, não sendo prevista expressamente a hipótese de poder proferir-se, nesse caso, sentença condicionada”. No mesmo sentido se posicionou Arnaldo Marmitt, Op. cit., p. 29, para quem a contraprestação não poderia ser exigida na demanda consignatória: “Na verdade nosso ordenamento não autoriza tal afirmação, eis que a consignatória apenas libera o devedor de sua obrigação. A este cumpre exigir eventual contraprestação pelas vias adequadas, e não nos autos do procedimento consignatório”.

95

Em antigo julgado do TJRS, reconheceu-se a inviabilidade de se condicionar a liberação do depósito. TJRS, Ap. civ. 37.926, 3ª Câmara Cível, rel. Gervásio Barcellos, j. 15.04.1981 “Consignação em pagamento. Descabe em ação de consignação em pagamento condicionar o levantamento do depósito ao cumprimento de obrigações não exigíveis nesse procedimento que visa tão somente os efeitos liberatórios do pagamento. Apelo desprovido”.

96

Art. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente.

97

Judith Martins-Costa, Op. cit., p. 360: “Se bem que a liberação do devedor relativamente aos juros, riscos, despesas e correção monetária ocorra desde a *efetivação do depósito*, a *eficácia do depósito* fica condicionada à procedência da demanda: a sentença *declara* que o depósito operou aqueles efeitos”.

98

Celso Agrícola Barbi, *Ação de consignação em pagamento e renovatória na nova lei do inquilinato*, p. 632: “Do ponto de vista da classificação processual das ações, prevalece o entendimento de que a ação de

consignação é ação de conhecimento, da espécie declaratória, porque o que nela se pretende é uma sentença que declare extinto o débito pelo depósito judicialmente feito”. Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 25-26, seguia o mesmo entendimento, assinalando que a sentença de procedência reconheceria a eficácia do depósito judicial e a exoneração do depositante: “Quando se diz que a ação de consignação é declaratória, o que se pretende dizer é que a sentença que a julgar procedente (!), será meramente declaratória, ou seja, dir-se-á que a pretensão de direito material nela contida fora posta no processo para que o juiz apenas declarasse (sem constituir, ordenar, condenar ou executar) eficaz o depósito judicial e liberado o devedor”.

99

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

100

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 37: “Não é, pois, na sentença que se contém a ‘força de pagamento’ a que alude a lei civil; nem mesmo é ela que atribui ou outorga ao depósito essa eficácia: tem-na o depósito por si mesmo, se efetivado bem e regularmente. O que a sentença de procedência faz é, precisamente, declarar que o depósito preenche e satisfaz os requisitos legais para substituir o pagamento como forma de liberação do devedor. O ato judicial constata e afirma que a consignação produziu esse efeito”. O tema é retomado pelo autor na página 78 da mesma obra: “A sentença de procedência que se venha a proferir apenas declara (entre outras declarações nela contidas) que o depósito operou aqueles efeitos. Portanto, estes não são da sentença. (...) A eficácia da declaração é, em qualquer dos casos, *ex tunc*. Tudo se explica à base de que a sentença julga o depósito, isto é, resolve se ele foi ou não realizado bem e eficazmente, com aptidão para liberar o devedor”.

101

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 128-129, explicou o tema à luz do Código Buzaid: “Contudo, vindo a contestação fundada na insuficiência do depósito (art. 896, IV), a ação consignatória assume natureza *dúplice*, ou seja, rejeitado que seja o pedido formulado pelo autor, o juiz o condenará, *independentemente da oferta de reconvenção pelo réu* (art. 899, § 2.º), a satisfazer o montante devido (ou seja, a diferença apontada na contestação – art. 896, parágrafo único), quando, então, a sentença também conterà uma carga *condenatória*, tanto que valerá como título executivo judicial (art. 584, I)”.

102

Clóvis do Couto e Silva, *Op. cit.*, p. 26: “Os pressupostos gerais para a consignação em pagamento são, em consequência, a existência de dívida líquida e certa, mora do credor, ou, ainda, incerteza fundada sobre quem seja o credor”.

103

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 39, afirma enfaticamente ser desnecessário o requisito da liquidez e da certeza: “Nunca estive em nenhuma disposição legal essa exigência. Na verdade, indispensável é a *afirmação* do autor no sentido da existência e do montante do débito”.

104

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., , p. 39-40.

105

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 73.

106

Kazuo Watanabe, *Da cognição no processo civil*, p. 111-112.

107

Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da tutela*, p. 34, analisa com a habitual precisão a técnica da cognição parcial: “O legislador, através da técnica da cognição parcial, pode desenhar procedimentos reservando determinadas exceções, que pertencem à situação litigiosa, para outros procedimentos; nos procedimentos de cognição parcial, o juiz fica impedido de conhecer as questões reservadas, ou seja, as questões excluídas pelo legislador para dar conteúdo a outra demanda. É o caso das ações possessórias e das ações cambiais”.

108

Eduardo Talamini, *Coisa julgada e sua revisão*, p. 59-60: “Eventualmente, não há plena convicção pessoal do magistrado quanto aos fatos, e ele mesmo assim acaba tendo de decidir, valendo-se de máximas da experiência ou dos critérios de distribuição dos ônus probatórios. Mas a falta de plena convicção pode ocorrer até mesmo quando o juiz sentencia amparando-se em provas ditas ‘diretas’. Por isso, não é o grau de convencimento pessoal do juiz, no momento da sentença, que permite qualificar a atividade cognitiva então encerrada em exauriente ou não. O adequado critério para tal classificação (sumário *versus* exauriente) é dado por aquilo que se fez antes, no curso do processo – melhor dizendo: por aquilo que o procedimento legalmente previsto *possibilitava fazer* para chegar à decisão”.

109

Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da tutela*, p. 37.

110

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 50-65. Colhe-se passagem, na página 65, que deixa clara a posição do autor sobre a sumariedade da demanda consignatória: “Não há, pois, como salvar, na perspectiva dogmática do direito brasileiro atual, a inadvertência dos legisladores do Código Civil ao inserirem, numa ação eminentemente sumária, como deve ser a consignatória, a possibilidade de controverter-se sobre a alegação de ‘justa recusa’ oposta pelo credor. Ou preserva-se, em toda a sua pureza, a demanda de consignação em pagamento, na qual apenas tenha lugar a controvérsia sobre a pretensão a liberar-se, manifestada pelo autor, ou ter-se-á de transformá-la em demanda destinada a decidir (não apenas conhecer) sobre a existência e validade do negócio jurídico indicado como fonte da

obrigação. Em termos técnicos, a ‘justa recusa’ ataca a causa petendi da demanda e não apenas os eventuais fundamentos, a que alude o art. 469, II, do Código de Processo Civil”.

111

Clóvis do Couto e Silva, Op. cit., p. 36: “A sentença na ação de consignação em pagamento há de ter implicitamente a reserva de que o réu possa, em outro procedimento específico, alegar as pretensões que ultrapassarem os limites do procedimento. Estas limitações fazem com que a sentença seja ‘sob reserva’, isto é, com a possibilidade de que o réu argúa em outro procedimento as suas pretensões”.

112

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 39: “Toda e qualquer matéria estranha ao objetivo da liberação do devedor é por hipótese impertinente. Mas isso não significa afastar toda discussão em torno da origem e natureza do débito, ou do seu valor; ao contrário, tal debate pode ser, e frequentemente é, indispensável ao convencimento do juiz relativamente à presença ou ausência, no caso concreto, do fundamento legal invocado pelo autor”. Com o mesmo entendimento se pronunciou Antonio Carlos Marcato, Op. cit., p. 71: “Mesmo sendo indiscutível que a própria lei processual procura restringir a matéria de contestação a certos limites (art. 896, CPC), isto não significa que esteja vedada a discussão a respeito da natureza, valor ou origem do débito”.

113

Adroaldo Furtado Fabrício, Op. cit., p. 40: “O julgamento verdadeiro e propriamente dito da ação consignatória, vinculativo para as partes e gerador de coisa julgada material, jamais poderia exceder os limites da declaração positiva ou negativa de eficácia liberatória do depósito. A declaração de liberação, e nada mais do que ela, é o bem da vida perseguido pelo autor; só ela é objeto do *petitum* que, por sua vez, delimita o conteúdo do *decisum*. Isso não importa, porém, em colocar-se fora do alcance do juiz, como razões de decidir, a resolução de outras questões. (...) Por decorrência, as resoluções sobre elas proferidas não integram o *decisum* e têm puro conteúdo lógico: não fazem coisa julgada material”.

114

Daniel Mitidiero, *Colaboração no processo civil*, p. 105, nota de rodapé 1: “Objeto do processo e objeto litigioso do processo são conceitos que não se confundem: o primeiro abarca tudo que se oferece à cognição do juiz no plano horizontal; o segundo define apenas e tão-somente o mérito da causa”.

115

STJ, REsp. 652.711/PE, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 12.03.2007, p. 219 “Ação consignatória. Discussão de cláusulas contratuais. Precedentes da Corte. 1. Esta Corte já assentou que, em se tratando de ação consignatória, ‘é possível ampla discussão acerca do débito, inclusive com o exame da validade de cláusulas contratuais’ (AgRg no Ag 406.408/DF, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrichi, DJ 18.02.2002; no mesmo sentido: AgRg no Ag 432.140/DF, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 17.06.2002; REsp 345.568/SP, 4ª Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 10.02.2003; REsp 299.171/MS, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 10.09.2001; REsp 401.708/MG, 3ª Turma, rel. Min. Castro Filho, DJ de 09.12.2003). 2. Recurso especial não conhecido”. No mesmo sentido:

STJ, REsp. 68.720/SP, 3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, *DJ* 20.09.1999, p. 59: “Processo Civil. Ação de Consignação em Pagamento. Alcance. A sentença de procedência, na ação de consignação em pagamento, tem efeito limitado, o de declarar a quitação pretendida; a cognição do juiz, todavia, é ampla, devendo enfrentar todas as questões articuladas em torno da controvérsia. Recurso especial não conhecido”. Há tempo a questão atinente à possibilidade de exame do crédito houvera sido enfrentada, com profundidade e brilho invulgar, pelo Des. Norberto Ungaretti, em julgado que orientou a jurisprudência do E. TJSC sobre o tema. TJSC, Ap. civ. 29.753, 3ª Câmara Cível, rel. Norberto Ungaretti, *DJ* 13.03.1989, p. 16: “Apelação. Ação de consignação em pagamento. É possível, nestas ações, discutir-se o *quantum debeatur*, pois, frequentemente, sem tal discussão, envolvendo inclusive a relação negocial existente entre as partes, não terá o juiz como saber se a recusa do credor foi justa, ou se o pagamento ofertado é ou não é integral. Carência de ação afastada. Oferecido pelo contribuinte, para pagamento de contribuição de melhoria, valor menor do que o devido, improcede a consignação. Sentença confirmada”. No acórdão lavrado pelo grande jurista catarinense há minudente análise da doutrina, a qual culmina na conclusão de que o *quantum debeatur* pode ser examinado na demanda consignatória.

116

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1.º O disposto no *caput* aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I – dessa resolução depender o julgamento do mérito; II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. § 2.º A hipótese do § 1.º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

117

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 83, destaca que a condenação ocorrerá sempre que for possível à luz das provas: “O § 2.º do art. 899 prescreve que, vindo a ação a ser julgada improcedente por insuficiência do depósito, o juiz, sendo isto possível em face da prova constante dos autos, determinará o valor integral da obrigação, valendo a sentença como título executivo para que o credor que fora réu na ação consignatória promova a execução forçada pelo saldo. As duas novidades são positivas e relevantes: a ação, que originariamente era apenas declaratória, agora adquire eficácia condenatória, para permitir – contra o autor – a cobrança executiva”.

118

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 111: “Como dito, em sua contestação o réu poderá alegar, sem prejuízo da dedução de outras defesas, a insuficiência do depósito realizado pelo autor, seja ele o extrajudicial (art. 890, § 3.º) ou o judicial (art. 893, I). Cumpre-lhe, nesse caso, indicar o exato montante que entenda devido, discriminando as verbas (ou os objetos) que o integram, pois: a) a não indicação acarretará a pura e simples desconsideração dessa defesa (art. 896, parágrafo único); e se ela representar o *único* fundamento da contestação, tecnicamente o réu estará na mesma situação do revel, sofrendo as consequências que daí advêm; (...)”.

119

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

120

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos ou parcela deles: I – mostrar-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

121

Para análise do julgamento antecipado parcial do mérito, ver Ricardo Alexandre da Silva, *Breves comentários ao novo código de processo civil*, p. 960 e ss.

122

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 32-33: “Exigindo o § 1.º do art. 890 que o depósito extrajudicial se faça em estabelecimento bancário oficial, ‘onde houver’, devemos concluir que, em não havendo essa espécie de casa bancária, a modalidade de consignação extrajudicial não será admissível. Seria possível objetar que esse impedimento somente poderia haver se o legislador tivesse usado a locução ‘se houver’, ao invés de ‘onde houver’, como consta da lei. Entretanto, a nosso ver, a expressão contida no texto impõe que se tenha por inviável o depósito extrajudicial caso não haja estabelecimento bancário oficial no local”. Em sentido contrário, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 46: “A solução correta é a de identificar-se mera prioridade dos bancos oficiais sobre os outros, pois não parece haver razão aceitável para atribuir-se maior confiabilidade aos estabelecimentos dessa classe ou maior segurança aos depósitos a eles recolhidos”.

123

A definição de “bancos oficiais” é trazida no art. 1.º, § 1.º, da Resolução 2.814/2001 do Banco Central: “Para os efeitos da Lei 8.951/1994, as instituições financeiras públicas definidas como estabelecimentos bancários oficiais são os bancos múltiplos com carteira comercial e os bancos comerciais, federais e estaduais, e a Caixa Econômica Federal”.

124

Encontra-se no processo civil conhecido exemplo de privilégio à Administração Pública, consistente na concessão, no art. 183 do CPC, de prazo em dobro para qualquer manifestação processual da União, Estados, Municípios, bem como suas autarquias e fundações de direito público. É sabido que a advocacia pública encontra-se bem aparelhada. Nem a União, com a AGU, nem os Estados, com suas procuradorias estaduais, são prejudicados na sua representação em juízo. Pode ser que isso ocorra em algum município, mas se trata de fenômeno residual. É indiscutível que o advogado privado, que litiga defendendo o cidadão contra a Administração Pública, dispõe de menos recursos para a defesa de seu cliente. Principalmente do mais importante deles: tempo. Não há justificativa, portanto, para o privilégio concedido à Administração Pública. Nem mesmo os “trâmites internos” da Administração justificam o prazo dobrado. Antes de conceder tratamento privilegiado à Administração, seria mais importante combater a sufocante burocracia que leva à perda de tempo e recursos na defesa dos interesses do Poder

125

Jorge Caldeira, *História do Brasil com empreendedores*, p. 328 e ss., demonstra como a atuação da Coroa, mediante desvalorização da moeda mediante impressão de dinheiro sem lastro no aumento da produção e tomada de empréstimos sem fins produtivos, inviabilizou o surgimento de um sistema privado de crédito após a Independência, fator imprescindível para que o país se desenvolvesse. O mesmo autor aponta que houve circulação de capitais em 1851, como resultado da proibição do tráfico de escravos, oportunidade aproveitada pelo Barão de Mauá, que criou o segundo Banco do Brasil. Ocorre que já em 1853 o banco foi estatizado, após iniciativa do partido Conservador. Argumentava-se que o banco privado suscitaria a especulação. O Império retardava o desenvolvimento econômico em nome de interesses privados. Percebe-se o quão enraizada na mentalidade brasileira é a desconfiança ao empreendedorismo, baseada na noção de que o Estado é o agente econômico por excelência. A primazia outorgada aos bancos oficiais para a realização do pagamento em consignação é reflexo dessa mentalidade.

126

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 34: “Não será possível a opção pelo depósito extrajudicial nos casos em que o credor, sendo desconhecido ou achando-se em lugar ignorado ou de difícil acesso, devesse ser cientificado por edital; assim como não será admissível essa forma de depósito se o devedor ou o terceiro depositante ignorarem o endereço do credor, ou no caso de haver litígio sobre o objeto de pagamento”.

127

Antonio Claudio Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 49: “Desconhecendo o interessado na extinção da dívida quem seja o credor (*dúvida quanto à identidade física*), ou tendo dúvida quanto à titularidade do crédito (*dúvida quanto à qualificação jurídica*), não poderá valer-se do depósito extrajudicial, seja pela impossibilidade de cientificar-se o destinatário da providência (no primeiro caso), seja porque o depósito não pode ser condicional, devendo referir-se a credor certo (no segundo). Sendo o credor incapaz, não poderá validamente receber ou dar quitação (CC, arts. 936 e 145, I, combinados), nem terá valor legal eventual recusa que venha a manifestar em relação ao depósito efetuado em seu favor, ficando inviabilizado, no que a ele concerne o depósito aludido no art. 890 do diploma processual civil”.

128

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código...* cit., p. 588: “A ação de consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação rege-se pelo art. 67 da Lei 8.245/1991. Nada impediria, porém, o emprego da consignação extrajudicial, com o depósito bancário, para consignação de aluguéis”.

129

Antonio Claudio Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 43 e ss.

130

Art. 4.º A instituição financeira, quando do recebimento de depósitos de consignação em pagamento, deve expedir, dentro de dois dias úteis, a correspondente notificação ao credor, cujo aviso de recepção deve ser assinado pessoalmente pelo destinatário e conservado pela instituição para os fins previstos em lei.

131

Antonio Claudio Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 51.

132

STJ, AgRg no Resp. 1.393.135/DF, 4ª Turma, rel. Min. Raul Araújo, *DJe* 18.06.2014: “(...) 3. Na consignação em pagamento, realizado o depósito extrajudicialmente e inerte o credor, apesar de notificado, não se configura a extinção automática da obrigação quando os elementos dos autos levarem a conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

133

Art. 6.º Ocorrendo a formalização de recusa por parte do credor, a instituição financeira deve expedir notificação ao depositante, no prazo de um dia útil, com aviso de recepção, para que o mesmo possa, nos termos da lei, fazer uso da prerrogativa de proposição de ação de consignação em pagamento prevista na legislação em vigor.

134

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 33.

135

TJRS, Ag inst. 70021352208, 10ª Câmara Cível, rel. Paulo Roberto Lessa Franz, *DJ* 24.09.2007: “Agravo de Instrumento. Contratos Agrários. Consignação em Pagamento. O ajuizamento da ação de consignação em pagamento fora do prazo de 30 dias estabelecido no § 3.º do art. 890 do CPC acarreta a ineficácia do depósito extrajudicial realizado em instituição bancária. Necessidade de depósito judicial de valores. Negado seguimento ao agravo de instrumento”.

136

Art. 6.º, parágrafo único. Os depósitos de que trata esta Resolução passam a ser tratados pela instituição financeira como depósitos judiciais, uma vez proposta a ação de consignação em pagamento referida no *caput*, cabendo ao depositante comprovar o fato perante a instituição depositária.

137

Art. 8.º É facultado à instituição financeira ressarcir-se, perante o depositante, de despesas de postagem, elaboração de documentos e outras incorridas na realização dos procedimentos determinados nos termos desta Resolução. § 1.º A instituição financeira poderá cobrar tarifa relativa à manutenção de conta de

depósitos, não superior à estabelecida para contas de depósitos à vista, debitando-a diretamente à conta que acolheu o depósito de consignação em pagamento e até o limite dos recursos nela existentes, decorridos, no mínimo, sessenta dias após o prazo referido no art. 4.º, parágrafo único, II, *a*, desde que não tenha sido proposta a ação de consignação em pagamento referida no art. 6.º e de que os recursos não tenham sido retirados por quem de direito.

138

Art. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente.

139

Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Parágrafo único. Designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles.

140

Ovidio Baptista da Silva, *Comentários... cit.*, p. 35, afirma que na hipótese de desconhecimento do credor, tal como ocorre nos títulos portáteis, a determinação do domicílio do devedor como lugar de pagamento será uma imposição lógica: “Se a dívida for *quérable*, o lugar do pagamento será o do domicílio do devedor, pois aí deverá ajuizar-se a ação de consignação em pagamento. Aliás, em certos casos, a determinação desse foro irá decorrer até mesmo de uma impossibilidade lógica de encontrar-se outro. Pense-se nos casos em que o devedor pretenda liberar-se com a ação de consignação em pagamento, ignorando quem seja o credor, por ser endossável o título representativo da obrigação”.

141

Art. 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor.

142

Judith Martins-Costa, *Op. cit.*, p. 311-312, salienta que a exigência de motivo grave não se confunde com extraordinário ou imprevisível, apesar de estes conceitos estarem compreendidos naquele. Caracterizando o art. 329 do CC/2002 como cláusula geral, a jurista aponta alguns exemplos de aplicação do dispositivo, embora reconheça a escassa utilidade da exemplificação ante as inúmeras hipóteses em que a cláusula pode incidir: “Poder-se-ia, exemplificativamente, aludir à doença grave que abate o devedor, ou seu familiar, a uma greve bancária, a um blecaute que inviabiliza o pagamento que deva ser feito via Internet etc., mas são tantas as hipóteses que a indicação casuística, aqui, é de pouca valia”.

143

Idem, p. 410, define o conceito de “corpo certo”: “‘Corpo certo’, ou ‘coisa certa’, é a coisa determinada, ao menos pelo seu gênero e quantidade (art. 243), que possui, além disto, algum sinal particular que a torna diferente de todas as demais, ainda que da mesma espécie ou qualidade”.

144

Art. 341. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada.

145

Judith Martins-Costa, Op. cit., p. 413, pronunciou-se sobre o tema na vigência do Código Buzaid: “Ora, para compreender ambas as regras (as da lei processual e a do Código Civil) que empregam o termo ‘citação’, compatibilizando-as, é necessário lembrar que o nosso Direito determina que a consignação será requerida no lugar do pagamento (CPC, art. 891, *caput*). Porém há coisas que não podem ser factivamente deslocadas. Assim, conquanto quem determine o lugar onde o credor-réu deve ir ou mandar receber seja o juiz (e, como regra, sendo este lugar a sede do juízo), há hipóteses, como vimos, em que a coisa deve ser entregue no lugar no qual está. Portanto, após a citação do art. 893 do CPC (que é, repita-se, citação *para* o processo), se a coisa deva ser entregue no lugar onde se encontra, haverá outra, para este fim: esta é a citação a que se refere a lei civil”.

146

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

147

Art. 218, § 3.º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

148

Evidentemente o credor só levantará o bem se ele tiver sido depositado. O depósito, por sua vez, só ocorrerá se, antes dele, o credor não houver ido buscar o bem.

149

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

150

Art. 890, parágrafo único. Quando a coisa devida for corpo que deva ser entregue no lugar em que está, poderá o devedor requerer a consignação no foro em que ela se encontra.

151

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...cit.*, p. 73 e ss.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: II – incompetência absoluta e relativa.

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Saliente-se, como também indicado no item 5, dos comentários ao art. 539, que a sentença será condenatória quando reconhecer a insuficiência do depósito, condenando o devedor, autor da demanda, ao pagamento do valor remanescente.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 74: “Se correm juros, cessa sua fluência desde o momento da realização do depósito. Ditos juros tanto podem ser os compensatórios como os moratórios: vimos já que a *mora debitoris* nem sempre exclui a admissibilidade da consignação, pois esta pode funcionar *também* como remédio para emendar a referida mora”. Identicamente, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 37. Em sentido contrário, Clóvis do Couto e Silvia, *Op. cit.*, p. 32, para quem os juros, referidos no art. 891 do CPC/1973 (reproduzido no art. 540 do código processual vigente), não seriam os moratórios: “Os juros, no caso, não são moratórios, pois, estando o credor em mora, eles não fluem (CC, arts. 963 e 1.061). Considera-se a cessação dos juros compensatórios, resultantes da utilização do bem, não da mora”.

Pontes de Miranda, *Comentários...* cit., p. 24.

Art. 343. As despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor, e, no caso contrário, à conta do devedor.

Arnaldo Marmitt, *Op. cit.*, p. 91: “Risco é a possibilidade de dano, que de potencial pode transformar-se em definitivo”.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 75: “Há risco da coisa (*periculum rei*), normalmente suportado pelo seu proprietário (*res perit domino*); risco da prestação, consistente na potencialidade de perecimento do bem que deva ser dado ou outro motivo que torne impossível a prestação; e risco da contraprestação, ou do preço. (...) A regra tanto abrange os riscos da coisa como os da prestação, dependendo de qual seja o objeto do depósito”.

161

Art. 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação.

162

Werter Faria, *Mora do devedor*, p. 137: “Com a mora do credor a outra parte livra-se das consequências do não cumprimento; não incide em mora e, quando estiver incurso nela, cessa. O devedor isento de dolo deixa de responder pelo objeto da prestação, embora siga vinculado”.

163

Súmula 271. A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário.

164

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...cit.*, p. 77.

165

Idem, p. 80: “Não é a periodicidade em si que fornece a *ratio legis*, mas sim a identidade do próprio litígio envolvente das várias prestações. Para não se incidir em pecado de literalismo interpretativo, o dado a considerar-se é que o motivo invocado para a consignação inicial seria, ao menos em tese e presuntivamente, válido também para os depósitos subsequentes. Razoável, é, pois, interpretar-se o dispositivo como se falasse de prestações *sucessivas* e não de prestações periódicas”. E arremata, na página 82: “Assim se deve interpretar a expressão ‘Consignada a primeira: não será esta, necessariamente, a primeira que se venceu, a primeira da série, como talvez pudesse parecer, mas a primeira em relação à qual se apresentou motivo para a consignação’”.

166

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários... cit.*, p. 38; Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação... cit.*, p. 114; Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários... cit.*, p. 81. Arnaldo Marmitt, *Op. cit.*, p. 192, refere-se a interesse processual implícito.

167

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. II, p. 138: “Conceitualmente, não há lugar para a existência de *pedidos implícitos*. Simplesmente, a lei e o sistema *dispensam o pedido* em algumas hipóteses, investindo o juiz do poder de pronunciar-se sobre juro, correção monetária, *astreintes* etc., ainda quando não hajam sido pedidos pelo demandante.” Clóvis do Couto e Silva, Op. cit., p. 33, manifestava-se com grande rigor sobre o tema, assinalando que o depósito das prestações vincendas não dependia de pedido: “Não há necessidade de formular requerimento na inicial ao juiz para consignar as prestações vincendas, uma vez que tal faculdade está expressamente concedida a independe de pedido. A desnecessidade do requerimento para depósito, quanto às prestações vincendas, resulta da disposição expressa do art. 290 do CPC”.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 81-82.

Art. 67, III. O pedido envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover os depósitos nos respectivos vencimentos.

Art. 2.º, § 2.º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 84: “Fora do prazo do artigo, já não se admite o depósito *nos mesmos autos*, mas nada inibe ao autor a propositura de nova demanda consignatória, fazendo instaurar processo distinto”. Com o mesmo entendimento, Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 115. O autor salienta que se não forem depositadas as demais prestações vincendas, o julgamento da demanda levará em consideração tão somente os depósitos realizados. Somente em relação a eles poderá o autor se exonerar.

Permitindo que o depósito ocorra até o trânsito em julgado da demanda, STJ, REsp. 33.976/SP, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 05.08.1996, p. 26.360. No mesmo sentido, TJPR, Ap. civ. 1128527-7, 12ª Câmara Cível, rel. Rosana Girardi Fachin, DJ 14.05.2014: “(...) 2. Em se tratando de prestações periódicas, admite-se o depósito em juízo das parcelas vincendas, até o trânsito em julgado da sentença, evitando-se, com isso, a multiplicação de demandas. 3. É a parte dispositiva da sentença que define os limites do provimento jurisdicional e, portanto, transita em julgado, sendo irrelevante, para essa finalidade, o conteúdo da fundamentação. Recurso conhecido e parcialmente provido”. Permitindo que os depósitos ocorram depois da sentença, STJ, REsp. 439.489/SP, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJ 19.04.2004, p. 151. Reconhecendo que os depósitos devem ocorrer apenas até a sentença, STJ, REsp. 126.610/SP, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 18.05.1998, p. 84. Com o mesmo

entendimento, a restringir o depósito à prolatação da sentença: TJRS, Ap. civ. 70064607997, 13ª Câmara Cível, rel. Elisabete Correa Hoeveler, *DJ* 15.06.2015: “Apelação cível. Ação de consignação em pagamento. Alienação fiduciária. Prestações periódicas. Depósitos após sentença. Impossibilidade. Não admitida a consignação das prestações após a sentença, porquanto implicaria violação ao princípio da segurança jurídica (art. 463, do CPC). Negaram provimento ao apelo. Unânime”. No mesmo sentido: TJSP, Ap. civ. 0023868-13.2011.8.26.0037, 8ª Câmara de Direito Privado, rel. Ferreira da Cruz; *DJ* 18.06.2015: “Hipótese em que 50% do imóvel foi cedido a terceiros. Promitente vendedora que anuiu expressamente a esse negócio. A declaração de extinção da obrigação contida na sentença abrange apenas os depósitos realizados até a sua data. Defesa que não demonstrou a insuficiência desses valores. As parcelas vencidas após esse termo não admitem quitação e, havendo interesse, mantido o levantamento do incontroverso, podem ser equacionadas em base procedimental autônoma. Recurso desprovido”.

174

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 85: “Ora, se é verdade o que ficou dito sobre a natureza declaratória da sentença proferida em ação de consignação, é certamente uma impossibilidade lógica a projeção dessa eficácia meramente declaratória para o futuro: seria preciso admitir-se como declarado (= verificado, certificado, acertado) na sentença que os *futuros* depósitos são regulares e tempestivos, aptos à liberação do devedor”. Na página seguinte, o jurista arremata o raciocínio, invocando dificuldades procedimentais: “Convém que se tenha em mente, outrossim, já do ponto de vista estritamente procedimental, a mencionada possibilidade de impugnação, pelo réu, do depósito intercorrente, impugnação que tem de ser apreciada e decidida. Essa consideração, só por si, põe em evidência, no mínimo, os inconvenientes envolvidos no prosseguimento dos depósitos depois da sentença de primeiro grau, mesmo antes do trânsito em julgado”. Na passagem seguinte, não escapa ao autor que o art. 67, III, da Lei de Locações limita o depósito das prestações vincendas à sentença de primeiro grau. Adota idêntico entendimento Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 115-116.

175

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código...* cit., p. 590: “Viola o art. 541, CPC, a decisão judicial que nega o direito ao depósito das prestações sucessivas depois de prolatada a sentença de primeiro grau. As prestações periódicas podem ser depositadas até o trânsito em julgado. Razões ligadas à economia processual sugerem essa solução”.

176

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 40: “Parece-nos, no entanto, legítimo que o tribunal admita o depósito complementar no caso em que, reformando a sentença que dera pela procedência da ação, considere insuficiente o depósito que a sentença julgara correto”.

177

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit. p. 41. Com maior especificação, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 87: “De um modo geral, incide o artigo sempre que, sendo certa e conhecida a identidade do credor, o pagamento normal é obstado ou dificultado por culpa deste ou por alguma circunstância objetiva”. O autor menciona as hipóteses de ausência e de impossibilidade de acesso ao lugar em que o credor está.

178

Art. 319. A petição inicial indicará: (...) VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

179

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 88: “A singularidade da inicial estará, sobretudo, no requerimento de citação, porque esta tem de ser feita, e portanto requerida, com a cumulativa qualidade de interpelação especial para receber, mediante levantamento do depósito”.

180

José de Moura Rocha, *Anotações sobre a consignação em pagamento*, p. 26: “A par da quantia, preceitua o art. 890 que deve ser requerida a consignação da ‘coisa devida’. Destarte, há de ser depositada ela, a coisa devida, sem possibilidade de poder ser substituída por outra prestação. Acontecendo assim estaríamos frente a uma dação em cumprimento violando o princípio de que as obrigações hão de ser cumpridas nos termos convencionados”. João de Matos Antunes Varela, *Op. cit.*, vol. II, p. 191, assinala, à luz do direito português, que inexistirá eficácia exoneratória se for depositada coisa diversa da convencionada: “Fiel à ideia de que não é possível a *dação em cumprimento* sem o assentimento do credor (art. 837º), a lei não reconhece validade liberatória ao depósito que não tenha por objeto a coisa que integra a prestação devida (arts. 1.027º, b e 1.029º do CPC)”.

181

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

182

Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

183

Art. 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

184

Art. 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação.

185

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterà: I – a individuação, tão completa quanto possível, do

documento ou da coisa; II – a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III – as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

186

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 91.

187

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

188

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

189

STJ, AgRg no Ag 909.173/RS, 1ª Turma, rel. Min. José Delgado, *DJe* 23.04.2008: “(...) 4. A posição assumida pelo TRF da 4ª Região encontra-se em harmonia com o entendimento deste STJ, confira-se: ‘não efetuado o depósito da quantia ou coisa devida no prazo legal, apesar de intimado o autor da consignatória, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC’ (AgRg no Ag 683.402/RJ, rel. Min. Jorge Scartezzini, *DJ* 13.02.2006)”.

190

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

191

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 93.

192

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 91: “O depósito deve ser realizado, necessariamente, antes da citação, pois sem ele o feito não pode prosseguir: o réu não teria depósito para levantar, sendo essa precisamente uma das opções que a citação lhe deve abrir”. O posicionamento é reiterado na página 93 da mesma obra: “O depósito é ato imprescindível ao prosseguimento do processo. Somente após a sua efetivação se pode cogitar da citação do demandado”.

193

Art. 246. A citação será feita: I – pelo correio; II – por oficial de justiça; III – pelo escrivão ou chefe de

secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV – por edital; V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1.º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2.º O disposto no § 1.º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta (...).

194

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: II – quando o citando for incapaz.

195

Art. 256. A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...).

196

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 91: “O terceiro que vai receber pelo credor tem de estar habilitado a passar quitação. Tanto poderá ser um procurador, munido dos correspondentes poderes especiais, como simples preposto que consigo leve recibo, subscrito pelo credor – tal como se passa no pagamento comum, extrajudicial”.

197

Priscila Kei Sato, *Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil*, p. 1.415.

198

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 2.º. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

199

STJ, REsp. 616.357/PE, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, *DJ* 22.08.2005, p. 263 “Ação de consignação em pagamento. Cumulação de pedidos. Precedentes da Corte. 1. Já decidiu a Corte ser possível em ação de consignação em pagamento ‘examinar o critério de reajustamento em contratos de mútuo para a aquisição da casa própria’ (REsp 257.365/SE, de minha relatoria, *DJ* 18.06.2001). Há, também, precedente no sentido de que se admite ‘a cumulação dos pedidos de revisão de cláusulas do contrato e de consignação em pagamento das parcelas tidas como devidas por força do mesmo negócio jurídico’ e de que quando o autor cumula pedidos ‘que possuem procedimentos judiciais diversos, implicitamente requer o emprego do procedimento ordinário’ (REsp 464.439/GO, rel. Min. Nancy Andrigli, *DJ* 23.06.2003). 2. Não viola o art. 292, § 1.º, I e II, do CPC, a decisão que defere ao autor a possibilidade de opção pelo

procedimento ordinário antes do indeferimento da inicial. 3. Recurso especial não conhecido”. Sob o código vigente, a possibilidade de cumular a consignação, com a revisão de cláusulas contratuais, foi expressamente admitida pelo TJPE, Ag. Inst. n. 0000677-89.2016.8.17.9000, Gabinete da 1ª Vice Presidência Segundo Grau, Rel. Jones Figueiredo Alves, j. 25/04/2017: “Direito Civil e Processual Civil. Ação revisional de Contrato c/c Consignatória. Pretensão Consignatória. Ausência de Verossimilhança das Alegações. Depósito do Valor Incontroverso da Dívida. Impossibilidade. Agravo Improvido. Decisão Unânime. A rigor, a pretensão consignatória das parcelas é uma faculdade conferida ao devedor, consoante permissivo do art. 335, V, do Código Civil. Contudo, ainda a rigor, tal depósito deverá abarcar o valor integral da dívida, a teor do art. 334 do CC/2002 – ao falar em coisa devida – e ainda em homenagem ao princípio “pacta sunt servanda”. O depósito de valor diverso do contratado apenas se mostra possível se, dentre outros requisitos, o autor demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações, no caso, as alegações de abusividade das cláusulas contratuais – o que, porém, não restou demonstrada. Ausente a demonstração da verossimilhança das alegações do autor, não cabe autorizar o depósito em valor diverso do contratado. Isso implicaria manifesta afronta ao princípio “pacta sunt servanda”, além do que não há como se exigir do credor receber alguém do contratado, mormente quando, repita-se, em primeira análise, não há aparente ilegalidade no contrato. De outro lado, a exclusão ou a não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito apenas se apresenta viável diante do efetivo depósito judicial do valor contratado, pois este é que tem o condão de suspender/elidir a mora. Agravo improvido. Decisão unânime”.

200

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I – resolver as questões processuais pendentes, se houver; II – delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III – definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV – delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V – designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento (...).

201

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

202

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; (...).

203

Art. 3.º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2.º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

204

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 43: “(...) é possível ocorrer casos em que se deva antecipar o depósito, em circunstâncias especiais. Esta emergência poderá ocorrer quando o devedor necessite realizar o pagamento no dia do vencimento da obrigação, ou em qualquer outra data indicada no contrato, sob pena de ser a prestação acrescida de outros encargos, decorrentes, por exemplo, da variação do valor monetário da obrigação, ou por qualquer outro motivo seja imprescindível o depósito imediato da quantia ou coisa devida. (...) As opções seguidas nestes casos foram o ajuizamento de uma ação de depósito cautelar preparatória ou este mesmo pedido de depósito – com sentido cautelar, mas na verdade antecipatório – na própria ação de consignação em pagamento”.

205

Pontes de Miranda, *Comentários...* cit., p. 27-28. O jurista aludia ao “estado de necessidade” decorrente da impossibilidade de o devedor comparecer no lugar, dia e hora determinados para a entrega do bem ou da quantia. A passagem foi escrita antes da modificação do art. 893 do CPC/1973, pela Lei 8.951/1994, a qual concedeu ao dispositivo redação semelhante à do art. 542 do código vigente. Ocorre que o estado de necessidade a que alude o jurista só poderia ocorrer se, antes do depósito, o juiz designasse data e lugar para a entrega da prestação, algo que deixou de ocorrer a partir da vigência da referida lei.

206

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 93.

207

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

208

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

209

Art. 292, § 2.º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

210

Art. 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher; feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente.

211

Art. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor.

212

Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou.

213

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 97: “Com efeito, o ajuizamento da ação faz supor que já se ache o credor em mora para receber, na especial modalidade de mora em escolher. Se prazo havia para esse fim, já se terá esaurido. Só se pode ressaltar a improvável hipótese de haver a lei ou o contrato previsto para a espécie um segundo prazo de escolha, especificamente para o caso de se ter de resolver em juízo o problema”.

214

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 45.

215

Judith Martins-Costa, *Op. cit.*, p. 418: “A solução, nos termos da lei civil é que, citado o credor, se mesmo assim não escolher, modifica-se a regra, e a escolha passa a ser do devedor”.

216

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 97.

217

Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.

218

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 97.

219

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 46, analisa o oferecimento de contestação na hipótese prevista no art. 894 do CPC/1973, reproduzido quase que literalmente no art. 543 do código vigente: “Nos casos comuns de ação de consignação em pagamento, fundada em *mora creditoris*, a citação é feita para que o credor compareça para receber a quantia ou coisa depositada, ou para contestar a ação. O prazo, porém, corre normalmente desde a citação. Nas hipóteses abrangidas pelo art. 894, porém, a citação é feita para que o credor proceda à escolha. Efetivada esta, novo prazo haverá de transcorrer até que o devedor possa oferecer o pagamento. (...) Entretanto, nas hipóteses do art. 894, é necessário que o juiz, ao

despachar a petição inicial, mande citar o demandado para que ele proceda à escolha; bem como proveja a respeito da contagem do prazo a ser concedido para a contestação”. Com o mesmo entendimento se manifestou Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 107: “É oportuno lembrar, a esse propósito, que no caso de obrigação de entrega de coisa indeterminada, ou insuficientemente determinada, com faculdade de escolha atribuída ao credor, continua vigente a determinação legal de prévia designação pelo juiz de data e hora (retro, art. 894). Em tal hipótese, é claro que o prazo de resposta não pode correr do aperfeiçoamento da citação, pois há outros atos a serem necessariamente processados antes. Portanto, nessa peculiaríssima situação, continua a vigorar a regra antiga, agora não escrita mas imposta pelo sistema: o prazo para contestar passa a fluir da data designada, em que se haja efetivado o depósito”.

220

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 105.

221

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

222

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 108. Apesar de admitir essa modalidade de resposta, o autor ressaltava a inexistência de interesse processual no oferecimento de reconvenção para obter eventual diferença do depósito. Com efeito, resulta do próprio art. 545, § 2.º (art. 899, § 2.º, do CPC/1973) a constituição de título executivo sobre a diferença entre o valor depositado e o efetivamente devido, razão pela qual não é necessário reconvir a fim de obtê-la. Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 106-107, também aceitava o oferecimento de reconvenção. Arnaldo Marmitt, *Op. cit.*, p. 123, admitia essa modalidade de resposta, mas assinalava que não poderia ser ultrapassado o objeto do processo, restrito à exoneração do devedor. Escrevendo sob o código atual, Priscila Kei Sato, *Op. cit.*, p. 1.415, assinala a possibilidade de oferecimento de reconvenção.

223

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 112-113. Depois de assinalar que o réu poderia opor exceção de incompetência relativa ou, no mérito, contestar o depósito em lugar incorreto, acrescentou o jurista: “Se está disposto a receber, mas só no lugar designado para o pagamento segundo a lei ou o contrato, basta-se o credor com a exceção. Se, ao contrário, interessa-lhe impedir a liberação do devedor, servir-se-á da alegação para contestar”. Concorde-se com esse posicionamento, sendo irrelevante, a conversão, no código vigente, da exceção de incompetência relativa em mero capítulo da contestação.

224

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

225

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 108, ao comentar o art. 896, do CPC/1973, faz precisa análise sobre o tema: “Com efeito, o que se pretende, e é realmente necessário, é preservar a especificidade do objeto da ação, assegurando-se no seu âmbito a discussão do que diga respeito ao pagamento e à sua eficácia liberatória – e nada mais do que isso. Ocorre, porém, que essa discussão, frequentemente, envolve os pressupostos primeiros não só da consignação, em si, mas do pagamento mesmo, tais como a existência do débito, a legitimação para pagar e receber, o valor a ser pago e assim por diante”.

226

Quando o fundamento da demanda consignatória for a incapacidade do credor (CC/2002, art. 335, III), impõe-se que a citação se realize mediante oficial de justiça (CPC/2015, art. 246, II, c/c art. 247, II).

227

A citação será feita por edital quando o credor não for conhecido ou se o lugar em que se encontrar for ignorado, incerto ou inacessível (CPC/2015, art. 246, IV, c/c art. 256, I e II).

228

Art. 246, § 1.º. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

229

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 108-109: “Sustentando o réu, em sua contestação, a inocorrência de recusa ou de mora em receber a quantia devida (art. 896, I) e sendo a dívida de natureza portátil, é do autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 333, I), vale dizer, deverá ele demonstrar que diligenciou (infrutiferamente, porém) o pagamento junto ao credor. Tratando-se de dívida quesível, bastará ao autor alegar que o réu não foi, nem mandou buscar a prestação devida, no tempo, lugar e modo convencionados, caso em que competirá ao segundo o ônus de provar que diligenciou o recebimento”.

230

Clóvis do Couto e Silva, *Op. cit.*, p. 44: “O conceito de justa causa submete-se ao que já foi dito anteriormente, quando se examinou o âmbito da ação de consignação em pagamento. Justa causa para o não recebimento da prestação são todas aquelas previstas no CC, sem as quais não se realiza um adimplemento satisfatório. A causa da obrigação e a validade, por exemplo, do contrato, nem sempre podem ser discutidas na ação de consignação em pagamento. Por isso, já se mencionou que a sentença, sob certos aspectos, é ‘sob reserva’, permitindo, mais tarde, ao credor a formulação de suas pretensões em outro procedimento”. Em sentido semelhante, defendendo a “sumariedade material” da cognição realizada nas ações de consignação, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 55 e ss.

231

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 112. Todos os exemplos são tirados do autor, que critica muito precisamente a ideia de que a consignatória ensejaria a emissão de sentença “sob reserva”.

232

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 109.

233

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 113: “À parte o caso de inutilidade da prestação, pode ocorrer que o credor tenha já, quando lhe permitam a lei ou o contrato, extraído da *mora debitoris* consequências tais que a tornem irreversível e insuscetível de ser emendada – como, v.g., se há cláusula resolutória do negócio jurídico, e o credor já a acionou”.

234

Para maiores considerações sobre o tema, remete-se o leitor ao item 1.1 dos comentários ao art. 539.

235

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 110.

236

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

237

Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes.

238

STJ, REsp. 260.743/SP, 4ª Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., DJ 23.10.2006, p. 314. No mesmo sentido, destacando a impossibilidade de contestação genérica, TJPR, Ap. civ. 1.343.195-5, 7ª Câmara Cível, rel. Fábio Haick Dalla Vecchia, DJ 06.07.2015: “Ação de consignação em pagamento. Contrato de financiamento para aquisição de veículo.1. Via processual eleita. Adequação. Recusa do credor em receber o valor devido. Art. 890 e § 1.º, CPC. 2. Valores consignados. Rejeição genérica na contestação. Necessidade de impugnação específica. Ônus a cargo da ré. Arts. 302, 333, II e 896, IV e parágrafo único, do CPC.3. Recurso conhecido e não provido.1. A consignação em pagamento é a via processual adequada para adimplir a obrigação quando há recusa da credora em receber o valor respectivo.2. Ao réu da ação de consignação em pagamento compete impugnar, especificamente, os valores consignados em juízo, indicando, de forma precisa e detalhada, o montante que entende devido, sob pena de serem aceitos os valores oferecidos pelo autor.3. Recurso conhecido e não provido”. Assinale-se, contudo, que o juiz não está adstrito ao valor depositado pelo autor, podendo determinar a produção de provas sobre o tema. A medida será necessária sempre que, a despeito da contestação genérica, o valor depositado parecer insuficiente.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 80, adotava entendimento diverso ao que foi consolidado no STJ, fazendo alusão à improcedência da demanda em decorrência da insuficiência do depósito: “Imaginemos que a sentença reconheça a legitimidade da recusa manifestada pelo credor e, pois, a insuficiência do depósito, julgando a demanda improcedente”. Em outra passagem da mesma obra, presente na página 84, a vinculação entre insuficiência do depósito e improcedência da demanda é realizada de forma mais explícita: “Seria o caso de admitir, nestas hipóteses, que o julgador, ao julgar improcedente a ação, por insuficiência do depósito – indicando os critérios que deveriam ser obedecidos para o cálculo –, determinasse a liquidação por cálculo de seu exato valor”. Também Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 136, após se referir à possibilidade de recusa de complementação, afirma que a insuficiência do depósito levará à improcedência da demanda: “Fá-lo-á, é claro, a seu risco, e a divergência que assim perdurará sobre o *quantum* devido será ao fim dirimida pela sentença – que repelirá a demanda se o juiz se convencer da efetiva insuficiência do depósito, aplicando, outrossim, o agora disposto no § 2.º”. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou entendimento contrário, de acordo com o qual a insuficiência do depósito impõe o reconhecimento da improcedência parcial da demanda: STJ, REsp. 756.341/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, DJ 10.12.2007, p. 373: “Processual Civil. S.F.H. Ação de Consignação em Pagamento. Depósito Parcial. Valores Incontroversos. Cabimento. Remessa para Apuração do Valor à Fase Posterior. Possibilidade. CPC, Art. 899, § 2.º. Exegese. I. A insuficiência do depósito não significa a improcedência do pedido, mas que o efeito da extinção da obrigação é parcial, até o montante da importância consignada, que poderá ser futuramente complementada, tão logo realizados os cálculos e apurado o real montante do débito, na esteira da jurisprudência mais recente da 4ª Turma, aplicando o disposto no art. 899, do CPC (REsp. 448.602/SC, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, unânime, DJU 17.02.2003). II. Recurso especial não conhecido”. No mesmo sentido: STJ, REsp. 645.756/RJ, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, DJe. 14.12.2010. O posicionamento do STJ está correto e deve ser prestigiado.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 115-116. Os três exemplos citados até a inserção da nota foram tirados do autor.

Art. 897. Não oferecida a contestação, e ocorrentes os efeitos da revelia, o juiz julgará procedente o pedido, declarará extinta a obrigação e condenará o réu nas custas e honorários advocatícios.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 118: “Não se pretenderá ver no dispositivo intenção de obrigar ao julgamento de procedência, automático e inelutável. Se falta prova documental imprescindível, ou se o juiz verifica que dos fatos expostos não decorre a consequência jurídica apontada, o julgamento de procedência, mesmo em ação consignatória, seria um absurdo lógico e jurídico”.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 69: “Se, pretendendo preservar-lhe a liberdade de

juízo, dêsemos ao magistrado, neste caso, os mesmos poderes que em geral o sistema brasileiro lhe confere, no que diz respeito ao modo como ele formará seu convencimento, na verdade estaríamos indo além desses próprios limites, na medida em que a sentença de improcedência impediria a liberação, que fora o objeto da ação não contestada, além de não atender ao interesse do credor que, pelo silêncio, induz a presunção de que não se recusa a receber o pagamento, consequência que não satisfaria a nenhuma das partes”.

244

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

245

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I – havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

246

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código...* cit., p. 592: “Sendo o caso, nada impede que declare extinto o processo sem resolução de mérito em face de problemas relativos aos pressupostos processuais e às condições da ação. (...) Nada obsta igualmente que determine prova de ofício a respeito das alegações do demandante (art. 370, CPC), ou que entenda que o demandante não tem direito à consignação”.

247

Art. 343, § 6.º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

248

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 70, aludia, sob o código revogado, à adoção do procedimento ordinário quando houvesse contestação: “Havendo contestação, prossegue-se na causa pelo rito ordinário, cabendo, também aqui o julgamento antecipado da lide, quando as questões controvertidas forem só de direito ou, sendo de fato, não exijam produção de prova em audiência”.

249

Art. 357, § 2.º. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incs. II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

250

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente

capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

251

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 137. Em sentido contrário, Pontes de Miranda, *Comentários...* cit., p. 54, para quem o prazo haveria de ser contado a partir do oferecimento da contestação: “A solução tem de ser a de se contar do dia da contestação (art. 896) e não depois de terminado o prazo para contestação. Quem logo contesta não pode ser prejudicado com o resto do prazo”. Com a devida vênia ao grande jurista, não se atinar qual seria o prejuízo do réu, sobretudo porque a complementação do depósito em regra o beneficia, ressalvadas as hipóteses em que pretenda manter o devedor preso à obrigação.

252

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 136-137: “O decêndio dentro do qual se admite a complementação é prazo preclusivo, e depois de sua extinção já não poderá o autor corrigir a insuficiência do depósito. Ter-se-á de prosseguir no processo até a sentença que a reconhecerá ou não. Naturalmente, em momento posterior ao previsto, sempre poderão as partes transigir, e até mesmo pôr fim ao litígio mediante pagamento complementar da diferença, mas aí já não se está no âmbito da incidência do artigo, e sim no da composição consensual do litígio. Por outras palavras, só dentro do prazo a parte autora tem *direito subjetivo* a realizar a complementação; fora dele, só a poderá fazer com anuência do réu”. No mesmo sentido, Arnaldo Marmitt, *Op. cit.*, p. 171.

253

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 79, afirmava tratar-se de faculdade outorgada ao credor. O mesmo entendimento foi manifestado por Arnaldo Marmitt, *Op. cit.*, p. 170 e por Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 136. Este jurista empregou o termo *faculdade* contrapondo-o a *dever*.

254

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições...* cit., vol. II, p. 204 e ss.: “Ônus é, por definição, um *imperativo do próprio interesse* (James Goldschmidt). É *encargo*, ou *peso*. Ele é o reverso de certas faculdades outorgadas às partes e caracteriza-se pelas consequências desfavoráveis que a lei associa a algumas delas. (...) Existem *ônus* absolutos e *ônus* relativos. São absolutos aqueles cujo não cumprimento conduz *inevitavelmente* ao resultado desfavorável. Sem o preparo o processo não será realizado e os recursos não serão processados em hipótese alguma, não havendo a menor esperança de que algum fato interfira para neutralizar os efeitos do descumprimento. (...) Os *ônus* relativos não trazem consequências inexoráveis. Descumpridos, seu titular *corre o risco* de ser prejudicado, mas ainda é possível que o risco não se consume – o que se dará se interferir algum acontecimento favorável”. Vitor de Paula Ramos, *Ônus da prova no processo civil*, p. 66 e ss., formula crítica muito bem fundamentada à tradicional divisão entre ônus perfeito ou absoluto e ônus imperfeito ou relativo: “A posição, apesar de repetida no Brasil, não parece persuasiva. Isso porque a consequência prevista na regra que atribui o *ônus*, conforme já mencionado, é fundamental e estrutural

ao seu funcionamento; é justamente o resultado em tese que estimula o sujeito a adotar a conduta, dependendo de sua atratividade. Sem a previsão de algum resultado, o ‘ônus imperfeito’ simplesmente perde sua normatividade, sua limitação à liberdade do sujeito da regra que o atribui, visto que a conduta passa a traduzir-se apenas em uma necessidade prática, uma faculdade do sujeito; deixa, portanto, de ser um *ônus jurídico* em sentido técnico”. Em conclusão sobre o ponto, afirma (p. 68): “Para que algo possa ser considerado um ônus, repita-se, é necessário que a regra preveja uma conduta e uma consequência jurídica correspondente, tanto para a adoção, quanto para a não adoção, a fim de que o sujeito da regra seja estimulado a praticar a conduta desejada, através da expectativa legítima do resultado”. Anissara Toscan, *Preclusão processual civil*, p. 106, também critica com grande precisão a classificação entre ônus relativos e absolutos: “Ao nosso sentir, os ônus processuais poderão assumir *graus de perfeição* diversos em virtude das circunstâncias específicas dos casos concretos, razão pela qual não há como se classificá-los *a priori* em perfeitos e imperfeitos ou absolutos e relativos. Sob essa perspectiva, há de se reconhecer que, embora as preclusões incontornavelmente operem quando verificadas suas causas ensejadoras, a intensidade dos efeitos que produzirão no processo dependerá do grau de perfeição que o ônus correspondente assumirá em cada situação específica”. Concorde-se que a correlação entre um resultado no processo e a conduta da parte é essencial ao conceito de ônus. Também se reconhece que os ônus processuais podem assumir feições específicas à luz do caso concreto. Todavia, analisado o efeito da inércia da parte, pode-se chegar à conclusão de que há ônus absolutos, cujo não desincumbimento, pela parte onerada, necessária e inevitavelmente levará a um prejuízo. Não é o que ocorre com o ônus relativo. A parte ficará em uma situação vantajosa com a desoneração. A vantagem é relativa, devendo ser comparada à situação da parte se não se desincumbisse do ônus. Assim, o ônus de responder a demanda não necessariamente conduzirá à procedência, mas o réu, sobretudo quando caracterizados os efeitos da revelia, está em situação pior à que estaria caso houvesse se desincumbido do encargo que lhe era atribuído. É o que ocorre com a complementação do valor objeto da consignação. Não se trata de dever, nem, tampouco de mera faculdade. É ônus a gravar o demandante, cuja não desincumbência, caso se comprove a insuficiência do depósito, conduzirá à procedência parcial da demanda, a impedir a exoneração integral e a autorizar a execução nos mesmos, pelo credor, do valor remanescente.

255

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 138: “Nenhum efeito opera a complementação parcial, mediante a qual o autor, reconhecendo dever mais do que consignara, mas entendendo ser a diferença menor do que a pretendida pelo credor, recolhe a depósito um saldo inferior àquele (vale dizer, o devedor depositara x; o credor alega que o débito é x + 2; o devedor deposita em complemento mais 1, alegando ser de x + 1 o valor realmente devido). Por inútil, tumultuadora e protelatória, uma tal complementação não deve sequer ser admitida – salvo, naturalmente, se concordar o réu, caso em que mais uma vez estaremos no terreno da transação”.

256

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 112. Identicamente, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 140.

257

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 139-140. Para o autor a sentença não coincidiria com qualquer das hipóteses previstas no art. 269 do CPC/1973, reproduzido no art. 487 do código vigente.

Também para Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 112, não há correspondência entre a sentença proferida na demanda consignatória após a complementação de depósito e os provimentos jurisdicionais previstos no art. 269 do CPC/1973.

259

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 138-139.

260

Idem, p. 142.

261

Nesse sentido decidiu o TJPR, Apelações Cíveis n.ºs. 6866-79.2009.8.16.0004 e 6863-27.2009.8.16.0004, 5ª Câmara Cível, Rel. Carlos Mansur Arida, j. 15/05/2018: “Apelações Cíveis. Ações de Consignação em Pagamento. Contrato Administrativo. Pretensão de Quitação das Obrigações Contratuais Mediante Depósito do Valor Incontroverso. Justa Recusa por Parte da Ré. Art. 544, II, do CPC. Existência de Pendências Reconhecida em Ação Própria. Inexistência de Dúvida Quanto à Titularidade do Crédito. Levantamento do Valor Depositado Independentemente do Trânsito em Julgado. Possibilidade. Valor Incontroverso. Majoração dos Honorários Advocatícios. Descabimento. Fixação que Atendeu aos Parâmetros Legalmente Previstos no Art. 85, §2º, do CPC. Recurso 01 Desprovido. Recurso 02 Parcialmente Provido. Recurso 03 Prejudicado”.

262

STJ, REsp 886.823/DF, 3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, *DJ* 25.06.2007, p. 236: “Ação de Consignação em Pagamento. Caráter Dúplice. A ação de consignação em pagamento, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também de modo mediato porque a sentença proporcionará um título executivo para a cobrança do saldo remanescente (CPC, art. 899, §§ 1.º e 2.º). Recurso especial conhecido e provido”.

263

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 128-129.

264

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) inc. IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

265

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*, vol. II, p. 764. No mesmo sentido, Ricardo Alexandre da Silva, *Atipicidade...* cit., p. 547 e ss.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 142-143.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 141: “Os motivos inspiradores da liberalidade legal são aí os mesmos: certo, a complementação não conduzirá à extinção do processo, mas servirá à superação do incidente relativo àquela determinada prestação. Os interesses da celeridade e da simplificação resultarão igualmente atendidos, senão na máxima extensão do objeto do processo, pelo menos no atinente a uma incidência que poderia representar fator de maior complexidade e retardamento. O limitado acordo entre os litigantes, insuficiente para suprimir a lide, servirá ao menos para impedir sua ampliação”.

STJ, REsp. 886.757/RS, rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ 26.03.2007, p. 214 “(...) 3. O depósito em consignação é modo de extinção da obrigação, com força de pagamento, e a correspondente ação consignatória tem por finalidade ver atendido o direito – material – do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação. Trata-se de ação eminentemente declaratória: declara-se que o depósito oferecido liberou o autor da respectiva obrigação”.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 69.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 120.

Idem, p. 89.

O mais comum dentre os fundamentos para a consignação judicial é a recusa do credor, demandado na consignatória, em receber a oferta. Esta, antes da demanda, é realizada na forma convencionada pelas partes. Assim, após a oferta do devedor e a recusa do credor, propõe-se a ação consignatória. O juiz recebe a petição, despachando-a, ocasião na qual determina que o depósito seja realizado no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 542, I e parágrafo único). Realizado o depósito, promove-se a citação do credor, indicando-se o local, o dia e a hora em que poderá receber. Tratando-se de obrigação pecuniária, limitar-se-á o mandado citatório a indicar que o bem está depositado em conta vinculada ao juízo. Ocorrerá o mesmo se se tratar de bem de pequena dimensão, cujo depósito tenha sido realizado nas dependências do Fórum. Não sendo possível depositá-lo aos cuidados da escrivania, será necessário fazê-lo mediante depositário. Nesse caso, avulta em importância a indicação do dia e local em que poderá o credor realizar o levantamento. Tratando-se a obrigação de corpo certo ou

imóvel, que tenha de ser buscado no local em que se encontra (CC/2002, art. 341), ao citar o credor o juiz o interpelará, a requerimento do autor, para que busque a coisa sob pena de depósito, o qual, nesse caso, ainda não terá sido realizado. Tratando-se de obrigação alternativa ou de gênero (CPC/2015, art. 543), o réu será citado para escolher a prestação, sob pena de a especificação ser exercida pelo autor. O mandado citatório também indicará data, horário e local para a entrega da prestação. Se o credor não comparecer, a prestação será depositada. Quando houver dúvida sobre a pessoa do credor (CPC/2015, art. 547), a citação terá o escopo de integrar os réus ao polo passivo a fim de que provem seu direito. A dúvida sobre a titularidade do crédito impede que a citação seja realizada para o levantamento do depósito.

273

Art. 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito.

274

Orosimbo Nonato, Op. cit., p. 33: “Antes que o credor se manifeste pela aceitação do depósito e enquanto o não impugna, poderá o devedor, pagando as respectivas despesas, requerer o levantamento, caso em que subsistirá a obrigação para todos os efeitos de direito. O arrependimento de depositante, anterior àquelas manifestações do credor, terá como consequência voltar a situação ao estado anterior ao depósito”.

275

Judith Martins-Costa, *Comentários...* cit., p. 401: “Se o devedor retira a coisa depositada, o depósito é tido como se não tivesse sido feito (eficácia *ex tunc*). Porém, nem todos os efeitos devem ter como ‘não tidos’: como, em regra, na petição de retirada há o reconhecimento da dívida, uma eficácia peculiar será gerada, qual seja, a interrupção da prescrição”.

276

Pontes de Miranda, *Comentários...* cit., p. 46: “‘Dúvida’, nos arts. 895 e 898, é dúvida (A ou B; ou A ou B ou C) ou ignorância (não se sabe quem é X)”.

277

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 99.

278

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 48: “Em todos esses casos, tanto de dúvida quanto de ignorância sobre a pessoa do credor, fica o devedor dispensado de proceder à oblação real antes de ajuizar a ação”.

279

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 100-101.

280

Idem, p. 102: “A citação a ser requerida pelo autor, nessa emergência, é a daquelas pessoas que ao seu critério se afigurem credores possíveis”.

281

TJSP, Ap. civ. 0328003-77.2009.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, rel. Alexandre Bucci, *DJ* 09.10.2014 “Ação de Consignação em Pagamento. Petição inicial que traz narrativa de propalada dúvida a quem pagar. Não inclusão no polo passivo de todos os supostos pretendentes ao recebimento do numerário que se pretende consignar judicialmente. Oportunidade processual concedida e não atendida pela parte autora. Desfecho de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito que deve ser convalidado (*ex vi* do quanto disposto nos arts. 47, parágrafo único, e 895, ambos do CPC). Recurso de Apelação do autor não provido”. Com idêntico entendimento sobre a caracterização de litisconsórcio passivo necessário, TJRS, Ap. civ. 70054529581, 18ª Câmara Cível, rel. Pedro Celso Dal Pra, *DJ* 26.08.2013: “(...) A ação consignatória somente é cabível em face do credor que se recusa injustificadamente ao recebimento de quantia ou bem ou, então, se, havendo mais de um suposto credor, ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber, ou pender litígio sobre o objeto do pagamento, impondo-se, nesse caso, o litisconsórcio passivo entre os sedizentes credores. (...)”. Ainda, na mesma linha, TJMG, Ap. civ. 1.0702.07.371747-3/001, 14ª Câmara Cível, rel. Rogério Medeiros, *DJ* em 24.05.2011: “(...) O art. 895 do CPC determina a constituição de litisconsórcio passivo necessário quando houver mais de uma pessoa interessada no recebimento da importância consignada judicialmente. (...)”.

282

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 117.

283

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 103.

284

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 73, refere-se à “data designada para o pagamento”. Contudo, não é preciso que o juiz designe data para o pagamento. Basta que no mandado citatório os réus sejam comunicados sobre a existência de demanda consignatória fundada na dúvida sobre a titularidade do crédito, sendo instados a comprovar sua condição de credores. Também é importante que já no mandado conste o valor do depósito.

285

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 122-123.

286

Idem, p. 131 e ss., criticou o art. 898 do código revogado, apontando a inaplicabilidade do procedimento de

arrecadação de bens de ausentes, afirmando que o código deveria se referir ao procedimento relacionado às coisas vagas. Também foi criticada a referência do dispositivo ao procedimento ordinário, sendo salientada pelo autor a superioridade do CPC/1939, que determinava a adoção do concurso de credores quando mais de um postulante apresentasse resposta à demanda consignatória.

287

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 74: “Se nenhum dos contestantes impugnar o pedido, opondo-se ao cabimento da ação, limitando-se as defesas de todos eles a afirmar o próprio direito contra as pretensões dos demais, o juiz sentenciará declarando efetuado o depósito e extinta a obrigação, prosseguindo o processo entre os credores na forma de um concurso de preferência”.

288

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 118-119.

289

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 124.

290

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 131.

291

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit. p. 132. O autor não só criticou a inaplicabilidade da arrecadação de bens de ausentes, como apontou a pertinência, à espécie, do procedimento de arrecadação das coisas vagas, solução que, felizmente, veio a ser adotada no código vigente.

292

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 73: “O juiz somente poderá decidir de plano para encerrar a causa quando, havendo comparecido apenas um dos pretendentes, o devedor concordar em pagar-lhe, assumindo o risco de um possível pagamento indevido”.

293

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

294

Antonio Carlos Marcato, *Ação de consignação...* cit., p. 117-118. O autor se refere à arrecadação de bens de ausentes, prevista equivocadamente, pelo código anterior.

295

TJMG, Ap. civ. 1.0024.12.030838-2/001, 5ª Câmara Cível, rel. Moacyr Lobato, *DJ* em 04.02.2015: “A propositura da ação de consignação em pagamento é possível se houver dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, e, comparecendo apenas um dos pretendentes, o juiz decidirá de plano, não tendo a obrigação de deferir o depósito ao credor que compareceu, como preceituam os arts. 895 e 898 do CPC. (...)”.

296

Nesse sentido, verificar: TJPR, Ap. Cív. 1.718.617-5, 12ª Câmara Cível, Rel. Ivanise Maria Tratz Martins, j. 21.02.2018. Transcreve-se a ementa: “Direito Civil e Processual Civil. Ação de Consignação em Pagamento. Sentença de Procedência, com Declaração de Realização do Depósito pelo Autor e Extinção da Obrigação. Insurgência da Autora e da Primeira Requerida. Apelação 2 (Pela Primeira Requerida, com Matéria Prejudicial à Apelação 1). Pedido de Anulação da Sentença, por Não Ter Sido Dirimida a Dúvida Sobre a Titularidade do Sobre os Depósitos Realizados Pelo Autor (Os Dois Réus Reclamam a Titularidade Sobre a Quantia). Acolhimento. Inobservância do Procedimento Legal. Efetuado o Depósito e Extinta a Obrigação, Impõe-se o Prosseguimento do Feito Unicamente entre os Credores, Observado o Procedimento Ordinário (Art. 898 do CPC/73 e Art. 548, III, do CPC/15). Sentença Anulada. Apelação 1 (Pela Autora). Pedido Para Majoração dos Honorários Advocatícios de Sucumbência. Conhecimento Prejudicado pela Anulação da Sentença. Apelação 1 Não Conhecida e Apelação 2 Conhecida e Provida”. Note-se que nesse caso o juízo de primeiro grau extinguiu o processo logo após a primeira fase, sem determinar o prosseguimento do feito em relação aos credores pretendentes. Extinto equivocadamente o processo, o recurso cabível é a apelação. Fala-se em extinção incorreta porque deveria apenas ter sido encerrada a primeira fase, mediante decisão interlocutória.

297

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 127. Pontes de Miranda, *Comentários...* cit., p. 32: “Cada um dos que se dizem credor tem de proceder como autor e como réu. As alegações e as provas foram apresentadas. Têm de oferecer, no prazo de quinze dias, a contestação, a exceção e a reconvenção (art. 297)”. O jurista se equivocou ao preconizar a necessidade de oferecimento de reconvenção. Da manifestação dos autores, comparecendo ao processo, deve ser depreendida a pretensão ao recebimento do crédito. Seria possível, contudo, que algum dos credores reconviasse contra o autor da demanda.

298

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (...).

299

Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.

300

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 130, defendeu que somente quando comparecesse já na segunda fase do processo o terceiro o faria mediante oposição, sendo-lhe facultado, pendente a primeira

fase, comparecer ao processo sem formular *oposição*.

301

Idem, p. 129: “Em tais casos, portanto, o procedimento se restringirá ao depósito e citação dos disputantes, seguindo-se a declaração judicial de liberação do devedor. Nada mais haveria a processar nos autos da consignatória, pois a matéria que seria objeto da segunda fase procedimental já constitui o conteúdo de outro processo”.

302

Art. 55, § 3.º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

303

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 129.

305

Washington de Barros Monteiro, *Curso de direito civil*, vol. III, p. 255: “Por outras palavras, enfiteuse é relação jurídica por via da qual o senhorio direto (o proprietário) autoriza outra pessoa (o enfiteuta) a usar, gozar e dispor da coisa, com certas restrições, inclusive pagamento de retribuição anual, chamada pensão”.

306

Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei 3.071, de 01.01.1916, e leis posteriores. § 1.º Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso: I – cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das construções ou plantações; II – constituir subenfiteuse. § 2.º A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial.

307

Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a remição dos aforamentos mediante aquisição do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos (...).

308

Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive os constituídos anteriormente a este Código, salvo acordo entre as partes, são resgatáveis dez anos depois de constituídos, mediante pagamento de um laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre o valor atual da propriedade plena, e de dez pensões anuais pelo foreiro, que não poderá no seu contrato renunciar ao direito de resgate, nem contrariar as disposições imperativas deste capítulo.

309

Orlando Gomes, *Direitos reais*, p. 311: “O direito de resgate é faculdade concedida ao foreiro que se inspira na política de liberação da propriedade, firmada contra a concepção medieval da enfiteuse. Quis-se facilitar ao titular do domínio útil a possibilidade de livrar-se do ônus real. A faculdade ampla de resgatar, outorgada ao foreiro, concorrerá para a extinção gradual do instituto. O direito de resgate é *direito potestativo*”.

310

Washington de Barros Monteiro, *Curso de direito civil*, vol. III, p. 263, elenca os requisitos para o resgate do aforamento: “Três, portanto, os requisitos para que o foreiro exerça o direito de resgate: *a)* decurso de dez anos após a constituição da enfiteuse; *b)* pagamento de um laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre o valor atual da propriedade plena; *c)* pagamento de dez pensões anuais pelo foreiro”.

311

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 144.

312

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 85. No mesmo sentido, citado pelo autor, Pontes de Miranda, *Comentários...* cit., p. 59: “O foro é o do lugar em que está situado o imóvel”.

313

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1.º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I – que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens (...).

314

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

315

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 146.

316

TJSP, Ap. civ. 0003538-94.2005.8.26.0072, 1ª Câmara de Direito Privado, rel. Rui Cascaldi, DJ 10.05.2013 “Ação de Consignação em Pagamento. Compra e venda de imóvel gravado com enfiteuse. Negativa do senhorio direto ao recebimento do laudêmio. Recusa legítima, diante da inobservância do direito de opção assegurado pelo art. 683 do CC/1916. Preliminar de carência de ação repelida. Sentença de procedência reformada. Recurso provido, com determinação”.

317

TJSP, Ap. civ. 9084753-19.2009.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Privado, rel. Percival Nogueira, *DJ* 09.09.2009: “Processual civil. Enfiteuse. Ilegitimidade ativa. Descaracterização. Adquirente do domínio útil que, na inércia do enfiteuta, pode cumprir a obrigação de pagar o laudêmio em seu lugar, perante o senhorio direto, com vistas à obtenção do registro da escritura pública. Falta de interesse de agir. Não configuração. Apelado que demonstrou, na qualidade de adquirente, a necessidade de obter a tutela jurisdicional almejada, para obter o registro da escritura, mediante o pagamento do laudêmio, pelo valor que entende devido e que se encontra controverso. (...)”.

318

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 84-85: “A pretensão fundamental contida na demanda é a de extinguir a enfiteuse, pelo resgate do foro, à qual se acumula o pedido de depósito em consignação da quantia correspondente às dez pensões anuais a que se refere o art. 693 do CC. (...) A ação, portanto, e a respectiva sentença de procedência, são preponderantemente constitutivas, com eficácia declaratória e mandamental, responsável esta pelo mandado que se expede para cancelamento do registro da enfiteuse”.

319

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 145: “O que ficou dito sobre a especificidade da ação consignatória para resgate do aforamento não afeta a classificação da sentença como declaratória. A eficácia constitutiva a que antes aludimos é, como nos demais casos, do depósito, substitutivo do pagamento, não da sentença, que se limita a declará-lo bom e suficiente. É o depósito, não a sentença, que opera a remição do emprazamento”. Na passagem imediatamente anterior, o autor se refere à caracterização da sentença como título para a remição do aforamento perante o Registro de Imóveis, nos termos do art. 250, I, da Lei de Registros Públicos.

320

Art. 250. Far-se-á o cancelamento: I – em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado (...).

77

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. XXIV, p. 88: “Se interesse há, o terceiro está legitimado, e a recusa do credor importa em mora”. Clóvis do Couto e Silva, *Op. cit.*, p. 26, afirmou expressamente a possibilidade de terceiros interessados pagarem a dívida e se utilizarem dos meios conducentes à liberação do devedor: “No Direito brasileiro, segundo o disposto no art. 930 do nosso CC, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor, embora não haja necessidade de que este integre a lide”.

152

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar da contestação.

258

Pontes de Miranda, *Comentários...* cit., p. 53: “A expressão ‘rescisão’, no art. 899, é erro de terminologia, que lamentamos estar no Código de 1973. Trata-se de resolução *lato senso*”. Também a Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...* cit., p. 51-52, a imprecisão terminológica não escapara, eis que o autor, ao comentar o art. 899 do CPC/1973, menciona a inviabilidade da complementação na hipótese de *resolução* por inadimplemento: “A complementação do depósito só ocorrerá nos casos em que o adimplemento (sic) não acarrete resolução do contrato. É sabido que, tendo havido inadimplemento, não poderá o credor enjeitar a prestação, se lhe for ainda útil. Todavia, em certos casos, o inadimplemento acarreta desde logo a resolução do contrato. Entre essas hipóteses estão aquelas em que há pacto comissório expresso, ou seja, uma convenção de extinção do efeito do negócio jurídico em razão do inadimplemento”.

304

Orlando Gomes, *Direitos reais*, p. 299: “Na *enfiteuse*, quem tem o domínio do imóvel aforado se chama *senhorio direto*; quem o possui imediatamente, *enfiteuta* ou *foreiro*. Costuma-se dizer que o senhorio é o titular do *domínio eminente* ou *direto* e o foreiro, do *domínio útil*, em alusão ao processo de fragmentação da propriedade realizado no Direito medieval”.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

CAPÍTULO II DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

1. Introdução

O Código de Processo Civil, na Parte Especial, Livro I (“Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença”), Título III (“Dos Procedimentos Especiais”), Capítulo II (“Da Ação de Exigir Contas”), arts. 550 a 553, disciplina a demanda de exigir contas. Trata-se de procedimento especial cuja etapa cognitiva é composta por duas fases. Na primeira, verifica-se o direito do autor a exigir contas, resolvendo-se questão preliminar mediante decisão interlocutória. Na segunda, julga-se a idoneidade das contas e se apura o saldo.

O autor nem sempre é credor. Não raras vezes, reconhecido seu direito a exigir contas, conclui-se pela existência de saldo em favor do demandado. A sentença que encerra a segunda fase constitui título executivo e permite a deflagração de processo de execução ou de medidas coercitivas ou executivas tendentes à satisfação do direito creditório (CPC/2015, art. 552) pelo autor ou pelo réu.

Há notáveis modificações em relação ao sistema anterior. Talvez a mais saliente seja a exclusão, como procedimento especial, da pretensão a prestar contas, esposada pelo administrador de bens. Contrariamente ao Código Buzaid, o administrador de interesses não mais dispõe de procedimento especial para a prestação de contas. Deverá fazê-lo seguindo o disposto no procedimento comum. Houve ampliação dos prazos para resposta, para impugnação das contas apresentadas pelo demandado, para a prestação de contas, pelo réu, depois da cominação na decisão interlocutória que encerra a primeira fase da etapa cognitiva do procedimento, bem como para a apresentação de contas, pelo autor, na hipótese de inércia do demandado condenado a prestá-las. Para todos esses atos processuais foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, valendo-se de cláusula aberta, define o código que as contas serão apresentadas na “forma adequada”. Trata-se de evidente flexibilização em relação ao que dispunha o CPC/1973, que previa a “forma mercantil”, levando a estéreis discussões sobre a validade de contadas apresentadas sem a adoção do método contábil de partidas dobradas.

Crê-se que as modificações fizeram do procedimento especial consagrado para a demanda de exigir contas mecanismo capaz de propiciar a tutela adequada dessa pretensão. O procedimento comum não seria capaz de permitir a tutela efetiva e adequada desse direito. Desse modo, a prestação de contas é eloquente demonstração de sua insuficiência. Principalmente por permitir a apuração e execução do saldo, o procedimento especial de exigir contas é técnica imprescindível para a tutela de relações jurídicas em que haja administração de interesses alheios.

Destaque-se que sob o enfoque da técnica processual, os termos “ação” e “demanda” não se confundem. O primeiro diz respeito ao direito subjetivo público e abstrato, atribuído aos cidadãos, de provocar a jurisdição para a defesa de direitos. Trata-se de direito fundamental consagrado no art. 5.º, XXXV, da Constituição. O autor, ao pleitear a tutela jurisdicional, exerce o direito de ação, deflagrando o processo. A seu turno, ao ato de expor, perante o Judiciário, a pretensão qualificada pela causa de pedir, dá-se o nome de demanda.¹ Conquanto seja nítida a distinção entre os termos “ação” e “demanda”, para evitar a repetição de palavras em uma mesma oração, pode ocorrer, ao longo desses comentários, o emprego dos termos como se sinônimos fossem. Atende-se, com isso, às exigências de estilo, sem que se pretenda erradicar a diferença conceitual entre os institutos.

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu

para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

1. Ação de exigir contas

O art. 550 traz grande mudança em relação ao procedimento especial de prestação de contas disciplinado no CPC/1973. O Código Buzaid, no art. 914, I e II, previa a ação de prestação de contas a quem tivesse o direito de exigí-las ou o dever de prestá-las. Assim, poderia propor a demanda tanto quem pretendesse prestar contas pela administração de interesses alheios, quanto quem pretendesse exigir contas daquele que lhe administra os interesses.² No código vigente, não há previsão de procedimento especial para a demanda do administrador de bens alheios interessado em prestar contas.

Sob o código revogado, afirmou-se, em atenção à duplicidade peculiar à prestação de contas, que o ordenamento não poderia omitir demanda específica para que as contas fossem prestadas.³ Com efeito, não se sabe, quando a demanda de dar contas é ajuizada, se haverá saldo favorável ao autor ou ao réu. É perfeitamente possível que o demandante, conquanto tenha o dever de prestar contas, seja credor do réu, que tem o direito de exigí-las. Isso ocorrerá sempre que os gastos do administrador superarem seus ganhos no exercício da atividade.

O código vigente excluiu o procedimento especial para a demanda proposta por quem pretende dar contas. Contudo, dessa exclusão não se pode concluir a inexistência da pretensão de prestar contas. Todo aquele que pretender prestá-las, poderá fazê-lo, ajuizando demanda que seguirá o procedimento comum.⁴ A solução não pode causar perplexidade. Sob o código revogado a doutrina se posicionava pacificamente no tocante à inexistência de duas fases na ação de dar contas.⁵ A questão preliminar, concernente à obrigação de prestá-las, era julgada na mesma *etapa* procedimental em que as contas eram apresentadas, algo diverso do que ocorre na demanda com a qual se pretende que outrem preste contas.

Assim, não há razão para que ocorra, quanto ao tema, polêmica semelhante à que grassou no início da vigência do CPC/1973, ocasião na qual se sustentou a supressão da demanda de imissão de posse, em decorrência da falta de previsão específica no código. A inexistência de procedimento especial não significa que o sujeito obrigado a prestar contas não possa fazê-lo. Só não disporá, para tanto, de procedimento específico. O código de processo civil sequer pode extirpar a obrigação de prestar contas, originária do direito material. Ademais, já se destacava, sob o código revogado, o caráter uno do procedimento da ação para dar contas, fator a comprovar a desnecessidade de previsão de procedimento especial.

2. Legitimidade e interesse processual

É parte legítima para propor a demanda de exigir contas todo aquele que tiver interesses administrados por outrem. A legitimidade passiva recai sobre quem administrar os interesses alheios.⁶ Correntistas detêm legitimidade para propor demandas de exigir contas contra bancos.⁷ O interesse processual, por sua vez, caracteriza-se pela necessidade de acesso à jurisdição para que as contas sejam prestadas, bem como na utilidade das contas para o autor.⁸ Sua nota definidora, na demanda em exame, é a resistência daquele que está obrigado a prestá-las.⁹ Isso significa que o autor deverá demonstrar que exigiu as contas extrajudicialmente, tendo o réu se recusado a prestá-las. É essa recusa que constitui o interesse processual.¹⁰

Contrariamente ao CPC/1973, que no art. 267, VI, fazia referência expressa à categoria “condições da ação”, o código vigente não a indica em qualquer dispositivo. Do mesmo modo, o CPC/2015 não faz menção à possibilidade jurídica do pedido. Com efeito, os arts. 17,¹¹ 330, II e III,¹² 337, XI,¹³ e 485, VI,¹⁴ restringem-se a indicar o interesse processual e a legitimidade. Diante da omissão do texto, é lícito concluir que a possibilidade jurídica deixou de ser considerada como categoria autônoma no direito positivo.

A supressão da categoria no código vigente, decorreu da dificuldade, há muito apontada na doutrina, em diferenciar o julgamento de mérito da impossibilidade jurídica.¹⁵ Na primeira edição destes comentários sustentei que a possibilidade fora absorvida pelo interesse processual. Atualmente, contudo, parece-me mais correto considerá-la como hipótese de improcedência, decorrente da proibição da pretensão pelo ordenamento jurídico. Se o pedido é proibido por lei, o autor não tem pretensão, daí decorrendo a improcedência.

A mesma dificuldade pode ser verificada em relação à legitimidade, categoria que, para parte da doutrina, também estaria relacionada ao mérito da demanda.¹⁶ Quando o juízo, após a instrução, afirma que o autor não pode cobrar do réu, considerado parte ilegítima, o que se afirma, na realidade, é que o demandante não tem pretensão contra o réu. Há, na hipótese, clara improcedência. Contudo, é possível que a inicial padeça de incoerência narrativa, de modo que o autor, embora proponha a demanda contra o réu, afirme que o credor seja terceiro. Em tais situações, após a oitiva do demandante para esclarecimentos, deve ser extinto o processo por ilegitimidade ativa.

No tocante à ilegitimidade passiva, saliente-se que o réu pode alegá-la na resposta, ocasião na qual o autor poderá realizar substituição no polo passivo ou nele incluir o terceiro indicado pelo réu, na forma do art. 339, §§1º e 2º, do CPC. Todavia, se a ilegitimidade passiva for decretada após a instrução, à luz das provas, haverá pronunciamento de mérito, no qual se reconhece que o autor não tem a pretensão de exigir contas contra o réu.

A fim de estabelecer a distinção entre mérito e legitimidade, assinale-se que a substituição processual (legitimidade extraordinária) é exemplo comum de questão estritamente processual, cuja ausência inviabiliza o julgamento do mérito. Corroborando, portanto, a autonomia das categorias interesse e legitimidade, compreendidos como pressupostos processuais, em relação ao *meritum causae*.

Com efeito, segundo o direito positivo, a legitimidade *ad causam* e o interesse processual não dizem respeito ao mérito. Sua inocorrência leva à extinção do processo mediante decisão terminativa (CPC/2015, art. 485, VI¹⁷), de modo que a pretensão poderá ser novamente submetida à apreciação do Judiciário, desde que corrigido o vício que levou ao encerramento do processo (CPC/2015, art. 486, § 1.º¹⁸).

O posicionamento aqui adotado não corresponde ao endosso irrestrito da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação estariam presentes sempre que fosse possível extraí-las da narrativa do autor.¹⁹ Reconhecer que frequentemente será proferida decisão terminativa em decorrência da inconsistência narrativa da inicial, não equivale a dizer que o interesse e a legitimidade serão aferidos somente à luz da peça inaugural. É possível que na inicial não conste qualquer inconsistência narrativa, mas se verifique que o autor postula direito alheio em nome próprio sem autorização legal para fazê-lo, situação que ensejará a extinção do processo sem

resolução de mérito.

No cotidiano forense, em grande parte dos casos em que são proferidas decisões terminativas, na realidade ocorre exame da relação jurídica material subjacente ao processo, o que significa que há, quando menos, julgamento parcial do mérito. Como já visto, a ideia de que houve extinção sem resolução de mérito é equivocada nas hipóteses em que se reconhece, após a instrução, que o devedor é terceiro, não o réu. Em situações que tais, o princípio da primazia do mérito (CPC, arts. 4º e 488) determina que o juiz se pronuncie desde logo sobre o objeto litigioso, o que demonstra como são raras as decisões verdadeiramente terminativas.

Contrariamente ao que afirmei na primeira edição desta obra, entendo hoje que a cobrança de crédito não vencido ou de dívida de jogo encerram hipóteses de julgamento de mérito. No primeiro caso, se a dívida ainda não venceu, é evidente que o autor não pode pleiteá-la em juízo, pois não tem ainda a pretensão. Se não tem pretensão, seu pedido deve ser julgado improcedente. Todavia, se no curso do processo houver inadimplemento da prestação cobrada, a demanda deve ser acolhida em razão da concretização dessa situação superveniente. Na segunda hipótese, a proibição de cobrança de dívida de jogo, na forma do art. 814 do Código Civil, implica a inexistência de pretensão, circunstância que também caracteriza a improcedência.

O art. 550, *caput*, utiliza a locução “aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas”. Não se pode extrair, dessa expressão, a ideia de que o código tenha adotado a teoria da asserção em sua forma pura, de modo que o interesse e a legitimidade só seriam verificados à luz da inicial. É certo que haverá prolação de decisões terminativas sempre que a inconsistência narrativa da inicial levar à descaracterização do interesse ou da legitimidade. Contudo, mesmo que a petição contenha exposição coerente, eventual pedido de revisão, cumulado à pretensão de exigir contas, deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme decidiu o STJ no REsp. 1.497.831/PR. Note-se que, no caso, o autor tem legítimo interesse em pleitear a revisão de cláusula contratual por ele considerada abusiva. Todavia, não poderá fazê-lo no âmbito da ação de exigir contas, em decorrência da impossibilidade de pleno exercício do contraditório na discussão do tema. A inviabilidade da discussão, portanto, assenta-se em questão processual, o que confirma a autonomia conceitual do interesse e da legitimidade.

Não é correto, portanto, extrair da leitura isolada do art. 550 a adesão do código à teoria da asserção em sua forma pura. Há hipóteses em que o exame da pretensão se inviabiliza em razão da falta de interesse ou de legitimidade, sendo essa ausência percebida após a instrução. Reitere-se, por fim, que o código não mais alude às “condições da ação”, o que autoriza a concepção de que o interesse e a legitimidade são pressupostos processuais, categoria que se não confunde com o *meritum causae*..

A doutrina costuma indicar, como hipóteses ensejadoras da demanda de exigir contas – portanto, nas quais há interesse e legitimidade – o contrato de mandato, a gestão de negócios, a parceria, a inventariança, a curatela e o depósito judicial.²⁰ Há, certamente, vários outros exemplos, pois a demanda de exigir contas poderá ser exercitada sempre que houver administração de interesses por terceiro. Emprega-se, aqui, o termo “interesses”, por considerá-lo abrangente de direitos e de bens titularizados por um sujeito, mas que sejam administrados por outro.

3. Petição inicial

O art. 550, § 1.º, determina que o autor especifique, detalhadamente, as razões que motivam o pedido de exigir contas, instruindo a petição inicial com os documentos comprobatórios dessa necessidade, sempre que existirem. A petição inicial se subordina aos requisitos elencados no art. 319 do CPC/2015, à exceção do contido no inc. VII,²¹ pois a audiência prevista no art. 334 do CPC/2015 não se aplica ao procedimento especial de exigir contas. Além dos genéricos, na petição inicial da ação de exigir contas há dois requisitos específicos: o autor deve requerer a prestação de

contas e deve detalhar as razões que o levam a fazê-lo.

O objetivo é evitar a propositura de demanda genérica, em que não sejam especificados os requisitos motivadores do ajuizamento. Como a sentença constitui título executivo e permite a execução do saldo apurado (CPC/2015, art. 552), proliferou-se o emprego da demanda de exigir contas sem qualquer cuidado, notadamente contra bancos, a fim de que o réu, incapaz de apresentar contas específicas, viesse a ser condenado e executado. O ajuizamento ocorria com inequívoca má-fé, o que levou o STJ a exigir que o autor indicasse motivos consistentes ao promover a demanda, na qual não poderiam ser discutidos encargos abusivos.²²

Pode-se afirmar que o código seguiu a linha adotada pelo STJ. Petições a que falte a indicação precisa dos motivos ensejadores da propositura da demanda, sejam ou não padronizadas, terão sua inépcia decretada, à luz do art. 330, I, e § 1.º, I.²³ Com efeito, falta-lhes a descrição da causa de pedir em que se fundamenta o pedido, o que leva ao indeferimento por inépcia. Antes de decretá-lo, contudo, impõe-se ao juiz intimar o autor para que emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, conforme assenta o art. 321, *caput* e par. ún., do CPC/2015.²⁴

Assim, sempre que a parte apresentar na inicial os motivos que justificam a pretensão de exigir contas, a petição será apta a produzir efeitos, deflagrando o processo. Se se tratar de demanda proposta contra instituição bancária, cabe ao autor impugnar os lançamentos que reputa inadequados, apresentando as razões pelas quais eles o são. Não se pode olvidar que segundo o STJ, Corte Suprema em matéria infraconstitucional federal, a ação de exigir contas não se presta à revisão de cláusulas contratuais, quer o pedido revisional ocorra na primeira fase, quer seja apresentado na segunda. A revisão deve ser pleiteada em demanda específica.²⁵ Cabe ao banco indicar os encargos cobrados, cuja legalidade não é objeto da ação de exigir contas. A demanda, nessa hipótese, será preparatória da revisional, cuja petição, tratando-se de contrato de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, deverá indicar o valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, § 2.º, do CPC/2015.²⁶

O art. 550, § 1.º, menciona ainda a necessidade de que à inicial sejam juntados, se existirem, os documentos comprobatórios da necessidade de que as contas sejam prestadas. Trata-se de outro ônus a incidir sobre o autor, que deverá acostar o contrato do qual se origina a obrigação de prestar contas. Caso não o faça, deverá indicar as razões pelas quais não pôde juntar os documentos que comprovam suas alegações.

Ainda no tocante à petição inicial, o art. 550, *caput*, menciona em termos equívocos que o autor requererá a citação do réu para que preste contas ou ofereça contestação. A redação pode levar à ideia incorreta de que haveria cumulação alternativa de pedidos. Evidentemente isso não ocorre. O autor pedirá a prestação de contas pelo réu. É o réu que pode, em vez de prestá-las, contestar.

Cabe ao demandante estimar o valor da causa, pois no momento do ajuizamento da demanda não é possível indicar o valor econômico envolvido, o que ocorrerá somente ao final da segunda etapa da fase de conhecimento. Esse posicionamento, adotado pela jurisprudência à luz do código revogado, deve ser mantido, pois os critérios elencados para a fixação do valor da causa, no art. 292 do CPC/2015, não são aplicáveis à ação de exigir contas, de modo que o valor da causa terá de ser estimado.²⁷

4. Cumulação de pedidos e litispendência

A etapa cognitiva da demanda de exigir contas, como já visto, divide-se em duas fases. Na primeira, decide-se sobre o direito do demandante de exigir contas. Na segunda, analisa-se a idoneidade das contas e se apura o saldo. Há, portanto, dois pedidos em cumulação sucessiva. Requer-se a procedência da pretensão à prestação de contas. Sucessivamente, pleiteia-se a apuração de contas e a apuração do saldo. Contudo, não é raro encontrar na praxe forense a realização de lacônicos pedidos de procedência da ação de prestação de contas. Todavia, considerada a disciplina do art. 550 do CPC/2015, ainda que o autor não apresente o pedido específico de julgamento das contas e de apuração do saldo, encerrada a primeira fase, deve o juiz

deflagrar a segunda. É dispensável o pedido de apuração do saldo, cuja realização é intrínseca à prestação de contas.

É de todo despropósito, na petição inicial, o pedido de cumprimento de sentença ou de adoção de medidas coercitivas ou sub-rogatórias. Sequer se sabe, quando ajuizada a demanda, se o autor será credor. Somente na segunda fase do procedimento será possível verificar a existência de crédito, de modo que a satisfação do direito creditório será objeto de petição específica, protocolada após a prolação da sentença que encerra a etapa cognitiva da ação de exigir contas.

A jurisprudência formada sob o Código Buzaid se consolidou no sentido da inadmissibilidade da cumulação dos pedidos de prestação de contas com revisão de cláusulas contratuais.²⁸ Esse posicionamento se pauta na diversidade de procedimentos. Não seria possível adotar o procedimento comum, pois a demanda de exigir contas com ele não se afiniza. A especialidade dessa ação reside precisamente na existência de etapa cognitiva dividida em duas fases. O procedimento comum é incapaz de abrigar essa especificidade procedimental, de modo que a demanda de exigir contas não pode ser cumulada com a revisão de cláusulas contratuais.

Afirmou-se que a pretensão do administrador em prestar contas não foi suprimida do ordenamento jurídico. O que não há é procedimento especial a referendá-la. Ocorre que o procedimento comum, incapaz de permitir a tutela jurisdicional adequada da pretensão de exigir contas, é hábil a prestá-la no tocante à pretensão de prestar contas. Sob o Código Buzaid, o procedimento da demanda de prestar contas – *ação ajuizada pelo administrador* – não se desdobrava em duas fases. A questão preliminar, consistente na obrigação de prestar, era julgada pelo mesmo provimento que apreciava as contas. Isso demonstra a aptidão do procedimento comum para o processamento da demanda de prestar contas, o que não ocorre em relação à ação para exigí-las.

Não se pode afirmar que a demanda de exigir contas é insuscetível de cumulação com qualquer outro pedido. Além da cumulação implícita dos pedidos de exigir contas e de apurar o saldo, pode haver cúmulo explícito com a pretensão de remoção de tutor ou curador.²⁹ Verificada a malversação de recursos na prestação de contas, pleiteia-se seja o tutor ou curador destituído, razão pela qual se trata de cumulação sucessiva, na qual o pedido prejudicado – destituição – será apreciado apenas se for acolhido o pedido prejudicial – direito a exigir contas e apuração do saldo. Também podem ser cumuladas, nessa hipótese, o sequestro dos bens administrados, assim como a glosa da remuneração do administrador, na forma do art. 553, par. ún., do CPC/2015.

Considerada a estreiteza dos limites cognitivos na demanda de exigir contas, cabe averiguar se é possível a formação de litispendência com outras ações condenatórias. Na primeira de suas acepções, o vocábulo é compreendido como a pendência de um processo. Contudo, na praxe forense o instituto é invocado como indicativo da impossibilidade de se ajuizar demanda em decorrência da pendência de outro processo.³⁰ Indaga-se se a propositura de ação de exigir contas inviabiliza o ajuizamento de ação de cobrança, p. ex., em razão da litispendência. A resposta é afirmativa. Considerada a constituição de título executivo em favor da parte credora, há litispendência entre a demanda de exigir contas e a ação de cobrança.³¹

Nos comentários ao art. 552 será mencionado que nem sempre a sentença proferida na demanda de prestar contas tem eficácia condenatória. É possível que o juiz, em atenção à atipicidade das técnicas de tutela executiva (CPC/2015, art. 139, IV), determine que a satisfação do crédito ocorra por meio de outra forma que não a condenação seguida por execução sub-rogatória. Nesse caso, não é proferida sentença condenatória, mas executiva ou mandamental. Dessa circunstância, contudo, não se pode extrair a inexistência de litispendência, pois o provimento jurisdicional também é dotado de eficácia declaratória em relação ao crédito, o que por si só inviabiliza a propositura de ação de cobrança que tenha como objeto crédito originário de lançamentos que digam respeito à prestação de contas.³²

5. Citação e prazo de quinze dias para resposta

O prazo para resposta é outra notável novidade em relação ao código anterior. O art. 915 do CPC/1973, concedia, desarrazoadamente, apenas cinco dias para que o réu oferecesse resposta. Considerando a necessidade de comprovar documentalmente os lançamentos (art. 917), era bastante comum, ante a exiguidade do prazo, que o réu contestasse apenas para obter mais tempo, o qual seria empregado para reunir os documentos e prestar as contas. Ciente disso, o legislador ampliou o prazo de resposta para 15 (quinze) dias. A solução merece aplausos, pois não havia qualquer justificativa para o prazo de cinco dias, o qual inviabilizava a apresentação dos lançamentos e da documentação a eles inerente.

Não há regra especial para a citação, que ocorrerá em conformidade com os preceitos gerais trazidos pelo código. Se o réu for pessoa jurídica pública ou privada, a citação pode se realizar eletronicamente, conforme prevê o art. 246, § 1.º,³³ desde que não se trate de microempresa, nem de sociedade empresária de pequeno porte. O réu também poderá ser citado pelo correio (CPC/2015, art. 246, I³⁴), desde que não verificadas as condições impeditivas elencadas no art. 247, I a V.³⁵ Frustrada a citação pelo correio, poderá ser realizado o ato citatório por oficial de justiça, na forma preconizada pelo art. 249, do CPC/2015.³⁶ Nas hipóteses em que aquele de quem se exige a prestação de contas não for conhecido, ou o lugar em que se encontrar for ignorado, incerto ou inacessível, impõe-se a realização da citação mediante edital (CPC, art. 246, IV, c/c art. 256, I e II³⁷).

A contagem de prazo ocorrerá em conformidade com o art. 219 do CPC, de modo que serão contabilizados somente os dias úteis.³⁸ Considerada a ampliação de prazo, de cinco para quinze dias, assim como o desconto dos dias não úteis, vê-se que o código vigente propicia ao réu tempo hábil a permitir a apresentação dos lançamentos atinentes ao período requerido pelo autor.

Nos termos do *caput* do art. 550, o réu é citado para prestar contas ou oferecer contestação, caracterizando-se incompatibilidade procedimental com a audiência conciliatória disciplinada no art. 334 do CPC. Sendo inviável a realização da audiência de conciliação, o que decorre da especialidade do procedimento de exigir contas, certamente o prazo para resposta não poderá ser contado na forma preconizada no art. 335, I, do CPC.³⁹

6. Revelia

Embora a leitura isolada do art. 550, *caput*, possa levar à conclusão de que o réu prestará contas ou responderá, o comportamento do demandado não se restringe a essa alternativa. Poderá permanecer revel, hipótese contemplada no art. 550, § 4.º, do CPC,⁴⁰ dispositivo que determina a realização de julgamento antecipado, na forma do art. 355.⁴¹ Contrariamente ao que a redação peremptória do dispositivo sugere, o tema merece análise mais cuidadosa.

A etapa cognitiva da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, compete ao juiz verificar a existência do direito de pedir contas. Na segunda, deverão ser prestadas as contas e apurado o saldo (CPC/2015, art. 552), prosseguindo o processo, mediante cumprimento de sentença, a fim de que ocorra a satisfação do direito creditório. A existência do direito de exigir contas é matéria preliminar em relação à prestação. É imprescindível, portanto, que antes de examinar as contas o juiz se pronuncie sobre o direito do autor de exigi-las. Assim, a despeito da revelia do réu, tal como ocorre em outras demandas,⁴² não haverá automaticamente julgamento antecipado na ação de exigir contas,⁴³ conforme assentou a jurisprudência do STJ firmada sob a égide do CPC/1973.⁴⁴

No código vigente, o art. 345, IV, assinala expressamente que a revelia não produzirá o efeito de presunção de veracidade das alegações do autor, quando elas forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas.⁴⁵ Desse modo, mesmo que o réu regularmente citado tenha permanecido silente, não se presumirão verdadeiras suas alegações quando elas não forem verossímeis ou afirmarem fatos em sentido divergente das provas, que, neste caso, terão sido produzidas pelo próprio autor.

Quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em descompasso com a prova produzida pelo próprio autor, é irrelevante que o revel tenha deixado de requerer provas em

consonância com o art. 349.⁴⁶ A falta de credibilidade das afirmações contidas na inicial permite ao juiz determinar a produção de provas, de modo que ele não estará obrigado a julgar antecipadamente o processo se não estiver convencido sobre as alegações do autor. Evidentemente, outro será o cenário se as alegações forem robustas, aplicar-se a presunção de veracidade e o réu deixar de requerer provas na forma do art. 349. Aplica-se, então, o art. 355, II, cabendo o julgamento antecipado da primeira fase do processo, mediante decisão interlocutória.

Já se admitia, sob o CPC/1973, sem que haja razão para modificar o entendimento, que o réu apresentasse reconvenção na ação de exigir contas.⁴⁷ O CPC/2015 é expresso ao estabelecer que o réu pode reconvir, sem contestar.⁴⁸ Nesse caso, desde que a reconvenção se contraponha aos fatos constitutivos invocados pelo autor, não pode se caracterizar a presunção de veracidade das alegações do autor, efeito da revelia elencado no art. 344 do CPC/2015. Seria contraditório que o código admitisse o oferecimento exclusivo de reconvenção, mas presumisse a veracidade das alegações do autor em decorrência da falta de contestação.⁴⁹

7. Contestação

O réu pode contestar a demanda, oferecendo resistência à pretensão de exigir contas esposada pelo autor. O código vigente se notabiliza pela intensa concentração das matérias de defesa na contestação, de modo que, antes de enfrentar o mérito, o réu pode alegar quaisquer das matérias indicadas no art. 337. Ser-lhe-á possível, portanto, invocar a ilegitimidade ativa do autor, sua ilegitimidade passiva, a falta de interesse processual (CPC/2015, art. 337, XI) e, no mérito, a inexistência de direito à prestação de contas. Ademais, pode o réu arguir impedimento ou suspeição do juiz, na forma prevista no art. 146 do CPC/2015.

No art. 550, *caput*, apresenta-se uma alternativa ao réu: apresentação das contas ou contestação. Sob o código revogado, que tinha no art. 915 dispositivo semelhante, a doutrina admitia a possibilidade de que o réu prestasse contas e, simultaneamente, contestasse a demanda. Isso ocorreria quando o autor divergisse das contas apresentadas extrajudicialmente pelo réu. Citado, o réu apresentaria as contas e invocaria a carência da demanda, por falta de interesse processual. Nessa hipótese, curiosamente, só seria possível a verificação da falta de interesse na segunda fase da demanda, na qual se apura o saldo e o juiz se pronuncia sobre as contas. Verificada a correção do que fora apresentado pelo réu extrajudicialmente, impor-se-ia condenar o autor, apesar da vitória na demanda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.⁵⁰

Considerando que a primeira fase da demanda tem como objetivo verificar o direito do autor de exigir contas, tem-se que a apresentação extrajudicial pelo réu extingue o interesse, tornando desnecessária a propositura da demanda. Bastará ao autor, caso considere as contas incorretas, impugná-las mediante demanda ajuizada pelo procedimento comum.⁵¹

Em outras palavras, se considerar incorretas as contas apresentadas extrajudicialmente, caberá ao titular do direito de exigir-las propor demanda de cobrança ou formular outra pretensão condenatória, a fim de obter os valores que entende devidos. Não será necessário ajuizar ação para verificar o direito a exigir contas. Logo, não há interesse processual na propositura da demanda de exigir contas se o réu as houver apresentado extrajudicialmente. Se, apesar da prestação extrajudicial, o autor deflagrar o procedimento especial, impõe-se extinguir o processo sem resolução de mérito, pois não há controvérsia sobre o direito de exigir contas, de modo que a primeira fase do procedimento é rigorosamente desnecessária, o que retira o interesse do autor. Não é correta a afirmação de que o réu contesta e presta contas. Nesse caso, limitar-se-á a contestar, informando que já as prestara extrajudicialmente, o que inviabiliza a instauração do procedimento especial.

8. Apresentação das contas

Regularmente citado, pode o réu apresentar as contas. Trata-se de reconhecimento da

procedência do pedido (CPC/2015, art. 487, III, *a*), a ensejar o encerramento da primeira fase da demanda. Não se pode olvidar que a etapa cognitiva da ação de exigir contas tem duas fases bem delimitadas. Na primeira, decide-se sobre o direito do autor de receber as contas. Na segunda, decide-se sobre as contas, apurando-se o saldo devedor. A sentença constituirá título executivo em favor do credor, autor ou réu (CPC/2015, art. 552).

É digna de nota a possibilidade de que o autor, titular do direito de exigir contas, seja devedor do réu, o que ocorre sempre que o administrador dos interesses alheios tenha despendido mais dinheiro na administração, do que aquele que recebera para realizar sua atividade. Em suma, é incorreto considerar o autor como credor. Ele pode, em não raros casos, ser devedor do demandado.

O art. 551, inovando em relação ao CPC/1973, dispõe que as contas devem ser apresentadas “na forma adequada”. O código revogado, no art. 917, mencionava expressamente a “forma mercantil”, também denominada contábil, por meio da qual os lançamentos são apresentados nas colunas de “deve” e “haver”, de uso corriqueiro no comércio.⁵² Também essa alteração merece aplauso, pois não raras vezes, a despeito da clareza com que eram apresentados os lançamentos, pleiteava-se a nulidade da prestação em decorrência da inobservância da forma mercantil.

“Forma adequada” é cláusula aberta. O código exige que as contas sejam prestadas de modo a tornar inequívocas as entradas e saídas, a fim de que o titular do direito de receber contas possa verificá-las com segurança.⁵³ Atente-se para a exigência, também contida no art. 551 do CPC/2015, de que sejam especificadas as receitas, a aplicação das despesas e, havendo, os investimentos. Esses são os elementos básicos da prestação de contas e deverão ser respeitados.

Não é necessário, embora possa ser útil, que as contas sejam contabilmente dispostas por profissional especializado, contador ou contabilista. A apresentação pelo próprio réu não caracteriza qualquer irregularidade. A propósito, ainda que o código se referisse à forma contábil, dessa locução não se poderia extrair a necessidade de que as contas fossem formuladas por profissional. Basta, para o código, que a prestação seja inteligível e que nela constem as receitas, as despesas e os investimentos. O dispositivo é inteiramente indiferente à pessoa que elaborará as contas. O que lhe interessa, repita-se, é a inteligibilidade⁵⁴.

Se o juiz reputar inadequada a forma com que o réu prestou as contas, cabe-lhe, antes de abrir prazo para a manifestação do autor, conceder prazo ao réu para que a forma seja corrigida, permitindo que a prestação alcance sua finalidade.⁵⁵ Se, instado a retificar a forma, quedar-se inerte o réu, viabiliza-se o julgamento antecipado da primeira fase da ação de exigir contas, sendo o demandado condenado a prestá-las de forma inteligível, sob pena de se considerar válidas as contas prestadas pelo autor, as quais não poderão ser impugnadas pelo réu desidioso (CPC/2015, art. 550, §§ 5.º e 6.º). Como se verá nos comentários ao art. 551, § 2.º, não é necessário que o demandado comprove os lançamentos documentalmente. Apenas se o autor impugnar caberá ao réu juntar aos autos os documentos comprobatórios.

9. Manifestação do autor

Prestadas as contas, concede-se ao autor o prazo de quinze dias para que se manifeste (CPC/2015, art. 550, § 2.º). A impugnação às contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, indicando expressamente o lançamento questionado (CPC/2015, art. 550, § 3.º). Estão proibidas e serão desconsideradas as impugnações genéricas, nas quais não seja apontado o lançamento que se pretende questionar. Ademais, não basta impugnar o lançamento. Impõe-se, ainda, fundamentar a impugnação. Em outras palavras, compete ao autor indicar as razões pelas quais reputa equivocado o lançamento. Ocorrendo impugnação específica e fundamentada, será concedido prazo ao réu para que apresente os documentos justificativos do lançamento (CPC/2015, art. 551, § 1.º).

Considerada a dificuldade prática que envolve a prestação de contas, o código dispensa o réu de acostar os documentos justificativos em sua primeira manifestação. Todavia, caso o autor impugne

específica e fundamentadamente algum lançamento, será imprescindível documentá-lo, ocasião na qual o juiz concederá prazo razoável para que o réu se desincumba desse ônus.

No art. 550, § 2.º, o código assinala que, prestadas as contas e concedido o prazo de quinze dias para que o autor sobre elas se manifeste, o processo seguirá na forma preconizada no Capítulo X (“Do Julgamento Conforme o Estado do Processo”), Título I (“Do Procedimento Comum”), do Livro I da Parte Especial (“Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença”). Isso significa que impugnadas as contas, cabe ao juiz determinar a produção de provas. A remissão é ao Capítulo X, dividido em quatro Seções (“Da Extinção do Processo”, “Do Julgamento Antecipado do Mérito”, “Do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito” e “Do Saneamento e da Organização do Processo”), mas é certo que o dispositivo se refere à de produção de provas. Em regra, será produzida somente a prova pericial, modalidade expressamente admitida no art. 550, § 6.º.

Crê-se que a remissão tenha sido ampla demais. É certo que a apresentação das contas pelo réu caracteriza reconhecimento jurídico do pedido, mas com isso se encerra apenas a primeira fase do processo, que deve seguir até o julgamento das contas e a apuração do saldo. Por esse motivo, não se vê como possam ser aplicados os dispositivos das Seções I e II do Capítulo X do Título I do Livro I da Parte Especial. Em outras palavras, são incabíveis a extinção do processo (Seção I) e o julgamento antecipado do mérito (Seção II). Há julgamento antecipado parcial do mérito (Seção III) porque a apresentação das contas encerra a primeira fase da demanda. Mas isso ocorre antes da intimação do autor para impugnar as contas do réu. São aplicáveis os institutos previstos na Seção IV (“Do Saneamento e da Organização do Processo”).

Embora seja admissível o saneamento compartilhado, com a indicação consensual das questões controvertidas (CPC/2015, art. 357, § 2.º⁵⁶), será mais usual a delimitação, pelo próprio juiz, das questões fáticas sobre as quais recairá a prova. Na realidade, considerada a finalidade da demanda de exigir contas, a prova terá como objeto os lançamentos especificamente impugnados pelo autor. Terá de ser designado perito que esteja habilitado a verificar a exatidão das contas e a apurar o saldo. Em síntese, apresentadas as contas pelo réu e realizada a impugnação específica e fundamentada pelo autor, caberá ao juiz determinar a produção de prova pericial para que seja verificada a exatidão das contas e apurado o saldo.

10. Decisão que reconhece o direito a exigir contas: natureza interlocutória

A ação de exigir contas é cominatória, pois a decisão que encerra a primeira fase do procedimento, ao reconhecer o direito do autor à prestação, condena o réu a exibi-las, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (CPC/2015, art. 550, § 5.º). A cominação é bastante nítida.

Caracteriza-se, nesse ponto, uma das mais importantes modificações em relação ao sistema anterior. Sob o CPC/1973, a ação de exigir contas também tinha duas fases, mas o encerramento da primeira ocorria mediante prolação de sentença, contra a qual cabia apelação.⁵⁷ No código vigente, outra é a natureza do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase e reconhece o direito a exigir contas. Não se trata de sentença, mas de decisão interlocutória.⁵⁸

Nos termos do art. 203, § 1.º, do CPC/2015,⁵⁹ sentença é o ato judicial “que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum”. O provimento que reconhece o direito a exigir contas, todavia, não encerra a fase cognitiva do processo, mas dá ensejo à deflagração da segunda etapa da fase de conhecimento da demanda, na qual as contas serão julgadas e o saldo apurado. Embora na dicção literal do dispositivo se faça referência ao encerramento da fase cognitiva do “procedimento comum”, o conceito pode ser aplicado sem qualquer inconveniente à ação de prestação de contas. O que importa, para caracterizar o ato judicial como sentença, é sua aptidão em encerrar a fase cognitiva do processo, algo que inócorre com a decisão que julga o direito a receber contas.

Poder-se-ia questionar essa posição, argumentando que ao final da primeira etapa da ação demarcatória é proferida sentença, havendo inclusive condenação em honorários. Ocorre que o

art. 581 alude expressamente à prolação de sentença, de modo que o provimento com o qual é finalizada a primeira fase da demarcatória admite a fixação de honorários.⁶⁰ Não há qualquer contradição com o disposto no art. 203, § 1.º, que ressalva “as disposições expressas dos procedimentos especiais”. A caracterização do ato judicial fundamentado no art. 581 como sentença é justamente uma das “disposições expressas”. Desse modo, a ação demarcatória não autoriza conclusão diferente daquela aqui adotada sobre a natureza do provimento que encerra a primeira fase.

Aduza-se que é irrelevante, para a classificação, que a decisão de reconhecimento ao direito de exigir contas diga respeito ao mérito da demanda, pois o código vigente prevê expressamente a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, mediante decisão interlocutória, contra a qual caberá agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 354, par. ún.,⁶¹ 356, I e II,⁶² e 1.015, II⁶³). Em outras palavras, o fato de decidir parcela do objeto litigioso não transforma o provimento em sentença, pois não é encerrada a etapa cognitiva do processo.

Por identidade de motivo, o provimento que recusa ao autor o direito de exigir contas deve ser classificado como sentença. Com efeito, a decretação de improcedência do pedido enseja a extinção da fase cognitiva, de modo que o ato judicial se amolda ao disposto no art. 203, § 1.º, do CPC/2015. Se não há direito a exigir contas, o réu não precisa prestá-las, de modo que a segunda etapa da fase cognitiva não será deflagrada. Contra essa sentença, que condenará o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cabe apelação (CPC/2015, art. 1.009⁶⁴).

Até que ocorra sedimentação do tema na jurisprudência e na doutrina, impõe-se a aplicação do princípio da fungibilidade, devendo ser aceito o recurso interposto, quer se trate de agravo, quer se trate de apelação. Note-se que sequer existe diferença de prazo a inviabilizar a fungibilidade recursal, pois tanto o agravo, quanto a apelação, devem ser interpostos em quinze dias contados da intimação da decisão recorrida (CPC/2015, art. 1.003, § 5.º⁶⁵). Acrescente-se que posições formalistas e restritivas não foram abrigadas pelo código, em cujo art. 8.º existe expressa menção à razoabilidade.⁶⁶ Certamente não é razoável, máxime diante do dissídio doutrinário e da ruptura com o sistema anterior, negar seguimento às apelações que porventura venham a ser interpostas contra as decisões de encerramento da primeira etapa⁶⁷.

11. Não cabimento de verbas sucumbenciais na decisão que reconhece o direito a exigir contas

Na decisão interlocutória que reconhece o direito a exigir contas não é cabível a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.⁶⁸ Há, quanto ao tema, mudança em relação ao posicionamento jurisprudencial adotado sob o código revogado.⁶⁹ Ocorre que o procedimento previsto no Código Buzaid concebia como sentença a decisão de encerramento da primeira fase da demanda. No regime atual, a etapa na qual se decide sobre o direito do autor de exigir contas é encerrada mediante decisão interlocutória, o que justifica a modificação de posicionamento.

A vitória do autor na primeira etapa do procedimento deve ser cotejada com o resultado da segunda fase, na qual serão julgadas as contas e apurado o saldo. Esse argumento pragmático já é suficiente para demonstrar a inadequação do arbitramento de honorários ao final da primeira fase. Acrescente-se que se trata de decisão, sendo que o art. 85, *caput*, assinala que a *sentença* condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.⁷⁰ O dispositivo claramente sinaliza que é inoportuna a fixação de verbas sucumbenciais em decisões proferidas ao longo do processo, mesmo aquelas que digam respeito ao mérito.

Ademais, não é pequena a possibilidade de que as contas eventualmente prestadas pelo demandado, em atendimento à cominação (CPC/2015, art. 550, § 5.º), venham a ser canceladas pelo juiz na sentença que encerra a segunda fase (CPC/2015, art. 552). Nesse contexto, impõe-se a fixação proporcional de honorários, pois seria injusto que o réu arcasse integralmente com a sucumbência apesar de sua derrota se limitar à primeira etapa da demanda. O critério, para tanto, deve ser a maior aproximação com as contas ao final consideradas idôneas pelo juízo.⁷¹

Por outro lado, é evidente que se a sentença acolher os cálculos do autor, a sucumbência do réu será total, pois terá sido derrotado não apenas na primeira fase, com o reconhecimento do direito do autor a exigir contas, mas também na segunda, com a aceitação das contas apresentadas pelo demandante. A dificuldade na determinação dos honorários somente ocorrerá quando o réu, vencido na primeira etapa, prestar contas que estejam mais próximas daquelas que ao final do processo sejam consideradas corretas pelo juiz. Não é necessária a apuração de saldo em favor do demandado. Basta que suas contas estejam mais próximas do resultado ao final alcançado com a demanda.

12. Condenação do réu a prestar contas em 15 (quinze) dias

Reconhecido o direito do autor a exigir contas, profere-se decisão dotada de eficácia condenatória (CPC/2015, art. 550, § 5.º). O provimento *condena* o réu a prestar contas em 15 (quinze) dias, cuja contagem atenderá ao disposto no art. 219 do CPC/2015, de modo que serão considerados somente os dias úteis. A premissa para a aplicação do dispositivo é o oferecimento de contestação pelo demandado ou sua revelia, hipóteses em que não tenha apresentado contas em conformidade com o art. 550, § 2.º. O termo inicial para a contagem do prazo é a intimação do demandado sobre o *trânsito em julgado* da decisão.⁷² Se não houver interposição de recurso, logo após a certificação do trânsito em julgado o juízo de primeiro grau intimará o réu, na pessoa de seu advogado, para que preste contas. Interposto recurso, em caso de desprovimento o demandado será intimado sobre a baixa dos autos, momento a partir do qual começa a ser contado o prazo para prestar contas.

Rompeu-se com o que dispunha o código revogado, cujo art. 915, § 2.º, concedia ao réu o exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar contas. Nada justificava a adoção de limite temporal tão restrito, de modo que a mudança merece elogios.

Destarte, tendo sido condenado a prestar contas, o réu terá até quinze dias da intimação do trânsito em julgado para fazê-lo, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor. Trata-se de cominação rigorosa aplicada ao demandado que não somente se recusou a prestar contas quando citado, mas se manteve recalcitrante mesmo depois da condenação.

Sob o código revogado, a doutrina assinalava que a proibição de impugnação das contas não implicava vedar a participação do réu na produção da prova pericial.⁷³ A inércia do réu condenado a prestar contas faz com que o autor seja intimado a apresentá-las. O juiz, contudo, não está obrigado a homologar automaticamente as contas indicadas pelo autor, sendo expressa, no art. 550, § 6.º, a possibilidade de realização de prova pericial. O réu pode participar da produção da prova. O que o código proíbe é a impugnação, formulada específica e fundamentadamente. Poderá, portanto, apresentar quesitos e nomear assistente técnico.

Conquanto se refira o art. 550, § 6.º, unicamente ao “exame pericial”, ao juiz é dado determinar a realização de outros meios de prova, de ofício ou a requerimento do autor. Não raras vezes, o demandante não dispõe da documentação imprescindível para a produção de prova pericial, de modo que o juiz pode ordenar a exibição de documentos, pois seus poderes instrutórios não são tolhidos na ação de exigir contas.⁷⁴ O usual, desde que o autor disponha dos documentos necessários, é que a prova pericial baste para a aferição da idoneidade das contas.

13. Apresentação de contas pelo réu e impugnação do autor

De acordo com o art. 550, § 6.º, se o réu, condenado a prestar contas na decisão interlocutória, deixar de fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, o autor será intimado a apresentá-las, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja possível apresentá-las, por não dispor dos documentos necessários, compete-lhe requerer a exibição de documentos ou outra medida adequada ao caso concreto. A inércia do autor enseja o arquivamento do processo.

As contas do autor, como se verá nos comentários ao art. 551, § 2.º, também devem ser apresentadas de forma adequada, incumbindo-lhe, além de especificar receitas, despesas e

investimentos, apontar o saldo que lhe cabe.

Se o réu condenado apresentar as contas, adota-se o disposto no art. 550, § 2.º, abrindo-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que impugne, fundamentada e especificamente, a prestação realizada pelo demandado. Nesse caso, o réu, embora não tenha apresentado contas após a citação, por ter somente contestado ou simplesmente se mantido revel, presta-as em acatamento à decisão condenatória, a qual reconhece o direito do autor de exigí-las e encerra a primeira fase do procedimento.

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º As contas do autor, para os fins do art. 550, §5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

1. Apresentação de contas na forma adequada

Como já mencionado, cabe ao réu apresentar contas de “forma adequada”, indicando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos eventualmente realizados. Não se exige, contrariamente ao que assinalava o código revogado, a exposição das contas em “forma mercantil”. Impõe-se, contudo, que elas sejam apresentadas de forma inteligível. Não é necessário que sejam elaboradas por contador ou contabilista. Basta que as contas demonstrem a evolução dos valores de forma compreensível para considera-las adequadas.

2. Impugnação do autor e juntada de documentos pelo réu

A impugnação do autor às contas apresentadas pelo réu deve ser específica. Isso significa que deve ser identificado o lançamento impugnado. Além disso, recai sobre o demandante o ônus de fundamentar sua objeção, apresentando as razões pelas quais o lançamento é incorreto ou indevido. Se não for identificado com precisão o lançamento ou se, quando identificado, inexistir fundamentação, a impugnação será considerada genérica, de modo a não se caracterizar a controvérsia.

A não caracterização de ponto controvertido acarreta severas consequências para o autor. Ao não se contrapor, específica e fundamentadamente às contas do réu, o demandante deixa de integrá-las aos pontos controvertidos que serão objeto de atividade probatória. Com efeito, nos termos do art. 374, III, do CPC/2016, os fatos incontroversos não dependem de prova, de modo que a falta de objeção específica inviabiliza o exame pericial sobre os lançamentos não impugnados.⁷⁵ Isso não exclui a possibilidade de que o valor de determinado apontamento, mesmo não impugnado, venha a ser atingido em decorrência de objeção lançada contra passagem anterior das contas. Demonstrada, por exemplo, a indevida incidência de juros ou de outro encargo, o saldo subsequente será atingido, ainda que não tenha sido objeto de refutação.

Apresentadas as contas e realizada impugnação específica e fundamentada pelo demandante, o juiz concederá “prazo razoável” para que o réu junte documentos comprobatórios dos lançamentos impugnados. A apresentação de contas, pelo réu, pode ocorrer tanto na resposta, após a citação (art. 550, *caput*), quanto em acatamento à sentença (art. 550, § 5.º). Em ambos os casos é aplicável o art. 551, § 1.º, de modo que ao demandado não se imputa o ônus de juntar documentos ao prestar contas. Cabe-lhe somente apresentá-las sob a “forma adequada”, dispondo-as de forma compreensível e indicando receitas, despesas e investimentos (art. 551, *caput*).

Apenas se houver impugnação específica e fundamentada pelo autor, recairá sobre o réu o

ônus de documentar os lançamentos no prazo razoável fixado pelo juiz. A exigência de documentação se restringe aos lançamentos impugnados. O código se vale de cláusula aberta. O caso concreto é que determinará a razoabilidade. Há de se ter máximo cuidado para evitar que a exiguidade de prazo venha a inviabilizar a apresentação de documentos. Não se perca de vista que amiúde o lançamento impugnado diz respeito a momento longínquo da relação entre as partes, de modo que a busca de documentos pode se mostrar árdua.

3. Contas do autor, forma adequada e obrigatoriedade de documentação simultânea

O art. 551, § 2.º, determina que as contas do autor devem ser apresentadas na forma adequada. Além da especificação das receitas, despesas e investimentos, deve o demandante indicar o saldo. O texto parte da premissa de que o autor age impelido pela busca de crédito, de modo que lhe cabe apontar o resultado das contas. Todavia, é cediço que nem sempre o resultado beneficiará o autor. Ele pode apenas ter direito a exigi-las, sem que ao final se configure saldo em seu favor. De qualquer forma, o dispositivo em análise determina que o demandante indique o saldo. Como consequência, dificilmente se verá a propositura de demanda de exigir contas quando o autor for devedor. Percebendo que o resultado da apuração não lhe é favorável, é quase certo que o legitimado ativo não ajuizará demanda, embora possa fazê-lo.

Além da forma adequada, as contas do autor devem ser prestadas conjuntamente com os documentos justificativos. Nota-se a diferença no tratamento da apresentação de contas do autor e do réu, já que este, ao prestá-las, não está obrigado a acostar os documentos comprobatórios. O tratamento diferenciado não fere a isonomia, pois o réu está impedido de impugnar as contas do autor (art. 550, § 5.º), o que comprova o equilíbrio do procedimento.⁷⁶ Se não tiver consigo os documentos, cabe ao réu requerer a exibição, na forma preconizada no art. 397 do CPC/2015.⁷⁷

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

1. Sentença e apuração do saldo

Já foi examinado que a etapa cognitiva da demanda de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, verifica-se o direito à obtenção das contas. Essa fase é encerrada por meio de *decisão interlocutória* que condena o réu a prestá-las sob pena de não poder impugnar as que o autor apresentar. Na segunda, desde que tenha sido reconhecido o direito a exigir contas, analisa-se a idoneidade das contas e se apura o saldo. Essa fase termina com a emissão de *sentença*, conforme resulta da expressa dicção do dispositivo, de modo que o recurso cabível é a apelação, que será recebida em duplo efeito (CPC/2015, art. 1.012, § 1.º, I a VI, *a contrario sensu*)⁷⁸.

É nítido o contraste: a primeira fase se encerra com a decisão interlocutória que reconhece o direito a exigir contas, ao passo que a segunda termina com a extinção da sentença que julga a idoneidade das contas e apura o saldo, que pode ser favorável ao autor ou ao réu. É necessário que a sentença a sentença apure o *quantum debeatur*.⁷⁹

2. Sentença e execução

O art. 552 assinala que a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo favorável ao credor. Isso não significa que o provimento jurisdicional tenha sempre eficácia condenatória, restringindo-se ao cumprimento de sentença disciplinado nos arts. 513, § 1.º, e 515, I, do CPC/2015. Fica superada, portanto, a ideia de que a sentença que extingue a fase cognitiva da demanda de exigir contas é sempre condenatória.⁸⁰

Com efeito, o art. 139, IV, do CPC/2015 permite que o juiz, no cumprimento de ordem judicial, adote técnicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, também nas demandas que tenham por objeto prestação pecuniária.⁸¹ Prevê-se, destarte, a atipicidade das técnicas executivas, não ficando o juiz circunscrito à execução por sub-rogação.⁸²

Só há condenação se ao provimento jurisdicional se seguir o cumprimento de sentença por execução (CPC/2015, arts. 520 e 523). Isso dependerá da vontade do credor ou da incapacidade de outras técnicas, que não a execução por sub-rogação, para a tutela do direito creditório. Adotando outras técnicas, em conformidade com o art. 139, IV, do CPC, o juiz não profere sentença condenatória, mas mandamental ou executiva.

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no *caput* for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.

1. Administrador e contas prestadas em apenso

O dispositivo determina que as contas do inventariante, tutor, curador, depositário e de qualquer outro administrador judicial devem ser prestadas em apenso ao processo no qual tiver ocorrido a nomeação.⁸³ Pretende-se evitar, com esse expediente, o tumulto processual que certamente ocorreria com a análise de contas em processos com objeto litigioso incompatível com o exame de contas.

Assinala-se na doutrina que o artigo termina dispondo sobre competência, à medida que a apreciação das contas dos administradores deve ocorrer perante o foro em que corre o processo ao qual a prestação de contas é apensada.⁸⁴ Se o processo tramitar em meio virtual, deve ocorrer o denominado “apensamento eletrônico”, medida corriqueira no cotidiano forense.

2. Condenação do administrador judicial ao pagamento do saldo e medidas executivas

Prevê-se, no art. 553, par. ún., que se houver condenação do administrador ao pagamento do saldo, pode o magistrado tomar medidas executivas. Apesar do uso do vocábulo “condenado”, não se pode ver no provimento eficácia condenatória. Tanto isso é verdade, que a parte final do art. 553, par. ún., autoriza o juiz a determinar medidas executivas “necessárias à recomposição do prejuízo”. Ora, se se tratasse de provimento condenatório, à sentença se seguiria necessariamente a execução por sub-rogação. Entretanto, não apenas o dispositivo se encerra com cláusula aberta – “medidas executivas necessárias à recomposição dom prejuízo” –, como ainda indica outras técnicas para a satisfação do crédito.

O sequestro de bens a que alude o dispositivo não é a medida cautelar prevista no art. 301 do CPC/2015. Trata-se de desapossamento.⁸⁵ A glosa, medida revestida de nítido caráter punitivo,⁸⁶ significa a suspensão do pagamento da remuneração do administrador decorrente de seu múnus.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. II, p. 102. Textualmente: “O ato de vir a juízo pedindo tutela jurisdicional, chamado demanda, tem por conteúdo uma pretensão de quem o realiza. Pretensão é a exigência de subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio”.

2

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários ao código de processo civil*, vol. XIII, p. 169: “Todo aquele que, de qualquer modo administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes a essa gestão”.

3

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários ao código de processo civil*, vol. VIII, t. III, p. 288: “De outro lado, como já foi posto em evidência, tanto pode ser o saldo das contas favorável ao que as presta, como àquele que as recebe; assim, se o devedor das contas é credor de pagamento, resulta manifesto seu interesse em prestá-las a fim de pôr-se em condições de cobrar o que lhe seja devido, ao passo que o interesse do ‘credor’ das contas que em verdade é devedor do saldo seria antes o de não tomá-las para furtar-se ao pagamento ou retardá-lo. Eis por que o sistema jurídico não pode deixar de contemplar também a ação de dar contas”.

4

Evaristo Aragão Santos, *Breves comentários ao novo código de processo civil*, p. 1.419/1.420: “No caso da ação de prestação de contas, percebeu-se não ser necessário procedimento especial destinado a servir também àquele que desejava *prestar* contas pela via judicial. Isso justamente porque poderia fazê-lo ou extrajudicialmente ou, no caso de alguma resistência da parte destinatária, pela via judicial, mas por meio do procedimento comum. Aliás, pela estrutura do CPC/1973, quando a demanda era iniciada pelo próprio obrigado à prestação das contas, o procedimento se desenvolvia em apenas uma fase e as contas, ao final, eram julgadas mediante pronunciamento de mérito do órgão judicial. Algo, portanto, substancialmente idêntico ao que se obteria por meio do procedimento comum”.

5

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, cit., p. 186/187, referindo-se à demanda para dar contas, denominada *espontânea*, diferenciava-a em relação à ação de exigir contas: “Enquanto esta tem o procedimento desdobrado em duas fases, com o mérito tratado por duas sentenças sucessivas, a ação de prestação de contas tem seu procedimento concentrado em uma única fase, de modo que, depois da sentença que a declarar procedente, nada mais restará senão a instauração da demanda executiva para a cobrança do saldo”. No mesmo sentido se posicionou Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, cit., p. 312, que destacou o caráter *uno* do procedimento da demanda para dar contas: “Sem embargo dessa inegável realidade, o procedimento da ação de oferecer contas é uno, sem comportar a divisão em fases ou estágios, e menos ainda os dois julgamentos separados característicos da ação de exigir contas”.

6

Antônio Carlos Marcato, *Procedimentos especiais*, p. 137: “Estão legitimados para a ação, ativa e passivamente, respectivamente, aquele que tem o direito de exigir a prestação de contas (titular do interesse, bem ou negócio) e o obrigado a prestá-las (administrador ou gestor)”.

7

STJ, Súmula 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária.

8

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições...*, cit., p. 302, em conhecida lição, define o interesse processual como necessidade e utilidade.

9

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 292. Na precisa definição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, *Curso avançado de processo civil*, vol. III, p. 262: “Afim, se o autor entra com ação de exigir contas quando o réu jamais se recusou a (ou até tentou) apresentá-las extrajudicialmente, ele, demandante, não tinha necessidade de tutela jurisdicional. Em consequência, não tinha interesse processual – e merece responder pelas verbas de sucumbência”.

10

A jurisprudência, firmada já sob o CPC/1973, estabeleceu o interesse do correntista em exigir contas mesmo quando apresentados regularmente os extratos bancários. A premissa, nesse caso, é a dúvida sobre a correção dos lançamentos. STJ, Ag. Rg. no AREsp. 92.488/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 28.06.2013: “Processo Civil. Agravo regimental. Recurso especial. Ação de Prestação de Contas. Cartão de Crédito. Interesse de Agir. Impossibilidade de cumulação de Pedidos da Inicial. Súmula 7/STJ. 1. Independentemente do fornecimento de extratos bancários, se o cliente tem dúvida acerca da correção de valores depositados em instituição financeira, há interesse processual na ação de prestação de contas. (...)”.

11

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

12

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) II – a parte for manifestamente ilegítima; III – o autor carecer de interesse processual.

13

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) XI – ausência de legitimidade ou de interesse processual.

14

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

15

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições...*, cit., p. 301, à luz do CPC/1973, enquadrava autonomamente a

possibilidade jurídica, conceituando-a como a admissibilidade em tese do pedido: “A demanda é juridicamente impossível quando de algum modo colide com regras superiores do direito nacional e, por isso, sequer comporta apreciação mediante exame de seus elementos concretos. Já *a priori* ela se mostra inadmissível e o autor carece de ação por impossibilidade jurídica da demanda. A *possibilidade* jurídica é a admissibilidade desta *em tese* e, sem ela, sequer se indagará se o demandante é parte legítima, se o provimento que pede é adequado, se é apto a lhe trazer proveito ou se ele tem razão ou não, pelo mérito (se venho a cobrar um crédito decorrente de jogo, de nada importa saber se ganhei honestamente, se realmente ganhei ou quanto ganhei – CC, art. 814)”. Calmon de Passos, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. III, p. 259/260, Fredie Didier Jr., *Pressupostos processuais e condições da Ação*, p. 226 e Fábio Gomes, *Carência da Ação*, p. 66, sustentaram, sob o CPC/1973, que a possibilidade jurídica seria hipótese de improcedência da demanda. Também o fez José Roberto dos Santos Bedaque, *Efetividade do processo e técnica processual*, p. 280: “Em outras palavras, *demanda juridicamente impossível* significa ser irrelevante eventual controvérsia fática, pois a improcedência pode ser afirmada desde logo, por manifesta colidência com a ordem jurídica. Esse resultado representa verdadeiro julgamento de mérito, na medida em que resolve a lide e elimina definitivamente a crise de direito material”. À luz do código vigente, Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Teoria geral do novo processo civil*, p. 116, apontam que o CPC/2015 aceitou as críticas endereçadas à possibilidade jurídica: “Mas a *possibilidade jurídica do pedido* sempre foi alvo de inúmeras críticas, dada a dificuldade de ser traçada uma distinção precisa entre a decisão que extingue o processo por impossibilidade jurídica do pedido e a decisão de mérito que julga a demanda improcedente. Essas críticas foram acolhidas pelo Novo Código de Processo Civil, que não faz mais referência à possibilidade jurídica, referindo apenas o *interesse de agir* e a *legitimidade ad causam* (arts. 17, 330, II e III, 337, IX, e 485, VI)”.

16

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, cit., p. 289, nota de rodapé 11.

17

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

18

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1.º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incs. I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. (...).

19

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições...* cit., vol. II, p. 317: “Segundo seus seguidores, as condições da ação deveriam ser aferidas *in statu assertionis*, ou seja, a partir do modo como a demanda é construída – de modo que se estaria diante de questões de mérito sempre que, por estarem as condições corretamente expostas na petição inicial, só depois se verificasse a falta de sua completa implementação”. É bastante conhecida a posição do autor contrária à teoria da asserção, nítida no título do item do qual foi retirada a passagem citada: “condições existentes e não apenas afirmadas (repúdio à teoria da asserção)”.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 175, de onde foram extraídos todos os exemplos citados.

Art. 319. A petição inicial indicará: (...) VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Evaristo Aragão Santos, *Breves...*, Op. cit., p. 1.423, com expressa referência ao precedente do STJ, REsp. 1.231.027/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJe* 18.12.2012, assim ementado: “Processual Civil. Recurso Especial. Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente. Cabimento da Ação de Prestação de Contas (Súmula n. 259). Interesse de Agir. Revisão de Cláusulas Contratuais. Comissão de Permanência, Juros, Multa, Capitalização, Tarifas. Impossibilidade. 1. O titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc.) ao longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em débito. 2. A entrega de extratos periódicos aos correntistas não implica, por si só, falta de interesse de agir para o ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem não ser suficientes para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na conta-corrente. 3. Hipótese em que a padronizada inicial, a qual poderia servir para qualquer contrato de conta-corrente do Banco Banestado, bastando a mudança do nome das partes e do número da conta, não indica exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de origem desconhecida e sequer delimita o período em relação ao qual há necessidade de prestação de contas, postulando sejam prestadas contas, em formato mercantil, no prazo legal de cinco dias, de todos os lançamentos desde a abertura da conta-corrente, treze anos antes do ajuizamento da ação. Tal pedido, conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela unanimidade da 4ª Turma no REsp. 98.626-SC, ‘soa absurdo, posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados’. 4. A pretensão deduzida na inicial, voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos encargos cobrados (comissão de permanência, juros, multa, tarifas), deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida cautelar preparatória. 5. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6. Recurso especial a que se nega provimento”.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; (...) § 1.º Considera-se inepta a petição

inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; (...).

24

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

25

Na primeira edição destes comentários não havia sido concluído o julgamento do REsp. n. 1.497.831/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual o STJ decidiu pela impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais no âmbito da ação de exigir contas.. Com a apreciação desse recurso foi firmada a seguinte tese: “Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas”. Transcreve-se a ementa: “Processual Civil. Recurso Especial Repetitivo. Ação de Prestação de Contas. Segunda Fase. Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente. Juros Remuneratórios e Capitalização dos Juros. Impossibilidade de Revisão dos Encargos Contratuais, que Devem Ser Mantidos nos Termos em que Praticados no Contrato Bancário sem Prejuízo da Possibilidade de Ajuizamento de Ação Revisional (STJ, REsp. 1.497.831/PR, 2ª Seção, Rel. p/. Ac. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJe* 07/11/2016)”. O precedente vem sendo acatado no duplo grau de jurisdição, como se vê no TJPR, Ap. Cív. 0000244-25.2007.8.16.0110, 16ª Câmara Cível, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 07.02.2018: “Na segunda fase da prestação de contas, analisa-se apenas se as contas foram apresentadas de forma adequada, especificando as receitas, as despesas e os investimentos, se houver (CPC, art. 551). Não se pode cogitar de revisão de cláusulas contratuais”. No mesmo sentido: TJPR, Ap. Cív. 1.283.232-3, 16ª Câmara Cível, Rel. Fabiane Pieruccini, j. 09.05.2018: “(...) O Colendo STJ consolidou, no julgamento do REsp nº 1.497.831/PR, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos, entendimento no sentido da “Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas”. 2. Havendo reforma da sentença, necessária a adequação do ônus sucumbencial”.

26

Art. 330, § 2.º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

27

TJPR, Ag. Inst. n. 1.147.716-6, 13ª Câmara Cível, Rel. Cláudio de Andrade, j. 14.05.2.014: “Agravo de instrumento. Prestação de contas. Primeira fase. Valor da causa. Fixação por mera estimativa do benefício visado, ante a impossibilidade de apurar, nesta fase, o valor econômico da demanda. Despacho modificado. Recurso provido”. No mesmo sentido, TJSP, Ag. Inst. 2272197-13.2015.8.26.0000, 25ª Câmara de Direito Privado, Rel. Hugo Crepaldi, *DJ* 02.03.2016: “Agravo de Instrumento. Ação de Prestação de Contas. Primeira Fase. Decisão que acolhe impugnação ao valor da causa. Descabimento. Não havendo pretensão econômica imediata na ação de prestação de contas, cabível a fixação de valor da causa com base em

mera estimativa da parte autora. Alegações apresentadas em impugnação que não alteram o entendimento manifestado por ocasião de julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte autora, contra a decisão que de ofício determinou a retificação do valor da causa. Recurso provido”.

28

STJ, Ag. Rg. no AREsp. 531.003/PR, 3ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 12.12.2014: “(...) 3. São inviáveis, em ação de prestação de contas, a revisão e o afastamento de cláusulas contratuais, procedimentos próprios da ação revisional. (...)”. No mesmo sentido: STJ, Ag. Rg. no REsp. 739.700/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, *DJ* 22.10.2007, p. 285: “Agravo Regimental. Recurso especial. Cumulação de Pedidos. Revisão Contratual. Prestação de Contas. Ritos. Incompatibilidade. 1. Consoante entendimento desta Corte, é inviável a cumulação de ação de revisão de cláusulas contratuais com ação de prestação de contas, em face da diversidade dos ritos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.

29

Edson Cosac Bortolai, *Da ação de prestação de contas*, p. 89: “Outra hipótese de cumulação seria o pedido, em prestação de contas, de remoção e dispensa de tutor ou curador (CPC, art. 1.194)”. No código vigente a remoção de tutor ou curador está prevista no art. 761. A outra hipótese a que alude o autor é a de cumulação alternativa entre a prestação de contas e a instituição de juízo arbitral. Com a vigência da Lei 9.307/1996, o exemplo perdeu validade.

30

Cândido Rangel Dinamarco, *Ação de prestação de contas, ação condenatória e litispendência*, p. 1551: “Em si mesma, e conceitualmente, litispendência nada mais é que a mera *pendência de um processo (litis – pendentia)*. É o estado de um processo vivo, ou seja, que já existe e ainda existe, porque já foi formado e ainda não foi extinto – o expressivo binômio *já e ainda* é usualmente empregado pela doutrina alemã na explicação do conceito de litispendência (*schon und noch*). Sinteticamente, diz Moniz de Aragão que a litispendência é ‘a fluência da causa em juízo’. Mas, segundo antiga usança, o vocábulo *litispendência* é mais frequentemente empregado para indicar o *impedimento* para a realização de um processo e consecução de seus resultados em razão de um estado anterior de litispendência – pendência de outro processo. A tal é a *exceção de litispendência*, da linguagem dos antigos, ‘consistente em uma defesa processual tipificada em lei e voltada à extinção do processo em razão de estar pendente um primeiro, pela mesma demanda”.

31

Nesse sentido é a lição de Cândido Rangel Dinamarco, *Ação de prestação de contas, ação condenatória e litispendência*, p. 1555-1556.

32

Pontes de Miranda, *Tratado das ações*, t. I, Parte II, Cap. II, p. 131 e ss., esclarece que todas as sentenças apresentam um feixe eficaz composto pelas cinco cargas de eficácia. No caso em análise, a declaração de existência do crédito é uma das eficácias que compõem a sentença proferida na ação de prestação de

contas. Sua intensidade é forte o suficiente para caracterizar a litispendência e evitar a propositura de demanda condenatória cujo objeto seja crédito originário das contas que compõem o pedido da demanda de prestação. Cândido Rangel Dinamarco, *Ação de prestação...* cit., p. 1554, parece referendar essa conclusão: “Toda sentença de mérito contém uma declaração. Declaração da existência, da inexistência, modo-de-ser ou objeto de uma relação jurídica ou de direitos, obrigações ou deveres. E a declaração que a sentença condenatória contém (ao lado do efeito de constituir título para a execução forçada) é rigorosamente idêntica à contida em eventual sentença meramente declaratória versando a mesma matéria, ou seja, a mesma relação litigiosa”.

33

Art. 246, § 1.º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

34

Art. 246. A citação será feita: I – pelo correio; II – por oficial de justiça; III – pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV – por edital; V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1.º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2.º O disposto no § 1.º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. (...).

35

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: I – nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3.º; II – quando o citando for incapaz; III – quando o citando for pessoa de direito público; IV – quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V – quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

36

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

37

Art. 256. A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...).

38

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

39

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; (...).

40

Art. 550, § 4.º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

41

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

42

José Carlos Barbosa Moreira, *O novo processo civil*, p. 98: “A despeito do teor literal do art. 319, não fica o juiz vinculado, ao nosso ver, à aceitação de fatos inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra a revelia; ademais, o pedido poderá ser declarado improcedente, v.g., em consequência da solução da *questão de direito* em sentido desfavorável ao autor”.

43

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 300.

44

STJ, REsp. 1.471.838/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJe* 26.06.2015: “(...) 8. A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos. (...)”.

45

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

46

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

47

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 302.

Art. 343, § 6.º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

Ricardo Alexandre da Silva, *Breves comentários ao novo código de processo civil*, p. 958.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 180, demonstra que o réu pode apresentar contas, mas ainda assim contestar, alegando que as prestara judicialmente, sendo elas recusadas pelo autor, que discordou do valor. Além desse caso, segundo o processualista, a apresentação simultânea das contas e da contestação ocorreria quando o réu sustentasse que realizou a prestação, mas o autor não fora buscar as contas, como lhe incumbia na forma pactuada entre as partes ou, ainda, quando o réu afirmasse que procurara o autor para lhe apresentar as contas, tendo este redarguido a inexistência de direito a exigi-las. Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 299, analisa a hipótese, restringindo-a, contudo, à discussão quanto ao saldo das contas, não em relação ao direito de prestá-las. Ambos os autores preconizam que o autor teria de arcar com as custas quando verificada a correção das contas apresentadas extrajudicialmente pelo réu.

Devo essa solução a Anissara Toscan, que criticou precisa e convincentemente o texto original, no qual era endossada, sem maior aprofundamento, a posição defendida por Ovídio Baptista e Adroaldo Furtado Fabrício.

Pontes de Miranda, *Comentários ao código de processo civil*, t. XIII, p. 135: “Forma mercantil: parcelas ou colunas de entradas e saídas, deve e haver, como demonstração gráfica, série de estados dos negócios da administração ou outra relação jurídica, com as somas finais e o saldo. Se as parcelas vencem juros, contam-se a cada saldo parcial, ou como for de uso, ou se somam em colunas diferentes, para que se tire o saldo deles, e se subtraia ou se junte ao saldo final. A falta de forma mercantil causa nulidade não cominada”.

Evaristo Aragão Santos, *Breves...* Op. cit., p. 1.432: “Não há mais, propriamente, forma específica. A prestação de contas precisa, sim, apresentar-se *adequada* aos fins a que se destina. É o que basta. A depender da relação jurídica subjacente ao debate, a organização das informações pode (e deve!) receber adaptações para melhor compreensão por parte de seus destinatários, ainda que se distancie do desenho usualmente adotado nos registros do comércio”.

Nesse sentido, TJPR, Ag. Inst. n. 1.147.716-6, decisão monocrática, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 24.11.2017. Identicamente, do mesmo relator, Ag. Inst. n. 1.735.154-7, j. 08/11/2017 e Ag. Inst. 1.719.605-9, j. 03/10/2017.

55

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero. *Novo código de processo civil comentado*, p. 597: “Se as contas não forem prestadas na forma adequada, tem o juiz de assinalar prazo razoável para que o demandante se manifeste a respeito das contas ofertadas ou determinar a correção na forma de apresentação das contas, para que esta seja adequada à forma exigida em lei”. A despeito da autorizada opinião dos juristas, crê-se que a forma inidônea das contas, uma vez constatada pelo juiz, inviabiliza a intimação do autor para que se manifeste. Será improfícuo determinar que se pronuncie sobre contas prestadas de forma incompreensível. Mais adequado é intimar o réu para que retifique a forma com que apresentou as contas, abrindo prazo para a impugnação, pelo autor, apenas depois da correção. Sublinhe-se que a intimação do réu é cabível somente em hipóteses extremas, nas quais a forma inadequada impeça a compreensão das contas. Considerado o excesso de trabalho a afligir os juízes, será usual que a forma não seja fiscalizada, seguindo-se, após a apresentação das contas, a intimação do autor para impugná-las. Conquanto isso normalmente aconteça, não é necessário que seja assim.

56

Art. 357, § 2.º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

57

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 304/305, destacou o caráter de sentença do provimento proferido com fundamento no art. 915, § 2.º do código revogado, contra o qual caberia apelação no duplo efeito, como demonstra passagem extraída da página 305: “Como quer que seja, de sentença se trata, como aliás está explícito no parágrafo, e o recurso cabível é, pois, o de apelação. E, como não há ressalva legal em contrário, os efeitos do recurso incluem o suspensivo”.

58

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 597: “Decisão da Primeira Fase. Tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo ou a uma de suas fases (art. 203, § 2.º, CPC). Por isso, comporta recurso por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC)”. No mesmo sentido, Evaristo Aragão Santos, *Breves...* Op. cit., p. 1.428/1.429, assinala precisamente que a decisão de encerramento da primeira fase só será sentença quando reconhecer a inexistência do dever de prestar contas: “No procedimento especial de exigir contas, o pronunciamento judicial que resolve a primeira fase só encerra a cognição quando, ali, extingue o processo (reconhecendo, por exemplo, a ausência do dever de prestar as contas ou a impossibilidade de prestá-las por meio daquele processo). Aí será sentença, impugnável, portanto, por meio de apelação. *Já quando reconhece o dever de o réu prestar contas, claramente esse pronunciamento não encerra a atividade cognitiva do órgão judicial.* Pelo contrário, conduz o procedimento para a fase na qual a cognição judicial é mais intensa: a discussão e julgamento das contas!”. Em sentido contrário, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros comentários ao*

novo Código de Processo Civil, p. 909: “Da sentença condenatória à prestação de contas caberá recurso de apelação a ser recebido no duplo efeito. Verificado o trânsito em julgado da sentença condenatória à prestação de contas, caberá a deflagração da fase de cumprimento de sentença, quando então o réu será intimado a prestar contas em 15 dias”.

59

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1.º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...).

60

Art. 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.

61

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

62

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I – mostrar-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. (...).

63

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; (...).

64

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

65

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5.º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 8.º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Adotando corretamente a fungibilidade recursal, ver TJPR, Ap. Cív. N. 1.622.506-4, Rel. Octavio Campos Fischer, j. 31.05.2017: “Apelação Cível. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Sentença de Procedência. Insurgência Recursal da Parte Requerida. 1. Decisão interlocutória de mérito que não extingue o processo, mas somente a primeira fase do procedimento, portanto, agravável, à luz do art. 1.015, inciso II, do novo Código de Processo Civil. Exegese dos art. 550, §5º, e 552, ambos do NCPC. Controvérsia acerca da natureza da decisão e do recurso cabível dentro da nova norma processual. Jurisprudência deste Tribunal que até o momento, conhece tanto do recurso de apelação quanto do agravo de instrumento, considerando os princípios da instrumentalidade das formas da efetividade e economia processual. Recebido o recurso de apelação. (...)”. Note-se o duplo acerto do julgado, pois reconhece o caráter interlocutório da decisão que encerra a primeira fase, a desafiar o recurso de agravo de instrumento, aplicando, correta e elogiavelmente, a fungibilidade recursal, de modo a admitir a apelação cível.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 598, manifestam-se em sentido contrário: “Na ação de prestação de contas tem o vencido de ser condenado nas despesas processuais – custas e honorários advocatícios. As despesas processuais são devidas a cada fase processual (art. 82, § 2.º, CPC). O fato de o procedimento apresentar estrutura diferenciada não interfere de modo nenhum no problema”. Crê-se, contudo, que a autorizada manifestação dos juristas não se aplique ao código vigente, embora fosse aplicável ao CPC/1973, em que a caracterização, como sentença, do provimento que encerrava a primeira etapa do processo não era objeto de dúvida.

STJ, RESP 258.964/PR, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 11.06.2001: “Ação de prestação de contas, primeira fase. Honorários de advogado. Precedente da Corte. 1. Vencida a parte ré, que apresentou vigorosa resistência, cabível a fixação de honorários de advogado na primeira fase da ação de prestação de contas. 2. Recurso especial conhecido e provido”. No mesmo sentido: TJRS, Ap. Cív. 70067988154, 20ª Câmara Cível, rel. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 09.03.2016: “Apelação Cível. Direito Privado Não Especificado. Ação de Prestação de Contas. Primeira Fase. Fixação de Honorários Advocatícios. Possibilidade. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça estão de acordo com a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais quando do julgamento de procedência da ação de prestação de contas, em sua primeira fase. Deram provimento ao apelo. Unânime”.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 310: “Pode suceder que o réu, vencido na primeira etapa (entenda-se, condenado a prestar contas a que, segundo sua contestação, não estava obrigado), venha a ser vitorioso na segunda, vale dizer, as contas por ele apresentadas com saldo a seu favor obtiveram a aprovação judicial, vencida a impugnação do autor. Em tal hipótese, só a distribuição proporcional das custas e honorários é solução justa, embora se deva reconhecer, por outro lado, a dificuldade de estabelecer-se um critério preciso de proporcionalidade. (...) Colocada nestes termos a controvérsia em juízo, a sucumbência se há de estabelecer e medir pela identidade, ou maior proximidade, entre as contas ao fim aprovadas e aquelas que a parte pretendia dar ou receber”.

Evaristo Aragão Santos, *Breves...* Op. cit., p. 1.430: “Quanto ao prazo, no regime anterior já se entendeu que as 48 (quarenta e oito) horas fluiriam do trânsito em julgado, devendo também a parte ser intimada pessoalmente (e não por meio de seu procurador a fazê-lo). Mais recentemente o STJ alterou essa orientação, considerando dispensável a intimação pessoal (REsp. 961439/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJ* 27.04.1999). O CPC/2015 segue essa linha. Como regra, o réu será intimado na pessoa de seu advogado, na forma do art. 513, § 2.º, I. O prazo fluirá a partir dessa intimação, caso os efeitos da decisão de primeira fase não sejam suspensos pela concessão de liminar em agravo de instrumento”. Discorda-se da última frase do posicionamento transcrito. O prazo é contado a partir da intimação da parte sobre o trânsito em julgado. Não se conta a partir da prolação da decisão, mas do trânsito em julgado. Logo, interposto agravo de instrumento, penderá recurso contra a decisão. Seja ou não deferido efeito suspensivo, o prazo para a prestação das contas não se inicia. Julgado o recurso e transitada em julgado a decisão, com o retorno dos autos à primeira instância e a intimação do demandado por meio de seu advogado, inicia-se o prazo de 15 dias para a prestação de contas. A jurisprudência firmada sob o código revogado se cristalizara nesse sentido, como se vê no TJRS, Ap. Cív. 70065103152, 15ª Câmara Cível, Rel. Ana Beatriz Iser, *DJ* 06.08.2015: “Apelação Cível. Mandato. Ação de Prestação de Contas. Segunda Fase. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso Rejeitada. Ausência de Intimação para Prestar as Contas em 48 Horas. Necessidade. Cerceamento de Defesa. Desconstituição da Sentença. I. Após o trânsito em julgado da sentença de primeira fase, passa-se à segunda fase, na qual o réu será intimado a prestá-las no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. II. Caso em que o demandado não apresentou as contas, pois ausente correta intimação para prestá-las no prazo de 48h, tendo o autor apresentado as suas contas, fora do prazo legal. Cerceamento de defesa configurado. Desconstituição da sentença. Precedentes desta Corte. Preliminar Rejeitada. Apelação Provida. Sentença Desconstituída”. No mesmo sentido, STJ, Ag. Rg. no REsp. 1.354.333/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJe* 03.08.2015: “Agravo Regimental no Recurso Especial. Prestação de Contas. Termo Inicial. Trânsito em Julgado. Definição. Comando para Prosseguir o Feito Mantido. 1. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação das contas pelo réu, previsto no art. 915, § 2.º, do CPC, deve ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir prestação de contas. 2. Solucionada a controvérsia do início do prazo, o feito deve prosseguir com esse parâmetro. Devolvidos os autos à origem, caberá àquela instância apreciar o cumprimento ou não do prazo em foco, prosseguindo-se com o feito como se entender por direito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 309: “Como se trata de sanção já de si extremamente

gravosa (a proibição de impugnar), não nos parece razoável dar-lhe interpretação extensiva. Temos, pois, por perfeitamente admissível a participação normal do réu na realização da prova pericial: o que lhe ficou interdito é a impugnação, e só ela”. No mesmo sentido, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 182.

74

Evaristo Aragão Santos, *Breves...* Op. cit., p. 1.431: “O juiz pode determinar a produção de outras provas que entender necessárias ao adequado julgamento das contas. A documental é uma delas, ainda mais diante do art. 551, § 1.º. Não se pode vedar ao órgão judicial a requisição, ao réu, da exibição de documentos que considere indispensáveis para o julgamento”. Sob o CPC/1973 o STJ decidiu que o requerimento de apresentação de documentos não constituía cumulação de pedidos: Ag. Rg. no Ag. 788.075/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, *DJe* 22.06.2009: “(...) 2. Ação de prestação de contas. Pedido para apresentação dos documentos necessários: o requerimento para a apresentação de documentos para verificação da correção na prestação de contas requerida, não configura cumulação de pedidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. O julgado torna nítida a possibilidade de exibição de documentos, embora não conceba o requerimento como pedido autônomo. Essa posição está correta. A exibição de documentos, nesse caso, tem nítido caráter instrumental. Trata-se de requerimento destinado a permitir o exame das contas. Não há pretensão autônoma, de modo que inexistente cumulação.

75

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...) III – admitidos no processo como incontroversos; (...).

76

Evaristo Aragão Santos, *Breves...* Op. cit., p. 1.434-1.435: “O tratamento desigual é compreensível, já que ao réu ficará vedado impugnar as contas do autor. Não ocorrerá o desdobramento do contraditório na forma do art. 551, § 1.º. Por isso as contas do autor já devem ser apresentadas com os documentos. É certo que na prática pode ser muito difícil ao autor juntá-los, já que vários deles, presumivelmente, podem estar na posse do réu. Seja como for, todos os documentos que justifiquem as contas propostas pelo autor *e que estejam a seu alcance* devem ser apresentados”.

77

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterà: I – a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II – a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III – as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

78

Sobre o tema, assinalando o cabimento de apelação cível contra a sentença que encerra a segunda fase da ação de exigir contas, ver TJPR, Ap. Cív. n. 1728036-3, 11ª Câmara Cível, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, j. 21.03.2018: “Apelação Cível. Ação de Prestação de Contas. Segunda Fase. Decisão Recorrível Mediante Recurso de Apelação. Art. 552 do NCPC. Ausência de Intimação da Segunda Ré da Sentença de Primeira Fase. Ausência de Interesse Processual da Ré Apelante para Arguir a Nulidade de Intimação da Corré.

Litisconsórcio Passivo Facultativo Simples. Art. 48 do CPC/73. Contas Apresentadas pela Ré Intempestivamente. Impossibilidade de Impugnar as Contas Prestadas pelo Autor. Art. 550, §5º do NCPC E 914, §2º do CPC/73. Litigância de Má-Fé não Demonstrada. Recurso de Apelação Não Provido”.

79

Evaristo Aragão Santos, *Breves...* Op. cit., p. 1.435: “Portanto, a segunda fase deve ser encerrada mediante a prolação de sentença *líquida*. É imprescindível, sob pena de nulidade (já que o julgamento estará incompleto), que a sentença registre saldo em favor de uma das partes”.

80

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários*, vol. XI, t. I, p. 117, ao aludir à sentença, afirma: “Esta possui por igual, efeitos condenatórios, porque, estabelecido o saldo, poderá aquele em favor de quem ele foi constituído postular execução da sentença”. Esta ideia está em conformidade com o que se defende no texto. A caracterização do provimento jurisdicional como condenação depende da adoção de execução sub-rogatória para a efetivação do direito de crédito.

81

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) inc. IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

82

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*, vol. II, p. 764: “Todavia, viu-se que a adequada interpretação do art. 139, inc. IV, do CPC, permite superar essa dicotomia injustificável, concluindo que todas as sentenças contêm executividade intrínseca e permitem a efetiva e plena realização do direito, pouco importando se se trata de prestação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar quantia. O dispositivo mencionado deve iluminar todo o sistema de tutela dos direitos, servindo como marco essencial para as técnicas de efetivação das decisões jurisdicionais. Assim, a técnica dos arts. 523 ss. (ou seja, a execução por expropriação patrimonial) passa a ser apenas uma das modalidades admitidas para a proteção de prestações pecuniárias, que não exclui, nem prefere, qualquer outra modalidade possível. Tudo deve reger-se pelos princípios da maior efetividade para o exequente e da menor onerosidade para o executado, na forma já estudada”. No mesmo sentido, Ricardo Alexandre da Silva, *Atipicidade dos meios executivos na efetivação das decisões que reconheçam o dever de pagar quantia no novo CPC*, p. 564: “O art. 139, inc. IV do NCPC caracteriza uma abertura do sistema à possibilidade de aplicação, inclusive no âmbito da tutela jurisdicional pecuniária, de mecanismos de indução e de sub-rogação, à semelhança do que ocorre em relação aos provimentos proferidos para a tutela das obrigações de fazer ou não fazer por força do art. 536, § 1.º”.

83

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 197-198, destaca que apesar da omissão do código, é evidente a referência aos administradores judiciais.

84

Evaristo Aragão Santos, *Breves...* Op. cit., p. 1.436: “O dispositivo também envolve regra de competência (funcional), já que esses administradores devem ser demandados no mesmo foro em que ocorreu a nomeação e, de preferência, perante o mesmo juízo no qual tramita esse processo”.

85

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...* cit., p. 198: “O ‘sequestro’ dos bens confiados ao administrador judicial, condenado a prestar contas, que deixe de pagar o saldo no ‘prazo legal’, sequestro não é. É retirada definitiva de posse dos bens cuja administração lhe fora confiada. Não se trata de medida cautelar nem mesmo preventiva”.

86

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...* cit., p. 329.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

CAPÍTULO III DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS

1. Posse: delimitação conceitual

Não é possível interpretar corretamente as regras instrumentais sem que se conheça o instituto a cuja proteção elas se destinam. Esse preceito metodológico é ainda mais verdadeiro no que se refere aos dispositivos processuais que disciplinam a tutela jurisdicional da posse, instituto jurídico firmemente enraizado no mundo da vida. Assim, antes de abordar as regras que regulam as ações possessórias, é necessário indicar elementos conceituais que contribuam para a compreensão da posse. Segundo o art. 1.196 do CC/2002,¹ possuidor é todo aquele que puder exercer, ainda que não plenamente, algum dos poderes inerentes à propriedade. A posse é definida obliquamente, por meio da caracterização do possuidor. Conquanto indireta, a definição legal traz subsídios importantes para a conceituação da posse. A referência à possibilidade de exercício de um dos poderes da propriedade deixa nítida a natureza fática do instituto. A posse, logo se percebe, é um fato. Manifesta-se na sociedade. Exprime-se pelo exercício de algum dos poderes que são conferidos pelo art. 1.228 do CC/2002 ao proprietário, quais sejam, o uso, o gozo, a disposição e o direito de recuperação.²

1.1. Posse como fato

Contra a definição da posse como fato, adotada na doutrina brasileira em diferentes épocas e, dentre muitos outros, por Lafayette Rodrigues Pereira,³ Antônio Joaquim Ribas,⁴ Tito Fulgêncio,⁵ Eduardo Espínola⁶ e Pontes de Miranda⁷, manifestaram-se Clóvis Beviláqua,⁸ Ruy Barbosa⁹ e Vicente Ráo,¹⁰ inspirados na lição de Rudolf von Ihering,¹¹ para quem a posse seria um direito. Essa questão atualmente está superada. A doutrina reconhece o caráter fático da posse, definindo-a como o poder que se pode exercer sobre determinada coisa.¹²

Caracterizando-se como o poder sobre a coisa, a posse se materializa na possibilidade de praticar algum poder intrínseco à propriedade ou domínio com exclusão de idêntica aptidão a qualquer outro membro da sociedade, ressalvados os casos de composses, nos quais dois ou mais sujeitos podem exercer sobre a coisa algum poder inerente ao domínio ou à propriedade.¹³ Trata-se, como enfatiza Pontes de Miranda, na esteira dos juristas que o antecederam, de “poder fático sobre a coisa”.¹⁴

O possuidor não perde a posse do apartamento que mantém desocupado. Do mesmo modo, o agricultor mantém a posse dos hectares não cultivados de sua fazenda. Esses exemplos comprovam a desnecessidade de *efetivo* exercício de poder sobre a coisa, bastando, para que se caracterize a posse, a *possibilidade de exercício do poder*. Fica afastada, portanto, a necessidade de contato com a coisa, a que corresponderia a noção tradicional de *corpus*.

1.2. Posse e intenção

Há manifestação de vontade na posse. O possuidor exprime sua intenção de possuir o bem. Assim, salvo quando a posse resultar de sucessão, hipótese em que o herdeiro será possuidor mesmo que ignore o falecimento do *de cujus*, haverá elemento volitivo a caracterizar a relação possessória. A posse adquirida pela sucessão é notável exceção ao disposto no art. 1.196 do CC/2002. Em regra, o possuidor estará ciente da possibilidade de exercer poder sobre a coisa. É nisso que consiste o elemento volitivo necessário à caracterização da posse.

1.3. Teorias subjetiva e objetiva

A análise pormenorizada das teorias de Friedrich Carl von Savigny e Rudolf von Ihering supera os limites deste trabalho, destinado fundamentalmente à compreensão dos dispositivos relacionados à tutela possessória no Código de Processo Civil. Contudo, considerada a influência das teorias subjetiva e objetiva nos estudos posteriores, não se pode deixar de indicar em seus traços mais gerais as concepções desenvolvidas pelos juristas.

Savigny enfatiza a importância da intenção na caracterização da posse. A vontade de deter a coisa é necessária para que aquele que a detém se torne possuidor. O ato físico de deter uma coisa tem na propriedade o fato jurídico correspondente, de modo que o *animus possidendi* corresponde à vontade de exercer a propriedade.¹⁵ A nota característica da teoria de Savigny consiste na ênfase concedida ao elemento volitivo, à vontade de possuir a coisa como proprietário, de modo que o *animus possidendi* seja equivalente ao *animus domini* ou *animus sibi habendi*.¹⁶

A teoria de Savigny sofreu vigorosa crítica por Rudolf von Ihering, para quem a noção de posse como poder físico sobre a coisa estaria completamente equivocada. A posse nada mais seria que a exteriorização da propriedade.¹⁷ Para Ihering também era indiferente a natureza da vontade de possuir, pois a diferença entre posse, detenção e apreensão dependeria do preceito legal aplicável ao caso.¹⁸ Precisamente por considerar a natureza da vontade do possuidor como irrelevante para a caracterização da posse, contrariamente ao que assinalava Savigny, a teoria de Ihering foi denominada de objetiva. A posse, para Ihering, é a exterioridade do domínio e sua proteção é realizada para que seja protegida a propriedade.¹⁹

Tanto a abordagem subjetiva, de Savigny, quanto a orientação objetiva, de Ihering, relacionam a posse à propriedade. Para o primeiro jurista, a posse se caracterizaria quando houvesse vontade de ser proprietário e a proteção da posse teria o fito de assegurar a paz social. De acordo com o segundo, a proteção da posse ocorria para que fosse protegida a propriedade. As duas abordagens relativizam a importância da posse, cuja proteção é realizada apenas para que seja tutelado o direito de propriedade.²⁰

Nesse ponto as teorias subjetiva e objetiva estão superadas, pois se reconhece que a posse deve ser protegida por si mesma, independentemente do direito de propriedade e até mesmo contra o proprietário, como resulta nítido do art. 1.197 do CC/2002. Ademais, as duas teorias procuram delimitar a posse a partir do Direito Romano, o que compromete a atualidade do instituto, que deve satisfazer as necessidades contemporâneas, as quais certamente diferem daquelas da antiga Roma.²¹

Quanto à crítica de Ihering à noção de poder fático sobre a coisa, retoma-se aqui a ideia de que a posse se caracteriza como a possibilidade de exercício do poder fático. Circunstâncias há em que esse poder não é exercido, como ocorre, para ficarmos com um dos exemplos trazidos pelo jurista alemão, com a madeira cortada e deixada no bosque. Mas inevitavelmente há possibilidade de exercício desse poder, de modo que a posse se caracteriza.

No que toca à intenção do possuidor, torna-se difícil, como se verá mais detidamente ao se examinar a diferença entre detenção e posse, dispensar por completo o elemento volitivo na caracterização da relação possessória. A falta de intenção, salvo a hipótese de abertura da sucessão, não permite que se adquira a posse. Não serei possuidor do *smartphone* que meu amigo esquece no meu carro. Tampouco o serei do carro que indevidamente é estacionado em minha vaga de garagem. E isso se deve ao fato de que em ambos os casos não tenho intenção de possuir legitimamente os referidos bens, os quais indiscutivelmente se encontram na esfera jurídico-patrimonial de seus proprietários. Não se pretende defender que só haverá posse quando houver vontade de possuir como proprietário. Haverá posse quando à possibilidade de exercício do poder físico sobre a coisa corresponder a vontade de possuí-la.

1.4. Posse e função social

Já Rudolf von Ihering reconhecia que a proteção da posse tinha como objetivo o *uso econômico*

da coisa.²² Todavia, o jurista concebia na proteção da posse um meio para a tutela da propriedade. Essa noção não deve prevalecer. A proteção possessória ocorre em atenção à posse em si, independentemente de sua relação com qualquer outro instituto jurídico. É para assegurar a melhor fruição do bem, em atendimento aos interesses do possuidor, que a posse é protegida.²³

Trata-se de instituto amplamente difundido na vida social. Seria difícil imaginar o aproveitamento econômico do bem, em atenção aos interesses do possuidor, sem que houvesse um sistema de proteção da posse. Tanto no campo, quanto na cidade, inumeráveis negócios jurídicos têm como objeto a posse. Eis a razão pela qual o legislador procurou tutelar a posse no plano infraconstitucional, positivando regras tanto no Código Civil, quanto no Código de Processo Civil.

Ainda que no plano constitucional inexistia disciplina específica sobre a posse, a Constituição erige a propriedade como direito fundamental (art. 5.º, XII), acrescentando que ela deverá atender a sua função social (art. 5.º, XIII).²⁴ A funcionalização da propriedade abre caminho para a ideia de funcionalização da posse.²⁵ No plano infraconstitucional, a função social da propriedade é disciplinada no art. 2.º, § 1.º, alíneas *a* a *d*, do Estatuto da Terra²⁶ (Lei 4.504/1964). O conceito de função social está difundido no direito positivo.²⁷ Pretende-se, aqui, compreender o que significa a função social da posse.

Costumeiramente, ao tratar do tema, acentua-se a necessidade de superação do conceito tradicional de posse, a fim de que o seu conteúdo seja ampliado e o instituto passe a ser visto como um direito real especial, deixando de ser o poder fático sobre a coisa, para ser “uma relação material, decorrente da vontade dotada de função social”.²⁸ A posse, considerada sua função social, passa a ser tutelada em razão do direito de possuir, em atenção às necessidades do homem.²⁹

Sustenta-se que desvestida de sua função social a posse tem sido incapaz de resolver as situações jurídicas para a qual existe como instituto, de modo que o Brasil, conquanto seja um país de dimensões continentais, contém em sua população milhares de despossuídos.³⁰ Assim, de acordo com esse posicionamento, no eventual conflito entre a função social da posse e a função social da propriedade, deverá o juiz realizar ponderação de valores e aplicar a regra da proporcionalidade, devendo ser efetivado o direito que melhor evidenciar o cumprimento de sua função social.³¹

Apresentado um resumo da justificação do princípio da função social da posse, passa-se a examiná-lo criticamente. A erradicação da pobreza e a melhoria das condições econômicas da população brasileira são objetivos que devem ser procurados incessantemente pela sociedade civil e pelo Estado. Nesse sentido, a proteção da posse como fenômeno independente da propriedade seguramente contribuirá para tutelar o possuidor contra o proprietário, algo que resulta de disposição expressa do Código Civil de 2002 (art. 1.196). Mas será tutelado pelo Direito o legítimo possuidor, não o esbulhador!

O esbulho gera imprevisibilidade e insegurança nas relações sociais e constitui grave violação da esfera jurídico-patrimonial do possuidor legítimo, quer ele seja, quer não seja simultaneamente proprietário. Para que a economia cresça e a pobreza diminua é necessária a realização de investimentos. Mas a premissa para a alocação de recursos é a previsibilidade, a confiança no retorno daquilo que foi investido, sendo digno de nota que o investidor aplica seu capital excedente. Se é assim, soluções jurídicas que levem à instabilidade, à insegurança, não podem ser consideradas como remédios para a erradicação da pobreza e diminuição da quantidade de despossuídos. O contrário é verdadeiro: a erradicação da pobreza passa pela segurança e previsibilidade das relações sociais. É preciso conceder ao legítimo possuidor a segurança de possuir.

Cabe ao juiz, não somente na tutela jurisdicional da posse, assegurar a previsibilidade do Direito, permitindo que os cidadãos planejem suas ações³². Mas essa proposição, válida para a generalidade dos casos, adquire traços ainda mais incisivos na tutela jurisdicional da posse, imprescindível para que possa ocorrer fruição dos bens.

Na condição de arrendatário de uma gleba de terra, é preciso ter segurança de que a posse será respeitada contra qualquer ato espoliativo do proprietário. Na condição de possuidor proprietário, é preciso ter a segurança de que a posse não será esbulhada, o que permitirá a alocação de recursos para o desenvolvimento da pecuária, da agricultura ou de outro empreendimento. A posse permite que o bem seja economicamente fruído pelo legítimo possuidor. Essa é a sua função, sendo de nenhuma relevância que ao substantivo se acrescente o adjetivo “social”. A posse de boa-fé, que protege o colono, que protegia já em Roma o pequeno agricultor, que permite a aquisição da propriedade por meio da prescrição aquisitiva em suas diversas modalidades, é o mesmo instituto que ainda hoje se mostra essencial para o desenvolvimento da economia, sendo objeto de miríade de negócios jurídicos.³³

Não se nega que o interesse do legítimo possuidor deve ser tutelado frente ao do proprietário, embora na maioria das vezes as figuras do possuidor e do proprietário coincidam. O que não se admite é a simplista solução de invocar a função social da posse a fim de permitir o esbulho do legítimo possuidor proprietário. A argumentação sobre a função social da posse trilha esse caminho sinuoso e não raras vezes parece admitir como objetivo a superação da “propriedade burguesa”. Ocorre que a proteção da propriedade e da posse é elemento essencial para que a economia se desenvolva, com melhores resultados principalmente para a parcela mais desfavorecida da população, seja pela oferta de emprego, seja pelo acesso a bens de consumo mais baratos, seja ainda pela redistribuição de recursos mediante tributação do imóvel.

Defender a ideia de que diante de um caso concreto de invasão – quer ele seja realizado por um indivíduo, quer o seja por um movimento social – a propriedade deva ceder em nome da função social da posse não é nada mais que solapar um dos alicerces da economia, inviabilizando a geração de riqueza e, conseqüentemente, impedindo a diminuição da pobreza. A regra de proporcionalidade não se aplica diante da tranquila solução trazida pelo direito infraconstitucional, favorável ao legítimo possuidor. Mais a mais, a noção de que caberia ao juiz ponderar os valores envolvidos não seria outra coisa que outorgar a possibilidade de que a solução fosse dada pelas diferentes inclinações ideológicas dos magistrados.

A proteção da posse em si mesma considerada, como possibilidade de exercício de poder sobre a coisa, assegura a fruição pelo legítimo possuidor. Discorda-se, portanto, da abordagem segundo a qual o desenvolvimento do capitalismo converteu a apropriação de bens pela posse no direito de propriedade³⁴.

Compreender a posse como instituto autônomo em relação à propriedade demonstra por si só sua importância para o mercado, o que contraria a ideia de que tenha sido esvaziada, justificável apenas à luz do conceito restrito de “apropriação fática das coisas”. Mesmo nesse caso, contudo, há de se ponderar que o desenvolvimento da noção de propriedade ocorreu muito antes do capitalismo. Este fenômeno surgiu na modernidade como decorrência, dentre outros fatores, do desenvolvimento de uma mentalidade capitalista, para a qual a *ascese intramundana*, originária das seitas protestantes e determinante para a constituição do conceito de *vocação profissional*, desempenhou fator fundamental.³⁵

Da autonomia da posse resulta, ainda, a impossibilidade de se verificar, para a finalidade de conceder proteção possessória, o cumprimento dos requisitos caracterizadores da função social da propriedade. Sendo a posse instituto autônomo, considerações sobre a função social da propriedade são completamente estranhas aos interditos possessórios. Desse modo, requerida a tutela jurisdicional da posse, não cabe ao juiz subordinar o deferimento da proteção possessória ao cumprimento dos requisitos elencados no art. 2.º, § 1.º, alíneas *a* a *d* do Estatuto da Terra ou, o que seria ainda pior, a critérios pessoais de atendimento da função social.

O ordenamento jurídico distingue a posse da propriedade e a legislação infraconstitucional, ao tutelar a posse, resguardou sua autonomia em relação à propriedade, de modo que a verificação, nas ações possessórias, dos requisitos da função social da propriedade, caracterizaria grave atentado ao sistema de tutela jurisdicional erigido para proteger a posse.³⁶

Poder-se-ia invocar a superioridade da Constituição para justificar o exame do cumprimento da

função social da propriedade no âmbito dos interditos possessórios. Ocorre que esse argumento se baseia na superioridade da Constituição para fazer tábula rasa da sistematização da posse e da propriedade no plano infraconstitucional. Da referência à função social da propriedade não se pode depreender a unificação desse instituto com a posse. Muito menos adequado será invocar a superioridade hierárquica da Constituição para condicionar a tutela jurisdicional da posse a requisitos exigidos para que a propriedade atinja sua função social.

Repita-se ainda outra vez: posse e propriedade não se confundem, de modo que a tutela jurisdicional da posse não está subordinada a requisitos elencados pelo ordenamento jurídico para a propriedade. Quando se separa juridicamente a posse da propriedade, pretende-se permitir a melhor fruição do bem. Para proteger a posse, em conformidade com o que exige o direito civil, disciplina-se procedimento especial no código de processo, o que se faz em nome da efetividade da jurisdição.

Não se pode supor que a separação entre posse e propriedade, tão cara para tantos valores amparados pelo Direito, como a segurança jurídica, a liberdade e a dignidade, seja inteiramente solapada ao argumento de que a Constituição, ao aludir à função social da propriedade, exige a verificação de seus requisitos para que seja concedida a tutela jurisdicional da posse. Se tal consideração estivesse correta, seria necessário decretar a inconstitucionalidade de todos os dispositivos que separam a posse da propriedade, o que fazem em atenção a antiquíssima distinção, presente na raiz do direito de origem romano-canônica.

Destarte, para que ocorra a efetiva e adequada tutela jurisdicional da posse, em atenção ao art. 5.º, XXXV e LXXVIII da Constituição, não se pode subordinar a concessão da proteção possessória ao acatamento de requisitos exigidos pela lei ou pela doutrina para a caracterização da função social da propriedade.

1.5. Objeto da posse

Conceituada a posse como possibilidade de exercício do poder fático sobre a coisa, cabe verificar quais bens se submetem à relação possessória. Em outras palavras, deve-se definir se a posse atinge apenas os bens materiais ou se abrangeria ainda “realidades imateriais”.³⁷ Afaste-se, desde logo, a ideia de que haveria posse de direitos pessoais, defendida com tanto brilho por Ruy Barbosa e Vicente Ráo. O que pretendiam os juristas, ao estenderem a posse aos direitos pessoais, era permitir que situações carentes de tutela obtivessem pronta resposta jurisdicional, mediante aplicação dos interditos possessórios.

Sendo a posse o poder fático sobre as coisas, por certo não é possível ampliá-la para nela abrigar a posse de direitos. Possui-se a coisa, não o direito. Ademais, a ideia da posse de direitos pessoais, além de conflitar com a dogmática, tornou-se desnecessária. Atualmente, com a possibilidade de obtenção de tutelas urgentes e a previsão de remédios especiais como o mandado de segurança, não há necessidade de ampliar o papel dos interditos possessórios.

Rejeitada a possibilidade de posse de direitos pessoais, volta-se à questão: restringir-se-ia a proteção possessória aos bens materiais ou bens imateriais também seriam passíveis de posse?

Prestigiada doutrina se posiciona contrariamente à possibilidade de ajuizamento de ações possessórias para a tutela de bens imateriais, de que seriam exemplo as energias e as ondas de rádio e televisão, de modo que a usucapião de linha telefônica, admitida na Súmula 193 do STJ,³⁸ seria notável exceção ao sistema de restrição dos remédios possessórios aos bens materiais.³⁹

Ocorre que a categoria “coisas corpóreas” abrange não apenas os bens que podem ser tocados, mas igualmente aqueles que sejam percebidos pelos sentidos, de que seriam exemplos as energias e as forças da natureza.⁴⁰ Assim, quando se menciona a posse de coisas corpóreas, alude-se igualmente a bens imateriais que possam ser percebidos pelos sentidos humanos.

Com efeito, a imaterialidade não faz desses bens abstrações construídas pela inteligência humana. São coisas que podem ser percebidas e, portanto, possuídas e protegidas pelas ações

possessórias. O Código Civil de 2002 define no art. 83, I, as energias que tenham valor econômico como bens móveis.⁴¹ Este dado do direito positivo constitui desmentido à ideia de que a proteção possessória não alcançaria bens imateriais. As energias, como se vê, estão explicitamente definidas como bens móveis, passíveis de propriedade e, portanto, de posse.

Restringir a proteção possessória aos bens corpóreos que podem ser tocados seria diminuir a importância da posse. O instituto, legado dos romanos, sempre esteve atrelado à realidade social. Trata-se, como se viu, de fato, não de direito. A posse de bens imateriais, compreendidos como aqueles que sejam perceptíveis aos sentidos humanos, é de todo adequada na contemporaneidade. É correto afirmar que a posse é protegida a fim de assegurar o melhor proveito econômico da coisa. Em outras palavras, protege-se a posse para assegurar ao possuidor a melhor fruição. Considerando o desenvolvimento tecnológico, a permitir a fruição de diversas realidades imateriais, seria arcaísmo incompreensível reduzir a posse às coisas materiais. Ciente disso, tratou o legislador de classificar as energias como bens móveis. Merecem classificação idêntica as ondas de rádio e de televisão.

Considerada a maior amplitude do conceito de coisas corpóreas, a abrigar as realidades imateriais, cabe investigar se poderiam as ações possessórias proteger bens caracterizados como propriedade intelectual e industrial. Pontes de Miranda responde afirmativamente.⁴² Todavia, a Súmula 228 do STJ rejeitou a aplicação do interdito proibitório para a tutela dos direitos autorais.⁴³

Concorda-se com posicionamento adotado pelo STJ. O direito autoral é direito e, como tal, não é alcançado pela proteção possessória. Para evitar o ilícito é possível ajuizar demanda inibitória, expressamente prevista no art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Para implementar a decisão poderão ser aplicados os mecanismos coercitivos ou sub-rogatórios previstos no art. 536, § 1.º do CPC/2015. Este dispositivo consagra o direito ao meio executivo necessário no caso concreto, sendo irrelevante que outro mecanismo tenha sido pleiteado pelo jurisdicionado.⁴⁴ Nota-se, portanto, que para a proteção do direito autoral, seja mediante tutela inibitória pura, seja por meio de remoção do ilícito, não é necessário lançar mão do interdito proibitório, o que confirma o acerto da orientação adotada no STJ.

2. Modalidades da posse

A compreensão dos dispositivos relacionados às ações possessórias também pressupõe o domínio conceitual das diversas modalidades de posse. O art. 567 do CPC/2015, por exemplo, alude ao possuidor direto ou indireto que tenha receio de ser molestado. Por sua vez, os arts. 1.200 e 1.201 do CC/2002 referem-se, respectivamente, à posse justa e à de boa-fé. Escusado dizer que a aplicação dos dispositivos requer conhecimento sobre as modalidades de posse, com o que se comprova a importância da classificação.

2.1. Posse direta e posse indireta

Haverá posse indireta sempre que outrem exercer a posse direta, não ocorrendo a exclusão de uma posse em relação à outra.⁴⁵ O usufruto é exemplo tradicional em que convivem a posse direta, exercida pelo usufrutuário, com a posse indireta, exercida pelo nu-proprietário. O conceito de posse indireta reforça a ideia de que não é necessário contato físico com a coisa para que ela se submeta à posse. Basta a possibilidade de exercício do poder sobre a coisa para que a posse se caracterize.

No art. 1.197 do CC/2002 é expressamente asseverado que a posse direta não anula a posse indireta, sendo outorgada ao possuidor direto proteção possessória contra o indireto.⁴⁶ Embora o dispositivo não o diga expressamente, evidentemente poderá o possuidor indireto ajuizar as ações possessórias para a defesa da posse agredida por terceiro. Também poderá fazê-lo contra o possuidor direto se a posse deste se tornar ilegítima.

2.2. Posse justa e posse injusta

O Código Civil define como posse justa aquela que não seja violenta, clandestina ou precária.⁴⁷ A definição, como se vê, ocorre por exclusão. Para saber o que é posse justa é necessário definir posse violenta, clandestina e precária. Violenta é a posse adquirida com o uso de força.⁴⁸ Clandestina é a posse cuja aquisição ocorre às ocultas, agindo arditosamente aquele que procura conquistar a posse.⁴⁹ Precária é a posse marcada pelo abuso de confiança, em que aquele que recebeu a coisa deixa de devolvê-la.⁵⁰ Justa, portanto, será a posse que não estiver tísada pelos vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.

2.3. Posse de boa-fé e posse de má-fé

De boa-fé, nos termos do *caput* do art. 1.201 do CC/2002, é a posse exercida por possuidor que desconhece vício ou obstáculo à aquisição da coisa.⁵¹ Caracteriza-se a posse de boa-fé quando houver plausibilidade na crença do possuidor sobre a legitimidade de sua condição, de modo que a consciência sobre o caráter ilegítimo da posse a caracteriza como de má-fé.⁵² O critério classificatório enfatizado pelo dispositivo é a convicção do possuidor sobre a idoneidade da posse, a demonstrar que a boa-fé é verificada na dimensão subjetiva, não na objetiva.⁵³

No parágrafo único do art. 1.201 é mencionado que o justo título do possuidor conduz à presunção de sua boa-fé.⁵⁴ Justo título é o fundamento de legitimidade da posse, compreendido como o ato jurídico que o possuidor reputa como capaz de lhe transmitir o bem.⁵⁵ Desse conceito decorre a importante consequência de que o justo título deve cumprir os requisitos formais que do título são exigidos.⁵⁶ Com efeito, tratando-se de ato jurídico capaz de instilar no possuidor a ideia de transmissão legítima e, conseqüentemente, de posse de boa-fé, não é aceitável que o justo título descumpra cabalmente os pressupostos de validade do título. Se isso ocorrer, justo título não há.

Suponha-se que o possuidor invoque como justo título de sua posse a transmissão verbal e gratuita do imóvel em que vive. Ainda que tenha havido a alegada “doação” e mesmo que o possuidor realmente creia na possibilidade de transmissão verbal da propriedade, fato é que inexistente justo título na hipótese, pois no art. 1.245 o Código Civil é inequívoco ao exigir o registro do título translativo no Registro de Imóveis para que se perfectibilize a transmissão da propriedade por ato *inter vivos*.⁵⁷ A “doação verbal” do imóvel é ato em completo descompasso com os requisitos previstos em lei para a transmissão da propriedade por ato entre vivos. Isso significa que não poderia o possuidor crer na legitimidade de sua posse? A resposta é negativa. O possuidor poderia crer na legitimidade de sua posse, mas nesse caso não contaria com a presunção de boa-fé em seu favor, haja vista a inexistência de justo título. A consciência do possuidor quanto à legitimidade ou ilegitimidade de seu ato teria de ser investigada.

Hipótese diversa ocorreria se o possuidor tivesse registrado o ato translativo no Registro de Imóveis, sendo este ato posteriormente anulado. Nesse caso o possuidor teria justo título, pois conquanto anulado, o ato jurídico em que se fundava sua posse parecia realmente cumprir os requisitos de validade capazes de permitir a transferência da propriedade.

O art. 1.201, parágrafo único do CC/2002, assinala que o justo título faz presumir a boa-fé. O próprio dispositivo aponta o caráter relativo da presunção, ao assinalar que ela inexistirá quando houver prova em sentido contrário ou quando a lei expressamente não a admitir. A presunção prevista no art. 1.201, parágrafo único, é presunção legal relativa. Caracteriza-se como hipótese legal de inversão do ônus da prova. Explica-se. Normalmente caberia ao possuidor provar sua boa-fé. Ocorre que, ao invocar ato jurídico caracterizado como justo título, passa a ser presumido como possuidor de boa-fé por força da lei. Recai sobre aquele que alega a ilegitimidade de sua posse o ônus de provar a má-fé. Daí se falar em inversão de ônus da prova.

Ocorrerá a perda da boa-fé, conforme assinala o art. 1.202 do CC, quando houver circunstâncias que façam presumir que o possuidor não desconhece a ilegitimidade de sua condição.⁵⁸ As circunstâncias a que alude o dispositivo constituem a fonte de prova adequada para a demonstração da má-fé do possuidor, já que esta normalmente não é alardeada, de modo que normalmente inexistirão outros elementos probatórios além de indícios.⁵⁹ Nos termos do código a prova indiciária será suficiente para que se evidencie a inviabilidade da crença do possuidor na

legitimidade de sua posse. Se o possuidor, crente na validade da doação verbal, foi notificado para abandonar o imóvel, não poderá a partir deste momento invocar a boa-fé de sua posse. Como se vê, bastará que se opere circunstância que torne ilegítima a crença na boa-fé para que a posse perca sua probidade.

Obviamente não poderá alegar boa-fé quem tenha tomado a posse consciente de violência injusta. Hipótese diferente é aquela na qual o possuidor crê que tenha realizado ato de desforço legítimo, conforme o art. 1.210, § 1.º do CC/2002, tendo na realidade agredido a posse de outrem. Nesse caso, ainda que a violência tenha caracterizado esbulho, agiu o possuidor crente na legitimidade da defesa da posse, não se caracterizando a má-fé.

A natureza da posse traz relevantes consequências. Nos termos do art. 1.216 do CC/2002 o possuidor ímprobo responderá desde o momento em que se caracterizou a má-fé pelos frutos colhidos e percebidos, assim como pelos que culposamente deixou de perceber, sendo-lhe assegurada somente a restituição das despesas de produção e custeio, a fim de evitar enriquecimento ilícito.⁶⁰ Impõe-se ainda a restituição dos frutos pendentes quando cessar a boa-fé.⁶¹ Conforme dispõe o art. 1.218, o possuidor de má-fé responderá pela perda ou deterioração da coisa mesmo que acidentais, a não ser quando demonstrar que ela aconteceria mesmo se o bem estivesse na posse daquele que o reivindica.⁶² Ademais, no art. 1.220 o Código Civil prescreve que o possuidor de má-fé será indenizado apenas pelas benfeitorias necessárias, não lhe cabendo o direito de retenção em relação a elas, nem o de levantamento das benfeitorias voluptuárias.⁶³

As sanções que recaem sobre o possuidor de má-fé não incidem sobre aquele que possuíra com boa-fé. O Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito aos frutos percebidos.⁶⁴ Do mesmo modo, o código isenta o possuidor probo de responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa a que não tenha dado causa.⁶⁵ No tocante às benfeitorias, concede a lei amplas prerrogativas àquele que possui de boa-fé. Será indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis e poderá levantar as benfeitorias voluptuárias que não lhe forem pagas desde que o faça sem prejudicar a coisa possuída. Poderá, além disso, exercer o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias ou úteis.⁶⁶

2.4. Presunção da manutenção do caráter da posse

O art. 1.203 do CC presume que a posse mantém o caráter com que fora adquirida.⁶⁷ Estabelece-se, também aqui, uma presunção relativa, passível de revogação se houver prova em sentido contrário. A manutenção do caráter da posse diz respeito tanto à justiça ou injustiça, concernente ao aspecto objetivo da posse, quanto ao aspecto subjetivo, relacionado à boa-fé ou má-fé do possuidor e ao exercício direto ou indireto da posse.⁶⁸

A mera vontade do possuidor é insuficiente para operar modificação na natureza da posse, a qual se altera somente quando houver mudança no título aquisitivo.⁶⁹ O possuidor violento continuará a sê-lo depois da cessação do esbulho. Mas outro será seu *status* se vier a adquirir a propriedade daquele que fora esbulhado. Não remanescerá, nesse caso, a violência da posse, como também não remanesceria se se tratasse de clandestinidade ou de precariedade.

Alteração no caráter da posse também ocorrerá se o possuidor de má-fé adquirisse o bem, hipótese em que se torna possuidor de boa-fé, ostentando título adequado para a transmissão da propriedade e, conseqüentemente, da posse.

Mesmo o exercício direto ou indireto da posse pode se alterar se sobrevier modificação do título com que a posse é exercida. Basta imaginar situação em que o locatário adquira o bem do locador e para ele o alugue.

3. Composse

É admitida pelo ordenamento jurídico a possibilidade de duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, sendo-lhes assegurado o exercício de posse sobre o bem desde que não ocorra exclusão de

outro compossuidor.⁷⁰ À posse de coisa *pro indiviso* se dá o nome de composses.

O tema suscitou grande polêmica desde o direito romano, pois ao conceber a posse como o poder exercido sobre a coisa, parte dos jurisconsultos não admitia a composses, já que o exercício de poder por um dos possuidores excluiria a posse dos demais.⁷¹ Posteriormente a composses foi reconhecida ao argumento de que representaria exceção ao princípio da exclusividade da posse. A coisa juridicamente indivisível seria possuída totalmente por cada um dos possuidores, tal como ocorre nas servidões.⁷²

A admissão da composses se torna bastante natural quando se reconhece a possibilidade de condomínio.⁷³ Com efeito, aceita a comunhão de propriedade sobre coisas juridicamente indivisíveis, deve-se admitir igualmente a possibilidade de composses.

Pontes de Miranda classificou a composses em *simples* ou de *mão comum*. Na *composses simples* cada um dos possuidores exerce autonomamente o poder fático sobre a coisa, sendo exemplo a composses direta dos condôminos de determinado terreno. Na *composses de mão comum* as posses não são independentes, de modo que nenhum possuidor poderá exercê-la autonomamente. É exemplo de *composses de mão comum* aquela exercida sobre cofre com segredo, sendo cada um dos proprietários conhecedor de parte dele.⁷⁴

Não é correta a ideia de que na composses cada possuidor possuiria uma fração abstrata do bem.⁷⁵ Como adverte Pontes de Miranda, a atribuição de quota significa posse sobre coisa individualizada, sendo certo que o Código Civil não faz menção a quotas ao disciplinar a composses.⁷⁶ O raciocínio do jurista, apresentado sob a vigência do Código Civil de 1916, vale também para a codificação civil de 2002. Conclui-se que a suposição de que haja partes abstratas a favorecer cada um dos possuidores implica a posse sobre partes individualizadas e, portanto, de composses não se trata.⁷⁷

O art. 1.199 do CC/2002 autoriza cada um dos possuidores a exercer a posse sobre a totalidade da coisa comum, desde que não exclua idêntica prerrogativa de outro possuidor.⁷⁸ Se houver ato atentatório à posse de outro possuidor, poderá este, nos termos do art. 1.199 ajuizar demanda possessória. Se a agressão à posse for praticada por terceiro, cada um dos compossuidores poderá se valer dos interditos.

4. Posse e mera detenção

O art. 1.198 do CC/2002 denomina de mero detentor aquele que conserva a posse em nome de outrem, seguindo suas ordens e instruções.⁷⁹ Esse dispositivo é complementado pelo art. 1.204 do mesmo diploma, a estabelecer que a posse é adquirida a partir do momento em que for possível exercê-la em nome próprio.⁸⁰ Para a separação entre os conceitos de posse e detenção ainda é necessário analisar o art. 1.208, também do Código Civil, de acordo com o qual atos de mera permissão ou tolerância não constituem posse.⁸¹

Os elementos colhidos do direito positivo permitem concluir que não haverá posse quando aquele que detiver a coisa o fizer sob as ordens de terceiro. Nesse caso há detenção, sendo o terceiro o verdadeiro possuidor. É possível adquirir a posse somente quando exercida em nome próprio, ou seja, sem que o poder fático exercido sobre a coisa tenha como fundamento ordens ou instruções do possuidor. Se a detenção realizada sob as instruções de outrem não caracteriza posse, igualmente não o fazem os atos de mera liberalidade ou tolerância do possuidor. Tolerar que o vizinho passe sobre o imóvel vez por outra, não significa abrir mão da posse, nem caracteriza a conduta como agressão.

Cabe destacar a inadequação das alusões a “posse em nome próprio” e “posse em nome alheio”, pelo singelo motivo de que aquele que exerce posse em nome de outrem na realidade possuidor não é, mas mero detentor.⁸² A posse pressupõe o exercício do poder fático no *interesse* do possuidor, de modo que não haverá posse quando este poder for exercido em benefício de outrem.⁸³

A diferença entre possuidor e detentor está no elemento volitivo, sendo claro que eles não se relacionam com a coisa da mesma maneira. Isso não significa que inexistia vontade na detenção. A conservação da coisa, contudo, é feita em nome de outrem, sem que o detentor possa pretender possuí-la.⁸⁴

Aceitando o elemento volitivo na definição da posse, torna-se mais fácil distingui-la da detenção. Contudo, as dificuldades crescem significativamente quando se recusa à vontade qualquer papel, como o fez Pontes de Miranda, para quem o direito positivo brasileiro havia abstraído *corpus e animus*, não os considerando como elementos definidores da posse.⁸⁵ Para o jurista inexistiria conceito apriorístico de detenção, sendo inexato supor que esta jamais geraria efeitos jurídicos, pois tudo dependeria do direito positivo.⁸⁶ Clóvis do Couto e Silva adotou o mesmo posicionamento, afirmando que o ordenamento jurídico indicaria os pressupostos da posse e da detenção.⁸⁷

É certo que ao abordar o tema não se pode ignorar o direito positivo. Mas isso obviamente não significa a impossibilidade de elaboração conceitual dos institutos. Sem que os conceitos de posse e detenção existissem previamente à elaboração legislativa, por óbvio não poderia o legislador discipliná-los, atribuindo-lhes diferentes efeitos.⁸⁸ Identifica-se no plano fático a diferença entre posse e mera detenção. Discorda-se, portanto, da ideia de que as diferenças entre posse e detenção decorram exclusivamente do direito positivo. Abstraído o direito, ainda seria facilmente verificável a diferença entre o caseiro contratado para cuidar da chácara enquanto o dono se ausenta e o possuidor que acredita na legitimidade da posse que exerce sobre a coisa. Trata-se, logo se vê, de situações fáticas diferentes, a originar dois diferentes institutos. Essa diferença o direito positivo não pode ignorar.

Vê-se, assim, que o elemento volitivo é essencial para a distinção entre posse e mera detenção.⁸⁹ O detentor age em conformidade com a vontade do possuidor e, por isso, não possui, mas apenas detém. A distinção não é meramente acadêmica, mas gera relevantíssimas consequências jurídicas.

Não poderá o mero detentor adquirir a propriedade por usucapião, pois não exerce a posse mansa e pacífica do bem. Note-se que o Código Civil, nos arts. 1.238, 1.239, 1.240 e 1.240 – A, § 1.º vale-se respectivamente das expressões “possuir como seu um imóvel”, “possua como sua”, “possuir, como sua” e “ao mesmo possuidor”, caracterizando a posse como indiscutível pressuposto para a usucapião. Assim, como a detenção não se confunde com a posse, a usucapião é inacessível ao detentor.

Para analisar a defesa da posse pelo detentor, mediante interditos, impõe-se previamente indicar duas categorias de detenção. A primeira, denominada detenção *dependente* ou subordinada, é aquela praticada pelo fâmulos da posse ou por aquele que exerce ato tolerado ou permitido pelo possuidor. Está prevista nos arts. 1.198 e 1.208 do CC/2002. A segunda modalidade de detenção é a *independente*, sendo exemplo aquela praticada com violência ou clandestinidade. Sua previsão está no período final do art. 1.208.⁹⁰

O detentor dependente não poderá ajuizar os interditos possessórios.⁹¹ Sua condição de servidor da posse não lhe outorga essa prerrogativa. Perceba-se, quanto ao detentor independente, que o vício de sua posse, eis que obtida mediante violência ou clandestinidade, limita-se ao antigo possuidor. Em relação ao restante da sociedade sua posse será legítima.⁹² Disso decorre a possibilidade do detentor independente fazer uso dos interditos contra terceiros.

O art. 1.208 do CC/2002 assinala que atos clandestinos ou violentos não conduzem à posse, senão depois da cessação da violência ou da clandestinidade. O dispositivo se conecta com o art. 1.203, de acordo com o qual a posse conserva o caráter com que foi adquirida. Esses dispositivos são a fonte normativa da conclusão de que o detentor conservará o caráter de injustiça de sua posse em relação ao possuidor, mas cessada a violência ou a clandestinidade, será possuidor perante a sociedade.

Foi dito que se terceiro violar a posse do detentor independente, este poderá empregar os

interditos possessórios. Isso, contudo, não inviabiliza a propositura de ação de reintegração de posse contra o detentor independente pelo possuidor que fora alijado da posse em razão de violência ou clandestinidade. É evidente que se não houver reintegração liminar, o possuidor poderá recuperar sua posse na sentença. Enquanto isso, aquele que perante o possuidor é mero detentor, tendo obtido posse por ato clandestino ou violento, poderá defendê-la de ataques perpetrados por terceiros.

5. Posse e propriedade

É por meio do conceito de possuidor que o art. 1.196 do CC/2002 define a posse. Ao fazê-lo, estabelece correlação com a propriedade, assinalando que será possuidor todo aquele que exercer, plenamente ou não, um dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição.

É bastante evidente que posse e propriedade não se confundem. A propriedade é direito real. A posse é fato. O proprietário do imóvel poderá ser também o possuidor, mas em situações corriqueiras da vida em sociedade o possuidor não é proprietário. Ademais, o sistema de proteção da posse permite que o possuidor seja tutelado contra o proprietário. Essa afirmação nega a teoria de Rudolf von Ihering, para quem a proteção da posse é realizada com a finalidade de se defender a propriedade.⁹³ Se nesse ponto Ihering tivesse razão, então nada justificaria que o possuidor fosse tutelado contra agressões à posse realizadas pelo proprietário.

Reconhece-se atualmente que a posse é protegida por sua própria relevância socioeconômica.⁹⁴ Prevaleceram as teorias absolutas de proteção da posse, segundo as quais ela é tutelada por si mesma, não como instrumento para a defesa da propriedade ou de qualquer outro instituto jurídico. Não se protege o direito à posse, mas o poder fático exercido sobre a coisa.⁹⁵

Como se verá adiante, nas ações possessórias sequer será possível discutir sobre a propriedade, eis que proibida a exceção de domínio. Também esse ponto reforça a separação entre posse e propriedade, institutos jurídicos inconfundíveis.

6. Posse e servidões

No art. 1.213 o Código Civil concede proteção às servidões aparentes, outorgando-a também às não aparentes quando os títulos se originarem do possuidor do prédio serviente ou daqueles de quem este os obteve.⁹⁶ As servidões aparentes são visíveis, não o sendo as não aparentes, de que seria exemplo a servidão de não edificação após determinada altura.⁹⁷ Considerada a visibilidade como elemento diferenciador entre as duas espécies de servidões, pode-se definir como aparente a servidão que se manifeste por “obra exterior”, sendo não aparentes as servidões cujo exercício prescinde de qualquer obra.⁹⁸

Também é clássica no direito brasileiro a distinção entre servidões contínuas e descontínuas. Haverá servidão contínua quando seu exercício não requerer qualquer atividade além daquela necessária para sua constituição, sendo exemplo a servidão de passagem de água. Descontínua será a servidão quando for necessária alguma conduta pelo proprietário do imóvel dominante.⁹⁹ Conquanto clássica, essa distinção não foi incorporada no art. 1.213 do CC.

A proteção às servidões aparentes é extraída por meio de interpretação *a contrario sensu*: se não se protege as servidões não aparentes, salvo nas hipóteses indicadas no dispositivo, então são protegidas as servidões aparentes.¹⁰⁰ Logo, havendo servidão aparente, é possível o emprego dos interditos possessórios para tutelá-la.¹⁰¹ Quanto à proteção das servidões não aparentes, são necessários maiores esclarecimentos.

O art. 1.213 assinala que não serão protegidas as servidões não aparentes a não ser que estejam tituladas, quer isso ocorra mediante registro, quer isso se dê por meio de justo título.¹⁰² Saliente-se que nos termos do que dispõe o STF no verbete 415 de sua Súmula de jurisprudência,¹⁰³ obras

permanentes seriam motivo capaz de justificar a proteção possessória da servidão.

Com a expressão “daqueles de quem este os houve” o art. 1.213 se refere à hipótese em que o possuidor do prédio serviente o tenha obtido com a servidão. Isso significa que se a servidão tiver sido registrada pelos proprietários anteriores ou decorrer de justo título anterior à aquisição do bem pelo atual proprietário, será possível protegê-la por meio das ações possessórias.¹⁰⁴

7. Aquisição da posse

O art. 1.204 assinala que a posse é adquirida a partir do momento em que se torna possível exercer em nome próprio algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.¹⁰⁵ É bastante evidente a conexão deste dispositivo com o art. 1.196, que ao definir quem é possuidor indica indiretamente o que é a posse. Extrai-se dessa conexão entre os dispositivos a ideia de que a posse, sendo fato, não será adquirida a não ser quando for possível o exercício de poder fático sobre a coisa.

Decorre do art. 1.204 que a realização de negócio jurídico não permitirá a caracterização de posse, só instaurada quando o adquirente efetivamente vier a exercer poder fático sobre a coisa, salvo na hipótese de *constituto possessório*.¹⁰⁶ Em virtude da cláusula *constituti* o alienante permanece na posse do imóvel, mas o faz em nome do adquirente. Estabelecida a cláusula *constituti*, poderá o adquirente defender a posse por meio dos interditos.

No art. 1.205, I, o Código Civil estabelece que a posse pode ser adquirida pela própria pessoa ou por representante, acrescentando o inc. II que mesmo terceiro sem mandato poderá adquirir a posse em nome daquele que a pretende, desde que haja posterior ratificação do ato aquisitivo.¹⁰⁷

O ato aquisitivo da posse, na hipótese do art. 1.205, I, exige vontade do agente, não sendo requerida a capacidade necessária para a celebração de negócios jurídicos. Contudo, para que haja representação, exige-se capacidade jurídica. A aquisição da posse, na hipótese de representação, decorrerá da vontade do representante, que só obterá a posse quando passar a exercer poder fático sobre a coisa, nos termos preconizados no art. 1.204. A aquisição por terceiro sem mandato exige posterior ratificação, de modo que nesse caso a capacidade jurídica é requisito, pois sem ela não haverá ratificação.¹⁰⁸

Conforme assenta o art. 1.206 do CC, a posse é transmitida aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres que apresentava durante a vida do *de cuius*.¹⁰⁹ Se posse injusta e de má-fé, não se transformará em justa e de boa-fé em razão da morte do possuidor.

No art. 1.207 o Código Civil estabelece que o sucessor universal continuará a posse do antecessor, facultando-se ao sucessor singular unir sua posse à daquele a quem sucede.¹¹⁰ Em relação ao sucessor universal, o art. 1.784 do CC estabelece a transferência da posse no momento da morte do *de cuius*.¹¹¹ Trata-se da *saisine*. Para que a posse e a propriedade sejam transferidas não é necessário que os herdeiros se manifestem, sendo certo que desde o óbito poderão tutelar a posse por meio das ações possessórias.¹¹²

A posse do herdeiro decorre do art. 1.784 e não se relaciona com o disposto nos arts. 1.196 e 1.204.¹¹³ O herdeiro se torna possuidor ainda que não exerça poder fático sobre a coisa, sendo desnecessária qualquer manifestação de vontade nesse sentido. Para a transmissão da posse basta o falecimento do *de cuius*. É admissível que a tutela possessória seja requerida pelo inventariante, detentor do poder fático sobre a coisa, contra um dos herdeiros¹¹⁴.

O legatário, por sua vez, encontra-se em situação diferente. No art. 1.923, *caput*, o Código Civil assenta que a propriedade da coisa certa lhe é transferida a partir da abertura da sucessão. Todavia, o § 1.º do mesmo dispositivo dispõe que ao legatário não se defere imediatamente a posse, sendo-lhe proibido nela ingressar por autoridade própria.¹¹⁵ Embora a propriedade seja transferida, a posse não o é, recaindo sobre o legatário, para obtê-la, o ônus de ajuizar ação de imissão na posse.¹¹⁶ O descabimento das ações possessórias decorre da inexistência de posse em

favor do legatário. Quem não exerce a posse, não pode se valer dos interditos possessórios, em razão da falta de interesse processual.

8. Perda da posse

O art. 1.223 do CC/2002 preconiza que haverá perda da posse, mesmo contra a vontade do possuidor, quando cessar o poder sobre o bem exercido nos termos do art. 1.196.¹¹⁷ Por sua vez, o art. 1.224 do mesmo código dispõe que a posse só se considera perdida, por quem não presenciou o esbulho, se ciente da agressão deixa de recuperar a coisa ou, tentando fazê-lo, é violentamente repellido.¹¹⁸

Ainda que a vontade do possuidor se manifeste no sentido de exercer a posse, terá ocorrido perda quando houver cessado definitivamente o poder fático exercido sobre a coisa.¹¹⁹

Há equívoco linguístico no art. 1.224. O correto seria que o dispositivo mencionasse “retomar a coisa”. Poder-se-ia argumentar que é correta a menção de retorno à coisa, mas nesse caso, logo se vê, impõe-se o uso da crase, omitido pelo legislador. Apesar do erro, extrai-se tranquilamente do dispositivo que o esbulho não presenciado pelo possuidor só levará à perda da posse se ele se abster de retomar a coisa esbulhada ou, tentando fazê-lo, for repellido com violência.

O tema exige maior reflexão. Por certo não se poderá exigir do possuidor que pratique o desforço para somente então lhe permitir acesso às ações possessórias. Se não presenciou o esbulho, mas está ciente do poder fático do esbulhador sobre a coisa, poderá desde logo fazer uso dos interditos.

9. Presunção de posse e tutela jurisdicional da posse de coisas móveis

O art. 1.209 do CC/2002 é regra de direito processual. Dispõe que a posse do imóvel leva à presunção da posse dos móveis que nele se encontrarem.¹²⁰ Trata-se de presunção relativa, podendo ser infirmada por prova em sentido contrário.

O dispositivo caracteriza inversão legal do ônus da prova. Explica-se. Segundo o art. 373, I do CPC/2015, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, se o litígio recair sobre a posse de bens móveis, terá o autor de prová-la. Contudo, se o autor comprovar a posse do imóvel em que se encontram as coisas móveis, caberá ao réu provar a posse sobre estes, invertendo-se o ônus da prova por força da lei. Daí se falar em inversão legal do ônus da prova.

O procedimento para a tutela jurisdicional das coisas móveis é questão controversa. A Lei 9.099/1995, no art. 3.º, IV c/c I, fixa a competência dos juizados especiais cíveis para o processamento e julgamento de ações possessórias sobre imóveis que não excedam o valor de quarenta salários mínimos.¹²¹ Embora o dispositivo mencione somente os bens imóveis, não faria sentido retirar da competência dos juizados especiais bens móveis que respeitem o valor de alçada. Assim, o art. 3.º, IV deve ser interpretado extensivamente, a fim de abrigar também os bens móveis.

Questiona-se, ante a previsão da Lei dos Juizados Especiais, se o autor pode propor as ações possessórias disciplinadas nos arts. 554 e ss. do CPC para a tutela jurisdicional da posse de bens móveis ou imóveis com valor igual ou inferior a quarenta salários mínimos. As diferenças procedimentais são relevantíssimas, pois as ações disciplinadas no código permitem a concessão de liminar, inexistindo previsão neste sentido na Lei dos Juizados Especiais. Isso significa que se a demanda for proposta em conformidade com o procedimento sumaríssimo, não será possível o deferimento de liminar possessória.

Sob o código processual revogado, posicionava-se a doutrina em favor da facultatividade, assinalando que caberia ao autor escolher o procedimento por meio do qual submeteria sua demanda à apreciação jurisdicional.¹²² Não há razões para se afastar desse posicionamento à luz do novo código.

Não seria coerente, em razão da vigência do CPC/2015, sustentar a revogação do art. 3.º, II, da Lei 9.099/1995, pois este dispositivo consagra regra especial para móveis e imóveis com valor igual ou inferior a quarenta salários mínimos. Por outro lado, o código concedeu grande ênfase à autonomia da vontade do jurisdicionado, permitindo inclusive a realização de negócios jurídicos processuais. Desse modo, a ideia de que o autor não poderia escolher entre um dos procedimentos previstos em lei não se afeiçoa à maior liberdade concedida às partes pela nova codificação.

A liberdade na escolha do procedimento – sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/1995, ou especial, disciplinado no CPC – se restringe às ações de força nova, ou seja, nas quais a violação da posse tenha ocorrido há menos de ano e dia. Se se tratar de ações de força velha, nas quais o procedimento especial estabelecido no código é incabível, deverá o autor submeter sua demanda aos Juizados Especiais ou ao procedimento comum, dependendo do valor da causa, conforme apontava a doutrina à luz do CPC/1973.¹²³

10. Tutela jurisdicional da posse: proteção do *jus possessionis*

O Código de Processo Civil disciplina as ações possessórias no Capítulo III, intitulado “Das Ações Possessórias”, do Título III, denominado “Dos Procedimentos Especiais”, do Livro I, designado “Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença”, da Parte Especial. Foram previstos os tradicionais interditos possessórios, quais sejam, as ações de reintegração e de manutenção de posse e o interdito proibitório.

A opção do legislador é louvável. Embora nos arts. 300 e ss. esteja disciplinada a tutela de urgência, o que autorizaria o pedido de antecipação de tutela em demandas possessórias, o procedimento especial regulado nos arts. 560 e ss. do Código de Processo Civil permite que seja proferida decisão liminar desde que a posse tenha sido agredida em prazo igual ou inferior a ano e dia. Ficam abstraídas, portanto, considerações sobre a urgência, o que indubitavelmente simplifica a proteção da posse.

Ademais, ainda quando se admita que o juiz possa construir, ouvindo as partes, o procedimento específico mais idôneo para o caso concreto, o que suprimiria a necessidade de um procedimento especial, certo é que nem todos os advogados e juízes atuariam adequadamente sob o ponto de vista técnico, o que poderia comprometer a tutela da posse, de modo que a previsão no código do tradicionalíssimo procedimento especial nas ações possessórias de força nova é medida acertada.

Há de se salientar que o código prevê procedimento específico para a tutela jurisdicional da posse. Trata-se de proteção do poder fático sobre a coisa ou *jus possessionis*, não do direito à posse ou *jus possidendi*.¹²⁴ Somente quando houver violação ou ameaça à posse haverá interesse processual na propositura das ações possessórias. Assim, se ocorrer esbulho, turbação ou ameaça, serão cabíveis, respectivamente, as ações de reintegração, manutenção ou o interdito proibitório. Se a inexistência das violações à posse for evidenciada na própria inicial, o juízo, após a oitiva do autor, decretará o indeferimento, por falta de interesse (CPC, art. 330, inc. III). Se a inexistência de vício for constatada após a resposta, o princípio da primazia do mérito (CPC, arts. 4º e 488) impõe o julgamento do *meritum causae*, com a improcedência da demanda. Com efeito, se não houve ameaça, turbação ou esbulho, o pedido possessório é improcedente.

Como a posse é fato, cuja proteção ocorrerá somente quando houver violação, perturbação ou ameaça, costuma-se mencionar que se trata de “meio suporte fático”, já que a posse só entrará no plano jurídico quando com ela concorrer outro fato, ou seja, o esbulho, a turbação ou a ameaça.¹²⁵ Essa ponderação é correta quando se leva em conta os interditos possessórios. Porém, também a usucapião é efeito da posse e nesse caso não é precisa a ideia de “meio suporte fático”.

As ações possessórias são materialmente sumárias, sendo nelas vedada a discussão sobre a propriedade, conforme assentam os arts. 557, par. ún. do CPC¹²⁶ e 1.210, § 2.º do CC.¹²⁷ A sumariedade material, a restringir o *thema decidendum* à posse, subsistirá mesmo quando as ações possessórias não seguirem o procedimento especial em razão do decurso do prazo de ano e dia. Essa posição já contava com a adesão da doutrina sob o código revogado, devendo ser mantida sob

o diploma vigente.¹²⁸

A natureza das ações possessórias é ponto controverso. Nega-se que sejam ações pessoais, pois inexistiria obrigação entre o autor e o réu.¹²⁹ Não seria concebível que o esbulhador, o turbador ou mesmo aquele que ameaça a posse fossem transformados em devedores do autor. Facilmente se vê que as ações possessórias, ecos na contemporaneidade dos célebres interditos romanos, não são ações pessoais. Concluir-se-ia, então, tratar-se de ações reais. Objetar-se, contra essa conclusão, que a posse é fato, cuja proteção só ocorre depois da agressão. Nessa perspectiva, não sendo a posse direito, não seria possível classificar as ações possessórias como ações reais.¹³⁰

Ocorre que se denominam como ações reais aquelas cujo bem da vida seja coisa corpórea, de modo que a concepção das ações possessórias como reais não pressupõe a caracterização da posse como direito real.¹³¹ As ações possessórias abrigam pretensões reais, ou seja, pretensões sobre a coisa, sendo então correto classificá-las como ações reais, embora a posse não seja um direito real.¹³²

Para evitar controvérsias, no art. 73, § 2.º, o CPC prevê que nas ações possessórias só haverá litisconsórcio necessário com o cônjuge do autor ou do réu quando se tratar de composse ou de ato praticado por ambos.¹³³ A existência de regra específica é digna de elogios, pois evita que se tenha de perquirir sobre a natureza das ações possessórias, nos termos do *caput* do art. 73, para se definir as hipóteses de litisconsórcio necessário.

11. Autotutela na posse

No art. 1.210, § 1.º, do CC/2002, abre-se notável exceção ao monopólio estatal da justiça.¹³⁴ O dispositivo, reproduzindo conteúdo do art. 502, parágrafo único, do CC/1916, autoriza o possuidor turbado ou esbulhado a se manter ou a se reintegrar na posse, desde que sua reação ocorra durante os atos de agressão ou logo depois.

Duas são as hipóteses de autotutela da posse: a legítima defesa e o desforço incontinenti.¹³⁵ No primeiro caso a reação do possuidor ocorre durante o ato de agressão. No segundo, logo depois da perda da posse, disciplinada nos arts. 1.223 e 1.224 do CC/2002. Pontes de Miranda, ao analisar o art. 502, *caput* e parágrafo único, do CC/1916, assinalava que na primeira parte – equivalente à primeira parte do art. 1.210, § 1.º do código vigente – o dispositivo previa a legítima defesa, prevendo o desforço incontinenti a partir do advérbio “contanto”.¹³⁶ A lição é correta e se aplica plenamente ao dispositivo vigente, que reproduz aquilo que o Código Beviláqua já dispunha sobre o tema.

A possibilidade de legítima defesa ou de desforço pelo possuidor indireto é questão interessantíssima. Poder-se-ia supor que por não exercer a posse imediata da coisa o possuidor indireto não pudesse praticar nem a legítima defesa, nem o desforço incontinenti. Todavia, na defesa que fez sobre o cabimento da autotutela possessória pelo possuidor indireto, Pontes de Miranda enfatizou que o art. 502, parágrafo único, do CC/1916 – art. 1.210, § 1.º, do CC/2002 – não distinguia entre possuidor direto e indireto, sendo certo, ademais, que o art. 486 do Código Beviláqua – art. 1.197 do CC/2002 – assinalava que a posse direta não excluía a indireta.¹³⁷ Em conclusão, como aponta o jurista, podem exercer a autotutela da posse o fâmulos, o possuidor direto, o representante legal e o possuidor indireto.¹³⁸

Antônio Joaquim Ribas se referia a antigo costume indicado pelos praxistas portugueses, de acordo com o qual o legítimo possuidor poderia procurar auxílio nas autoridades para realizar o desforço. A possibilidade era criticada pelo Conselheiro, ao argumento de que não havia previsão legal para que as autoridades viessem em socorro daquele que alegava violação à posse.¹³⁹ Pontes de Miranda sustentava que esse entendimento estava incorreto já à época do Conselheiro Ribas.¹⁴⁰

É certo que, atualmente, aquele que sofre agressão em sua posse pode se socorrer das autoridades policiais para lhe auxiliarem na legítima defesa. Também poderá fazê-lo para que as autoridades lhe auxiliem no desforço. O fundamental é que a legítima defesa seja simultânea ao

ato de agressão e o desforço ocorra logo depois da perda da posse. Obviamente se está perante cláusula aberta, que deverá ser examinada caso a caso. Dúvida não há, porém, quanto à possibilidade de o desforço ser realizado a partir do momento em que o esbulhado tem consciência da perda da posse.¹⁴¹ Trata-se de aplicação do art. 1.224 do CC/2002, de acordo com o qual aquele que não presenciou o esbulho só perderá a posse quando, ciente do ato espoliativo, deixar de tentar retornar à coisa ou for violentamente repellido tentando recuperá-la. Não estará desatendido o aspecto temporal previsto no artigo se o legítimo possuidor precisar procurar auxílio para o desforço.¹⁴²

Qualquer que seja o caso, para que a legítima defesa ou o desforço sejam tolerados pelo direito, deverá o legítimo possuidor empregar força que seja suficiente apenas para garantir a manutenção ou a restituição à posse. É o que consta na segunda parte do art. 1.210, § 2.º do CC. É óbvio que o excesso deve ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e será punível na forma da lei.

12. Ações de imissão de posse e embargos de terceiro

As ações possessórias, reitere-se, limitam-se à tutela da posse. O direito à posse, ou *jus possidendi*, não será objeto dos interditos. Sua proteção ocorrerá por meio da ação de imissão de posse. O Código de Processo Civil de 1939 previa para ela procedimento especial, nos arts. 381 a 383. Como não houve previsão específica no Código de 1973, discutiu-se sobre a permanência da ação. A questão foi superada na doutrina, reconhecendo-se a continuidade da ação de imissão de posse. A omissão do legislador processual não poderia extirpar uma pretensão no plano material. Em outras palavras, a ação de imissão de posse continuou a existir como pretensão, apesar da falta de previsão específica no código de processo.¹⁴³

Essa conclusão, válida para o Código de 1973, é igualmente aplicável ao código vigente. Há interesse processual na ação de imissão de posse quando o objeto do processo for o direito à posse, sendo a demanda proposta com o objetivo de efetivar a posse daquele que a ela tem direito, mas ainda não a exerceu.¹⁴⁴ É por jamais ter existido o poder fático sobre a coisa que as ações possessórias não podem ser ajuizadas pelo autor da imissão de posse.

Será instruída a petição inicial com prova documental apta a comprovar o direito à posse, limitando-se a controvérsia a esse tema. Trata-se, portanto, de ação sumária, sendo nela proibida a discussão sobre qualquer outra questão que não seja o direito à posse.¹⁴⁵ Estará vedada inclusive a discussão sobre a propriedade. Temas como a validade do contrato e o domínio deverão ser analisados em demanda posterior.¹⁴⁶

A proibição de discussão sobre a propriedade é relevante para que não se confundam as ações reivindicatórias com as ações de imissão de posse. Nas reivindicatórias o domínio é invocado como causa de pedir, tornando-se necessariamente questão jurídica a ser apreciada, o que não ocorre nas ações de imissão, em que o direito à posse pode se originar de lei ou contrato, sem que o autor seja proprietário.¹⁴⁷ Admite-se, todavia, nas ocasiões em que o autor for proprietário não possuidor, a possibilidade de propositura tanto da ação de imissão de posse, quanto da ação reivindicatória. Contudo, se propuser esta demanda em vez daquela, haverá discussão sobre a propriedade, tema que não integra o objeto das ações de imissão de posse.¹⁴⁸

Em conformidade com os arts. 300 e ss. do CPC o autor poderá obter liminar de imissão na posse se comprovar a urgência. A liminar eventualmente deferida poderá se estabilizar nos termos do art. 304.¹⁴⁹

Convém enfatizar que a ação de imissão de posse terá como objeto o direito à posse, *jus possidendi*, sendo inservível para a proteção da posse entendida como poder fático sobre a coisa. A proteção da posse, reitere-se, será objeto das ações possessórias. A exceção à regra, como indicado alhures, é a transmissão de posse que tenha ocorrido mediante constituto possessório, a outorgar a possibilidade de ajuizamento dos interditos possessórios (vide item 7).

No art. 674 o CPC indica o cabimento de embargos de terceiro quando houver constrição ou ameaça de constrição sobre bens que o terceiro possua ou sobre os quais exerça direito incompatível com o ato constitutivo. O *caput* do dispositivo emprega a locução “sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua”, e seu parágrafo primeiro se refere expressamente ao terceiro possuidor.¹⁵⁰ São nítidas, portanto, as referências à posse.

A despeito disso, os embargos de terceiro não podem ser considerados uma ação possessória típica, pois se voltam contra o ato judicial, não contra a violação da posse. É possível que os embargos de terceiro sejam promovidos por quem não exerça a posse sobre o bem. Ademais, o desforço previsto no art. 1.210, § 1.º do CC/2002 é inconcebível nos embargos de terceiro.¹⁵¹ Essas peculiaridades impedem a caracterização dessa ação incidental como um interdito possessório.

A rápida abordagem da ação de imissão de posse e dos embargos de terceiro apenas comprova que há somente três ações possessórias típicas, quais sejam, a de reintegração, a de manutenção e o interdito proibitório, respectivamente voltadas contra o esbulho, a turbacão e a ameaça à posse.

Seção I Disposições gerais

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1.º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2.º Para fim da citação pessoal prevista no § 1.º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.

§ 3.º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1.º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

1. Ações possessórias e fungibilidade

Tecnicamente não se confundem as “ações” com as “demandas”. A “ação” é o direito subjetivo público, uno e abstrato, outorgado a todos os cidadãos no art. 5.º, XXXV da Constituição, por meio do qual podem postular tutela jurisdicional perante o Poder Judiciário. O direito constitucional de ação é exercido por meio do ato processual com o qual se requer a tutela jurisdicional, instaurando o processo e apresentando ao juiz a pretensão, qualificada pela causa de pedir, por meio da qual será delimitado o objeto litigioso. A este ato se dá o nome de demanda.¹⁵² Ao longo dos comentários, porém, poderá ser empregado o vocábulo técnico “ação” no lugar de “demanda”, a fim de evitar a repetição de palavras em uma mesma frase. Há de se atentar, contudo, para a diferença conceitual entre os institutos.

De acordo com a violação à posse haverá interesse processual na propositura de uma demanda possessória específica. Assim, havendo mera ameaça, a ação pertinente é o interdito proibitório. Tratando-se de turbacão, cabe a propositura de demanda de manutenção. Caso tenha ocorrido esbulho, caracterizado pela perda da posse, deve o autor propor ação de reintegração.

O art. 554, *caput*, prevê a fungibilidade entre as ações possessórias¹⁵³. Trata-se de reprodução do art. 920 do CPC/1973, com a irrelevante diferença da retirada de uma vírgula inadequadamente aplicada no dispositivo revogado. Isso significa que o autor poderá postular manutenção e obter reintegração, bastando para tanto que fique comprovada a perda da posse. O oposto é verdadeiro. Pleiteando reintegração, poderá ser mantido na posse se inexistir esbulho, mas mera turbacão. Há fungibilidade entre os pedidos e, conseqüentemente, entre as tutelas jurisdicionais. O pedido imediato do autor é a prolatação de provimento jurisdicional. O pedido mediato é posse do bem ou

a inibição de ameaça à posse.¹⁵⁴

A fungibilidade é aplicável também ao interdito proibitório. Para se chegar a essa conclusão basta perceber que o art. 554 integra as disposições gerais do capítulo das ações possessórias. Sob o código revogado a doutrina se posicionava majoritariamente nesse sentido.¹⁵⁵

Não é relevante a razão que leva à concessão de pedido diverso do que fora apresentado pelo autor. Poderá ter ocorrido equívoco na interpretação dos fatos constitutivos, caracterizando o autor como esbulho a agressão que consistia em turbação. Mas também é possível que a agressão original se intensifique, passando da ameaça ao esbulho. Tanto em um caso, quanto em outro, o juiz concederá a tutela jurisdicional adequada para repelir a ofensa à posse.

Discute-se se a fungibilidade entre as ações possessórias caracteriza exceção à regra da vinculação do juiz ao pedido do autor, prevista no art. 141 do CPC.¹⁵⁶ Em favor da ideia de que não haveria propriamente exceção, argumenta-se que o autor pleiteia proteção possessória contra a agressão, qualquer que seja a ofensa à posse, de modo que existiria apenas *uma* ação possessória.¹⁵⁷

Crê-se, contudo, que há exceção à regra da adstrição ao pedido. São três as ações possessórias típicas. Quando o autor postula reintegração, mas o juiz lhe concede manutenção, está concedendo tutela jurisdicional diferente da que fora postulada, embora seja suficiente para evitar a violação à posse. O mesmo ocorreria se fosse pleiteada a manutenção e o juiz deferisse a reintegração, constatando, com base nas provas, que houve perda da posse. É necessário reconhecer que para cada violação há uma ação típica, determinada pelo pedido, razão pela qual, concedido outro pedido, caracteriza-se exceção à regra da vinculação.

A fungibilidade não se restringe às liminares possessórias. Abrange inclusive as demandas propostas depois de ano e dia da agressão, em que o procedimento será comum, nos termos do art. 558, parágrafo único do CPC/2015.

Em regra, quando qualificar os fatos constitutivos diferentemente do que fizera o autor, terá o juiz de ouvir previamente as partes sobre a possibilidade de qualificação diversa, nos termos do art. 10 do CPC.¹⁵⁸ Todavia, quer se trate de procedimento especial, restrito às ações propostas com prazo igual ou inferior a ano e dia, quer se trate de procedimento comum, não precisará o juiz ouvir previamente as partes para conceder prestação jurisdicional possessória diferente da que fora postulada. O art. 554 lhe permite conceder prestação jurisdicional diversa, de modo que inexistirá surpresa capaz de prejudicar as partes. Como o sistema de proteção da posse excepciona expressamente a adstrição do juiz ao pedido, não é necessária nem razoável a prévia intimação das partes sobre a possibilidade de qualificação do fato constitutivo de forma diversa, da qual decorrerá concessão de prestação jurisdicional diferente da postulada.

A fungibilidade se aplica apenas às ações possessórias típicas. Estão excluídas as ações de imissão de posse, reivindicatórias e os embargos de terceiro. Enfim, apenas no âmbito dos três interditos possessórios o juiz não estará vinculado ao que foi postulado. Se for proposta demanda de reintegração de posse, não poderá o juiz convertê-la em ação de imissão se verificar que não há *jus possessionis*, mas direito à posse. Nesse caso, assim como em outros correlatos, deve ser reconhecida a carência da ação.

2. *Litisconsórcio passivo multitudinário*

Caracteriza-se o litisconsórcio passivo multitudinário quando houver grande número de réus nas ações possessórias. O art. 554, § 1.º, vale-se de conceito aberto, externado na expressão “grande número de pessoas”, aplicando-se quando houver algumas dezenas ou mesmo muitas centenas de réus.

Na vigência do código revogado já se recomendava que na hipótese de litisconsórcio passivo multitudinário o autor deveria apontar a existência de pluralidade de réus na inicial, trazendo

informações que permitissem a citação daqueles que liderassem a invasão, bem como dos que se encontrassem na área sob litígio, desde que possível sua identificação.¹⁵⁹

O art. 554, § 1.º não se afasta dessa orientação, preconizando a citação daqueles que estiverem no local, denominados de “ocupantes”, bem como a citação por edital dos demais, ou seja, daqueles que foram qualificados na petição inicial, mas não foram encontrados. Caberá ao oficial de justiça identificar todas as pessoas que forem encontradas no local e então citá-las. Não importa que não tenham sido arroladas na exordial, pois o autor não tem como individualizá-las. Evidentemente não haverá nulidade processual se nem todos os invasores forem citados. Sabe-se que nas áreas em litígio coletivo pela posse há enorme oscilação no número de ocupantes, o que evidentemente inviabiliza a citação de todos.

Impõe-se sempre a intimação do Ministério Público, o que decorre também do art. 178, III, do CPC.¹⁶⁰ Não parece correto o entendimento de que se houver identificação de todos os réus não será necessária a intimação do *Parquet*.¹⁶¹ A participação do Ministério Público no processo tem como fundamento a relevância dos conflitos coletivos por terra. Com a atuação do órgão ministerial pretende-se que sejam adotadas medidas para evitar a violência ou conter sua escalada. A participação não se baseia, portanto, em razões estritamente processuais, mas fundamentalmente sociais.

Caso o oficial de justiça identifique hipossuficientes na área conflagrada, será necessária a intimação da Defensoria Pública. Compreende-se por hipossuficiente aquele que não dispuser de recursos econômicos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 98 do CPC/2015.¹⁶² A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.¹⁶³ A intimação a que alude o dispositivo deverá ocorrer depois da realização do ato citatório, pois somente nesse momento terá sido constatada a existência de hipossuficientes.

Nos termos do art. 72, II do CPC, caberá à Defensoria Pública não apenas defender os hipossuficientes, mas também os réus revéis citados por edital ou com hora certa até que seja constituído advogado.¹⁶⁴ Assegura-se à Defensoria Pública o prazo em dobro para todas as manifestações processuais.¹⁶⁵

Para facilitar a implementação do ato citatório, no art. 554, § 2.º, é mencionado que o oficial de justiça procurará os ocupantes por uma vez, citando por edital os que não forem encontrados. Trata-se, aqui, dos invasores que tiverem sido identificados na petição inicial. Obviamente não poderia ocorrer citação por edital de ocupantes não identificados na exordial que estivessem ausentes no momento de realização da diligência.

No parágrafo terceiro do dispositivo em comento é imposto ao juiz o dever de dar ampla publicidade à demanda, o que pode ocorrer, dentre outros meios, por anúncios em jornais locais e estações de rádio, bem como mediante inserção de cartazes na região conflituosa. A expressão “outros meios” é suficiente para que se perceba o caráter aberto do rol indicado no artigo. Assim, poderá o juiz determinar a divulgação da demanda em redes sociais, *sites* e blogs, bem como em entidades da sociedade civil organizada. O objetivo é permitir que o maior número possível de pessoas esteja ciente da demanda e possa, se for o caso, defender seus interesses em juízo.

Nota-se, por fim, a inexistência de relação entre o objeto do *caput* e seus parágrafos. Haveria maior rigor sistemático se os parágrafos originassem dispositivos autônomos, cuja inserção deveria ocorrer após o art. 565, no qual são regulados os litígios coletivos pela posse.

Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:

I - condenação em perdas e danos; II - indenização dos frutos.

Parágrafo único. Pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para:

- I - evitar nova turbacão ou esbulho;
- II - cumprir-se a tutela provisória ou final.

1. Cumulação de pedidos

O procedimento das ações possessórias é projetado para permitir rápida resposta jurisdicional contra a agressão à posse. É para o alcance dessa finalidade que foi concebida a audiência justificatória e prevista a possibilidade de concessão de liminares, sem que seja necessário averiguar a urgência no caso concreto, desde que a demanda seja proposta em até um ano e um dia da agressão. Nisso consiste a especialidade das ações possessórias.

Quando o pedido do autor se fundar no poder fático que pode exercer sobre a coisa, não em direito à posse, ser-lhe-ão abertas as portas dos interditos possessórios. No dispositivo em análise o código permite que o autor realize cumulação de pedidos sem ter de abrir mão do procedimento especial. Isso não significa que o possuidor esteja impedido de efetuar outras cumulações. Para fazê-lo bastará atender aos requisitos do art. 327, § 1.º do CPC, I a III.¹⁶⁶ Assim, desde que os pedidos não sejam incompatíveis entre si, o mesmo juízo tenha competência para conhecê-los e o procedimento seja adequado para todos, poderá ser realizada a cumulação.

Ocorre que para as ações possessórias é previsto procedimento especial. Que acontecerá se o autor cumular ao pedido de reintegração, manutenção ou ao interdito proibitório, pretensão não indicada no art. 555 do CPC?

À luz do código anterior, admitia-se a possibilidade de o autor cumular outras pretensões aos pedidos possessórios, além daquelas expressamente elencadas no código, advertindo, contudo, que isso ensejaria a perda da especialidade do procedimento.¹⁶⁷ Dito de outro modo, estava vedada a obtenção de liminar exclusivamente fundamentada nos requisitos das ações possessórias. Para obter a antecipação dos efeitos da tutela caberia, então, ao autor demonstrar a urgência e a verossimilhança, nos termos do art. 273 do CPC/1973.

Em resumo, sob o código anterior a cumulação de pedidos não contemplados expressamente no art. 921, levava à impossibilidade de obtenção da liminar típica das ações possessórias.

O tema merece especial atenção, pois no art. 327, § 2.º do código vigente, prevê-se expressamente a possibilidade de cumulação de outros pedidos, bastando para tanto que seja adotado o procedimento comum, *sem que haja prejuízo à aplicação das técnicas processuais diferenciadas que não forem incompatíveis com o procedimento comum*.¹⁶⁸

Isso significa que poderá ser deferida liminar para proteção da posse, mas terão de ser atendidos os requisitos dos arts. 300 e ss. do CPC/2015, incumbindo ao autor o ônus de comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano à luz do caso concreto. Em outras palavras, não lhe bastará indicar que a agressão à posse ocorreu em prazo igual ou inferior a ano e dia, tal como ocorre nas ações tipicamente possessórias.

O art. 555 seria inútil caso se entendesse pela possibilidade de cumulação de quaisquer outros pedidos às pretensões possessórias, mantendo-se a possibilidade de deferimento de liminar com fundamento na violação da posse em prazo igual ou inferior a ano e dia. Com efeito, se qualquer pedido pudesse ser cumulado sem inviabilização do procedimento especial, não haveria sentido em discriminar as hipóteses em que a cumulação é aceita.

Destarte, para utilizar o procedimento especial das ações possessórias, fundamentando-se na alegação de violação à posse datada de prazo igual ou inferior a ano e dia, deverá o autor se limitar à cumulação dos pedidos expressamente apontados no art. 555. Poder-se-ia criticar esse posicionamento alegando que não há incompatibilidade da liminar proferida nas ações possessórias com o procedimento comum, haja vista a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela. Ou seja, se pode ser antecipada tutela possessória com fundamento nos arts. 300 e ss. do CPC/2015, por que haveria incompatibilidade?

Reitere-se que o fundamento para a propositura de ações possessórias típicas pelo procedimento especial é a violação da posse por prazo igual ou inferior a ano e dia. Se o autor quiser empregar procedimento projetado especificamente para as ações possessórias, não poderá cumular aos pedidos possessórios outros que não os indicados no art. 555. Se o fizer, embora lhe sejam fechadas as portas do procedimento especial de reintegração de posse, poderá obter a tutela possessória mediante medida liminar que antecipe os efeitos da tutela, desde que cumpridos os requisitos dos arts. 300 e ss. do CPC/2015.

A desvantagem do autor consiste na impossibilidade de invocar apenas a violação da posse por prazo igual ou inferior a ano e dia para obter medida liminar que satisfaça seus interesses. Cumulando pedidos não indicados no art. 555, terá de demonstrar a existência de perigo de dano e probabilidade do direito no caso concreto.

2. Condenação em perdas e danos e indenização dos frutos

O CPC autoriza, no art. 555, I, que ao pedido possessório seja cumulada a condenação em perdas e danos, prevendo no inc. II, de forma dispensável, que à pretensão possessória seja cumulada a indenização dos frutos. Diz-se dispensável porque a indenização prevista no segundo inciso está abrangida no primeiro, pois nos termos do art. 402 do CC/2002¹⁶⁹ as perdas e danos compreendem não apenas o que foi perdido, mas o que se deixou de lucrar.¹⁷⁰ Assim, bastaria ao CPC aludir às perdas e danos, sendo supérfluo o inc. II do art. 555.

Deverá ser indenizada não apenas a privação da posse, mas igualmente os prejuízos decorrentes da agressão.¹⁷¹ Danos que não estejam correlacionados à agressão ou à ameaça à posse não poderão ser cumulados aos pedidos possessórios.¹⁷²

Para a delimitação do alcance da condenação em perdas e danos é necessário considerar o disposto no Código Civil sobre a responsabilidade por perda ou deterioração da coisa. Conforme o art. 1.217, o possuidor de boa-fé não será responsabilizado quando não der causa ao dano.¹⁷³ O art. 1.218, por sua vez, assinala que o possuidor de má-fé responderá pela perda ou deterioração da coisa mesmo quando sejam acidentais, a não ser que consiga provar que o dano ocorreria ainda que a coisa estivesse com o legítimo possuidor.¹⁷⁴

O regime de indenização decorrente de violação ou ameaça à posse difere da regra geral contida no art. 402 do CC/2002, conforme salientava a doutrina à luz do código anterior.¹⁷⁵ Como visto alhures (vide item 2.3 da introdução a estes comentários sobre as ações possessórias), segundo o art. 1.216 do CC/2002, o possuidor de má-fé responde pelos frutos que deixou de colher por sua culpa. O código desconsidera o que poderia ter colhido o legítimo possuidor, fixando como parâmetro para a indenização aquilo que o agressor deixou culposamente de retirar. A regra contida no art. 1.216 é especial em relação à do art. 402, de modo que para a fixação da indenização não será considerada a capacidade do legítimo possuidor, como determina o art. 402, mas a do possuidor de má-fé que deixou culposamente de colher os frutos, conforme assenta o art. 1.216.

3. Atipicidade dos meios executivos e efetivação do provimento jurisdicional concessivo da reparação em perdas e danos pelo equivalente pecuniário

O CPC menciona que ao autor é lícito cumular ao pedido possessório a *condenação em perdas e danos*. A interpretação literal do dispositivo levaria à conclusão de que no capítulo referente à indenização o juiz sempre proferiria sentença condenatória, cuja implementação se daria por cumprimento, nos termos dos arts. 513, § 1.º e 515, I do CPC. Ficaria reservada, para o capítulo da sentença atinente à reparação, a técnica da execução por sub-rogação. Não se crê, contudo, que seja assim.

Ocorre que o art. 139, IV do CPC, autoriza o juiz, no cumprimento de ordem judicial, a empregar técnicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, *inclusive nas ações que*

tenham por objeto prestação pecuniária. ¹⁷⁶ Está prevista, portanto, a atipicidade das técnicas executivas, de modo que o juiz não está adstrito à condenação seguida de execução por sub-rogação. ¹⁷⁷

Isso significa que para o ressarcimento da violação ou ameaça à posse o juiz poderá empregar mecanismos coercitivos ou sub-rogatórios no lugar da sentença de condenação. Só haverá condenação quando ao provimento se seguir o cumprimento baseado em sentença provisória ou definitiva (CPC, arts. 520 e 523), o que dependerá da vontade do autor ou da inidoneidade, no caso concreto, de outras técnicas que não a execução voltada à expropriação do patrimônio do agressor.

Desse modo, a não ser que o autor postule o cumprimento de sentença ou este seja o meio mais idôneo quando ponderados o direito à tutela jurisdicional efetiva e o princípio da menor onerosidade da execução, poderá o juiz aplicar técnicas coercitivas ou sub-rogatórias que assegurem a satisfação do direito à indenização. A tutela jurisdicional a ser concedida pelo juiz não se limita à técnica de condenação, ressalvada a hipótese em que ela seja requerida pelo autor que sofrera as lesões ou quando as especificidades do caso inviabilizarem qualquer outra técnica além da execução por sub-rogação.

A possibilidade de utilização de outros meios executivos se torna ainda mais nítida quando se nota que o capítulo de sentença voltado à proteção possessória não exige a deflagração de cumprimento nos moldes dos arts. 520 e 523. Com efeito, tratando-se de reintegração de posse, de manutenção ou de interdito proibitório, não há necessidade de se deflagrar o cumprimento de sentença por execução, pois se trata, respectivamente, de provimentos executivos e mandamentais, os quais dispensam a fase processual voltada ao cumprimento. ¹⁷⁸

O parágrafo único, inc. II do art. 555, corrobora o posicionamento aqui adotado. Perceba-se que o dispositivo alude à *imposição de medida necessária e adequada para que seja cumprida a tutela provisória ou final*. A expressão *tutela final* abrange o provimento relacionado com as perdas e danos. Ora, ao conceder ao legítimo possuidor o direito de pleitear medidas que garantam o cumprimento da tutela final, inclusive a ressarcitória, o código expressamente autoriza que na efetivação do capítulo sentencial referente à tutela reparatória o juiz se utilize de outras técnicas que não exclusiva e obrigatoriamente o cumprimento de sentença por execução, cujo objetivo é a expropriação de bens do condenado.

A perspectiva da atipicidade, ademais, relaciona-se com a ideia de que não basta ao juiz proferir provimento declaratório, impondo-se efetivamente tutelar o direito, o que significa se utilizar das técnicas necessárias para tanto. ¹⁷⁹ Essa é a ideia subjacente ao art. 4.º do CPC, que estabelece o direito à tutela em prazo razoável. ¹⁸⁰ O dispositivo abriga, implicitamente, a ideia de que a mera declaração de direitos é insuficiente para tutelá-los, salvo no tocante às hipóteses de incerteza sobre a existência de uma relação jurídica.

4. Tutela ressarcitória específica

O art. 555 se refere à indenização por perdas e danos. No item anterior, demonstrou-se que a tutela ressarcitória pelo equivalente poderá ser implementada por meio de outras técnicas que não o cumprimento de sentença por execução. Mas além da tutela ressarcitória pelo equivalente, evidentemente poderá o juiz conceder tutela ressarcitória específica, caracterizada como a forma de tutela ideal, pois concede àquele que foi lesado a exata restituição ao estado anterior à lesão. ¹⁸¹ Para tanto, poderá o juiz conjugar o art. 555, I e II, com o art. 536, § 1.º, todos do CPC, a fim de impor ao agressor a restituição ao estado anterior.

Suponha-se que na efetivação do esbulho tenha sido destruído um muro e as cercas divisórias entre as diversas plantações cultivadas pelo legítimo possuidor. Se houver tutela ressarcitória pelo equivalente o esbulhador entregará ao legítimo possuidor o equivalente pecuniário dos bens que danificou. Solução superior seria a determinação de que o muro e as cercas divisórias fossem reconstruídas pelo invasor, hipótese de tutela específica. Para isso o juiz poderá se utilizar de

meios coercitivos ou sub-rogatórios.

Haverá tutela ressarcitória específica mesmo que os consertos sejam realizados por terceiros às expensas do invasor, pois a incapacidade técnica deste para a restituição ao estado anterior não pode inviabilizar a tutela específica.¹⁸² A prática demonstra que corriqueiramente a tutela específica exigirá a atuação de terceiros, sem que com isso se perca o caráter específico.

Passados muitos anos da introdução de técnicas destinadas à obtenção da tutela específica no art. 84 do CDC e nos arts. 461 e 461 – A do código processual anterior, é surpreendente que se encontre resistência à tutela ressarcitória específica. A perplexidade é tanto maior quando se percebe que sequer seria necessária a previsão de dispositivos infraconstitucionais sobre o tema, já que a tutela específica é corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.¹⁸³

Só não haverá tutela ressarcitória específica se o lesado assim preferir ou se dela decorrer excessiva onerosidade.¹⁸⁴ Ademais, poderá se mostrar insuficiente a tutela específica, de modo que a completa reparação exigiria complemento mediante tutela pelo equivalente, tal como ocorreria na hipótese de derrubada de árvores.¹⁸⁵ O legítimo possuidor poderia requerer o replantio, mas isso não seria suficiente para reparar seus prejuízos, de modo que lhe seria lícito postular a complementação do ressarcimento mediante tutela pelo equivalente.

O ponto essencial sobre o tema consiste na percepção de que não apenas o legítimo possuidor não está adstrito ao cumprimento de sentença por execução na hipótese de tutela ressarcitória pelo equivalente, como visto no item anterior, como também sequer a tutela pelo equivalente é a forma de ressarcimento prioritária. Sendo desejo do legítimo possuidor e inexistindo excessiva onerosidade, a tutela deverá ocorrer na forma específica.

5. Medidas destinadas a evitar nova turbção ou esbulho e a efetivação da tutela provisória ou final

No art. 555, par. ún., I e II, indica-se a possibilidade de cumulação dos pedidos possessórios com medidas destinadas a evitar nova turbção ou esbulho e a efetivar a tutela possessória provisória ou final. Percebe-se de plano o caráter aberto dos dispositivos, de modo que será permitida qualquer medida, seja para inibir nova turbção ou esbulho, seja para efetivar a tutela jurisdicional da posse, quer ela seja liminar e provisória, quer ela seja definitiva.

No código anterior era prevista a cominação de pena para a hipótese de nova turbção ou esbulho (art. 921, II) e o desfazimento de construções ou plantações feitas em prejuízo da posse do legítimo possuidor (art. 921, III). O cotejo com o código revogado realça a amplitude dos dispositivos ora em comento. Sob o código vigente, *além* da multa pecuniária, poderão ser requeridas e deferidas quaisquer medidas capazes de inibir nova agressão à posse e de efetivar a tutela jurisdicional possessória, sendo possível conjugar o dispositivo em comento com o art. 536, § 1.º, também do CPC. Assim, exemplificativamente, poderá ser deferida a busca e apreensão de equipamentos e instrumentos usados na invasão, a remoção de pessoas ou coisas, bem como o desfazimento de plantações e construções.¹⁸⁶

Caso sejam desfeitas construções e plantações, deverá ser atendido o disposto no art. 1.214, par. ún. do CC/2002, sendo o possuidor de boa-fé indenizado pelas despesas com produção e custeio, embora deva restituir os frutos colhidos com antecipação, assim como aqueles pendentes à época em que cessar a boa-fé, o que normalmente ocorrerá com a citação.

A sentença de reintegração de posse decreta a ilicitude das plantações e obras eventualmente construídas pelo agressor, de modo que o órgão jurisdicional pode determinar sua remoção por terceiros ou pode autorizar o legítimo possuidor, agora reintegrado, a fazê-lo. Será desarrazoado, contudo, *condenar* o réu a realizar a remoção. Como adverte a doutrina, para que sejam removidas construções ou plantações, basta que sejam implementados atos executivos, sendo de todo inadequado aguardar que o réu *cumpra a prestação* para a qual foi condenado.¹⁸⁷

O desfazimento de construções ou plantações pode ser determinado por liminar possessória. Note-se que o art. 555, par. ún., II, menciona a possibilidade de aplicação de medidas necessárias e adequadas para o *cumprimento da tutela provisória* da posse. Desse modo, tendo sido deferida liminar de reintegração de posse, fica nítido o caráter ilícito das plantações e construções eventualmente realizadas pelo agressor. Para efetivar a medida liminar, o desfazimento dessas construções e plantações poderá ser deferido. Há, contudo, responsabilidade objetiva do autor da ação de reintegração, o qual terá de ressarcir todos os prejuízos causados ao réu caso a liminar seja ao final revertida.

6. Cumulação de pedidos e possibilidade de julgamento antecipado parcial

A cumulação de pedidos permitida pelo art. 555 do CPC é sucessiva. Caracteriza-se pela relação de prejudicialidade entre as pretensões, sendo julgado o pedido subsequente apenas caso o antecedente seja acolhido, estando ambos correlacionados em razão da conexidade originária da causa de pedir.¹⁸⁸ O código disciplina a cumulação sucessiva no art. 327.¹⁸⁹

É fácil compreender a relação de prejudicialidade entre as pretensões. Só será julgado procedente o pedido de ressarcimento se antes tiver sido judicialmente reconhecida a agressão à posse. Sem o provimento da pretensão possessória, não pode ser acolhido, nem mesmo apreciado, o pedido de ressarcimento. O reconhecimento de agressão à posse é, portanto, prejudicial à tutela ressarcitória, pois só haverá direito ao ressarcimento se tiver ocorrido a agressão à posse.

Questiona-se se seria possível a cumulação da tutela ressarcitória com o pedido de inibição do interdito proibitório, já que nesta ação possessória não há ato concreto de agressão, mas mera ameaça à posse.¹⁹⁰ A cumulação deve ser admitida. Não é difícil imaginar hipótese de prejuízos causados pela ameaça não consumada. Suponha-se que diante do cerco do imóvel o possuidor o abandone, deixando de zelar por seu rebanho. Se na sua ausência parte do rebanho vier a se perder, aquele que ameaçou a posse será responsabilizado. O mesmo ocorreria se na fuga do legítimo possuidor, motivada por ameaça, fosse perdido o momento adequado para o plantio da safra. As perdas teriam de ser ressarcidas por quem houvesse realizado a intimidação.

Indicada a relação de prejudicialidade entre o pedido possessório e o ressarcitório, cabe analisar se será possível o julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos dos arts. 355¹⁹¹ e 356¹⁹² do CPC.¹⁹³

A primeira das hipóteses de julgamento antecipado parcial diz respeito ao pedido incontroverso (art. 356, I) e se caracterizará quando o réu não impugnar o fato constitutivo do direito do autor. Suponha-se que o réu não se contraponha à alegação de posse do autor, deixando igualmente de contrastar a alegação de esbulho, manifestando-se contrariamente apenas em relação à alegação e ao pedido de perdas e danos. Nesse caso, a posse do autor e o esbulho serão fatos incontroversos e essa incontrovérsia permitirá que seja julgado antecipadamente o pedido de reintegração de posse.

Em regra, o fracionamento do mérito ocorrerá quando o pedido de reintegração ou de manutenção na posse for cumulado com o de ressarcimento por perdas e danos (CPC, art. 555). Mas é possível imaginar o julgamento antecipado parcial mesmo quando haja somente pedido possessório. Imagine-se que uma empresa reflorestadora promova a remoção de cercas, o desbaste de pinheiros e a instalação de uma central de operações, na suposição de que toda a área esteja sob sua posse. O vizinho propõe ação de reintegração tendo como objeto a totalidade da área ocupada. Citada, a empresa percebe seu equívoco e deixa de impugnar o pedido em relação a uma parte do imóvel, alegando, todavia, a legitimidade de sua posse quanto ao restante. O juiz deverá julgar antecipada e parcialmente o mérito, reintegrando o autor na fração incontroversa.

Na mesma hipótese é possível que já tenha sido proferida liminar possessória sobre a totalidade do imóvel. A decisão interlocutória exarada com fundamento no art. 356, I, substituirá a liminar no tocante à fração incontroversa, ou seja, à área que a empresa ré reconhece ter esbulhado. Trata-se de decisão definitiva, submetida aos efeitos da coisa julgada (CPC/2015, art.

503), contra a qual cabe o recurso de agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015, II). Em relação à parte controversa a liminar prevalecerá. Nos comentários ao art. 563 será analisada a possibilidade de revogação da liminar possessória quando houver modificação do contexto fático-probatório.

A segunda hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito decorre da desnecessidade de produção de outras provas sobre determinado pedido e resulta da aplicação conjugada do art. 356 com o art. 355, I do CPC/2015. Pode-se imaginar que em uma ação de reintegração de posse cumulada com pedido ressarcitório, o autor obtenha a liminar sem a oitiva do réu. É possível que após a resposta do réu, considerados os documentos juntados aos autos, o juiz esteja definitivamente convencido sobre a violação à posse e a necessidade de reintegração, circunstâncias que já ensejaram o deferimento da liminar. Poderá ocorrer o fracionamento do mérito, com o julgamento antecipado do pedido de reintegração. Nessa hipótese a instrução será realizada para que haja decisão sobre o pedido de tutela ressarcitória. O pedido de reintegração de posse terá sido decidido e, se não for interposto agravo de instrumento, haverá formação de coisa julgada (CPC, art. 503).

Também será possível o julgamento antecipado de parcela do pedido quando houver revelia, presumir-se a veracidade das alegações fáticas nos termos do art. 344 e o réu deixar de requerer a produção de provas, conforme resulta da aplicação combinada do art. 356, II, com o art. 355, II. Reputa-se mais difícil a ocorrência dessa hipótese, pois em regra a revelia, conjugada com a presunção de veracidade dos fatos invocados pelo autor e com a omissão do revel na indicação dos meios de prova, levará ao julgamento antecipado do mérito, com o encerramento da fase processual cognitiva.

Contudo, pode-se supor que o juiz, diante da revelia e da presunção de veracidade dos fatos concernentes à agressão possessória, esteja convencido sobre a violação à posse, mas ainda pretenda produzir elementos de prova no tocante ao ressarcimento. Nesse caso, nos termos da aplicação conjugada do art. 356, II, com o art. 355, II, ambos do CPC, haverá julgamento antecipado somente de parcela do mérito, prosseguindo o processo para que seja quantificada a extensão dos danos decorrentes da agressão à posse.

Admite-se, portanto, o julgamento antecipado parcial do pedido possessório, prejudicial em relação ao pedido de ressarcimento ou ao pedido de implementação de medidas que evitem nova agressão ou efetivem a tutela concedida. O que jamais poderá acontecer é o julgamento antecipado do pedido prejudicado.¹⁹⁴ Como dito, só haverá direito à tutela ressarcitória se ficar comprovada a ocorrência de danos. Desse modo, se o juiz tiver dúvida quanto à violação da posse, não poderá julgar antecipadamente o pedido de indenização, ainda que o réu não o tenha impugnado especificamente. O mesmo vale para os pedidos concernentes à inibição de novo esbulho ou turbação ou à aplicação de medidas para a efetivação da sentença, pois também eles têm como premissa o acolhimento da pretensão possessória.

Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

1. Ações possessórias e juízos dúplices

Haverá juízo dúplice quando as posições do autor e do réu se confundirem, de modo que a pretensão poderia ser exercida também por quem se encontra no polo passivo da demanda. São exemplos de ações dúplices as ações de divisão e de demarcação de terras, disciplinadas nos arts. 569 e ss. do CPC.

Indaga-se se as ações possessórias seriam realmente ações dúplices, já que as posições entre autor e réu são inconfundíveis. Argumenta-se, em defesa da duplicidade autêntica das ações possessórias, que autor e réu esposam a mesma pretensão, consistente na tutela da posse.¹⁹⁵ Todavia, considerando a necessidade de que o réu formule pedido para que sua posse seja

protegida, pode-se concluir que as ações possessórias não são intrinsecamente dúplices.¹⁹⁶ Com efeito, caso a duplicidade fosse intrínseca, não seria necessário que o réu pleiteasse proteção possessória, pois já teria sua posse tutelada com a improcedência da demanda. Assim, a duplicidade das ações possessórias decorre da escolha do legislador.¹⁹⁷

O artigo em comento permite que o réu formule na própria contestação a sua pretensão possessória ou ressarcitória. Sob o código revogado se tratava de grande vantagem oferecida ao réu das ações possessórias, à medida que a reconvenção deveria ser apresentada em peça autônoma, não podendo ser um capítulo da contestação. À luz do código vigente a vantagem em relação aos réus de outras demandas desaparece, pois o art. 343 permite que o réu reconvenha na própria contestação.¹⁹⁸

A pretensão do réu poderá ser formulada em relação à posse, à tutela ressarcitória, às medidas inibitórias de nova turbacão ou esbulho e também às medidas para efetivação da sentença.¹⁹⁹ Não se admite antecipação de tutela em favor do réu.²⁰⁰ Assim, não será possível cumular pedidos para a efetivação de liminar, na forma do art. 555, parágrafo único, II, do CPC. Em outras palavras, como ao réu não cabe o direito de obter liminar possessória, não haverá interesse processual na formulação de pedidos destinados à efetivação de provimentos liminares.

O motivo para a proibição de tutela liminar em favor do réu é simples. No momento da resposta do réu o procedimento das ações possessórias já perdeu sua especialidade, não sendo possível o deferimento de liminar.²⁰¹ Portanto, a impossibilidade de concessão de liminar em favor do réu decorre da limitação da especialidade do procedimento até a resposta do réu.

Na resposta o réu poderá alegar que o autor ameaça sua posse, requerendo então seja ele inibido de praticar atos de agressão.²⁰² Isso significa que a pretensão possessória do réu não se limita à reintegração ou à manutenção na posse.

2. Interdito proibitório e indenização

O art. 556 prevê que o réu só poderá pleitear indenização, inclusive no aspecto moral, quando for o caso de esbulho ou turbacão praticados pelo autor. A interpretação literal do dispositivo exclui a possibilidade de pretensão ressarcitória formulada contra ato de intimidação praticado pelo autor. Todavia, é possível que da ameaça decorram prejuízos, de modo que a interpretação literal não pode prevalecer, sendo admissível que o réu pleiteie ressarcimento decorrente de ameaça realizada pelo demandante.

Recorre-se novamente ao exemplo do pecuarista que tenha saído de sua posse, sem, no entanto, perdê-la para o autor do ato de intimidação. Se da ausência do réu resultar a perda de animais, será possível responsabilizar o autor que praticou a ameaça. Também haveria responsabilidade caso a ausência do réu possuidor inviabilizasse o plantio da safra na época adequada. Esses exemplos, já formulados alhures, demonstram que da ameaça podem surgir prejuízos, sendo lícito ao réu formular pedido de reparação na sua resposta.

3. Ações possessórias e reconvenção

Optou-se por conceder às ações possessórias caráter dúplice, consistente na possibilidade de formulação de pedido de proteção possessória na própria resposta do réu, que deverá alegar e provar sua posse, requerendo ainda expressamente a proteção possessória.²⁰³ Indagava-se, sob a vigência do código revogado, se o réu poderia reconvir. Admitia-se a reconvenção para pretensões não previstas expressamente no art. 922 do código revogado, aceitando-se igualmente que o réu reconviasse para pleitear proteção possessória sobre bem diverso ou fração diferente do próprio bem disputado, pois o pleito contraposto previsto no art. 922 do CPC/1973, reproduzido no art. 556, tinha como pressuposto o mesmo objeto litigioso.²⁰⁴ Daí afirmar a doutrina que não era necessária a identificação da pretensão do réu com todos os elementos da demanda formulada pelo autor.²⁰⁵

Vê-se que no CPC/1973, pretendendo o réu tutela possessória sobre o mesmo bem objeto da pretensão do autor, não era necessário propor reconvenção. Contudo, poderia o réu reconvir quando desejasse obter tutela possessória em relação a outro bem ou mesmo sobre parte diferente do mesmo bem.

O código vigente, como já dito, permite no art. 343 que a reconvenção seja apresentada como capítulo da contestação. Trata-se de reflexo da busca pela atenuação das formas no processo civil. Basta que a pretensão seja formulada separadamente da matéria de defesa, sendo desnecessário que isso ocorra em petição autônoma. Se sob o código anterior havia possibilidade de reconvenção para formulação de pretensão possessória sobre outro bem ou parte diferente do mesmo bem, por maioria de razão à mesma conclusão se deve chegar sob o código vigente, em que a reconvenção poderá ser apresentada na própria contestação.

Destarte, poderá o réu apresentar pedido reconvenicional referente a outras pretensões possessórias, ou seja, poderá requerer tutela jurisdicional da posse sobre outro bem ou fração diversa do próprio bem sobre o qual se litiga. Evidentemente a possibilidade de reconvenção não permite que o réu veicule pretensões distintas da possessória e daquelas previstas no art. 555 do CPC. É expressamente proibido ao réu, assim como ao autor, veicular pretensões relacionadas com a propriedade, conforme resulta do art. 1.210, § 2.º do CC, conjugado com o art. 557, parágrafo único, do CPC.

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

1. Pendência de ações possessórias e proibição de ajuizamento de ações petitórias: interpretação conforme a Constituição

Quando se fala que as ações possessórias são sumárias, alude-se à impossibilidade de discussão de direito à posse, matéria que deverá ser objeto de ações petitórias, como a imissão de posse ou a reivindicatória. Ocorre que o art. 557 não se limita a proibir a denominada exceção de domínio. Vai além e procura impedir que na pendência de ação possessória seja ajuizada ação para o reconhecimento do domínio. É preciso delimitar o alcance da proposição normativa.

O dispositivo em análise reproduz o art. 923 do Código Buzaid em sua última redação, ressaltando, contudo, a possibilidade de propositura de ação de reconhecimento de domínio contra terceiro.²⁰⁶ Sob o código anterior a regra foi duramente criticada, sendo surpreendente sua previsão no CPC/2015. Censurava-se a possibilidade, concedida pelo art. 923 do CPC/1973, de que o possuidor ilegítimo, valendo-se de ação possessória, inviabilizasse a retomada da coisa pelo proprietário, que estaria proibido de ajuizar ação reivindicatória, disso resultando violação à propriedade.²⁰⁷

Em vista da limitação ao direito de propriedade e também ao direito de ação, procurou-se interpretar o art. 923 do CPC/1973 restritivamente. Sustentou-se que só seria proibido o ajuizamento de ação para o reconhecimento do domínio quando os litigantes disputassem a posse baseados na propriedade. Assim, apenas quando nas ações possessórias o domínio fosse invocado *ad colorandum possessionem* vigoraria a proibição à propositura de ações para o reconhecimento do domínio.²⁰⁸

Ocorre que essa construção, adequada à luz do Código Civil de 1916, não encontra mais fundamento no ordenamento atual. Com efeito, não há no Código Civil de 2002 dispositivo que, à semelhança do art. 505, parte final do Código Beviláqua, assinale que a posse não pode ser reconhecida àquele a quem evidentemente não pertencer o domínio. Tampouco existe previsão que repita a redação original do art. 923 do CPC/1973, parte final, de acordo com a qual a posse

deveria ser julgada em favor daquele a quem evidentemente o domínio pertencesse. O que há, no Código Civil vigente, é a proibição da alegação de domínio em sede possessória, conforme se vê no art. 1.210, § 2.º.

Frente à proibição da exceção de domínio pelo Código Civil, reiterada no art. 557, parágrafo único, do CPC, fica nítida a inviabilidade de que os litigantes controvertam sobre a posse alegando propriedade. Isso implicaria a perda de sumariiedade das ações possessórias, transformadas em demandas plenárias nas quais seria discutido o *direito à posse*. Ocorre que a questão petitória não pode ser introduzida no âmbito das ações possessórias, cujo objetivo é a proteção do poder fático sobre a coisa. Alegações de propriedade devem ser desconsideradas, conforme resulta claro da aplicação dos arts. 1.210, § 2.º, do CC/2002 e 557, parágrafo único, do CPC.

Poder-se-ia sustentar que no código processual vigente haveria maior justificativa para a proibição de propositura de ação petitória na pendência de demanda possessória, já que seu art. 503, § 1.º, admite que a coisa julgada atinja questões prejudiciais decididas no processo. Com efeito, se sob o CPC/1973, em que a matéria petitória indiscutivelmente não fazia coisa julgada, pois decidida *incidenter tantum*, a tese era concebível, sob o código atual seria ainda mais forte, pois a questão envolvendo a propriedade, sendo prejudicial em relação à posse, seria coberta pela coisa julgada. Isso só não ocorrerá porque a propriedade é matéria estranha ao juízo possessório e nele não pode ser debatida. Deve ser repelida, portanto, qualquer tentativa de caracterização da propriedade como questão prejudicial em relação à posse, pois no âmbito das demandas possessórias não se pode discutir sobre a propriedade.

O juízo possessório é independente do petitório. Por força dos arts. 1.210, § 2.º, do CC/2002 e 557, parágrafo único, do CPC/2015, é proibida a discussão sobre propriedade no âmbito das ações possessórias.²⁰⁹ A exceção de domínio é proibida. As ações possessórias são o instrumento adequado para a tutela da posse e sua causa de pedir é distinta daquela das ações petitórias. Trata-se, logo se vê, de demandas distintas!

Não é correto sustentar que o art. 557 preservaria a finalidade das ações possessórias, já que estas não deixariam de ser demandas autônomas na hipótese de propositura de ação petitória.²¹⁰ Se aceita a justificativa para o dispositivo, de acordo com a qual seria adequada a vedação ao ajuizamento de demandas petitórias quando a posse fosse disputada com fundamento na propriedade, ter-se-ia de concluir que o art. 557, *caput*, conduz à transformação das ações possessórias, concebidas para a célere tutela do poder fático sobre a coisa, em demandas plenárias, nas quais se discutirá sobre o direito de propriedade.

O problema da justificativa para o dispositivo está em sua premissa. Não é possível, no atual ordenamento jurídico, discutir sobre posse com fundamento na propriedade. Tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil proíbem essa discussão. A matéria petitória não pode ser apreciada no âmbito das ações possessórias. É para tutelar a posse como fato que os interditos estão previstos no estatuto processual.

Sendo assim, é necessário concluir que inexistente justificativa para a aplicação do art. 557, *caput*, dispositivo que colide não apenas com o art. 1.228 do CC/2002, mas igualmente com o art. 170, II da Constituição. E não é apenas com este dispositivo constitucional que o art. 557 se choca. Ao vedar injustificavelmente a propositura de ação petitória pelo proprietário, o artigo em comento também colide com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5.º, XXXV, da Constituição.²¹¹

É concebível a restrição ao acesso à justiça em determinadas circunstâncias, mediante institutos como a litispendência e a coisa julgada, por exemplo. Contudo, considerada a indiscutível autonomia entre as demandas possessórias e petitórias, fundadas que são em diferentes causas de pedir e conducentes a tutela jurisdicional diversa, nada justifica a proibição contida no art. 557, *caput*. Trata-se de restrição inconstitucional, pois agride a um só tempo o direito de propriedade, ao inviabilizar a restituição do imóvel mediante ação reivindicatória, e o direito de ação, ao proibir que o proprietário se valha de ação reivindicatória para proteger seus interesses.

Nem se invoque o Enunciado 487, da Súmula de jurisprudência do STF, como argumento em sentido contrário, pois sua aprovação ocorreu no longínquo ano de 1969, sob a vigência do Código Civil de 1916, cujo art. 505, *in fine*, admitia que a posse fosse disputada com fundamento no domínio.²¹² Essa autorização inexistia no Código Civil vigente, de modo que a propriedade é tema estranho às demandas possessórias. Ademais, é sabido que desde a vigência da Lei 6.820/1980, que modificou o art. 923 do CPC/1973, o qual, por sua vez, alterara o art. 505 do CC/1916, a exceção de domínio se tornou inviável no direito brasileiro.

Ao analisar o art. 923 do Código de Processo revogado, dispositivo idêntico à primeira parte do art. 557, *caput*, do Código vigente, Arruda Alvim assinalou que haveria na hipótese espécie de litispendência, a despeito da inexistência de identidade entre as demandas.²¹³ A proibição à propositura de ações petitórias, pendente a ação possessória, teria como escopo inviabilizar que a posse fosse julgada em função do domínio, o que atentaria contra o juízo possessório.²¹⁴ Reitere-se, contudo, que o art. 1.210, § 2.º do CC, impede a discussão da posse com fundamento no domínio. Desse modo, não se concebe como poderia ocorrer julgamento do litígio possessório em conformidade com a propriedade, circunstância, ademais, que decorre da própria autonomia dos interditos possessórios, fundamentados em causa de pedir diferente das ações dominiais.

Poder-se-ia sustentar que a proibição de propositura de ações petitórias, pendente de julgamento a ação possessória, teria a finalidade de evitar decisões contraditórias no plano prático, à medida que a sentença de procedência em ação de reivindicação retiraria a utilidade do provimento obtido na ação possessória.²¹⁵ Se isso fosse correto, então mesmo após o trânsito em julgado da ação possessória deveria ser proibido o ajuizamento de ação reivindicatória para a retomada da coisa, a fim de evitar contradição prática entre julgados. Todavia, como se sabe, é admitida a propositura de ação petitória após o esgotamento da demanda possessória.²¹⁶

Ora, é indiscutível que a ação petitória pode vir a tutelar o proprietário que fora sucumbente na ação possessória, levando a resultado oposto, sob o ponto de vista prático, àquele obtido no juízo possessório. Assim, mesmo com o ajuizamento posterior ao trânsito em julgado da ação possessória pode haver colisão entre os julgados. Logo, há de se concluir que a alegada contradição não legitima a proibição contida no art. 557 do CPC/2015. Em termos técnicos, considerando que as ações para a tutela da posse têm objeto distinto em relação às petitórias, sequer se pode falar em contradição. O ordenamento jurídico admite que o proprietário não seja possuidor, de modo que sua derrota na esfera possessória não contradiz eventual vitória no âmbito das demandas em que se discute a propriedade.

Adotando a técnica da interpretação conforme a Constituição é possível extrair o único sentido em que o art. 557 não seria inconstitucional: ter-se-ia de enxergar na proibição à propositura de ação para o reconhecimento do domínio apenas a vedação dessa discussão no âmbito da própria demanda possessória, de modo que não seria possível discutir a propriedade por meio do pedido contraposto disciplinado no art. 556, nem mediante oferecimento de reconvenção.²¹⁷

Sob o código anterior essa solução foi indicada por Pontes de Miranda, para quem a propositura de ação possessória não poderia obstaculizar o ajuizamento de ação reivindicatória ou declaratória de domínio.²¹⁸ Esse é, realmente, o único sentido que preserva a constitucionalidade do dispositivo em análise. Consideradas as diferenças entre os elementos das ações petitórias e possessórias, cujas causas de pedir e pedidos são diferentes, é rigorosamente inconstitucional inviabilizar o ajuizamento de ações para o reconhecimento do domínio na pendência de ação possessória.

Criticou-se o posicionamento aqui adotado ao argumento de que a revogação do art. 923, 2ª parte do CPC/1973,²¹⁹ teria invalidado a opinião de Pontes de Miranda, a qual estaria calcada na possibilidade de discussão de domínio no âmbito das ações possessórias.²²⁰ De fato, o argumento de Pontes de Miranda fora construído sob a redação original do CPC/1973, quando ainda se previa que a posse seria julgada em favor daquele que evidentemente fosse proprietário. Porém, a passagem em que Pontes de Miranda procura restringir o alcance do dispositivo, baseia-se na ideia geral de que não é justo, nem razoável, impedir o proprietário de invocar seu direito em demanda

autônoma durante a pendência de ação possessória, pois isso estimularia o possuidor ilegítimo a litigar apenas para retardar o ajuizamento de demanda pelo proprietário.²²¹

Ademais, a eliminação, no art. 923 do CPC/1973, da alusão ao julgamento da posse em favor daquele a quem evidentemente pertencesse o domínio, comprova o repúdio à possibilidade de discussões petitorias no âmbito possessório, o que reforça a ideia de que é na relação processual possessória que não poderá ser exercida demanda para o reconhecimento do domínio.

Também é certo, como assinala Adroaldo Furtado Fabrício,²²² que em seu célebre “Compêndio de Teoria e Prática de Processo Civil”, originalmente publicado em 1857, Paula Batista sustentava, com fundamento no art. 77 do Código de Processo francês, que o réu na ação possessória não poderia invocar o domínio até o julgamento da demanda possessória. Mas isso decorria da ideia de que o reivindicante teria de se assumir como proprietário não possuidor, o que inviabilizaria o pedido de tutela jurisdicional da posse.²²³ A posição de Paula Batista foi corretamente criticada, pois não se aplicaria às ações de reintegração de posse, já que nessas o proprietário não seria possuidor, eis que teria perdido sua posse em razão do esbulho.²²⁴

Não é argumento decisivo a previsão da regra nos antigos códigos de processo estaduais ou no direito estrangeiro. Deve-se ter como premissa a separação entre os juízos possessório e petitorio, a fim de se extrair a interpretação do dispositivo mais adequada ao atual ordenamento jurídico brasileiro. Ora, à medida que o direito positivo brasileiro não mais admite a discussão da posse com base no domínio, tal como consta do art. 1.210, § 2.º, do CC e do art. 557, parágrafo único, do CPC, perde sustentação a tese originalmente defendida por Adroaldo Furtado Fabrício, de acordo com a qual a proibição de ajuizamento de ações petitorias na pendência de ação possessória só seria aplicável quando a posse fosse disputada com base no domínio.²²⁵ Tanto isso é verdade que na edição mais recente de seus “Comentários” ao CPC/1973 foi defendida a ideia de que o art. 1.210, § 2.º do CC, teria derogado o art. 923 do CPC/1973.²²⁶

É esse o posicionamento que aqui se defende. Vedada a exceção de domínio no juízo possessório e defendida a autonomia deste com o petitorio, não é razoável sustentar a proibição de ajuizamento de ações petitorias na pendência de processo possessório com base no argumento de decisões praticamente conflitantes. Trata-se de demandas diferentes. Ademais, a possibilidade de ajuizamento de ações petitorias após o trânsito em julgado das possessórias não elimina o risco de que o proprietário sucumbente na ação possessória se sagra vencedor na petitoria. Como já visto, considerada a diferença entre os respectivos objetos litigiosos – eis que diferentes os pedidos e também a causa de pedir – sequer se poderia falar em contradição prática entre as decisões.

É fundamental compreender que o art. 557, *caput*, não reintegra ao ordenamento jurídico a possibilidade de discussão sobre a posse com fundamento no domínio. Se isso é correto, esse dispositivo por certo não pode ser explicado à luz de ações possessórias fundadas em propriedade, pois se trata de fundamento expressamente rejeitado pelo ordenamento jurídico brasileiro desde o Código Civil de 2002. O Código de Processo não restaurou a exceção de domínio. Pelo contrário, proibiu-a no art. 557, parágrafo único, fazendo coro ao que já dispunha o Código Civil. Sendo assim, o único entendimento possível do art. 557, *caput*, à luz da Constituição e do Código Civil, é o de que estão proibidas discussões sobre propriedade formuladas incidentalmente nas ações possessórias. Em outras palavras, não será possível propor ação, tampouco oferecer resposta, com fundamento na propriedade.

Poder-se-ia invocar, contrariamente à tese aqui defendida, que o STF já se manifestou sobre a constitucionalidade da restrição à propositura de ações petitorias durante a tramitação de ações possessórias ao julgar o Recurso Extraordinário 87.344/MG.²²⁷ Esse precedente, relatado pelo Ministro José Carlos Moreira Alves, uma das maiores autoridades brasileiras sobre o tema da posse, foi erigido quando ainda vigia o Código Civil de 1916, cujo art. 505, citado no corpo do acórdão, permitia a disputa da posse com base no domínio. Ocorre que essa possibilidade inexistia no Código civil vigente, de modo que o RE 87.344/MG não pode ser invocado como argumento em favor da constitucionalidade do art. 557 do CPC.

Facilmente se percebe que a vedação contida no art. 557, em sua interpretação literal,

permitiria que o possuidor de má-fé inviabilizasse a retomada do bem pelo proprietário no juízo petitário. O dispositivo estimularia a propositura de demandas possessórias infundadas e a chicana, a fim de que o proprietário ficasse pelo maior tempo possível inabilitado a postular tutela jurisdicional no plano petitário. Essa compreensão não é adequada, pois colide com dispositivos constitucionais e suprime a separação entre os juízos possessório e petitário. Trata-se, todavia, da concepção prevalecente na doutrina²²⁸ e na jurisprudência²²⁹ erigidas sob o CPC/1973. Crê-se que o novo código oportunize a rediscussão do tema e a prevalência da interpretação conforme a Constituição aqui acatada.

2. Possibilidade de propositura de ação de reconhecimento de domínio contra terceiros

O art. 557 excepciona a possibilidade de propositura de ações para reconhecimento de domínio contra terceiros. Fica permitido, portanto, o ajuizamento de ações petitorias contra quem não figurar como parte no processo possessório. A ressalva contida na parte final do *caput*, segundo a qual não será possível ao autor ou ao réu proporem demanda petitoria, “exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”, refere-se ao próprio bem disputado na ação possessória e reforça a interpretação conforme a Constituição indicada no tópico precedente.²³⁰

Não seria razoável supor que a exceção prevista no art. 557, *in fine*, sinalizasse a possibilidade de que as partes reivindicassem outro bem contra terceiro. Isso tornaria a ressalva inútil, pois é óbvio que a parte no processo possessório pode reivindicar outro bem contra outra parte. Tratar-se-ia, então, de bens distintos, de modo que não haveria coincidência entre nenhum dos elementos da demanda, pois não seriam idênticas as partes, nem a causa de pedir, nem o pedido. Nesse caso o dispositivo seria rigorosamente inútil, pois é óbvio que o réu na ação possessória poderá propor ação reivindicatória, sobre outro bem, contra outra pessoa que não o autor da ação possessória.

Para que a ressalva tenha sentido o pressuposto é que esteja autorizado o ajuizamento de ação petitoria cujo objeto seja o próprio bem disputado na demanda possessória. Nesse caso, se é permitida a propositura contra terceiro, de ação reivindicatória para obter tutela petitoria em relação ao próprio bem objeto da ação possessória, é igualmente aceitável o ajuizamento de ação petitoria em face da parte contrária no interdito possessório. Trata-se de outra demanda, cujo exercício é possibilitado pela autonomia entre os juízos possessório e petitário.

Reitera-se a interpretação conforme a Constituição do art. 557, *caput*. Ao inviabilizar o ajuizamento de ação para o reconhecimento de domínio simultaneamente à discussão sobre a posse, o dispositivo afronta não apenas o direito de propriedade, previsto no art. 170, II da CF/1988, mas ofende igualmente o direito fundamental de acesso à justiça, disciplinado no art. 5.º, XXXV, da CF/1988.

3. Demandas compreendidas na expressão “ação para reconhecimento do domínio”

É preciso delimitar quais demandas estão compreendidas na expressão “ação para reconhecimento de domínio”. Certamente devem ser incluídas nesse rol a ação reivindicatória e ações declaratórias típicas nas quais seja pleiteado o reconhecimento da propriedade.

Também devem ser incluídas no enunciado do art. 557 as ações de usucapião. Essas são exemplo de ações declaratórias, não de ações constitutivas, pois nas sentenças de procedência se reconhece que “existe a relação jurídica da propriedade usucapida”, sendo que o momento da usucapião é anterior à sentença e o ato de registro é efeito mandamental.²³¹ Ou seja, não se usucapa no momento de transcrição da sentença no registro, mas antes da sentença, ato jurisdicional que apenas declara a prévia existência da usucapião. A jurisprudência erigida sob o código processual revogado vedava a propositura de usucapião na pendência de ações possessórias.²³²

Caso se dê ao art. 557 a interpretação literal, não abonada neste trabalho, concluir-se-á que as demandas referidas não poderão ser ajuizadas enquanto pender a demanda possessória. Se for adotada a interpretação do dispositivo conforme a Constituição, aqui defendida, chegar-se-á à

conclusão de que o réu não poderá apresentar pedido contraposto ou reconvenção nos quais seja deduzida demanda reivindicatória, de usucapião ou declaratória de reconhecimento da propriedade²³³.

4. Proibição de exceção de domínio nas ações possessórias

No art. 557, parágrafo único, é consagrada a proibição de exceção de domínio no âmbito das ações possessórias, reiterando-se o que assinala o art. 1.210, § 2.º, do CC. Trata-se de regra que inviabiliza o debate de matéria estranha à posse, reforçando o *caput* do dispositivo em análise.²³⁴

O CC/1916 admitia nos arts. 505, *in fine*²³⁵ e 507, parágrafo único,²³⁶ a disputa possessória com fundamento no domínio.²³⁷ Essa possibilidade, contudo, causava embaraço à sistematização da defesa da posse. Assinalava-se que, ao verificar os títulos invocados pelos possuidores, o juiz deveria se limitar ao fundamento possessório, de modo a não examinar sua validade e não misturar o juízo possessório com o petitório.²³⁸ Ao interpretar o dispositivo, o juiz deveria harmonizá-lo com as demais regras do sistema de proteção da posse, sendo inadmissível a resposta do réu fundada na propriedade.²³⁹

É inequívoco, contudo, que o art. 505 do CC/1916 permitia discussão dominial, pois assentava que a posse não deveria ser julgada em favor daquele a quem evidentemente não pertencesse a propriedade. Retirava-se com isso a autonomia da proteção possessória. Posteriormente, o art. 923 do CPC/1973, em sua redação original, revogou a última parte do art. 505 do Código Beviláqua, dispondo que a posse deveria ser julgada em favor daquele a quem evidentemente pertencesse o domínio.²⁴⁰ Com a revogação da parte final do art. 923, pela Lei 6.820/1980, não houve repristinação da parte final do art. 505 do CC/1916, em conformidade com o que preconiza a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro no art. 2.º, § 3.º.²⁴¹ Esse posicionamento era acolhido pela doutrina, que reconhecia a inviabilidade da exceção de domínio após a modificação do art. 923, do CPC/1973, operada pela Lei 6.820/1980.²⁴² Com essa modificação, foram retirados os fundamentos para a aplicação da Súmula 487 do STF, pois a exceção de domínio se tornou inviável.

No Código Civil vigente, por sua vez, nenhum dispositivo reproduz a parte final do art. 505 ou a regra contida no art. 507, parágrafo único, do CC/1916. O que há é dispositivo a considerar inútil a exceção de domínio no âmbito possessório (art. 1.210, § 2.º, do CC/2002), afirmando regra ora reproduzida no art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, torna-se ainda mais saliente a inaplicabilidade da Súmula 487 do STF, cujo cancelamento deveria ter sido decretado a partir da vigência da Lei 6.820/1980.

É preciso analisar a disposição que proíbe a exceção de domínio com a possibilidade de alegação de propriedade *ad colorandum possessionem*. Na prática forense não raras vezes um dos contendores junta aos autos matrícula comprobatória da propriedade. Todavia, o máximo que se admite aos contendores, sem que haja violação à autonomia do juízo possessório, é a referência à propriedade ou ao direito, sem que isso signifique alegação possessória fundada no domínio.²⁴³

O litigante deverá invocar o poder fático sobre a coisa. É isso que deverá ser alegado e comprovado, juntamente com a violação ou ameaça, para que ocorra a tutela jurisdicional da posse. Considerações sobre a propriedade não poderão fundamentar a disputa sobre a posse. Será permitido à parte apenas corroborar suas alegações possessórias se referindo à propriedade, quicá para comprovar sua modalidade e limites.²⁴⁴ Mas o fundamento do pedido sempre será a posse. É ela a causa de pedir remota. A referência à propriedade apenas colorirá ou reforçará a posse. Isso significa que a alusão à propriedade, com o intuito de enfatizar a posse, não legitima o pedido de tutela possessória fundamentado no domínio.

Fica afastada, portanto, a possibilidade de que as partes litiguem no âmbito possessório invocando diferentes títulos dominiais. A tutela da posse não se compadece da demora necessária à verificação da propriedade. Trata-se de demanda sumária, restrita ao *jus possessorium*, cuja autonomia tem como pressuposto a proibição de alegação de matéria petitória²⁴⁵. À luz do Código

de Processo de 1973, a exceção de domínio ainda era aceita na jurisprudência quando ambos os litigantes disputassem a posse com base na propriedade.²⁴⁶ Contudo, com a reiteração, no art. 557, parágrafo único, do CPC/2015, da regra proibitiva contida no art. 1.210, § 2.º, do CC/2002, crê-se que é chegado o momento de erradicar a possibilidade de que a posse seja debatida com fundamento na propriedade.

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no *caput*, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

1. Prazo de ano e dia e procedimento especial para proteção da posse

O art. 558 mantém o tradicional prazo de ano e dia como critério distintivo entre o procedimento especial das ações possessórias e o comum. Ultrapassado o prazo, a demanda não perderá seu caráter possessório, mas a tramitação do processo não estará sujeita às regras especiais previstas nos arts. 560 e ss. do CPC/2015.

No código anterior, a doutrina advertia para a incorreção no uso do termo “ordinário”, no art. 924, para se referir ao procedimento das ações possessórias quando esgotado o prazo de ano e dia.²⁴⁷ A referência à ordinarietade poderia levar à falsa conclusão de perda do caráter sumário das ações possessórias, as quais, contudo, continuavam materialmente sumárias, sendo proibida em seu âmbito a discussão sobre o domínio.²⁴⁸

O dispositivo comentado corrigiu o equívoco terminológico, fazendo referência ao procedimento comum. Com isso a proposição normativa se torna tecnicamente mais precisa, enfatizando o caráter possessório das ações propostas depois do escoamento do prazo de ano e dia, donde resulta a impossibilidade de discussão sobre a propriedade, sendo proibida a exceção de domínio no direito brasileiro.

A principal vantagem concedida ao autor pelo procedimento especial a que alude o art. 558 do CPC/2015 consiste na possibilidade de obtenção de liminar possessória sem que seja necessário demonstrar o perigo de dano no caso concreto. Nas ações de força velha, assim denominadas aquelas propostas depois do escoamento do prazo de ano e dia, será possível obter liminar antecipatória, mas para tanto o autor deverá comprovar o perigo de dano ou obter tutela da evidência com base no art. 311, I e IV, do CPC/2015, já que os incs. II e III não se aplicam às ações possessórias.

Ademais, o procedimento especial propicia a realização de audiência exclusiva para a obtenção de liminar possessória, nos termos do art. 562 do CPC/2015, na qual são concedidas maiores prerrogativas ao autor, como adiante se verá. É certo que essa vantagem diminuiu no código vigente, pois o art. 300, § 2.º, do CPC/2015, prevê a possibilidade de justificação prévia para a obtenção de liminares no âmbito da tutela de urgência. Mas ainda assim é possível visualizar, quanto ao ponto, situação mais vantajosa para o autor ao se valer do procedimento especial. É corrente o entendimento segundo o qual a audiência de justificação nas ações possessórias é realizada em favor do autor, para que ele possa comprovar a presença dos requisitos que autorizam a concessão da liminar. Não se sabe ainda qual será a interpretação prevalecente do art. 300, § 2.º, do CPC/2015, mas não é irrealista supor que doutrina e jurisprudência concederão ao *réu* maior possibilidade de atuação, ao passo que no procedimento especial o *autor* é o protagonista da audiência de justificação.

Embora o art. 558 se refira somente às ações de reintegração e de manutenção, a previsão de especialidade procedimental nele prevista é igualmente aplicável ao interdito proibitório. Essa conclusão, recomendada pela interpretação teleológica do art. 558 do CPC/2015 é respaldada pelo art. 568 do CPC/2015, que admite a aplicação ao interdito proibitório das regras contidas na Seção

II do Capítulo III²⁴⁹. Há de se atentar, contudo, para a circunstância de que o interdito proibitório deve ser ajuizado na iminência do esbulho ou da turbacão, de modo que o prazo de ano e dia a que se refere o art. 558, *caput*, a ele não é aplicável. Não se crê que o autor tivesse interesse processual em ajuizar interdito contra ameaca realizada há meses. Nesse caso, o decurso do tempo sem a consumacão da ameaca, demonstra que não era necessário o ajuizamento da açao.

Parte da doutrina reservava às açoes propostas no prazo de ano e dia a denominacão de interditos possessórios.²⁵⁰ Na prática forense, contudo, as expressões “ações possessórias” e “interditos possessórios” são empregadas como sinônimos.²⁵¹ Também neste texto o uso da expressão “interditos possessórios” será empregado como equivalente das ações possessórias, quer se trate de ações de força nova, ajuizadas em ano e dia da violacão, quer se trate de ações de força velha, cuja tramitacão atenderá às regras do procedimento comum (CPC, art. 558, parágrafo único, do CPC/2015).

2. Prazo de ano e dia e questões relacionadas à contagem

Tratando-se de açao de reintegracão de posse, o prazo de ano e dia deverá ser contado a partir da perda da posse, verificada em conformidade com o disposto no art. 1.223 do CC/2002. Perda haverá quando cessar o poder fático exercido sobre a coisa. Contudo, nos termos do art. 1.224 do CC/2002, o prazo não começará a correr se o possuidor não presenciou o esbulho. Será contado apenas quando o ausente se abster de recuperar a posse depois de informado sobre a perda. A prova será tormentosa, incumbindo ao réu o ônus de comprovar que o autor estava ciente da violacão e nada fez para repeli-la. Nesses casos, a contagem do prazo de ano e dia ocorrerá a partir da ciência do autor a respeito do esbulho.

Pode se revelar complicada a contagem do prazo nas ações de manutençao de posse. Ocorre que a turbacão poderá ser resultado de um conjunto de atos de perturbacão da posse. Como assinalava a doutrina sob o código revogado, se houver continuidade entre os atos, a turbacão será consumada a partir do primeiro, tal como ocorreria se o agressor continuamente transitasse sobre a posse alheia. Todavia, se entre os atos houver autonomia, a cada nova perturbacão começará a contagem para a propositura da açao de manutençao de posse, tal como se daria se em uma ocasião o agressor removesse divisas e em outra colhesse frutos na posse alheia.²⁵²

Na hipótese de ameaca à posse, o prazo para o ajuizamento de interdito proibitório será contado a partir da concretizacão do ato intimidatório. Nos comentários ao art. 568 será retomada a ideia de que o prazo de ano e dia não é aplicável ao interdito proibitório, apesar do contido no art. 568. A ameaca deve se referir a esbulho ou turbacão *iminentes*, de modo que o interesse processual do possuidor ameacado está limitado ao momento de iminência da turbacão ou ameaca. É certo que passados alguns meses do ato de intimidacão, não faria sentido ajuizar a açao inibitória. Se a antiguidade da ameaca for apontada na própria inicial, o juízo, depois de ouvir o demandante, indeferirá a petição caso o autor confirme que a intimidacão não é recente (CPC, art. 330, inc. II). Caso essa circunstância se evidencie após a resposta, a primazia do mérito, encampada nos arts. 4º e 488 do CPC, impõe a apreciacão do *meritum causae*, com a improcedência da demanda.

3. Ações possessórias e inaplicabilidade do regime da tutela de urgência

A possibilidade de antecipacão de efeitos da tutela nos procedimentos especiais mediante provimento não típico, isto é, deferido em demanda que não siga o procedimento especial disciplinado nos arts. 560 e ss., é questão intrincada. Questiona-se primeiramente se o autor poderá escolher entre o procedimento especial e a tutela de urgência genérica. Em segundo lugar, indaga-se sobre a possibilidade de obtençao de provimento de urgência depois de escoado o prazo de ano e dia.

Em relacão às ações de força nova, assim denominadas aquelas propostas em até ano e dia da violacão à posse, sustentou-se, sob os Códigos Civil e de Processo Civil revogados, a inviabilidade de pedidos simultâneos, baseados no procedimento especial e na antecipacão de tutela genérica

prevista no art. 273 do CPC/1973. Admitia-se, contudo, que o autor, motivado por razões probatórias ou financeiras, não adotasse o procedimento especial.²⁵³

A principal vantagem no uso da ação especial de reintegração de posse é a desnecessidade de comprovação do perigo no caso concreto. Ademais, quer a ação seja de força nova, quer seja de força velha, conservará o caráter possessório, o que significa a impossibilidade de discussão sobre a propriedade. Mesmo diante dessas vantagens, é possível que o autor prefira obter liminar satisfativa por meio de requerimento de tutela de urgência, disciplinado nos arts. 300 e ss. do CPC/2015.²⁵⁴ Nesse caso, contudo, impõe-se ao autor cumprir os requisitos elencados no dispositivo, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano no caso concreto. Não será suficiente, para a obtenção da liminar, alegar violação à posse em prazo igual ou inferior a ano e dia.

Poder-se-ia argumentar que havendo procedimento especial, a prever tutela jurisdicional típica da posse, o autor obrigatoriamente teria de segui-lo. Mas esse entendimento não se coaduna com a maior liberdade que o código concede aos litigantes, a quem é outorgada a possibilidade de realizar negócios processuais, alterando o procedimento e fixando calendário, conforme disciplinam os arts. 190 e 191 do CPC/2015. Além disso, permite-se que as partes delimitem as questões fático-jurídicas que devem ser dirimidas e que atuem conjuntamente com o juiz no saneamento do processo, como se vê nos art. 357, §§ 2.º e 3.º, do CPC/2015.

Seria contraditório que o código permitisse o saneamento compartilhado do processo e autorizasse a celebração de convenções processuais capazes de modificar o procedimento comum, mas obrigasse o autor a propor demandas possessórias pelo rito especial. A maior autonomia concedida às partes se reflete nessa questão, de modo que será possível o ajuizamento da demanda pelo procedimento comum, hipótese em que o autor deverá comprovar os requisitos específicos do art. 300 para obter liminar satisfativa.

Não será possível, no curso de ação proposta segundo o procedimento especial, postular tutela de urgência com fundamento no art. 300. O autor já terá optado pelo procedimento das ações de força nova, incompatível com a tutela de urgência disciplinada nos arts. 300 e ss. Essa incompatibilidade permanece mesmo após o encerramento da fase especial, o que ocorre com a resposta do réu. Mas ainda que não houvesse falta de interesse processual, por inadequação, seria remotíssima a chance de o autor, inexitoso no pedido de liminar possessória, obtê-la sob as vestes de tutela urgente. Em regra, faltar-lhe-ia verossimilhança, eis que não conseguira comprovar a existência da posse e da agressão, razão pela qual não lhe fora deferida a liminar possessória. Também não será possível o deferimento de tutela da evidência, o que será melhor analisado nos comentários ao art. 566.

De acordo com o art. 558, parágrafo único, do CPC/2015, esgotado o prazo a ação permanecerá possessória, mas deverá tramitar pelo procedimento comum. Nesse caso, indaga-se se seria possível a obtenção de liminar com fundamento no art. 300 do CPC/2015 nas ações de força velha. A resposta é positiva. Sob o código anterior já se admitia essa possibilidade, destacando-se a aplicação do art. 461-A do CPC/1973 quando ultrapassado o prazo de ano e dia, o que asseguraria a prolatação de liminar executiva, capaz de transferir desde logo a posse em favor do demandante que comprovasse os requisitos de urgência e de perigo²⁵⁵.

Caso não tenha sido ajuizada demanda possessória no prazo de ano e dia da violência à posse, poderá ser requerida a concessão de liminar satisfativa com fundamento nos arts. 300 e ss. do CPC/2015. Deverá o autor comprovar a urgência e o perigo de dano no caso concreto. O demandante seguirá o procedimento comum, o que lhe permite pleitear a liminar em caráter antecedente, conforme o procedimento estabelecido no art. 303 do CPC/2015.²⁵⁶ Nesse ponto se materializa grave incongruência do sistema, pois o art. 304 do CPC/2015²⁵⁷ permite a estabilização da decisão se contra ela não for interposto recurso, o que não ocorre nas liminares obtidas em ações de força nova que sigam o procedimento especial.

A especificidade do rito previsto nos arts. 560 e ss. não permite que a liminar possessória seja requerida com fundamento no art. 303 do CPC/2015. Como a estabilização, por expressa

determinação do art. 304, vincula-se a requerimento formulado em conformidade com o art. 303, seguramente não poderá ocorrer quando o pedido houver sido formulado com base no art. 561, cujo fundamento é a posse e sua agressão, sendo desnecessário provar o perigo de dano.

Vê-se, assim, que passado o prazo decadencial previsto no art. 558 do CPC/2015, o autor poderá ajuizar demanda possessória, requerendo em caráter antecedente a prolatação de liminar satisfativa, a qual poderá se estabilizar, conforme se depreende dos arts. 303 e 304 do Código de Processo Civil de 2015. Há quebra de sistema nesse ponto, já que não é possível a estabilização da liminar possessória nas ações de força nova. Isso significa que o autor de ação de força velha poderá ser beneficiado com a estabilização, o que não ocorre com o autor nas ações de força nova. A incongruência é manifesta.

Essa conclusão não se aplica aos litígios possessórios coletivos em que tenha sido proposta ação de força velha, para os quais se prevê no art. 565 do CPC/2015 a obrigatoriedade de realização de audiência de mediação antes da concessão de liminar. Assim, por expressa previsão legal, não será cabível o requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente (art. 303 do CPC/2015).

O autor que optar pelo ajuizamento de demanda em conformidade com o procedimento comum, evidentemente poderá ser beneficiado pela estabilização, ainda que não tenha transcorrido o prazo previsto no art. 558. Nesse caso, reitere-se, caber-lhe-á comprovar a presença dos requisitos elencados nos arts. 300 e 303 do CPC/2015. A vantagem caracterizada pela estabilização é balanceada pela necessidade de comprovar o perigo de dano no caso concreto, algo que o demandante que propuser ação segundo o procedimento especial não precisará fazer.

Dito de outro modo, o autor que promover a demanda segundo o procedimento especial, terá o ônus de comprovar os requisitos indicados no art. 561 do CPC/2015, sendo desnecessário demonstrar a urgência. Por outro lado, o autor da ação de força velha, ou aquele que optar pelo procedimento comum apesar da possibilidade de ajuizar a ação de força nova, poderá requerer tutela provisória da evidência com fundamento no art. 311, I e IV, sendo inaplicáveis às ações possessórias os incs. II e III.

4. Ações possessórias, convenções processuais, saneamento compartilhado e delimitação consensual de questões

Uma das mais importantes alterações trazidas pelo código é a possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais quando o objeto do processo versar sobre direitos disponíveis e as partes forem capazes. É o que prevê o art. 190 do CPC/2015²⁵⁸. Impõe-se verificar se os litigantes poderiam celebrar negócios processuais no âmbito das ações possessórias.

Tratando-se de ações de força nova, não será viável a celebração de negócios processuais até a resposta. Decorre da abreviação procedimental a impossibilidade das partes convencionarem sobre o processo. Todavia, a especialidade do procedimento vai apenas até a concessão ou denegação da liminar, momento a partir do qual será adotado o procedimento comum. Não existe razão para que as partes não possam dispor sobre o processo após a concessão ou denegação da liminar, pois a partir de então será adotado o procedimento comum, por expressa dicção do art. 566 do CPC/2015²⁵⁹. A convenção, contudo, não poderá atingir a sumariiedade material das ações possessórias, sendo vedado às partes convencionarem a possibilidade de discussão sobre propriedade. Tal estipulação desnaturaria a natureza da demanda e inviabilizaria a adoção do procedimento especial.

Também a delimitação consensual de questões e o saneamento compartilhado, respectivamente previstos no art. 357, §§ 2.º e 3.º,²⁶⁰ poderão ocorrer depois do momento de concessão ou de denegação da liminar possessória. Como já dito, depois da decisão sobre a liminar possessória o procedimento se torna comum, modalidade de tramitação na qual a delimitação consensual de questões e o saneamento compartilhado podem ser utilizados. Logo, nada impede que o sejam depois de ultrapassada a fase especial do procedimento das ações possessórias. Não será permitido, contudo, que sejam delimitadas questões relacionadas à propriedade, pois as ações

possessórias sempre são sumárias, sendo proibida em seu âmbito discussão sobre questões petitorias.

Nas ações de força velha individuais, será adotado o procedimento comum, como resulta nitidamente do art. 558, par. ún. do CPC/2015. Sendo assim, será possível a realização de negócios processuais, a delimitação consensual de questões e o saneamento compartilhado. Como as ações de força velha não perdem seu caráter possessório, aplicam-se aqui as conclusões já apresentadas no tocante às ações de força nova, de modo que não será possível às partes delimitar questões ou convencionar sobre matéria petitoria.

Art. 559. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 (cinco) dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

1. Incapacidade financeira do autor mantido ou reintegrado e prestação de caução

O dispositivo em análise reproduz, na essência, o art. 925 do Código de Processo Civil de 1973 revogado, trazendo importante ressalva quanto à inaplicabilidade da exigência de caução quando se tratar de autor economicamente hipossuficiente. O preceito normativo continua confuso e causa inquietação já no tocante ao legitimado para requerer a caução. Apesar da redação abstrusa, deve-se entender que o réu, contra quem foi proferida liminar de manutenção ou de reintegração de posse, tem o *ônus* de comprovar a inidoneidade financeira do autor que obtivera a liminar de manutenção ou de reintegração.

Comprovada a incapacidade financeira, o réu deverá requerer, em cinco dias, que o juízo determine que o autor caucione, caução esta que poderá ser real ou fidejussória, sob pena de sua omissão acarretar o depósito da coisa.²⁶¹ A caução poderá ser prestada por terceiro, solução já consentida pela doutrina construída sob o CPC/1973.²⁶²

A doutrina firmada sob o código anterior se posicionou firmemente no tocante à impossibilidade de outro meio de prova que não o documental para a demonstração da incapacidade financeira do autor.²⁶³ A conclusão vale para o código vigente. É certo que a admissão de ampla produção probatória causaria confusão e seria detrimental ao processo possessório. O dispositivo impõe ao réu o *ônus* de comprovar a incapacidade financeira do autor, a qual deverá ser demonstrada por prova documental.

Evidentemente o juiz deverá ouvir o autor antes de decidir sobre a questão. Trata-se de manifestação do princípio do contraditório (art. 9.º do CPC/2015). O autor beneficiado pela liminar poderá trazer aos autos prova documental de sua capacidade financeira, sendo-lhe vedado produzir outras provas, sob pena de ofensa à isonomia, pois o réu, como visto, também pôde se valer apenas de documentos²⁶⁴. O juiz poderá não deferir a caução mesmo quando haja provas sobre a precariedade da situação econômica do autor, pois lhe cabe averiguar o risco concreto ocasionado pela manutenção ou reintegração de posse.²⁶⁵ Assinalou-se, no mesmo sentido, que faltaria interesse processual ao réu para requerer o depósito do bem litigioso quando a posse fosse inquestionavelmente do autor, já que nesse caso inexistiria direito a futuro ressarcimento, haja vista o caráter injusto da posse do réu.²⁶⁶

Se o réu não conseguir tornar duvidoso o direito do autor será remota a possibilidade de reversão da liminar no momento de prolatação da sentença, de modo que o baixo risco de prejuízo recomenda o indeferimento do pedido do réu para que o autor seja onerado com a prestação de caução. Vê-se, assim, que a apresentação de resposta é requisito para o pedido do réu, o que já era apontado pela doutrina sob o Código revogado.²⁶⁷

Embora o dispositivo tenha sido inserido nas disposições gerais sobre as ações possessórias, por certo se aplica apenas às hipóteses de manutenção ou de reintegração de posse, o que

recomendaria sua inserção na Seção II. Isso decorre não apenas da literalidade do art. 558, a se referir ao “autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse”, mas também da impossibilidade de se vislumbrar prejuízos ao réu na hipótese de interdito proibitório. A inibição de ameaça à posse procura impedir que sejam causados prejuízos ao autor. Por isso não se concebe qualquer justificativa ao réu, no interdito proibitório, apta a fundamentar eventual pedido sobre a necessidade de caução.

2. Momento do requerimento do réu e valor da caução

Quando se afirma que a apresentação de resposta é requisito para a alegação de precariedade financeira do autor e para o pedido de que lhe seja assinalado prazo para que preste caução, não se está a propor que a alegação tenha de ser formulada na resposta²⁶⁸. Ocorre que a falta de impugnação ao pedido do autor inviabiliza a demonstração do risco inerente à liminar de reintegração ou de manutenção de posse. Sem que haja dúvida sobre a verossimilhança das alegações apresentadas na inicial, algo que, na generalidade dos casos, pressupõe resposta à demanda, não haverá necessidade de arbitramento de caução, pois são mínimos os riscos decorrentes da liminar possessória.

O réu não precisa formular na resposta a alegação de incapacidade financeira do autor, o que fica claro com a expressão “a qualquer tempo”. Poderá fazê-lo em petição simples a partir da resposta até o momento de prolação da sentença. Proferida esta, não remanesce a liminar possessória, o que inviabiliza a determinação de caução em favor do réu.²⁶⁹

O valor da caução precisará refletir os danos que porventura possam decorrer da liminar de manutenção ou de reintegração de posse, o que significa a desnecessidade de correspondência com o valor do bem objeto da demanda.²⁷⁰ Procura-se evitar prejuízos ao réu. Assim, ao formular a petição em que alega a inidoneidade financeira do autor contemplado com a liminar, recai sobre o réu o ônus de apontar, mediante prova documental, os prejuízos que decorrerão da manutenção ou da reintegração provisória do autor na posse. Poderá, por exemplo, afirmar que a liminar lhe impede de realizar a colheita, exigindo que o valor da caução corresponda ao lucro que auferiria com a venda dos frutos.

3. Parte economicamente hipossuficiente e inaplicabilidade do dispositivo

Sempre foram contundentes as críticas à necessidade de caução pelo autor beneficiado pela liminar possessória, já que ela concretiza, na prática, censurável restrição de acesso à justiça aos mais pobres.²⁷¹ Na tentativa de mitigar as críticas, acrescentou-se ao art. 559 a ressalva de aplicação em relação aos autores economicamente hipossuficientes. Isso significa que, quando comprovar sua hipossuficiência econômica, o autor não ficará onerado com a prestação de caução.

Como já mencionado nos comentários ao art. 554, deve-se compreender por hipossuficiente a parte que não dispuser de recursos econômicos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o que dispõe o art. 98 do CPC/2015.²⁷² O ônus de comprovar a incapacidade financeira do autor recai sobre o réu. O autor, por sua vez, terá o ônus de comprovar sua hipossuficiência, a fim de que não ocorra o depósito da coisa litigiosa.

Considerada a ressalva constante na parte final do art. 559, vê-se que o dispositivo somente será aplicável quando a incapacidade financeira do autor, beneficiado com a liminar de reintegração ou de manutenção, não se traduzir em hipossuficiência econômica. Com efeito, quando a incapacidade financeira caracterizar o autor como economicamente hipossuficiente, será inaplicável o art. 559 do CPC/2015. Procura-se evitar que as parcelas mais pobres da população sejam alijadas da reintegração ou da manutenção de posse por meio de liminares. Mas o dispositivo será aplicável contra autores de ações possessórias que, conquanto não sejam hipossuficientes, não detenham capacidade financeira de arcar com os prejuízos decorrentes da eventual reversão da liminar possessória.

O dispositivo em comento distingue os economicamente hipossuficientes, daqueles que, embora

estejam em patamar econômico superior, pois são capazes de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma do art. 98 do CPC, não estão em condições de ressarcir o réu dos prejuízos decorrentes do cumprimento da liminar de reintegração ou de manutenção de posse.

A ressalva presente no art. 559, apesar de impedir que sejam prejudicadas as camadas mais desfavorecidas da população, não afasta sua inconstitucionalidade. Continuam cerceados pelo artigo os autores favorecidos por liminares possessórias que não tenham condições de responder por prejuízos na improvável hipótese de reversão da liminar possessória. Por que improvável? Porque o juiz já deferiu em favor do autor a liminar, o que demonstra a verossimilhança de suas alegações. Apreciando a questão que lhe foi submetida, o juiz acolheu provisoriamente o pedido, o que demonstra grande probabilidade de que a sentença seja proferida no mesmo sentido.

A inconstitucionalidade do artigo decorre de restrição indevida de acesso à justiça. Poder-se-ia afirmar que é lícito ao legislador infraconstitucional estabelecer restrições, sem que isso implique inconstitucionalidade. O problema, contudo, está na perda de eficácia de liminar possessória, após o juiz verificar a verossimilhança das alegações, exclusivamente em razão de motivos econômicos. Essa distinção fere a isonomia que deve prevalecer entre as partes e que é garantida pela Constituição no art. 5.º e pelo próprio CPC/2015, que assegura paridade de tratamento no art. 7.º.²⁷³ Melhor que ressaltar a aplicação, seria não positivar a exigência de caução.

4. Depósito da coisa litigiosa

Até que se decreta a inconstitucionalidade do dispositivo em controle concentrado ou a menos que ela seja reconhecida em controle difuso, a regra deverá ser aplicada. Assim, caso o réu comprove que o autor não tem capacidade econômica de arcar com os prejuízos que advirão de eventual reversão da liminar, o juiz abrirá o prazo de cinco dias para que o autor requeira caução. Trata-se de ônus cujo não cumprimento acarretará o depósito da coisa.

Discutiu-se, sob o código revogado, se se trataria de depósito ou de sequestro²⁷⁴. Contudo, a redação do artigo, tão precária quanto a outros pontos, mostrou-se pouco passível de controvérsia sobre a consequência da omissão do autor: a coisa litigiosa será depositada. Note-se que não estão presentes os requisitos para o sequestro cautelar. O depósito será realizado, tornando ineficaz a liminar possessória, exclusivamente em razão da incapacidade financeira do autor, a despeito da convicção do juiz sobre a necessidade de reintegração ou manutenção na posse. Vê-se, assim, que se trata de depósito do bem litigioso, não de sequestro cautelar.

Seção II Da manutenção e da reintegração de posse

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

1. Ações de reintegração e de manutenção de posse

O art. 560 trata da tutela típica da posse, estabelecendo que o autor esbulhado poderá se valer da ação de reintegração, socorrendo-se contra a perda da posse, caracterizada nos termos dos arts. 1.223 e 1.224 do CC/2002. Quando a posse for agredida sem que haja perda, caracteriza-se a turbação, a ensejar a propositura de ação de manutenção. Quando houver ameaça à posse será adequado o interdito proibitório, a fim de que a conduta hostil seja inibida. Trata-se de repetição desnecessária do conteúdo do art. 1.210, *caput*, do CC/2002, dispositivo que se refere ainda ao interdito proibitório.²⁷⁵

As ações possessórias típicas, disciplinadas nos arts. 554 a 568, têm como fundamento a proteção ao *jus possessionis*. Fica nítida a sua distinção em relação às ações petitórias, nas quais se discute sobre a propriedade ou direito à posse, de que são exemplos, respectivamente, as ações reivindicatória e de imissão de posse. O autor não invocará sua propriedade ou o direito à posse do bem, mas sim o poder fático que exerce sobre a coisa, a lhe conferir interesse processual no

ajuizamento das ações possessórias.

Já se viu, nos comentários ao art. 554 do CPC/2015, que as ações possessórias são fungíveis, cabendo ao juiz outorgar a proteção possessória necessária no caso concreto. É possível, por exemplo, que tenha sido ajuizada ação de manutenção. Se a turbação se converter em esbulho, deve o juiz conceder liminar de reintegração de posse. Caso tenha sido proferida liminar de manutenção, mas ocorra perda da posse no curso da demanda, deve o juiz conceder tutela contra a conduta espoliativa, por liminar ou sentença. O fundamental é que haja tutela jurisdicional efetiva e adequada.

2. Legitimidade (ativa e passiva) e interesse processual

O código vigente não faz referência às “condições da ação”, limitando-se a indicar a legitimidade e o interesse (CPC, arts. 17, 337, XI e 485, VI). Demonstra-se, com isso, que a “possibilidade jurídica” perdeu sua autonomia no direito positivo. Ademais, a falta de indicação da expressão “condições da ação” permite que se conceba o interesse e a legitimidade como pressupostos processuais.

Caso a falta de interesse ou de legitimidade ativa resultem da própria inicial, o juízo, depois da indispensável oitiva do autor, indeferi-la-á caso seja reiterada a inconsistência narrativa, com fundamento no art. 330, incs. II e III, do CPC. Por outro lado, se a inexistência de posse ou de vício a maculá-la for identificada somente depois da resposta, impõe-se a decretação de improcedência do pedido, em atenção à primazia do mérito (CPC, arts. 4º e 488).

O interesse processual é conferido ao possuidor que sofrer ameaça, turbação ou esbulho em sua posse. No tocante à legitimidade passiva, o art. 339, §§ 1º e 2º, admite a correção após a resposta, ocasião na qual o autor poderá substituir o réu no pólo passivo, nele incluindo o terceiro indicado pelo demandado, ou poderá manter o réu originariamente indicado, adicionando o terceiro em litisconsórcio passivo.

Será legitimado ativo para propor ação possessória aquele que tiver sofrido o esbulho, a turbação ou a ameaça. Havendo composses, o compossuidor agredido poderá se valer dos interditos contra aquele que o agrediu. Se o agressor for terceiro não compossuidor, qualquer um dos compossuidores poderá ajuizar a demanda possessória, ressalvada a hipótese em que a composesse seja exercida pelos cônjuges, ocasião na qual ambos deverão promover a demanda possessória. Portanto, exceto na composesse realizada por cônjuges, haverá litisconsórcio ativo facultativo.

Essa conclusão decorre já do art. 1.199 do CC/2002, dispositivo a assegurar a cada um dos compossuidores o exercício de “atos possessórios”, expressão que abriga a possibilidade de ajuizamento das ações possessórias. Ademais, o art. 1.314 do CC/2002 reforça essa conclusão, ao autorizar cada condômino a defender sua posse sobre a coisa.²⁷⁶ À época de vigência do CPC/1973 essa posição foi abrigada na jurisprudência e não há razão para que seja modificada sob o novo código.²⁷⁷ Caso o compossuidor pretenda integrar a relação processual já instaurada, deverá participar do processo na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do Código de Processo Civil de 2015.

O art. 1.197 do CC/2002 autoriza que o possuidor direto promova ação possessória contra o indireto. Será possível que ocorra o oposto, sendo ajuizada ação possessória pelo possuidor indireto contra o possuidor direto. É o que aconteceria quando vencesse o termo de estipulação de direito real de habitação (art. 1.414 do CC/2002). Notificado sobre o vencimento o possuidor direto se tornaria possuidor injusto, sendo lícito ao possuidor indireto ajuizar ação de reintegração de posse. Evidentemente seria possível o ajuizamento de ação reintegratória pelo possuidor indireto contra terceiro que espoliasse a posse.

Segundo o art. 73, § 2º, do CPC/2015, só haverá litisconsórcio, ativo ou passivo com o cônjuge, se a agressão à posse for por ambos perpetrada ou quando se tratar de composesse. Isso significa que se marido e esposa forem compossuidores, a agressão à posse ensejará a propositura de ação

possessória em litisconsórcio ativo necessário, excluindo a regra geral de litisconsórcio ativo facultativo. Caso marido e esposa pratiquem a agressão ou a ameaça, contra ambos, em litisconsórcio passivo necessário, deverá ser ajuizado o interdito.

Quanto à legitimidade passiva, deverá figurar como réu quem tiver praticado o ato de ofensa ou ameaça à posse. Contudo, o art. 1.212 do CC/2002 permite que a ação de reintegração de posse ou indenizatória seja proposta contra o terceiro que recebeu o bem espoliado consciente da violência.²⁷⁸ Obviamente o dispositivo, ao pressupor o esbulho, aplica-se somente à ação de reintegração, pois nas hipóteses de turbacão e de ameaça, a propiciarem respectivamente a propositura de ação de manutenção e o ajuizamento de interdito proibitório, inexistente perda da posse.

Embora o art. 1.212 do CC/2002 pareça estabelecer uma liberalidade em relação à legitimidade passiva, como se o autor pudesse escolher contra quem ajuizar a demanda, a compreensão correta do dispositivo impõe que a ação possessória seja proposta contra aquele que recebeu e no momento está com o bem esbulhado, sendo possível intentar a ação indenizatória contra o esbulhador e todo aquele que tiver recebido a coisa sabendo de sua origem viciosa.²⁷⁹

Além da ação indenizatória decorrente de perda da coisa, pode haver litisconsórcio passivo na hipótese de cumulação simples entre os pedidos de reintegração de posse e de indenização. Tendo o bem esbulhado sido repassado a terceiro, este será o réu em relação ao pedido possessório, mas o indenizatório poderá ser proposto contra aquele que praticou o esbulho e contra quem recebeu o bem esbulhado consciente da violência.

Com o falecimento daquele que fora esbulhado ou turbado, é inequívoca a legitimidade do espólio para o ajuizamento dos interditos²⁸⁰. Contudo, é de se salientar que os herdeiros terão legitimidade concorrente com o espólio para a propositura de ação possessória até que os bens sejam partilhados, o que decorre da *saisine*, prevista no art. 1.784 do CC/2002, e resulta ainda do art. 1.207 do mesmo diploma legal.²⁸¹

A tônica deve ser a maior efetividade da proteção jurisdicional da posse. A restrição da legitimidade ativa ao espólio é atécnica, pois os herdeiros são compossuidores a partir da abertura da sucessão, como resultado do condomínio que entre eles se estabelece. Ademais, limitar a legitimidade ativa ao espólio poderia inviabilizar a mais adequada proteção possessória, impedindo os herdeiros de defenderem, mediante emprego dos interditos, a posse adquirida a partir do falecimento do *de cujus*. Assim, aberta a sucessão, os herdeiros terão legitimidade para ajuizar as ações possessórias antes ou depois da nomeação de inventariante. Caracteriza-se hipótese de legitimidade ativa concorrente entre o espólio e cada um dos herdeiros. A jurisprudência erigida ante o CPC/1973 adotou este entendimento, o qual deve ser mantido sob o código vigente.²⁸²

3. Intervenção de terceiros

No CPC/1973, quando a demanda fosse proposta contra mero detentor, caracterizava-se a hipótese de intervenção de terceiros denominada nomeação à autoria, cabendo ao réu indicar o proprietário ou possuidor. Ocorria, então, a extromissão, sendo o mero detentor retirado do polo passivo, no qual ingressava o possuidor ou o proprietário. No código vigente é adotada solução mais ampla, aplicável a todas as hipóteses de ilegitimidade passiva, não apenas àquelas relacionadas à mera detenção.

Se o réu invocar sua ilegitimidade, deverá indicar o legitimado passivo, sob pena de suportar as custas processuais e os prejuízos que recaírem sobre o autor em decorrência da omissão (art. 339 do CPC/2015)²⁸³. O autor poderá, em quinze dias, substituir o réu (art. 338,²⁸⁴ *caput*, CPC/2015) ou incluir como litisconsorte passivo o terceiro por ele indicado (art. 339, § 2.º, CPC/2015²⁸⁵).

Destarte, se for ajuizada ação de reintegração de posse contra o mero detentor, este deverá indicar quem é o possuidor ou proprietário, cabendo ao autor corrigir o polo passivo da demanda.

A ação reintegratória deve ser ajuizada contra quem possui o bem, não contra aquele que meramente o detém.

Se o autor cumular ao pedido de reintegração o de indenização por perdas e danos (art. 555, I, do CPC/2015), aquele, que tiver praticado o esbulho na condição de empregado ou preposto do possuidor ou do proprietário, não poderá ser excluído do polo passivo da demanda em razão do disposto no Código Civil, arts. 186,²⁸⁶ 927²⁸⁷ e 932, III.²⁸⁸ Os dispositivos estabelecem responsabilidade solidária entre o empregador e seus prepostos, de modo que não poderá ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva eventualmente formulada pelo empregado que tiver praticado o esbulho. O empregado e seu patrão terão de ressarcir solidariamente os prejuízos causados ao espoliado.

Já foi visto que se o terceiro recebeu o bem sabendo da violência que o maculava, contra ele deverá ser ajuizada a ação de reintegração de posse, conforme dispõe o art. 1.212 do CC/2002. Se o terceiro tiver recebido o bem sem conhecer sua origem viciosa deverá alegar a ilegitimidade passiva, nos termos do art. 339 do CPC/2015, indicando aquele que lhe transmitiu o bem ou a posse. O Enunciado 80 aprovado na Primeira Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal endossa esse posicionamento.²⁸⁹

O Código Processual revogado previa a denunciação da lide ao proprietário ou ao possuidor indireto no art. 70, II, do CPC/1973. O dispositivo autorizava a denunciação da lide quando o possuidor direto fosse citado em nome próprio, em hipóteses como a do usufrutuário, do credor pignoratício ou do locatário. O rol era meramente exemplificativo.

A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros provocada, na qual o denunciado é citado pelo autor ou pelo réu, em demanda antecipada e eventual de caráter indenizatório, simultaneamente à sua participação na condição de litisconsorte do denunciante na demanda principal. O denunciado é réu na ação regressiva que constitui a denunciação da lide, mas também é litisconsorte do denunciante na demanda principal.

À medida que o CPC/2015, no art. 125, indica a possibilidade de denunciação da lide apenas para a obtenção de indenização pela evicção (inc. I) e para exercício de direito de regresso (inc. II), não mais aludindo à hipótese de denunciação pelo possuidor direto ao indireto ou ao proprietário, poder-se-ia supor que a previsão do art. 70, II do Código revogado, não encontraria ressonância no novo diploma. Isso, contudo, não é correto.²⁹⁰ Ocorre que a denunciação da lide ao possuidor indireto ou proprietário nada mais é que uma especificação da hipótese mais genérica de denunciação como exercício, no mesmo processo, de ação regressiva, conforme reconhecia a doutrina durante a vigência do código anterior.²⁹¹ Assim, a hipótese abrigada no art. 70, II, do CPC/1973 está compreendida no art. 125, II, do código vigente.

É certo que ao ajuizar a denunciação da lide o denunciante tenciona obter o ressarcimento dos prejuízos que podem decorrer da ação que contra ele foi ajuizada, de modo que a hipótese prevista no art. 70, II, sempre esteve incluída no caso mais amplo de ação regressiva, previsto no art. 70, III, do Código anterior e no art. 125, II, do CPC/2015.

Caberá a denunciação da lide sempre que o possuidor direto desejar se ressarcir contra o possuidor indireto dos prejuízos ocasionados pela propositura de ação reintegratória contra si. Suponha-se que o denunciante tenha celebrado contrato de arrendamento de terra com o denunciado.²⁹² Diante da propositura de ação de reintegração de posse, o denunciante pode vir a sofrer sérios prejuízos, razão pela qual desde logo faz a denunciação da lide ao arrendante denunciado, para que ele seja condenado a reparar os prejuízos que advirão na hipótese de procedência da ação possessória. Note-se que não resultaria qualquer diferença prática caso se concebesse a hipótese de denunciação da lide ao possuidor indireto como modalidade abarcada pela denunciação nas hipóteses de evicção (art. 125, II, do CPC/2015).

A oposição era caracterizada pelo código anterior como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 56 a 61). No código vigente foi caracterizada como procedimento especial (arts. 682 a 686). É modalidade de intervenção espontânea, na qual o terceiro propõe demanda contra o autor e o réu

do processo originário, a fim de que o bem seja atribuído em seu favor. A oposição poderá se relacionar com ação possessória quando o terceiro se considerar legítimo possuidor do bem. Será, então, o instrumento por meio do qual o terceiro exercerá sua pretensão reivindicatória ou mesmo possessória.²⁹³

Poder-se-ia questionar a possibilidade de o terceiro ajuizar ação petitória na pendência de demanda possessória, em razão da vedação contida no art. 557 do CPC/2015. A jurisprudência erigida ante o CPC/1973 rejeitava firmemente a possibilidade de terceiro propor oposição, fundamentando-se na propriedade, enquanto pendesse litígio possessório entre terceiros sobre o mesmo bem. Baseava-se, para tanto, no art. 923 do código revogado.²⁹⁴ Todavia, o art. 557 traz significativa ressalva em relação ao art. 923 do código anterior. Na parte final do dispositivo, lê-se que a pretensão petitória poderá ser deduzida contra terceiro. Sendo assim, terceiros também poderão propor demandas petitórias enquanto pender ação possessória sobre o mesmo bem. Não seria coerente que o código permitisse a propositura de demandas petitórias contra terceiros, por um dos litigantes na ação possessória, mas proibisse que terceiro propusesse demanda petitória tendo como objeto o mesmo bem.

Desse modo, por força da exceção contida na parte final do art. 557 do CPC, admite-se que terceiro promova oposição, fundada no direito de propriedade, contra os litigantes na ação possessória. A jurisprudência sobre o tema deve ser modificada com a vigência do CPC/2015.

A assistência simples (CPC, art. 121), praticada por terceiro juridicamente interessado, também será possível no âmbito das ações possessórias. Embora não seja proibida, a assistência litisconsorcial (CPC, art. 124) raramente ocorrerá nos interditos. A premissa para essa forma de intervenção espontânea é a influência da sentença na relação jurídica havida entre o assistente e o adversário do assistido. Sem que haja relação entre o assistente e o adversário do assistido essa modalidade de intervenção não pode se concretizar. Pois bem. Imagine-se que “Ricardo”, proprietário do imóvel, celebre contrato de arrendamento do mesmo imóvel com “Alexandre” e “José”. Com o primeiro, estipula-se prazo de um ano, no qual ocupará a terra em composses com “José”. Com este, avença-se prazo de dois anos. No primeiro, ocupará o imóvel em composses com “Alexandre”, passando a fruí-lo individualmente a partir do início do segundo ano. Se, passado um ano, “Alexandre” não se retira do imóvel, dá ensejo à propositura de reintegração de posse por “José”. Nesse caso, “Ricardo” poderá ingressar na demanda como assistente litisconsorcial de “José”, pois a sentença repercutirá na relação jurídica entre o assistente (“Ricardo”) e “Alexandre” (adversário do assistido). A permanência de “Alexandre” caracteriza esbulho e justifica, por exemplo, a cobrança de multa eventualmente estipulada no contrato para a hipótese de infração do prazo de arrendamento. Essa hipótese demonstra que a assistência litisconsorcial em tese será admissível, embora na maioria dos casos ocorra assistência simples.

4. Valor da causa

O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor. Ocorre que nas ações possessórias o pedido imediato é a proteção à posse, compreendida como o exercício de poder fático sobre a coisa. O valor da causa, portanto, não corresponde ao valor do bem, pois a posse não se confunde com a propriedade. À falta de dispositivo para disciplinar a questão, ante o código revogado, a jurisprudência se pacificou no sentido de que o valor da causa nas ações possessórias equivale ao “benefício patrimonial pretendido pelo autor”.²⁹⁵

Ao assentar a correspondência entre valor da causa e benefício econômico perseguido pelo autor, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o caráter casuístico da valoração da causa nas ações possessórias, pois é evidente que este benefício deverá ser verificado à luz dos elementos do caso concreto.

O CPC/2015 também não disciplinou especificamente a matéria, de modo que a orientação firmada sob o código anterior deve ser mantida. Se houver cumulação de pedidos (CPC, art. 555), o autor deverá indicar como valor da causa a soma dos pedidos, nos termos do art. 292, VI.²⁹⁶ O mesmo artigo permite que o juiz corrija o valor da causa *ex officio*, mediante arbitramento,

determinando ao autor o recolhimento das custas, possibilidade de atuação não prevista expressamente no código anterior.²⁹⁷

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

1. *Liminar possessória: requisitos*

Para interpretar esse dispositivo corretamente é preciso destacar que sua inserção ocorreu na Seção II do Capítulo III, na qual é disciplinado o procedimento especial das ações possessórias, típico das ações de força nova, ou seja, daquelas ajuizadas em até um ano e um dia da ofensa à posse. O descumprimento dos requisitos não ensejará a improcedência da demanda, mas apenas o indeferimento da liminar, o qual não poderá ocorrer sem que antes seja realizada audiência justificatória (CPC, art. 562). É digno de nota que o dispositivo faz menção aos requisitos que deverão ser *provados* pelo autor, de modo que não bastará a mera narrativa quanto à existência de posse e a agressão em prazo igual ou inferior a ano e dia.

Evidentemente, se o autor não invocar a posse e deixar de alegar a violação, caracterizar-se-á hipótese de inépcia da petição inicial, por falta de causa de pedir, nos termos do art. 330, I, e § 1.º, I do CPC/2015.²⁹⁸ Há, aqui, duplo enquadramento legal, pois ao não invocar a posse e deixar de alegar a violação, o demandante também dá azo ao indeferimento da inicial, em razão da falta de interesse (CPC, art. 330, inc. III). Na prática, contudo, será rara tamanha incúria do autor na elaboração da inicial da ação possessória.

Quando se menciona que o art. 561 do CPC/2015 se aplica às ações de força nova, evidentemente não se está afirmando que nas ações possessórias ajuizadas após ano e dia da violência não seja necessário comprovar a posse e sua perda, na demanda de reintegração, ou a posse e a turbação, na demanda de manutenção. O autor, mesmo nas ações que tramitem pelo procedimento comum, terá de comprovar sua posse e a agressão. O dispositivo em análise, entretanto, indica os requisitos para o deferimento da liminar possessória, aplicando-se às ações de força nova, assim entendidas aquelas cuja agressão tenha ocorrido em até um ano e um dia da propositura da demanda.

Saliente-se que a concessão de liminar possessória, nas ações de força nova, não pressupõe urgência. Assim, desde que cumpridos os requisitos elencados no art. 561, impõe-se o deferimento da liminar possessória, sendo inexigível a prova da urgência e do risco de dano.²⁹⁹ O que torna especial o procedimento de reintegração de posse é justamente a possibilidade de deferimento da liminar sem que seja necessário verificar a urgência e a verossimilhança nos moldes do art. 300 do CPC/2015.

O art. 1.211 do CC/2002 estabelece regra de julgamento para a hipótese de manutenção de posse.³⁰⁰ De acordo com o dispositivo, quando mais de uma pessoa se disser possuidora, a posse será mantida com quem tiver a coisa, salvo se se comprovar que a obteve de modo vicioso. É usual, nas disputas judiciais pela posse, que ambos os litigantes se afirmem possuidores. Havendo dúvida sobre as alegações do autor, o juiz deve designar audiência justificatória. Se ainda assim permanecer em dúvida, aplica-se a regra de julgamento presente no art. 1.211 do CC/2002, mantendo-se provisoriamente na posse da coisa o litigante que nela estiver.³⁰¹

Não se pode vislumbrar no referido dispositivo a referência ao *possessorium sumarissimum*, apesar da opinião em sentido contrário de prestigiosa doutrina.³⁰² A presença do instituto, a

propósito, sempre foi alvo de contundentes questionamentos.³⁰³ Com efeito, para a proteção da posse na hipótese de turbacão, está prevista a demanda de manutenção, na qual a cognição se restringirá à matéria possessória. Para a mais rápida tutela do direito, concede-se a possibilidade de deferimento de liminar possessória, a fim de que o autor turbado seja mantido na posse. Não será possível, portanto, com fundamento em um dispositivo, supor a existência de outro procedimento destinado a tutelar a posse. Aliás, já não o era mesmo antes da edição do Código Civil de 1916, conforme indicam as eruditas lições de Antônio Joaquim Ribas.

A regra trazida pelo art. 1.211, destarte, deve ser vista como orientação ao juiz nas hipóteses em que, mesmo após a realização de audiência justificatória, não estiver convencido sobre quem deve ser mantido na posse. Em razão do estado de dúvida, convém manter provisoriamente na posse o litigante que nela estiver, conforme assenta a regra de julgamento prevista no art. 1.211 do CC/2002.

Note-se que a aplicação do dispositivo será rara e somente ocorrerá se o juiz não estiver convencido pelas alegações do autor, nem mesmo após a audiência de justificação, tampouco se convencendo sobre a impertinência das razões do demandante. Para resolver o estado de dúvida, o sistema de proteção possessória outorga ao juiz uma regra de julgamento, indicando que deve ser mantido na posse, ainda que em caráter provisório, aquele que a exercer. Tratando-se de interdito de manutenção, quem exerce a posse é o autor, pois não houve esbulho a acarretar a perda da posse, mas prática de ato turbativo.

2. *Caráter sumário: pronunciamento jurisdicional restrito à posse*

O art. 561 reforça a caracterização das ações possessórias como sumárias no tocante à matéria discutida, de modo que o autor não poderá controverter sobre a propriedade ou sobre direito à posse.³⁰⁴ A cognição do juiz ficará restrita ao *jus possessionis*, sendo irrelevantes alegações quanto ao *jus possidendi*. O autor deve alegar a posse, compreendida como o poder fático que exerce sobre a coisa. Esta é a causa de pedir. Alegações relacionadas à propriedade ou a contratos que tenham como objeto o direito à posse não viabilizam a tutela possessória. Reitere-se: o código processual vigente reforçou a proibição da exceção de domínio (art. 557, parágrafo único), fazendo coro ao que já dispunha o art. 1.210, § 2.º, do CC/2002.

Poder-se-ia questionar o acerto dessa afirmação ao argumento de que é comum nas ações possessórias juntar a certidão de matrícula do imóvel objeto do litígio ou o contrato de arrendamento que outorga a posse imediata ao autor. Ocorre que ao juntar esses documentos e se referir ao direito o autor não está litigando sobre a posse com fundamento na propriedade,³⁰⁵ mas apenas corroborando sua alegação referente à posse. O que interessa é a caracterização da posse como causa de pedir. O autor alegará sua condição de possuidor, eis que pode exercer, plenamente ou não, algum dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade (art. 1.196 do CC/2002).

Mesmo quando juntar aos autos a matrícula de registro imobiliário, o autor não invocará sua condição de proprietário, questão que não pode ser apreciada no âmbito da ação possessória. Alegará, isso sim, que é possuidor, pois pode exercer poder sobre a coisa com vistas a dela obter proveito econômico, circunstância que é corroborada pela matrícula imobiliária. A propriedade do bem não será discutida na ação possessória e não pode ser considerada como questão prejudicial à posse. Indicar o domínio em uma ação possessória apenas servirá para reforçar as alegações concernentes ao exercício de poder fático sobre a coisa com vistas ao seu aproveitamento econômico.

É bastante esclarecedor perceber que os arts. 1.210, § 2.º do CC/2002 e 557, parágrafo único, do CPC/2015 permitem a reintegração, a manutenção de posse ou a concessão de interdito proibitório contra o proprietário. Se o autor comprovar sua posse, será irrelevante a alegação de ser ele o legítimo proprietário do bem, pois na seara possessória é sobre a posse que se discute. Entendimento contrário subverteria todo o sistema de tutela jurisdicional da posse e traria ainda o grave inconveniente de permitir que o pronunciamento judicial sobre a propriedade, compreendida então como questão prejudicial, faria coisa julgada, nos termos do art. 503, § 1.º, do

3. Bens objeto das ações possessórias

Já se viu que a posse se restringe às coisas corpóreas. Todavia, essa categoria abrange não apenas os bens que podem ser tocados, conforme preconizava antiga definição romana, mas também aqueles que podem ser percebidos pelos sentidos, como as energias e forças da natureza, de modo que a energia elétrica, gases e vapores podem ser objeto de proteção possessória desde que tenham sido integrados à esfera jurídico-patrimonial de quem os utiliza.³⁰⁷

O art. 83, I, do CC/2002, ao classificar as energias que tenham valor econômico como bens móveis, torna clara a possibilidade de posse de energias. Trata-se de decorrência lógica. É óbvio que se as energias são bens móveis e os bens móveis são passíveis de propriedade, há então posse de energias, pois a posse nada mais é que a possibilidade de exercício de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC/2002).

Seria lamentável anacronismo, a revelar incompreensão sobre a função da posse, a restrição da proteção possessória somente às coisas tangíveis, que podem ser tocadas. A posse tem como objetivo assegurar o melhor aproveitamento econômico do bem. Trata-se de instituto jurídico fortemente ligado à realidade social, com seus avanços tecnológicos e intensas trocas comerciais. Por isso a limitação da posse às coisas tangíveis implicaria restrição desarrazoada ao alcance de um instituto que há milênios vem amparando o homem e facilitando a vida em sociedade.

Defender que bens passíveis de apreensão pelo sentido são coisas corpóreas para efeito de proteção possessória não equivale a sustentar a possibilidade de posse de direitos. A ideia da posse de direitos tinha como objetivo permitir a rápida proteção de direitos carentes de tutela. Reconhece-se, porém, que desde as reformas do CPC/1973, que resultaram na inserção de medidas coercitivas e executivas para o cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, tornou-se desnecessário defender a possibilidade de posse sobre direitos, de modo que pretensões relacionadas a direitos autorais, propriedade industrial e intelectual são tuteláveis por meio de técnicas previstas no procedimento comum.³⁰⁸ A Súmula 228 do STJ, já citada no item 2.1 da Introdução, corrobora esse entendimento, considerando o interdito proibitório inadmissível para a tutela do direito autoral.

Também é possível a proteção possessória de servidões aparentes e das não aparentes quando os títulos se originarem do possuidor do prédio serviente ou daquele de quem este os obteve, conforme assinala o art. 1.213 do CC/2002. O STF, à época em que ainda decidia sobre direito infraconstitucional federal, editou a Súmula 415, já indicada no item 6 da Introdução, segundo a qual servidões de trânsito não tituladas, mas tornadas permanentes em virtude de obras realizadas, são passíveis de proteção possessória. O STJ, por meio da Súmula 193, permitiu a usucapião de linhas telefônicas, como visto no item 1.5 da Introdução, no qual se discutiu a respeito do objeto da posse.

4. Prova da posse e da data de turbação ou do esbulho

O art. 561, nos incs. I e III, determina que o autor comprove a posse e a data da turbação ou do esbulho. É óbvio que se não houver comprovação da posse não poderá ser deferida a liminar pleiteada pelo autor. O juiz, contudo, não julgará a demanda antecipadamente, mas determinará a realização de audiência de justificação (art. 562 do CPC/2015) e, posteriormente, prosseguirá com a instrução probatória.

Quanto à data da turbação ou do esbulho, já foi visto que o art. 558 estabelece o prazo de ano e dia para que a demanda tramite pelo procedimento especial. A prova da data da agressão é, portanto, elemento indispensável para o juiz verificar a possibilidade de concessão de liminar. Se não estiver convencido sobre o momento da agressão, deverá, antes de indeferir a liminar, designar audiência de justificação (art. 562 do CPC/2015).

Na ação de reintegração deverá ser considerada a data da perda da posse, que ocorre, nos termos do art. 1.223 do CC/2002, quando o autor deixa de exercer poder fático sobre a coisa. Não será deflagrado o prazo, todavia, quando o autor não tiver presenciado o esbulho. Nesse caso, a contagem só se iniciará quando o ausente não tentar recuperar a posse perdida depois de devidamente informado sobre o esbulho (art. 1.224 do CC/2002). O termo inicial será a data em que o autor soube da agressão.

Havendo continuidade entre os atos de perturbação da posse, o prazo de ano e dia para o ajuizamento da ação de manutenção será contado a partir do primeiro ato. Se houver pluralidade de atos sem vínculo entre si, a cada nova turbacão se inicia a contagem do prazo de ano e dia, conforme se viu mais detalhadamente nos comentários ao art. 558 do CPC/2015.

Ultrapassado o prazo de ano e dia da agressão, não é juridicamente possível a concessão de liminar sem que se verifique o perigo de dano. Já foi visto que nas ações de força velha o autor terá de comprovar os requisitos do perigo de dano e da urgência, elencados no art. 300 do CPC/2015. A tutela provisória também poderá ser obtida com base na evidência, desde que comprovados os requisitos indicados no art. 311, I e IV.

Para evitar a designação de audiência de justificação (art. 562 do CPC/2015), a comprovação da posse terá de ocorrer mediante prova documental, como por exemplo fotografias, notas fiscais de produtor rural, faturas de energia elétrica e telefone e boletins de ocorrência lavrados perante a autoridade policial. Documentos comprobatórios da propriedade, como a certidão de matrícula do imóvel e o certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, serão apenas corroborativos e não permitirão discussão sobre a propriedade.

É ainda bastante comum na prática o emprego de provas documentadas, de que são exemplos os termos de declaração lavrados perante notários. Todavia, embora seu uso esteja disseminado, é necessário advertir que se trata de fonte com escasso valor probatório, pois produzida sem contraditório.³⁰⁹ O juiz jamais poderá conceder a liminar fundamentando-se exclusivamente nesses termos de declaração. O comparecimento perante o tabelião nada mais prova que o fato de o declarante ter se dirigido a um tabelionato para prestar suas declarações. A previsão da ata notarial como prova típica, no art. 384, não modifica o enquadramento da questão.³¹⁰ Estando em dúvida o juiz, impõe-se a realização de audiência justificatória (art. 562 do CPC/2015).

Também será possível que o autor apresente prova produzida em outro processo. Trata-se meio de prova indicado no art. 372 do CPC/2015. Embora não previsto expressamente no código revogado, era amplamente utilizado sob sua vigência.³¹¹ A prova produzida no processo anterior é levada ao segundo processo sob a forma de documento, mas preserva sua natureza original.³¹² Essa é a particularidade da prova emprestada, que poderá ser utilizada contra quem tiver participado do processo anterior. É possível imaginar que sejam juntados laudos periciais e provas orais produzidas no primeiro processo, úteis para a demonstração da posse do autor.

5. Esbulho ou turbacão, perda ou continuidade da posse

Nos incs. II e IV, o art. 561 do CPC/2015 determina que o autor comprove a turbacão e seu prosseguimento na posse ou o esbulho e a perda da posse. Em ambos os casos deve ser aplicada a fungibilidade prevista no art. 554, *caput*. Desse modo, embora o autor alegue esbulho, se a prova indicar a ocorrência de turbacão o juiz deverá deferir liminar para a manutenção. E o oposto também é verdadeiro. Poderá o réu ter narrado turbacão, tendo na verdade ocorrido ato espoliativo. Deverá o juiz, nesse caso, deferir a liminar reintegratória. Não comprovados o esbulho ou a turbacão, a improcedência da demanda é medida que se impõe.³¹³

Não é relevante que o descompasso entre a situação narrada e aquela verificada na prática decorra de modificação posterior nos fatos ou de equívoco na narrativa do autor. A tutela jurisdicional efetiva e adequada pressupõe ampla fungibilidade entre os pedidos típicos de proteção à posse.

6. Competência nas ações possessórias imobiliárias

Tratando-se de ações possessórias imobiliárias, o juízo do foro de situação da coisa detém competência absoluta, conforme assenta o art. 47, § 2.º, do CPC/2015.³¹⁴ Tratando-se de demanda que tenha bem móvel por objeto, a propositura deve ocorrer, em regra, no foro de domicílio do réu, conforme aponta o art. 46, *caput*, do CPC.³¹⁵

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

1. Concessão da liminar inaudita altera parte

O art. 562 reproduz com ligeira modificação o art. 928 do CPC/1973. Criticou-se, ante o código revogado, a expressão “petição inicial devidamente instruída”, reiterada no dispositivo em comento, pois ela remeteria à necessidade de documentos indispensáveis à propositura da demanda, como por exemplo a procuração.³¹⁶ Correta a crítica, pois em vez de “devidamente instruída”, deveria o legislador utilizar expressão que se referisse à comprovação dos requisitos do artigo anterior.

A despeito do problema redacional, é nítido que o artigo em análise permite o deferimento de liminares nas ações de manutenção e de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, quando a petição inicial contiver documentos capazes de convencer o juiz sobre a violência e a necessidade de proteção do autor. Trata-se de notável e expressa exceção ao art. 9.º do CPC/2015, que não poderá ser invocado a fim de que o réu seja ouvido previamente à concessão de liminar.

Como já visto nos comentários ao artigo precedente, a prova coligida com a inicial só pode ser documental ou documentada, como fotografias, faturas de energia elétrica, água e telefone, notas fiscais de produtor rural, mapas, plantas e prova emprestada de outro processo. A certidão do imóvel e o cadastro de imóvel rural são provas referentes à propriedade e seu valor probatório é apenas corroborativo. O autor poderá ainda se utilizar de prova emprestada e de ata notarial. Em resumo, todas as provas lícitas são admissíveis, cabendo ao juiz avaliá-las em cada caso.

2. Audiência justificatória

Não são raros os casos em que o juiz desde logo profere a medida liminar apta a tutelar a posse com base nos elementos probatórios trazidos na inicial. Todavia, se não estiver convencido sobre as alegações do autor, deverá, antes de indeferir a liminar, designar a realização de audiência justificatória.

Ante o código anterior a solução não era pacífica na doutrina, havendo voz autorizada a defender a necessidade de requerimento expresso do autor, sob pena de indeferimento da liminar, quando os documentos trazidos com a inicial fossem insuficientes para convencer o juízo.³¹⁷ O argumento se baseava no art. 930 do CPC/1973, reproduzido no art. 564 do código vigente, a preceituar que o autor promoverá a citação do réu em cinco dias “concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração”.

A posição majoritária, contudo, apegava-se à letra do próprio art. 928 do CPC/1973, cujo conteúdo foi reiterado neste art. 562 do CPC/2015, a preconizar a designação de audiência de justificação quando o juiz não estiver convencido pelos documentos trazidos na inicial.³¹⁸ Este é o entendimento correto e deve ser adotado sob a vigência do novo código. O art. 562 do CPC/2015 utiliza expressão peremptória – “caso contrário” – para destacar a necessidade de designação de audiência se o juiz não estiver convencido pelos documentos coligidos com a inicial.

E certo que o art. 564 do CPC/2015 – art. 930 do CPC/1973 – faz referência ao deferimento ou indeferimento da liminar, empregando a expressão “concedido ou não o mandado liminar”. Note-se, contudo, que a liminar pode ser deferida ou indeferida depois da realização da audiência. O art. 564 deve ser interpretado conjuntamente com o art. 562, daí resultando a conclusão quanto à necessidade de audiência de justificação quando o juiz não estiver convencido pelos documentos trazidos com a inicial. O requerimento específico do autor para que se realize a justificação não é relevante. Saliente-se que esse era o entendimento prevalecente na jurisprudência erigida sob o CPC/1973, inexistindo motivo para que seja alterado sob o código vigente.³¹⁹ O ato jurisdicional que designa a audiência justificatória é destituído de eficácia decisória, não cabendo contra ele a interposição de recurso.³²⁰

Nos termos do art. 1.211 do CC/2002, se mesmo depois da realização de audiência justificatória o juiz não estiver convencido sobre as alegações do autor, deverá mantê-lo na posse. Trata-se de regra de julgamento, a ser aplicada somente nos casos em que, mesmo depois da audiência justificatória, o juiz ainda não esteja convencido. Isso significa que se as provas demonstrarem a posse e a turbacão, o juiz deferirá a liminar de manutenção requerida pelo autor. Se as provas, inclusive aquelas produzidas na audiência justificatória, não convencerem o juiz sobre quem seja o possuidor, haverá de manter provisoriamente na posse o autor, ou seja, aquele que a exerce no momento de ajuizamento da demanda. Trata-se de hipótese em que a posse não foi perdida, pois não houve esbulho, mas turbacão, conservando-se o bem na esfera jurídica daquele que fora agredido.

3. Citação e atuação limitada do réu na audiência justificatória

O art. 562 menciona a citação do réu para comparecer à audiência justificatória. O ideal é que seja expedido mandado citatório em conformidade com os arts. 562 e 564, parágrafo único. Este dispositivo assinala que a contagem de prazo para contestação, quando for designada a audiência, iniciar-se-á da intimação da decisão de deferimento ou indeferimento da liminar, que ocorrerá em nome do advogado constituído pelo réu. Por esse motivo a citação a que alude o art. 562 deve ocorrer mediante expedição de mandado que cumpra todos os requisitos exigidos pelo código (art. 250 do CPC/2015), havendo menção ao início do prazo para resposta e às consequências da revelia.³²¹ No mesmo mandado haverá citação e intimação para o comparecimento à audiência justificatória.

Caso conste no mandado expedido com fundamento no art. 562 somente referência à audiência justificatória, terá havido apenas intimação para comparecimento à audiência, impondo-se então a expedição de novo mandado após o deferimento ou indeferimento da liminar, sendo insuficiente a mera intimação prevista no art. 564, parágrafo único.³²²

Em resumo, sendo realizada citação mediante expedição de mandado que atenda aos requisitos do art. 250, e comunique o réu sobre a audiência justificatória, após o deferimento ou indeferimento da liminar, bastará a intimação em nome do advogado para que se inicie o prazo de apresentação da resposta. Essa intimação pode ocorrer na própria audiência justificatória. Se o réu não tiver advogado, impõe-se sua intimação pessoal. Se o primeiro mandado tiver se limitado a convocar o comparecimento do réu para a audiência de justificação, terá de ser expedido novo mandado de citação por ocasião do deferimento ou indeferimento da liminar possessória.³²³

Para delimitar a atuação do réu na audiência justificatória é preciso compreender que se trata de ato processual designado com o objetivo de permitir que o autor faça prova de sua posse e da agressão, a fim de que seja deferida a liminar em seu favor. O réu não poderá oferecer resposta, nem produzir provas ou arrolar testemunhas. Limitar-se-á a contraditar as testemunhas e a lhes fazer reperguntas.³²⁴ Esclareça-se que reperguntas não são novas perguntas, mas somente questões relacionadas a pontos obscuros ou contraditórios das declarações prestadas em juízo.³²⁵

Nessa fase do procedimento o juiz não tem poder probatório, podendo apenas colher a prova cuja produção foi expressamente requerida pelo autor.³²⁶ Isso, contudo, não constitui violação ao art. 370 do CPC/2015. A atividade probatória se restringe a permitir a formação de juízo sobre o

deferimento ou indeferimento da liminar. Posteriormente, após a apresentação de resposta e consequente tramitação do processo segundo o procedimento comum, será possível que o juiz se valha de seus poderes instrutórios.

Discutia-se, sob o código revogado, a respeito da possibilidade de conciliação na audiência justificatória.³²⁷ Crê-se que o juiz, no início do ato, pode recomendar a conciliação, esclarecendo as partes sobre as vantagens da composição amigável de conflitos. Esse entendimento conta com o respaldo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º³²⁸ e 139, V,³²⁹ ambos do CPC/2015.

Saliente-se que nas ações de força nova não será adequada a designação da audiência prevista no art. 334³³⁰. Seria possível supor, em um primeiro momento, que a designação só estaria proibida durante a fase especial do procedimento, ou seja, até a apresentação de resposta. Ocorre que a audiência de conciliação ou de mediação deve ocorrer antes que o réu responda, de modo que há insuperável obstáculo para a sua realização nas ações possessórias especiais. Com efeito, não há espaço no iter procedimental para que a audiência de conciliação seja designada. O mesmo não ocorre em relação às ações de força velha individuais, cuja tramitação seguirá o procedimento comum, embora seja mantida a sumariada material, com a proibição de discussão sobre a propriedade (CPC, art. 558, parágrafo único).

É evidente que a incompatibilidade procedimental, a inviabilizar a designação da audiência disciplinada no art. 334 nas ações de força nova, impede que a contestação seja oferecida no prazo preconizado pelo art. 335, I, do CPC/2015.³³¹ Sendo impertinente a designação da audiência, seria incogitável levá-la em consideração para a contagem de prazo para resposta, a qual deve atender ao disposto no art. 564, *caput* e parágrafo único, dispositivo que realça o caráter especial do procedimento nas ações de força nova.

Nas ações de força velha a incidência do procedimento comum (CPC, art. 558, parágrafo único) autoriza a aplicação do art. 334 do CPC/2015, de modo que o prazo para apresentar resposta é disciplinado no art. 335, I, à medida que deve ser realizada a audiência de conciliação ou de mediação.

Às ações coletivas de força velha se aplica o art. 565, dispositivo a prever audiência de mediação com diversos entes públicos. É indiscutível que também nesse caso não é cabível a audiência de conciliação e de mediação indicada no art. 334 do Código. Os dois atos não são idênticos, já que na audiência prevista no art. 565 devem participar entes públicos cuja presença não é exigida no art. 334.

4. *Privilégio das pessoas jurídicas de direito público*

Prevê-se, no art. 562, parágrafo único, lamentável privilégio às pessoas jurídicas de direito público, proibindo-se o deferimento de liminar de manutenção ou de reintegração contra esses entes sem que antes sejam ouvidos no processo. O dispositivo não se aplica ao interdito proibitório, pois assinala que “não será deferida a *manutenção* ou a *reintegração* liminar sem prévia audiência”.

É em dispositivos como este que se percebe a triste herança patrimonialista do Brasil.³³² Menciona-se o patrimonialismo porque o legislador abandonou o critério objetivo em que se pautara no *caput*, segundo o qual é possível o deferimento de liminares possessórias sem a oitiva do réu. Simplesmente se optou por conceder privilégio às pessoas jurídicas de direito público, em desfavor do direito à tutela jurisdicional efetiva e adequada.

Não há fundamento para que a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações, assim como Estados estrangeiros, sejam favorecidos no âmbito das ações possessórias. O arremedo de justificativa consiste na suposição, de todo incorreta, segundo a qual agentes públicos não agiriam intencionalmente com vistas a perpetrar agressões à posse, de modo que antes de proferir liminar de reintegração ou de manutenção, deve o juiz ouvir as pessoas jurídicas de direito público.³³³

Há uma miríade de incorreções nessa tentativa de justificar o que é injustificável. Primeiramente, a violação à posse deve ensejar a mais pronta resposta jurisdicional. Note-se que em regra o juiz já estará convencido sobre a necessidade de deferir a liminar no momento em que determina a oitiva da pessoa jurídica ré. A oitiva apenas adia a efetivação de liminar sobre cuja pertinência o juiz já está convicto. Ademais, a intenção do agente público é irrelevante. A própria Constituição, no art. 37, § 6.º, estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros. Sendo irrelevante para fim de responsabilização, certamente não se pode amparar o privilégio concedido às pessoas de direito público na falta de vontade de seus agentes em causar violações à posse. Agredida a posse, deveria haver imediata reprimenda à agressão. Por fim, a jurisprudência é pacífica ao repudiar a impossibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, interpretando restritivamente o disposto na Lei 9.494/1997.³³⁴ Ora, admitida a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela nesses casos, impõe-se reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo analisado, admitindo-se a reintegração ou manutenção de posse mediante liminar.

A propósito, é frísante a inconstitucionalidade do art. 562, parágrafo único, do CPC/2015. Viola-se, a um só tempo, a isonomia prevista no art. 5.º da Constituição, eis que inexistente razão para o tratamento desigual entre todas as outras partes e as pessoas jurídicas de direito público, e o direito à tutela jurisdicional efetiva e adequada (art. 5.º, XXXV e LXXVIII da CF/1988; art. 4.º³³⁵ do CPC/2015), pois o juiz, convencido do esbulho ou da turbação, é obrigado a aguardar a manifestação do ente público para só então proferir a liminar possessória.

A não ser que seja reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo em exame concentrado de constitucionalidade – o que não se crê que ocorra, pois o art. 928, parágrafo único, do CPC/1973 trazia idêntica disposição, não tendo sido decretada a inconstitucionalidade ao longo dos quarenta e dois anos de vigência – e a menos que o juiz considere inconstitucional o dispositivo em controle difuso, a regra terá de ser aplicada.

É preciso esclarecer que não é necessária a realização de audiência específica para que se ouçam os representantes judiciais. Impõe-se apenas oportunizar a manifestação do ente público, a fim de que sejam indicados os motivos conducentes à impertinência da liminar no caso concreto. É vedado o oferecimento de contestação. Ademais, como no texto do dispositivo não consta qualquer indicação a respeito do prazo, há de se entendê-lo como judicial, a ser deferido pelo juiz caso a caso.³³⁶

Tratando-se de prazo judicial, específico para a manifestação do ente público, não se aplica a contagem dobrada prevista no art. 183, *caput*, do CPC/2015, o que resulta da aplicação analógica do § 2.º do mesmo dispositivo.³³⁷ Não faria sentido observar a contagem dobrada em prazo judicial especificamente concedido para a manifestação da pessoa jurídica de direito público. Ao conceder o prazo, o juiz observa as circunstâncias do caso concreto, de modo que a contagem dobrada violaria a análise judicial. Por analogia, se o juiz deixar de fixar prazo, será aplicado o art. 218, § 3.º, do CPC/2015.³³⁸ Os cinco dias previstos no dispositivo também terão de ser contados sem a dobra prevista no *caput* do art. 183 do CPC/2015.

Se o juiz estiver convencido pelos documentos apresentados na inicial, antes de deferir a liminar possessória deverá assinar prazo ao ente público para que se manifeste apontando as razões conducentes à inviabilidade do deferimento da liminar. Já foi visto, nos comentários ao art. 562, *caput*, que o juiz é obrigado a designar audiência justificatória quando não estiver convencido pelos documentos apresentados na inicial. O ente público deverá, nesse caso, ser citado para comparecer à audiência. Não é necessário que sua manifestação ocorra apenas depois da justificação. O juiz poderá conceder prazo para a entrega de arrazoado antes da audiência. Comparecendo a ela, poderá o réu indicar, à luz das provas coligidas na justificação, as razões que impedem o deferimento da liminar. É desnecessário e seria absurdo conceder novo prazo ao réu para que se manifeste depois da produção de prova em audiência justificatória.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

1. Liminar possessória e recurso cabível

O artigo ora analisado é dispensável. É bastante evidente que deverá ser proferida liminar de reintegração ou manutenção de posse se na audiência justificatória o autor comprovar os requisitos exigidos no art. 561 do CPC/2015. Na prática é frequente que o juiz não decida na própria audiência, mas determine a conclusão dos autos para decisão em gabinete. Quer a decisão seja proferida na audiência justificatória, quer o seja em gabinete, o recurso cabível é o agravo de instrumento,³³⁹ em conformidade com o art. 1.015, I do CPC/2015.³⁴⁰

Seria possível discordar dessa conclusão, ao argumento de que a liminar possessória não corresponde à tutela provisória disciplinada nos arts. 294 e ss. Já foi visto nos comentários ao art. 558 que a liminar proferida nas ações de força nova não se estabiliza, contrariamente às deferidas em conformidade com o art. 303, dada a incompatibilidade entre o procedimento para a estabilização e o procedimento especial de tutela da posse. Também esse ponto poderia ser invocado para sustentar a inaplicabilidade do art. 1.015, I, às liminares possessórias, que não seriam então espécies de tutela provisória.

Ocorre que ao prever o cabimento de agravo de instrumento no art. 1.015, I, o código emprega a expressão *tutela provisória* em sentido lato. Para a determinação do recurso cabível não serão provisórias apenas as liminares obtidas em conformidade com os arts. 294 e ss. Serão também tutelas provisórias as liminares proferidas nos procedimentos especiais. E não pode haver dúvida sobre a provisoriedade, pois as liminares possessórias são provimentos jurisdicionais substituídos apenas pelas sentenças, amparados em cognição sumária, de modo que jamais poderão ser confundidas com as decisões interlocutórias de julgamento antecipado parcial do mérito, disciplinadas no art. 356, I e II, as quais se fundamentam em cognição exauriente.

2. Natureza satisfativa

O código vigente suprimiu o livro específico dedicado às ações cautelares. Mas há referências à tutela cautelar no Livro V da Parte Geral, a disciplinar a tutela provisória. Contudo, ainda que não houvesse referência explícita à tutela cautelar, não se poderia negar a diferença entre provimentos que satisfazem desde logo a pretensão do autor e aqueles que apenas asseguram o direito, tipicamente cautelares. É certo que ao satisfazer o pedido do autor, ainda que provisoriamente, a liminar possessória é provimento satisfativo, inconfundível com a tutela cautelar. A distinção se torna ainda mais nítida quando se percebe que para o deferimento da liminar possessória é desnecessário o perigo de dano no caso concreto, o qual é pressuposto para a concessão de liminar cautelar, conforme reconhecia a doutrina firmada sob a vigência do CPC/1973.³⁴¹

3. Deferimento da liminar e preclusão *pro judicato*

Quer a liminar possessória tenha sido deferida sem audiência justificatória, quer o tenha sido após justificação, há preclusão *pro judicato*. Isso significa que o juiz não poderá, perante os mesmos fatos e provas, alterar a decisão. Contudo, será possível retratar-se se for interposto agravo de instrumento. É intuitivo que a modificação do que fora decidido no tocante à posse, ao livre talante do juiz, causaria grave transtorno às partes e potencializaria as chances de conflito, de modo que a conservação da liminar, por meio da preclusão *pro judicato*, atende ao objetivo de pacificação social inerente ao processo. A propósito, o instituto da preclusão tem sua base valorativa assentada na segurança jurídica, efetividade e certeza dos provimentos jurisdicionais.³⁴² O art. 505 do CPC/2015 é obstáculo intransponível à possibilidade de modificação da decisão quando mantido o contexto fático-probatório.³⁴³ Se após a concessão de liminar surgir fato novo, o juiz deverá levá-lo em conta, de ofício ou a requerimento da parte. Se houver constatação de ofício, antes de decidir o juiz ouvirá as partes. É o que consta no art. 493, *caput* e parágrafo único, do CPC/2015.³⁴⁴ A doutrina anterior ao código vigente já admitia a possibilidade de modificação da liminar quando surgisse fato novo, posicionamento que deve continuar prestigiado³⁴⁵. É preciso reafirmar que as liminares possessórias não se submetem ao regime de

estabilização previsto nos arts 303 e 304. do CPC/2015, conforme análise realizada no item 3 dos comentários ao art. 558.

Questão mais difícil diz respeito à possibilidade de modificação da liminar se surgir prova capaz de demonstrar o desacerto da decisão. Vozes autorizadas da doutrina, ao analisarem o tema sob o código revogado, defendiam a ideia de que além do juízo de reconsideração em agravo de instrumento, apenas ao proferir sentença o juiz poderia analisar novamente a questão.³⁴⁶ Todavia, crê-se que seja mais adequada a um processo civil preocupado com a justiça, a possibilidade de revogação da liminar quando o réu trazer prova contundente sobre o desacerto da medida. A alteração do acervo probatório que fundamentou a medida autoriza que seja prolatada outra decisão.³⁴⁷

É corriqueira na prática forense a interposição de agravo de instrumento assim que o réu é comunicado sobre o deferimento de liminar possessória em seu desfavor. A tentativa de obtenção de efeito suspensivo inviabiliza que sejam levadas ao segundo grau todas as provas em que se fundamentará a defesa. Mas ainda que em determinadas situações isso fosse possível, trata-se de documentos que ainda não passaram pelo exame do primeiro grau, de modo que sua validade, na segunda instância, é relativa. Assim, é bastante comum que ao agravar e pedir a reconsideração o réu não tenha em mãos todo o acervo probatório com que procurará demonstrar sua condição de legítimo possuidor.

É plausível, portanto, que somente com a contestação surja prova robusta sobre o desacerto da liminar. Pode ser, ademais, que prova pericial demonstre que os atos possessórios do réu, considerados como esbulho, foram efetivamente praticados sobre imóvel no qual ele exercia legitimamente o poder fático. Em casos como esse a liminar, a pedido do réu, poderá ser revogada. Com efeito, se a prova demonstra que os atos possessórios foram praticados sobre bem integrante da esfera jurídica do demandado, é impositiva a revogação da liminar.

Ainda que o juiz perceba por si só a contundência das provas, não poderá alterar o que fora decidido sem que haja pedido do réu. Nesse caso, antes de decidir, o magistrado terá de ouvir o autor beneficiado com a liminar, como corolário dos princípios do contraditório e da colaboração (CPC, arts. 9.º e 10).³⁴⁸ É proibida, portanto, a modificação de ofício da liminar possessória.³⁴⁹

O regime de estabilização disciplinado nos arts. 303 e ss não se aplica às ações de força nova, como visto nos comentários ao art. 558. É certo, contudo, que o autor poderá optar pelo regime da tutela de urgência, o que também foi analisado na abordagem do art. 558, assumindo o ônus de comprovar o perigo de dano no caso concreto e de demonstrar a urgência da medida. Se houver postulação em conformidade com o art. 303, mas não for interposto recurso, nem apresentada contestação, a liminar de urgência se estabilizará (CPC, art. 304, § 1.º). A análise do tema, contudo, transcende os limites destes comentários.

4. Liminar possessória e responsabilidade objetiva

Caso a liminar possessória seja revogada ou a sentença decida em sentido contrário, o beneficiário da medida será responsabilizado e terá de arcar com os prejuízos causados pela implementação da medida. Essa conclusão, apoiada pela doutrina anterior ao código vigente,³⁵⁰ encontra fundamento no art. 559, a prever a necessidade de caução para o ressarcimento futuro e eventual das perdas e danos. Ao exigir a caução, o dispositivo reconhece que o autor beneficiado pela medida responderá pelos prejuízos que sua implementação acarretar ao réu se houver posterior revogação.

A obrigação de indenizar incidirá sempre que houver prejuízo e a medida liminar for revogada, quer isso ocorra mediante provimento de agravo de instrumento, decisão interlocutória motivada por modificação no acervo fático-probatório ou prolatação de sentença. Trata-se de responsabilidade objetiva, sendo irrelevante o dolo ou a culpa, impondo-se ao autor a prova dos prejuízos e do nexo de causalidade com o deferimento da liminar.

Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.

1. Promoção da citação

O dispositivo impõe ao autor a promoção da citação do réu, deferida ou não a liminar possessória. Nos comentários ao art. 562 já foi destacado que o juiz não poderá indeferir a liminar sem antes designar audiência de justificação. Naquela ocasião foi salientado que se o juiz designar audiência justificatória o réu será no mesmo mandado citado para oferecer resposta e intimado a comparecer à justificação. Contudo, se o mandado se restringir a intimá-lo para participar da audiência, depois da sua realização deverá ser expedido mandado citatório, que cumpra os requisitos elencados no art. 250 do CPC/2015.

Em regra, ao propor a demanda o autor já terá pago as custas necessárias para a realização do ato citatório. Tratando-se de processo com autos físicos, incumbe-lhe deixar uma via da petição destinada à confecção do mandado. Tratando-se de processo com autos eletrônicos, bastará o pagamento das custas referentes à citação para que seja expedido o mandado, considerando-se promovido o ato.

Se a quitação das custas relacionadas ao ato citatório não tiver ocorrido na distribuição da demanda, o autor deverá realizá-la após o deferimento da liminar possessória. Será oportuno que o cartório judicial confeccione um só mandado, a fim de que se realize concomitantemente a citação e a intimação do réu quanto ao deferimento de liminar. A conclusão não muda quando for designada audiência de justificação e o autor não tiver recolhido as custas no momento da distribuição. Deverá fazê-lo em cinco dias contados da intimação da liminar.³⁵¹

Em conformidade com o art. 485, III, do CPC/2015,³⁵² a omissão do autor em promover a citação, tenha ou não sido designada audiência justificatória, ensejará a extinção do processo por abandono quando acarretar paralisação do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias.³⁵³ Na hipótese de concessão da liminar sem audiência de justificação, é razoável a aplicação analógica do art. 302, II, a fim de que o autor seja responsabilizado pelos prejuízos que sua inércia no fornecimento de meios para a citação ocasionar ao réu.³⁵⁴

Se o réu for pessoa jurídica de direito público, graças ao injustificável e inconstitucional privilégio assegurado no art. 562, parágrafo único, não poderá ser concedida liminar sem manifestação dos representantes judiciais. A citação, quando os autos forem físicos, ocorrerá em conformidade com o art. 242, § 3.º.³⁵⁵ Tratando-se de autos eletrônicos, será realizada por meio do cadastro previsto no art. 246, V, §§ 1.º e 2.º do CPC/2015.³⁵⁶ Sendo designada audiência justificatória, o ente público será citado nos termos do art. 562, bastando a intimação realizada de acordo com o art. 246, V, §§ 1.º e 2.º do CPC/2015. Até que sejam criados os cadastros a que alude o art. 246, § 1.º, a citação deverá ser realizada perante o órgão de advocacia, na forma preconizada no art. 242, § 3.º, do CPC/2015. As intimações, nos autos eletrônicos, também ocorrem eletronicamente, embora haja variação quanto à forma dependendo do sistema utilizado.

2. Justificação prévia e contagem do prazo para resposta

Com a designação de justificação prévia, o prazo para resposta deverá ser contado a partir da intimação do réu sobre o deferimento ou indeferimento da liminar. Na análise do art. 562 foi destacado que o réu se limita a contraditar e reinquirir testemunhas, sendo-lhe vedado oferecer resposta. Mesmo que se trate de ente beneficiado pela regra inconstitucional do art. 562, parágrafo único, não será permitida a apresentação de contestação, mas apenas de arrazoado indicativo das razões pelas quais a liminar não deve ser deferida.

Destarte, com a designação de audiência justificatória, a contagem do prazo para apresentação de resposta se inicia a partir da intimação do réu sobre o deferimento ou indeferimento da liminar. Antes disso a revelia é incogitável, pois não fora franqueada ao réu oportunidade para responder.

Se o réu apresentar resposta na audiência justificatória, deverá o juiz determinar seu desentranhamento. Se por descuido a resposta não for desentranhada, quando houver intimação sobre a liminar possessória o réu deverá reiterar suas alegações, pois antes disso não lhe fora oportunizada a resposta. Embora aparentemente formal, esse posicionamento procura resguardar a especialidade do procedimento nas ações de força nova. Se for consentida a apresentação antecipada de resposta a finalidade da fase especial das ações de força nova será desvirtuada. Trata-se de um conjunto de atos projetado para propiciar a produção de provas pelo autor, com o consequente deferimento da liminar. É por isso que se não admite que o réu responda e produza provas. Por fim, embora o código use a expressão *prazo para contestar*, já se viu nos comentários ao art. 556 que será possível reconvir.

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbacão afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2.º e 4.º.

§ 1.º Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2.º a 4.º deste artigo.

§ 2.º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.

§ 3.º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4.º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5.º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.

1. Ações de força velha e audiência de mediação

É preciso delimitar o alcance do art. 565. Inicialmente havia sido concebido para obrigar a realização de audiência de conciliação antes da concessão de liminares de reintegração e manutenção na posse. O instituto procurava favorecer os movimentos sociais alinhados com o grupo ocupante do poder, no governo federal, à época de discussão e aprovação do código. A proposição encontrou forte resistência na base parlamentar vinculada ao agronegócio. O embate de forças no parlamento resultou em dispositivo em descompasso com seus objetivos originais.

As determinações do art. 565, já se vê no *caput*, aplicam-se somente aos litígios coletivos em que se dispute a posse ou propriedade de bem imóvel quando a agressão tiver ocorrido há mais de ano e dia e for requerida a concessão de liminar. Precisamente por isso não se aplicam ao interdito proibitório, cujo fundamento deve ser a ameaça iminente de turbacão ou de esbulho, expressões utilizadas no dispositivo.

Já foi assinalada, ao longo desses comentários, a possibilidade de concessão de liminares nas ações de força velha, desde que atendidos os requisitos indicados no art. 300, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano. Também será possível a obtenção de tutela provisória com base na evidência, desde que atendidos os requisitos indicados no art. 311, I e IV do CPC/2015. É somente nesse contexto que se aplica o dispositivo. Em outras palavras, é inadmissível

a realização da audiência de mediação nas ações possessórias de força nova, quer o litígio seja individual, quer seja coletivo. A audiência de mediação deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da decisão que a designar. Convém enfatizar que esta audiência não se confunde com aquela disciplinada no art. 334 do CPC/2015. Não se trata de conciliação ou de mediação apenas entre as partes, mas de mediação conduzida pelo juiz, contando com a presença de outros entes públicos.

2. Nova audiência de mediação

Se for deferida a liminar, mas não ocorrer sua implementação no prazo de um ano contado da data da distribuição da demanda, o art. 565, § 1.º prevê a realização de nova audiência de mediação, na forma disciplinada nos demais parágrafos do dispositivo. A audiência deverá ser realizada em até trinta dias contados a partir da data em que a distribuição da ação completou um ano. Terão de ser ouvidos os mesmos órgãos e autoridades elencados nos §§ 2.º a 4.º.

3. Participação do ministério público e da defensoria pública

O art. 565, § 2.º prevê desnecessariamente o comparecimento do Ministério Público, reiterando o que já consta no art. 178, III do CPC. Procura-se, com a participação do *Parquet*, assegurar o cumprimento de medidas que evitem a violência nos conflitos possessórios.

O dispositivo analisado também prevê a participação da Defensoria Pública quando houver beneficiários da assistência judiciária gratuita. Adotou-se, com outra nomenclatura, o mesmo critério indicado no art. 554, § 1.º, no qual se faz alusão a “pessoas em situação de hipossuficiência econômica”. A função da Defensoria Pública é representar os hipossuficientes em juízo.

4. Presença do juiz na área objeto do litígio

No parágrafo terceiro do artigo em análise é disciplinada a possibilidade de comparecimento do juiz à área litigiosa sempre que sua presença se fizer necessária para a efetividade da medida judicial. Trata-se de outro dispositivo pouco inspirado. O comparecimento do juiz não depende da existência desse dispositivo. Não se discute que a presença do magistrado, considerada a importância do cargo que ocupa, poderá arrefecer os ânimos mais exaltados e, desse modo, evitar conflagrações. Mas é de uma obviedade ululante a possibilidade de o juiz comparecer ao palco do litígio, o que torna a proposição desnecessária.

5. Participação de órgãos responsáveis pelas políticas agrária e urbana da união, estados, distrito federal e municípios

No art. 565, § 4.º, é prevista a intimação dos órgãos responsáveis pelas políticas agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Procura-se trazer para a audiência de mediação os principais atores governamentais interessados na resolução de conflitos pela terra. O dispositivo menciona sua participação na audiência para se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre “a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório”. Apesar da redação abstrusa, compreende-se que os órgãos serão ouvidos para proporem soluções ao conflito, indicando, dentro de suas respectivas competências, possibilidades de assentamento dos invasores. Com razão a doutrina adverte que bastaria a intimação sobre o processo para que os órgãos apresentassem eventuais subsídios, pois a audiência se pauta por razões jurídicas, não políticas.³⁵⁷ De fato, a participação de diversos órgãos governamentais na audiência opera a inadequada transformação de um ato processual, destinado à resolução do caso concreto, em ato administrativo, pautado por influxos políticos. Compreende-se e se apoia com veemência a realização de audiências públicas na definição da política fundiária. Mas é inadequado que em litígios possessórios coletivos, sob o regime procedimental da ação de força velha, haja intimação específica para a participação em audiência de diversos órgãos governamentais, o que evidentemente levará à politização da discussão.

E inegável que a razão de ser do dispositivo é tentativa de inviabilizar a retomada imediata da posse, condicionando-a à realização prévia de audiência de mediação. O artigo havia sido elaborado para incidir nas ações de força nova e é evidente que nesse caso seriam enormes os problemas para a obtenção da tutela jurisdicional da posse. Se prevalecesse a redação original do dispositivo, os interditos possessórios perderiam sua efetividade. E aqui é preciso deixar clara a posição de que o ordenamento jurídico repele atos de agressão à posse, quer eles sejam praticados por um indivíduo, quer o sejam por movimentos sociais.

Sublinhe-se que o interesse dos órgãos no processo não é jurídico. Eles não podem propor pedidos nem contra eles pedidos poderão ser propostos. Desse modo, tem-se que a participação de órgãos federais, como o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não deslocará a competência da justiça estadual para a federal.

6. Litígios coletivos por propriedade e audiência de mediação

A realização de audiência de mediação foi ampliada para os conflitos coletivos sobre a propriedade no art. 565, 5º. Novamente andou mal o legislador. Como adverte a doutrina, a questão dominial é jurídica, solucionável por meio do exame de matrículas imobiliárias, caracterizando-se como questão técnica, de modo que as providências exigidas pelo artigo apenas atrasam o julgamento do processo.³⁵⁸

Com efeito, a presença dos órgãos indicados no parágrafo quarto é inútil na discussão sobre o domínio. A Defensoria Pública já teria sido procurada para a defesa dos hipossuficientes e o *Parquet* atuaria em razão do interesse público ou social do conflito (CPC, art. 178, I). Não se compreende no que possa auxiliar para a tutela jurisdicional a realização de audiência de mediação que, considerada a matéria debatida, estritamente técnica, poderia ser solucionada sem estrépito pelo juiz. Nas questões dominiais a audiência de mediação preconizada pelo art. 565 é ato processual dispensável e, conseqüentemente, atentatório à tutela jurisdicional efetiva e adequada (art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988 e art. 4.º do CPC/2015), sendo duvidosa sua constitucionalidade.

Art. 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum.

1. Fim da fase especial e aplicação do procedimento comum

Depois da apresentação de resposta pelo réu, encerra-se a fase especial das ações possessórias de força nova. A partir de então passam a ser aplicadas as disposições do procedimento comum. O art. 566 traz significativa mudança de redação em relação ao art. 931 do CPC/1973, que se referia à aplicação do procedimento ordinário. A referência à ordinarização poderia levar à incorreta conclusão de que a ação perderia seu caráter possessório, tornando-se possível o debate sobre a propriedade. Em meio a tantos passos infelizes, andou bem o legislador ao se referir ao procedimento comum, repetindo o que fizera no art. 558, parágrafo único. A modificação realça a aplicação do procedimento comum após a apresentação de resposta nas ações de força nova, o que absolutamente não se confunde com a possibilidade de discussão sobre a propriedade no âmbito das ações possessórias.

2. Ações possessórias e julgamento antecipado parcial do mérito

Nos comentários ao art. 555 já foi abordada a possibilidade de aplicação do julgamento antecipado parcial, também denominado fracionamento do mérito, no âmbito das ações possessórias. Trata-se de instituto disciplinado no art. 356 do CPC/2015. Será cabível, em resumo, quando houver pedido incontroverso (art. 356, I), quando for desnecessária a produção de outras provas (art. 356, II, c/c art. 355, I) e quando o réu revelar sofrer os efeitos da presunção de veracidade e deixar de requerer a produção de provas (art. 356, II, c/c art. 355, II). Para a análise da aplicação do fracionamento do mérito no âmbito das ações possessórias, indicam-se os comentários ao art. 555.

3. Ações possessórias e tutela da evidência

Nos comentários ao art. 558 já se mencionou de passagem a possibilidade de aplicação da tutela da evidência, disciplinada no art. 311 do CPC/2015³⁵⁹, nas ações de força velha. As de força nova, como sabido, se pautam pelos critérios definidos no art. 561, de modo que não será possível a obtenção de liminar com fundamento na tutela da evidência. O fundamento para a liminar possessória nas ações de força nova, reitere-se, é a posse anterior do autor e a agressão em prazo igual ou inferior a ano e dia.

Apenas as hipóteses definidas no art. 311, I e IV, serão aplicáveis às ações de força velha. Evidentemente não terão possibilidade de aplicação os incs. II e III, que se referem, respectivamente: (a) às alegações que só possam ser comprovadas documentalmente, sobre as quais haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante e (b) ao pedido reipersecutório relacionado ao pedido de depósito. Ora, a posse pode ser comprovada por outros meios que não somente a prova documental, o que afasta a aplicação do art. 311, II. Ademais, as ações possessórias têm como exclusivo objeto a posse, restando inviabilizada a aplicação do art. 311, III, a prever hipótese de reivindicação do bem.

Antes de tudo é bom afirmar que não existe incompatibilidade entre a tutela da evidência, nas hipóteses previstas no art. 311, I e IV, e as ações possessórias de força velha. O art. 565, *caput*, limita-se a referir que antes da concessão de medida liminar deverá ser deferida audiência de mediação se houver litígio coletivo sobre a posse de imóvel. É certo que nem todas as ações de força velha abrigarão litígio coletivo sobre a posse de imóvel. Ademais, como a tutela provisória pode se basear na urgência ou na evidência, mesmo nas ações subordinadas ao art. 565, *caput*, poderá haver concessão lastreada na evidência, impondo-se ao juiz, contudo, designar audiência de mediação antes de conceder a medida.

No art. 311, I, é prevista a tutela da evidência na hipótese de abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Permite-se que a liminar seja deferida sem urgência em razão da inconsistência da resposta.³⁶⁰ No IV, por sua vez, é regulada a tutela da evidência decorrente da apresentação de prova documental suficiente pelo autor, sem que o réu tenha na resposta conseguido infundir dúvida no juiz. Nesse caso a doutrina salienta que o réu é que deverá suportar o tempo para a produção da prova, não o autor, razão pela qual deve ser deferida em favor do demandante tutela provisória, baseada na evidência.³⁶¹

Nesse ponto fica ainda mais nítido o descabimento de tutela da evidência no âmbito de ações possessórias de força nova. O autor invoca sua posse e pede a liminar adequada para tutelá-la. Não faria qualquer sentido que o juiz deixasse de averiguar os requisitos do art. 561 para conceder tutela da evidência baseado na inconsistência da resposta ou na imposição ao réu do ônus do tempo do processo. Se o autor fez prova dos requisitos exigidos no art. 561, terá sido concedida liminar em seu favor, já na inicial ou depois de audiência de justificação. Não se vê como, após indeferir a liminar – o que demonstra ou que o autor não conseguira demonstrar a posse, ou falhara ao comprovar a agressão – o juiz pudesse proferir-la mediante tutela da evidência.

Chegado esse ponto é preciso enfatizar a diferença entre a tutela da evidência e o julgamento antecipado do mérito, integral ou parcial. É certo que o art. 355, I, dispõe sobre a possibilidade de julgamento antecipado quando inexistir necessidade de produção de outras provas. O dispositivo se refere à possibilidade de julgamento antecipado em razão da suficiência das provas produzidas pelo autor e pelo réu para o *julgamento definitivo* da questão. Nas hipóteses disciplinadas pelo art. 311 não há tutela definitiva, mas apenas provisória.

A cognição, no âmbito do julgamento antecipado, é exauriente. Na tutela da evidência, trata-se de cognição sumária. O juiz não está convencido em definitivo. A inconsistência da resposta (CPC, art. 311, I) ou a necessidade de dilação probatória embora o autor tenha carreado prova documental dos fatos constitutivos (CPC, art. 311, IV), não permitem que o juiz decida com força de coisa julgada, mas apenas que imponha ao réu o encargo consistente na demora do processo.

Nas ações de força velha será possível tanto o julgamento antecipado parcial do mérito, quanto

a concessão de tutela da evidência. Nas ações de força nova a liminar possessória se baseia nos requisitos indicados no art. 561, de modo que há insanável incompatibilidade procedimental com a tutela da evidência.

4. Saneamento compartilhado e convenções processuais

A aplicação do saneamento compartilhado e das convenções processuais às ações possessórias já foi analisada nos comentários ao art. 558, aos quais se faz referência.

5. Prolatação de sentença e efeito da apelação

Contra a decisão que deferir ou indeferir a liminar, cabe agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, I). Contra a decisão que julgar antecipadamente parcela do mérito, também caberá agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, II). Contra as sentenças nas ações possessórias, caberá apelação, que terá, nos termos do art. 1.012, *caput*, o efeito suspensivo como regra.³⁶²

Questão que sempre preocupou a doutrina diz respeito aos efeitos da apelação quando a sentença não confirma a liminar possessória ou quando, apesar do indeferimento da liminar, a sentença acolhe o pedido do autor. A doutrina, sob o código anterior, chegara à seguinte solução: (a) no primeiro caso, interposta a apelação, seria interrompida a eficácia da sentença que revogara a liminar, de modo que o autor continuaria na posse do bem; (b) no segundo, como não foi obtida a liminar possessória, só haveria reintegração ou manutenção depois do julgamento da apelação.³⁶³ Pode-se acusar a solução de formalista, mas ela resultava de regra inequívoca do direito positivo então vigente (CPC/1973, art. 520), que não indicou as sentenças proferidas nas ações possessórias dentre as exceções ao efeito suspensivo do apelo.

No CPC/2015 há importante novidade sobre o tema. O art. 1.012, § 1.º, V, assinala que a sentença que confirmar, conceder ou revogar tutela provisória, começará a produzir efeitos imediatamente. Isso significa que a apelação contra essas sentenças não terá efeito suspensivo.³⁶⁴ Caberá ao apelante requerê-lo diretamente no segundo grau.³⁶⁵

Assim, se for revogada na sentença a liminar possessória outrora concedida, tão logo ocorra a publicação o réu poderá postular o cumprimento provisório da sentença (CPC, art. 1.012, § 2.º³⁶⁶). Poder-se-ia sustentar que continuaria desamparado o autor que não tivesse obtido liminar possessória, mas posteriormente viesse a vencer a demanda. Para tutelá-lo basta que o juiz conceda a liminar na sentença, o que é indiscutivelmente possível e está previsto no próprio art. 1.012, § 1.º, V. O deferimento de liminar no ato sentencial não precisa ser objeto de pedido, podendo ser oficiosamente concedido pelo juiz.

A solução poderia ser criticada ao argumento de que liminares possessórias não são tutelas provisórias segundo os arts. 294 e ss. Isso é verdade. Porém, no sistema recursal, a expressão “tutela provisória” abriga também as ações possessórias. Se assim não fosse, chegar-se-ia à absurda conclusão de que igualmente não cabe agravo de instrumento contra as liminares possessórias, já que o art. 1.015, I, vale-se da mesma expressão.

Forçando o argumento, seria possível questionar por qual motivo as liminares possessórias não estariam incluídas nos arts. 294 e ss. Ora, ao longo destes comentários em várias passagens foi demonstrada a incompatibilidade procedimental entre a liminar possessória do procedimento especial e a tutela provisória do procedimento comum. Entender contrariamente seria retirar do procedimento especial qualquer singularidade. Ocorre que o fundamento para a concessão de liminar possessória é a posse e sua violação. São outros os fundamentos para a tutela provisória, que exige verossimilhança e perigo de dano no caso concreto.

Ademais, não há dúvida que uma mesma expressão pode adquirir significados diferentes ao longo de um mesmo diploma legal. Basta pensar no termo “lide”, que possui o significado de conflito de interesses no art. 303 e sentido aproximado ao de processo no art. 125, que trata da denunciação da lide. *Tutela provisória*, nos arts. 294 e ss., diz respeito apenas às tutelas de

urgência e de evidência concedidas conforme os requisitos preconizados por aqueles dispositivos. *Tutela provisória*, nos arts. 1.012, § 1.º, V e 1.015, I, é expressão mais abrangente, compreendendo também as liminares proferidas nas ações possessórias.

Por fim, em favor da solução aqui proposta, milita além do direito positivo a noção de justiça. Seria francamente injusto fazer o autor vitorioso, mas que não obtivera a liminar, aguardar o julgamento da apelação para, somente então, ser tutelado. O tempo do processo não pode penitenciar a parte cuja razão é reconhecida após cognição exauriente! Do mesmo modo, seria afrontoso à justiça conservar na posse o autor que após cognição exauriente vem a ser reconhecido como possuidor ilegítimo. O art. 1.012, § 1.º, V, indiscutivelmente, significa um avanço em relação ao código anterior.

6. Eficácia da sentença de procedência

As sentenças e liminares proferidas nas ações de reintegração de posse têm eficácia executiva. Aquelas proferidas nas ações de manutenção de posse e nos interditos proibitórios têm eficácia mandamental.³⁶⁷

Nos provimentos executivos, segundo a célebre definição de Pontes de Miranda, o juiz retira algo que está onde não deveria, para colocá-lo onde deveria estar, mas não está.³⁶⁸ A definição se casa perfeitamente com a reintegração de posse, na qual o bem está onde não deveria – esfera jurídico-patrimonial do esbulhador – e com a implementação da liminar é levado para onde deveria estar, mas não estava – esfera jurídico-patrimonial do autor.

Em relação aos provimentos mandamentais, embora exista alguma divergência doutrinária, a nota caracterizadora é a expedição de ordem, acompanhada de mecanismo coercitivo.³⁶⁹ É o que ocorre nas ações de manutenção de posse (CPC, art. 555, parágrafo único, I e II) e é a própria essência do interdito proibitório (CPC, art. 567).

Saliente-se que a classificação segundo as tutelas do direito tem como premissa a análise do processo a partir do direito material, a fim de que sejam identificadas as deficiências das técnicas processuais. Desse modo, ao classificar as sentenças, deve o processualista fazê-lo à luz das tutelas do direito material.³⁷⁰

Consideradas as tutelas do direito material como critério distintivo, pode-se classificar as liminares e sentenças de procedência proferidas em ações de reintegração de posse e de manutenção como tutelas de remoção do ilícito, pois procuram erradicar os efeitos da ação contrária ao direito.³⁷¹ Os provimentos de inibição proferidos nos interditos proibitórios são exemplo clássico de tutela inibitória, cujo objetivo é impedir que ocorra a violação ao direito, sua repetição ou continuidade.³⁷²

Poder-se-ia sustentar, com fundamento no prosseguimento da ação ilícita, que na hipótese de esbulho haveria tutela inibitória. Mas essa compreensão do que se passa quando é proferido provimento de reintegração não seria correta. O objetivo na ação de reintegração de posse, bem como na de manutenção, é eliminar o ilícito, impedindo que continue a irradiar efeitos no plano fático. Quando o juiz defere a reintegração, elimina o esbulho e, por consequência, seus efeitos. Ademais, seria incorreto falar em inibição, pois o ato ilícito, tanto na reintegração, quanto na manutenção, já teria ocorrido. O que se faz é eliminá-lo, a fim de que cesse de produzir efeitos.

Seção III Do interdito proibitório

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

1. Interdito proibitório e preventividade

A doutrina salienta o caráter tradicional do interdito proibitório, assinalando sua ocorrência nas Ordenações do Reino.³⁷³ Trata-se de medida preventiva, destinada a evitar a ocorrência de esbulho ou de turbacão, mediante aplicação de pena pecuniária contra quem houver ameaçado o legítimo possuidor.

Ao analisar o dispositivo sob o código processual revogado, Clóvis do Couto e Silva comentou que poderia ser adotada no Brasil a solução preconizada por parte da doutrina portuguesa, consistente na aplicação do poder geral de cautela do juiz em substituição ao interdito proibitório.³⁷⁴ Todavia, é preciso advertir que o interdito proibitório não é medida cautelar. Trata-se, isso sim, de medida tipicamente preventiva, inibitória do ato ilícito. Em outras palavras, o interdito tem como objetivo evitar a concretização do esbulho ou da turbacão.

A diferença entre as tutelas inibitória e de remoção de ilícito e os provimentos tipicamente cautelares já foi demonstrada na doutrina. Os provimentos cautelares são voltados a impedir a ocorrência de *dano*, ao passo que os inibitórios têm como escopo evitar a ocorrência, reiteração ou prosseguimento do ato ilícito. Por sua vez, provimentos de remoção, também denominados reintegratórios, objetivam restituir a situação fática ao estado anterior à prática do ilícito, a fim de que sejam eliminados os efeitos decorrentes da ilicitude.³⁷⁵

Os provimentos cautelares não são técnicas, mas tutelas do direito, cujo fundamento é o *perigo de dano*, circunstância também originária do plano do direito material.³⁷⁶ É fácil perceber, portanto, que as tutelas inibitória e de remoção do ilícito se distinguem das cautelares por inibirem o *ato ilícito*, sendo a inibição do *dano* mera consequência da prevenção da própria ilicitude. A tutela cautelar, ao apresentar o dano como pressuposto, não é realmente uma tutela preventiva, mas repressiva.³⁷⁷

Nota-se com clareza a distinção entre os institutos, de modo que o alvitre de Clóvis do Couto e Silva não merece acolhida. A previsão do código de uma ação específica para a prevenção da agressão à posse é teoricamente correta e rende bons resultados na prática. Para concluí-lo, basta perceber que o exercício do poder geral de cautela pressupõe que seja indisponibilizado bem de patrimônio do esbulhador ou turbador para que, na eventualidade de esbulho ou turbacão, fosse usado como garantia contra os prejuízos. Muito mais prática, além de teoricamente correta, é a solução apresentada no código: frente à ameaça, comina-se multa pecuniária capaz de influenciar o réu a não consumir sua ameaça.

2. *Justo receio de agressão à posse*

O dispositivo é bastante claro ao estabelecer o “justo receio” de turbacão ou de esbulho iminente como fundamento para a concessão da medida inibitória. Não serão suficientes, portanto, meras elucubrações. É imprescindível que haja elementos concretos a caracterizar a ameaça.³⁷⁸ Isso não significa que ela não possa ocorrer pela forma verbal.³⁷⁹ A ameaça terá de ser injusta, de modo que o exercício regular de direito não legitima a propositura de interdito proibitório. Assim, é indiscutível que a notificação sobre rescisão do comodato não é fundamento para o ajuizamento da ação de inibição. Note-se que o justo receio se relaciona a ameaça iminente, o que significa que não haverá interesse processual no ajuizamento do interdito em relação a ameaça antiga e não consumada. Se essa circunstância for verificada com a leitura da inicial, o juízo, ao despachá-la, deverá requerer esclarecimentos do autor quanto à urgência. Sendo reiterada a antiguidade da ameaça, a inicial deve ser indeferida (CPC, art. 330, inc. III). Caso essa circunstância venha a ser demonstrada depois da resposta, o princípio da primazia do mérito (CPC, arts. 4º e 488) determina que seja reconhecida a improcedência da demanda. Se a ameaça não é iminente, o autor não tem pretensão ao interdito proibitório.

Serão legitimados para a propositura do interdito, tanto o possuidor direto, quanto o possuidor indireto, da mesma forma como ocorre com as ações de reintegração e de manutenção de posse.

3. *Provimento mandamental e multa pecuniária*

A tutela inibitória é concretizada por meio da prolação de provimento mandamental, pois à ordem para que não ocorra o ato espoliativo ou a turbacão o juiz acrescenta multa pecuniária. O valor da multa não pode ser indeterminado e deve ser indicado no mandado.³⁸⁰

Embora o interdito proibitório seja uma medida tipicamente preventiva, nada impede que o juiz, em atenção à “plasticidade” da multa, realize cominação em ordem crescente de valor e em periodicidade determinada, para o fim de evitar que o esbulho perdure caso seja consumado.³⁸¹ É possível, portanto, que o juiz arbitre um valor e o duplique para cada dia que permaneça a situação de ilicitude. Ou, ainda, é possível que o juiz aplique a multa, em caso de concretização da ameaça à posse, em periodicidade diferente da diária.

A ideia poderia ser criticada ao argumento de que a fixação de multa em consideração à consumação do esbulho levaria à desnaturação do interdito proibitório, medida tipicamente preventiva. Crê-se, todavia, que a preventividade do interdito ficaria reforçada com a cominação de multa em ordem crescente. Ademais, a crítica poderia ser realizada ainda que o juiz fixasse a multa em valor determinado exclusivamente para a eventualidade de concretização da ameaça, sem alusão ao prosseguimento do esbulho, pois a aplicação, seja ou não a multa cominada em ordem crescente, tem como pressuposto a agressão da posse.

Em outras palavras, é indiferente que no provimento o juiz assinale “comina-se a multa de cem mil reais na hipótese de esbulho” ou “comina-se a multa de cem mil reais na hipótese de esbulho, cominando-se ainda o valor de dez mil reais para cada dia em que o réu permaneça no imóvel”. Em ambos os casos a multa só será aplicada se houver descumprimento da ordem. O descumprimento ainda sujeitará o réu à responsabilidade penal por crime de desobediência.

O objetivo, contudo, não é enriquecer o autor com a multa, mas dissuadir o réu a praticar o esbulho ou a turbacão. Precisamente por isso o juiz deverá empregar a coerção de forma equilibrada, a fim de que ela seja capaz de influenciar o responsável pelo ato de intimidação a não prosseguir em seu intento.

A expressão “determinada pena pecuniária” estabelece limite semântico à interpretação do texto, de modo que não poderão ser aplicados outros mecanismos coercitivos, como a restrição de direitos. Saliente-se que referida expressão não inviabiliza a plasticidade da multa, pois basta que haja determinação do valor para que seja cumprido o que determina o art. 567.

A execução da multa deve ocorrer nos mesmos autos em que se processou o interdito. Para a satisfação do direito creditório pode ser deflagrado o cumprimento de sentença por execução ou podem ser adotadas as medidas atípicas previstas no art. 139, IV do CPC/2015.

4. Interdito proibitório e proteção de direitos pessoais

O interdito proibitório é ação possessória típica, assentando-se, portanto, na proteção à posse. Não será possível aplicá-lo para a tutela de direitos pessoais, tendo o Superior Tribunal de Justiça editado verbete sumular que assinalou a inadmissibilidade do interdito para a proteção de direito autoral³⁸². A mesma Corte tem precedente antigo admitindo o emprego do interdito proibitório para a proteção de patente de invenção.³⁸³ Não se crê, contudo, que o direito de patente seja passível de proteção por meio das ações possessórias, conforme apontado na introdução destes comentários.

A inviabilidade de proteção por meio dos interditos possessórios não significa que para a tutela do direito autoral inexistam técnicas eficientes. O autor poderá pleitear tutela jurisdicional inibitória ou de remoção do ilícito, cabendo ao juiz, para implementá-las, utilizar-se das medidas indicadas no 536, § 1.º, do CPC/2015. Como se vê, a falta de interesse processual na deflagração das ações possessórias, não priva o titular do direito autoral ou de propriedade industrial, de mecanismos adequados para a proteção de seu direito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

1. Aplicação das regras da Seção II

O dispositivo disciplina a possibilidade de aplicação ao interdito proibitório das regras constantes na Seção II do Capítulo III, atinentes à fase especial das ações de manutenção e de reintegração de posse. O texto legal, indiscutivelmente lacônico, está parcialmente correto.

Com efeito, deverá o possuidor que se sentir ameaçado provar a posse e a ameaça de iminente turbação ou esbulho, nos termos do art. 561. O juiz poderá deferir liminar *inaudita altera parte*, cabendo-lhe designar audiência de justificação caso não esteja convencido com os documentos trazidos com a inicial.³⁸⁴ A intimação do réu, caso já tenha sido citado por ocasião da audiência de justificação, deverá atender ao que dispõe o art. 564.

Todavia, não se aplica ao interdito proibitório o contido no art. 562, parágrafo único, referente à necessidade de oitiva prévia dos representantes das pessoas jurídicas de direito público antes da concessão de liminar.³⁸⁵ O art. 562, parágrafo único, dispositivo incluído na Seção II, refere-se somente às hipóteses de manutenção ou de reintegração de posse, conforme consta expressamente em seu texto. Trata-se de limite semântico que inviabiliza interpretação ampliativa.

2. Interdito proibitório e prazo de ano e dia

O art. 558 consagra o procedimento especial às ações possessórias ajuizadas em até um ano e um dia da agressão. É este dispositivo que permite a aplicação das regras da fase especial, previstas na Seção II. Ocorre que ele certamente não se aplica ao interdito proibitório³⁸⁶. O fundamento para o ajuizamento da ação é a ameaça de iminente turbação ou esbulho, de modo que o interesse processual no ajuizamento da demanda está limitado ao período em que perdurar a ameaça. Não faria mesmo qualquer sentido que meses após a ameaça não consumada, viesse o autor a requerer tutela jurisdicional.

Assim, caso o legítimo possuidor perceba movimentação no entorno do imóvel possuído, com acampamento e chegada de terceiros, ser-lhe-á lícito buscar proteção enquanto perdurar o acampamento. Com a saída dos terceiros das imediações, extingue-se o interesse processual no ajuizamento da demanda. Como já afirmado, se o caráter não recente da ameaça for extraído da própria inicial, o juízo, depois de solicitar esclarecimentos ao autor, indeferirá a inicial por falta de interesse (CPC, art. 330, inc. III), desde que as informações do autor reiterem a antiguidade da intimidação. Se essa circunstância vier à tona apenas após a resposta – o que é menos comum – o juízo julgará improcedente a demanda possessória. Sendo antiga a ameaça, inexistente intimidação a ensejar a proteção interdital. Logo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

3. Interdito proibitório e caução: desnecessidade

Também não se aplica ao interdito proibitório o disposto no art. 559, a respeito da necessidade de caução. Somente a manutenção ou o esbulho poderiam levar a eventuais prejuízos do réu na ação possessória que viessem a exigir caução prévia. É o que consta de forma expressa no próprio dispositivo, que alude ao “autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse”. Há, portanto, exclusão do interdito proibitório do âmbito de aplicação do art. 559 do CPC/2015.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

2

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

3

Lafayette Rodrigues Pereira, *Direito das coisas*, vol. I, p. 29-30. A posse era definida como poder exercido sobre a coisa, conceito corrente na doutrina atual, sendo ainda enfatizada a vontade do possuidor como elemento caracterizador da posse: “A posse consiste no poder de dispor fisicamente da coisa, com a intenção de dono, e de defendê-la contra as agressões de terceiro. Pressupõe, portanto, uma coisa fisicamente submetida à dominação da nossa vontade”. Todavia, ao se pronunciar especificamente sobre a natureza da posse, o Conselheiro assinalou na página 40 da mesma obra, seu caráter simultaneamente fático e jurídico: “É, pois, força reconhecer que a posse é um fato e um direito – um fato pelo que respeita à detenção, um direito por seus efeitos”. Prevalece, contudo, a lapidar definição de que se trata de poder exercido sobre a coisa, difundida na doutrina atual.

4

Antônio Joaquim Ribas, *Da posse e das ações possessórias*, p. 3-4. Na grafia da época: “A posse é, pois, o imperio natural ou material que os homens exercem sobre as cousas, abstracção feita do direito que possuem, ou não, ter para exercê-lo”. Na sequência, o autor concluía que a “a posse é apenas mero facto independente de toda a noção jurídica”. Não se pode esquecer, quando se cita juristas do século XIX, que a doutrina brasileira exerceu papel fundamental na sistematização da posse em nosso Direito, como demonstra Sérgio Said Staut Júnior, *A posse no direito brasileiro da segunda metade do século XIX ao Código Civil de 1916*, p. 123: “A construção da regulamentação jurídica da posse no Brasil a partir da segunda metade do século XIX é especialmente fruto de criação doutrinária. Até o advento do Código Civil de 1916 não havia uma legislação sistematizando toda teoria possessória como se observa na codificação citada e no atual Código Civil brasileiro. Encontram-se disposições esparsas em relação à posse nas Ordenações Filipinas e algumas poucas referências nas legislações modernizadoras em matéria de propriedade sem qualquer preocupação em definir um regime jurídico específico e completo para a posse e seus efeitos”.

5

Tito Fulgêncio, *Da posse e das ações possessórias*, vol. I, p. 12: “Condições diferenciais: a posse é poder de fato, instaura-se pelo exercício de fato de algum poder do domínio”.

6

Eduardo Espínola, *Posse, propriedade, compropriedade ou condomínio. Direitos autorais*, p. 30: “Na posse, a situação é puramente de fato”.

7

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. XIII, p. 141: “A posse, no sentido que aqui nos interessa, é o estado de fato, a que a lei liga consequências jurídicas”.

8

Clóvis Beviláqua, *Direito das coisas*, vol. I, p. 3: “A posse, considerada em si mesma, funda-se em um mero fato e se apresenta como estado de fato; mas uma vez firmada, nela a ordem jurídica, em atenção à paz social e à personalidade humana, respeita o que ela apresenta ser, reconhece o *jus possessionis*, o direito de posse, que os interditos defendem. Eis a explicação desta forma especial do direito. É um interesse que a lei protege; portanto é um direito”.

9

Ruy Barbosa, *Posse de direitos pessoais*, p. 44, com grifos do próprio autor: “Desde que se não considere a posse como *poder físico*, mas como a *simples exterioridade do exercício do direito*, *‘basta para a proteção possessória a exterioridade do direito e a possibilidade do seu exercício’*. Ora, não se pode negar que os direitos incorpóreos se realizam exteriormente, exercendo-se”.

10

Vicente Ráo, *Posse de direitos pessoais*, p. 11, com negrito do autor: “Que a posse não é o poder physico sobre a cousa, e sim o exercício, a exterioridade de um direito, eis a noção que mais clara aparece, até á evidencia, ao estudar-se a *posse dos direitos*”.

11

Rudolf von Ihering, *Teoria simplificada da posse*, p. 96: “Se se parte desta definição: ‘os direitos são os interesses juridicamente protegidos’, não pode haver a menor dúvida de que é necessário reconhecer o caráter de *direito* à posse. Expusemos mais acima o interesse que implica a posse: constitui ela a condição da utilização econômica da coisa”. A definição da posse como direito é retomada na página 103 da mesma obra: “A posse, como relação da pessoa com a coisa, é um *direito*; como parte do sistema jurídico, é um *instituto de direito*”.

12

Arruda Alvim, *Comentários ao Código Civil brasileiro*, vol. XI, t. II, p. 65: “A posse, historicamente, como se disse antes, tem sempre sido relacionada com o *poder* exercido sobre uma coisa; ou, ao *controle* exercido sobre uma coisa”.

13

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 7. Por sua importância e rigor conceitual, transcreve-se a passagem: “A posse é poder, *post-sedere*, possibilidade concreta de exercitar algum poder inerente ao domínio ou à propriedade. Não é o poder inerente ao domínio ou à propriedade; nem, tão pouco, o exercício desse poder. Rigorosamente, a posse é o estado de fato de quem se acha na possibilidade de exercer poder *como* o que exerceria quem fosse proprietário ou tivesse, sem ser proprietário, poder que sói ser incluso no direito de propriedade (*usus, fructus, abusus*). A relação inter-humana é com exclusão de qualquer outra pessoa; portanto é relação entre o possuidor e o *alter*, a comunidade”.

14

Idem, p. 13. A expressão “poder fático sobre a coisa” é recorrente em textos sobre a posse e a empregarei ao longo dos comentários, ficando desde logo esclarecido que ela não foi criada por mim.

15

Friedrich Carl von Savigny, *Traité de la possession en droit romain*, p. 2, apud Astolpho Rezende, *A Posse e sua Proteção*, p. 47-48. Eis a tradução livre do jurista brasileiro: “Mas, para ser considerada como posse, toda detenção deve ser intencional; isto é, para ser possuidor não basta deter a coisa; é preciso *querer* detê-la. A detenção de uma coisa é um fato físico correspondente ao fato jurídico da propriedade. Por consequência, o *animus possidendi* não é outra coisa que a intenção de exercer o direito de propriedade”.

16

Astolpho Rezende, *A Posse e sua Proteção*, p. 48, assinala que em Savigny a vontade de ter a coisa como possuidor (*animus possidendi*) corresponde à vontade de exercer o direito de propriedade (*animus domini*) ou de ter a coisa para si (*animus sibi habendi*).

17

Rudolf von Ihering, *Teoria simplificada da posse*, p. 107.

18

Idem, p. 105-106. Textualmente: “(...) a verdadeira explicação da diferença está, não na natureza particular da vontade de possuir, a qual não tende nunca à apreensão da coisa, mas na disposição legal que, conforme a diversidade da relação (*causa possessionis*), faz nascer ora a posse, ora a detenção ou a apreensão”.

19

Rudolf von Ihering, *Teoria simplificada da posse*, p. 86-87.

20

São denominadas de absolutas as teorias que sustentam a proteção possessória na posse em si, ao passo que as abordagens que a vinculam à propriedade são chamadas de relativas. Já sob o Código Civil de 1.916 se entendia que a posse é protegida por si mesma, de modo que nosso ordenamento acolheu a orientação das “doutrinas absolutas” de proteção da posse. Ver, sobre o tema, João Baptista Monteiro, *Ação de reintegração de posse*, p. 47.

21

Francisco Cardozo Oliveira, *Hermenêutica e Tutela da Posse e da Propriedade*, p. 83, afirma que a natureza fática da posse permanece, a despeito das mudanças de regimes econômicos, o que não significa que se possa atribuir ao instituto conceito abstrato capaz de permitir a aplicação da noção de posse romana à atualidade. Desse modo, como adverte corretamente o autor, a transposição de conceitos do Direito

Romano para a atualidade não seria nada além de formalismo não histórico.

22

Rudolf von Ihering, *Teoria simplificada da posse*, p. 108-109.

23

Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 67.

24

A Constituição trata da posse de terras ao decretar a nulidade de quaisquer atos jurídicos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse dos povos indígenas (art. 231, § 6.º). Nos demais casos em que o termo é empregado, faz-se referência à posse em cargos eletivos (arts. 28, 29, III e 78, p. ex.) ou ao ingresso no funcionalismo público por militares (art. 142, II e III). Há, ainda, nas hipóteses de pagamento de precatório em decorrência de desapropriação de imóvel residencial único, referência à “imissão na posse” (art. 78, § 3.º, do ADCT). Em nenhum desses casos, logo se vê, ocorre referência ao instituto jurídico da posse.

25

Luiz Edson Fachin, *A função social da posse e a propriedade contemporânea*, p. 19, sustenta que a função social da propriedade consiste no conjunto de limitações imposto pelo interesse público, de modo a retirar da propriedade privada o que pode ser retirado, ao passo que a função social da posse se relaciona à necessidade do possuidor. Segundo o autor, os conceitos não estão no mesmo plano.

26

Art. 2º É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. § 1º A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente: a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias; b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; c) assegura a conservação dos recursos naturais; d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem. (...)

27

No Código Civil de 2002, art. 421, faz-se referência à “função social dos contratos”. Na academia, discute-se sobre a função social da empresa. À própria noção de justiça, acrescentou-se no art. 170 da Constituição, dispositivo que abre o título referente à “Ordem Econômica e Financeira”, o adjetivo *social*, para ressaltar os aspectos igualitário e distributivo do conceito. Friedrich von Hayek, *Direito, legislação e liberdade*, vol. III, p. 79 e ss., critica a noção de justiça social, enfatizando que se trata de tentativa de moralização do processo impessoal e autorregulado de produção e distribuição de bens no regime de mercado. Embora o exame se concentre na locução “justiça social”, as reflexões de Hayek são úteis para se perceber como o emprego de expressões similares tem se dado para justificar a intervenção do Estado e as preferências ideológicas do intérprete e aplicador da lei.

28

Ana Rita Vieira Albuquerque, *Da função social da posse*, p. 199. Segundo a autora, na página 177 da obra citada, sustentar a posse como protegida por si mesma implicaria concebê-la como direito. Por outro lado, sustentar que ela seria protegida em função de outro direito, inviabilizaria vê-la como um direito em si mesma. Todavia, a abordagem de von Ihering já caracteriza um desmentido a esse entendimento, pois o jurista, como se viu, considerava a posse um direito, mas fundamentava sua proteção na tutela da propriedade. Por outro lado, defende-se neste trabalho a caracterização da posse como um fato, cuja tutela deve ocorrer por si próprio, não em atenção à propriedade ou a outro direito. A caracterização da posse como fato consistente na possibilidade de exercício de um dos poderes de propriedade decorre de longa tradição doutrinária e também do direito positivo (Código Civil, art. 1.196).

29

Idem, p. 196-197. Nas páginas 195-196 a autora traz seu conceito de posse: “A posse é forma de ocupação primária, corresponde ao fim último de liberdade e de dignidade da pessoa humana, na medida em que possa estar ligada aos direitos de moradia, possa implementar a erradicação da pobreza e torne efetiva a igualdade entre todos, principalmente diante de um conceito amplo de cidadania”.

30

Ana Rita Vieira Albuquerque, *Da função social da posse*, p. 205.

31

Idem, p. 209-212.

32

Paula Pessoa Pereira, *Legitimidade dos precedentes*, p. 57: “Aulis Aarnio afirma que os tribunais deem se comportar de maneira tal que os cidadãos possam confiar e, a partir daí, planejar suas ações e atividades sobre bases racionais, porquanto as decisões judiciais, em muitos casos, são a punica razão propriamente dita para um planejamento futuro. E é justamente nesses casos, em que a decisão se apresenta como único veículo de confiança justificada dos cidadãos, que o juiz tem uma verdadeira responsabilidade, que é a de procurar realizar a expectativa da certeza jurídica”.

33

Luiz Eduardo Ribeiro Freyesleben, *A usucapião especial urbana*, p. 21, assinala que o uso da terminologia “prescrição aquisitiva”, em vez de “usucapião” tem sido alvo de críticas infundadas, pois a usucapião é modalidade do gênero prescrição. O autor afirma com grande precisão que tanto na hipótese de prescrição aquisitiva, quanto na de extintiva, está-se diante de idêntica “situação estrutural”, qual seja, “situações amalgamadas pelo tempo e pela inércia do titular do direito”.

34

Francisco Cardozo Oliveira, *Hermenêutica e tutela da posse e da propriedade*, p. 90. Textualmente: “No desenvolvimento do capitalismo a apropriação de bens que caracteriza a posse evoluiu para assumir a forma jurídica do direito de propriedade. Esvaziou-se o conteúdo da posse, que exprime a natureza fática da apropriação de bens, voltada para a satisfação das necessidades humanas. Prevaleceu a noção de posse valorada pela forma jurídica do direito de propriedade, onde a apropriação de bens é regulada pelo mercado”. O autor cita em nota de rodapé o volume I de “O Capital”, p. 80.

35

Max Weber, *A ética protestante e o espírito do capitalismo*, p. 156-157: “(...) a valorização religiosa do trabalho profissional mundano, sem descanso, continuado, sistemático, como o meio ascético simplesmente supremo e a um só tempo comprovação a mais segura e visível da regeneração de um ser humano e da autenticidade de sua fé, tinha que ser, no fim das contas, a alavanca mais poderosa que se pode imaginar da expansão dessa concepção de vida que aqui temos chamado de ‘espírito’ do capitalismo”. Passados mais de cento e dez anos de sua primeira publicação, no periódico *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, coordenado pelo próprio Weber, “A Ética Protestante” continua sendo explicação inexcedível sobre a formação do capitalismo e a importância que nela desempenharam elementos culturais, notadamente a noção de ascese professada pelas seitas protestantes. Do mesmo autor, sobre o tema, ver ainda *A gênese do capitalismo moderno*, p. 106 e ss., na qual é abordada a formação da mentalidade capitalista.

36

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 428-429, apresenta argumento similar para criticar antigo acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, que exigira do autor da ação possessória a apresentação de documento que comprovasse a incorporação do bem à sua esfera patrimonial. Sustentou o jurista: “O Tribunal de Apelação do Piauí, a 4 de maio de 1.939 (*Acórdãos*, 192), exigiu ao autor da ação possessória apresentar título legítimo pelo qual o bem se lhe incorporou ao patrimônio. Escusado é dizer-se que absurdamente o exigiu. A posse pode ser adquirida por ato-fato jurídico; e na ação possessória só se alega posse, e não domínio, ou outro direito real ou pessoal: o próprio possuidor imediato da casa, que a possui como locatário, não precisa exhibir o título de locação. O que se está a discutir é posse, e não direito”. Aproximando a lição do tema em análise, pode-se afirmar que o objeto da discussão, nas ações possessórias, é a posse, não os requisitos previstos para que se considere cumprida a função social da propriedade.

37

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 48.

38

Súmula 193. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por usucapião.

39

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 48-51.

40

Moreira Alves, *Posse: estudo dogmático*, vol. II, t. I, p. 153. Transcreve-se a passagem: “As coisas corpóreas – que são as perceptíveis pelos nossos sentidos, e não apenas pelo tato como as definiam os romanos (*ea quae tangi possunt* – as que podem ser tocadas) que é a maneira mais comum de se revelar a materialidade da coisa – abarcam, portanto, as matérias em estado gasoso (assim, o gás, o vapor), bem como as *energias* ou *forças* naturais, como a energia elétrica, pois umas e outras são susceptíveis de percepção pelos sentidos”.

41

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: I – as energias que tenham valor econômico.

42

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 147-148.

43

Súmula 228. É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.

44

Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela contra o ilícito*, p. 235.

45

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 153.

46

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

47

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

48

Cf. Clóvis Beviláqua, *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado*, p. 15.

49

Cf. Orlando Gomes, *Direitos reais*, p. 41.

Cf. Tito Fulgêncio, *Da posse e das ações possessórias*, vol. I, p. 39.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Cf. Manoel Antônio Coelho da Rocha, *Instituições de direito civil*, p. 256.

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 165.

Art. 1.201, parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Darcy Bessone, *Direitos reais*, p. 272, apresenta elucidativa explicação: “A palavra *título* não é empregada no sentido de instrumento ou documento. Comporta, em Direito, mais de uma acepção. Ela é usada no sentido de instrumento ou documento, mas, no caso, não é esse o sentido em que a lei a emprega. Título, aqui, é o fato gerador do direito, o fato do qual a posse deriva. A justiça do título diz respeito à sua aptidão, em princípio, para constituir ou transmitir o direito”.

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 175.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 196-197.

60

Art. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas de produção e custeio.

61

Art. 1.214, parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação.

62

Art. 1.218. O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante.

63

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

64

Art. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.

65

Art. 1.217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa.

66

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

67

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

68

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 202.

69

70

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

71

Astolpho Rezende, *A posse e sua proteção*, p. 236-237. Lafayette Rodrigues Pereira, *Direito das coisas*, vol. I, p. 41, assinalava: “A posse é de sua natureza exclusiva. Se alguém tem o poder de dispor fisicamente de uma coisa, é evidente que em relação a essa mesma coisa outro não pode ter igual poder: – o poder dum aniquilaria o poder do outro”. Clóvis Beviláqua, *Direito das coisas*, vol. I, p. 40, reconhecia a impossibilidade de o mesmo bem ser possuído por dois ou mais sujeitos, mas admitia a possibilidade de composses de coisa indivisa: “A posse, como a propriedade, é exclusiva, no sentido de que duas ou mais pessoas não podem possuir, simultaneamente e por inteiro, a mesma coisa. Pode, porém, uma coisa indivisa ser possuída em comum, seja ou não, no exercício de um direito, como no regime de comunhão de bens, marido e mulher, ou na transmissão da herança, herdeiros, antes da partilha”.

72

Antônio Joaquim Ribas, *Da Posse e das Ações Possessorias*, p. 89.

73

Tito Fulgêncio, *Da Posse e das Ações Possessórias*, vol. I, p. 33.

74

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 111-112.

75

Lafayette Rodrigues Pereira, *Direito das coisas*, vol. I, p. 42. *In verbis*: “Entretanto, nada obsta que diversas pessoas possuam em comum uma mesma coisa indivisa (*pro indiviso*); – é o que se chama *posse comum*, ou segundo a tecnologia moderna – *compossessão* – (*compossessio*). Nesse caso nenhum dos compossuidores possui a coisa por inteiro, mas cada um possui uma *parte abstrata*, e não pode dispor senão dessa parte”. Seguindo o Conselheiro Lafayette, Tito Fulgêncio, *Da posse e das ações possessórias* p. 33 e Orlando Gomes, *Direitos reais*, p. 49.

76

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 114.

77

Astolpho Rezende, *A posse e sua proteção*, p. 237. No mesmo sentido, Darcy Bessone, *Direitos reais*, p. 267.

78

Tito Fulgêncio, *Da posse e das ações possessórias*, vol. I, p. 36.

79

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou de instruções suas.

80

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

81

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

82

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. VIII, t. III, p. 338.

83

Astolpho Rezende, *A posse e sua proteção*, p. 139.

84

Eduardo Espínola, *Posse, propriedade, compropriedade ou condomínio. Direitos autorais*, p. 33.

85

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 6.

86

Idem, p. 35.

87

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XI, t. I, p. 121.

88

Roberto Mattoso Câmara Filho, *Posse e ações possessórias*, p. 4.

89

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, vol. VIII, t. III, p. 337.

90

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 123 e ss.

91

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XIII, p. 255. Pela impossibilidade de ajuizamento de ação possessória pelo detentor se manifestara Tito Fulgêncio, que não distinguia entre detentor dependente e independente. Vide *Da posse e das ações possessórias*, vol. I, p. 90.

92

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 115.

93

Rudolf von Ihering, *Teoria simplificada da posse*, p. 87-91.

94

Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 64.

95

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, vol. XIII, p. 200.

96

Art. 1.213. O disposto nos artigos antecedentes não se aplica às servidões não aparentes, salvo quando os respectivos títulos provierem do possuidor do prédio serviente, ou daqueles de quem este os houve.

97

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 344-345.

98

Roberto Mattoso Câmara Filho, *Posse e ações possessórias*, p. 297.

99

Astolpho Rezende, *A posse e sua proteção*, p. 167.

TJPR, Ap. Cív. 1.441.064-9, 17ª Câmara Cível, Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, J. 02.03.2016: “1. O direito de vizinhança de passagem forçada e a servidão de passagem são fatos jurídicos distintos, com suportes fáticos e efeitos absolutamente diversos. 2. O manejo de ações possessórias apenas é possível em relação às servidões aparentes, mesmo que não constituído formalmente o direito real de fruição sobre coisa alheia em questão, sendo incompatível a proteção possessória com o direito de vizinhança de passagem forçada, por sua própria natureza. 3. A legitimidade passiva nas ações possessórias típicas – reintegração, manutenção e interdito proibitório – coincide com aquelas pessoas que, nos termos em que narrados na inicial (in status assertionis), são responsáveis pelos atos de esbulho, turbação ou ameaça à posse dos autores. 4. O fato de alguém ser proprietário do imóvel litigioso (no caso, do imóvel no qual está localizada a servidão aparente de passagem) não lhe concede legitimidade para figurar como réu em ação possessória relativa ao bem, quanto mais se os atos de esbulho, turbação ou ameaça são imputados exclusivamente a outras pessoas, pelos próprios autores – até porque, como é dito e repetido por esta Câmara Cível constantemente, em sede de ações possessórias o que se discute é posse, não direito de propriedade”. O julgado é interessantíssimo não apenas por estabelecer a incompatibilidade da tutela possessória com o direito de vizinhança de passagem forçada, mas também por assentar a ilegitimidade passiva, nas ações possessórias, do proprietário do imóvel em que se localiza a servidão de passagem. Também merece relevo o trecho no qual se enfatiza que no juízo possessório não se discute o direito de propriedade. Ressalve-se que ao afirmar que somente é possível a tutela possessória das servidões aparentes, o julgado as contrapõe ao direito de vizinhança, não às servidões não aparentes, cuja tutela possessória pode ocorrer na forma do art. 1.213 do CC.

Ver TJPR, Ap. Cív. 0001655-26.2014.8.16.0121, 18ª Câmara Cível, Rel. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 21.03.2018: “Apelação cível. Ação de manutenção de posse. Sentença de improcedência. Existência de servidão de passagem aparente e contínua. Turbação não configurada. Aplicação da Súmula 415 STF. Recurso improvido. 1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação ou reintegrado, no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, sua data, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso dos autos, restou comprovada a existência de servidão aparente, nos termos do artigo 1.379 do Código Civil, o que afasta a ocorrência da turbação, eis que merece proteção possessória, nos termos da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal”.

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 347.

Súmula 415. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

105

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

107

Art. 1.205. A posse pode ser adquirida: I – pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante; II – por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação.

108

Arruda Alvim, *Comentários...*, p. 220 e ss.

109

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

110

Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

111

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

112

Eduardo de Oliveira Leite, *Comentários ao novo Código Civil*, vol. XXI, p. 19-20.

113

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 234.

114

TJPR, Ag. Inst. 1.555.002-0, 11ª Câmara Cível, Rel. Lenice Bodstein, j. 22.02.2017: “Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Sucessão. Situação fática. Reintegração de posse de inventariante comprovada. Herdeiro que invade imóvel sem autorização judicial. Esbulho configurado. Requisitos do art. 561/CPC preenchidos. 1. Inventariante que tem o poder de fato sobre a coisa, caracterizando posse. 2. Ordem judicial que indeferiu o ingresso de herdeira no imóvel. Esbulho configurado. Recurso conhecido e não provido”.

115

Art. 1.923. Desde a abertura da sucessão pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. § 1.º. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria.

116

Arruda Alvim, *Comentários...*, p. 233.

117

Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.

118

Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repellido.

119

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 396-397.

120

Art. 1.209. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem.

121

Art. 3.º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I – as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

122

Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 290. No mesmo sentido, Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 315.

123

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 317.

124

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, vol. XIII, p. 200.

125

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XI, t. I, p. 121. No mesmo sentido, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 341.

126

Art. 557, parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

127

Art. 1.210, § 2.º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

128

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, vol. II, p. 267-268. No mesmo sentido, apontando a restrição cognitiva nas ações possessórias, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos especiais*, p. 93-94.

129

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, vol. XIII, p. 205.

130

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, vol. VIII, t. III, p. 346.

131

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 205 e ss.

132

Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, t. X, p. 15. No mesmo sentido, aludindo às pretensões reais, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 207.

133

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. (...) § 2.º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de comosse ou de ato por ambos praticado.

134

Art. 1.210, § 1.º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

135

João Baptista Monteiro, *Ação de reintegração de posse*, p. 49. Nas palavras do autor: “A legítima defesa da posse não pode confundir-se com o desforço. A primeira somente tem lugar enquanto a perturbação perdurar. Se o possuidor já perdeu a posse, por ato do perturbador, já não se pode falar em legítima defesa. A legítima defesa, pressupõe, portanto, a atualidade da violação e a simultaneidade da reação do possuidor, que põe fim à perturbação antes da consumação da perda da posse. O segundo somente pode ter lugar após a perda da posse. O desforço é a atuação daquele que perdeu a posse, através da utilização de força própria para retomar a coisa”.

136

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 348. Na mesma página o autor menciona que o termo “resistência” se aplica aos casos de turbação, aplicando-se o termo “desforço” na hipótese de esbulho.

137

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 358. Na página 360 da mesma obra, o autor assinala que pode ocorrer violação à posse mediata, sem que a posse imediata seja ofendida simultaneamente. É o que ocorreria quando o arrendatário, possuidor direto, permitisse que fossem desmontadas grades do jardim, que fossem colhidas frutas ou que fosse extraída lenha. Também ocorreria apenas violação à posse mediata quando o possuidor direto permitisse que caça e pesca fossem realizadas no bem arrendado. Tudo isso demonstra o acerto da posição do jurista ao defender com grande precisão a possibilidade de o possuidor mediato se valer da legítima defesa ou do desforço incontinenti.

138

Idem, p. 347.

139

Antônio Joaquim Ribas, *Da posse e das ações possessórias*, p. 240. Textualmente: “Mas, devemos observar que nenhuma lei concede às nossas autoridades judiciais ou policiais a atribuição de concederem este auxílio, sem exame do caso e a simples requerimento da parte; e que seria temeridade que o fizessem, pois delle se poderia facilmente aproveitar o esbulhador, quer para commeter o esbulho, allegando ser o desforçamento, quer para se defender contra o desforçamento, allegando ser este o esbulho contra o qual elle apenas se defende”.

140

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 358.

141

Idem, p. 352.

142

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 358.

143

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, vol. II, p. 232 e ss.

144

Ovídio Baptista da Silva, *Ação de imissão de posse*, p. 168. No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 412. Textualmente: “A ação de imissão de posse é o meio processual pelo qual se permite que aquele que tem o *direito de haver a posse* atue contra aquele que se obrigou a transferi-la”.

145

Ovídio Baptista da Silva, *Ação de imissão de posse*, p. 183.

146

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 415.

147

Ovídio Baptista da Silva, *Ação de imissão de posse*, p. 120, 153 e 157. Nesta última página, como hipóteses de propositura de ação de imissão de posse sem que o autor seja proprietário, Ovídio Baptista reproduz os exemplos de Pontes de Miranda, quais sejam, a ação do cessionário da herança quando tiver sido registrado o contrato de transmissão e a ação do vendedor para a imissão na posse da coisa alienada após prolatação de sentença em demanda de redibição.

148

Idem, p. 166-167. Segundo Ladislau Karpát, em *Tutela antecipada na defesa da posse e da propriedade imóvel*, p. 112, a ação de imissão de posse será sempre proposta pelo proprietário que não é possuidor. As ações de imissão de posse se diferenciariam das reivindicatórias à medida que a propriedade do autor seria um pressuposto, o que não ocorreria nas ações de reivindicação. Esse posicionamento, contudo, é duplamente impreciso. Em primeiro lugar, a imissão de posse pode ser proposta por quem não seja proprietário, bastando, para tanto, que tenha direito à posse. Ademais, contrariamente ao que afirma Ladislau Karpát, as demandas reivindicatórias têm como premissa a propriedade do autor. Se houver propositura de demanda reivindicatória, sem que o autor invoque a propriedade, impor-se-á a extinção do processo sem resolução de mérito.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato construtivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1.º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Pontes de Miranda, *Tratado das ações*, t. VI, p. 195. No mesmo sentido se manifesta Ladislau Karpát, *Tutela antecipada...*, p. 83, afirmando que os embargos atacam o ato judicial. Adroaldo Furtado Fabrício reconhece a feição possessória dos embargos de terceiro fundamentados na agressão à posse, mas salienta a maior conveniência de que a hipótese seja tratada separadamente das ações possessórias, pois são cabíveis embargos de terceiro com fundamento em propriedade e direitos creditórios. Vide *Comentários...*, p. 344.

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. II, p. 102. Textualmente: “O ato de vir a juízo pedindo tutela jurisdicional, chamado *demanda*, tem por conteúdo uma *pretensão* de quem o realiza. Pretensão é a *exigência de subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio*”.

Eduardo de Avelar Lamy, *Princípio da fungibilidade no processo civil*, p. 95, esclarece que o vocábulo “fungibilidade”, no âmbito do direito, se relaciona à ideia de substitutividade. Nas palavras do autor: “(...) no âmbito do direito material, fungibilidade significa generalidade e, conseqüentemente, substitutividade, possibilidade inerente de troca”.

Arruda Alvim, *Manual de direito processual civil*, vol. II, p. 237, esclarece com grande precisão a diferença entre pedido imediato e pedido mediato, embora indique somente três espécies de pedido imediato, em conformidade com a teoria ternária, ignorando a possibilidade de pedidos mandamentais e executivos. *In verbis*: “O *pedido imediato* (tipo de providência jurisdicional solicitada, isto é, *declaração, constituição/desconstituição* ou *condenação* do réu que, nesta medida, determina a natureza da *ação*; pedido imediato, pois, é aquele que desde logo, diretamente se deseja; é o pedido dirigido ao Poder Judiciário, no sentido de que outorgue a tutela *especificamente* solicitada. Já o chamado *pedido mediato* representa o bem jurídico material (*bem da vida*) subjacente ao *pedido imediato*”.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, vol. XIII, p. 207/208. No mesmo sentido, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, vol. VIII, t. III, p. 359, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos especiais*, p. 90-91 e Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 221. Saliente-se que Joel Dias Figueira Jr., na passagem citada, sustenta a falta de interesse processual no pedido de interdito proibitório apresentado depois da propositura da ação de manutenção. Em sentido contrário se manifestara, Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 181. Se deferida a liminar de manutenção, por certo não haverá interesse processual na apresentação de pedido inibitório. Todavia, indeferida a manutenção, pois não demonstrada a turbação, pode o juiz deferir o interdito proibitório se considerar caracterizada a ameaça. Logo, há fungibilidade entre o pedido de manutenção e o de inibição.

156

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

157

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 358-359 e Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 182. Em sentido contrário, indicando que o juiz pode conceder pedido diverso, Antônio Carlos Marcato, *Procedimentos especiais*, p. 152.

158

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

159

Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 252.

160

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

161

Adroaldo Furtado Fabrício, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.440.

162

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

163

TJPR, Ag. Inst. 0010710-34.2018.8.16.0000, 8ª Câmara Cível, Rel. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 29.05.2018: “Decisão monocrática. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Afirmação de insuficiência de recursos. Presunção relativa de veracidade. Utilização do teto de isenção do imposto de renda como parâmetro. Observância do art. 99, § 2º, do CPC/2015. Renda líquida superior ao teto de isenção. Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza afastada. Recurso não provido”.

164

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: II – réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

165

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

166

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1.º. São requisitos de admissibilidade da cumulação que: I – os pedidos sejam compatíveis entre si; II – seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III – seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

167

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, vol. VIII, t. III, p. 365.

168

Art. 327, § 2.º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

169

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

170

Adroaldo Furtado Fabrício, *Breves comentários...*, p. 1.443.

171

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XI, t. I, p. 130.

172

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, vol. VIII, t. III, p. 361.

173

Art. 1.217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa.

174

Art. 1.218. O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante.

175

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 132-133. Ovídio Baptista da Silva endossa esse posicionamento. Vide *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XIII, p. 212-213.

176

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) inc. IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

177

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. *Novo curso de processo civil*, vol. II, p. 764: “Todavia, viu-se que a adequada interpretação do art. 139, IV, do CPC, permite superar essa dicotomia injustificável, concluindo que todas as sentenças contêm executividade intrínseca e permitem a efetiva e plena realização do direito, pouco importando se se trata de prestação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar quantia. O dispositivo mencionado deve iluminar todo o sistema de tutela dos direitos, servindo como marco essencial para as técnicas de efetivação das decisões jurisdicionais. Assim, a técnica dos arts. 523 ss. (ou seja, a execução por expropriação patrimonial) passa a ser apenas uma das modalidades admitidas para a proteção de prestações pecuniárias, que não exclui, nem prefere, qualquer outra modalidade possível. Tudo deve reger-se pelos princípios da maior efetividade para o exequente e da menor onerosidade para o executado, na forma já estudada”. No mesmo sentido, Ricardo Alexandre da Silva, *Atipicidade dos meios executivos na efetivação das decisões que reconheçam o dever de pagar quantia no novo CPC*, p. 564: “O art. 139, IV do NCPC caracteriza uma abertura do sistema à possibilidade de aplicação, inclusive no âmbito da tutela jurisdicional pecuniária, de mecanismos de indução e de sub-rogação, à semelhança do que ocorre em relação aos provimentos proferidos para a tutela das obrigações de fazer ou não fazer por força do art. 536, § 1.º”.

178

Sobre a eficácia executiva da sentença de reintegração de posse e mandamental das sentenças de

manutenção e de interdito proibitório, veja-se Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, vol. II, p. 268 e 419. Essa classificação foi apresentada pioneiramente por Pontes de Miranda no *Tratado das ações*, t. VI, p. 103.

179

Luiz Guilherme Marinoni. *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 120: “As sentenças (condenatória, mandamental, etc.) são técnicas que permitem a prestação da tutela jurisdicional dos direitos. Mas, quando se pensa em termos de ‘tutela dos direitos’, é preciso verificar se o processo está conferindo a sua devida e adequada tutela, e para tanto não basta saber se foi proferida uma sentença condenatória ou mandamental, uma vez que estas não refletem o resultado que o processo proporciona no plano do direito material. Na verdade, as sentenças refletem apenas o ‘modo’ (a técnica) pelo qual o direito processual tutela os diversos casos conflitivos concretos”. No mesmo sentido se manifesta Gustavo Osna. *Direitos individuais homogêneos*, p. 25: “Com efeito, a modificação teleológica faz com que a simples declaração (hoje compreendida com a hermenêutica como médium necessário) não encerre a atividade judicatória ou exonere o magistrado. Considerando que seu objetivo final passa a ser a efetiva proteção do interesse material, é apenas com a concretização de tal resultado que sua tarefa terá sido satisfatoriamente realizada”. A ênfase na tutela do direito leva à classificação das tutelas em atenção ao direito material e, mais do que isso, à adaptação da estrutura do processo ao direito protegido, conforme assinala Sérgio Cruz Arenhart. *Perfis da tutela inibitória coletiva*, p. 100: “Toda essa classificação é pensada sob o prisma das peculiaridades diferenciadas da realidade jurídica a ser atendida. Assim, consubstancia a preocupação do processo com o direito material, que procura adequar-se a este para bem cumprir suas funções. Além de preocupar-se, então, com o tipo de provimento conferido, vai buscar adequar toda a estrutura do processo ao direito material, seja considerando os pressupostos processuais (como a legitimidade e a competência para a ação), seja estabelecendo a forma de realização do direito mais adequada para o caso específico”. Vê-se, assim, que é necessário dotar os juízes de técnicas adequadas para a efetivação do direito, conforme assinala Clayton Maranhão, *Tutela jurisdicional do direito à saúde*, p. 159: “De nada adiantaria a previsão de formas substanciais adequadas de tutela se, no plano do processo, inexistirem técnicas processuais adequadas à efetivação dessa mesma tutela. Só a presença no ordenamento jurídico de técnicas processuais adequadas de efetivação permitem a realização máxima da garantia constitucional de tutela jurisdicional efetiva e adequada, pois o isolamento científico das formas *flexíveis* de tutela jurisdicional mandamental e executiva *lato sensu* somente foi possível por intermédio da conjugação delas com técnicas processuais de efetivação”. É no contexto da tutela jurisdicional efetiva e adequada que se afirma a atipicidade dos meios executivos, a fim de que o juiz possa utilizar meios adequados para a tutela ressarcitória.

180

Art. 4.º. As partes têm o direito de obter-me prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

181

Luiz Guilherme Marinoni. *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 313.

182

Idem, p. 333.

183

Idem, p. 313.

184

Idem, p. 311.

185

Idem, p. 314. Sobre a cumulação da tutela ressarcitória específica com a tutela ressarcitória pelo equivalente, veja-se páginas 318 e ss. do mesmo livro.

186

Sobre a possibilidade de demolição de construções, ver TJPR, Ap. Cív. 1.592.945-0, 17ª Câmara Cível, Rel. Rosana Girardi Fachin, j. 08.03.2017: “Apelação cível. Ação de reintegração de posse c/c pedido de cominação de pena para caso de novo esbulho e desfazimento de construção com pedido liminar. Sentença de procedência. Posse anterior e esbulho demonstrados. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Alegação da titularidade do imóvel que apenas reforça o justo exercício da posse pela autora. Fato modificativo Não comprovado. Ônus dos requeridos. Inconsistência das alegações de aquisição do bem, pelos requeridos, em face do acervo probatório. Aquisição de cotas de empreendimento que sequer foi objeto de cessão formal. Reintegração de posse devida. Retorno ao *statu quo ante*. Demolição das construções. Art. 55, parágrafo único, II, CPC. Sentença mantida”. Acerca da aplicação da multa nas ações possessórias, ver TJSC, Ap. Cív. 0302251-39.2015.8.24.0036, Rel. Sebastião César Evangelista, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 12-04-2018: “(...) A legislação processual civil prevê a possibilidade de o magistrado fixar multa cominatória em ações possessórias, com o escopo de coibir a parte a praticar ou deixar de praticar determinado ato (artigo 555, parágrafo único, incisos I e II, do CPC/15). A multa aplicada deve ser suficiente e compatível com a obrigação (artigo 537, CPC/15), justamente para compelir a parte obrigada a cumprir a determinação judicial e, de outro lado, impedir que volte a reincidir em atitude perniciosa aos interesses tutelados na demanda. (...)”.

187

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 602. Na redação dos autores: “Aliás, como é declarada a ilicitude da construção ou da plantação, não há o menor cabimento em *condenar* o réu a desfazer, uma vez que, para a tutela do direito, não é preciso esperar uma prestação, sendo necessária, ao revés, apenas a prática de atos executivos por parte do próprio órgão jurisdicional para a remoção do ilícito”.

188

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. II, p. 167.

189

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

190

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, vol. VIII, t. III, p. 363.

191

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

192

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos ou parcela deles: I – mostrar-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

193

Para uma análise do julgamento antecipado parcial do mérito, vide Ricardo Alexandre da Silva, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 960 e ss.

194

Adroaldo Furtado Fabrício, *Breves comentários...*, p. 1.444.

195

Antônio Carlos Marcato, *Procedimentos especiais*, p. 154.

196

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, vol. XIII, p. 215.

197

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, vol. VIII, t. III, p. 368.

198

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

199

Analisando o código anterior, Clóvis do Couto e Silva assinalava que o réu poderia apresentar as mesmas pretensões que o autor, apesar de o dispositivo se referir somente às tutelas possessória e ressarcitória. Vide *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XI, t. I, p. 136. Concorde com essa posição, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 369.

200

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 216.

201

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 370. No mesmo sentido, Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 314-315.

202

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 369.

203

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 197.

204

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 371.

205

Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 312.

206

Eis a redação do dispositivo à época de revogação do código anterior: “Art. 923. Na pendência do processo possessório é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar ação de reconhecimento do domínio”. Observe-se que na redação original havia um complemento, em parte observado no art. 557: “Não obsta, porém, à manutenção ou à reintegração na posse a alegação de domínio ou de outro direito sobre a coisa; caso em que a posse será julgada em favor daquele a quem evidentemente pertencer o domínio”. Essa redação suscitou grande controvérsia, pois derogava o art. 505 do CC de 1.916, cuja parte final assinalava: “Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio”.

207

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 199. No mesmo sentido, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 379.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 379 e ss. Na 9ª edição, considerando que o Código Civil vigente, no art. 1.210, § 2.º, passou a prever de forma radical a proibição da exceção de domínio, o autor defendeu que teria ocorrido derrogação do art. 923 do CPC/1973, dispositivo de conteúdo idêntico ao art. 557, *caput*, primeira parte, à medida que a proibição de discussão do domínio no âmbito das ações possessórias impediria a única interpretação razoável da regra contida no art. 923 do código revogado, qual seja, a de que seria proibido ajuizar ações declaratórias de domínio, na pendência da ação possessória, apenas quando os litigantes postulassem a posse com base no domínio. Com a vigência do CPC/2015 o autor voltou a professar a posição que defendera antes da vigência do CC/2.002. Essa questão será abordada adiante. Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, vol. III, p. 45, também sustenta que a proibição de ajuizamento de ação dominial, na pendência de demanda possessória, limita-se às hipóteses em que a posse, nas possessórias, é pleiteada com base no domínio.

Arruda Alvim, *Comentários...*, p. 249. Por sua importância para o argumento aqui desenvolvido, faz-se a transcrição da passagem com os destaques do autor: “As ações possessórias *stricto sensu* são as ações em que se discute, *exclusivamente*, sobre posse – enquanto fato – e aquilo que disso *diretamente* deriva, tal como o direito o discipline”. E prossegue nas p. 256-257: “O plano de discussão e avaliação da situação possessória é *como situação de fato (situação possessória, exclusivamente)*, ou seja, fundamentalmente, tendo em pauta o *ius possessionis* e não o *ius possidendi*. Nada impede que haja referência ao *direito*, apenas com vistas ao esclarecimento da situação possessória (*ad colorandum et corroborandum possessorium*)”. Como se vê, pode ocorrer *referência* ao direito, o que não equivale a postular com fundamento no direito, como se verifica no seguinte trecho da mesma obra, retirado das p. 276-277: “Com isto, o que se verifica é que se o art. 927 diz respeito aos elementos que hão de ser trazidos para o juízo que há de ser feito em sede de pedido de liminar, pelo texto do art. 1.210, § 2.º, constata-se que – *percebida congruência atinente ao âmbito possível de alegações no juízo possessório* – em todo processo em que se tenha por objeto ação possessória *stricto sensu* não há espaço para alegação de direito, em função do qual se pudesse embasar a situação possessória. Se alegado, não deverá ser considerado, justamente porque, ao lado da vedação legal, *ad argumentandum tantum*, isto não obsta à solução possessória, em favor daquele cuja posse deve ser protegida, *independentemente do possível direito que possa estar subjacente à posse do adversário*”.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Breves comentários...*, p. 1.446. No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 922.

Gleydson Kleber Lopes de Oliveira, *Ações possessórias enfoque sobre a cognição*, p. 104 e 107. Na primeira passagem o autor alude à necessidade de interpretação conforme, salientando que o intérprete deve encontrar um sentido para o texto legal que esteja em conformidade com a Constituição.

Súmula 487. Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.

213

Arruda Alvim, *Comentários...*, p. 281.

214

Idem, p. 285.

215

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 225.

216

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 604.

217

Sobre a técnica da interpretação conforme a Constituição, afirmou Luiz Guilherme Marinoni em *Tutela inibitória*, p. 175: “A interpretação conforme estabelece uma única interpretação *conforme* a Constituição, declarando que *todas as outras são com elas incompatíveis*”. Isso significa que quaisquer outros sentidos que fossem atribuídos ao art. 557 do CPC serão inconstitucionais.

218

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 199. Por sua importância para o argumento, transcreve-se a passagem em que a ideia é defendida: “O que se há de entender é que não se pode, pelo simples fato de ter alguém proposto ação possessória, ficar inexercível a ação de reivindicação, ou mesmo a ação de declaração do domínio, fora do processo possessório. No processo da ação possessória de modo nenhum se pode propor, com a contestação, a contra-ação em que se alegue o domínio, ou se meter na petição da ação possessória o pedido de reivindicação, ou de declaração do domínio. Seria absurdo que, pela simples pendência de ação possessória, que pode ir até o julgamento de recursos, ficasse o proprietário privado do exercício da pretensão à tutela jurídica”.

219

Na redação original: “Na pendência do processo possessório é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento do domínio. Não obsta, porém, à manutenção ou à reintegração na posse a alegação de domínio ou de outro direito sobre a coisa; caso em que a posse será julgada em favor daquele a quem evidentemente pertencer o domínio”.

220

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 378-379. A crítica foi mantida na 9ª edição dos “Comentários” do autor ao CPC/1973, como se vê na p. 454.

221

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 200. Por sua centralidade para o argumento, transcreve-se textualmente a posição do jurista: “Vedar-se a quem é proprietário propor ação de reivindicação, ou mesmo a ação de declaração da propriedade (art. 4.º), inclusive a de usucapião, que é declaratória, seria nada menos do que se permitir que alguém que sabe da próxima propositura da ação concernente à propriedade, entre com a ação possessória, para que a pendência de tal ação obste ao exercício da pretensão e da ação do proprietário”.

222

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, 378.

223

Francisco de Paula Batista, *Compêndio de teoria e prática do processo civil*, p. 54-55.

224

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 218.

225

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 379.

226

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários ...*, p. 464. Por sua importância, faz-se a transcrição da passagem: “Ora, como anteriormente ficou visto, a aplicação do disposto no art. 923, em sua única interpretação aceitável, tinha por pressuposto a introdução, no debate possessório, da discussão relativa ao *ius possidendi*, consoante entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência. Agora, afastada a possibilidade dessa interpenetração das duas questões no mesmo processo, torna-se impossível a ocorrência desse pressuposto. A abolição da *exceptio dominii*, operada pelo novo Código Civil, afasta a possibilidade de se questionarem no âmbito da ação possessória temas relacionados ao direito de possuir, com o que também desaparecem a oportunidade e o motivo, antes presentes, para a vedação da propositura da ação petítória no curso da possessória. Com base nesse raciocínio, portanto, é possível afirmar-se que, pela via indireta da supressão de sua hipótese de incidência (suporte fático, *fattispecie*, *tatbestand*), resultou derogada a regra do art. 923 do Código de Processo Civil. Texto legal, aliás, que não deixará saudades, certo que sua aplicação foi sempre motivo de intermináveis disceptações e controvérsias, inspirando-se sua formulação, de resto, em conceitos que a moderna ciência do processo não mais prestigia”. Com a lamentável, desnecessária e inusitada reiteração, no art. 557, *caput*, do CPC, do que constava no art. 923 do CPC/1973, Adroaldo Furtado Fabrício voltou a defender sua posição original, sustentando que a limitação estabelecida no dispositivo se aplica às hipóteses em que a disputa da posse ocorra com fundamento no domínio. Vide, do autor, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*,

227

STF, RE 87.344, rel. Min. Moreira Alves, j. 14.09.1978, publicado no *DJ* em 16.10.1978, p. 8.022. Eis a ementa: “Concorrência de Ações. Ação de Reivindicação e Ação Possessória. Trancamento da Ação de Reivindicação com Base na Interpretação Literal da Primeira Parte do art. 923 do Código de Processo Civil. Aplicando-se a hipótese do art. 308, VII, do Regimento Interno, e havendo sido rejeitada a arguição de relevância, o recurso extraordinário só poderá ser apreciado no que diz respeito à alegação de ofensa ao art. 153, *caput* e § 22, da Emenda Constitucional 1/69. Não é inconstitucional o artigo 923, 1ª parte, do Código de Processo Civil, não o sendo também a interpretação literal que lhe deu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário não conhecido”.

228

Arruda Alvim, *Comentários...*, p. 278-281, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos especiais*, p. 94, Antonio Carlos Marcato, *Procedimentos especiais*, p. 95. Sob o CPC/2015 esse entendimento conta com as adesões de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 921-922 e de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 604.

229

STJ, AgRg no REsp 1.389.622/SE, 4ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJe* 24.02.2014. Com o mesmo entendimento, AgRg no REsp 1.296.991/DF, 1ª Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 18.06.2012. Neste caso foi rejeitada oposição ajuizada por terceiro com fundamento no domínio.

230

Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 922.

231

Pontes de Miranda, *Tratado das ações*, t. II, p. 228-229.

232

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 318.166/SP, 4ª Turma, rel. Min. Raul Araújo, *DJe* 28.03.2014. No mesmo sentido, REsp 171.624/MG, 4ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro *DJ* 18.10.2004, p. 279, cuja ementa assinala: “Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião. Recurso especial conhecido e provido”.

233

O Enunciado 443, do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, admite a alegação de usucapião, como matéria de defesa, nas ações possessórias propostas pelo proprietário: “Em ação possessória movida pelo proprietário é possível ao réu alegar a usucapião como matéria de defesa, sem violação ao art. 557”. Esse entendimento não é correto, pois como visto no texto, a interpretação conforme a Constituição leva à vedação de pedidos petitórios contrapostos ou de reconvenção petitória. O réu, contudo, poderá formular demanda na qual requeira a usucapião. Essa solução não cultua o formalismo estéril. Pretende-se evitar que discussões petitórias sejam trazidas para o âmbito dos interditos possessórios.

234

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 374, adverte que a exceção de domínio consiste, mais propriamente, em alegação baseada no *jus possidendi*, o qual não tem na propriedade o fundamento exclusivo.

235

Art. 505. Não obsta a manutenção, ou reintegração na posse, a alegação de domínio, ou de outro direito sobre a coisa. Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio.

236

Art. 507, Parágrafo único. Entende-se melhor a posse que se fundar em justo título; na falta de título, ou sendo os títulos iguais, a mais antiga; se da mesma data, a posse atual. Mas, se todas forem duvidosas, será sequestrada a coisa, enquanto se não apurar a quem toque.

237

Clóvis Beviláqua, *Direito das Coisas*, vol. I, p. 72-73, sustentava a possibilidade de disputa da posse com fundamento no domínio, de modo que nesse caso a posse não deveria ser reconhecida àquele que evidentemente não fosse proprietário. O eminente civilista defendia que desde o Assento de 16 de fevereiro de 1.786 o direito luso-brasileiro reconheceu que a posse não deveria ser atribuída a quem não fosse proprietário. Por sua influência, merece transcrição o posicionamento do autor: “A controvérsia prevista pelo Código Civil, art. 505, segunda parte, é a da posse a título de proprietário, o que, desde logo, exclui a posse indireta frente à direta. Se ambos os contendores reclamam a posse como emanção de sua propriedade, nada mais racional e justo do que não *julgar a posse em favor daquele a quem, evidentemente, não pertencer o domínio*”. Saliente-se que sempre foi controversa a ideia de que o Assento de 1786 tenha, em sentido contrário às Ordenações, admitido a exceção de domínio. Lafayette Rodrigues Pereira, *Direito das coisas*, vol. I, p. 91 e ss., nota de rodapé 40, assinalara que a conclusão de que o Assento de 1786 autorizava a exceção de domínio se baseava em sua má compreensão. O que pretendia o Assento era evitar que a posse do *de cujus* fosse transmitida aos irmãos e sobrinhos se houvesse bisnetos. Em essência, o Assento confirmaria a proibição de alegação de domínio nas ações possessórias.

238

Astolpho Rezende, *A posse e sua proteção*, p. 589.

Art. 923. Na pendência do processo possessório é defeso assim ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento do domínio. Não obsta, porém, à manutenção ou à reintegração na posse a alegação de domínio ou de outro direito sobre a coisa; caso em que a posse será julgada em favor daquele a quem evidentemente pertencer o domínio.

Art. 2.º, § 3.º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Luiz Guilherme Marinoni, *Da exceção de domínio no direito brasileiro (arts. 505 do CC e 923 do CPC)*, p. 243. Reproduz-se a passagem: “Em conclusão, parece que o art. 505 do CC foi revogado pelo art. 923 do CPC, sendo que a Lei 6.820, de 16.09.1980, ao suprimir a segunda parte do art. 923, não restaurou a norma revogada, não sendo mais possível invocar-se a exceção de domínio, desmerecendo censura o acórdão em sua conclusão, muito embora não tenha acentuado que o art. 505 do CC já se encontrava revogado pelo art. 923 do CPC, quando da edição da Lei 6.820/80”. Em sentido contrário se manifestara Joel Dias Figueira Jr., *A exceção de domínio nos códigos civil e processual civil após o advento da lei 6.820 de 16.09.1980*, p. 130-133, para quem a Lei 6.820/1980 não teria revogado ou derogado o art. 505 do CC/1916. Ocorre que referido dispositivo já havia sido revogado pelo próprio art. 923, segunda parte, de modo que a revogação da parte final dessa proposição normativa inviabilizou a exceção de domínio no direito brasileiro.

Arruda Alvim, *Comentários...*, p. 256-257 e 276-277.

É de Clóvis do Couto e Silva a alusão à modalidade e aos limites da posse examinados pela referência ao domínio. O autor sustentava a possibilidade de se “estabelecer a existência” da posse com base na propriedade, o que não parece correto, pois no âmbito possessório a propriedade não será invocada como fundamento, mas sim o poder fático exercido sobre a coisa. Vide *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. XI, t. I, p. 139.

TJSC, Ap. Cív. n. 0001082-22.2012.8.24.0125, 2ª Câmara de Direito Civil, Rel. Sebastião César Evangelista, j. 10.05.2018: “Apelação cível. Reintegração de posse. Sentença de improcedência. Exercício de posse anterior e esbulho não configurados. Âmbito restrito de análise relativo à demanda possessória. Inviabilidade do pleito reintegratório. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Para a procedência dos pedidos na demanda reintegratória deve ficar evidenciado nos autos, além da prática de

esbulho pelo requerido, o exercício da posse anterior pelo autor, prova esta de responsabilidade exclusiva do demandante. As ações sujeitas ao rito especial possessório **não comportam discussões relativas à propriedade sobre o bem**, as quais deverão ser debatidas em ações de caráter petitório. Não restando configurados os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil/1973 (CPC/2015, art. 516), na forma do artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal (CPC/15, art. 373, I), a improcedência dos pedidos formulados na inicial da reintegratória é medida impositiva”.

246

STJ, 4ª Turma, AgRg. no REsp. 906.392/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 26.04.2010.

247

Art. 924. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção seguinte, quando intentado dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho; passado esse prazo, será ordinário, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

248

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 232.

249

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

250

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, vol. II, p. 273.

251

Lafayette Rodrigues Pereira, *Direito das coisas*, vol. I, p. 77, nomeou o capítulo II de sua obra de “Interditos Possessórios”. O § 18, que iniciava as considerações do autor sobre o tema, intitulava-se “Ações Possessórias em Geral”.

252

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 389. Foram retirados dessa obra as conclusões sobre o tema, bem como os exemplos.

253

Joel Dias Figueira, *Liminares nas ações possessórias*, p. 203.

254

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

255

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 421-422. No mesmo sentido, Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 205. Este autor invocava o art. 273 do CPC, destacando a necessidade de cumprimento dos pressupostos para a antecipação de tutela genérica. Francisco Antonio Casconi, *Tutela antecipada nas ações possessórias*, p. 116, também se posicionava pela possibilidade de concessão de liminar satisfativa nas ações de força velha, desde que fossem atendidos os requisitos indicados no art. 273 do código revogado. A jurisprudência também admitia a antecipação de tutela nas ações de força velha: “(...) 4. É possível a antecipação de tutela em ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), submetida ao rito comum, desde que presentes os requisitos que autorizam a sua concessão, previstos no art. 273 do CPC, a serem aferidos pelas instâncias de origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Ag. Rg. no REsp. 1.139.629/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. em 06/09/2012, *DJe* 17/09/2012)”. Admitida a possibilidade de antecipação de tutela quando presentes os requisitos da urgência e da verossimilhança nas ações de força velha, evidentemente impõe-se o indeferimento da liminar quando não houver presença simultânea de ambos os requisitos, conforme reconhecia a jurisprudência erigida sob a vigência do código revogado: “Agravo de Instrumento. Desnecessidade da Juntada de Certidão de Intimação Quando Outras Peças dos Autos Revelarem a Tempestividade do Recurso. Peças Outras que Formam o Instrumento Suficientes para a Adequada Compreensão das Questões Discutidas Independentemente da Juntada do CD da Audiência de Justificação. Ausência de Ratificação das Razões de Recurso Após a Decisão dos Embargos de Declaração Opostos à Decisão Recorrida. Requisito Não Previsto no Código de Processo Civil Como Pressuposto de Admissibilidade do Recurso. Princípio da Razoabilidade. Ação de Reintegração de Posse. Força Velha. Tutela Antecipada Deferida com Fundamento no art. 273 do Código de Processo Civil. Requisito Situação de Risco Ausente. Recurso Provido (TJPR, Ag. Inst. 1.162.047-2, 18ª Câmara Cível, rel. Des. Albino Jacomel Guerios, J. 07.05.2014)”. A ementa demonstra abordagem lúcida e precisa sobre a instrumentalidade do processo, à medida que questões formais, atinentes à falta de ratificação do recurso após a interposição de embargos declaratórios e a ausência de certidão de intimação, foram suplantadas corretamente, à luz da dogmática processual. A falta de ratificação de recurso jamais foi requisito, de modo que sua ausência não poderia justificar a negativa de seguimento do recurso. Por outro lado, como corretamente assinalado no aresto, havendo outros documentos capazes de comprovar a tempestividade do recurso, nada justifica inadmiti-lo em razão da falta de certidão de publicação e de intimação. As regras processuais devem ser interpretadas a fim de assegurar a tutela jurisdicional, sendo inaceitável postura formalista detrimental ao acesso à justiça.

256

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

257

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

258

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

259

Art. 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum.

260

Art. 357. (...) § 2.º. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incs. II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3.º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

261

Sobre a caracterização da atividade do réu como desincumbência de um ônus, ver Clóvis do Couto e Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 142.

262

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 241. Concordes com a possibilidade de caução por terceiro, Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 142 e Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 397.

263

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 395-396. No mesmo sentido, Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 365, para quem a produção de outros meios de prova tumultuaria o processo, sendo recomendável nesse caso o desentranhamento da petição e seu processamento em apartado.

264

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 238.

265

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 259.

266

Roberto Mattoso Camara Filho, *Posse e ações possessórias*, p. 368/369.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 397.

Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 368.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 240.

Joel Dias Figueira Jr., *Op. cit.*, p. 364.

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 259. No mesmo sentido, apontando a lamentável discriminação intrínseca ao dispositivo, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 400 e ss. e Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 369 e ss., para quem o art. 925 do código revogado seria inconstitucional por limitar o acesso à justiça e discriminar os litigantes, vedando aos menos aquinhoados a possibilidade de efetivação de liminares de reintegração ou de manutenção de posse.

É digno de nota que sob o código revogado fora assentado o entendimento de que o mero deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita não era suficiente para comprovar a inidoneidade financeira do autor beneficiado com a liminar: “(...) Fundamento no art. 925 do CPC. Descabimento, no caso concreto. Ausência de prova da inidoneidade financeira do autor. Ônus do qual o réu não se desincumbiu ao juntar nos autos documentos inaptos a refletir com detalhamento e exatidão a atual situação financeira do demandante. Irrelevância do fato de ser beneficiário da justiça gratuita, ante a veracidade presumida e precária da declaração de hipossuficiência, válida enquanto não comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, conforme preconiza o art. 7.º da Lei 1.060/1950. Agravo de Instrumento Provido (TJSP, Ag. Inst. 2072617-02.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Reynaldo, j. 07/05/2014)”.

Art. 7.º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Para Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 237, tratar-se-ia de sequestro. Contrariamente, adotando o entendimento de que se trata de depósito, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 398 e Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 367. Roberto Mattoso Camara Filho, *Posse e ações*

possessórias, p. 368, afirmava corretamente que o dispositivo encerrava hipótese de depósito judicial, de modo que deveria ser nomeado depositário.

275

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

276

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

277

TJPR, Ap. Cível 564630-2, 17ª Câmara Cível, rel. Des. Lauri Caetano da Silva, *DJ* 19.05.2009. Transcreve-se a ementa: “(...) 1.O co-possuidor é parte legítima para propor demanda visando a defesa da posse, não sendo necessário a inclusão no pólo ativo dos demais co-possuidores. 2.Equivocada a sentença que indefere a petição inicial, por considerar que a co-possuidora seria parte ilegítima para figurar sozinha no pólo ativo de ação possessória. É caso de litisconsórcio facultativo”. No mesmo sentido, posicionando-se pela inexistência de litisconsórcio ativo necessário entre condôminos que ajuízam ações possessórias, TJPR, Ag. Instrumento 849106-1, 18ª Câmara Cível, decisão monocrática, rel. Des. Ivanise Tratz Martins, *DJe* 13.02.2012.

278

Art. 1.212. O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era.

279

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 341.

280

Sobre o tema, ver TJPE, Ag. Inst. 422370-90000843-58.2016.8.17.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 06.12.2016: “(...) 4 – A posse passível de proteção possessória pode ser tanto a posse direta quanto a indireta. Logo, em sendo o espólio passível de deter a posse indireta sobre os bens móveis ou imóveis, naturalmente que é possível que ele possa proteger a sua posse através de ações possessórias”.

281

Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

STJ, REsp. 1.244.118/SC, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 28.10.2013. Eis a ementa na parte que se refere à legitimidade dos herdeiros para o ajuizamento dos interditos possessórios: “(...) 3. Aberta a sucessão, a transmissão do patrimônio faz-se como um todo unitário (condomínio hereditário), e assim permanece, até a partilha, em situação de indivisibilidade (art. 1.580 do CC/1916), a que a lei atribui natureza imóvel (art. 44, III, do CC/16), independentemente dos bens que o compõem. 4. Adquirem os sucessores, em consequência, a composesse pro indiviso do acervo hereditário, que confere a cada um deles a legitimidade para, em relação a terceiros, se valer dos interditos possessórios em defesa da herança como um todo, em favor de todos, ainda que titular de apenas uma fração ideal. De igual modo, entre eles, quando um ou alguns compossuidores excluem o outro ou os demais do exercício de sua posse sobre determinada área, admite-se o manejo dos interditos possessórios. (...)”. No mesmo sentido: TJRS, Ap. Cív. 70059833079, 17ª Câmara Cível, rel. Des. Gonzalez Custodio, j. 05.11.2015. Assinala a ementa: “Apelação Cível. Ação de Manutenção de Posse. Matéria de Fato. Extinção do processo sem Julgamento de Mérito. Legitimidade Ativa do Autor na Defesa da Posse. Sentença Reformada. A existência de condomínio entre herdeiros em imóvel que não foi inventariado não impede que qualquer dos herdeiros, pelo Princípio da Saisine, defenda a posse ou propriedade da universalidade de bens componentes do espólio, porque os direitos, deveres e obrigações se transferem imediatamente para todos os herdeiros logo após a morte do autor da herança. Deram Provimento à Apelação”.

Sobre o tema, ver TJPR, Ag. Inst. 1.568.257-0, 18ª Câmara Civil, Rel. Denise Antunes, j. 08.03.2017: “Agravado de instrumento. Ação de reintegração de posse. Aplicabilidade imediata do novo Código de Processo Civil aos processos em andamento. Alteração do polo passivo do feito. Na apresentação de contestação pela agravante, restou informado quem são os possuidores do imóvel vizinho ao lote em discussão. Possibilidade, de acordo com o art. 339, § 2º, do CPC/15 de substituição do polo passivo. Alegação de ilegitimidade passiva da primeira ré (Agravante). Fatos que dão conta da impossibilidade da ré em executar atos de violação ou ameaça à cogitada posse da parte autora. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante que se impõe. Questão afeta ao argumento da inadequação do ajuizamento da ação possessória para o reconhecimento de propriedade que diz respeito ao julgamento final da demanda. Devida é a continuidade da demanda. Recurso parcialmente provido”.

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. (...) § 2.º. No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

286

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

287

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

288

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

289

Enunciado 80. É inadmissível o direcionamento de demanda possessória ou ressarcitória contra terceiro possuidor de boa-fé, por ser parte passiva ilegítima diante do disposto no art. 1.212 do novo Código Civil. Contra o terceiro de boa-fé, cabe tão somente a propositura de demanda de natureza real.

290

Art. 125. É admissível a denúncia da lide, promovida por qualquer das partes: I – ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

291

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. I, p. 375.

292

O exemplo foi retirado de Athos Gusmão Carneiro, *Intervenção de terceiros*, p. 84. O autor tratou da hipótese de denúncia da lide prevista no art. 70, II, em item intitulado “Evicção nos casos de transferência da ‘posse’ ou ‘uso’”, donde se conclui que para ele o inc. I abrangeria o inc. II.

293

STJ, Ag. Rg. nos Edcl. no Resp. 1.099.469/DF, 3ª Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJe* 22.09.2011. Eis a ementa no que interessa ao ponto: “(...) 1 – É cabível o oferecimento de oposição pela TERRACAP para defesa de sua posse sobre bem imóvel, com fundamento em domínio da área pública, em ação de reintegração de posse entre particulares. (...)”.

294

STJ, Ag. Rg. no Resp. 917.816/DF, 4ª Turma, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, *DJe* 19.08.2011. Transcreve-se a ementa: “Existente ação cujo pedido de reintegração de posse se funda exclusivamente na posse, não há

previsão legal para a propositura de oposição para que seja discutida a propriedade ou o domínio do bem' (REsp 685.159/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. em 06.10.2009, *DJe* 19.10.2009). 2. Agravo regimental não provido”.

295

STJ, Resp. 1.230.839/MG, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 26.03.2013. Eis a ementa: “Processo Civil. Recurso Especial. Ação de Reintegração de Posse. Contrato de Comodato. Valor da Causa. 1. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem. 3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato. 4. Recurso especial parcialmente provido”. O acórdão justifica que a parte autora não pretendia se imitar na posse em razão de dação em pagamento, mas sim, ser reintegrada por força da extinção do contrato de comodato, de modo que o preço do imóvel não seria o parâmetro para o valor da causa. Ocorre que, como a posse não se confunde com a propriedade, o valor do bem imóvel jamais poderá equivaler ao valor da causa. No mesmo sentido, assinalando que o valor da causa nas possessórias corresponde ao valor patrimonial pretendido pelo autor: STJ, Ag. Rg. no REsp. 612.033/SP, 4ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 14/09/2009, STJ, REsp. 490.089/RS, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJ* 09/06/2003, p. 272 e TJPR, Ag. Inst. 1.440.111-9, 18ª Câmara Cível, rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. 16.03.2.016, cuja ementa ora se transcreve: “Reintegração de Posse. Valor da Causa. Proveito Econômico Visado com a Medida Possessória. Precedente do STJ e Desta Corte. Pretensão, no caso, de reintegração de parte de uma ilha que compõe área de reservatório de usina hidrelétrica. Benefício inestimável. Manutenção do valor da causa atribuído pelo autor. Recurso provido”.

296

Art. 292, inc. VI – na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.

298

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; (...) § 1.º Considera-se inepta a petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; (...).

299

Lúcio Delfino, *A desnecessidade de demonstração da urgência para o deferimento de tutela antecipada possessória (posse nova)*, p. 360: “Não há, portanto, exigência legal de se provar ‘risco de dano irreparável ou de difícil reparação’, nem de se demonstrar ‘urgência no deferimento da tutela’, em ‘ações possessórias’ de *força nova*. Basta a evidência dos requisitos indicados pelo art. 928 do Código de Processo Civil. E assim é por uma razão singela: o próprio legislador, num *juízo de ponderação*, concluiu pela existência do *periculum in mora* – e, de tal modo, da própria *urgência* – naqueles casos em que a ‘ação possessória’ é intentada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (*força nova*) (CPC, art. 924)”. Esse entendimento, lançado sob o código revogado, é plenamente aplicável ao atual.

300

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

301

Antônio Joaquim Ribas, *Da posse e das ações possessórias*, p. 228, ao analisar as Decretais de Inocêncio III, uma das pretensas fontes do *possessorium sumarissimum*, indicava que se pretendia apenas presumir o prosseguimento da posse mais antiga quando sua perda não fosse demonstrada: “O Papa, pois, entendeu apenas que, não estando provada a perda da posse mais antiga, devia-se presumir que ella continuava; e estando provado ser aquella uma posse titulada, e não assim a mais moderna, devia-se também presumir ser esta viciosa, caso existisse, e dever succumbir ante a exceção da parte adversa”.

302

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. X, p. 415: “A ação do art. 500 do Código Civil é a do *possessorium sumarissimum* medieval, nascido na Itália, Espanha, Portugal, França e Alemanha, no século XIII. Ação de cognição incompleta, superficial, com intuitos de paz imediata, pela manutenção da *momentânea possessio*. Quanto à existência desse remédio no direito anterior ao Código Civil, estava a favor Manuel de Almeida e Sousa (*Tratado dos Interditos*, 109-120); contra, Antonio Joaquim Ribas (*Da Posse*, 251-257). Não há dúvida de que o prático de Lobão prestou grande serviço em mostrar que advogados e juizes estavam a confundir os dois institutos de proteção à posse e a aplicar a um o que concernia a outro. Diríamos hoje: confundindo a cognição superficial das ações do art. 371 com a *interina*”. No mesmo sentido, pela previsão do instituto do *possessorium sumariissimum* no art. 500 do CC/1.916, reproduzido no art. 1.211 do código vigente, Roberto Mattoso Câmara Filho, *Posse e ações possessórias*, p. 336: “O objetivo do *sumariissimum* é de, ante a posição antagônica de duas pessoas quanto à posse de uma coisa, estabelecer um estado de trégua, até deliberação judicial final”.

303

Antônio Joaquim Ribas, *Da posse e das ações possessórias*, p. 251: “Fundando-se, não na pátria legislação ou praxe forense, mas na autoridade dos jurisconsultos estrangeiros, procura Almeida e Souza sustentar a legalidade do *possessório summarissimo*. Mas, esta empresa era irrealizável; e o erudito causídico de Lobão não podia deixar de naufragar”.

304

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 262.

305

Arruda Alvim, *Comentários...*, p. 249, 256-257 e 276-277.

306

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1.º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I – dessa resolução depender o julgamento do mérito; II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

307

José Carlos Moreira Alves, *Posse estudo dogmático*, vol. II, t. I, p. 153.

308

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos especiais*, p. 101/102.

309

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 409. Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, vol. III, p. 51, sustenta que declarações escritas de testemunhas não têm valor probatório. Nas palavras do autor: “São meros depoimentos testemunhais escritos e, em consequência, sem nenhum valor, pois a prova testemunhal tem modo próprio de ser colhida”.

310

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

311

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. A jurisprudência assentava, com correção, a necessidade de contraditório no processo anterior para que pudesse ocorrer o empréstimo da prova no outro processo: “A inércia da parte quanto ao pagamento dos honorários periciais enseja a preclusão do direito de produzir a prova técnica. É mister, para se admitir prova emprestada, a observância do contraditório nos autos onde foi produzida. Não tendo o réu comprovado o alegado pagamento do débito constante de nota promissória, mantém-se a sentença de procedência do pedido inicial. Inteligência do art. 333, II, do CPC (TJPR, Ap. Cív. n. 156.350-6, 7ª Câmara Cível, rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 17.05.2005)”. Quanto aos requisitos da prova emprestada, transcreve-se a ementa de julgado lapidar: “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5.º, LV), quer pela juntada de prova pericial produzida em outros autos (prova emprestada), nos quais não houve a participação dos autores, quer porque houve a prolação de sentença imediatamente após a juntada do laudo pericial, sem que as partes sobre ele se manifestassem. 2. ‘O autor da ação deve ser intimado de documentos novos juntados aos autos pelo réu, e vice-versa, sempre que influenciarem no julgamento da causa; ambos devem ser cientificados dos que forem neles entranhados por iniciativa do juiz’ (STJ-RT 729/148). Também no sentido de que as partes devem tomar conhecimento dos documentos juntados por determinação judicial: RF 291/306, 300/227, RJTAMG 26/303” (TJPR, Ap. Cív. 748.931-8, 3ª Câmara Cível, rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 14.06.2011). Para que a prova seja emprestada é necessário que a parte contra quem se

pretenda produzi-la, tenha participado do processo anterior. A ementa transcrita é interessante em ainda outro aspecto: exige a manifestação das partes sobre documento trazido aos autos pelo juiz. Trata-se de atendimento ao contraditório, em conformidade com sua feição cooperativa prevista nos arts. 6.º, 9.º e 10 do CPC/2015.

312

Paulo Osternack Amaral, *Provas*, p. 99-100, demonstra com exatidão a manutenção da natureza original da prova emprestada: “Destaque-se que um laudo pericial transportado para outro processo não deixará de ter natureza de prova pericial. Tampouco a circunstância de o laudo ingressar no segundo processo sob a forma de documento transforma a prova pericial produzida em prova documental ou em prova atípica”.

313

TJPE, Ap. Cív. 451717-70088383-15.2014.8.17.0001, 6ª Câmara Cível, Rel. José Carlos Patriota Malta, j. 25.10.2016: “Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Aplicação do art. 1.196 do CC e do art. 561, do CPC. Não comprovação do exercício da posse e do esbulho. Apelo desprovido. Sentença preservada. Decisão unânime”.

314

Art. 47, § 2.º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

315

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

316

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 271.

317

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 410.

318

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 284. Transcreve-se o argumento: “No Código de 1973, art. 928, 2ª parte, diz-se que, se o juiz não deferir, *in limine*, a expedição do mandado de manutenção, ou de reintegração, ‘determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que foi designada’. Não há a alternativa, o que pode ocorrer é que tenha havido indeferimento da petição inicial, o que é outro assunto”. No mesmo sentido, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 270 e Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 147. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, p. 611, adotam posição intermediária, assinalando que o juiz deve realizar a audiência, a não ser que o autor tenha confessado

fato que contradiga os requisitos exigidos no art. 561 ou tenha realizado alegação que inviabilize a comprovação da posse e da agressão sumariamente.

319

STJ, Ag. Rg. no AREsp. 38.991/MT, 4ª Turma, rel. Min. Raul Araújo, *DJe* 26.08.2014. Transcreve-se a ementa: “Agravamento Regimental no Agravo em Recurso Especial. Liminar de Reintegração de Posse. Insuficiência de Provas. Audiência de Justificação Prévia. Necessidade de Realização. Incidência da Segunda Parte do Art. 928 do CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp. 900.534/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, *DJe* de 14.12.2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

320

TJPR, Ag. Inst. 1.219.481-9, 6ª Câmara Cível, rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, decisão monocrática, *DJe* 15.07.2.014: “Decisão Monocrática. Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda com Pedido de Reintegração de Posse. Despacho que Designou a Audiência de Justificação. Análise do Pedido Liminar Postergada. Ausência de Conteúdo Decisório. Inteligência do Art. 504 do CPC. Precedentes. Art. 557, *caput*, CPC. Recurso a que se Nega Seguimento, Monocraticamente”.

321

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 419. O comentário, realizado sob a égide do código revogado, tem total aplicação perante o vigente: “Daí se infere que, embora o aludido art. 928 só se refira à citação do réu ‘para comparecer à audiência’, cuida-se de autêntica e completa citação, que deve atender a todas as formalidades e requisitos pertinentes – inclusive e principalmente no que se refere à advertência sobre as consequências legais da revelia e ao prazo de resposta, com explícito registro de que este há de correr da futura intimação”. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 611, afirmam que o ato a que alude o art. 562 é incorretamente denominado citação. Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 270, realizara a mesma crítica sob o código anterior.

322

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 419.

323

Idem, *ibidem*.

324

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 611. O posicionamento é acolhido na jurisprudência: “Obtempera-se que a audiência de justificação não é o momento em que o réu é convocado a se defender, ou seja, não assume o ônus de contestar na audiência, sendo exclusivo do autor a produção de provas, podendo o réu, todavia

contradizer e reinquirir as testemunhas apresentadas pelo autor” (TJPR, Ag. Inst. 1.361.351-1, 18ª Câmara Cível, rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 27.05.2015, passagem extraída do corpo do acórdão).

325

Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 325. No mesmo sentido, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 272, embora utilize o termo *reinquirir* em vez de *reperguntar*.

326

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 272.

327

Arruda Alvim, *Comentários...*, p. 330 se manifestava contrariamente. Nas suas palavras: “Ao ensejo da justificação prévia, inexistente oportunidade processual *própria* para *conciliação*, ainda que está dentro dos poderes do juiz determinar audiência para conciliação”. Joel Dias Figueira Jr., *Liminares nas ações possessórias*, p. 330 sustentava que o juiz poderia iniciar o ato processual recomendando a conciliação. Textualmente: “Comparecendo os litigantes pessoalmente à audiência de justificação, é de bom alvitre que o juiz antes de dar prosseguimento ao ato proponha a conciliação, na tentativa de solucionar o conflito jurídico e sociológico da forma menos gravosa e violenta a qualquer das partes”.

328

Art. 3.º, § 2.º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

329

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) inc. V – promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

330

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

331

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; (...).

Luiz Guilherme Marinoni, *A ética dos precedentes*, p. 76 e ss., realiza análise precisa dos efeitos do patrimonialismo no processo civil e seu impacto negativo na adoção de um sistema precedentalista no Brasil. Max Weber, *Economia e Sociedade*, vol. I, p. 151, abordara o patrimonialismo como tipo da dominação tradicional. Sua obra é um dos pilares da sociologia e fundamentou as abordagens realizadas por Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, autores que são estudados no livro de autoria de Luiz Guilherme Marinoni.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 277-278: “Não obstante as restrições que se possam fazer aos privilégios concedidos por lei a certas classes de litigantes, particularmente os que se referem à generosidade dispensada pelo Código à Fazenda Pública, a exigência de prévia audiência dos representantes legais do Poder Público, constante do art. 928, parece justificada, sob o fundamento de que os agentes da Administração Pública não cometeriam deliberadamente agressões possessórias ilegais, capazes de legitimar os interditos. Não se deve, porém, esquecer que, em certas regiões do território nacional, a ocorrência de graves desvios de função, praticados por interesses políticos subalternos de administradores locais, é muito mais frequente do que se poderia imaginar”. Apesar da ressalva contida na última frase, discorda-se com veemência dessa afirmação do processualista gaúcho. A corrupção atingiu níveis endêmicos no Brasil, não se limitando a “certas regiões”. Isso comprova que não há justificativa para a crença de que os agentes públicos não praticariam, intencionalmente, violações à posse de particulares. Mas ainda que graves desvios funcionais se circunscrevessem a determinadas regiões do Brasil, não haveria justificativa para o privilégio concedido às pessoas jurídicas de direito público, que contam no art. 562, par. ún., com importante ferramenta para adiar a justa recuperação ou manutenção da posse. Trata-se violação frontal à igualdade no processo, de modo que o dispositivo é inconstitucional, ferindo a isonomia com que as partes devem ser tratadas.

STJ, Ag. Rg. nos Edcl. no AREsp. 240.513/PE, 1ª Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 06/03/2015. Eis a ementa: “Administrativo. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial. Pensão por Morte. Possibilidade de Antecipação dos Efeitos da Tutela. Interpretação Restritiva do Art. 2.º B da Lei 9.494/1997. Súmula 729 do STF. Agravo regimental da União Desprovido. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as vedações previstas no art. 2.º-B da Lei 9.494/1997 devem ser interpretadas restritivamente. Dessa forma, preenchidos os requisitos autorizadores de sua concessão, é admissível a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, desde que a situação não esteja inserida nas vedações da supramencionada norma. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem determinou a imediata implantação do benefício (pensão por morte), não existindo vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária. Inteligência da Súmula 729/STF. 3. Agravo Regimental da União desprovido”. No mesmo sentido, admitindo a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública para a tutela do direito à saúde, mediante custeio de cirurgia cardíaca, STJ, Ag. Rg. no AREsp. 420.158/PI, 2ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 09.12.2013.

Art. 4.º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

336

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 413.

337

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. (...) § 2.º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

338

Art. 218, § 3.º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

339

Adroaldo Furtado Fabrício, *Breves comentários...*, p. 1.456.

340

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias.

341

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 269.

342

Anissara Toscan, *Preclusão processual civil*, p. 127. É preciso acrescentar, contudo, que a autora critica de forma consistente a ideia de preclusão dos poderes do juiz. Considerando que o instituto se relaciona com os ônus que recaem sobre as partes, excluindo direitos processuais, seria inadequado admitir que a atividade jurisdicional, orientada por poderes-deveres, pudesse ser atingida pela preclusão. Textualmente, na página 90 da obra citada: “Retomando, nesse caminhar, raciocínio alinhavado no capítulo anterior, acerca da impropriedade de se falar em incidência de preclusão sobre o juiz – sujeito sobre o qual não pesam ônus, tampouco direitos processuais, mas somente *poderes-deveres* relacionados com a condução do processo –, chama atenção o fato de que em todas as situações em que a doutrina *majoritária* afirma ocorrer preclusão de poderes do juiz, no sentido de que não se permitirá que ele redecida controvérsia já analisada, na verdade o que se verifica é preclusão do direito da parte prejudicada de obter pronunciamento diverso do já proferido, em virtude de não ter interposto o recurso cabível contra a decisão”. A expressão é mantida neste texto em razão de seu uso consagrado na doutrina e jurisprudência. Todavia, sob o ponto de vista dogmático, é preciso concordar com a autora, assinalando como

conceitualmente incorreta preclusão de poderes do juiz.

343

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...).

344

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

345

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 276. São notáveis os termos peremptórios em que a ideia é apresentada: “A impossibilidade de modificar a medida liminar, sem a ocorrência de algum fato novo relevante, deve ter-se por indiscutível”.

346

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 415. Textualmente: “Com efeito, o mecanismo todo da proteção possessória orienta-se pelo interesse público na estabilidade da situação de fato. Um sistema que permitisse ao juiz dar e retirar sucessivamente a posse, segundo as variantes que a seu espírito oferecesse a evolução da prova ao longo do processo, negaria a base mesma desse mecanismo. Para decidir sobre a posse, tem o julgador duas oportunidades definidas: a apreciação do pedido liminar e a sentença definitiva, que confirma ou modifica provimento inicial”. No mesmo sentido, Joel Dias Figueira Jr., *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. IV, t. I, p. 292: “Parece-nos insustentável a tese contrária, porquanto nada mais óbvio que, se assim não fosse, e o ordenamento permitisse ao juiz modificar a qualquer tempo o seu entendimento, a sua decisão, de acordo com o desenrolar do processo, conforme os sucessivos articulados das partes e eventuais provas produzidas, instaurar-se-ia, por certo, uma verdadeira desordem no plano fático, entrando em cheque os mecanismos do próprio sistema que se baseia no devido processo legal”. O mesmo argumento também é apresentado em *Liminares nas ações possessórias*, p. 432. Digno de nota, contudo, que em passagem subsequente dos *Comentários ao Código de Processo Civil* (p. 293), o autor admite a possibilidade de revogação da medida se houver mudança no estado de fato ou no estado da prova: “Em síntese, não se submetendo a decisão concessiva ou denegatória da tutela antecipada ao regime de imutabilidade da coisa julgada, poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo, desde que se verifique alguma *circunstância superveniente* relacionada com a matéria de fundo objeto da lide (mérito propriamente dito) hábil a sustentar a sua reversibilidade, isto é, que haja *mudança no estado de fato* capaz de acarretar no desaparecimento, surgimento ou modificação da situação emergencial que lhe serviu de pressuposto, ou, no *estado da prova*, de forma a modificar o juízo respeitante aos fatos e ao direito afirmado”. Identicamente, Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, vol. III, p. 53. *In verbis*: “Concedida a liminar, o juiz, antes da sentença final, só poderá revogá-la se a parte manifestar seu inconformismo através de agravo”.

347

Anissara Toscan, *Preclusão processual civil*, p. 206. A autora faz alusão à modificação do contexto “fático-probatório”, o que implica a admissão de que a produção de prova pode levar à revogação da decisão. Embora a passagem se refira às tutelas de urgência sob o CPC/1973, é inegável sua validade para as liminares possessórias no código vigente. Textualmente: “Quando, por outro lado, houver modificação do conjunto fático-probatório que embasou a decisão estável, abre-se caminho para que uma *nova decisão* seja proferida, considerando o não enquadramento nos limites objetivos da preclusão; (...)”.

348

Daniel Mitidiero, *Colaboração no processo civil*, p. 135-136, acentua a importância do contraditório efetivo para a conformação de um processo justo: “Não há dúvida que a necessidade de um processo justo encontra esteio à vista da necessidade de obter-se uma decisão justa, sendo considerado mesmo seu pressuposto. Nessa perspectiva, assume o contraditório o papel de um verdadeiro ‘*cardine della ricerca dialettica*’ pela justiça do caso concreto, funcionando como uma norma de absoluta imprescindibilidade para a formação da decisão judiciária. Não basta, todavia, outorgar direito a influir na construção da decisão se não se prevê um correlato dever de debate acometido ao órgão jurisdicional”.

349

Essa era a posição da jurisprudência sob o código anterior e merece ser mantida. Cita-se, como exemplo, o seguinte julgado: TJSP, AI 2178548-91.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, DJ 16.11.2015. Eis a ementa: “Ação Possessória. Tutela Antecipada. Revogação de Ofício. Impossibilidade. Preclusão *Pro Judicato*. Reforma da Decisão. No caso concreto, sem provocação das partes, o juízo ‘a quo’ revogou, de ofício, a tutela antecipada, reapreciando os mesmos fatos que foram objeto de decisão anterior. Todavia, a matéria não é de ordem pública e, uma vez que não foram apresentadas novas provas, operou-se a denominada preclusão *pro judicato*. É vedado ao juiz proferir nova decisão sobre os mesmos fatos, nos termos do art. 471 do Código de Processo Civil. Agravo provido”.

350

Ovídio Araújo Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 286.

351

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 279.

352

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

353

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 281.

354

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: (...) II – obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias.

355

Art. 242, § 3.º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

356

Art. 246. A citação será feita: (...) V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1.º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio. § 2.º O disposto no § 1.º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta.

357

Adroaldo Furtado Fabrício, *Breves comentários...*, p. 1.460.

358

Adroaldo Furtado Fabrício, *Breves comentários...*, p. 1.460.

359

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalment e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

360

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 322.

361

Idem, p. 323.

362

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

363

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 423-424. No mesmo sentido, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 286.

364

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo: § 1.º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V – confirma, concede ou revoga tutela provisória.

365

Art. 1.012, § 3.º. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II – relator, se já distribuída a apelação. § 4.º Nas hipóteses do § 1.º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

366

Art. 1.012, § 2.º Nos casos do § 1.º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

367

Pontes de Miranda, *Tratado das ações*, t. VI, p. 103. No mesmo sentido, Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, vol. II, p. 268 e 419.

368

Pontes de Miranda, *Tratado das ações*, t. I, p. 225. Eis a passagem: “A sentença favorável nas ações executivas *retira* valor que está no patrimônio do demandado ou dos demandados, e põe-no no patrimônio do demandante”. Em outro trecho, *Tratado das ações*, t. VII, p. 134, analisando a ação reivindicatória, Pontes de Miranda elaborou definição lapidar que se aplica a todas as ações e sentenças executivas: “Quem reivindica, em ação, pede que se apanhe e retire a coisa, que está, contrariamente a direito, na esfera jurídica do demandado, e se lhe entregue. Nas ações de condenação e executivas por créditos não se dá o mesmo: os bens estão na esfera jurídica do demandado, acorde com o direito; porque o demandado deve, há a condenação dele e a execução, que é a retirada de bem, que está numa esfera jurídica, para outra, a fim de satisfazer o crédito; portanto, modifica-se a linha discriminativa das duas esferas”.

Edson Ribas Malachini, *As ações (e sentenças) condenatórias, mandamentais e executivas*, p. 53, assinala que a responsabilidade penal, decorrente do desatendimento da ordem, seria um dos elementos caracterizadores das ações e sentenças mandamentais. Textualmente: “A nosso ver, portanto, esse deve ser considerado um dos traços distintivos da decisão *mandamental*: o de gerar, seu descumprimento, responsabilidade penal para o destinatário da ordem. Ainda, pois, que se lhe agregue, como reforço, para dar mais efetividade à decisão, a *cominação de pena pecuniária* (como, e.g., se prevê no art. 461, § 4.º), não é tal cominação que lhe atribuirá o caráter mandamental – até porque tal cominação tem, como sempre teve, natureza tipicamente *condenatória*: importa, como se viu anteriormente, em *adiantamento de condenação*”. Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, p. 358-359, enfatiza a conjugação entre ordem e medida coercitiva como traço definidor dos provimentos mandamentais: “A essência da mandamentalidade está no mandamento, vale dizer, na ordem imposta sob pena de multa. (...) O que define a mandamentalidade é a possibilidade de se requerer ordem sob pena de multa”. No livro de minha autoria, intitulado *Condenação e Cumprimento de Sentença*, p. 79, procurei definir os contornos gerais dos provimentos mandamentais: “Pode-se afirmar, em síntese, que na sentença mandamental o juiz ordena. O descumprimento da ordem caracteriza resistência injustificada ao poder estatal, caracterizando crime de desobediência. Em geral a ordem é reforçada pela cominação de mecanismos coercitivos, cujo propósito é influenciar a parte, a fim de que cumpra o que lhe fora determinado”.

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 114.

Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, p. 117. O autor traça com grande precisão a diferença entre tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito: “A tutela de remoção do ilícito diferencia-se da inibitória por remover ou eliminar o ilícito; a tutela inibitória, no caso de ilícito continuado, não remove ou elimina o ilícito, mas apenas visa a convencer o réu a cessar de praticá-lo”.

Idem, p. 26. Eis o conceito: “A tutela inibitória, configurando-se como tutela preventiva, visa a prevenir o ilícito, culminando por apresentar-se, assim, como uma tutela anterior à sua prática, e não como uma tutela voltada para o passado, como a tradicional tutela ressarcitória”.

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 425. O autor aponta a previsão do interdito proibitório nas Ordenações Manoelinas (Livro III, Título 80, §§ 6-9) e Afonsinas (Livro III, Título 62, §§ 5-7). Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 287, indica a previsão do instituto nas Ordenações Filipinas (Livro III, Título LXXVIII, § 5.º).

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 154.

375

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 227. Na dicção do autor, com o rigor analítico que lhe é costumeiro: “A ação de remoção do ilícito pressupõe um ilícito que já ocorreu, tendo por objetivo a sua remoção, e essa, por mera consequência da realização do desejo do próprio direito material, impede a produção de eventuais danos. Portanto, admitindo-se a separação entre ilícito e dano, fica bastante fácil perceber a distinção entre a ação de remoção do ilícito – voltada contra o ilícito e, apenas por isso, capaz de impedir danos – e a ação cautelar. Quando não se percebia a separação entre ilícito e dano, *era impossível raciocinar em termos de remoção do ilícito, e apenas por esse motivo admitia-se a ação cautelar, ainda que se estivesse, na realidade, atacando um ilícito já praticado*”.

376

André Luiz Bäuml Tesser, *Tutela cautelar e antecipação de tutela*, p. 111. O autor inscreve os provimentos cautelares no plano do direito material, contrapondo-os à antecipação de tutela, corretamente caracterizada como técnica processual. Conclui correlacionando a tutela cautelar com o perigo de dano, pressuposto também encontrado no plano material. Textualmente: “Isso porque, se a tutela cautelar está situada no plano do direito material, a situação de perigo que a fundamenta somente pode ser correlata a algo igualmente ligado ao direito material. Por isso, o perigo de *dano é sua condicionante urgente*, elemento nitidamente presente e de origem no direito material”.

377

Daniel Mitidiero, *Antecipação da Tutela*, p. 38.

378

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 153.

379

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 316. Concorde com a posição, Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 427.

380

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 153.

381

Sérgio Cruz Arenhart, *Perfil da tutela inibitória coletiva*, p. 360, traça precisa e meticulosa análise sobre a multa coercitiva, abordando sua plasticidade, consistente na possibilidade de o juiz determinar sua periodicidade e valor em conformidade com as circunstâncias do caso concreto.

382

383

STJ, Resp. 7.196/RJ, 3ª Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, *DJ* 05.08.1991, p. 9.997. A ementa assinala: “Civil. Interdito Proibitório. Patente de Invenção Devidamente Registrada. Direito de Propriedade. I – A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias. II – O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patentes de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito. III – Recurso não conhecido”.

384

STJ, Ag. Rg. no AREsp. 785.261/MT, 3ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, *DJe* 09.12.2015. Reza a ementa: “Agravado Regimental no Agravado em Recurso Especial. 1. Ofensa ao art. 928 do CPC. Ação de Interdito Proibitório. Inicial Insuficiente de Provas. Audiência de Justificação Prévia. Necessidade de Realização. Inteligência da Segunda Parte do art. 928 do CPC. Precedentes. 2. Tese de Prejudicialidade. Impossibilidade de Acatamento. Súmula 7 do STJ. 3. Agravado Improvido. 1. É compreensão desta Corte que, não estando a inicial devidamente instruída com elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil, deverá o magistrado designar audiência de justificação com o intuito de possibilitar ao autor da ação a demonstração do alegado. Precedentes. (...). 3. Agravado regimental a que se nega provimento”.

385

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 430, manifestava-se, sob o código revogado, contrariamente à ideia aqui defendida. Para ele era necessária a oitiva prévia dos representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Saliente-se, contudo, que já no art. 928, par. ún., do CPC/1973, constava a referência à reintegração ou manutenção liminar.

386

Adroaldo Furtado Fabrício, *Comentários...*, p. 426. O autor assinala corretamente que a adoção da medida está limitada à duração da ameaça.

106

Arruda Alvim, *Comentários...*, vol. XI, t. II, p. 208.

297

Art. 292, § 3.º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

CAPÍTULO IV DA AÇÃO DE DIVISÃO E DA DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES

1. Introdução

No Capítulo IV do Título III – “Dos Procedimentos Especiais” – do Livro I – “Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença” – da Parte Especial, arts. 569 a 598, o Código de Processo Civil disciplina as ações de demarcação e de divisão. A redação dos dispositivos nem sempre é clara, o que suscita não poucas dúvidas na aplicação. Trata-se, muito possivelmente, do mais tumultuado dentre todos os procedimentos especiais.

A origem desses procedimentos é o Direito Romano. A demanda demarcatória era conhecida como *actio finium regundorum*, ao passo que a ação de divisão era denominada *actio communi dividundo*.¹ Como se verá a seguir, o objetivo da ação de demarcatória é fixar a linha de confrontação de um determinado imóvel, bem como aviventar ou substituir marcos de delimitação. A ação divisória, por sua vez, tem a finalidade de extinguir o condomínio sobre determinado imóvel, permitindo a constituição de quinhões em favor de cada um dos condôminos.

Pode-se indicar a melhor fruição da propriedade como fundamento tanto da demarcação quanto da divisão. Para permitir ao proprietário de terreno particular o melhor proveito de sua situação jurídica, o Código Civil assegura, nos arts. 1.297 e 1.320, respectivamente o direito de demarcação e o de divisão do imóvel. O Código de Processo Civil, como adiante se verá, permite que essas pretensões sejam cumuladas, o que suscita grande número de indagações.

Com os olhos voltados para a tentativa, empreendida pelo Código Civil nos dispositivos indicados, de assegurar a melhor fruição possível do direito de propriedade, que os dispositivos do Código de Processo Civil devem ser interpretados. Com efeito, para que se possa aproveitar plenamente o domínio, é fundamental que o imóvel esteja perfeitamente delineado. Do mesmo modo, o estado de comunhão pode ser fonte de sem número de dissídios, o que inviabiliza o melhor aproveitamento da propriedade. Assim, as regras que serão comentadas a seguir têm como objetivo permitir a tutela jurisdicional dos direitos à demarcação e à divisão, elementos importantes para o máximo aproveitamento da propriedade.

Seção I Disposições gerais

Art. 569. Cabe:

I – ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estrear os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;

II – ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estrear os quinhões.

1. Ação demarcatória: interesse processual e legitimidade

A lacônica redação do art. 569, I, pode levar à compreensão incompleta sobre as hipóteses de ajuizamento da ação demarcatória. Em uma primeira leitura, seria possível concluir que o proprietário poderia constranger o confinante a estrear os respectivos prédios mediante fixação de novos limites ou por meio da aviventação dos já apagados. Não estaria prevista a hipótese de propositura da ação quando não houvesse quaisquer limites entre as propriedades, donde resulta a incompletude do dispositivo, pois essa pode ser considerada a mais proeminente finalidade da

demarcatória.²

Ainda no que se refere à redação, acrescenta-se que a locução “novos limites” é imprecisa. A referência à “aviventação” é suficiente para se perceber que o dispositivo, ao aludir a “novos limites”, está na realidade se referindo aos marcos que os materializam.³

Para melhor compreensão sobre a finalidade da ação demarcatória, é preciso conjugar o dispositivo em exame com o art. 1.297 do Código Civil,⁴ no qual é prevista a possibilidade de ajuizamento da ação demarcatória quando entre os imóveis não houver linha de confrontação. Com efeito, a expressão “pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios” significa que o proprietário poderá ajuizar demanda a fim de que seja estabelecida a linde até então inexistente entre os prédios contíguos. Mas também o dispositivo do Código Civil não é infenso a críticas, pois faz uso da locução “aviventar rumos apagados”. Ocorre que o “rumo” é abstrato, razão pela qual não poderá ser aviventado.⁵ Objeto de aviventação, portanto, são os marcos que concretizam a linha demarcatória, sinalizando os rumos.

A despeito das imprecisões que possam conter, resulta dos dispositivos analisados a possibilidade de ajuizamento da ação demarcatória quando não houver linha de confrontação, quando for necessário aviventar marcos apagados ou substituir os que estiverem destruídos, ou, ainda, quando forem nebulosos os limites.⁶ Essas são as hipóteses em que haverá interesse processual.

Contudo, é importante destacar que os imóveis devem ser contíguos, de modo que a contiguidade é uma das notas definidoras do interesse processual.⁷ Não será cabível a demarcatória quando os imóveis estiverem separados por vias públicas, rios ou acidentes geográficos. O interesse do autor é ressaltado, ainda que os imóveis sejam separados por um rio ou outro acidente geográfico, quando houver situação de dúvida, decorrente, por exemplo, de bifurcação de rio.⁸

A existência de tapumes entre as propriedades não é suficiente para extinguir o interesse processual na ação demarcatória. Com efeito, um muro entre as propriedades não significa ausência de interesse na demarcação, pois a posse ilegítima é, nesse caso, consequência da imprecisão dos limites.⁹

Tanto é certo que a existência de tapumes – muros, cercas, divisórias – entre os imóveis não inviabiliza a propositura da ação demarcatória que o Código de Processo Civil, no art. 581, parágrafo único, prevê que a demarcação trará como efeito anexo a restituição da área invadida. Nesse caso, tendo sido realizadas construções no imóvel invadido, o Código Civil prevê nos arts. 1.258 e 1.259 a possibilidade de aquisição da área ocupada indevidamente. O tema será analisado adiante. Por ora, cabe destacar que seria gravíssimo erro julgar o autor carecedor de demanda única e exclusivamente em razão de existir tapume entre as propriedades. A construção de muro ou de cerca pode ser fruto de equívoco do confinante, motivado pela supramencionada imprecisão dos limites, de modo que continuará cabível a ação demarcatória. Nesse sentido se manifestou a jurisprudência sob o código revogado.¹⁰

Certamente o confrontante poderá invocar sua posse mansa e pacífica e postular a usucapião da área invadida. Trata-se de questão prejudicial à demarcação. Mas mesmo nesse caso a inviabilidade da pretensão demarcatória não decorrerá, pura e simplesmente, da existência de tapume entre os imóveis. É possível, repita-se, que a edificação do tapume tenha ocorrido sem fundamento jurídico, como resultado de confusão sobre os limites. A propósito, classifica-se a confusão sobre os limites em subjetiva e objetiva. Na primeira modalidade, há uma linha de confrontação, repudiada por um dos confrontantes. Na segunda, inexistem os marcos entre os imóveis.¹¹

Quando houver marcos entre os imóveis, como resultado da convenção entre os interessados, não haverá interesse no ajuizamento de ação demarcatória, mas poderá ser proposta ação para a retificação de marcos, cujo fundamento será a inserção do marco em lugar incorreto.¹²

Ainda quanto ao interesse processual, menciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça que aceitou a propositura de demanda demarcatória para que fossem separadas as áreas comuns da propriedade privativa em condomínio por edificações.¹³ Embora em regra a demarcatória não seja cabível, as circunstâncias do caso concreto justificaram a adequação da medida.

Quando da leitura da inicial resultar inconsistência em relação ao interesse processual, o juízo intimará o autor para se manifestar. Sendo reiterada a incoerência narrativa, a indicar a desnecessidade ou inadequação da demarcatória, a petição será indeferida, em conformidade com o art. 330, inc. III, do CPC. Se a existência prévia de linha de confrontação, a desnecessidade de avivenciação ou substituição de marcos e a clareza dos limites for constatada após a instrução, a demanda deve ser julgada improcedente, pois o autor não terá a pretensão de demarcar. Quanto à legitimidade ativa, tanto o Código de Processo Civil (art. 569, I) quanto o Código Civil (art. 1.297) fazem alusão ao proprietário. Discute-se, na doutrina, se teriam legitimidade ativa os titulares de direitos reais limitados.¹⁴ Argumentos ponderáveis militam em favor de cada uma das posições e a jurisprudência não se pacificou sob o código de processo revogado.¹⁵

A resposta à questão passa pelo exame da finalidade do instituto. Em última análise, a ação demarcatória tem como objetivo assegurar o melhor uso, gozo e disposição do bem imóvel, em conformidade com o disposto no art. 1.228 do Código Civil.¹⁶ Não é adequado, portanto, que ocorra a propositura da demanda demarcatória por quem não seja proprietário, pois os efeitos da demarcação poderão atingi-lo. Essa circunstância foi bem percebida por Paulo Cezar Pinheiro Carneiro,¹⁷ que destacou a possibilidade de que a demarcatória renda ensejo à transcrição da linha de confrontação, assim como dos lindeiros, nos termos do art. 167, I, n. 23, da Lei de Registros Públicos.¹⁸ Nesse caso, como assinala o jurista na passagem referida, é de pouca relevância o argumento de que o proprietário não se submeteria à coisa julgada, pois a implementação da sentença de demarcação lhe atingiria.

Poder-se-ia sustentar que a caracterização de litisconsórcio ativo necessário solucionaria o problema, à medida que estaria assegurada a participação do proprietário no polo ativo da demanda. Mas, além da dificuldade consistente na própria caracterização dessa modalidade de litisconsórcio, já que ninguém pode ser obrigado a postular contra outrem, é correto afirmar que o ajuizamento da ação por outrem contraria a vontade do proprietário, maior interessado na demarcação.¹⁹ Com efeito, se tivesse dúvida sobre os limites ou percebesse a necessidade de aviventar ou substituir marcos apagados ou destruídos, caberia a ele, proprietário, promover a ação. É ele o maior interessado em assegurar o uso, gozo e a livre disposição da coisa.

Desse modo, crê-se que a legitimidade ativa para a propositura da ação demarcatória recai sobre o proprietário, o nu-proprietário, o enfiteuta e o senhorio direto, além dos condôminos, que proprietários são (CPC/2015, art. 575). Todos eles, além do interesse na demarcação, sofrerão os efeitos práticos da demanda. Disso decorre a legitimidade ativa para propô-la. Considerada a premissa de assegurar a melhor fruição da propriedade, permitindo que ajuíze a ação quem vier a sofrer os efeitos da sentença, a legitimação ativa do proprietário e do nu-proprietário não traz qualquer dificuldade de visualização.

Pode-se questionar se o raciocínio seria válido também para o enfiteuta. A resposta é positiva. O enfiteuta é titular do domínio útil do imóvel, caracterizando-se a enfiteuse como o mais abrangente dos direitos reais sobre coisa alheia.²⁰ Considerado, portanto, seu interesse na demarcação, torna-se nítida sua legitimidade. Por identidade de raciocínio, consideradas as características da enfiteuse, o senhorio direto, titular do domínio direto, também tem interesse e legitimidade ativa.

Exclui-se, portanto, a legitimidade ativa do superficiário, do usufrutuário, do usuário, do habitador, do concessionário de uso especial para fins de moradia e do concessionário de direito real de uso. Também fica excluída a legitimidade ativa do anticresista, do credor hipotecário e do pignoratício, os quais são credores, não proprietários do bem, de modo que a eles o problema sequer se coloca, já que não desfrutam de qualquer fração do domínio.²¹

Por fim, considerada a premissa adotada, também será parte legítima ativa o promissário comprador quando o contrato tiver sido inscrito no Registro de Imóveis, tiver havido quitação e no contrato constarem as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e imissão de posse.²²

Se, por exemplo, a demarcação for requerida por habitador ou usuário, o juízo deve intimá-lo para esclarecer sua relação com o imóvel. Confirmado o uso ou habitação, a inicial deve ser indeferida, com fundamento no art. 330, inc. II, do CPC. Se essa circunstância só for revelada depois da instrução, há de se julgar improcedente a demanda, em atenção à primazia do mérito, abrigada nos arts. 4º e 488 do código processual.

Idêntico raciocínio se aplica à legitimidade passiva. Se o autor propuser a demanda contra quem não seja confinante e essa circunstância ficar clara na inicial, o juízo, depois da oitiva do demandante, poderá extinguir parcialmente a demanda, sem resolução de mérito, em relação ao não confinante. Se essa circunstância for esclarecida depois da instrução, ocorrerá exame de mérito, com o pronunciamento de improcedência em relação ao réu que não era confinante. Por fim, é possível que o demandando apresente, na resposta, o legitimado passivo, ocasião na qual pode haver substituição ou inclusão do terceiro (CPC, art. 339, §§ 1º e 2º).

2. Ação demarcatória e reivindicatória

É necessário distinguir a ação demarcatória da reivindicatória. Nesta, o proprietário não possuidor se fundamenta no domínio para que a coisa seja recuperada daquele que a possui injustamente.²³ Tratando-se de ação destinada à retomada contra o possuidor injusto, a reivindicatória tem como pressuposto a certeza sobre os limites do imóvel. Na demanda demarcatória, por sua vez, a inexistência de limites ou a dúvida sobre a linha de confrontação são elementos caracterizadores do legítimo interesse processual.²⁴

Em outras palavras, o autor será carecedor da ação demarcatória se não houver dúvida sobre os lindes do imóvel, ao passo que a ação reivindicatória pressupõe que o bem a ser retomado esteja perfeitamente delimitado. Vê-se, assim, que a distinção entre as ações não se dá em razão da aptidão para restituir a área objeto do litígio, pois também a ação demarcatória, nos termos do art. 581, parágrafo único, do CPC/2015, *determinará a restituição da área invadida*.

3. Ação demarcatória como ação real imobiliária

A ação demarcatória é ação real, pois tem a restituição da coisa como pedido mediato (CPC/2015, art. 581, parágrafo único).²⁵ O critério para a definição como ação real não radica, portanto, no direito discutido.²⁶ Trata-se de ação real imobiliária em decorrência do que consta no art. 80, I, do CC, dispositivo segundo o qual serão considerados bens imóveis os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram.²⁷ Consistindo em ação real imobiliária, será necessário o consentimento do cônjuge para o ajuizamento da ação. Por identidade de motivo, formar-se-á litisconsórcio passivo, excetuada a hipótese de casamento sob o regime da separação absoluta de bens, conforme assinala o art. 73, § 1.º, I, do CPC/2015.²⁸ Outra consequência da classificação da demarcatória como ação real imobiliária é a competência absoluta do foro de situação do imóvel, nos termos do art. 47, *caput* e § 1.º, do CPC/2015.²⁹ Nas hipóteses em que o imóvel estiver situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento abrangerá a integralidade do bem (CPC/2015, art. 60),³⁰ solução conforme ao que a doutrina há muito preconizava.³¹

4. Ação divisória: interesse processual e legitimidade

O art. 569, II, assinala a legitimidade ativa do condômino para a ação de divisão, a fim de que sejam estremados os quinhões dos demais consortes. O condomínio é disciplinado nos arts. 1.314 a 1.330, do CC.

De acordo com o art. 1.320 do CC, a divisão da coisa poderá ser requerida a todo tempo,

recaindo as respectivas despesas sobre o quinhão de cada condômino. O § 1.º do mesmo dispositivo assinala que os condôminos poderão pactuar a situação de indivisão por prazo correspondente a cinco anos, o qual poderá ser prorrogado. Nos §§ 2.º e 3.º prescreve-se, respectivamente, que o estado de indivisão determinado por doador ou testador não poderá exceder de cinco anos, sendo possível, a requerimento de qualquer interessado e com fundamento em motivos relevantes, que o juiz determine a divisão da coisa antes do prazo.³²

A finalidade da ação de divisão, logo se vê, é a extinção do condomínio, a fim de que a coisa comum seja partilhada, atribuindo-se a cada proprietário o seu quinhão.³³ A demanda pode ser ajuizada para a dissolução de condomínio constituído por terras rurais ou urbanas, desde que sejam divisíveis. Aplicam-se à espécie os arts. 87³⁴ e 88,³⁵ ambos do CC. De acordo com o primeiro dispositivo, serão divisíveis os bens cujo fracionamento possa ocorrer sem modificação da substância, diminuição considerável do valor ou prejuízo do uso a que são destinados. Por sua vez, o art. 88 preconiza que bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis em razão de convenção entre as partes ou de determinação legal. Vê-se, assim, que a indivisibilidade pode se originar da natureza, de convenção entre as partes ou de imposição normativa.³⁶

Caracterizada a indivisibilidade, se os condôminos não adjudicarem a coisa a um proprietário, indenizando os demais, o art. 1.322, *caput*, do CC prescreve que ocorrerá venda com a repartição do valor apurado, preferindo-se, em iguais condições de oferta, o comproprietário a estranho e, entre os proprietários, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas ou, inexistindo benfeitorias, o que tiver o maior quinhão. O parágrafo único do dispositivo assinala que, se nenhum condômino tiver benfeitorias e os quinhões forem idênticos, realizar-se-á licitação entre estranhos, procedendo-se à licitação entre os condôminos antes da adjudicação da coisa ao estranho que tiver oferecido maior preço. Em condições iguais, preferir-se-á o condômino ao estranho.³⁷ A alienação judicial da coisa comum seguirá as disposições gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária, conforme assenta o art. 725, IV, do CPC/2015.³⁸

Nos termos do art. 504 do CC³⁹, é vedado ao condômino, proprietário de quinhão em coisa comum, alienar sua parte a terceiros se algum dos comproprietários se dispuser a pagar o mesmo preço. O condômino que não tiver sido informado sobre a alienação poderá depositar o preço e obter para si o quinhão vendido, desde que, no prazo decadencial de 180 dias contados a partir da transferência da propriedade, ajuíze demanda, que correrá sob o procedimento comum. A fim de assegurar a ciência dos demais comproprietários sobre a venda do quinhão, *poderá* o interessado deflagrar o procedimento de jurisdição voluntária previsto no art. 725, V, do CPC/2015.⁴⁰ Não se trata de dever do interessado, que poderá, em vez de instaurar o procedimento, notificar os demais condôminos extrajudicialmente.⁴¹

Ainda no tocante à indivisibilidade, tem-se que a divisão da coisa comum deverá respeitar o módulo mínimo da propriedade rural previsto no art. 65 do Estatuto da Terra,⁴² dispositivo complementado pelo art. 8.º da Lei 5.868/1972,⁴³ que proíbe que qualquer imóvel seja desmembrado ou dividido em área menor que o módulo calculado para o imóvel ou que a fração mínima de parcelamento, prevalecendo a área menor.

A jurisprudência pacificou-se em torno do tema, aplicando o art. 65 do Estatuto da Terra de forma a inviabilizar divisões que resultem em quinhões inferiores ao módulo rural.⁴⁴ Prevaleceu na jurisprudência, durante a vigência do Código revogado, o entendimento de que a propositura de demanda da qual resultasse divisão em área inferior ao módulo mínimo gera a extinção do processo sem resolução do mérito.⁴⁵ Há, contudo, posicionamento, com o qual se concorda, de acordo com o qual o tamanho da área a ser desmembrada diz respeito ao mérito da ação divisória.⁴⁶ A questão merece maior aprofundamento.

As condições da ação, no Código de Processo Civil de 1973, eram gênero ao qual correspondiam três espécies: legitimidade ativa e passiva *ad causam*, possibilidade jurídica e interesse processual. As categorias eram explicitamente indicadas nos arts. 3.º e 267, VI, do Código revogado. O código atual não emprega a locução “condições da ação”, de modo que a legitimidade e o interesse podem ser concebidos como pressupostos processuais. No que se refere à possibilidade jurídica, parte da

doutrina sempre a considerou como frisante exemplo de improcedência da demanda, a ensejar a extinção do processo com resolução do mérito.⁴⁷ Esse entendimento prevaleceu durante a redação do Código vigente, de modo que a possibilidade jurídica perdeu sua autonomia no direito positivo..

Com efeito, é digno de nota que o Código vigente não menciona a possibilidade jurídica do pedido. No art. 330, II e III, ao indicar as hipóteses de indeferimento da petição inicial, refere-se o Código, respectivamente, à parte manifestamente ilegítima e ao interesse processual. Do mesmo modo, ao indicar, no art. 337, quais matérias devem ser discutidas preliminarmente na contestação, o Código se refere, no inc. XI, à ausência de interesse ou de legitimidade processual. Por fim, o art. 485, ao dispor sobre as sentenças terminativas, assinala que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual (inc. VI).

Crê-se que a orientação do legislador, ao omitir a possibilidade jurídica, esteja correta. A jurisprudência consolidada sob o CPC/1973 sufragou a ideia de que haverá carência da ação, por impossibilidade jurídica, quando a pretensão formulada, sinônimo de pedido de tutela jurisdicional, estiver expressamente proibida no ordenamento jurídico.⁴⁸ Ora, se a pretensão é proibida pelo ordenamento, então o pedido será improcedente, sendo irrelevante a argumentação coligida pelo autor para o seu acatamento. Na primeira edição destes comentários defendi a ideia de que a possibilidade jurídica teria sido absorvida pelo interesse processual. Contudo, parece-me mais adequado conceber a impossibilidade como hipótese de improcedência..

Feitas essas considerações, é necessário afirmar a correção do julgado do Tribunal de Justiça do Paraná há pouco citado. Há expressa previsão quanto à possibilidade de se pleitear a divisão, tanto no Código Civil (art. 1.320) quanto no Código de Processo Civil (art. 569, II). Assim, quando a demanda divisória levar à constituição de quinhão em tamanho inferior ao módulo mínimo, sendo essa circunstância verificada na instrução, haverá resolução de mérito, impondo-se a decretação de improcedência do pedido. Contudo, se na inicial o autor indicar a inferioridade da área em relação ao módulo mínimo, o juízo, depois de requerer esclarecimentos, indeferirá a inicial, mediante decisão terminativa, por falta de interesse processual.

A primazia do mérito, prevista nos arts. 4º e 488 do CPC, faz com que haja soluções distintas, a depender do momento em que o tema é apreciado. Estando clara na inicial a inferioridade da área, não será econômico dar continuidade ao processo, de modo que o juiz, depois de se esclarecer junto ao autor, deve indeferir a inicial, extinguindo o processo (CPC, art. 330, III). Por outro lado, se a instrução já tiver sido instaurada, será útil e econômico que a pretensão seja apreciada, a fim de que recaia a coisa julgada sobre o *decisum*, inviabilizando nova demanda com vistas à divisão da mesma área, desde que tenha sido mantido o módulo mínimo.

A doutrina adverte que também deverá ser respeitada a Lei Orgânica Municipal, de modo que, se nela houver proibição ao desmembramento de um condomínio, a divisão não poderá ocorrer, mesmo que seja possível e dela não resulte diminuição do valor ou prejuízo ao uso.⁴⁹

Quanto à legitimidade para a propositura da ação divisória, há posições divergentes na doutrina. O art. 569, I, assinala que a ação de divisão caberá ao condômino para obrigar os demais consortes a estreimar os quinhões. O mesmo conteúdo pode ser depreendido do art. 1.320 do CC. Para parte da doutrina, a legitimidade para a propositura da demanda divisória ficaria restrita aos proprietários.⁵⁰ Mas também se defende maior amplitude à legitimação, a fim de que ela compreenda o fiduciário e o enfiteuta que contar com o consentimento do senhorio direto, bem como o promissário comprador e o herdeiro único.⁵¹

A extensão da legitimidade ao enfiteuta não gera perplexidade, pois ele é o titular do domínio útil. Será necessário, contudo, que haja consentimento do senhorio direto para o ajuizamento da demanda. A propriedade é atribuída ao fiduciário, conquanto seja resolúvel e restrita. Trata-se, contudo, de legítimo proprietário, sendo adequada sua legitimação ativa para a demanda divisória.⁵²

O promissário comprador titular de contrato quitado, averbado junto à matrícula do imóvel, no qual constem cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade, bem como de imissão de posse,

também deve ser legitimado à propositura, pois inequívoco detentor de interesse processual na divisão. Admitida a adjudicação do imóvel por força do contrato, parece inexistir razão para tolher a legitimação do promissário comprador. Por fim, no tocante ao herdeiro único, sabe-se que com a abertura da sucessão os bens lhe são imediatamente transmitidos (CC, art. 1.784). Essa circunstância autoriza que se lhe outorgue legitimação ativa para o ajuizamento da ação divisória.

Se da leitura da inicial não se depreender a qualidade de proprietário, fiduciário, enfiteuta, promissário comprador ou herdeiro único do autor, o juízo, depois de ouvi-lo, indeferirá a inicial caso não haja retificação (CPC, art. 330, inc. II). Se essa circunstância for esclarecida apenas depois da instrução, em atenção à primazia do mérito (CPC, arts. 4º e 488), há de se decretar a improcedência da demanda, pois o autor não tem a pretensão de dividir. Todavia, considerando a duplicidade das ações divisórias, a improcedência da demanda não inviabiliza a divisão da área em relação aos outros proprietários partícipes da relação processual.

Quanto à legitimidade passiva, se a inconsistência narrativa da inicial levar à conclusão de que um terceiro deveria figurar no processo, o juízo se esclarecerá junto ao demandante, ordenando, se for o caso, a retificação do polo passivo. Nos termos do art. 339, §§1º e 2º, do CPC, o réu poderá indicar a legitimidade passiva de outrem, ocasião na qual o autor requererá a substituição no polo passivo ou a inclusão do terceiro. Trata-se de matéria de ordem pública, sobre a qual o juízo deverá decidir no saneamento do processo (CPC, art. 357, inc. I).

5. Ação divisória e inventário

A ação divisória e o inventário têm escopos diferentes. Com a primeira, como já dito, pretende-se extinguir o condomínio, a fim de que cada comproprietário receba seu quinhão. No inventário ocorrerá a partilha dos bens do *de cujus*, mas os sucessores podem se tornar condôminos de um imóvel. São nítidos, portanto, os resultados diversos a que levam as demandas. Também é digno de nota que a partilha terá como objeto uma universalidade de bens, ao passo que a divisória tem como requisito a comunhão sobre um único bem.⁵³ A partilha, ademais, é irrepetível, podendo a divisão, por seu turno, realizar-se quantas vezes forem necessárias.⁵⁴

6. Ação divisória como ação real imobiliária

Para classificar uma ação como real é necessário verificar a que fim ela se destina. Se o objetivo for permitir o adimplemento de uma prestação, trata-se de ação pessoal. Consistindo a finalidade da demanda na obtenção da coisa, sua natureza será real.⁵⁵ Considerado esse critério, pode-se afirmar que se trata de ação real, destinada a propiciar a dissolução do estado de comunhão, por meio da atribuição ao proprietário de seu quinhão. Trata-se de bem que é individualizado e atribuído ao condômino por força da demanda, cuja natureza real é inquestionável.

Aplica-se à ação divisória o art. 80, I, do CC, preceito normativo a assinalar que os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram são bens imóveis. Nos termos do art. 73, § 1.º, I, do CPC/2015, impõe-se o consentimento do cônjuge para a propositura da demanda. Há litisconsórcio passivo necessário quando o cônjuge for réu, a não ser que o casamento se pautar pelo regime da separação absoluta de bens. Esse posicionamento já vigorava na jurisprudência erigida sob o código anterior, devendo ser preservado sob o diploma vigente.⁵⁶ Para o processamento da demanda a competência do foro da situação do imóvel é absoluta e decorre do art. 47, *caput* e § 1.º, do CPC/2015. Se o imóvel estiver situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, o juízo prevento terá competência para decidir sobre a integralidade do bem, o que resulta do art. 60 do CPC/2015.

Trata-se, assim, do mesmo regime a que se submete a ação de demarcação.

7. Ações dúplices, imprescritíveis e restritas às terras particulares

As ações divisórias e demarcatórias são ações dúplices, o que significa que as posições de autor

e réu se confundem.⁵⁷ Não se trata, tal como ocorre com as ações possessórias, de duplicidade imposta por conveniência do legislador, mas sim, de característica originária do objeto e finalidade das ações em comento.

Tome-se como exemplo demanda demarcatória ajuizada para a delimitação dos imóveis. A legitimidade para promovê-la recai sobre o proprietário, que proporá a demanda contra os confinantes de seu prédio. O objetivo é que seja criada a linha de confrontação entre os imóveis. É bastante nítido, nesse caso, que a resposta dos réus caracterizará também um pedido para que a linha apresente determinada conformação. Simplesmente por responderem os réus formulam pretensão, do que resulta a duplicidade das ações demarcatórias.

Considere-se agora as ações divisórias. O propósito delas é extinguir o condomínio, a fim de que a cada comproprietário seja atribuído seu quinhão. Facilmente se percebe que ao apresentarem resposta os demais condôminos formulam pretensão ao juízo, requerendo que os quinhões sejam atribuídos de maneira específica, em consonância com os títulos dominiais. Inequívoco, portanto, o caráter dúplice também das ações de divisão.

É por conta da duplicidade das ações de demarcação e de divisão que não poderá ocorrer extinção do processo por desídia do autor.⁵⁸ Com efeito, a tal ponto se confundem as posições do autor e dos réus, que bastará que um deles impulsione o processo para que fique inviabilizada a hipótese de extinção sem resolução de mérito prevista no art. 485, III, do CPC/2015.⁵⁹

As ações divisórias e demarcatórias são imprescritíveis.⁶⁰ O art. 1.320 do CC prescreve que a ação divisória poderá ser proposta a todo tempo, o que significa que os condôminos poderão ajuizá-la enquanto persistir a indivisão. O art. 1.297, por sua vez, dispõe que o proprietário poderá constranger o confinante a demarcar o imóvel. A premissa, por óbvio, é que a qualquer tempo poderá ser ajuizada a demarcatória. Em suma, persistindo a confusão entre os limites e a comunhão, poderão ser ajuizadas as demandas demarcatória e divisória.

O bem que se pretende dividir ou cujos limites se quer demarcar, deve ser privado, o que resulta não somente da denominação do capítulo em que estão previstas as ações de divisão e de demarcação – “Da Ação de Divisão e da Demarcação de Terras Particulares – mas também de legislação esparsa, a regular a discriminação de terras públicas (Lei 6.383/1976) e a demarcação de terras indígenas (Decreto 1.775/1996).⁶¹

8. Ações de demarcação e de divisão: parciais ou totais

Há ação demarcatória parcial quando a confusão entre os limites, a necessidade de delimitação entre os imóveis ou de substituição ou renovação de marcos atingir somente parte do perímetro, não sua totalidade. Do mesmo modo, haverá parcialidade na divisão se optarem alguns condôminos por permanecerem com seus quinhões indivisos. Isso obviamente não lhes retira a possibilidade de posteriormente requerer a divisão.⁶²

É válido destacar que a divisão parcial exige a presença, em litisconsórcio passivo, de todos os condôminos, ao passo que na demarcação parcial só devem integrar a relação processual os confinantes da parcela do perímetro que se mostrar duvidosa.⁶³ Não faria qualquer sentido que participassem do processo mesmo os confinantes cujos limites em relação ao imóvel do autor sejam perfeitamente conhecidos e estejam seguramente demarcados.

9. Caráter contencioso das ações de demarcação e de divisão

As ações demarcatória e divisória são contenciosas. Todavia, poderá ocorrer demarcação e/ou divisão mediante convenção das partes, sem necessidade de propositura das demandas em análise, conforme prevê o art. 571 do CPC/2015, desde que todos os interessados sejam maiores, capazes e estejam em acordo. A propósito, a possibilidade de solução amigável de litígios envolvendo a divisão ou a demarcação sempre foi reconhecida pela doutrina.⁶⁴

Não pode haver dúvida sobre o caráter contencioso das ações de demarcação e de divisão.⁶⁵ Em nada auxilia, para sua caracterização como procedimentos de jurisdição voluntária, a possibilidade de celebração de acordo extrajudicial. A possibilidade franqueada, no art. 571, aos interessados maiores e capazes não altera o caráter contencioso das ações em questão. Entendimento contrário levaria à incorreta conclusão de que seriam espécies de jurisdição voluntária todas as ações em que fosse possível a transação extrajudicial.

Ademais, a homologação de acordo com fundamento no art. 57 da Lei dos Juizados Especiais não caracteriza jurisdição voluntária. Trata-se ainda de jurisdição contenciosa, tal como seria qualquer transação homologada no âmbito de um processo.⁶⁶

Art. 570. É lícita a cumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos.

No dispositivo ora examinado o Código dispõe sobre a possibilidade de “cumulação” das ações de demarcação e de divisão. Todavia, não é preciso muito esforço para perceber que se não trata de verdadeira cumulação.

O autor na demarcatória será o proprietário que pretenda delimitar a linha de confrontação que separa seu imóvel dos prédios contíguos. Poderá ainda, como foi visto, pretender marcar a linha divisória já existente, assim como substituir ou aviventar marcos arruinados ou apagados. Qualquer que seja o caso, serão legitimados passivos os confinantes. A causa de pedir consiste na propriedade aliada à inexistência de linha demarcatória.⁶⁷ Tratando-se de demanda ajuizada para a substituição ou aviventação de marcos, a causa de pedir será a propriedade do imóvel aliada à ruína ou ao esmaecimento dos marcos. O pedido consistirá na constituição de linha demarcatória, na inserção de novos marcos, ou, ainda, na substituição ou aviventação de marcos. Não há nada em comum com a ação divisória para que se possa falar em cumulação de demandas.

Com efeito, a ação de divisão é proposta por um comproprietário com o objetivo de extinguir o condomínio existente sobre determinado bem. A causa de pedir é a propriedade de um bem em comumhão. O pedido é a extinção da comunhão, com a atribuição a cada condômino de seu quinhão. Inexistindo coincidência entre os três elementos da demanda – partes, causa de pedir e pedido – não há verdadeira cumulação.⁶⁸

Cabe aqui um esclarecimento conceitual. Não se confundem, sob o ponto de vista da técnica processual, as “ações” com as “demandas”. “Ação” é direito subjetivo público, uno e abstrato, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição. Quando se acessa o Judiciário exerce-se o direito de ação. Esse exercício consiste no pedido de tutela jurisdicional que instaura o processo e submete ao juiz a pretensão qualificada pela causa de pedir, delimitando o objeto litigioso. Ao ato de provocar o Poder Judiciário, deflagrando o processo, dá-se o nome de demanda.⁶⁹ Advirta-se que nestes comentários os termos *ação* e *demandas* poderão ser empregados como sinônimos, a fim de evitar a repetição de palavras em uma mesma oração. Há de se atentar, contudo, para a diferença conceitual.

Vê-se que a hipótese prevista no art. 570 jamais representaria uma cumulação de ações.⁷⁰ Aliás, a ação, compreendida como direito de acesso ao Judiciário, não pode ser cumulada. Tratar-se-ia, então, de cumulação de demandas. Porém, para que houvesse cumulação, seria necessária alguma identidade entre os elementos da demanda – partes, causa de pedir e pedido.⁷¹ Ocorre que essa identidade, como já dito, não existe. O artigo em comento encerra apenas hipótese de cumulação subjetiva, eis que os pedidos de demarcação e de divisão geram litisconsórcio passivo necessário, pois devem ser citados todos os confinantes e todos os condôminos.

Não se vê, portanto, hipótese de cumulação objetiva. É certo que são apresentados pedidos diferentes – demarcação e divisão – baseados em fundamentos diferentes – inexistência de linha de confrontação ou comunhão sobre um bem – mas, para que houvesse autêntica cumulação de demandas, seria imprescindível que duas causas de pedir qualificassem um dos pedidos ou uma mesma causa de pedir ensejasse a realização de dois ou mais pedidos.⁷² Isso não acontece na modalidade de “cumulação” indicada no dispositivo em estudo. O que ele permite, em última

análise, é que um mesmo processo abranja procedimentos especiais distintos.

O art. 570 dispõe em termos inequívocos que primeiramente deverá ser processada e julgada a demarcação. Trata-se de prioridade lógica. Afinal, não seria nada razoável dividir um imóvel cujos limites são ignorados. Para que se extinga a comunhão sobre o bem é necessário que sejam conhecidos seus limites.

1. Citação dos confinantes e dos condôminos

O dispositivo assinala a necessidade de que sejam citados os confinantes e os condôminos. Os confinantes são citados para se manifestarem sobre o pedido de demarcação, ao passo que a citação dos comproprietários ocorre em razão do pedido de divisão.

Divide-se a doutrina sobre a amplitude de atuação dos réus. Por um lado, em posição mais restrita, salienta-se que os confinantes poderão contestar somente a demanda demarcatória, do mesmo modo que os condôminos contestam apenas a divisória.⁷³ Por outro lado, admite-se que os condôminos, réus na divisão, possam apresentar ao juízo linha de confrontação diversa da que fora pleiteada pelo autor.⁷⁴ Isso caracterizaria a possibilidade de contestarem também o pedido demarcatório. O posicionamento mais amplo é o mais correto.

É perfeitamente concebível que os demais condôminos, réus na divisória, tenham interesse em propor linha de confrontação com características diferentes daquela que fora pleiteada pelo autor. Nesse caso, ao apresentarem outra linha de demarcação para o imóvel titularizado em comunhão, inequivocamente contestam a ação demarcatória. É razoável que seja outorgada aos condôminos a oportunidade de contestarem a ação de demarcação, pois são comproprietários do imóvel que se submeterá à divisão.

A propósito, se há um fundamento para a extravagante possibilidade de “cumulação” prevista no dispositivo, trata-se justamente da possibilidade de permitir que os condôminos se manifestem sobre a linha demarcatória. Não houvesse a cumulação, ter-se-ia de cogitar a sempre complexa hipótese de litisconsórcio ativo necessário, a fim de que todos os comproprietários se manifestassem sobre a demarcação. Mas mesmo essa atuação conjunta não eliminaria todos os problemas. É facilmente imaginável a hipótese em que os condôminos tenham diferentes opiniões sobre a conformação do perímetro. Nesse caso, o litisconsórcio ativo necessário seria solução menos satisfatória que a “cumulação” disciplinada no art. 570 do CPC/2015.

No que toca aos confinantes, dúvida não há sobre a falta de interesse em participarem da ação divisória, o que é claramente indicado no art. 572, de acordo com o qual, sendo fixados os marcos, os confinantes serão terceiros em relação ao processo divisório. Até pode ocorrer que um dos condôminos seja também confinante do condomínio, por ser proprietário de prédio contíguo. Mas sua participação na divisão decorre exclusivamente de sua qualidade como condômino, não tendo qualquer relação com sua situação de confinante do condomínio.

Consequência nem sempre percebida da “cumulação” em comento é a possibilidade de que o condômino deixe de indicar com exatidão a linha de confrontação do imóvel, imposição que recai ao autor da ação divisória por força do art. 588, I, do CPC/2015.⁷⁵ É óbvio que o autor não terá como indicar o perímetro do condomínio, pois é precisamente a inexistência de linha de confrontação que o levou a propor a demanda demarcatória. É certo, portanto, que nesse caso o descumprimento do art. 588, I, não ensejará o indeferimento da petição inicial.

Art. 571. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se, no que couber, os dispositivos deste Capítulo.

1. Má localização do dispositivo

O art. 571 está incorretamente localizado. Percebe-se facilmente que os arts. 570 e 572 estão

conectados. O primeiro dos dispositivos, como já visto, regula a “cumulação” entre as demandas demarcatória e divisória. O segundo assinala que após a colocação dos marcos da linha de demarcação os confinantes serão considerados terceiros na divisória.

A inserção em sequência dos preceitos contidos nos arts. 570 e 572 facilitaria a interpretação dos parágrafos deste último dispositivo, ficando claro que a demanda a que se referem tem como fundamento a violação da linha demarcatória em razão da ação de divisão. Desse modo, o preceito contido no dispositivo em análise estaria melhor localizado imediatamente após a previsão sobre o cabimento da demarcação e da divisão (art. 569). Com efeito, seria mais adequado, antes de prever a “cumulação” entre demarcação e divisão, apontar que ambas poderão ser realizadas extrajudicialmente.

2. Demarcação e divisão extrajudiciais: forma

A doutrina já reconhecia a possibilidade de que os confinantes e condôminos realizassem amigavelmente a demarcação e a divisão de terras particulares⁷⁶. Trata-se de direito material de caráter privado, viabilizando-se a transação em conformidade com o art. 841 do CC.⁷⁷ A transação, como decorre do art. 840, é o contrato por meio do qual os transatores previnem ou resolvem litígio, mediante concessões mútuas.⁷⁸ Ao estipularem a demarcação ou a divisão, inegavelmente os interessados previnem litígio, evitando a propositura de demanda para o mesmo fim. É certo, ademais, que tanto na demarcação quanto na divisão, realizarão mútuas concessões a fim de prevenir o litígio.

O art. 571 alude expressamente à escritura pública como instrumento por meio do qual devem ser transacionadas a demarcação e a divisão. É o que basta para se perceber a insuficiência de eventual transação realizada mediante documento particular. Essa determinação está em conformidade com o art. 108 do CC, segundo o qual a escritura pública é forma essencial para a validade de negócios jurídicos que versem sobre a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis com valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo.⁷⁹

É fácil perceber a incidência do art. 108 do CC à hipótese. Quando se demarca ou divide um imóvel, altera-se o direito de propriedade que sobre ele se exerce. Há, indiscutivelmente, modificação na propriedade, o que impõe a escritura pública como forma essencial à validade da divisão ou da demarcação. Ocorre que o art. 571 exige de forma inequívoca a escritura pública, de modo que não é necessário recorrer ao dispositivo do diploma civil para se perceber a invalidade da transação celebrada mediante documento particular. Lastima-se a solução, reflexo de concepção burocrática que amesquinha a vontade das partes, mas ela decorre do direito positivo.

Analizando o dispositivo em comento, Humberto Theodoro Jr.⁸⁰ assinalou a possibilidade de que a transação ocorra mediante escritura particular, desde que seja homologada judicialmente, nos termos do art. 57 da Lei 9.099/1995, para que então seja registrada em consonância com o art. 167, I, item 23, da Lei 6.015/1973.⁸¹ Nesse caso não se poderia cogitar de invalidade, pois o documento particular teria sido homologado judicialmente. Todavia, é mais cômodo e célere estipular a transação em escritura pública, levando-a a registro, ato a dispensar a homologação judicial.

3. Demarcação e divisão extrajudiciais: capacidade e concordância dos interessados

A capacidade dos interessados é requisito imprescindível para que demarquem e/ou dividam determinado imóvel. O art. 571 menciona a maioria e a capacidade. Trata-se de nítida superfetação. Bastaria se referir à capacidade plena, já que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes (art. 3.º,⁸²) e os maiores de 16 e menores de 18 são considerados relativamente incapazes (art. 4.º, I⁸³).

Também não se fazia necessária a referência à concordância dos interessados. Obviamente só

haverá transação se houver concordância entre os interessados. Note-se que deverão participar da composição todos os confinantes, quando se tratar de demarcação, assim como todos os condôminos, na hipótese de divisão. Em resumo, deverão participar da transação todos os interessados que participariam do processo.

É possível que haja divisão parcial, conforme assinalado nos comentários ao art. 569. Assim, dois ou mais condôminos podem preferir manter indivisa determinada porção do condomínio. No âmbito judicial a concordância sobre a indivisão se limita aos condôminos que pretenderem manter a parte indivisa, sendo desnecessária a anuência dos demais.⁸⁴ Algo diverso ocorre no plano extrajudicial. Se um dos condôminos não concordar com a divisão parcial, recusar-se-á a assinar a transação, o que basta para que as partes tenham de recorrer ao Judiciário.

Ainda sobre a divisão, certamente é vedada a constituição de quinhões que descumpram o módulo mínimo previsto no art. 65 do Estatuto da Terra. É óbvio que a restrição reconhecida judicialmente atinge também os atos jurídicos extrajudiciais. Caso haja desatendimento ao módulo legal, deverá ser recusado o registro pelo cartório competente.

4. Demarcação e divisão extrajudiciais: aplicação dos dispositivos do Capítulo IV

O art. 571, *in fine*, estabelece que serão observados os dispositivos do Capítulo IV, no que couber, na demarcação e na divisão extrajudiciais. A referência não se restringe às disposições sobre prova pericial. Alcança, ainda, os dispositivos concernentes à legitimidade. Em outras palavras, o art. 571 exige que participem do ato todos os interessados que teriam legitimidade para integrar o processo. Quanto aos demais dispositivos, a conveniência da aplicação deve ser analisada à luz do caso concreto.

Art. 572. Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor.

§ 1.º No caso do *caput*, serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente.

§ 2.º Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão ou de seus sucessores a título universal, na proporção que lhes tocar, a composição pecuniária do desfalque sofrido.

1. Aplicação do art. 572 à hipótese de cumulação do art. 570

Para que o dispositivo em análise seja corretamente compreendido, impõe-se ter como premissa que sua aplicação ocorrerá na hipótese de “cumulação” entre as demandas de demarcação e de divisão⁸⁵. Reiterando a prioridade lógica da primeira perante a segunda, pois antes de dividir é necessário delimitar, o art. 572 decreta que os confinantes, partes legítimas na demarcatória, serão considerados terceiros na demanda de divisão cumulada.

Rememore-se que o art. 570 prevê inusitada modalidade de “cumulação”, em que não há identidade entre as partes, a causa de pedir e os pedidos. Desse modo, os confinantes, legitimados para a demanda de demarcação, não o serão para a de divisão, razão pela qual o Código lhes caracteriza como terceiros após a fixação dos marcos da linha demarcatória, a qual só ocorrerá depois do trânsito em julgado da sentença de demarcação. Mas a perda do *status* de parte não submete os confinantes a eventuais prejuízos que a divisão venha a lhes causar, conforme se verá a seguir.

2. Vindicação ou indenização

O art. 572, *caput*, *in fine*, outorga aos confinantes, terceiros na ação divisória, a possibilidade de vindicarem ou pleitearem indenização em decorrência da perda de terrenos ocasionada pela ação divisória da qual não participam. Reitere-se que a premissa para a aplicação do dispositivo é a “cumulação” entre as demandas demarcatória e divisória.

É bastante claro que os confinantes que tiverem participado da ação demarcatória não poderão se insurgir contra a linha de confrontação traçada pela sentença que acolher o pedido de demarcação (art. 581, CPC/2015), pois sujeitos à coisa julgada. Terceiros que não tiverem participado da ação demarcatória poderão impugnar a própria linha de confrontação definida pela sentença.⁸⁶ Poder-se-ia imaginar que os terceiros prejudicados necessariamente teriam participado da demanda demarcatória. Mas isso seria errado. É possível que a divisão atinja terceiros que não eram confinantes do imóvel dividendo, mas foram atingidos pela constituição dos quinhões, que lhes usurpou parte do imóvel.

Na hipótese em análise, contudo, os terceiros a que alude o Código eram parte na demarcatória e foram prejudicados, posteriormente, pela divisória, que lhes subtraiu parcela do imóvel concedida pela sentença que acolhera a demanda demarcatória. Tenha-se em mente que a demarcação, por si só, implica reconhecimento de domínio e enseja a restituição de área eventualmente invadida, conforme preconiza o art. 572, § 2.º, do CPC/2015. A demarcação reconhece o domínio do confrontante.

Nessa circunstância, tendo sido prejudicado o confinante que fora parte na demanda demarcatória e é terceiro na divisória, o art. 572 lhe confere a possibilidade de vindicar o terreno de que se julgue despojado ou de requerer a indenização correspondente ao valor da parcela do imóvel que lhe foi usurpada. É preciso entender, primeiramente, quais demandas estariam compreendidas no verbo “vindicar”.

Parte da doutrina, ao interpretar o art. 948 do CPC/1973, sustentava que, ao facultar ao confrontante a possibilidade de *vindicar* o terreno que lhe foi retirado, o Código permitiria que ele ajuizasse as demandas reivindicatória ou de reintegração de posse.⁸⁷ Para outros autores, porém, o confinante, terceiro na ação de divisão, *vindicaria* por meio de embargos de terceiro, sendo restrita a possibilidade de propositura de demanda reivindicatória.⁸⁸

Concorda-se que os confinantes deverão ajuizar embargos de terceiro para se protegerem contra a usurpação de seu imóvel na demanda divisória. Embora tenha havido significativa mudança na redação do dispositivo que prevê os embargos de terceiro, remanesce a possibilidade de propositura dessa ação para que o confinante *vindique* parcela de seu terreno que lhe foi subtraída. Os embargos de terceiro podem ser manejados pelo proprietário e, apesar de inexistir previsão específica sobre a legitimidade dos confinantes, trata-se de medida necessária e adequada para a prestação da tutela jurisdicional.⁸⁹

Primeiramente, é preciso perceber que não cabe ação possessória. Os interditos têm como objeto a tutela da posse. Poderia alguém supor que o confinante, despojado por força da ação divisória, tutelaria seu direito adequadamente por meio de ação possessória. Mas isso não ocorre! O despojamento decorrente da divisão subtrai propriedade do confinante. A linha de confrontação, fixada na demarcatória, é alterada por força de decisão posterior, a acarretar a perda de propriedade sobre parcela do terreno que lhe fora usurpada. Disso resulta a insuficiência da ação de reintegração de posse, que tutela somente o *jus possessionis*, sendo incapaz de restituir a propriedade em favor do confrontante prejudicado.

A reivindicatória, por sua vez, é demanda na qual o proprietário não possuidor postula a posse contra o ilegítimo possuidor, não proprietário. Essa definição é suficiente para demonstrar que a demanda não permite a tutela do direito do confinante, pois o que ocorre com a divisão é usurpação de propriedade em favor do condômino. Em outras palavras, o condômino se torna proprietário, não podendo figurar no polo passivo da demanda reivindicatória. A questão pode ser vista por outro ângulo. Apesar da divisão, a atingir a propriedade, é possível que o confinante

permaneça na posse da totalidade do imóvel, o que retiraria sua legitimidade ativa na reivindicatória.

São pertinentes, portanto, os embargos de terceiro. É de somenos importância que o confinante não tenha sido arrolado expressamente como um dos legitimados no art. 674, § 2.º. Primeiramente, é necessário convir que a vindicação de que trata o art. 572 é hipótese bastante rara, o que justifica a omissão do legislador. Em segundo lugar, a legitimidade dos confrontantes decorre do próprio art. 572, à medida que os embargos de terceiro são a medida necessária e adequada para tutelar o direito de propriedade que foi agredido.

Poder-se-ia afirmar, contra o posicionamento aqui adotado, que o art. 572 não encerra hipótese de constrição capaz de ensejar os embargos de terceiro. Mas essa afirmação não é correta. O vocábulo *constrição*, que se aplica a arrestos, sequestros ou penhoras, por maioria de razão se aplica também à perda da propriedade originária de decisão judicial. Trata-se da constrição por excelência, gerando efeitos mais graves e danosos para o prejudicado que a penhora ou o arresto.

Pondere-se, ainda, que, diante do dissídio doutrinário e das especificidades do caso concreto, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, a fim de que sejam relativizadas exigências formais em benefício da tutela do direito. Assim, se o confinante ajuizar demanda e intitulá-la de reivindicatória, com fundamento na causa de pedir e atento ao pedido de vindicação, o juiz poderá outorgar a proteção necessária à tutela do direito, desconstituindo o provimento jurisdicional que ensejou a violação da propriedade. Seria possível inclusive que o autor designasse sua demanda como *vindicatória*, já que o *nomen juris* é irrelevante para a tutela jurisdicional.⁹⁰ O que importa é que conste pedido de proteção à propriedade motivado por agressão ao terreno do confinante que participara da demanda demarcatória. Delineada corretamente a causa de pedir e apresentado o pedido, impõe-se acolher a demanda, qualquer que seja o nome que a ela tenha sido atribuído.

O art. 572 permite que o confinante, em vez de *vindicar* a fração do imóvel que lhe foi usurpada, postule o ressarcimento mediante demanda indenizatória. Haverá, aqui, tutela pelo equivalente pecuniário, em vez da tutela específica concedida na hipótese de embargos de terceiro. O confrontante deverá comprovar o valor da parcela de propriedade que lhe foi subtraída. A prova do vínculo entre o dano causado e a divisão será dada pela própria planta do quinhão. O confinante é livre para escolher a forma de ressarcimento, se tutela específica ou se tutela pelo equivalente. Caso opte pela indenização, o confinante permite que a faixa de terra que lhe foi usurpada seja transferida definitivamente para o quinhoeiro.

3. Citação dos condôminos ou dos quinhoeiros

No CPC/1973 o atual § 1.º constituía dispositivo específico (art. 949). Agiu com acerto o legislador do Código vigente ao transformá-lo em § do art. 572, pois a imbricação entre os enunciados normativos é inequívoca. O art. 572, § 1.º, dispõe que, nas demandas vindicatória ou indenizatória, caso a ação de divisão ainda não tenha transitado em julgado, deverão ser citados todos os condôminos, caracterizando-se litisconsórcio passivo necessário. Caso já tenha ocorrido o trânsito em julgado da divisão, deverão ser citados os quinhoeiros dos terrenos vindicados. A proposição é bastante lógica e não pode causar perplexidade.

Se a demanda divisória não estiver encerrada, ainda haverá a situação de comunhão sobre o imóvel dividendo, a ensejar a propositura da demanda vindicatória (embargos de terceiro) ou indenizatória contra todos os condôminos. Por outro lado, se a divisão já tiver transitado em julgado, terá ocorrido a extinção do condomínio, com a formação e atribuição de quinhões aos condôminos, ora quinhoeiros. Nesse caso, deverá ser proposta a demanda vindicatória ou de indenização contra o(s) quinhoeiro(s) beneficiado(s) pelo despojamento da propriedade do confinante.

O foro competente dependerá da demanda ajuizada, conforme já assinalava a doutrina sob o Código anterior.⁹¹ Tratando-se de demanda vindicatória, pela qual se postule a restituição da parcela de terra usurpada, o foro será o da situação da coisa (CPC/2015, art. 47⁹²). Sendo proposta

demanda indenizatória, o foro competente será o do domicílio do réu (CPC/2015, art. 46⁹³).

4. Título executivo em favor do quinhoeiro que restituir o terreno ou pagar a indenização

A disposição contida no art. 572, § 2.º, era, no Código revogado, o parágrafo único do art. 949. Foi acertada a escolha do legislador em disciplinar a demanda do condômino prejudicado em um só dispositivo. O texto preconiza que a sentença de procedência, proferida na demanda vindicatória ou indenizatória, ajuizada contra o(s) quinhoeiro(s), valerá como título executivo contra os demais condôminos que tiverem participado da divisão ou de seus sucessores universais, a fim de que o quinhoeiro sucumbente seja compensado pelo desfalque sofrido.

É preciso aclarar a hipótese de incidência do dispositivo. O confinante que participara da demarcatória, sendo prejudicado pela divisão, poderá ajuizar demanda vindicatória ou indenizatória. Ajuizando a demanda e se sagrando vencedor, o confrontante será ressarcido do prejuízo que a divisão lhe causara. A tutela será específica, com a restituição do terreno despojado, ou pelo equivalente monetário. Pois bem. O art. 572, § 2.º, assinala que a sentença de procedência proferida na demanda vindicatória ou de indenização servirá como título executivo para que o quinhoeiro, que teve de indenizar ou restituir o terreno, possa se compensar frente aos demais condôminos.

A premissa desse dispositivo é que a divisão só despojou o confinante porque foi dada certa conformação aos quinhões que constituíam o imóvel dividendo. Dito de outro modo, além do quinhoeiro que efetivamente usurpou o terreno do confinante, os demais condôminos se beneficiaram da divisão que causou o despojamento, pois seus quinhões também se tornaram maiores por conta disso. A medida que todos foram beneficiados, não seria justo que somente o quinhoeiro demandado tivesse de arcar com o ressarcimento em pecúnia ou com a restituição. É por isso que a sentença valerá como título executivo, a fim de que seja compensado pelos demais condôminos o quinhoeiro que efetivamente espoliou o confinante.

Para que a sentença sirva como título executivo contra os demais condôminos, é necessário que eles tenham participado da demanda vindicatória ou de indenização. É por esse motivo que compete ao quinhoeiro realizar a denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II.⁹⁴ A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros provocada, por meio da qual o denunciante, autor ou réu, integra terceiro ao processo, na posição de seu litisconsorte, ao mesmo tempo em que propõe contra este terceiro demanda indenizatória eventual, que só será julgada se o denunciante sucumbir na demanda principal.

A denunciação da lide tem por finalidade o julgamento, no mesmo processo, da demanda principal, na qual o denunciado figura como litisconsorte do denunciante, assim como da demanda regressiva e eventual que é exercida pelo denunciante contra o denunciado. Fala-se em demanda eventual porque a denunciação só será apreciada se o denunciado perder a principal.

Transportando o conceito para a hipótese em análise, tem-se que o quinhoeiro, ao ser citado na demanda vindicatória ou indenizatória, deverá denunciar a lide aos demais condôminos. Isso significa que todos os comproprietários atuarão em litisconsórcio contra o confinante autor. Se o quinhoeiro originalmente citado for derrotado pelo confinante, será apreciada a demanda regressiva que constitui a denunciação da lide, a fim de que ocorra compensação pela restituição ou pagamento de indenização. Julgada procedente a demanda regressiva, poderá o quinhoeiro que fora derrotado pelo confinante promover desde logo a execução da sentença.⁹⁵

Se o confinante tiver proposto demanda indenizatória, a sentença proferida na ação regressiva permitirá o cumprimento de sentença (CPC/2015, art. 513 e ss.). Serão permitidas medidas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC/2015⁹⁶, de modo que o juiz não estará restrito à execução por sub-rogação⁹⁷.

Se tiver sido ajuizada demanda vindicatória, o quinhoeiro, que sofreu redução em seu terreno em virtude da sentença proferida em embargos de terceiro, não poderá ser compensado apenas

por meio de pecúnia. Poderá requerer a penhora e adjudicação de frações dos terrenos dos demais condôminos que permitam compensação proporcional à redução de seu quinhão.

Evidentemente não caberá qualquer compensação se o ataque à propriedade do confinante decorrer de equívoco exclusivo na demarcação de determinado quinhão. Nesse caso, os demais quinhoeiros não são beneficiados pela usurpação, que decorre de erro específico em relação a um quinhão determinado.

Ainda no tocante ao direito de regresso, sublinhe-se que o art. 572, § 2.º, refere-se aos sucessores universais dos condôminos que participaram da demanda divisória. Não estão incluídos, portanto, os sucessores a título singular. A boa-fé do adquirente – sucessor singular – impede que ele sofra a ação de regresso. Note-se que a aquisição do quinhão ocorre depois da divisão. Inexistindo demanda indenizatória ou vindicatória à época da alienação, não seria justo, nessas circunstâncias, que o adquirente respondesse em ação de regresso.⁹⁸

Art. 573. Tratando-se de imóvel georreferenciado, com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial.

1. Imóvel georreferenciado e dispensa de prova pericial

Atento aos avanços tecnológicos, o Código permite, no art. 573, a dispensa da prova pericial quando houver averbação do georreferenciamento no registro de imóveis. A disposição é salutar, pois permite economia de tempo em proveito das partes e do próprio Judiciário.

O georreferenciamento ao Sistema Geodésico Brasileiro está previsto no art. 167, §§ 2º e 3º, da Lei 6.015/1973.⁹⁹ Trata-se de inserção decorrente da Lei 10.267/2001, publicada em 29 de agosto de 2001, com vigência na mesma data.

De acordo com os dispositivos citados, o “desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais” será obtido mediante memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Para a transferência de imóveis rurais também é exigido o georreferenciamento, conforme consta no art. 167, § 4.º, da Lei de Registros Públicos.

O georreferenciamento permite, portanto, que se descreva com exatidão os limites entre os imóveis rurais, razão pela qual a prova pericial, nesse caso, deixa de ser necessária, por expressa disposição do art. 573 do CPC/2015.

2. Produção de prova pericial apesar do georreferenciamento

Assinala-se a possibilidade de que a prova pericial seja necessária apesar do georreferenciamento. Isso ocorrerá, conforme afirma Humberto Theodoro Jr., quando a divergência entre os títulos dominiais dos confrontantes tornar o georreferenciamento insuficiente ou quando estiverem apagados os marcos nele constantes. Nesses casos, deverá ser produzida prova pericial.¹⁰⁰

Seção II Da demarcação

Art. 574. Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.

1. Títulos de propriedade e designação do imóvel

O dispositivo em análise é reprodução substancial da regra contida no art. 950 do CPC/1973. Nos comentários ao art. 569, I, já foi visto que a legitimidade ativa para a propositura da demanda demarcatória é titularizada pelo proprietário, o nu-proprietário, o enfiteuta e o senhorio direto, o

promissário comprador,¹⁰¹ bem como os condôminos (CPC/2015, art. 575), que proprietários são.

O art. 574 exige que acompanhem a inicial os títulos de propriedade, a fim de que seja constatada a legitimação ativa do autor. Trata-se de documentos indispensáveis à propositura da demanda (CPC/2015, art. 320¹⁰²), de modo que sua falta ensejará o indeferimento da inicial (CPC/2015, art. 321¹⁰³) se o autor, instado a emendar a peça, apresentando os títulos dominiais, permanecer omissos. Saliente-se que não é admissível o indeferimento direto, sem que tenha sido concedido prazo para a juntada dos documentos. Assim, se o juiz constatar que a inicial não veio acompanhada dos títulos de domínio, deverá conceder ao autor o prazo de quinze dias para emendá-la. Apenas se permanecer inerte, deixando transcorrer em aberto esse prazo, deverá o juiz indeferir a inicial.

Se a demanda tiver sido proposta por um dos condôminos, constituir-se-á litisconsórcio ativo necessário. Nesse caso, basta que um dos condôminos apresente os títulos de domínio para que seja cumprida a exigência do art. 574. Caracterizado o litisconsórcio no polo ativo, seria formalismo desarrazoado exigir que o promovente da demanda, e só ele, juntasse aos autos os títulos de domínio. O que interessa é o cumprimento do disposto no art. 574, para que se possa aferir a legitimidade ativa do demandante.

Ao promovente caberá descrever o imóvel pela sua situação e denominação. Assim, deverá indicar pormenorizadamente o endereço completo e a denominação do bem, a fim de que seja determinado com precisão o imóvel demarcando.¹⁰⁴ A descrição insuficiente também ensejará a inépcia da inicial se o autor, instado a completá-la, omitir-se.

2. Descrição dos limites por constituir, aviventar ou renovar

O dispositivo em análise exige a descrição dos limites a demarcar, aviventar ou renovar. A exigência de que o autor apresente a linha demarcanda foi objeto de polêmica sob o Código revogado e merece algumas considerações.

Afirma-se, por um lado, que não pode recair sobre o autor o ônus de descrever a linha de confrontação, pois muitas vezes ele promove a demanda precisamente por desconhecê-la.¹⁰⁵ Assim, quando o objeto da demanda fosse precisamente a constituição de limites, caberia ao autor descrever detalhadamente a área sob litígio, sendo dispensável a indicação da linha de confrontação, pois não seria razoável determinar a descrição, já na inicial, de limites que só serão obtidos com o encerramento do processo.¹⁰⁶

Por outro lado, alega-se que o autor deve indicar já na inicial a linha divisória que considera correta, a fim de que a exordial contenha elementos para a manifestação dos réus e orientação do juiz, pois seria inaceitável deixar de indicar os pontos confusos na delimitação entre os imóveis, deixando ao livre talante do agrimensor o levantamento da linha.¹⁰⁷ A irresignação do autor com a indeterminação da linha demarcatória lhe imporia o ônus de indicar qual seria a delimitação mais adequada, de modo que, ainda quando a demanda fosse proposta precisamente para a constituição de limites, caberia ao autor apontar a conformação que eles deveriam apresentar.¹⁰⁸

Crê-se que seja imprescindível a apresentação, na petição inicial, da linha de confrontação que o autor entende como adequada. Ainda que ele tenha dúvida sobre a correção do traçado, deverá indicar a delimitação que lhe parecer correta à luz do título de propriedade.¹⁰⁹ Jurisprudência majoritária, erigida sob o Código revogado, reconhecia a necessidade de indicação dos limites na inicial.¹¹⁰

A questão se torna ainda mais complexa quando o título de propriedade for omissos na indicação das extremas. Nesse caso, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro sustenta que não seria exigível o apontamento da linha demarcatória na inicial, em razão da falta de elementos hábeis a delimitá-la. Caberia aos peritos obter as informações necessárias para a demarcação, valendo-se das prerrogativas que lhes são outorgadas.¹¹¹

É certo que haverá situações nas quais os títulos de propriedade serão omissos ou lacunosos, o que tornará mais difícil a indicação da linha divisória pelo autor. Todavia, mesmo nesse caso ele deve apresentar a confrontação que lhe parece mais adequada. A delimitação correta só será obtida por meio da perícia. Mas poderá o autor, da mesma forma que os peritos, consultar confinantes e antigos proprietários, a fim de definir a linha que lhe parece correta. O relaxamento da exigência, nesse caso, permitiria, por identidade de argumento, que o autor deixasse de indicar a linha de confrontação sempre que tivesse dúvida sobre o traçado. Em última análise, isso significaria que o autor estaria eximido de apresentar os limites sempre que alegasse dúvida, mesmo quando seus questionamentos pudessem ser facilmente dirimidos pela consulta aos títulos de propriedade.

Sustenta-se, em resumo, que a exigência do Código é correta e bem posta. O autor tem o ônus de apresentar a linha demarcatória que considera correta. É essa linha, a propósito, que ele pretende fazer prevalecer e sobre a qual controverterá em juízo. Isso não significa que sejam precisos os limites entre os imóveis. Se forem, sequer haverá interesse processual no ajuizamento de demanda para o estabelecimento dos limites. Quando muito, o interesse do autor, nesse caso, limitar-se-á à aviventação de marcos, pois os limites são conhecidos.

Não se pode confundir a demarcação com a ação reivindicatória. Nesta o autor conhece o traçado do imóvel e aponta com exatidão a fração que lhe foi usurpada. Não é o que ocorre na demarcatória, em que existe dúvida sobre os limites a constituir. Mas desde logo, apesar da incerteza, o autor deve indicar a linha de confrontação que lhe parece mais correta. Sua omissão enseja o indeferimento da petição inicial se, instado pelo juiz a emendá-la, indicando o traçado que entende correto, deixar de fazê-lo (CPC/2015, art. 321, *caput* e parágrafo único, c/c art. 9.º). Ou seja, não poderá ser decretada a inépcia da inicial sem a concessão de prazo para que o autor promova a emenda.

Em relação à linha, não poderá o autor realizar cumulação alternativa eventual, a fim de que prevaleça traçado secundário, caso o juiz não defira a linha demarcatória considerada como a mais correta. Incumbe-lhe apontar a linha mais apropriada à luz dos títulos e demais informações coligidas, sendo impertinentes quaisquer considerações e pedidos a respeito de traçado alternativo.¹¹² Seria incoerente a cumulação alternativa, ainda que em caráter eventual, pois só pode haver um traçado correto.

3. Interesse processual

O interesse processual do autor tem como premissa a contiguidade entre os imóveis. Se entre eles houver via pública a demanda demarcatória não será cabível. Do mesmo modo, a existência de acidente geográfico a separar os terrenos também inviabilizará a demarcação, a não ser que o autor justifique sua dúvida. Por outro lado, a mera existência de tapumes não será obstáculo ao processamento e acolhimento da pretensão de demarcar. Para a análise desses temas com maior profundidade, indica-se a leitura dos comentários ao art. 569.

4. Citação dos confinantes e litisconsórcio passivo necessário

O art. 574 exige ainda a “nomeação” dos confinantes. Indiscutivelmente deve o autor qualificá-los, pois serão réus na demanda demarcatória. É por sua legitimidade passiva que devem ser “nomeados”. Disso resulta que há mais do que simples nomeação, há qualificação e citação (CPC/2015, art. 576) de todos os confinantes para que integrem o processo. Constitui-se litisconsórcio passivo necessário. Desse modo, seria mais adequado que o dispositivo se referisse à necessária citação dos confinantes, em vez da sua simples nomeação.¹¹³

Caso seja proposta ação demarcatória parcial, cujo objeto se limite a parte da linha de confrontação, não será necessária a citação de todos os confrontantes, mas apenas daqueles cujos imóveis fizerem divisa com o imóvel demarcando.¹¹⁴

Tratando-se de demanda dúplice, na qual as posições de autor e réu são intercambiáveis, se um

dos confinantes apresentar linha de confrontação diferente em sua contestação, essa proposta equivalerá a pedido para que prevaleça a delimitação então apresentada. Ademais, poderão os confinantes alegar a desnecessidade de delimitação, pois são conhecidos e indiscutíveis os limites entre os imóveis.

5. *Foro competente*

Obviamente, além das exigências elencadas no art. 574, consistentes nos requisitos específicos da petição inicial da demanda demarcatória, o autor deverá cumprir os requisitos gerais, válidos para qualquer exordial, indicados no art. 319 do CPC/2015,¹¹⁵ à exceção do disposto no inc. VII,¹¹⁶ pois a audiência de conciliação e de mediação, prevista no art. 334, não é realizada nas ações demarcatórias, conforme apontado nos comentários aos arts. 577 (item 3) e 578 (item 2).

Incumbe ao autor endereçar a petição para o juízo competente (CPC/2015, art. 319, I). Tratando-se de imóvel localizado no Brasil, a competência recai exclusivamente sobre os órgãos judiciários brasileiros, como resultado nítido do art. 23, I, do CPC/2015.¹¹⁷

Segundo o art. 47, *caput* e § 1.º, do CPC/2015,¹¹⁸ é competente o foro de situação da coisa para o processamento e julgamento das ações demarcatórias. Trata-se, como já visto alhures, de consequência da caracterização dessas demandas como reais e imobiliárias. Caso o imóvel se situe em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento compreenderá todo o imóvel (CPC/2015, art. 60¹¹⁹). Como a competência é determinada em razão da matéria, caso o imóvel, ao longo da tramitação, venha a integrar outra comarca em virtude de modificação na competência territorial, será competente o juízo da comarca à qual o imóvel passou a pertencer.¹²⁰

A competência recairá sobre a Justiça Estadual, a não ser que haja interesse da União, empresas públicas ou autarquias federais, o que ocorrerá sempre que um dos entes públicos indicados for confinante do imóvel demarcando.¹²¹

6. *Valor da causa*

Como já dito, além de atender ao disposto no art. 574, deverá o autor cumprir os requisitos genéricos de toda petição inicial, previstos no art. 319 do CPC/2015. Assim, ao propor a demanda demarcatória, o autor deverá indicar o valor da causa. Conquanto haja orientação expressa a respeito, constante no art. 292, IV, o tema traz alguns questionamentos.¹²²

De acordo com o direito positivo, o valor dado à causa nas ações de demarcação deverá corresponder ao valor da avaliação da área. Houve, aqui, modificação redacional em relação ao Código anterior, cujo art. 259, VII, indicava como critério “a estimativa oficial para lançamento do imposto”. Apesar da mudança redacional, o valor venal segue ainda como critério para a valoração da causa.¹²³ Seria excessivo e desarrazoado formalismo exigir que antes da propositura da demanda a parte avaliasse o imóvel. Essa avaliação, ademais, poderia subestimar propositalmente o valor do bem, de modo que o valor venal continua sendo critério objetivo e seguro para a atribuição do valor da causa. Se o valor venal for excessivo, não refletindo o preço de mercado do imóvel, o autor poderá então se valer de laudos extrajudiciais.

Como o legislador definiu um critério, torna-se inadequado substituí-lo pelo proveito econômico, o qual seria de difícil mensuração. Questiona-se, ainda, se o valor deveria ser atribuído proporcionalmente quando se tratasse de demarcação parcial. Todavia, levando-se em conta as dificuldades para a definição do proveito econômico, assim como para o estabelecimento de proporção na demarcação parcial, crê-se que o mais adequado seja a valoração da causa em consonância com a estimativa para cobrança do IPTU, tratando-se de imóvel urbano, ou do ITR, cuidando-se de imóvel rural.¹²⁴

7. *Cumulação de pedidos*

O CPC/1973, no art. 951, permitia expressamente que o autor cumulasse a demarcação com a reintegração de posse, possibilidade que recebeu duras críticas da doutrina, à medida que o pedido demarcatório já abrange o de restituição da área invadida, de modo que a cumulação seria desnecessária.¹²⁵

O Código vigente não reproduz dispositivo semelhante ao art. 951, opção que se deve aplaudir, pois a procedência da demarcatória já enseja a restituição da área invadida, com a declaração da posse, conforme consta expressamente no art. 581, parágrafo único. Apesar da falta de previsão legal e da inquestionável possibilidade de restituição em decorrência do acolhimento do pedido de demarcação, voz autorizada da doutrina defende a possibilidade de cumulação sob o Código atual.¹²⁶

A mesma razão que inviabiliza a cumulação do pedido demarcatório com o possessório também impede que se apresente pedido reivindicatório no âmbito do processo de demarcação. Como a sentença demarcatória já possibilita a restituição da área invadida, “declarando o domínio ou a posse do prejudicado” (CPC/2015, art. 581, parágrafo único), não há necessidade de apresentar o pedido reivindicatório, razão pela qual, em relação a ele, inexistente interesse processual.

Será possível cumular outras demandas à demarcação, o que ficava claro no art. 951 do Código revogado, que admitia expressamente a cumulação com os pedidos de reintegração de posse ou de indenização decorrente da usurpação do imóvel.

À medida que a sentença demarcatória permite a restituição da área invadida, o autor poderá formular pedido indenizatório, para a apuração das perdas e danos decorrentes da ocupação indevida do imóvel, apesar de inexistir disposição expressa autorizando-o a tanto. Será possível, por exemplo, postular indenização pelos frutos percebidos pelo confinante que exerceu a posse de má-fé, consciente de que invadiu a propriedade de seu vizinho. Sublinhe-se que o caráter especial do procedimento de demarcação não inviabiliza a referida hipótese de cumulação, respaldada pelo art. 578, que prevê a aplicação do procedimento comum na primeira fase do processo demarcatório após o prazo para resposta.

Não se pode supor que o art. 570 do CPC/2015, ao prever a cumulação das ações demarcatória e divisória, proíba que à demarcação sejam cumulados outros pedidos. O que se pretendeu ao positivar o cúmulo da divisão com a demarcação foi evitar que prevalecesse o posicionamento doutrinário vigente nas primeiras décadas do século passado, que rejeitava essa possibilidade.¹²⁷ Isso obviamente não significa que estejam proibidas outras cumulações.

A propósito do tema, o art. 327, § 2.º, do CPC/2015 admite a cumulação entre pedidos submetidos a procedimentos especiais e aqueles que são processados em conformidade com o procedimento comum, desde que o autor opte por este, não ficando prejudicadas as técnicas diferenciadas que não forem procedimentalmente incompatíveis.

Ocorre que em sua primeira etapa a demanda demarcatória tramita pelo procedimento comum após o prazo para resposta (CPC/2015, art. 578), inexistindo qualquer óbice à referida cumulação.¹²⁸ Assim, desde que cumpridas as demais exigências elencadas no art. 327, válidas para todas as hipóteses de cumulação, ao pedido de demarcação poderá ser cumulado qualquer outro que com ele seja compatível, como o de indenização ou o de nulidade de título dominial do confrontante.¹²⁹

Art. 575. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo, intervir no processo.

1. Legitimidade ativa do condômino

Já se viu que os proprietários serão legitimados ativos para o ajuizamento da demarcatória. O conceito de proprietário, para fim de legitimidade ativa na demarcação, abrange ainda o nu-proprietário, o enfiteuta e o senhorio direto, bem como o promissário comprador. Assim,

considerando a indiscutível qualidade de comproprietário, evidentemente qualquer condômino está legitimado a promover a demanda para a delimitação do imóvel. Poderá, ainda, cumulá-la com a divisão, conforme expressa previsão do art. 570 do CPC/2015.

2. Intimação dos demais condôminos e litisconsórcio ativo necessário

No processo civil vigora a regra de que ninguém é obrigado a provocar o Poder Judiciário. Em outras palavras, ninguém pode ser constrangido a acessar a justiça. Precisamente por isso sempre foi controversa a figura do litisconsórcio ativo necessário. Mas ela existe e encontra exemplo no art. 575 do CPC/2015. Ao propor a demanda, deverá o autor intimar os demais condôminos, para que intervenham no processo. O Código revogado (art. 952) era expresso ao assinalar a formação de litisconsórcio ativo necessário, o que fazia por meio da locução “citando-se os demais como litisconsortes”. Embora não haja idêntica proposição no art. 575, o caráter necessário do litisconsórcio é indiscutível.

Para maior esclarecimento sobre o que foi afirmado, convém distinguir o litisconsórcio necessário do unitário. Haverá necessidade quando a relação jurídica material impuser, no plano do processo, que mais de um sujeito figure em um dos polos da demanda a fim de que a sentença seja eficaz, conforme se depreende do art. 114 do CPC/2015.¹³⁰

Pense-se, por exemplo, na conhecida hipótese de anulação de casamento ajuizada pelo Ministério Público (CC, art. 1.549). Não é possível que figure no polo passivo apenas o marido ou somente a esposa. O litisconsórcio é necessário. Como a sentença haverá de nulificar o matrimônio, obviamente esse efeito jurídico não se limitará a um dos cônjuges, razão pela qual, além de necessário, o litisconsórcio é também unitário, em razão da imprescindível uniformidade de tratamento, decorrente da incidência da relação jurídica.¹³¹ Há unitariedade, na dicção do art. 116 do CPC/2015, quando a decisão de mérito tiver de ser uniforme para os litisconsortes.¹³²

Imagine-se, agora, o que ocorre em uma demanda de usucapião. Embora seja necessário trazer ao processo o proprietário e todos os confinantes (CPC/2015, art. 246, § 3.º¹³³), é perfeitamente possível que não ocorra tratamento uniforme em relação a eles. De fato, pode ser que um dos confinantes sucumba, sendo reconhecida contra ele a procedência da usucapião. Mas isso não necessariamente ocorrerá com os demais confinantes, que poderão manter suas propriedades tal como estavam antes da propositura da demanda de usucapião, de modo que nesse caso o litisconsórcio é necessário, mas não unitário.

No que toca à ação demarcatória, é possível que não haja unanimidade entre os comproprietários sobre a linha demarcanda. Também pode ser que um dos condôminos reputa não haver dúvidas sobre os limites do imóvel. Mas isso não elide o caráter necessário do litisconsórcio, nem sua unitariedade.¹³⁴ Com efeito, a unitariedade do litisconsórcio se relaciona com o tratamento uniforme concedido pelo provimento jurisdicional aos litisconsortes, em situações nas quais a relação jurídica entre eles, os litisconsortes, não pode ser cindida. Ora, a relação entre os condôminos é incindível e a linha demarcatória obviamente será a mesma para todos, de modo que a unitariedade do litisconsórcio entre os comproprietários, na ação demarcatória, é indiscutível.¹³⁵

Art. 576. A citação dos réus será feita por correio, observado o disposto no art. 247.

Parágrafo único. Será publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259.

1. Citação pelo correio

Prevvia-se no Código revogado (art. 953) que seria pessoal a citação dos réus que residissem na comarca, ocorrendo a dos demais por edital. Essa diferença no tratamento entre os confinantes foi objeto de críticas contundentes.¹³⁶ Com efeito, à medida que o autor poderia escolher o foro competente quando o imóvel se situasse em mais de uma comarca, seria possível propor a demanda demarcatória naquela que tivesse o número menor de confinantes, deixando que a

maioria fosse citada por edital. Seria possível, portanto, escolher quais confinantes seriam citados pessoalmente.

Considerando que a citação por edital tem alcance prático questionável, já que pouquíssimas pessoas acessam e leem os editais, indiscutivelmente poderia a demarcatória prejudicar alguns confinantes. Quando menos, tratava-se desigualmente jurisdicionados na mesma situação, mediante critério aleatório e injustificável, o que caracterizava flagrante inconstitucionalidade. Para tornar mais segura a participação dos confinantes, em consonância com a segurança jurídica que deve presidir o processo, o Código vigente traz modificação relevante sobre o tema, prevendo a citação pessoal, pelo correio, de todos os réus, residam ou não na mesma comarca. Há, quanto ao ponto, avanço elogiável, eis que tratados igualmente sujeitos que se encontram na mesma situação.

Também é digna de encômios a previsão de que a citação se realizará pelo correio. Ocorre que, situando-se alguns confinantes em outra comarca, poder-se-ia cogitar a necessidade de citação mediante carta precatória. O Código deixa claro que isso não será necessário.

Se o confinante for empresa pública ou privada, desde que não se trate de microempresa ou de sociedade empresária de pequeno porte, a citação poderá ocorrer de forma eletrônica, na forma prevista pelo art. 246, § 1.º.¹³⁷ Trata-se a citação eletrônica de forma mais célere que a realizada pelo correio, portanto, está em conformidade com o direito à duração razoável do processo, consagrado no art. 4.º do CPC¹³⁸ e no art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988.¹³⁹

Como já assinalado nos comentários ao art. 569, I, em consequência da caracterização da ação demarcatória como real e imobiliária, impõe-se a formação de litisconsórcio passivo entre os cônjuges, ressalvada a hipótese de casamento em regime de separação absoluta de bens.¹⁴⁰

2. Publicação de edital

No art. 576, parágrafo único, é prevista a *publicação* de edital em conformidade com o disposto no art. 259, III. O dispositivo em exame não trata da citação por edital. É cediço que a citação editalícia deverá ocorrer quando o réu for desconhecido ou incerto, bem como nas hipóteses em que ignorado, incerto ou inacessível o lugar no qual se encontre ou, ainda, quando prevista em lei. É o que resulta do art. 256, I a III, do CPC/2015.¹⁴¹

O art. 576, parágrafo único, determina a *publicação* de edital a fim de que participem do processo interessados incertos ou desconhecidos, nos termos do art. 259, III.¹⁴² Trata-se de providência louvável que procura assegurar a mais ampla participação na demanda demarcatória, não se relacionando, reitere-se, com a citação por edital, que deverá ocorrer sempre que presentes as hipóteses descritas no art. 256, I a III.

Art. 577. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 (quinze) dias para contestar.

1. Prazo para resposta

Nos termos do art. 577, após a citação os réus terão o prazo comum de quinze dias para apresentar resposta. Houve, também aqui, modificação em relação ao que dispunha o Código revogado, cujo art. 954 definia o prazo de vinte dias. Ao afirmar que o prazo é comum, o dispositivo salienta a impossibilidade de que a contagem ocorra na forma dobrada prevista no art. 229.¹⁴³ Será irrelevante, portanto, para a definição do prazo, que os réus tenham advogados diferentes, integrantes de escritórios de advocacia distintos. Sempre será de quinze dias o prazo para responder.

2. Início da contagem do prazo

Como a citação se realiza pelo correio (CPC/2015, art. 576), o prazo para responder será contado

a partir da juntada aos autos do último mandado citatório cumprido, conforme assinala o art. 231, I, do CPC/2015.¹⁴⁴ Frustrada a citação pelo correio, o ato citatório deverá ser cumprido mediante oficial de justiça, conforme assenta o art. 249.¹⁴⁵ Nesse caso, obviamente, a contagem do prazo começará a partir da juntada aos autos do mandado citatório.¹⁴⁶ Realizando-se a citação por edital, o prazo será contado no dia útil seguinte ao fim da dilação concedida pelo juiz (CPC/2015, art. 231, IV¹⁴⁷).

Tratando-se de citação eletrônica (CPC/2015, art. 246, § 1.º), plenamente aplicável às ações demarcatórias, o prazo para responder será contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou do dia útil seguinte ao término do prazo para a consulta, conforme dispõe o art. 231, V, do CPC/2015.¹⁴⁸ Poder-se-ia entender que quando não houvesse consulta ao ato citatório a contagem se iniciaria “ao término do prazo para que a consulta se dê”. Essa interpretação é equivocada. Para a compreensão do dispositivo não se pode esquecer da locução “o dia útil seguinte”, aplicável tanto quando ocorrer consulta ao ato citatório quanto quando essa consulta não acontecer e escoar o prazo. Em resumo, o início da contagem do prazo para responder sempre ocorrerá no dia útil seguinte, qualquer que seja a hipótese em que incida o art. 231, V, do CPC/2015.¹⁴⁹

3. Resposta: contestação e reconvenção

Ao contestarem a demarcatória os réus poderão articular, preliminarmente, as matérias indicadas no art. 337 do CPC/2015, I a XIII. Assim, incumbe-lhes, antes de apresentar as questões concernentes ao mérito, invocar a inexistência ou nulidade de citação, a incompetência absoluta, a incorreção do valor da causa, a inépcia da petição inicial, a perempção, a litispendência, a coisa julgada, a conexão, a incapacidade da parte, o defeito de representação ou a falta de autorização, a estipulação de convenção de arbitragem, a falta de legitimidade ou de interesse processual, a ausência de prestação que a lei exija como preliminar, assim como a concessão indevida da gratuidade da justiça.

No que se refere aos requisitos processuais, o autor não terá interesse processual quando propuser a demarcatória sem que haja contiguidade, tal como ocorreria quando os imóveis fossem separados por um rio ou uma rodovia.¹⁵⁰

Também não haverá interesse processual se o autor deixar de invocar confusão sobre os limites entre os imóveis. Em outras palavras, para pleitear a restituição de parcela do imóvel que lhe tenha sido subtraída, deve o demandante ajuizar a ação reivindicatória, não a demarcatória.¹⁵¹ Não se pode perder de vista que o fundamento da demarcatória é a confusão sobre a linha de demarcação, de modo que se os limites forem conhecidos pelo autor, a ele cabe reivindicar o imóvel usurpado, ou, ainda, pleitear a reintegração de posse. Não há interesse processual na demarcação, pois o próprio autor alega conhecer os limites do imóvel, de modo que a demarcatória não é a demanda adequada para a resolução do litígio.

Caso o objeto da demarcatória seja terra devoluta, também inexistirá interesse processual, cabendo no caso a demanda discriminatória prevista na Lei 6.383/1976. O óbice, aqui, decorre do próprio ordenamento jurídico, que prevê a demanda demarcatória somente para a divisão de terras particulares..

Como já dito, se as circunstâncias caracterizadoras da falta de interesse forem identificadas na inicial, o juízo ouvirá o autor e, a persistir o desinteresse, indeferirá a inicial (CPC, art. 330, inc. III). Se apenas na instrução esses fatos ficarem evidenciados, a primazia do mérito (CPC, arts. 4º e 488) determina a improcedência da demanda.

O réu também poderá invocar a ilegitimidade ativa ou passiva *ad causam*. Será parte ilegítima para figurar no polo passivo quando não for confinante. O demandante, por sua vez, não terá legitimidade quando não titularizar o direito real capaz de ensejar a ação demarcatória.¹⁵² Quanto à legitimidade ativa, se a não titularização de direito real autorizador da demarcatória se evidenciar na inicial, o juízo ouvirá o autor e indeferirá a inicial se a legitimidade ativa não se

evidenciar. No tocante à legitimidade passiva, o réu poderá indicar terceiro para figurar no processo, havendo substituição ou inclusão como litisconsorte (CPC, art. 339, §§ 1º e 2º). Se apenas depois da instrução ficar caracterizado que o réu não é confinante, a primazia do mérito impõe a prolação de sentença extintiva, julgando a pretensão improcedente em relação a ele (CPC, arts. 4º e 488).

Quanto ao mérito, os réus poderão alegar a desnecessidade de demarcação, invocando a inexistência de confusão sobre a linha demarcatória. Podem propor linha de confrontação diversa da que foi apresentada pelo demandante na inicial. Ser-lhes-á possível, ainda, afirmar a usucapião sobre a área demarcanda, do que resultaria a perda de propriedade do autor ou o fim da confusão sobre as extremas.¹⁵³

Foi mencionado que haverá perda de interesse processual quando o *autor* ajuizar a demanda demarcatória reconhecendo a existência de limites. Esta afirmação não contradiz a ideia de que haverá questão de mérito quando o *réu* alegar ausência de confusão de limites. O objetivo da primeira etapa da ação demarcatória é definir a linha de confrontação. Se isso não for necessário, a demanda deve ser julgada improcedente. Ocorre que, se o próprio autor reconhecer que não há confusão sobre os limites da propriedade, ele não terá interesse processual em ajuizar a demarcatória. Caber-lhe-á propor ação reivindicatória ou de reintegração de posse. As situações não se confundem.¹⁵⁴

A alegação de usucapião merece maiores considerações. Há muito se reconhece a possibilidade de se invocar a prescrição aquisitiva como matéria de defesa, tema cristalizado na Súmula 237 do STF.¹⁵⁵ No âmbito interno do processo, o prazo para alegar prescrição é a resposta. Se não o fizer, ter-se-á operado preclusão, conforme reconhecia a jurisprudência que sobre o tema se pronunciara à época de vigência do CPC/1973.¹⁵⁶

Ocorre que o acolhimento da alegação de usucapião na contestação, *exclusivamente como matéria de defesa*, inviabilizará a demarcação, mas não permitirá a obtenção de título dominial pelo réu.¹⁵⁷ Com efeito, vários cuidados cercam a ação de usucapião de imóvel, como a necessidade de citação pessoal de todos os confinantes (CPC/2015, art. 256, § 3.º) e a publicação de editais (CPC/2015, art. 259, I¹⁵⁸). Em vista disso, a simples alegação da prescrição aquisitiva como matéria de defesa não poderá ensejar a aquisição da propriedade pelo réu, conforme reconhecia a jurisprudência erigida perante o Código revogado.¹⁵⁹ Sublinhe-se que a possibilidade de usucapião extrajudicial, prevista no art. 1.071, que insere o art. 216-A na Lei de Registros Públicos, não altera o enquadramento do tema.

Mas a questão ainda merece uma observação. Mencionou-se que, quando alegada a usucapião como simples matéria de defesa, não será possível a transmissão da propriedade. Isso é correto. Cabe verificar se o réu poderia reconvir, a fim de obter o reconhecimento da propriedade e sua transferência no Registro de Imóveis por meio da reconvenção.

Primeiramente, é preciso afirmar o cabimento da reconvenção no âmbito da demarcatória, conforme reconhecia a doutrina sob o CPC/1973.¹⁶⁰ A propósito, o art. 578 do Código vigente, ao se referir a prazo para *resposta*, em vez de prazo para *contestação*, indica com clareza a possibilidade de que o réu reconvenha. Evidentemente não haverá interesse processual em reconvir para apresentar linha de confrontação diversa, pois neste caso bastará contestar. O caráter dúplice das demandas demarcatórias permite que a contestação sobre os limites equivalha a pedido para que seja reconhecida a linha de confrontação sugerida pelo réu. Mas é admissível, como já dito, que o réu reconvenha formulando outras pretensões, dentre as quais figuram os pedidos de indenização por percepção de frutos pelo possuidor injusto e a usucapião. A reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC/2015, deve ser formulada na própria contestação.

Quando reconvém, o réu exerce pretensão contra o autor. Se reconvier, adotando as providências que seriam exigidas em uma demanda de usucapião, como a citação pessoal de todos os confinantes (CPC/2015, art. 256, § 3.º), a publicação de editais (CPC/2015, art. 259, I), a cientificação da União, Estado, Distrito Federal e Municípios (Lei de Registros Públicos, art. 216-A, § 3.º, em aplicação analógica) e a intimação do Ministério Público, em sendo o caso (p. ex.: usucapião

especial, conforme art. 5.º, § 5.º, da Lei 6.969/1981, art. 178, I a III, do CPC/2015), a propriedade poderá ser reconhecida em favor do réu, propiciando a modificação de matrícula para que lhe seja oportunizada a transferência.¹⁶¹

A razão pela qual a alegação da prescrição aquisitiva como matéria de defesa é inservível para a transmissão de propriedade em favor do réu radica na necessidade de que sejam adotadas as cautelas que cercam o pedido de usucapião. Ademais, a contestação não encerra um pedido. Como a premissa para que possa haver transferência da propriedade, inclusive com retificação das matrículas, é o cumprimento das exigências de uma demanda de usucapião, tem-se que, se forem cumpridas essas exigências, poderá ser reconhecida a propriedade ao reconvinte, cuja reconvenção encerra um pedido, tal como se tivesse ocorrido propositura de uma demanda autônoma. Assim, proposta a reconvenção, o réu não precisará ajuizar uma demanda específica para o reconhecimento de propriedade por usucapião, desde que, obviamente, os requisitos da prescrição aquisitiva tenham sido cumpridos.

Esse posicionamento facilita o acesso à justiça, evitando que tramite demanda de usucapião posterior para declarar situação fática que já fora reconhecida em demanda anterior, no caso, a demarcatória. Parece mesmo não haver sentido, quando se defende a celeridade da prestação jurisdicional e se combate com afincos a morosidade, determinar que o réu, que cumpriu todos os requisitos de uma ação autônoma de usucapião e reconveio, seja obrigado a ajuizar demanda autônoma para só então obter o que o judiciário já lhe concedera: o reconhecimento de propriedade sobre determinada área.

O fundamental, repita-se, é que a reconvenção cumpra os requisitos que seriam exigidos em uma demanda autônoma de usucapião. Isso feito, a propriedade poderá ser declarada em favor do réu reconvinte.

A usucapião é prejudicial em relação à demarcação, o que traz a óbvia consequência de que terá de ser apreciada antes da demarcatória. Se houver ajuizamento de demanda de usucapião autônoma, a tramitar perante outro juízo, ocorrerá hipótese de prejudicialidade externa, podendo ser suspenso o processo de demarcação por até um ano.¹⁶² Se ambas as demandas tramitarem perante o mesmo juízo, a conexão entre elas permitirá que sejam resolvidas conjuntamente, ocasião na qual, reitere-se, primeiramente deverá ser decidida a ação usucapional.¹⁶³

Sublinhe-se, por fim, que será irrelevante a alegação sobre prescrição extintiva, pois as demandas demarcatórias, como já visto, são imprescritíveis. Enquanto perdurar a confusão sobre limites a ação poderá ser ajuizada. O que poderá ocorrer é a prescrição aquisitiva, jamais a extintiva.

O art. 578 assinala que após o prazo de resposta será observado o procedimento comum, de modo que não há necessidade de realização da audiência prevista no art. 334 do CPC/2015, a qual deve ocorrer antes da resposta. Desse modo, o prazo para que o réu responda não será contado na forma preconizada pelo art. 335, I, CPC/2015.¹⁶⁴

Art. 578. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum.

1. Especialidade da demanda demarcatória

Alguns elementos traduzem o caráter especial da ação demarcatória. Em primeiro lugar, há um procedimento projetado em duas fases, sendo a primeira destinada à obtenção da linha de confrontação e a segunda à cravação dos limites no imóvel. A primeira etapa é encerrada pela sentença que determinará o traçado da linha de confrontação (CPC/2015, art. 581). Trata-se de provimento jurisdicional que não extingue o processo, servindo como passaporte para que se iniciem as atividades destinadas à delimitação do imóvel demarcando. O processo, em sua segunda fase, será encerrado pela sentença homologatória (CPC/2015, art. 587).

Ademais, na demanda demarcatória a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade

das alegações do autor, previsto no art. 344 do CPC/2015,¹⁶⁵ nem suscita o julgamento antecipado (CPC/2015, art. 355, II¹⁶⁶), pois o juiz, ressalvadas as hipóteses de imóvel georreferenciado (CPC/2015, art. 573) e de concordância de todos os réus com o traçado proposto pelo autor,¹⁶⁷ deverá determinar a produção de prova pericial antes de proferir a sentença que definirá a linha de confrontação (CPC/2015, art. 579)¹⁶⁸.

Destarte, a especialidade da demanda demarcatória consiste na existência de procedimento dividido em duas fases, cada uma delas encerrada por sentença. Além disso, na demarcatória a revelia não produz os efeitos de presunção de veracidade, cabendo ao juiz produzir prova pericial antes de proferir a sentença por meio da qual definirá a linha de demarcação.¹⁶⁹

2. Aplicação do procedimento comum

O art. 578 assinala que depois do prazo para resposta será adotado o procedimento comum. A redação é mais clara e precisa que a do art. 955 do Código revogado, que previa a adoção do “procedimento ordinário” se houvesse contestação, determinando o julgamento antecipado caso nenhum dos réus tivesse apresentado resposta. Ocorre que o CPC/1973 (art. 956), assim como faz o Código vigente (art. 579), exigia a produção de prova pericial antes que o juiz determinasse o traçado da linha de demarcação, de modo que não poderia ocorrer o referido julgamento antecipado.

A realização obrigatória de perícia é decorrência da especialidade procedimental da ação demarcatória. A prova pericial poderá ser dispensada apenas se se tratar de imóvel georreferenciado (CPC/2015, art. 573) ou se todos os réus anuírem com a delimitação apresentada pelo autor.

Como visto no item 3, dos comentários ao art. 577, não será realizada audiência de conciliação ou de mediação na demanda demarcatória. Ao dispor que o procedimento ordinário será aplicado somente depois do prazo para resposta, o art. 578 sinaliza inequivocamente a desnecessidade de realização do referido ato processual. Não ocorrendo a audiência, evidentemente o prazo para resposta não poderá ser contado na forma do art. 335, I, do CPC/2015.

Os traços caracterizadores da especialidade da ação demarcatória não impedem que sua tramitação na primeira fase, após o prazo para resposta, ocorra em conformidade com o procedimento comum, na forma determinada pelo Código. Com efeito, apenas a ineficácia da revelia, decorrente da imprescindibilidade de produção de prova pericial sobre a linha de confrontação (CPC/2015, art. 579), é técnica estranha ao procedimento comum.

Se houver cumulação entre os pedidos de demarcação e de indenização, a revelia não evitará a produção de prova sobre a linha demarcanda, nos termos do art. 579, mas o juiz poderá presumir a veracidade dos fatos que fundamentam o pedido indenizatório, desde que não se caracterize quaisquer das hipóteses que inviabilizam a presunção de veracidade (CPC/2015, art. 345). Nota-se uma vez mais que nada impede a cumulação entre os pedidos de demarcação e de indenização.

Referindo-se ao procedimento comum, o dispositivo em análise autoriza a realização do saneamento do processo em conformidade com os arts. 357 e ss. do CPC/2015, assim como a designação de audiência de instrução e julgamento (CPC/2015, art. 358 e ss). Isso significa que, além da prova pericial prevista no art. 579, poderão ser obtidas provas orais, assim como prova pericial diversa daquela destinada à obtenção da linha demarcatória.¹⁷⁰

Também poderá ocorrer julgamento antecipado parcial, nos termos do art. 356, I,¹⁷¹ quando houver incontrovérsia sobre parcela do pedido. É perfeitamente concebível que os réus concordem com parte da delimitação, considerando inapropriada somente parcela da linha demarcatória proposta pelo autor. Nesse caso, não há qualquer óbice ao julgamento antecipado parcial, mediante decisão interlocutória, a fim de que sejam reconhecidos os limites incontroversos. Note-se que o art. 356, *caput*, prevê a possibilidade de fracionamento do mérito quando a incontrovérsia recair sobre um dos pedidos cumulados ou sobre *parcela* do pedido.¹⁷² No

caso, tem-se por incontroversa parte do pedido de demarcação, circunstância a autorizar o julgamento antecipado, medida importante para que a questão sobre limites seja estabilizada no plano fático.

É digno de nota que apenas a hipótese prevista no art. 356, I, será aplicável. Ocorre que as regras do procedimento especial de demarcação exigem a produção de prova pericial (CPC/2015, art. 579) antes da determinação dos limites, o que inviabiliza a aplicação do art. 356, II¹⁷³, c/c o art. 355, I.¹⁷⁴ Como a produção de prova pericial é obrigatória – ressalvadas as hipóteses de imóvel georreferenciado e de concordância dos réus com a linha demarcatória traçada pelo autor – a revelia não caracterizará a presunção de veracidade das afirmações do autor, o que impede o julgamento antecipado parcial com fundamento no art. 356, II, c/c o art. 355, II.

Deve ser destacado que as decisões de julgamento antecipado parcial do mérito, conquanto sejam interlocutórias, fazem coisa julgada e se submetem à ação rescisória, como resulta nitidamente dos arts. 503¹⁷⁵ e 966¹⁷⁶, ambos do CPC/2015.

Não será aplicável o requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente (CPC/2015, art. 303) nem o regime de estabilização (CPC/2015, art. 304). Ocorre que a petição inicial da demanda demarcatória deve atender aos requisitos elencados no art. 574, de modo que não se concebe situação em que o autor pudesse requerer a antecipação de tutela por meio da petição inicial limitada, disciplinada no art. 303. Em resumo, não é possível harmonizar a exigência contida no art. 574 com o caráter sintético da petição disciplinada no art. 303. Mas isso não significa que não possa ser pleiteada tutela de urgência no âmbito da demanda demarcatória.

Não será possível que o autor requeira, em antecipação de tutela, a demarcação provisória do bem. É sabido que efeitos constitutivos não podem ser antecipados, sendo inaceitável que o juiz anule provisoriamente um contrato ou reconheça uma linha de confrontação provisória. Mas poderão ser antecipados outros efeitos da futura sentença de procedência, provimento jurisdicional capaz, nos termos do art. 581, parágrafo único, de restituir a área invadida.

Já se afirmou várias vezes que a premissa para a demanda demarcatória é a confusão sobre os limites entre os imóveis. Se o autor tiver pleno conhecimento sobre a linha de confrontação, não há interesse processual na demarcação, cabendo-lhe, se for o caso, propor demanda de reintegração de posse ou reivindicatória. É possível, na prática, que, apesar da dúvida sobre a exata localização da área de confrontação, o autor esteja certo sobre a invasão parcial de seu terreno. Como há confusão entre os limites, existe interesse processual na demanda demarcatória, cuja sentença, como visto, determinará a restituição do bem ao autor.

Todavia, estando certo do esbulho ou da turbção, poderá o autor promover a ação possessória pertinente, a fim de que ocorra tutela da posse em relação à área que indiscutivelmente lhe pertence.¹⁷⁷ Retenha-se o ponto: o emprego do interdito possessório se limita à fração do terreno sobre a qual não há dúvida a respeito da titularidade. A discussão sobre os limites não impede que se saiba que a partir de determinado marco a propriedade inequivocamente se inicia. Em outras palavras, desconhecer onde se situa a linha de confrontação, não impede o proprietário de promover ação possessória em relação à parcela do imóvel em que inexista dúvida sobre a titularidade.

Ademais, poderá o autor pleitear que lhe seja deferida tutela cautelar, a fim de evitar que se caracterizem danos irreparáveis. Imagine-se que o autor é proprietário de imóvel com valiosa floresta de eucaliptos, a qual delimita sua propriedade e a de seu vizinho. Havendo confusão sobre as extremas, poderá o demandante propor a ação demarcatória. A fim de evitar que ocorra derrubada e remoção dos eucaliptos, poderá o autor pleitear a indisponibilização cautelar das árvores até que seja proferida a sentença. O mesmo exemplo serve para demonstrar a possibilidade de antecipação de efeitos da futura sentença de procedência, o que obviamente não significa determinar provisoriamente a linha fronteira entre os imóveis. O que o juiz fará, tendo sido requerida tutela de urgência satisfativa, é restituir a posse, em favor do autor, sobre parcela que provavelmente integra a propriedade do autor considerados os títulos dominiais apresentados com a inicial.

Também poderão as partes celebrar negócios jurídicos processuais, conforme prevê o art. 190 do CPC/2015. Assim, será possível ajustar o procedimento em conformidade com as particularidades da demanda. Não será possível, contudo, pactuar a não realização da prova pericial prevista no art. 579. Se houver concordância manifesta com os limites propostos pelo autor, a primeira fase poderá ser julgada antecipadamente. Caso contrário, deve ocorrer produção de prova pericial a fim de que o juiz delimite a linha de confrontação, sendo vedado às partes pactuar que a resolução do feito ocorrerá somente com fundamento na produção de provas orais. Também não poderá o juiz definir a linha demarcatória sem que haja perícia.

Art. 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda.

1. Necessidade de produção de prova pericial

Na generalidade dos casos, a revelia autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, bem como o julgamento antecipado do processo, desde que o revel não tenha requerido a produção de provas nos termos do art. 349. Mas nem sempre a omissão do réu trará essas consequências.

Com efeito, reiterando o que já constava no diploma revogado, o CPC/2015 dispõe que também não se caracterizará a referida presunção se, havendo vários réus, um deles oferecer resposta (CPC/2015, art. 345, I), se o litígio versar sobre direitos indisponíveis (CPC/2015, art. 345, II) ou se a petição inicial não estiver acompanhada por instrumento que a lei considere necessário para a prova do ato (CPC/2015, art. 345, III). Ademais, o Código vigente consagrou tese acolhida na jurisprudência, assinalando que não se produzirá o efeito de presunção de veracidade quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas documentais (CPC/2015, art. 345, IV¹⁷⁸).

Todavia, ainda que nenhum dos réus ofereça resposta à demanda, na ação demarcatória a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade enunciado no art. 344 do CPC/2015. Trata-se de especificidade da demanda de demarcação. Assim, antes de proferir a sentença que determinará a linha de confrontação, o juiz deve produzir prova pericial, nomeando um ou mais peritos, em conformidade com o disposto no art. 579 do CPC/2015. A revelia não acarreta, ao contrário do que ocorre na generalidade dos casos, o efeito de presunção de veracidade das alegações do autor.

Há, quanto a esse ponto, modificação em relação ao disposto no Código anterior, cujo art. 956 previa a nomeação de um agrimensor e de dois arbitradores. A inflexibilidade do dispositivo do Código revogado se mostrava inadequada em várias situações, pois em imóveis de menor extensão o traçado da linha demarcanda não exigia a presença de três peritos. O art. 579 permite que o juiz avalie a necessidade de nomear mais de um profissional, evitando que haja despesas desnecessárias. O juiz designará os peritos atento às circunstâncias do caso concreto, como a extensão e o relevo da área em que se encontra o imóvel.

Embora não esteja obrigado a isso, em regra o juiz nomeará um agrimensor e um arbitrador.¹⁷⁹ O primeiro deve preparar a *planta* da área em que foi apurada a linha de confrontação e lavrar o *memorial descritivo* com as atividades realizadas em campo. Ao segundo, atribui-se a análise dos documentos e demais elementos probatórios que permitirão a obtenção do traçado da linha demarcanda.¹⁸⁰

No art. 580 o Código indica os elementos que deverão ser considerados pelo arbitrador para que a linha de confrontação seja apurada. Obviamente, caso seja nomeado somente um perito, caberá a ele a análise dos documentos e demais elementos probatórios. O perito deverá necessariamente possuir conhecimentos técnicos sobre agrimensura, cabendo-lhe comprovar documentalmente sua especialização no prazo de cinco dias (CPC/2015, art. 465, § 2.º, II¹⁸¹).

2. Hipóteses de desnecessidade da prova pericial

Não será necessário produzir prova pericial quando o imóvel for georreferenciado, conforme assinala o art. 573. A prova também será dispensável, como já mencionado, quando os réus anuírem expressamente à linha de confrontação proposta pelo autor. A hipótese não se confunde com a mera revelia. Se os réus deixarem de contestar, ainda assim o juiz terá de determinar a produção da prova pericial indicada no art. 579 do CPC/2015. Mas, se concordarem expressamente com a demarcação indicada na inicial, não será necessário produzir prova.

A autonomia da vontade das partes permite que o juiz considere resolvida a questão, acolhendo, por meio da sentença proferida no art. 581 do CPC/2015, a demarcação aceita consensualmente. Seria mesmo contraditório que o Código exigisse a produção da prova nesse caso, apesar de permitir, no art. 571, que a demarcação se realize extrajudicialmente.

3. Submissão ao regime da prova pericial e indicação de assistentes técnicos

A prova produzida à luz do art. 579 se submeterá ao regime da prova pericial descrito nos arts. 464 e ss. Isso significa que as partes poderão arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistente técnico e oferecer quesitos.

Sob o Código revogado a questão não era pacífica na doutrina, mas já prevalecia a opinião favorável à adoção do regime geral para a produção de prova pericial, do qual decorria a possibilidade de as partes indicarem assistente técnico e formularem quesitos.¹⁸²

Considerando que após a resposta será adotado o procedimento comum, não se vê razão que justifique a impossibilidade de as partes indicarem assistentes técnicos e submeterem quesitos ao juízo. Trata-se de faculdades concedidas às partes pelo art. 464 do CPC/2015, dispositivo aplicável à ação demarcatória, que tramitará sob o procedimento comum após o prazo para resposta (CPC/2015, art. 578). Assim, seria contraditório submeter a tramitação do processo ao referido padrão ritual e impedir que as partes indicassem assistentes técnicos e quesitos, razão pela qual essas prerrogativas podem ser exercidas no âmbito das ações de demarcação.

4. Possibilidade produção de prova pericial diversa

Admite-se que a prova pericial não se limite ao levantamento do traçado da linha demarcanda, sendo possível que sua produção se faça necessária para o esclarecimento de outros pontos.

Basta imaginar a cumulação da demanda demarcatória com pedido de indenização. Peritos agrimensores ou arbitradores dificilmente teriam capacidade técnica para calcular os prejuízos ocasionados pela ocupação indevida do imóvel. Nesse caso, seria adequada a nomeação de perito para a apuração dos prejuízos causados ao autor.

Ao analisar a questão sob o Código revogado, Humberto Theodoro Jr. posicionou-se contrariamente à nomeação de outros profissionais, salientando que todos os dados técnicos deveriam ser oferecidos pelos peritos arbitradores.¹⁸³ Esse entendimento era irretocável sob a vigência do Código anterior, no qual se impunha que o juiz nomeasse três peritos, sendo um agrimensor e dois arbitradores. A fim de evitar custas excessivas relacionadas à perícia, cabia realmente ao juiz escolher, dentre os arbitradores, profissionais que tivessem capacidade técnica para enfrentar outras questões além do levantamento do traçado da linha de confrontação. Sob o Código vigente, sobretudo quando houver designação apenas do agrimensor, será possível nomear outro profissional, capaz de dirimir as dúvidas do juiz sobre questões técnicas não relacionadas ao levantamento da linha demarcatória.

Em resumo, sempre que a questão a ser dirimida pela prova pericial transcender a capacidade técnica dos peritos, o juiz deverá designar profissional de sua confiança habilitado tecnicamente a trazer subsídios para a resolução da questão.

Art. 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as

informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem.

1. Análise de elementos probatórios e apuração da linha demarcanda

Os peritos indicados pelo juiz deverão apurar a linha demarcanda entre os imóveis. Para tanto, além da análise dos títulos de propriedade, o art. 580 determina que sejam examinados os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar, além de outros elementos probatórios que forem apurados. Trata-se, logo se vê, de cláusula aberta, concedendo ampla liberdade aos auxiliares do juízo para que obtenham informações que permitam levantar a linha de confrontação. Embora o dispositivo empregue o plural, já foi visto nos comentários ao artigo anterior que o juiz poderá, atento às circunstâncias do caso concreto, nomear somente um auxiliar.

Após a análise dos títulos dominiais, o perito irá a campo, a fim de constatar se os dados sobre as dimensões e limites dos imóveis, apurados nos documentos, harmonizam-se com aqueles que resultam dos trabalhos de medição.¹⁸⁴

O texto se refere aos “rumos” e aos “marcos”. Os marcos que eventualmente tiverem sido afixados nos terrenos poderão ser constatados nos trabalhos de campo. “Rumos”, como já advertido nos comentários ao art. 569, são direções.¹⁸⁵ Tratando-se de abstração, por certo não poderão ser constatados pelos peritos. Mas obviamente os auxiliares do juízo tentarão, à luz dos títulos dominiais e das demais informações obtidas, determinar as direções que compõem a linha de confrontação.

O Código autoriza a coleta de subsídios não somente com os vizinhos dos imóveis a serem delimitados, mas igualmente junto a quem, embora não more na vizinhança, tenha informações importantes a prestar sobre os limites.¹⁸⁶ As pessoas ouvidas pelos peritos não são testemunhas, mas informantes, cujas afirmações devem ser averiguadas pelos auxiliares do juízo.¹⁸⁷

Na dicção do dispositivo em exame, o laudo preparado pelos auxiliares do juízo deverá ser minucioso. O Código revogado, no art. 957, parágrafo único, exigia que os peritos juntassem aos autos a planta da região e o memorial das operações de campo. Embora o Código vigente não contenha expressa determinação nesse sentido, vê-se como oportuna a juntada dos referidos documentos ao processo, pois são elementos essenciais para a confecção do laudo. Todavia, considerada a ausência de regra manifesta sobre a apresentação em juízo dos referidos documentos, a omissão dos auxiliares do juízo não constituirá nulidade.

Apresentado o laudo, que atenderá aos requisitos do art. 473¹⁸⁸ e conterá resposta fundamentada aos quesitos, as partes serão intimadas para manifestação, nos termos do art. 477, § 1.º.¹⁸⁹ O juiz fixará o prazo para a entrega do laudo, que deverá ocorrer com antecedência mínima de vinte dias da audiência de instrução e julgamento. Trata-se de decorrência da aplicação do procedimento comum à primeira fase da demanda demarcatória.

2. Análise da posse

Conforme assenta o art. 1.298 do CC, a linha demarcanda deverá se basear, primeiramente, nos títulos. Caso deles não seja possível obter informações concludentes, será então analisada a posse justa dos confrontantes. Se nem mesmo o exame da posse permitir a demarcação, ocorrerá a divisão em partes iguais entre os prédios, cuja impossibilidade, por seu turno, levará à adjudicação do imóvel em favor de um dos confinantes, indenizando-se o outro.¹⁹⁰

É preciso atentar para a hierarquia estabelecida no CC. Somente será averiguada a posse justa dos confinantes se os títulos dominiais forem insuficientes para a apuração da linha demarcatória. Se não houver correspondência entre a posse e o título, ficará resguardada a possibilidade de alegação de usucapião. Porém, desconsiderada a prescrição aquisitiva, a posse só será analisada se os títulos de domínio não forem concludentes.¹⁹¹

Há de se notar que o CC se refere à posse justa, compreendida como aquela isenta dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade. Somente a posse destituída de vícios poderá subsidiar o traçado da linha demarcatória. Trata-se de consequência que também decorre do art. 581, parágrafo único, dispositivo a prever a restituição da área indevidamente ocupada. Ora, a previsão de entrega da área invadida tem como premissa a ilegitimidade da posse injusta na demarcação.

Se a posse justa não for comprovada, tornando-se, assim como os títulos dominiais, critério insuficiente para o estabelecimento dos limites, ocorrerá a demarcação por partilha da zona disputada, dividindo-se o terreno em partes iguais entre os imóveis.¹⁹² Pressuposto para a partilha é a possibilidade de *divisão cômoda*, expressão empregada no art. 1.298 do CC.

Frustrada a possibilidade de cômoda divisão, o imóvel será adjudicado em favor de um dos confinantes, cabendo ao outro indenizá-lo. Se essa situação se verificar, o laudo pericial deverá indicar o valor da indenização, além de justificar a razão pela qual não é possível a divisão cômoda.¹⁹³ Caracteriza-se, na hipótese, demarcação por zona disputada, cabendo ao confinante, em favor de quem o imóvel é adjudicado, indenizar o outro confrontante em dinheiro.¹⁹⁴

O art. 580 do CPC/2015, ao empregar a locução “minucioso laudo”, exige que o auxiliar do juízo demonstre fundamentadamente a insuficiência do domínio, a não comprovação de posse justa e a inviabilidade de cômoda divisão. Também incumbe ao perito descrever minudentemente as características dos imóveis, a fim de que o juiz possa decidir quem será beneficiado pela adjudicação. À falta de indicação de critérios objetivos no CC, caberá ao magistrado, dentre outras circunstâncias, avaliar a utilização que cada confrontante dará ao terreno, a eventual imprescindibilidade do bem para um dos confinantes e qual das partes, caso seja beneficiada com a adjudicação, permitirá a maior conservação do valor do imóvel.

Art. 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda.

Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.

1. Linha demarcanda e encerramento da primeira fase

O objetivo da primeira fase da demanda demarcatória é propiciar a determinação do traçado da linha de confrontação. É para essa finalidade que é produzida prova pericial específica, sendo nomeados um ou mais auxiliares do juízo (CPC/2015, art. 579). Determinado por sentença o traçado da linha demarcatória, inaugura-se a segunda fase do procedimento, passando-se então às atividades de campo, destinadas à delimitação em conformidade com a linha apurada.

Sublinhe-se, no entanto, que a prova pericial pode chegar à conclusão de que não há fundamento para a demarcação.¹⁹⁵ É o que ocorreria quando o auxiliar do juízo constatasse que o autor não figura como proprietário nos títulos dominiais, que o título de propriedade é viciado ou, ainda, que já existe linha de confrontação perfeitamente definida. Nesses casos será proferida sentença de improcedência do pedido de demarcação.¹⁹⁶ Também será julgada improcedente a demanda quando reconhecida a usucapião da área objeto de demarcação.¹⁹⁷

Sempre que houver determinação dos limites o pedido terá sido acolhido. Assim, ainda que ocorra demarcação por zona disputada – adjudicação do imóvel a um dos confinantes e indenização em dinheiro ao outro, conforme o art. 1.298 do CC – a sentença será de procedência.

2. Eficácia da sentença de demarcação

A sentença que julgar improcedente a demanda demarcatória será declaratória negativa, como o são todos os provimentos jurisdicionais que não acolhem o pedido. Divide-se a doutrina sobre a classificação das sentenças de procedência da ação demarcatória.¹⁹⁸

Três situações podem ser especificadas quanto ao tema. Quando a sentença define a linha de confrontação se apoiando nos títulos ou na posse justa, declara algo que já existia. Os limites não foram criados, mas meramente reconhecidos, razão pela qual o provimento não é constitutivo, mas declaratório. Por outro lado, nas hipóteses de demarcação por partilha da zona disputada ou de demarcação por zona disputada – adjudicação em favor de um dos confinantes, que deverá indenizar o outro, nos termos do art. 1.298 do CC – são criadas situações jurídicas. Por esse motivo o provimento é constitutivo.

Mas há de se levar em conta ainda outra consideração. Se houver restituição de terreno invadido, a sentença proferida na demarcatória será executiva. Nesse caso, não se restringe o provimento jurisdicional a decretar a linha de confrontação. Vai além, ordenando a restituição do bem, nos termos do art. 581, parágrafo único, do CPC/2015.

Como se vê, a classificação da sentença de demarcação dependerá das especificidades do caso concreto. Sua eficácia poderá ser declaratória, constitutiva ou executiva.

3. Restituição da área invadida

No art. 581, parágrafo único, como já destacado em várias passagens destes comentários, o Código permite a restituição da área que eventualmente tenha sido invadida. Se nas hipóteses em que houvesse ocupação indevida não fosse possível restituir, com a sentença de procedência da demanda demarcatória, a fração do imóvel que sofreu invasão, o provimento não seria executivo, mas declaratório.¹⁹⁹

Nesse caso a demarcatória se tornaria instrumento pouco útil, pois à delimitação entre os imóveis haveria de se seguir demanda reivindicatória ou de reintegração de posse, em descompasso com a economia processual e com a efetividade do processo.

Nos termos do art. 581, parágrafo único, torna-se inquestionável a possibilidade de restituição do imóvel invadido. Em locução pouco feliz, o dispositivo alude à declaração do domínio ou da posse do prejudicado. A expressão poderia sugerir que a propriedade ou a posse do demandante seriam apenas declaradas, o que inviabilizaria a retomada da área invadida. Esse entendimento, contudo, é equivocado. O mesmo preceito legal adota tom peremptório ao afirmar que a “sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida”. A declaração é eficácia que acompanha todos os provimentos de procedência e no caso significa apenas que a sentença demarcatória reconhecerá o domínio ou a posse do autor, determinando a imediata restituição da área que tiver sido invadida.

Em resumo, para obter a restituição da área o autor não precisará cumular ao pedido de demarcação o de reivindicação ou de reintegração de posse, pois a devolução da área invadida é efeito anexo da sentença.²⁰⁰ A sentença demarcatória, por si só, operará a restituição da área invadida e proverá a respeito da aquisição de propriedade e das indenizações na hipótese de construção em terreno alheio. Situação diversa ocorre no que diz respeito à indenização. Para ser indenizado pelos prejuízos originários da indevida ocupação o autor deverá cumular pedidos. Feita a cumulação, a prova pericial deverá indicar o valor a ser ressarcido.

Nos termos do art. 1.258 do CC, se houver construção em terreno alheio, limitando-se a edificação à vigésima parte do imóvel invadido, o construtor de boa-fé adquirirá a propriedade da parte ocupada, desde que o valor da construção seja superior ao da parcela invadida. Caberá ao ocupante indenizar a área perdida e a diminuição de valor da área restante. Note-se que a premissa para a aplicação do dispositivo é que a construção ocorra no terreno do invasor, mas inadvertidamente atinja também o de seu confinante.

Caso o invasor tenha agido com má-fé, adquirirá a propriedade da área ocupada se pagar dez vezes o valor da indenização apurada segundo os critérios previstos no art. 1.258. Ademais, só haverá aquisição da propriedade se o valor da edificação for significativamente superior ao da fração do solo ocupada e se não houver possibilidade de demolição da parte da construção

localizada em terreno alheio sem grave comprometimento de sua estrutura.²⁰¹ É preciso, para que o artigo se aplique, que a construção também tenha se realizado em solo do invasor, vindo a ocupar parte do imóvel vizinho não superior a vinte por cento da área deste.

Adverte-se na doutrina que poderá ocorrer perda da utilidade da área que remanescer com o proprietário, em razão da eventual desconformidade com imposições legais. Nesse caso, a indenização deverá corresponder ao total do imóvel invadido.²⁰² Para que ocorra a aquisição da propriedade pelo invasor, quer ele tenha agido com boa-fé, quer o tenha de forma ímproba, é necessário que todas as exigências elencadas no art. 1.258 sejam cumpridas.

Quando a construção representar mais que a vigésima parte do terreno invadido, o construtor de boa-fé adquirirá a propriedade da área ocupada, mas responderá por perdas e danos compostas pelo valor da parcela de solo invadida, pelo valor que a invasão acrescenta à construção e pela desvalorização da área restante. É o que assenta o art. 1.259 do CC, dispositivo que também determina a demolição da construção que ultrapassar um vigésimo da área invadida quando o construtor tiver agido de má-fé. Nesse caso, impõe-se ainda ao invasor o pagamento em dobro das perdas e dos danos apurados.²⁰³

Destaca-se que também na hipótese prevista no art. 1.259 é necessário que o construtor de boa-fé tenha edificado no seu próprio solo. Quando a construção ocorrer inteiramente em terreno alheio, aplica-se o art. 1.255 do CC. O dispositivo estabelece a perda do que tiver sido construído ou semeado, devendo o construtor de boa-fé ser indenizado. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno invadido, o art. 1.255, parágrafo único, autoriza a aquisição da área invadida mediante pagamento de indenização a ser fixada pelo juiz se não concordarem as partes²⁰⁴.

A existência de construções é questão delicada e também deverá ser objeto de análise pelo juiz na sentença demarcatória. Constatada pelo perito a existência de construções ou plantações, deverá esse fato ser consignado no laudo pericial. A sentença na demarcatória necessariamente proverá sobre a restituição do imóvel, de modo que, se houver construção ou plantação em terreno alheio, essa circunstância terá de ser levada em conta pelo juiz. Isso não colide com o que se afirmou há pouco sobre a necessidade de cumular o pedido de demarcação com o de indenização.

O pedido indenizatório cumulado com o de demarcação não diz respeito à indenização por construção, que decorrerá automaticamente da restituição do imóvel, como efeito anexo da sentença. A indenização a ser cumulada se refere a outros fatos, como, por exemplo, aos frutos que o confinante de má-fé percebeu ao longo da ocupação indevida do imóvel.

Para implementar a restituição no plano fático o juiz poderá utilizar todas as medidas coercitivas e sub-rogatórias que estiverem ao seu alcance, aplicando-se ao caso o art. 139, IV, do CPC/2015.²⁰⁵ O autor deve ser imitado na posse da área invadida antes do início da segunda etapa da demanda demarcatória, a fim de que cesse a agressão ao seu direito de propriedade.

4. Honorários advocatícios e despesas processuais

A sentença que encerra a primeira fase da ação demarcatória condenará os sucumbentes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC/2015.²⁰⁶

Segundo o art. 89, quando não houver litígio, as despesas nos juízos divisórios serão pagas proporcionalmente aos quinhões.²⁰⁷ A expressão “juízos divisórios” compreende também as ações de demarcação e de partilha.²⁰⁸ A repartição proporcional das despesas entre os interessados também está prevista no art. 1.297 do CC. Nas demandas demarcatórias o pagamento proporcional das despesas não levará em conta os quinhões, como acontece nas ações de divisão, mas a testada atribuída a cada um dos confinantes.²⁰⁹

Para disciplinar no caso concreto o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, é preciso definir as situações em que não há litígio. Caracteriza-se a resistência à pretensão demarcatória quando os réus alegarem preliminar de carência da demanda ou, no mérito, sustentarem a existência de limites claros e conhecidos entre os imóveis, de modo que a demanda deveria ser julgada improcedente. Nesses casos, sendo proferida sentença de demarcação, a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios seguirá o disposto no art. 85 do CPC/2015.

Se os réus se limitarem a apresentar linha demarcatória com características diferentes, não se caracterizará o litígio, em razão da concordância sobre a necessidade de demarcar os imóveis. Nessa hipótese, deve ocorrer o pagamento proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da inexistência de pretensão resistida.²¹⁰

Art. 582. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários.

Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural.

1. Encerramento da primeira fase

A sentença proferida ao final da primeira fase do processo de demarcação indicará o traçado da linha demarcatória (CPC/2015, art. 581). A segunda fase é destinada à realização das atividades de campo voltadas à concretização do traçado que fora apurado, mediante inserção em solo dos marcos. O traçado da linha de confrontação não pode ser discutido após o trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase. Não será possível iniciar as atividades materiais de demarcação até que ocorra o trânsito em julgado da sentença demarcatória.

2. Recurso cabível

Contra a sentença proferida ao final da primeira fase da ação demarcatória cabe o recurso de apelação. A apelação interposta contra a sentença homologatória (CPC/2015, art. 587), que encerra a segunda fase e extingue o processo, será recebida somente no efeito devolutivo, em razão de disposição legal expressa (CPC/2015, art. 1.012, § 1.º, I²¹¹). Essa regra não se aplica à apelação interposta contra a sentença que encerra a primeira fase (CPC/2015, art. 581), a qual será recebida no duplo efeito.

Ao disciplinar a apelação na demanda de demarcação, o art. 1.012, § 1.º, I, do CPC/2015 restringe a eficácia imediata à sentença homologatória, de modo que se deve entender, *a contrario sensu*, que o provimento jurisdicional que encerra a primeira fase do processo de demarcação poderá ser impugnado por apelação recebida no duplo efeito.

Sendo a eficácia da sentença que encerra a primeira etapa interrompida pela interposição de apelo, é indiscutível que durante a pendência do recurso não poderá ocorrer a retificação no registro de imóveis nas hipóteses de demarcação por zona disputada ou de demarcação por partilha da zona disputada (CC, art. 1.298). Na realidade, até que ocorra o trânsito em julgado, não será transferida a propriedade em favor do condômino a quem o imóvel foi adjudicado, de modo que inexistente fundamento para que o outro confinante promova a execução do valor da indenização.

A mesma conclusão se aplica às hipóteses em que as construções de algum confinante tiverem invadido o imóvel de terceiro. Os arts. 1.258 e 1.259 do CC preveem a possibilidade de transferência de propriedade ao invasor mediante pagamento de indenização. Até o trânsito em julgado não será possível transferir a propriedade e, portanto, não haverá fundamento para a execução do valor da indenização.

Se o autor tiver cumulado com o pedido de demarcação a indenização referente aos frutos percebidos pelo possuidor de má-fé, o cumprimento de sentença por execução não poderá ser deflagrado enquanto a apelação não for julgada. O efeito suspensivo da apelação interrompe a eficácia da sentença e inviabiliza a instauração do cumprimento de sentença. Porém, a partir do momento em que pender de julgamento recurso sem efeito suspensivo, o capítulo da sentença referente à indenização pelos frutos percebidos pelo possuidor de má-fé poderá ser executado provisoriamente, submetendo-se o exequente à responsabilidade objetiva (CPC/2015, art. 520, I²¹²).

3. Coisa julgada

A coisa julgada material atingirá o traçado da linha de confrontação. Mas não se restringirá a isso. A propriedade do imóvel demarcando também será coberta pela coisa julgada material. Essa questão gerou dissídio doutrinário sob o Código revogado.²¹³ Sob o Código vigente a questão dominial será atingida pela coisa julgada sempre que for debatida e expressamente decidida como questão prejudicial.

O art. 503, § 1.º, I a III, dispõe que a questão prejudicial decidida expressamente no processo fará coisa julgada se de sua resolução depender o julgamento do mérito, se tiver ocorrido contraditório pleno e efetivo e se o juiz tiver competência em razão da matéria e da pessoa apreciá-la. Não será atingida pela coisa julgada a questão prejudicial se houver restrição probatória ou limitações à cognição.²¹⁴

Ora, a ação demarcatória é plenária, podendo nela ser alegadas quaisquer matérias de defesa, de modo que inexistente limitação cognitiva. Também não está proibida a realização de outras provas além da pericial, sendo possível que o juiz designe audiência de instrução e julgamento e colha provas orais. Desse modo, não há restrições cognitivas ou probatórias que inviabilizem a formação de coisa julgada sobre questões prejudiciais.

A propriedade será questão prejudicial sempre que for impugnada por um dos confinantes. Nesse caso, para que o juiz possa decidir sobre a demarcação, terá antes de se pronunciar sobre o domínio, caracterizando-se a prejudicialidade. O juiz da demarcatória é competente para a apreciação de questões sobre a propriedade, pois a ação de demarcação é real imobiliária. Tendo ocorrido debate sobre a matéria, haverá ampliação dos limites objetivos da coisa julgada à questão referente à propriedade.

A revelia, óbice à extensão da coisa julgada às questões prejudiciais (CPC/2015, art. 503, § 1.º, II), merece maior reflexão. Todos os confinantes deverão ser citados na demanda demarcatória, caracterizando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Se um dos confrontantes não responder, será considerado revel, embora contra ele não se aplique a presunção de veracidade, pois deverá ser produzida prova pericial ainda que todos os réus deixem de apresentar resposta (CPC/2015, art. 579).

Supondo que um dos réus questione a titularidade dominial do autor, terá ocorrido debate sobre a propriedade, de modo que o tema ficará coberto pela coisa julgada material. Trata-se de questão prejudicial à demarcação, pois se o autor não for proprietário, sequer terá legitimidade para propor a ação demarcatória. A revelia de um dos réus não seria óbice à formação de coisa julgada sobre a questão prejudicial. O que o art. 503, § 1.º, II, proíbe, é a ocorrência de coisa julgada contra o revel. Ademais, terceiros poderão impugnar o que foi decidido na demarcatória, pois o art. 506 do CPC/2015 é expresso ao impedir que a coisa julgada prejudique terceiros.²¹⁵

Será coberto pela coisa julgada o capítulo concernente à restituição da área invadida. Também o serão os capítulos da sentença que dispuserem sobre a indenização a ser paga pelo confinante em favor de quem o bem foi adjudicado na hipótese de demarcação por zona disputada (CC, art. 1.298). Do mesmo modo, serão cobertas pela coisa julgada material as indenizações pagas pelo confinante que houver construído em terreno de terceiro, assim como a aquisição da propriedade (CC, arts. 1.258 e 1.259), pois tais questões integram o objeto litigioso da demanda demarcatória nas hipóteses em que houver necessidade de restituir a área invadida. Não se trata, contudo, de

questões prejudiciais, mas de capítulos autônomos, não se aplicando a eles o disposto no art. 503 do CPC/2015.

4. Registro das operações de inserção de marcos em planta e memorial descritivo

Encerrada a primeira fase da ação demarcatória com o trânsito em julgado da sentença que apurou o traçado da linha demarcanda, será realizada pelo perito a concretização das extremas por meio da inserção dos marcos no solo.²¹⁶ Trata-se do mesmo auxiliar do juízo que fora designado na primeira fase. A segunda etapa é denominada de fase executiva e é constituída pelas tarefas necessárias para que a linha de confrontação definida na sentença seja materializada no solo.²¹⁷

Todas as tarefas do perito deverão ser anotadas em plantas e em memorial descritivo,²¹⁸ a fim de que sejam identificados os pontos assinalados. No art. 583, o CPC/2015 determina que as plantas se façam acompanhar por cadernetas de operação de campo, além de indicar o conteúdo do memorial descritivo.

5. Identificação do imóvel rural

O art. 4.º, I, da Lei 4.504/1964,²¹⁹ define os imóveis rurais, cuja escrituração no Livro de Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, de acordo com o art. 176, § 1.º, II, item 3, *a*, da Lei 6.015/1973, deverá apresentar o código do imóvel, os dados constantes do CCIR, a denominação, bem como as características, confrontações, localização e área.²²⁰

A identificação dos imóveis rurais para que possa ocorrer a escrituração é disciplinada no art. 176, § 3.º, do mesmo diploma legal.²²¹ Será obtida por memorial descritivo, assinada por profissional habilitado, sendo emitida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. Deverá conter as coordenadas dos vértices definidores dos limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.

Ao realizar os trabalhos de campo, assinalando as divisas, o perito deverá identificar os imóveis rurais em atenção ao que preconiza o art. 176, § 3.º, da Lei 6.015/1973.

Art. 583. As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo, que conterá:

I – o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos;

II - os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios, as lagoas e outros;

III – a indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual;

IV – a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras;

V – as vias de comunicação;

VI – as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais;

VII – a indicação de tudo o mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada.

1. Cadernetas de operação de campo

Nas cadernetas de operação de campo o perito registrará as atividades realizadas para a concretização, em solo, do traçado da linha demarcanda.²²² Por expressa determinação do art. 583, os referidos documentos deverão acompanhar as plantas e o memorial descritivo. O objetivo é permitir que as partes possam conferir a correção do trabalho realizado pelo perito.

2. Conteúdo do memorial descritivo

O conteúdo do memorial descritivo, indicado no dispositivo em análise, que praticamente reproduz o art. 962 do CPC/1973, tem sido objeto de críticas pela doutrina.²²³ Com efeito, considerando que o objetivo da demarcação é a apuração da linha demarcanda e sua concretização no solo, mediante cravação dos marcos, mostram-se excessivas algumas das exigências contidas no art. 583, como a composição geológica dos terrenos e as distâncias a pontos de referência (incs. IV e VI).

Ainda que o Código vigente não reproduza os requisitos exigidos para a planta, indicados no art. 961 do CPC/1973, crê-se que haja um excesso de exigências. Não há justificativa para que a composição geológica seja indicada pelo perito, pois tudo o que a demarcação objetiva é a delimitação entre os imóveis. Não se pode esquecer que o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 583 exigirá expressivo número de horas do trabalho desenvolvido pelo perito, ocasionando custos desnecessários para as partes, interessadas exclusivamente na demarcação do imóvel.

Se não houver cumprimento de todos os requisitos do art. 583, mas as descrições realizadas pelo perito no memorial descritivo forem suficientes para permitir a averiguação do acerto na tarefa de concretização da linha demarcanda, não haverá nulidade.²²⁴ Terá sido atingida a finalidade para a qual o procedimento especial de demarcação foi criado.²²⁵ Desse modo, a decretação de nulidade da sentença homologatória que se baseou em memorial descritivo a que faltaram indicações desnecessárias, previstas no art. 583 do CPC/2015, seria formalismo imoderado.

Em suma, quando as anotações nas cadernetas de campo, assim como a planta e o memorial descritivo, tiverem permitido a correta afixação dos marcos, bem como a conferência pelas partes, não deve ser decretada a nulidade da sentença em razão do não acatamento de requisito supérfluo à luz das circunstâncias do caso concreto.

Art. 584. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição.

1. Inserção obrigatória de marcos

Para determinar o perímetro do imóvel é necessário partir de um ponto, denominado marco primordial, e relacioná-lo com outros pontos nos vértices dos ângulos.²²⁶ A representação do imóvel é um polígono. Haverá marcos em número adequado para a delimitação do perímetro e todos terão como referência o marco primordial.²²⁷ Para assegurar a perenidade da demarcação, o marco primordial deve ser constituído por material resistente.

É certo que a atividade pericial desenvolvida na segunda fase se realizará por meio da tecnologia atual à disposição dos peritos. Sempre que os avanços tecnológicos permitirem que se alcance o objetivo da demanda demarcatória – apuração da linha de confrontação e sua efetivação entre os imóveis – deverão ser empregados sem que se possa cogitar de nulidade.

2. Acidentes naturais de difícil remoção ou destruição

Fica dispensada a inserção de marcos nos vértices dos ângulos sempre que os pontos coincidirem com acidente natural de difícil remoção ou destruição. É o que ocorre quando o ponto

assinalado pelo vértice dos ângulos coincidir com rocha ou porção de água.²²⁸

Art. 585. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura encontradas.

1. Verificação dos marcos e conferência da planta e do memorial descritivo

No art. 964 do CPC/1973, determinava-se que os *arbitradores* percorreriam a linha, a fim de verificar sua exatidão com o traçado apurado na sentença. No Código vigente não há obrigatoriedade na nomeação de um agrimensor e de dois arbitradores. O Código sequer faz alusão à figura dos arbitradores.

A compreensão do artigo em análise pode encerrar alguma dificuldade à medida que o Código vigente admite a designação de um só perito para a apuração da linha demarcanda e realização dos trabalhos de campo (CPC/2015, art. 579). No dispositivo em comento, por outro lado, há referência à pluralidade de peritos. A antinomia é apenas aparente.

Se o juiz designar somente um auxiliar para a obtenção da linha demarcanda e sua concretização no solo, deve-se entender que caberá a ele percorrer a linha, verificando os marcos e a exatidão do memorial descritivo e da planta. Não há qualquer impedimento a que o único perito nomeado pelo juízo realize o trabalho de verificação, preparando relatório específico para tanto.

O Código é inequívoco ao permitir a nomeação de um só perito no art. 579. Examinando a complexidade do caso, poderá o juiz, portanto, designar somente um auxiliar da justiça, a quem caberá apurar o traçado da linha demarcanda e realizar as atividades de campo que caracterizam a fase executiva da demanda demarcatória. Caberá a ele fixar os marcos, redigir a planta e o memorial descritivo e, findas essas tarefas, conferir a exatidão do que realizou. Para tanto, poderá contar com auxiliares de sua confiança. Percebendo alguma inexatidão, caberá ao perito desde logo corrigi-la, consignando a correção no relatório da diligência de verificação.

Não se pode extrair do art. 585 a necessidade de nomeação de novos peritos apenas para verificar a correção dos dados constantes na planta e no memorial descritivo. Essa verificação poderá ser realizada pelo próprio profissional, auxiliado pelos assistentes técnicos das partes, que exercerão importante papel nessa etapa do procedimento.

Caso sejam designados dois ou mais peritos, obviamente as atividades poderão ser divididas entre eles, a fim de que um dos auxiliares do juízo verifique o trabalho do outro na inserção dos marcos e na confecção do memorial descritivo e da planta. Ainda que tenha sido nomeado mais de um perito, os assistentes técnicos indicados pelas partes poderão participar de todas as diligências em campo.

2. Relatório específico para a verificação

Deverá ser elaborado relatório específico para a verificação da correção do memorial e da planta. Como já dito, caso tenha sido nomeado um só perito, eventuais inexatidões deverão ser corrigidas, constando a correção no relatório. O perito poderá se fazer acompanhar por auxiliares de sua confiança. A proposta de honorários periciais deverá ocorrer em valor suficiente para a remuneração dos auxiliares. Pagos os honorários periciais, não poderá o perito, posteriormente, requerer complementação para o fim de remunerar seus próprios assistentes.

Se mais de um perito tiver sido nomeado, as tarefas da fase executiva da demanda demarcatória deverão ser divididas, de modo que um dos auxiliares confira o trabalho realizado pelo outro.

Art. 586. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se

manifestem sobre ele no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á, em seguida, o auto de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta.

1. Manifestação das partes

Com a juntada aos autos do relatório de verificação, as partes serão intimadas para se manifestarem no prazo comum de quinze dias. Os assistentes técnicos poderão participar da diligência de verificação, subsidiando as partes na impugnação de eventuais inexatidões. A prolatação de sentença homologatória (CPC/2015, art. 587) sem que tenha sido dada oportunidade às partes de se manifestarem sobre o relatório de verificação é causa de nulidade.

2. Lavratura do auto de demarcação

A possibilidade de impugnação pelas partes se restringe à segunda etapa ou fase executiva do processo de demarcação. A exatidão da linha demarcanda já terá sido objeto de sentença e estarão preclusas quaisquer questões que contra ela se pretendam levantar. Mas, em relação à segunda fase, as partes poderão postular o que entenderem adequado, inclusive a produção de prova pericial para demonstrar eventual inexatidão nas operações de campo.²²⁹

Sobre a manifestação das partes deverá ser intimado o perito, a fim de que sejam trazidos mais elementos para a formação da convicção do juiz sobre o acerto das atividades de campo.²³⁰ A possibilidade de oferecimento de impugnação às operações da segunda fase demonstra com clareza que a apreciação do mérito, na demanda demarcatória, ocorre paulatinamente.²³¹

O Código vigente trouxe significativa novidade no tocante à recorribilidade das decisões interlocutórias. O agravo de instrumento é previsto em rol taxativo, elencado no art. 1.015. As decisões que não forem agraváveis, por não estarem previstas neste dispositivo, não precluirão, podendo ser alegadas em preliminar de apelação ou de contrarrazões, conforme assenta o art. 1.009, § 1.º, do CPC/2015.²³² Cabe verificar se a decisão interlocutória que julga eventual impugnação será agravável.

Por um lado, poder-se-ia sustentar que ao aludir a “cumprimento de sentença”, o art. 1.015, parágrafo único,²³³ estaria se referindo somente ao cumprimento de sentença por execução, disciplinado nos arts. 513 e ss. Por outro lado, poder-se-ia ampliar o conceito de cumprimento de sentença, para que a locução incluísse expressamente as decisões proferidas na segunda fase da demanda demarcatória. Desse modo, as decisões que julgarem as impugnações seriam agraváveis. Este entendimento deve prevalecer.

As atividades realizadas na segunda etapa da ação demarcatória nada mais são que o cumprimento, em sentido lato, do que fora decidido na sentença que encerra a primeira fase. Incide à hipótese, portanto, o conceito de cumprimento de sentença, conforme reconhece a doutrina.²³⁴

É possível que a parte tenha solicitado a realização de diligência, como a oitiva do perito em audiência, por exemplo. Rejeitada a oitiva pelo juiz, também poderá ser interposto o agravo de instrumento, vez que se trata de decisão interlocutória proferida no cumprimento da sentença que encerra a primeira fase da demarcatória.

3. Auto de demarcação

Depois da realização de todas as correções que se fizerem necessárias, o juiz determinará a lavratura do auto de demarcação, no qual constará detalhada indicação dos limites, em conformidade com o memorial descritivo e a planta.

Art. 587. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação.

1. Assinatura do auto de demarcação

O auto de demarcação deverá ser subscrito pelo juiz e pelo perito. Novamente o Código se refere no plural ao auxiliar do juízo, embora seja possível que um só perito atue na demanda demarcatória (CPC/2015, art. 579). Só haverá lavratura do auto de demarcação quando tiverem sido realizadas todas as correções que se fizerem necessárias, conforme assenta o art. 586, parágrafo único.

2. Eficácia da sentença homologatória

A sentença homologatória tem eficácia preponderantemente declaratória, pois reconhece a exatidão do traçado indicado no auto de demarcação, assim como a exatidão dos trabalhos de campo. Embora aceite a eficácia declaratória da sentença que encerra o processo demarcatório, Humberto Theodoro Jr. assinala que, ao erradicar a confusão sobre as extremas, por vezes mediante partilha e adjudicação, seria também constitutiva.²³⁵ Crê-se que o raciocínio valha para a sentença proferida na primeira fase, mas não seja adequado para a homologatória, que ao reconhecer a exatidão do auto de demarcação, declara os limites entre os imóveis em conformidade com o traçado apurado ao final da primeira fase. Assim, entende-se que a sentença homologatória será sempre declaratória.

3. Sentença homologatória e recurso cabível

A sentença homologatória a que alude o art. 587 não é *meramente homologatória*. Cuida-se de provimento jurisdicional que resolve a lide entre os confrontantes, sendo acobertado pela coisa julgada e se submetendo à desconstituição por meio de ação rescisória.²³⁶

Já foi assinalado nestes comentários que a demarcação não é procedimento de jurisdição voluntária. A demarcação é caracterizada pelo caráter contencioso, com a singularidade de que o mérito é resolvido em etapas. Primeiro haverá pronunciamento jurisdicional que determinará o traçado da linha demarcanda (CPC/2015, art. 581). Trata-se de sentença, não de decisão interlocutória. Posteriormente, realizadas as atividades de campo, poderão as partes oferecer impugnação (CPC/2015, art. 586). A apreciação das manifestações da parte ocorrerá mediante decisões interlocutórias. Avança-se no julgamento do mérito. Por fim, o litígio é resolvido por meio da homologação do auto de demarcação. O provimento jurisdicional que homologa o auto é outra sentença (CPC/2015, art. 587).

Contra a sentença homologatória será cabível o recurso de apelação, recebido somente no efeito devolutivo, conforme assenta o art. 1.012, § 1.º, I, do CPC/2015. Contra a sentença, tal como já ocorria no sistema erigido pelo Código revogado, será possível ajuizar ação rescisória (CPC/2015, art. 966).

Seção III Da divisão

Art. 588. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá:

I – a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel;

II – o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas;

III – as benfeitorias comuns.

1. Petição inicial da ação divisória

Além dos requisitos do art. 319 do CPC/2015, a petição inicial da ação de divisão deverá indicar a origem da comunhão e conter descrição do imóvel na qual se aponte sua denominação, situação, seus limites e suas características. Os condôminos devem ser qualificados, assinalando-se os que estiverem estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas, as quais devem ser especificadas. Deve a petição inicial apontar as benfeitorias comuns.

O propósito da demanda divisória é a extinção da comunhão em imóvel, a fim de que se possa atribuir a cada condômino o seu quinhão. O condomínio a ser dissolvido pode recair sobre propriedade rural ou urbana, desde que sejam divisíveis. Deverá ser respeitado o módulo legal mínimo disciplinado no art. 65 do Estatuto da Terra.²³⁷

Estão legitimados à propositura da demanda os proprietários, o fiduciário, o enfiteuta que estiver autorizado pelo senhorio direto, o promissário comprador e o herdeiro único.²³⁸ Devem ser citados todos os condôminos (CPC/2015, art. 588, II), caracterizando-se na hipótese litisconsórcio passivo necessário, de modo que a omissão em relação a um dos comproprietários ocasionará a nulidade do processo.²³⁹

Tratando-se de ação real imobiliária, a propositura da demanda pressupõe o consentimento do cônjuge, que também deverá ser citado, salvo se o casamento tiver sido celebrado sob o regime da separação absoluta de bens, nos termos do art. 73, § 1.º, I, do CPC/2015. Por identidade de razão, deverá haver consentimento do convivente em união estável, o qual também deve ser citado na condição de litisconsorte necessário na ação divisória. Se a união estável não for conhecida pelo autor, o próprio réu deverá advertir para esta situação, solicitando a inclusão do convivente no polo passivo da demanda. Permanecendo inerte, não poderá o réu pleitear posteriormente a nulidade do processo.

Não se pode perder de vista que as ações de divisão são dúplices, de modo que as posições de autor e de réu são intercambiáveis. A resposta do condômino encerra em si mesma um pedido. Na inicial o autor pede a extinção da comunhão e será recomendável que indique as especificidades do quinhão que entende lhe deva ser atribuído.²⁴⁰ Ao responderem, os demais condôminos podem formular suas próprias pretensões no tocante aos quinhões.

A competência para o processamento e julgamento da demanda é do foro de situação da coisa (CPC/2015, art. 47, § 1.º). Se o imóvel estiver localizado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento compreenderá a totalidade do bem (CPC/2015, art. 60).

O valor da causa, segundo o art. 292, IV, deve corresponder ao valor de avaliação da área ou do imóvel objeto do pedido. Embora tenha havido mudança redacional em relação ao disposto no art. 259, VII, do Código revogado, crê-se que o valor venal continue sendo o critério para a valoração da causa. Seria formalismo excessivo, a prejudicar o acesso à justiça, exigir que a parte avaliasse o bem antes de propor a demanda divisória. No entanto, o valor venal do imóvel poderá ser afastado quando estiver em descompasso com o mercado. Nesse caso, poderá o autor se basear em avaliações para valorar a causa.

Nos termos da aplicação conjugada dos arts. 578 e 589, o procedimento comum é aplicado somente depois do transcurso do prazo para resposta, de modo que o autor está dispensado de cumprir o disposto no art. 319, VII, do CPC/2015, pois a audiência de conciliação e de mediação, disciplinada no art. 334, não é realizada no âmbito das demandas divisórias. Com efeito, se o procedimento comum se aplica apenas depois da resposta, não é cabível a referida audiência, a qual deve ocorrer antes que o réu responda.

2. Título de propriedade

O documento comprobatório da propriedade é indispensável à propositura da demanda (CPC/2015, art. 320) e sua ausência pode gerar a inépcia da inicial se o autor, instado a juntá-lo,

deixar de fazê-lo. Como manifestação dos princípios do contraditório e da colaboração processual (CPC/2015, arts. 9.º e 6.º), antes de indeferir a petição o juiz deverá intimar o autor para que apresente seu título de domínio, advertindo-o de que a omissão ensejará o indeferimento da exordial caso o documento não seja apresentado (CPC/2015, art. 321, *caput* e parágrafo único).

3. Origem da comunhão e indicação das benfeitorias

Exige o Código que seja assinalada a origem da comunhão. Diversos negócios jurídicos podem levar à comunhão, como a compra em comum. Ela também pode resultar da sucessão.²⁴¹ Exige-se a indicação da origem para que se verifique a inexistência de óbice à pretensão divisória, de que seriam exemplos alguma estipulação negocial ou ato de última vontade.²⁴²

A propósito do tema, saliente-se que o art. 1.320, § 1.º, do CC estabelece que os condôminos podem estipular a indivisão por prazo não superior a cinco anos, passível de prorrogação. No § 2.º, o dispositivo assenta que a indivisão estabelecida por doador ou testador não pode ultrapassar cinco anos. Por fim, no § 3.º, autoriza-se que o juiz, a requerimento do interessado e mediante motivos relevantes, determine a cessação do estado de indivisão.

Destarte, caso os condôminos tenham estipulado a indivisão do bem por prazo inferior aos cinco anos previstos no art. 1.320, § 1.º, do CC, haverá óbice à pretensão divisória. Do mesmo modo, caso o testador ou o doador tenham estabelecido o estado de indivisão por prazo inferior a cinco anos, a pretensão divisória deverá ser rejeitada. Vê-se, assim, que a indicação da origem da comunhão é elemento imprescindível para a análise da viabilidade da demanda divisória.

A descrição das benfeitorias, tanto as comuns quanto as de cada condômino, tem o objetivo de permitir a melhor composição dos quinhões, de modo que a cada comunheiro seja outorgada a benfeitoria que lhe pertence.²⁴³

Tanto a indicação da origem da comunhão, quanto a descrição das benfeitorias, são requisitos da petição inicial da demanda de divisão, de modo que a omissão do autor conduzirá ao indeferimento da petição inicial se, instado a apontar a origem do condomínio e a descrever as benfeitorias, deixar de fazê-lo. (CPC/2015, art. 321, *caput* e parágrafo único).

4. Cumulação de pedidos

Além da cumulação com o pedido de demarcação, expressamente prevista no art. 570 do CPC/2015, a demanda divisória poderá ser cumulada com pedido indenizatório, a fim de que haja ressarcimento dos comproprietários pelo período em que um dos condôminos usou exclusivamente o imóvel.

A jurisprudência, sob o Código revogado, admitia expressamente a hipótese, determinando que nesses casos o condômino que usou o bem com exclusividade deve indenizar os demais, sendo fixado “aluguel” para tanto.²⁴⁴ A doutrina critica corretamente o uso dessa terminologia, pois a cobrança de aluguel pressupõe a celebração de acordo entre os interessados, o que inexistente na hipótese.²⁴⁵ Trata-se de indenização pela ocupação exclusiva, o que elide a caracterização da verba fixada como aluguel.

Também será possível cumular ao pedido de divisão o de reintegração de posse. O art. 1.199 do CC deixa clara a possibilidade de composses sobre coisa indivisa.²⁴⁶ Assim, se um dos condôminos impedir que o outro exerça a posse sobre o bem, aquele que teve a posse turbada ou esbulhada poderá requerer a reintegração ou a manutenção na posse.

Pode-se cumular a divisória com a demarcatória. E também se pode cumular a demanda divisória com pedido possessório. Nada disso contradiz a assertiva, lançada em várias passagens ao longo desses comentários, segundo a qual não é possível cumular a demarcação com as ações possessórias.

Com efeito, ainda que haja cumulação entre as demandas divisória e demarcatória, o condômino poderá requerer proteção possessória contra o comunheiro que lhe tenha turbado ou esbulhado. Mas a pretensão possessória é dirigida contra outro condômino, não contra confinantes. A demarcação por si só restitui o bem indevidamente ocupado (CPC/2015, art. 581, parágrafo único), de modo que não há necessidade, logo, inexistente interesse processual, no requerimento de proteção possessória contra o confinante. Contudo, poderá ser postulada antecipação dos efeitos da tutela, conforme análise empreendida nos comentários ao art. 578.

Em suma, a inviabilidade da cumulação de pedido possessório ou reivindicatório com a demanda de demarcação não impede que seja pleiteada proteção possessória para proteger o compossuidor contra o esbulho ou turbação praticados pelo condômino.

Art. 589. Feitas as citações como preceitua o art. 576, prosseguir-se-á na forma dos arts. 577 e 578.

1. Citação dos condôminos por correio

O dispositivo em análise determina que a citação dos condôminos ocorra pelo correio, da mesma forma que serão citados os réus na demanda demarcatória. Já o Código revogado, no art. 968, adotava os dispositivos previstos para a ação de demarcação no tocante à citação e resposta dos réus. Repetia-se, na demanda divisória, o problema consistente na previsão de que somente os residentes na comarca fossem citados pessoalmente, ocorrendo a citação dos demais réus por edital. Essa diferença de tratamento não encontrava qualquer justificativa. Ademais, poderia o autor, na hipótese de imóvel localizado em mais de uma comarca, escolher onde seria proposta a demanda, *selecionando* os réus que seriam citados pessoalmente.

Felizmente o tema foi modificado no Código vigente, sendo prevista, no art. 576, a citação por correio de todos os confinantes. Trazendo o dispositivo para a demanda divisória, tem-se que deverão ser citados pelo correio todos os condôminos, residam ou não na comarca em que ajuizada a demanda. O dispositivo não somente corrige inadequação contida no Código anterior, como traz outra melhora significativa: não será necessário expedir carta precatória para a citação dos condôminos residentes em outras comarcas.

Quando o condômino for empresa privada – pense-se, por exemplo, na compra em comum, envolvendo sociedade empresária e seus sócios –, ressalvada a hipótese de microempresa ou de empresa de pequeno porte, poderá ocorrer citação eletrônica, conforme preceitua o art. 246, § 1.º, do CPC/2015.

A referência ao art. 576 ainda traz como consequência a necessidade de que seja expedido edital, na forma do art. 259, III, a fim de que sejam ouvidos eventuais interessados. Não se trata de citação, mas de *publicação* de edital. Obviamente, se o réu for desconhecido ou incerto, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar no qual se encontre, caberá a citação por edital, nos termos do art. 256, I a III, do CPC/2015.

Crê-se que a publicação de edital seja providência salutar a permitir a participação de interessados na demanda divisória. Dentre os interessados, destacam-se os confinantes, que poderão demandar a restituição de terrenos que lhes tenham sido usurpados (CPC/2015, art. 594).

2. Prazo para resposta

Como determina o art. 577, expressamente indicado no art. 589, os condôminos terão o prazo comum de quinze dias para oferecer resposta. Assentando o caráter comum do prazo, o art. 577 inviabiliza a contagem dobrada prevista no art. 229 do CPC/2015. Não terá qualquer relevância, portanto, que os réus se façam representar por advogados diferentes de escritórios distintos, pois o prazo para responder sempre será de quinze dias.

Realizando-se a citação pelo correio (CPC/2015, art. 576), conta-se o prazo para resposta a partir

da juntada do último mandado citatório cumprido (CPC/2015, art. 231, I).²⁴⁷ Se malograr a citação pelo correio, deverá ser realizada por oficial de justiça (CPC/2015, art. 249), hipótese em que o prazo começará a correr a partir da juntada aos autos do último mandado citatório cumprido (CPC/2015, art. 231, II). Ocorrendo citação por edital, o prazo para resposta começará a correr no dia útil seguinte ao do término da dilação concedida pelo juiz (CPC/2015, art. 231, IV).

Sendo realizada citação eletrônica (CPC/2015, art. 246, § 1.º), o prazo para resposta será contado a partir do dia útil seguinte à consulta realizada pelo advogado cadastrado ao teor da citação ou do dia útil seguinte ao término do prazo para a consulta, na forma prevista no art. 231, V, do CPC/2015.

É importantíssimo levar em conta que, na hipótese de cumulação entre as demandas demarcatória e divisória, o prazo para os comunheiros, réus da divisão apresentarem resposta é comum com o dos confinantes, réus na demarcação.²⁴⁸ É irrelevante que a demanda demarcatória seja julgada em primeiro lugar. Ocorrida a citação, devem os réus de ambos os pedidos apresentarem resposta no prazo comum de quinze dias, cuja contagem ocorrerá em conformidade com os critérios acima apontados.

3. Resposta: contestação e reconvenção

A referência do art. 589 ao art. 578 permite concluir que na demanda divisória os réus poderão não apenas contestar, mas também reconvir. Ocorre que o art. 578 se refere ao “prazo para resposta”, deixando claro que a atitude do réu pode não se limitar à contestação.

Como a ação divisória é dúplice, não será necessário reconvir para pleitear a formação de quinhão segundo determinados critérios. Para tanto bastará contestar. Mas o réu poderá reconvir para pleitear a indenização pelo uso exclusivo do imóvel pelo autor ou, ainda, para obter proteção possessória, sempre que seu exercício da posse for turbado pelo autor ou por outro condômino.²⁴⁹ O art. 1.199 do CC autoriza a composse, que será resultado natural do condomínio sobre imóvel. Permitida a composse, qualquer ato que restrinja a relação possessória por um dos condôminos poderá ser repellido por meio de proteção interdital.

Em resumo, decorre da própria duplicidade da ação divisória a possibilidade de que os réus reconvenham para o fim de postular proteção possessória. Não seria coerente com o caráter dúplice do instituto que o autor pudesse postular reintegração ou manutenção na posse, mas o réu, cuja posição, justamente em razão da duplicidade, confunde-se com a do autor, não pudesse fazê-lo. Ademais, a referência do art. 589 ao art. 578, que determina a adoção do procedimento comum após o prazo para resposta, deixa claro que poderão ser apresentadas na via reconvenicional quaisquer pretensões que pudessem ser exercidas na inicial. Trata-se de decorrência da tramitação do processo segundo o referido padrão procedimental.

Na contestação, assim como ocorre com a demanda demarcatória, os réus podem, em preliminar, apresentar as matérias elencadas no art. 337 do CPC/2015, I a XIII. Cabe-lhes apontar a inexistência ou nulidade de citação, a incompetência absoluta, a incorreção do valor da causa, a inépcia da petição inicial, a perempção, a litispendência, a coisa julgada, a conexão, a incapacidade da parte, o defeito de representação ou a falta de autorização, a estipulação de convenção de arbitragem, a falta de legitimidade ou de interesse processual, a ausência de prestação que a lei exija como preliminar, assim como a concessão indevida da gratuidade da justiça.

Haverá decisão terminativa, por falta de interesse processual, quando for pleiteada divisão em desconformidade com cláusula contratual ou com estipulação constante em ato de última vontade, desde que o prazo de divisão seja inferior a cinco anos (CC, art. 1.320, §§ 1.º e 2.º) e essa circunstância for apreciada antes da resposta. Nesse caso, o juízo indeferirá a inicial (CPC, art. 330, inc. III). Caso esses fatos surjam somente na instrução, será proferida sentença de improcedência, à luz do princípio da primazia do mérito, consubstanciado nos arts. 4º e 488 do CPC. Caracteriza-se ilegitimidade *ad causam* quando o condômino, autor ou réu, não titularizar direito real que lhe permita figurar em um dos polos da ação divisória.²⁵⁰

Chegado o saneamento do processo e considerado o caráter dúplice da demanda, é possível que ela prossiga mesmo quando ao autor falte legitimidade. Desde que estejam presentes todos os outros condôminos e haja anuência quanto à continuidade do feito, o processo poderá prosseguir. O juiz, nesse caso, advertirá as partes sobre o rateio das despesas processuais. Embora a solução pareça incomum, trata-se de consequência da duplicidade da demanda.

Em relação ao mérito, poderá ser alegada a impossibilidade de divisão, por descumprimento do módulo legal mínimo previsto no Estatuto da Terra. Essa questão, como visto nos comentários ao art. 569, não diz respeito ao interesse processual, mas ao mérito do processo.²⁵¹ Também poderá ser invocado o descumprimento de lei municipal que vede a divisão da área no tamanho pretendido pelo autor. Em resumo, no tocante ao mérito são admissíveis quaisquer alegações que questionem a existência de condomínio ou a pretensão a dividir.

Tema dos mais controversos é a alegação de usucapião no âmbito da ação divisória. Admite-se, na generalidade dos processos, que a prescrição aquisitiva seja invocada como matéria de defesa, conforme estabelece a Súmula 237 do STF. Contudo, sua alegação no âmbito das ações divisórias é objeto de críticas severas.

Afirmou-se, em doutrina, que o condômino exerce a posse em razão de sua condição de proprietário, como resultado do exercício regular de direito. Sua presença no imóvel seria autorizada pelos demais consortes, que sentiriam a propriedade comum mais protegida pela sua presença. Desse modo, não poderia o comproprietário pretender usucapir a totalidade da área ou mesmo seu quinhão, pois isso significaria indevida modificação dos títulos que justificam a posse.²⁵²

Ponderou-se, em sentido contrário, que o condômino não poderia invocar a prescrição aquisitiva enquanto agisse como comproprietário. Mas poderia usucapir se passasse a agir como titular exclusivo, desde que essa inversão de título não fosse impugnada pelos demais condôminos. Considerando que a usucapião extraordinária dispensa boa-fé e justo título, poderia se caracterizar a prescrição aquisitiva quando o exercício da posse pelo condômino excluísse igual direito dos demais consortes.²⁵³

A conduta do condômino, ao atuar como proprietário exclusivo, evidentemente não ocorre segundo a boa-fé. Rompe-se a confiança dos demais consortes. Desse modo, não se caracterizará a usucapião ordinária, que tem na boa-fé um de seus requisitos, conforme assenta o art. 1.242 do CC.²⁵⁴ Mas poderá ocorrer a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.240, pois a ocupação do imóvel por quinze anos, sem interrupção nem oposição, dispensa a boa-fé. É importante destacar que o prazo para a usucapião extraordinária poderá se reduzir a dez anos se o possuidor constituir no imóvel sua moradia ou tiver nele realizado obras ou serviços.²⁵⁵

Não será possível a usucapião especial de imóvel rural, que tem em um de seus requisitos a não titularização de qualquer imóvel pelo possuidor. Ora, se o possuidor é condômino, então é proprietário, o que exclui a prescrição aquisitiva disciplinada no art. 1.239 do CC.²⁵⁶ Por outro lado, poderá se consolidar a usucapião especial urbana, prevista no art. 1.240 do CC, pois seu requisito é a não titularização de *outro* imóvel urbano ou rural.²⁵⁷ Isso significa que o condômino poderá adquirir a propriedade de até 250 metros quadrados do bem de que seja comproprietário.²⁵⁸ O objetivo dessa modalidade de usucapião é diminuir os problemas habitacionais. Crê-se que será rara sua ocorrência no âmbito de condomínio. Mas disso não decorre que a hipótese jamais possa se concretizar.

Pode-se criticar a divergência de tratamento entre as modalidades de usucapião especial, já que seria admissível que o condômino invocasse a usucapião especial urbana, mas ele não poderia alegar a especial rural. Mas essa diferença se origina dos limites semânticos dos dispositivos que preveem cada uma das modalidades de usucapião. O art. 1.239 exige que o possuidor não seja proprietário de imóvel rural ou urbano. De sua parte, o art. 1.240 traz como requisito que o possuidor não seja proprietário de *outro* imóvel. A distinção entre as hipóteses de incidência é evidente.

A usucapião familiar, disciplinada no art. 1.240-A do CC, encerra hipótese específica de prescrição aquisitiva sobre imóvel titularizado em condomínio com ex-cônjuge ou ex-companheiro.²⁵⁹ Trata-se de prova de que o direito positivo admite a alegação de usucapião sobre coisa indivisa. O objetivo da regra é permitir a aquisição da propriedade exclusivamente por aquele que se responsabilizou pelo sustento da prole. Não se vislumbra hipótese de alegação no âmbito de ação divisória, pois o ex-cônjuge ou ex-convivente não ajuizará essa demanda, mas as ações de divórcio ou de extinção de união estável.

No tocante à ação de divisão, a hipótese mais provável é a de alegação da usucapião extraordinária. A doutrina a tem admitido.²⁶⁰ Assim também a jurisprudência anterior ao Código vigente.²⁶¹ Isso significa que os demais condôminos, ao perceberem o exercício de posse em caráter exclusivo, deverão se valer dos remédios possessórios, a fim de evitar a prescrição aquisitiva. Se antes a todos os consortes era franqueado o acesso ao imóvel, a partir do momento em que houver restrição, caracteriza-se a inversão de título do condômino, que passa a exercer a posse em caráter exclusivo. Imagine-se o levantamento de tapumes em área comum, a impedir o exercício da composses. Ou a resistência, por qualquer meio, ao ingresso na propriedade pelos outros condôminos.

Se um dos comproprietários administrar a coisa comum, prestando contas aos demais e repartindo os frutos, certamente não haverá usucapião. Todavia, caso se negue a compartilhar os frutos percebidos, haverá sinal de que a posse passou a ser exercida com ânimo de exclusividade. Aos demais condôminos caberá utilizar o remédio possessório adequado, a fim de evitar a prescrição aquisitiva.

A usucapião deverá ser alegada no prazo para resposta, sob pena de preclusão, identicamente ao que ocorre nas ações de demarcação. A arguição da prescrição aquisitiva como matéria de defesa ensejará a improcedência do pedido de divisão em relação à área possuída, mas não autorizará a obtenção de propriedade, tal como ocorre na ação demarcatória. A possibilidade de usucapião extrajudicial, prevista no art. 1.071 do CPC/2015, que introduz o art. 216-A na Lei de Registros Públicos, é irrelevante para a questão aqui analisada.

Ocorre que se o réu reconvier, cumprindo as exigências da demanda de usucapião, citando pessoalmente os confinantes (CPC/2015, art. 256, § 3.º), publicando editais (CPC/2015, art. 259, I), cientificando a União, Estado, Distrito Federal e Municípios (Lei de Registros Públicos, art. 216 – A, § 3.º, aplicada analogicamente) e intimando o *Parquet* quando necessário, poderá ser declarada a propriedade em seu favor, ocorrendo o registro competente.

Só não há aquisição da propriedade quando a usucapião é alegada como simples matéria de defesa, porque não são cumpridas as formalidades exigidas na demanda específica de usucapião. Quando forem cumpridas as exigências legais, poderá ocorrer aquisição de propriedade, desde que o réu tenha apresentado sua pretensão em reconvenção. Tal posicionamento evita a propositura de demanda posterior para o enfrentamento de tema sobre o qual o Judiciário já se pronunciou. Prestigia-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e o acesso à justiça.

A alegação de usucapião é questão prejudicial em relação à divisão, de modo que deverá ser apreciada primeiramente. Proposta demanda de usucapião autônoma, caracteriza-se prejudicialidade externa, a viabilizar a suspensão do processo divisório pelo prazo máximo de um ano.²⁶² Tramitando ambos os processos no mesmo juízo, a conexão permitirá que haja resolução conjunta, devendo ser julgada antes a pretensão usucapicional.²⁶³

Considerada a imprescritibilidade das ações de divisão, a arguição de prescrição extintiva será irrelevante. Permanecendo o estado de indivisão, qualquer dos comunheiros poderá pleitear a divisão.

A referência ao art. 578 torna inequívoca a aplicação do procedimento comum *após* o prazo para resposta. Desse modo, tal como ocorre nas ações demarcatórias, não será realizada a audiência de conciliação e de mediação indicada no art. 334 do CPC/2015. Em consequência, a contagem do prazo para responder não atenderá ao disposto no art. 335, I, do CPC/2015.

4. Especialidade da demanda divisória: procedimento em duas fases

O art. 589 faz referência ao art. 578, dispositivo segundo o qual, após o prazo para resposta, aplicar-se-á o procedimento comum. Como visto no item anterior, a aplicação conjugada dos dispositivos leva à desnecessidade de realização da audiência de conciliação e de mediação do art. 334 do CPC/2015. Excetuada essa notável ressalva, pode-se afirmar que todo o trâmite da primeira fase da demanda divisória ocorre segundo o procedimento comum. As partes podem requerer a produção de provas e o juiz pode designar audiência de instrução e julgamento. Mas a atividade probatória deve se restringir a alegações que se relacionem com a existência e extinção da comunhão. É essa a finalidade da primeira etapa da demanda de divisão.

Tal como ocorre com a ação de demarcação, há, na divisão, procedimento em duas fases, destinando-se a primeira à verificação e à extinção da comunhão, mediante prolação de sentença, ao passo que a segunda tem por escopo atribuir os quinhões a cada um dos comunheiros. O procedimento em duas etapas é o traço definidor da ação divisória.

Todavia, contrariamente ao que ocorre com a demanda de demarcação, na qual a sentença que encerra a primeira fase tem como objetivo indicar o traçado da linha de confrontação (CPC/2015, art. 581), o que pressupõe a realização de atividades de agrimensura, na ação de divisão todas as atividades de campo ocorrerão depois da primeira fase. Isso não significa que não haverá produção de prova pericial, mas esse meio de prova, assim como qualquer outro que venha a ser empregado pelo juiz na primeira fase, terá como finalidade averiguar a existência de condomínio e permitir sua extinção.

Lamenta-se que a elaboração do Código vigente não tenha despertado maior discussão sobre o tumultado procedimento da ação de divisão. Embora tenham ocorrido ligeiras modificações em relação ao CPC/1973, ainda causa assombro a má distribuição de vários dispositivos, a confundir o intérprete sobre o *iter* procedimental. Não bastasse isso, as seguidas remissões ao procedimento da demanda demarcatória causam grande confusão, pois ignoram as diferenças de escopo entre a divisão e a demarcação.

5. Aplicação do procedimento comum

O art. 578, referido pelo art. 589, assenta que o procedimento comum será observado depois do prazo para resposta. Isso significa que na primeira fase da demanda divisória poderão ser empregados os meios de prova e os institutos do procedimento comum. Uma vez mais se deve destacar que a finalidade da primeira fase da ação divisória é reconhecer a existência de comunhão e extingui-la. Nada mais que isso. Para tanto, deverá o juiz verificar os títulos de propriedade e os documentos comprobatórios do condomínio.

Apesar da limitação de objeto, pode ser necessária a produção de prova pericial, a fim de que se delimite a área sobre a qual recai a prescrição aquisitiva alegada por um dos condôminos. A prova pericial também pode ser útil para dirimir dúvida sobre a autenticidade de assinatura de testador que institui o condomínio. Identicamente, pode ser útil ao juiz a oitiva de testemunhas ou das partes, para que fique mais clara a existência de comunhão. Mas as provas produzidas na primeira etapa não dirão respeito aos quinhões. Não serão realizados trabalhos de agrimensura, nem aferidos os valores de benfeitorias. Essas questões ficam relegadas para a segunda etapa do processo de divisão.

É importante destacar que, contrariamente ao que ocorre na demarcação, na demanda divisória não há obrigatoriedade na produção de prova pericial já na primeira fase.²⁶⁴ E, ainda que seja produzida prova pericial, ela não se referirá à metragem ou ao valor dos quinhões. Ficará restrita às questões que digam respeito ao condomínio e à sua extinção. Somente depois de transitada em julgado a sentença que encerra a primeira etapa, serão realizadas as atividades de campo.²⁶⁵

Com a aplicação do procedimento comum à primeira etapa, viabiliza-se o saneamento do

processo segundo os arts. 357 e ss do CPC/2015, assim como a designação de audiência de instrução e julgamento (CPC/2015, art. 358 e ss), conforme já enfatizado. Ao delimitar as questões sobre as quais recairá a prova (CPC/2015, art. 357, II), o juiz deverá se fixar na existência de condomínio e na possibilidade de dissolução.

Cabe na ação divisória o julgamento antecipado parcial, em conformidade com o art. 356, I,²⁶⁶ se houver incontrovérsia sobre um dos pedidos. Suponha-se que tenham sido cumulados os pedidos de divisão e de reintegração de posse. Se o comunheiro deixar de contestar o pedido de reintegração, haverá possibilidade de fracionamento do mérito, com a prolação de decisão interlocutória definitiva sobre o tema. Também será cabível o julgamento antecipado parcial do mérito se a contestação se restringir à possibilidade de extinção do condomínio, mas não houver impugnação quanto à existência da comunhão. Poderá então o juiz, antes da produção de provas na primeira fase, proferir decisão interlocutória reconhecendo a comunhão, na forma do art. 356, I, do CPC/2015.

No art. 356, II, o Código autoriza o fracionamento do mérito nas hipóteses em que é admitido o julgamento antecipado da totalidade do pedido. Assim, será possível julgar antecipadamente um dos pedidos ou parcela do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas além da documental (CPC/2015, art. 355, I) ou, havendo revelia, caracterizar-se a presunção de veracidade das alegações do autor e não existir requerimento de produção de provas (CPC/2015, art. 355, II).

Essas hipóteses de incidência do julgamento antecipado parcial encontram aplicação mais restrita no âmbito das ações de divisão. Ainda será possível imaginar, contudo, que a revelia do réu que tenha turbado a posse do autor oportunize o julgamento antecipado parcial do pedido de manutenção de posse (CPC/2015, art. 356, II, c/c art. 355, II). Também é possível que os documentos acostados pelas partes na inicial e na resposta permitam concluir pela existência de condomínio, apesar de algum dos réus impugná-la. Haveria, nesse caso, situação diferente da incontrovérsia, em razão da impugnação de um dos réus. Contudo, o convencimento permitido pela prova documental autorizaria o fracionamento do mérito (CPC/2015, art. 356, II, c/c art. 355, I).

Conquanto as decisões de julgamento antecipado parcial do mérito sejam interlocutórias, haverá formação de coisa julgada material, submetendo-se referidos provimentos à ação rescisória, nos termos dos arts. 503 e 966 do CPC/2015.

Consideradas as especificidades da petição inicial da ação divisória (CPC/2015, art. 588), não é cabível o requerimento de tutela antecipada antecedente, previsto no art. 303 do CPC/2015, de modo que também não será viável o regime de estabilização disciplinado no art. 304. Considerados os requisitos obrigatórios constantes no art. 588, seria difícil imaginar situação em que a tutela de urgência pudesse ser requerida na forma preconizada pelo art. 303. Ademais, tanto o reconhecimento de condomínio, mediante provimento declaratório, quanto sua extinção, por decisão constitutiva negativa, não podem ser antecipados. É difícil visualizar até mesmo algum efeito da futura sentença de procedência que pudesse ser objeto de antecipação.

Eventual violência à posse poderá ser combatida por meio de interdito possessório. Se a agressão à posse houver sido cometida há menos de ano e dia, poderá ser deferida liminar de reintegração ou de manutenção. Se a ofensa for anterior a esse prazo, poderá ser postulada a antecipação de tutela, mas o autor terá de cumprir os requisitos do art. 300 do CPC/2015, demonstrando o perigo de dano e a probabilidade de êxito da demanda.

Não se exclui a possibilidade de que seja requerida tutela cautelar em caráter antecedente, em conformidade com o art. 305 do CPC/2015. Eventual cumulação da demanda divisória com pedido ressarcitório pelo uso exclusivo do imóvel poderá engendrar o pedido de tutela cautelar, a fim de que seja indisponibilizado o patrimônio do autor. Também é possível imaginar o requerimento de proteção acautelatória quando determinada atividade realizada pelo condômino puder causar dano irreparável a alguma benfeitoria, quer ela pertença ao requerente da medida, quer ela seja comum.

O fundamento a permitir a concessão de tutela de urgência no âmbito da ação divisória é a tramitação da primeira fase em conformidade com o procedimento comum. O caráter especial da divisão consiste na existência de duas etapas, destinando-se a primeira somente à verificação da existência de condomínio e à sua extinção. Destarte, a especialidade procedimental da demanda divisória não inviabiliza a concessão de provimentos de urgência na forma dos arts. 300 e 305 do CPC/2015, pois a primeira fase tramita de acordo com o procedimento comum, cujos institutos poderão ser utilizados.

Embora resulte dos arts. 589 e 578 do CPC/2015 que o procedimento comum será aplicado somente depois do prazo para resposta, não há incompatibilidade procedimental a inviabilizar o pedido de tutela de urgência. Ressalte-se, entretanto, que a disciplina concedida às ações divisórias não é compatível com a audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, cuja realização deve ocorrer sempre antes que o réu responda. Sendo assim, a aplicação do procedimento comum *após* o prazo para o demandado responder impede que referida audiência seja designada.

Nesse cenário, é lícito às partes realizar negócios jurídicos processuais na primeira etapa, nos termos disciplinados no art. 190 do CPC/2015. As convenções processuais deverão estar em consonância com a finalidade da primeira fase da ação de divisão, voltada à comprovação e dissolução do condomínio.

6. Prolatação de sentença e encerramento da primeira fase

Graças à falta de sistematização dos dispositivos que integram a Seção III deste Capítulo IV, não é possível perceber com clareza o momento em que a sentença deve ser proferida. Para determiná-lo, deve-se levar em consideração o escopo da primeira fase da ação de divisão. Como já dito, a sentença tem como objetivo desconstituir o condomínio. A instrução é realizada para permitir que a indivisão do imóvel seja reconhecida e, posteriormente, extinta, a fim de que posteriormente sejam determinados os quinhões.

Desse modo, tão logo haja elementos que propiciem a convicção do juiz sobre a existência da comunhão e a possibilidade de extingui-la, deve ser proferida a sentença que põe fim à primeira etapa da ação divisória. Trata-se de provimento com eficácia constitutiva negativa, pois o condomínio é extinto. Tendo ocorrido resistência à pretensão divisória, haverá condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.²⁶⁷ Haverá coisa julgada sobre o condomínio e a extinção da comunhão.²⁶⁸

Contra a sentença, cabe apelação (CPC/2015, art. 1.009), que será recebida no duplo efeito. Não se pode confundir o provimento jurisdicional que encerra a primeira etapa da demanda de divisão com a sentença homologatória (CPC/2015, art. 597, § 2.º), a qual extingue o processo. Contra esta, será interposta apelação que será recebida apenas no efeito devolutivo (CPC/2015, art. 1.012, § 1.º, I).

Art. 590. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural.

Parágrafo único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha.

1. Nomeação de peritos e início da segunda fase

Com a nomeação dos peritos pelo juiz, inicia-se a segunda fase da ação de divisão. Muito embora autorizada voz da doutrina tenha recomendado, sob o CPC/1973, a nomeação de peritos na sentença que encerra a primeira fase, são bastante claras as desvantagens dessa proposta.²⁶⁹ Seria

inviabilizada a impugnação dos peritos pelas partes, que não teriam como arguir a suspeição ou o impedimento. Sequer a alegação em recurso seria possível, pois a matéria, não analisada em primeira instância, não poderia ser apreciada em segundo grau. A necessidade de manifestação das partes sobre a proposta de honorários do perito constituiria outro grave inconveniente. É facilmente imaginável o tumulto procedimental que resultaria do pronunciamento das partes sobre a remuneração do perito após a sentença. É nítido, portanto, que a nomeação deve ocorrer no provimento jurisdicional que inicia a segunda fase da demanda divisória.

Transitada em julgado a sentença, o juiz deve nomear o perito, intimando as partes sobre a designação, a fim de que possam arguir a suspeição ou o impedimento, bem como se manifestar sobre a proposta de honorários formulada pelo experto. Não é necessário que as partes peticionem requerendo a produção da prova pericial. Trata-se de desdobramento natural do acolhimento da demanda divisória. O objeto da perícia é a constituição dos quinhões. O artigo é bastante expresso ao permitir a nomeação de um só profissional. A complexidade do caso determinará a necessidade de nomeação de um ou mais peritos.

Mencionou-se que na primeira etapa pode ser produzida prova pericial. Mas a perícia lá produzida não se refere aos quinhões, de modo que os auxiliares do juízo que atuaram na primeira fase da divisória, contrariamente ao que ocorre na ação de demarcação, em regra não serão os mesmos que participarão da segunda. Recomenda-se, na doutrina, a realização de vistoria do imóvel na primeira etapa.²⁷⁰

Não se crê, contudo, que seja necessária a vistoria para se aferir a possibilidade de divisão do imóvel, nem, tampouco, o cumprimento do módulo legal mínimo previsto no Estatuto da Terra. Todavia, se houver necessidade de vistoria na primeira etapa, vindo o juiz a nomear *expert* versado em agrimensura, ele poderá ser mantido para os trabalhos realizados na segunda fase. Mas a hipótese não é comum, pois não se vê em quê seria relevante a vistoria do imóvel para a prolação de sentença que se limita a reconhecer a comunhão e a extingui-la. O cumprimento do módulo legal mínimo não justificaria a vistoria, pois os documentos carreados pelas partes já devem ser capazes de demonstrar a possibilidade de divisão sem que o referido estatuto seja infringido. De qualquer modo, se houver necessidade de vistoria e o juiz nomear perito versado em agrimensura na primeira etapa, o experto poderá ser mantido na segunda.

2. Identificação do imóvel rural

Como já mencionado nos comentários ao art. 582, parágrafo único, a definição dos imóveis rurais no direito positivo é realizada no art. 4.º, I, da Lei 4.504/1964. Na escrituração no Cartório de Registro de Imóveis, conforme assenta o art. 176, § 1.º, II, item 3, *a*, da Lei 6.015/1973, deverão constar o código do imóvel, os dados constantes do CCIR, a denominação, as características, confrontações, localização e área.

O art. 176, § 3.º, da Lei dos Registros Públicos aponta os requisitos necessários para a identificação dos imóveis rurais a fim de que ocorra a escrituração. Ela será realizada por meio de memorial descritivo, sendo assinada por profissional habilitado, emitindo-se a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. Devem constar as coordenadas dos vértices definidores dos limites, em georreferenciamento ao Sistema Geodésico Brasileiro.

Nos trabalhos de campo, que constituem a segunda etapa da demanda divisória, ao assinalar as divisas, cumpre ao perito identificar os imóveis rurais em conformidade com o preconizado no art. 176, § 3.º, da Lei 6.015/1973.

3. Constituição dos quinhões e partilha

Reconhecida e extinta a comunhão, realiza-se na segunda fase, com a designação de prova pericial, o trabalho de constituição dos quinhões. Para sua formação será levado em conta o aspecto econômico. Não se trata, portanto, de assegurar igualdade na extensão de terras, mas sim, no valor que a elas se atribui.²⁷¹

Deverão ser respeitados os percentuais instituídos no ato jurídico do qual decorre a indivisão. Imagine-se que haja comunhão entre três condôminos. Se disposição testamentária conceder a um condômino cinquenta por cento do imóvel, deixando vinte e cinco por cento para cada um dos outros dois, esses percentuais terão de ser respeitados na divisão. Após a apuração do valor total do imóvel, serão formados os quinhões em atenção aos percentuais definidos no testamento. Idêntico raciocínio vale para qualquer ato jurídico que tenha levado à comunhão.

Para assegurar a igualdade na partilha sob o critério econômico, devem os peritos apontar as vias de comunicação existentes, bem como as construções e benfeitorias, indicando seus valores, proprietários e ocupantes. Da mesma forma, devem ser relacionadas as águas que banham o imóvel e outras informações economicamente relevantes, como a composição geológica dos terrenos, qualidade e extensão dos campos, matas e capoeiras, distância a rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerados urbanos e polos comerciais (CPC/2015, art. 583, IV e VI).

O Código, curiosamente, faz menção a essas informações – composição geológica, extensão dos campos e sua qualidade, distância em relação a ferrovias, etc. – quando trata das ações demarcatórias, na qual elas são inúteis, deixando de elencá-las nos dispositivos que disciplinam as ações de divisão, em que serão importantes para a determinação do valor dos quinhões.

Certamente as circunstâncias do caso concreto determinarão a importância das informações levantadas na perícia. Se o imóvel se destinar à produção de soja, por exemplo, serão relevantes os dados sobre as rodovias, ferrovias e portos. Caso se volte à pequena produção ou à agricultura de subsistência, essas informações serão menos relevantes. O importante é que sejam colhidos na perícia todos os elementos conducentes à equânime divisão econômica do imóvel.

Art. 591. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de 10 (dez) dias, os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões.

1. Pedido de constituição dos quinhões

No mesmo ato jurisdicional que determinar a produção de perícia, instaurando a segunda fase da demanda divisória, o juiz intimará os condôminos para que apresentem pedidos sobre os quinhões. Não seria adequado que essa intimação ocorresse na sentença que encerra a primeira fase da demanda. Basta imaginar que a um só tempo poderia a parte ser constrangida a recorrer, mediante apelação, e a formular seu pedido de quinhão, algo que, ademais, estaria em franca contradição com o recurso. Com efeito, quem formula pedido de quinhão em tese concorda com a extinção do condomínio.

Desse modo, para evitar tumulto processual e a imposição de conduta contraditória às partes, há de se entender que o despacho que abre a segunda etapa da divisão determinará a produção de prova pericial para a constituição dos quinhões, além de intimar as partes para que formulem seus pedidos justificadamente, caso ainda não o tenham feito na primeira fase.

Objetiva-se facilitar a divisão na hipótese de dissenso entre os condôminos. Os pedidos devem estar justificados, cabendo às partes apontar as benfeitorias e plantações, bem como outras circunstâncias relevantes, como a residência em parte do imóvel. Trata-se de ônus, não de dever processual, de modo que a omissão da parte não ensejará qualquer sanção.²⁷²

2. Apresentação dos títulos

O dispositivo assinala que as partes deverão apresentar seus títulos caso ainda não o tenham feito. Não se pode entender que a referência do Código seja aos títulos de domínio, pois cabe aos réus apresentá-los na resposta e, ao autor, na inicial.²⁷³ Assim, para que o art. 591 tenha alguma relevância, deve-se compreender que esteja a se referir a outros títulos que não os dominiais, tais como os que se referem à construção de benfeitorias, realização de plantações e posse sobre determinada fração do imóvel.²⁷⁴

Os pedidos dos condôminos, devidamente instruídos, serão de grande importância para que o perito possa demarcar os quinhões, na forma preconizada no art. 582, parágrafo único, do CPC/2015. É indiscutível que será de grande valia a especificação de títulos que conduzam a determinada divisão do imóvel. Mas os títulos de domínio já terão sido juntados e avaliados na primeira fase, finalizada pela sentença que reconheceu o condomínio e o extinguiu. A reabertura de prazo para que as partes comprovassem o domínio seria de todo inconveniente ao avanço do procedimento.

Art. 592. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias.

§ 1.º Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel.

§ 2.º Havendo impugnação, o juiz proferirá, no prazo de 10 (dez) dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões.

1. Oitiva das partes

Apresentados os requerimentos de constituição de quinhões pelas partes, deve o juiz ouvi-las no prazo de quinze dias. Trata-se de evidente manifestação do princípio do contraditório na segunda etapa da ação divisória (CPC/2015, art. 9.º). Os condôminos têm o direito de se manifestar sobre os pedidos e documentos juntados pelas outras partes, a fim de demonstrar inexatidões ou esclarecer o juízo.

O prazo de quinze dias é comum, de modo que não incidirá a duplicação prevista no art. 229 do CPC/2015 para as hipóteses em que os litisconsortes estiverem representados nos autos por diferentes procuradores.

2. Anuência e divisão do imóvel

Se não houver impugnação aos requerimentos de formação de quinhões, bastará que o perito os delimite. A omissão do condômino caracterizará anuência ao que fora requerido pelo consorte. Se, a despeito da inexistência de impugnação, os pedidos não forem harmônicos entre si, caberá ao juiz decidir, à luz das alegações e dos títulos apresentados pelas partes. Trata-se de consequência da natureza dúplice da demanda divisória. Basta que haja discrepância entre os pedidos para que o juiz tenha de se pronunciar sobre os títulos a serem considerados na formação dos quinhões e sobre qual dos requerimentos deve prevalecer.

Se algum dos condôminos permanecer silente na segunda etapa da demanda divisória, deixando de formular pedido de quinhão, seu silêncio deve ser interpretado como concordância ao pedido dos demais. A não desincumbência do ônus de formular o pedido de quinhão poderá prejudicá-lo. Trata-se, logo se vê, de consequência típica da caracterização da conduta da parte como ônus relativo. Não há dever de cumprir o encargo imposto pela lei, mas o descumprimento pode levar a situação prejudicial.

Caso tenha havido revelia, os condôminos revéis permanecerão em comunhão.²⁷⁵ Se um só dos comunheiros for revel, por certo o estado de indivisão não remanescerá. Com efeito, não há que se falar em comunhão quando o quinhão indiviso pertencer a um só condômino. Ocorrerá, sendo revel somente um dos condôminos, a extinção do condomínio e a partilha em conformidade com o pedido dos demais condôminos.

3. Impugnação

Como já destacado, resulta da natureza dúplice da demanda divisória que a formulação de pedidos entre si discrepantes é o que basta para caracterizar a impugnação. Mas, além disso, pode a parte, instada a se manifestar sobre os requerimentos e os títulos apresentados pelos consortes, formular oposição específica. A ela se dá o nome de impugnação.

Assim, tendo um dos comunheiros pleiteado determinado quinhão, invocando, para tanto, sua condição de residente e a construção de benfeitorias, poderá outro condômino, ciente dessa manifestação, alegar que a benfeitoria é comum e que a residência no condomínio não poderia ensejar o quinhão requerido, razão pela qual o pedido deve ser indeferido pelo juiz. Em casos como esse, o juiz decidirá, proferindo decisão interlocutória. Contra a decisão caberá agravo de instrumento.²⁷⁶

Com efeito, por identidade de argumento ao que fora assinalado nos comentários ao art. 586, parágrafo único, contra as decisões interlocutórias prolatadas na segunda etapa da demanda divisória, caberá agravo de instrumento. Isso decorre da caracterização da segunda etapa como cumprimento de sentença. Mas ainda que assim não fosse, o art. 1.015, parágrafo único, estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra decisões proferidas no processo de inventário. Ora, tal como ocorre na divisão, o processo de inventário também tem como objetivo a partilha de bens. Assim, a interpretação extensiva da locução “processo de inventário” levaria à mesma conclusão quanto ao cabimento do agravo de instrumento.

Art. 593. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas há mais de 1 (um) ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda.

1. Perímetro e benfeitorias do confinante

Cabe ao perito fixar com exatidão o perímetro do imóvel dividendo. Se for atingida benfeitoria de confinante erigida há mais de um ano, deverá ser respeitada. A regra, constante no art. 973 do Código Buzaid, foi censurada pela doutrina.²⁷⁷ Não se pode negar, contudo, que forte senso prático a preside. É indiscutível que os comunheiros litigariam para evitar que lhes fosse atribuído o quinhão no qual constasse a benfeitoria.²⁷⁸

O dispositivo, levando em conta a situação fática, estabelece pragmaticamente que a benfeitoria erigida há mais de um ano será respeitada, o que não significa que os condôminos perderão a propriedade da área para o confinante. Deverão recuperá-la e, posteriormente, realizar nova divisão.²⁷⁹ Nas hipóteses em que não for viável a divisão do imóvel recuperado, o comunheiro que a adjudicar deverá ressarcir os demais.²⁸⁰

2. Benfeitorias permanentes

O art. 973, parágrafo único, do CPC/1973 indicava que seriam consideradas benfeitorias “as edificações, muros, cercas, culturas e pastos fechados, não abandonados há mais de 2 (dois) anos”. O prazo indicado no dispositivo não era suficiente para que o condômino se sentisse seguro em obter o quinhão que abrangesse a benfeitoria abandonada. Sempre haveria o temor de que o confrontante litigasse para manter a posse da área. A não indicação de prazo, portanto, é solução superior.

Por outro lado, era bastante útil a caracterização de benfeitorias. Inexistente regra específica no Código processual vigente, deverão ser consideradas como benfeitorias permanentes as melhorias realizadas no imóvel, há mais de um ano, nas quais o confinante ainda tenha interesse econômico. Seriam exemplo os muros, cercas, galpões, casas, poços e plantações.

Presentes esses melhoramentos, deverão os condôminos reivindicar o imóvel ou, eventualmente, ajuizar ação de reintegração de posse de força velha. Quando retomada a faixa indevidamente ocupada pelo confinante, deverá ocorrer nova partilha. Insista-se que a desconsideração das benfeitorias no perímetro do imóvel dividendo não acarreta perda de domínio dos condôminos. Só não poderá ocorrer a divisão, a fim de evitar que um dos consortes seja prejudicado.

Art. 594. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados.

§ 1.º Serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente.

§ 2.º Nesse último caso terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obrigar à restituição, a haver dos outros condôminos do processo divisório ou de seus sucessores a título universal a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido.

1. Usurpação de terrenos, restituição ou indenização

Da mesma forma que o art. 572, concernente à cumulação das demandas de demarcação e de divisão, o art. 594 estabelece que os confinantes do imóvel dividendo poderão pleitear a restituição de terrenos que lhes sejam usurpados em decorrência da divisão. Embora o dispositivo mencione somente a restituição, é certo que os confinantes poderão pleitear também a indenização, assim como ocorre no art. 572. Não haveria qualquer sentido em permitir que a escolha da forma de tutela ocorresse quando os comunheiros cumulassem a divisão e a demarcação e negá-la quando fosse ajuizada apenas a demanda divisória.

A premissa para a incidência do dispositivo é a usurpação de propriedade dos confrontantes em razão das atividades de delimitação dos quinhões realizadas na ação de divisão. Ocorrendo essa usurpação, poderão os confinantes requerer a tutela jurisdicional que considerarem adequada, seja ela específica, seja ressarcitória pelo equivalente pecuniário.

2. Restituição do imóvel

As razões apontadas nos comentários ao art. 572 do CPC/2015, relacionadas à inadequação das ações possessórias e da reivindicatória para a restituição do imóvel, podem ser reproduzidas na análise do dispositivo em tela.

Os interditos possessórios têm como objetivo tutelar a posse. Ocorre que na hipótese prevista no art. 594 do CPC/2015 há mais que perda da posse. Os confrontantes perdem o domínio como resultado das atividades de divisão. As ações possessórias, nesse contexto, são incapazes de assegurar a tutela pretendida pelo confinante que sofreu usurpação.

Também não é adequada a ação reivindicatória, pois nela o proprietário não possuidor litiga contra o possuidor não proprietário. Há de se atentar que o confinante, usurpado pela divisão, perde sua condição de proprietário, o que já desautoriza a propositura da demanda. Além disso, o comunheiro beneficiado pela usurpação não é mero possuidor, mas titular de domínio. Vê-se, assim, que a inadequação da demanda reivindicatória é patente.²⁸¹

Incabíveis os interditos possessórios e a reivindicatória, poderá o confinante esbulhado ajuizar embargos de terceiro. Apesar da redação do art. 674 ser substancialmente diferente daquela do art. 1.046 do CPC/1973, os embargos de terceiro continuam sendo a medida adequada para que o confrontante requeira a restituição da parcela do imóvel usurpada.

O art. 674, § 1.º, do CPC assinala que os embargos de terceiro podem ser ajuizados pelo proprietário. Conquanto inexistir disposição expressa sobre a legitimidade dos condôminos, sua condição de proprietários lhes concede legitimidade para a propositura. Ademais, os confrontantes obtêm legitimidade para pleitear a restituição, por meio de embargos de terceiro, do próprio art. 594 do CPC/2015. Trata-se de medida capaz de ensejar a prestação da tutela jurisdicional, o que basta para caracterizar sua adequação e a legitimidade dos confinantes.

É certo, por outro lado, que a perda de propriedade dos confrontantes, decorrente da divisão, caracteriza ato construtivo, a autorizar o ajuizamento dos embargos de terceiro. Como já mencionado nos comentários ao art. 572, pode-se mesmo afirmar que a usurpação é a constrição por excelência.

Há de se atentar, contudo, que a medida de restituição disciplinada no art. 594 permite a aplicação do princípio da fungibilidade. As exigências formais devem ser relativizadas em favor da tutela jurisdicional. Desse modo, se o confinante propuser demanda, nominando-a de reivindicatória, atento à causa de pedir e ao pedido o juiz deverá conceder a tutela jurisdicional capaz de assegurar a restituição da fração do terreno usurpada na divisão.

O nome da demanda, como já dito, não tem qualquer relevância na definição da tutela. Sendo assim, poderia o confrontante designar sua demanda de ação de restituição, pois isso não traria qualquer consequência para a tutela jurisdicional. O que importa, está claro, é que seja apresentado pedido congruente com a causa de pedir. Narrada a usuração, cabe ao autor pleitear a restituição. Razões já indicadas amparam o entendimento de que os embargos de terceiro são a ação cabível.

3. Pedido indenizatório

O art. 594 não refere expressamente a possibilidade de pedido de indenização pelos confinantes. A menção se restringe à restituição. Todavia, inexiste qualquer justificativa para que a indenização possa ser requerida pelos confinantes quando a usuração ocorrer no âmbito de demandas cumuladas de demarcação e divisão (CPC/2015, art. 570 c/c art. 572), mas não se possa requerê-la quando exercida somente a ação de divisão.

Destarte, apesar da omissão legislativa, a interpretação conjugada dos arts. 572 e 594 do CPC/2015 torna clara a possibilidade de escolha dos confinantes, que poderão ajuizar demanda voltada à restituição ou pleitear indenização. Concede-se, portanto, a possibilidade de os confinantes pleitearem tutela pelo equivalente pecuniário, no lugar da tutela restituitória específica que seria obtida na hipótese de ajuizamento de embargos de terceiro.

Para obter a indenização o confinante deverá indicar o valor da parte do imóvel que lhe foi usurpada. Nesse caso, a propriedade será transferida ao(s) comunheiro(s), a quem caberá indenizar o confinante.

4. Citação dos condôminos ou dos quinhoeiros

O art. 594, § 1.º, reproduz substancialmente o disposto no art. 572, § 1.º. Se não tiver ocorrido o trânsito em julgado da demanda divisória, dispõe o artigo em comento que deverão ser citados todos os condôminos na ação indenizatória ou de restituição promovida pelo confinante, caracterizando-se litisconsórcio passivo necessário. Se já tiver transitado em julgado a divisória, impõe-se citar os quinhoeiros beneficiados pela usuração. É bastante clara a razão de ser do dispositivo.

Enquanto a divisão não estiver encerrada persiste a comunhão sobre o imóvel dividendo, de modo que a demanda a ser promovida pelos confinantes, seja ela indenizatória, seja de restituição (embargos de terceiro), haverá de ser proposta contra todos os condôminos. Com o trânsito em julgado da divisória terá sido extinto o condomínio, sendo constituídos os quinhões, com atribuição a cada um dos quinhoeiros. Nesse caso, é indiscutível que a demanda ajuizada pelos confinantes deverá ser proposta somente contra quem tiver sido beneficiado indevidamente com a divisão. Ou seja, serão réus os quinhoeiros a quem a usuração beneficiou.

Como destacado na análise do art. 572, § 1.º, a definição do foro competente dependerá da demanda pela qual optarem os confinantes. Tratando-se de demanda voltada à restituição da coisa, a competência será do foro de situação, conforme assenta o art. 47 do CPC/2015. Ajuizada demanda indenizatória, competente será o foro de domicílio do réu, como assenta o art. 46 do mesmo Código.

5. Formação de título executivo em favor do quinhoeiro que restituir o terreno ou pagar a indenização

O art. 594, § 2.º, reitera substancialmente os termos do art. 572, § 2.º. A sentença de procedência, proferida na demanda de restituição (embargos de terceiro) ou de indenização, será título executivo a permitir que o quinhoeiro a quem coube indenizar ou restituir parcela do imóvel possa se ressarcir perante seus antigos consortes.

Só ocorreu a usuração do imóvel confinante porque os quinhões obtiveram determinada conformação, a fim de que fosse preservada a igualdade econômica entre os quinhões. Assim, os demais também se beneficiaram da usuração, de modo que não seria justo que somente um dos quinhoeiros respondesse pela indenização ou restituição. Essa é a razão pela qual a sentença constitui título executivo contra os ex-consortes.

Para tanto, todos os ex-condôminos deverão participar da demanda de restituição ou de indenização, impondo-se ao quinhoeiro denunciar a lide aos demais, na forma do art. 125, II. Trata-se de modalidade de intervenção de terceiros provocada, por meio da qual denunciante e denunciado passarão a atuar em litisconsórcio contra o adversário do denunciante na ação principal. Além disso, a denunciação encerra demanda regressiva e eventual, do denunciante contra o denunciado.

Desse modo, tem-se que, julgada procedente a demanda de restituição ou indenizatória promovida pelo confinante, poderá o juiz, no mesmo processo, dispor sobre o ressarcimento que os ex-consortes deverão conceder ao quinhoeiro sucumbente. Menciona-se o caráter eventual da denunciação da lide, pois a demanda regressiva, proposta pelo quinhoeiro denunciante contra os ex-condôminos, só será julgada se ele sucumbir na demanda ajuizada pelo confinante usurpado.

Com a procedência da ação de regresso, desde logo poderá ser deflagrada a execução. Tendo sido ajuizada demanda indenizatória, a sentença proferida na ação regressiva e eventual que constitui a denunciação da lide poderá ser objeto de cumprimento de sentença (CPC/2015, arts. 513 e ss.), no qual serão permitidas as medidas atípicas disciplinadas no art. 139, IV, do CPC/2015.²⁸²

Caso tenha sido ajuizada demanda de restituição (embargos de terceiro), a compensação do quinhoeiro sucumbente poderá ocorrer mediante penhora e adjudicação de parcelas dos terrenos dos ex-condôminos. Não há sentido, nesse caso, para que a compensação seja somente pecuniária.

Não haverá direito à compensação perante os ex-condôminos quando a usuração se originar de erro na demarcação de quinhão específico, a envolver apenas o quinhoeiro e seu confinante. Ocorre que nessa hipótese os ex-condôminos não são beneficiados pelo despojamento da propriedade de algum vizinho, de modo que não há qualquer compensação a ser realizada.

Saliente-se, por fim, que o art. 592, § 2.º, assim como o art. 572, § 2.º, menciona somente os sucessores universais dos condôminos que figuraram na ação divisória. Não poderá o quinhoeiro denunciar a lide aos sucessores a título singular de algum ex-condômino.²⁸³

Art. 595. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar, para adjudicação a cada condômino, a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas.

1. Possibilidade de nomeação de um só perito

Apesar de o dispositivo se referir a “peritos”, empregando o plural, já foi visto que o art. 590 autoriza a nomeação de somente um auxiliar do juízo. A complexidade das atividades a serem desempenhadas na fase executiva determinará a nomeação do número de auxiliares e, por expressa determinação legal (CPC/2015, art. 590), poderá o juiz se limitar a um profissional.

2. Proposta de divisão

Trate-se de um ou mais peritos, caberá encaminhar ao juízo laudo fundamentado que contenha

proposta de divisão do imóvel. A sua elaboração será presidida pelo princípio da igualdade econômica dos quinhões. Já foi salientado ao longo desses comentários que a divisão não é meramente geométrica, mas principalmente econômica.²⁸⁴ Trata-se de imperativo decorrente da incidência do art. 1.321 do CC,²⁸⁵ que faz referência expressa às regras da partilha e da herança, dentre as quais figura o art. 2.017 do mesmo diploma,²⁸⁶ dispositivo a estabelecer a maior igualdade possível entre os bens a serem partilhados.²⁸⁷

A igualdade dos quinhões sobre a perspectiva econômica não será o critério exclusivo a orientar a elaboração do laudo. Deverá ser respeitada a comodidade dos condôminos, de modo a lhes atribuir a preferência aos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar que o quinhão seja retalhado em glebas separadas.

Trata-se de regras que permitirão a divisão cômoda, ainda que sua implementação acarrete determinada discrepância econômica entre os quinhões. As circunstâncias do caso concreto determinarão a maneira como a divisão deverá ocorrer. Salienta-se na doutrina que a comodidade não pode caracterizar privilégio a um ou outro dos quinhoeiros, mas considerar os interesses de todos.²⁸⁸

Ao elaborar o laudo indicado no art. 595, o perito já terá tomado as providências elencadas no art. 590, sendo recomendável que cumpra ainda as indicações constantes no art. 583, todos do CPC/2015. No laudo deverão constar, ainda, os cálculos sobre compensações aos quinhoeiros que perderem parte de benfeitorias próprias.

Quando formular o laudo com a proposta de divisão, o perito já terá realizado os trabalhos de campo e, portanto, verificado a existência de benfeitorias comuns insuscetíveis de divisão cômoda, a necessidade de instituição de servidões, os excessos decorrentes de benfeitorias particulares e o valor das eventuais compensações. O laudo que apresenta ao juízo deve ser completo e se pronunciar sobre todas as questões relacionadas à constituição dos quinhões, a fim de que, ouvidas as partes, possa ocorrer a deliberação sobre a partilha.

Art. 596. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha.

Parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando, além do disposto nos arts. 584 e 585, as seguintes regras:

I – as benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação;

II – instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoadado com o prédio serviente;

III – as benfeitorias particulares dos condôminos que excederem à área a que têm direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho mediante reposição;

IV – se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro.

1. Oitiva das partes

Concede-se às partes o prazo comum de quinze dias para que se manifestem sobre o laudo apresentado pelo perito. Tratando-se de prazo comum, não ocorrerá a duplicação prevista no art. 229 do CPC/2015.

As partes poderão se manifestar sobre todos os aspectos do plano de divisão, oferecendo impugnação caso haja discordância. Assim, poderão se opor à constituição dos quinhões em todos os seus aspectos, tais como o retalhamento em glebas separadas, o retalhamento de benfeitorias

próprias, o equívoco no cálculo das compensações, o encravamento desnecessário do quinhão, a concentração indevida de recursos naturais em um dos quinhões e a atribuição incorreta de terreno contíguo a outro condômino que não o residente ou proprietário da benfeitoria. Enfim, poderá ser impugnado qualquer aspecto do plano de divisão.

Após a manifestação das partes, o juiz deve abrir prazo para que o perito se manifeste.²⁸⁹ Prestados os esclarecimentos do experto e realizadas eventuais correções, devem ser ouvidas as partes. Questões que permaneçam obscuras podem ser dirimidas mediante produção de prova pericial.²⁹⁰

2. Constituição dos quinhões e benfeitorias

O art. 596, parágrafo único, I, assinala que as benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos, sendo o outro consorte compensado. A adjudicação deverá ocorrer de forma a preservar a igualdade econômica entre os quinhões. Disso decorre que ao quinhoeiro a quem foi adjudicada a benfeitoria comum será atribuída área menor.

É importante perceber que a compensação ocorrerá preferencialmente por meio da atribuição de área menor, como consequência do imperativo de igualdade econômica entre os quinhões. Somente haverá compensação pecuniária se não for possível equilibrar economicamente os quinhões mediante atribuição de área menor ao consorte beneficiado com a benfeitoria comum.²⁹¹ A compensação pecuniária, apesar do disposto no art. 596, parágrafo único, IV, será subsidiária.

Quanto às benfeitorias particulares dos condôminos que excederem seus quinhões, o Código determina, no art. 596, parágrafo único, III, que ocorrerá adjudicação ao vizinho, mediante reposição, a qual será feita em dinheiro. Assim, o condômino vizinho a quem parte da benfeitoria foi adjudicada deverá repor em dinheiro, ao quinhoeiro proprietário, o valor representado pela adjudicação de parte da benfeitoria.²⁹²

A adjudicação de parte da benfeitoria ao vizinho deverá ser realizada somente quando de outra forma não for possível dividir o imóvel. Em regra, a fim de assegurar a igualdade entre os quinhões, deve-se retalhá-los de modo a atribuir a benfeitoria a quem a edificou. Não sendo isso possível, deverá o quinhoeiro a quem parte da benfeitoria foi adjudicada pagar àquele que a construiu. Note-se que no caso não é possível a compensação por meio da atribuição maior de terras, de modo que a compensação terá de ocorrer em dinheiro.

No art. 596, parágrafo único, II, determina-se que sejam instituídas as servidões necessárias, sendo fixada compensação monetária ao condômino serviente. É preciso distinguir as servidões das passagens forçadas. Estas são instituídas quando houver encravamento de quinhão. Por sua vez, servidões de trânsito serão constituídas para permitir que o quinhoeiro se desloque de uma gleba a outra, passando por outro quinhão, quando tiver ocorrido retalhamento em glebas separadas.²⁹³

Certamente será preferível que cada quinhão tenha sua própria saída para a via pública. Também será preferível, nos termos do art. 595 do CPC/2015, que não ocorra retalhamento do quinhão em glebas separadas. Quando o encravamento e o retalhamento forem inevitáveis, impõe-se a instituição de passagem forçada ou de servidão de trânsito, fixando-se indenização ao proprietário do quinhão serviente.

O art. 596, parágrafo único, II, assenta que não serão indenizáveis as servidões naturais. Entende-se por esta expressão aquelas que decorram das características do imóvel. Assim, não caberá qualquer indenização pela passagem de águas de um quinhão ao outro, pois se trata de servidão natural.²⁹⁴ É digno de nota que o dispositivo se refere a “servidões indispensáveis”. A ênfase do direito positivo serve como advertência ao perito para que realize a divisão de modo a evitar a necessidade de instituição de servidões.

No art. 596, parágrafo único, IV, o Código estabelece que as compensações e reposições serão feitas em dinheiro quando as partes não dispuserem de outro modo. Quando se tratar de benfeitoria comum, atribuída somente a um dos quinhoeiros, a compensação deverá ocorrer preferencialmente por meio da atribuição de mais terras ao proprietário que fora preterido, a fim de que seja preservada a igualdade econômica entre os quinhões. Se se tratar de benfeitoria particular que exceda a área atribuída ao quinhoeiro, haverá compensação em dinheiro. Na hipótese de benfeitorias comuns, portanto, o art. 596, parágrafo único, IV, não é peremptório.²⁹⁵

3. Decisão interlocutória sobre a partilha

Apresentado o laudo com a proposta de divisão pelo perito, o juiz intimará as partes. Oferecida impugnação à proposta, antes de decidir o juiz deve ouvir o perito, a fim de que sejam realizados os esclarecimentos e as correções pertinentes. Se o laudo for retificado, as partes devem se manifestar novamente, pois terá ocorrido modificação substancial no documento que embasará a partilha. Ouvidas as partes no prazo comum de quinze dias, deliberará o juiz sobre a partilha.

Trata-se de decisão interlocutória, contra a qual será cabível o recurso de agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único). Como enfatizado nos comentários ao art. 592, a expressão “cumprimento de sentença”, prevista no art. 1.015, parágrafo único, abrange as decisões proferidas na segunda fase da ação divisória, que se caracterizam como o cumprimento do que fora decidido pelo juiz ao encerrar a primeira etapa.

4. Demarcação dos quinhões

O art. 596, parágrafo único, assinala que, em cumprimento à decisão do juiz que deliberar sobre a partilha, caberá ao perito realizar a demarcação dos quinhões. Para tanto, deverá proceder da forma indicada nos arts. 584 e 585 do CPC/2015. Após a fixação dos marcos, deverá ser verificado o perímetro pelo perito e seus assistentes. A demarcação dos quinhões, e não poderia ser diferente, segue o que foi preceituado na disciplina da ação demarcatória. Depois da verificação do trabalho de campo, com a colocação dos marcos, caberá ao perito elaborar o relatório indicado no art. 586 do CPC/2015.

Art. 597. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará o memorial descritivo.

§ 1.º Cumprido o disposto no art. 586, o escrivão, em seguida, lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino.

§ 2.º Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida sentença homologatória da divisão.

§ 3.º O auto conterá:

I – a confinação e a extensão superficial do imóvel;

II – a classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte e com a respectiva avaliação ou, quando a homogeneidade das terras não determinar diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade;

III – o valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão.

§ 4.º Cada folha de pagamento conterá:

I – a descrição das linhas divisórias do quinhão, mencionadas as confinantes;

II – a relação das benfeitorias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação;

III – a declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e o modo de exercício.

1. Memorial descritivo

O art. 597 determina que, após a realização dos trabalhos de campo, com a descrição na planta dos quinhões e das servidões aparentes, caberá ao perito elaborar o memorial descritivo. Os trabalhos de campo do perito serão encerrados com a juntada aos autos do relatório previsto no art. 586 do CPC/2015, como visto há pouco. Com o fim dos trabalhos de campo, será imprescindível a formulação de memorial descritivo pormenorizado, sobre o qual a escritania lavrará o auto de divisão.

2. Auto de divisão

O auto de divisão deverá conter, na forma determinada pelo art. 597, § 3.º, a confinação e a extensão superficial do imóvel (inc. I), a classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte e a respectiva avaliação ou, sendo homogênea a composição do imóvel, sua avaliação na totalidade (inc. II) e o valor e a área atribuída a cada condômino, com a indicação de eventuais reduções e compensações resultantes da diversidade de valores das glebas que compõem cada quinhão (inc. III).

Como o objetivo do auto de divisão é permitir o registro dos quinhões no Registro de Imóveis, adverte-se na doutrina que nele deverão constar todos os documentos necessários para essa finalidade, como certidões tributárias e comprovantes de pagamento de compensações.²⁹⁶ Deverá ser subscrito pelo juiz e pelo perito, conforme determinação expressa do art. 597, § 2.º.

3. Folhas de pagamento

O escrivão também lavrará a folha de pagamento, com base no memorial descritivo formulado pelo perito.²⁹⁷ Segundo o art. 597, § 4.º, cada folha deverá conter a descrição das linhas divisórias do quinhão, com a menção aos confinantes (inc. I), a relação das benfeitorias e culturas do quinhoeiro, assim como das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação (inc. II) e a indicação das servidões que foram instituídas, especificando-se o lugar, a extensão e o modo de exercício (inc. III). Cada condômino receberá sua folha de pagamento, pois se trata de documento indispensável para a transcrição dos quinhões perante o Registro de Imóveis.

As informações contidas nas folhas de pagamento devem ser completas, a fim de permitir a transcrição do quinhão no Registro de Imóveis.²⁹⁸ Como adverte a doutrina, além dos elementos indicados no art. 597, § 4º, deverá a folha de pagamento cumprir as exigências contidas na Lei de Registros Públicos e no Estatuto da Terra, indicando a matrícula do imóvel perante o INCRA, registro da cota ideal do quinhoeiro no Registro de Imóveis, certidões fiscais de adimplemento de obrigações tributárias e qualificação completa do comunheiro.²⁹⁹

4. Sentença homologatória

Com a assinatura do auto de divisão pelo juiz e pelo perito, deve ser proferida a sentença de extinção do processo de divisão. Realizadas todas as atividades de campo, fixados os quinhões e lavrados pela escritania os documentos necessários para a transcrição no Registro de Imóveis, deve findar a segunda fase da ação divisória e, com ela, todo o processo.

Vale para a sentença que homologa o auto de divisão o que foi dito sobre a sentença homologatória que encerra a segunda fase da demanda demarcatória: trata-se de provimento que extingue processo jurisdicional e que não é, portanto, *meramente* homologatório.

Diverge a doutrina sobre a eficácia da sentença. Sua caracterização como executiva tem como

fundamento a desnecessidade de cumprimento de sentença para a entrega de coisa certa.³⁰⁰ Por outro lado, sua identificação como provimento constitutivo leva em conta a criação de um novo *status* jurídico para os comunheiros, que passam a ser proprietários exclusivos de parcelas do imóvel que antes titularizavam em comum.³⁰¹ A eficácia constitutiva é, de fato, o elemento mais relevante da sentença que homologa o auto de divisão e encerra a segunda fase da ação divisória.

Em regra não haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a não ser que alguma das partes tenha deflagrado incidentes processuais infundados, pois a constituição dos quinhões é interesse de todos os condôminos.³⁰² Quanto às custas processuais, o art. 1.315 do CC é inequívoco ao estabelecer que o condômino é obrigado a arcar com elas na proporção de sua parte.³⁰³ Poderá o consorte não arcar com suas despesas desde que renuncie à sua parte ideal, conforme assenta o art. 1.316 do CC.³⁰⁴ Assim, caso renuncie, no curso do processo, ao seu quinhão, o condômino ficará isento do pagamento das custas e despesas processuais.

5. Recurso cabível

Contra a sentença homologatória do auto de divisão caberá apelação, recebida somente no efeito devolutivo (CPC/2015, art. 1.012, § 1.º, I). Conquanto seja a apelação recebida somente no efeito devolutivo, por expressa disposição do art. 250, I, da Lei dos Registros Públicos, as matrículas dos quinhões, assim como a revogação da matrícula anterior, só poderão ocorrer depois do trânsito em julgado.³⁰⁵

Contra a sentença homologatória do auto de divisão será cabível ação rescisória (CPC/2015, art. 966),³⁰⁶ pois não se trata de provimento jurisdicional meramente homologatório, como também não o é a sentença que homologa o auto de demarcação, conforme visto nos comentários ao art. 587.

Art. 598. Aplica-se às divisões o disposto nos arts. 575 a 578.

1. Remissão desnecessária

O dispositivo em comento não tem qualquer utilidade. O art. 589, como visto, já determina a aplicação, às demandas divisórias, dos arts. 576, 577 e 578, todos do CPC/2015. Poder-se-ia imaginar que a utilidade decorreria da referência ao art. 575. Ocorre que esse dispositivo outorga aos condôminos a legitimidade para promoverem ação demarcatória. Sua aplicação analógica às ações divisórias é totalmente desnecessária, pois é óbvio que qualquer dos condôminos terá interesse na extinção da comunhão e na formação dos quinhões, tal como assinala o art. 1.320 do CC.

É curioso perceber que no CPC/1973 já havia dispositivo reputado como inútil pela doutrina.³⁰⁷ Tratava-se do art. 981, que se referia aos arts. 952 a 955. Os dispositivos continham os preceitos ora reproduzidos nos arts. 575 a 578. Causa perplexidade que, mesmo diante da crítica da doutrina, as remissões desnecessárias tenham sido mantidas no Código vigente.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 615.

2

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários ao código de processo civil*, vol. XIII, p. 399: “Desvela-se deste modo a insuficiência da fórmula empregada pelo legislador no art. 946: temos nele previstas duas hipóteses para a demarcatória: a) quando se torne necessária a fixação de novos marcos (ditos na lei ‘novos limites’), de modo que a linha demarcatória verdadeira seja refeita; e b) os casos em que a ação demarcatória se destine à ‘aviventação’ da linha de marcos quando estes (indicados na lei como ‘limites’) se tenham apagado, seja pela ação do tempo, seja por obra do homem. Todavia, onde teria ficado a função principal da demarcatória, que é justamente demarcar os prédios confinantes quando entre eles jamais teria existido qualquer linha de confrontação?”.

3

Idem, p. 398-399.

4

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

5

Lopes da Costa, *Demarcação, divisão, tapumes*, p. 42. Textualmente: “O rumo é uma direção. A direção é um ente de razão. Não pode assim ser destruída, deslocada ou arruinada. O que se apaga, se destrói ou arruína é o sinal material no solo: o valo, o marco”. No mesmo sentido, Ovídio Baptista da Silva, op. cit., p. 398.

6

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários ao código de processo civil*, vol. IX, t. II, p. 12. Literalmente: “Podemos resumir, basicamente, a três situações o cabimento da ação demarcatória: a) inexistência de limites entre as propriedades; b) necessidade de aviventar rumos apagados ou renovar marcos destruídos ou arruinados; c) confusão quanto aos limites existentes”.

7

Humberto Theodoro Jr., *Breves comentários ao novo código de processo civil*, p. 1469, destaca com grande precisão a necessidade de que os imóveis sejam contíguos: “É o direito de propriedade que, em última análise, por sua exclusividade natural, confere ao dono do imóvel o direito de tê-lo sempre discriminado dos demais prédios vizinhos. Mas essa faculdade de manter discriminado o bem imobiliário pressupõe, obviamente, a contiguidade de dois ou mais prédios, porque, a não ser junto ao vizinho imediato, não tem o proprietário interesse jurídico relevante em assinalar os extremos do seu terreno”.

8

Pontes de Miranda, *Comentários ao código de processo civil*, t. XIII, p. 475-476, amparando-se em jurisprudência, reconhece que mesmo a existência de rio não será obstáculo ao ajuizamento da

demarcatória, pois o curso d'água pode ter se bifurcado, de modo que os dados do relevo não excluem de antemão o interesse na demanda: “Nem sequer, a existência de rio, ou outro dado geográfico, a preexclui”.

9

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1472 expõe o assunto de forma precisa: “A posse promíscua é efeito e não causa da confusão de limites, motivo pelo qual a incerteza pode perdurar, não obstante o estabelecimento de posse exclusiva de um dos confinantes sobre porção certa e delimitada do imóvel na confrontação com o vizinho. (...) O que não se admite, contudo, é que a simples e imediata comprovação de um muro possa transformar-se num insuperável empecilho à ação demarcatória, sem indagar-se como e por que o tapume foi colocado naquela posição. (...) Parece-me lógico que a colocação unilateral de tapumes por um dos confinantes, sem atender a seus títulos e aos interesses do vizinho, e, ainda, sem a concordância deste, não tem força jurídica de tornar certa a linha *divisória* e de eliminar o direito de confrontante de reclamar o levantamento da linha verdadeira em juízo”.

10

STJ, REsp 38.199/MG, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, *DJ* 28.11.1994, p. 32615: “Ação Demarcatória. Existência de Muro Divisório. Falta de Correspondência com o Título. Se a linha divisória existente não corresponde aos títulos e não há outros limites, devidamente definidos no terreno, cabível a demarcatória. Precedente: REsp. 3.193”. Com o mesmo entendimento, transcreve-se acórdão pioneiro sobre o tema no STJ: REsp. 3.193, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, *DJ* 09.10.1990, p. 10894: “Processual Civil. Coisa Julgada e Preclusão. Inexiste coisa julgada material se as questões decididas foram somente de natureza processual. A incidência do disposto no art. 468 do CPC supõe decisão de mérito. Ação Demarcatória. Existência de Marcos Divisórios. Falta de Correspondência com os Títulos. Se a linha divisória existente não corresponde aos títulos e não há outros limites, devidamente definidos no terreno, cabível a demarcatória. A reivindicatória supõe a perfeita individuação da coisa e para tanto é adequado o pedido de demarcar”.

11

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1471, diferencia com clareza as duas categorias: “Diz-se que a confusão de limites pode ser *subjativa* ou *objetiva*. É *subjativa* quando existe materialmente a assinalação da linha, mas um dos vizinhos não a aceita como correta. É *objetiva* a confusão de limites quando, pela ausência material dos marcos divisores das duas propriedades, estabelece-se *posse promíscua*, pelo exercício simultâneo de atos possessórios dos vizinhos nos confins imprecisos de seus terrenos”.

12

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 201.

13

STJ, REsp. 165.223/RJ, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, *DJ* 08.03.1999, p. 221: “Condomínio por unidades autônomas. Pretensão de que sejam extremadas as áreas comuns daquelas que integram uma dessas unidades, uma vez que incertos os limites. Denunciada a existência de litígio e pedindo-se a providência adequada a sua solução, há que se outorgar a prestação jurisdicional apta a compô-lo.

14

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1473-1474, sustenta que o vocábulo *proprietário* compreende os titulares de propriedade limitada, de que são exemplos “o nu-proprietário, o usufrutuário, o habitador, o senhorio, o enfiteuta, e o titular de servidão”. No mesmo sentido, Ovídio Baptista da Silva, op. cit. p. 414; Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 406, fazendo alusão ao enfiteuta, ao usufrutuário, ao usuário, ao habitador, ao credor anticrético e ao titular da servidão, admitindo ainda a ação para a demarcação da posse envolvendo possuidores; Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários ao código de processo civil*, vol. IX, p. 48, defendia que o proprietário, no âmbito da ação demarcatória, “tanto pode reunir em sua pessoa todos os direitos elementares, ou componentes do domínio, como pode estar desfalcado de algum ou de alguns deles”, de modo que seriam legitimados ativos o usuário, o usufrutuário, o enfiteuta, cabendo a qualquer deles integrar a demanda em litisconsórcio ativo; Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 14-18, assinala que a ampliação da legitimidade ativa aos titulares de direitos reais de uso, gozo e fruição, além do promissário comprador, seria solução “mais prática”, a exigir, todavia, a caracterização de litisconsórcio ativo necessário. Note-se que o autor aceita a legitimidade dos detentores de domínio pleno ou parcial, como o enfiteuta, o nu-proprietário, o senhorio direto e o proprietário. Contrariamente, Lopes da Costa, *Demarcação, divisão, tapumes*, p. 76, amparava-se no direito romano para sustentar que o direito real que limite a propriedade não se caracterizaria como propriedade limitada: “A propriedade pode não ser plena, por se haver dela destacado uma das faculdades para constituir um direito atribuído a outrem. Sem embargo, ela continua como propriedade. O direito real que a limite não constitui uma propriedade limitada. Basta atentar na terminologia: é um direito real na coisa *alheia*, *ius in re aliena*. Vigorosamente dispunha o texto romano: ‘Corretamente dizemos ser nosso todo o imóvel, embora de outrem seja o usufruto dele’. *Recte decimus eum fundum totum nostrum esse, etiam quum usufructus alieno est. (Digesto – de verborum significatione – lei X, fr. 25)*”; Clóvis do Couto e Silva, *Comentários ao código de processo civil*, vol. XI, t. I, assinalava que legitimados ativos e passivos eram apenas os proprietários: “Legitimados ativos e passivos são somente os proprietários, excluindo-se os usufrutuários, os titulares de direito real de uso, habitação, etc”; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 619, sustentam a restrição da legitimidade ativa ao proprietário, excluindo do vocábulo os detentores de direitos reais limitados: “Apenas o proprietário tem legitimidade ativa e passiva para ação demarcatória. (...) Os titulares de direitos reais limitados não têm legitimidade para ação demarcatória”.

15

Restringindo a legitimidade ativa ao proprietário e concedendo à palavra sentido restrito, a excluir os titulares de direitos reais limitados, decidiu o TJMG, ApCiv 1.0684.09.007618-4/001, 10ª Câmara Civil, rel. Veiga da Costa, DJ em 21.06.2013. Reza a ementa: “Ação Demarcatória. Ausência de Comprovação da Propriedade do imóvel. Ilegitimidade Ativa Configurada. A ‘legitimação ativa e passiva para a ação demarcatória pressupõe a propriedade (arts. 946, I, Código de Processo Civil, 1.297 e 1.298, CC). Apenas o proprietário tem legitimidade ativa e passiva para a ação demarcatória (STJ, 4ª Turma, j. em 30.08.1993, DJ 20.09.1993, p. 19.179). Os titulares de direitos reais limitados não têm legitimidade para a ação demarcatória’ (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo, 3ª ed., 2011, Ed. RT, pág. 879). Não comprovada a propriedade do autor em relação ao imóvel demarcando, deverá ser reconhecida a sua ilegitimidade para propor a ação demarcatória. Recurso não provido”. Ampliando a legitimidade ativa aos titulares de direitos reais de gozo, decidiu o

TJPR, ApCiv 693627-2, 18ª Câmara Cível, rel. Roberto De Vicente, *DJ* 15.20.2010, embora na solução do caso concreto o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, pois o demandante detinha somente escritura pública de cessão de direitos de herança. Assinala a ementa: “Apelação Cível. Ação Demarcatória Extinta sem Julgamento de Mérito, nos Termos do Artigo 267, VI, do CPC. Autor que detém apenas escritura pública de cessão de direitos de herança, não registrada no cartório de registro de imóveis. Ilegitimidade ativa *ad causam*. Somente o proprietário e/ou para quem (sic) direito real de gozo (ex.: usufrutuário) tem legitimidade ativa para a ação demarcatória. Recurso desprovido”. Costuma-se indicar na doutrina, em abono à tese de restrição da legitimidade ativa ao proprietário, o STJ, REsp 20.529/AL, 4ª Turma, rel Min. Dias Trindade, *DJ* 20.09.1993. Eis a ementa: “Processual Civil. Ação demarcatória. Pressuposto Essencial. É pressuposto essencial para a propositura da ação demarcatória que seja o autor proprietário do imóvel demarcado”. Contudo, a sucinta fundamentação não enfrenta o alcance do termo “proprietário”, limitando-se a indicar a carência de demanda demarcatória na qual não tenha sido juntada prova do domínio. Eis o voto: “O acórdão confirmou sentença que teve como carecedor do direito de ação demarcatória o autor, por não provar a sua qualidade de proprietário do imóvel que se pretende demarcar. A circunstância de haver o autor, com a apelação, feito juntar reprodução de certidão resumida do registro de escritura sobre imóvel em determinada rua, sem indicar sequer o nome do proprietário, não poderia ser conhecida pelo órgão julgador, sobretudo para suprir omissão da parte apelante ao ajuizar a presente ação. Para a instância revisora ordinária, por conseguinte, restou não comprovada a qualidade de titular do domínio do autor da ação, situação de fato que não cabe rever em recurso especial. Isto posto, voto no sentido de não conhecer o recurso”. Vê-se, assim, que o julgado não prestigia a tese da restrição da legitimidade, mas se posiciona- apenas sobre a necessidade de comprovação do domínio já na petição inicial, em conformidade com o art. 950 do Código de processo revogado.

16

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

17

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 17.

18

Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: I – o registro: (...) 23) dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores.

19

O art. 575 do CPC/2015, como se verá adiante, prevê hipótese de litisconsórcio ativo necessário quando a demanda demarcatória for ajuizada por um dos condôminos. Nesse caso, os demais comproprietários serão seus litisconsortes.

20

Orlando Gomes, *Direitos Reais*, p. 299-300.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 414.

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 50. *In verbis*: “Há, entretanto, um direito real novo sobre o qual, em tema de legitimidade *ad causam*, o silêncio do Código de 1973 sabe a omissão. Refiro-me ao direito real de aquisição, contido na promessa irrevogável de venda devidamente inscrita no Registro de Imóvel. Ela é mais do que um pré-contrato. É oponível *erga omnes*. Tem execução específica. Mesmo que o futuro adquirente não tenha recebido, por antecipação, a posse, é evidente que o problema das extremas do imóvel é também problema seu, razão por que a ele não pode permanecer estranho”. No mesmo sentido, admitindo a legitimidade ativa do promissário comprador, Antonio Carlos Marcato, *Procedimentos Especiais*, p. 190, para quem a *legitimatio*, ressalvada a exceção, fica adstrita ao proprietário. Com o mesmo entendimento, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 29, para quem o promissário comprador teria legitimidade desde que o contrato estivesse registrado, houvesse quitação, imissão na posse e a avença contivesse as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 415.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 616. Na dicção dos autores: “Na ação reivindicatória é sabida a exata extensão daquilo que se reivindica; na ação demarcatória, essa certeza só se obtém com a sentença”.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 405-407. O jurista advertia corretamente que não era possível sustentar a natureza real da ação demarcatória com base na ideia de que ela estaria baseada em direito real. Seu argumento era comprovado por meio da ação para ressarcimento de danos causados em prédios rústicos rurais ou urbanos, prevista no art. 275, II, do Código revogado. Referida demanda, conquanto se baseasse em direito real, gerava pretensão pessoal, calcada no direito das obrigações. É digno de nota que Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 413, sustentava o contrário, assinalando que o caráter real da demarcatória decorria da natureza real do direito: “A ação de demarcação é sempre ação real, porque, mesmo quando quer demarcar imóvel algum possuidor ou alguns possuidores, o direito é real”. Há contradição em relação àquilo que fora afirmado no *Tratado das ações*, vol. VII, p. 350, onde o jurista assinalou que as demarcações seriam pessoais quando se destinassem à aviventação ou substituição de marcos, sendo reais quando seu objeto consistisse no estabelecimento dos limites: “A ação para se aporem marcos é *pessoal*, ao passo que a de *fixação* (ou *retificação*) de limites é real”.

Contrariamente à posição defendida no texto, afirmando que se trata de ação real por ter o direito de propriedade como fundamento, manifestou-se Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 4: “São

reais, porque o direito em questão, tanto num, como no outro caso, é o de propriedade”.

27

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: I – os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram.

28

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. §1.º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I – que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

29

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1.º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

30

Art. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo preventivo estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.

31

Tito Lívio Pontes, *Divisão, demarcação e tapume*, p. 35. O autor defendia a competência do juízo preventivo tanto para as ações de divisão quanto para as de demarcação: “Quer se trate de divisão, quer de demarcação, quer se cogite de cumulação dessas ações, toda a vez que os imóveis em questão estiverem situados em territórios de comarcas ou Estados diferentes, o foro competente é aquele a que primeiro se recorreu para a propositura da ação”.

32

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. § 1.º Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior. § 2.º Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. § 3.º A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo.

33

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 24. Nas palavras do autor: “É proposta por condômino contra condômino, para obrigar à partilha da coisa comum”.

34

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.

35

Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.

36

Sílvio de Salvo Venosa, *Direito civil parte geral*, p. 298: “Resumindo, há que se ter a indivisibilidade *por natureza, por determinação legal e por vontade entre as partes*”.

37

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lance, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lance, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.

38

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de: (...) V – alienação de quinhão em coisa comum.

39

Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência. Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço.

40

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de: (...) V – alienação, locação e administração da coisa comum.

41

STJ, REsp. 7.833/RS, 4ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro, *DJ* 06.04.1992: “Venda de Quinhão em coisa comum. Procedimento. Conteúdo da Oferta. 1. O procedimento previsto nos arts. 1104 e ss. do CPC não é obrigatório ao interessado que deseja alienar o seu quinhão. A comunicação ao condômino pode ser feita através de notificação extrajudicial (...)”.

42

Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural.

43

Art. 8.º. Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art. 65 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixado no § 1.º deste artigo, prevalecendo a de menor área. § 1.º - A fração mínima de parcelamento será: a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas, para os Municípios das capitais dos Estados; b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais Municípios situados nas zonas típicas A, B e C; c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios situados na zona típica D.

44

STJ, AgRg no Ag 37.810/SP, 4ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro, *DJ* 28.02.1994, p. 2893: “Ação de Divisão. Módulo (Art. 65 da Lei n. 4.504, de 30-11-64). 1. ‘É divisível o imóvel rural, se, de um lado, o quinhão pertencente aos autores é superior ao módulo regional e se, de outro, também o são os quinhões somados dos réus, permanecendo estes em comunhão’. (...)”. No mesmo sentido, afirmando que o desmembramento do imóvel deve respeitar o módulo rural, quer ocorra por ato *inter vivos*, quer se dê por ato *causa mortis*, STJ, REsp 36.713, 3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, *DJ* 27.09.1999, p. 93.

45

TJSP, ApCiv 0001329-71.2012.8.26.0246, 8ª Câmara de Direito Privado, rel. Salles Rossi: “Ação de Divisão. Imóvel inferior ao módulo rural. Afronta ao art. 65, *caput* e §1º da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra). Carência da ação corretamente decretada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido”.

46

TJPR, ApCiv 1.409.361-3, 17ª Câmara Cível, rel. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, *DJ* 24.11.2015. Eis a ementa: “Processual Civil. Indeferimento da Inicial. Impossibilidade Jurídica do Pedido (Art. 267, VI, do CPC). Conceito dessa Condição da Ação. Inexistência de Vedação Expressa e em Abstrato no Ordenamento Jurídico Quanto à Dedução do Pedido Perante o Poder Judiciário. Aplicação Restrita. Exemplos. Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5.º, XXXV, da CF). Pedido de Divisão de Imóveis Comuns pelo Condômino. Expressa Previsão no Ordenamento Jurídico (Art. 1.320 do CCB e Art. 946, II, do CPC). Área a Ser Desmembrada que é Inferior ao Módulo Rural da Região. Questão de Mérito. Avaliação quanto à Procedência ou Improcedência da Causa de Pedir de Direito. Teoria Abstrata da Ação. Impossibilidade de Julgamento Liminar de Improcedência da Demanda Fora das Hipóteses do Art. 285-A do CPC. *Error In*

Procedendo. Sentença Anulada, de Ofício, com Devolução do Feito à Origem. Apelação Prejudicada. A possibilidade jurídica do pedido, condição da ação, conforme previsto no art. 267, VI, do CPC, equivale à inexistência de vedação expressa no ordenamento jurídico quanto aos pedidos deduzidos na petição inicial. Por consequência, sua ausência, ou seja, a impossibilidade jurídica estará caracterizada quando houver vedação expressa e em abstrato no ordenamento jurídico em relação ao pedido e causa de pedir em análise”.

47

Calmon de Passos, *Comentários ao código de processo civil*, vol. III, p. 259-260. Nas palavras do jurista: “A impossibilidade jurídica é também uma das formas de improcedência *prima facie*. (...) Pode-se, de logo, concluir, por igual, pela improcedência, quando o tipo de pedido formulado pelo autor é desconhecido pelo ordenamento jurídico a que se reporta. Desconhecido porque vetado expressamente, desconhecido porque nele não prevista solução que agasalhe sua acolhida”. No mesmo sentido, Fábio Gomes, *Carência da ação*, p. 66, baseando-se em lição de Calmon de Passos. Fredie Didier Jr., *Pressupostos processuais e condições da ação*, p. 226, também segue as pegadas de Calmon de Passos, afirmando que a impossibilidade jurídica ensejaria a resolução do mérito, com a improcedência *prima facie* do pedido do autor: “A improcedência macroscópica é apenas a forma mais avultante de improcedência, e, por isso, deveria ser tratada ainda com mais rigor – como já acontece com os casos de decadência legal e prescrição em favor de incapaz. O caso é de improcedência *prima facie*”. Para uma defesa vigorosa das condições da ação e da categoria “possibilidade jurídica”, v. Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. II, p. 301.

48

STJ, REsp 1.291.357/SP, 4ª Turma, rel. Min. Marco Buzzi, *DJe* 26.10.2015: “(...) No exame das condições da ação, considera-se juridicamente impossível o pedido, quando este for manifestamente inadmissível, em abstrato, pelo ordenamento jurídico. Para se falar em impossibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, deve haver vedação legal expressa ao pleito da autora. (...)”. No mesmo sentido, também do STJ, REsp 1.472.941/SC, 3ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, *DJe* 13.03.2015: “(...) 4. A carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido somente é caracterizada pela dedução em juízo de pretensão expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...)”.

49

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 21.

50

Pontes de Miranda, à luz do CPC/1973, em *Comentários...*, p. 410 afirmava que a legitimidade para a propositura de demanda de divisão de bem imóvel recaía exclusivamente sobre os proprietários: “A ação de divisão do ‘bem imóvel’ isto é, da divisão da propriedade imóvel, claro que somente compete ao proprietário”. Advertia, porém, que quando houvesse comunhão poderia haver *pretensão à divisão*, ainda que se não tratasse de divisão da propriedade: “Mas onde quer que haja comunhão, ainda sem ser condomínio, pode haver *pretensão à divisão*, se essa é praticável”. Sob o Código de 1939, Tito Livio Pontes, *Divisão, demarcação e tapume*, p. 61, restringia a legitimidade ativa aos proprietários. Adotando o sentido restritivo, à luz do código vigente, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,

Novo código de processo civil comentado, p. 623: “A legitimação ativa e passiva para a ação divisória pressupõe propriedade (arts. 569, inc. II, CPC, e 1.320, CC). Apenas o proprietário tem legitimidade ativa e passiva para a ação divisória”.

51

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 26-30. O autor destaca que o promissário comprador será parte legítima quando o contrato estiver registrado, houver quitação, imissão na posse e no contrato constarem as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade.

52

Eduardo de Oliveira Leite, *Comentários ao novo código civil*, vol. XXI, p. 713, enfatiza a condição de proprietário do fiduciário: “Na qualidade de proprietário (embora propriedade resolúvel), o fiduciário não é um mero usufrutuário, mas verdadeiro proprietário, enquanto perdura o seu direito”. E sobre as características da propriedade do fiduciário, o jurista acrescenta, na página 717 da obra citada: “A propriedade do fiduciário, como já examinamos, é restrita e resolúvel, não porque lhe seja vedado alienar os bens, mas porque é temporária, porque está submetida à condição resolutiva, e, a todas as alienações que fizer, adere, necessariamente, a cláusula resolutiva, porque ninguém pode transferir mais direitos do que tem”.

53

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 408-409. Textualmente: “A *actio communi dividundo*, que é a nossa ação divisória moderna, pressupõe que o estado de indivisão se dê em coisa singular e não sobre uma universalidade, como se dava igualmente em direito romano. Se a comunhão tiver origem em sucessão hereditária, a ação competente será a *familiae eriscundae* – a nossa ação de partilha –, afastada, aqui, a ação divisória de que trata o Código no art. 946. A natureza e função das duas ações divisórias, a *actio communi dividundo* de que estamos a tratar e a ação de partilha, têm marcantes diferenças entre si. Não é apenas a origem que as distingue, mas igualmente a função. Enquanto a ação de divisão tem por fim extinguir o estado de indivisão, a *familiae eriscundae* nem sempre alcança este resultado. Obtém-se por ela a partilha, mas nem sempre a extinção do condomínio”.

54

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 108, assinalava que a sobrepartilha não significa repetição da partilha, pois se trata de mero complemento: “Enquanto que a ação de divisão pode repetir-se tantas vezes quantas haja uma coisa comum a dividir, a partilha não se repete. (...) A partilha é única, tendo como pressuposto um fato único – a morte – fato que se não repete. A sobrepartilha não infirma a unicidade da partilha. Pode ocorrer algumas vezes na divisão da herança, mas como complemento, ou continuação de uma só e mesma ação. Não é uma ação nova de partilha do mesmo patrimônio deixado pelo *de cuius*”.

55

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 405.

Ver TJPR, Ap. Cív. 327.894-2, 8ª Câmara Cível, Rel. Jorge de Oliveira Vargas, j. 11.05.2006: “I. Ação de divisão. A ação divisória é real imobiliária, para a qual devem ser citados ambos os cônjuges. Aplicação do art. 10, § 1º, I do CPC. II. O processo divisório, para o qual não são convocados todos os condôminos, padece de nulidade 'pleno jure'”. Precedente do STJ. III. Processo anulado de ofício para que se completem as citações. IV. Recurso prejudicado.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 615: “Tanto a ação de demarcação como a ação de divisão são ações dúplices – qualquer um dos confinantes pode pedir a demarcação, qualquer um dos condôminos pode postular a dissolução do condomínio. Qualquer um deles pode figurar indistintamente como demandante e demandado. O direito à tutela do direito é comum a todos os confinantes e a todos os condôminos”. A duplicidade das ações de divisão e demarcação é moeda corrente na doutrina. Dissente da ideia Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 390: “A ação de divisão, proposta por um só, ou por alguns, quando os outros não querem dividir, não é ação dúplice. Os outros não estão a exercer a pretensão de dividir, que lhes compete. Nem se podem ter, indiferentemente, como autor e réu. Repete-se, nos livros, que a ação é sempre dúplice, sem se atentar ao que se passa no terreno das realidades”. Apesar do grande prestígio do autor, trata-se de posição com a qual não se pode concordar, conforme demonstrado no texto.

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 39: “Não se conhece na demarcação, ou na divisão, a extinção do processo por inércia, nome que o Código de 1973 adotou para a antiga absolvição de instância. Como todos os interessados colimam a separação do meu e do teu, qualquer deles pode fazer andar o processo”.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III -por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 408. No mesmo sentido, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 411, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 615. Especificamente sobre a imprescritibilidade da ação demarcatória, Tito Livio Pontes, *Divisão, demarcação e tapume*, p. 33.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 1-2.

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 13-14.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 409-410, assinala que na hipótese de divisão parcial não é necessário que haja acordo entre todos os condôminos, bastando que estejam concordes quanto à indivisão os comproprietários que quiserem permanecer em comunhão.

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 195. Assinalava o autor: “Também é possível fazerem-se a demarcação ou a divisão através de negócio jurídico. Denomina-se a este negócio jurídico de ‘contrato de fixação de limites’, ou de ‘quinhões’. Constitui-se através de uma manifestação de vontade dos proprietários dos prédios confinantes, por meio da qual se estabelecem os limites”. O jurista advertia que a premissa para que fossem celebrados os negócios jurídicos em questão era que todos os interessados fossem maiores e capazes. Anteriormente, já Lopes da Costa, *Demarcação, divisão, tapumes*, p. 43 e ss, manifestara-se pela possibilidade de que os confinantes transigissem desde que fossem capazes. Merece destaque o fato de que o autor tratou do tema em um capítulo designado “Jurisdição Voluntária”. É equivocado atribuir natureza voluntária às ações de divisão e de demarcação em vista da possibilidade de acordo, do mesmo modo como não é correto caracterizar o acordo celebrado extrajudicialmente pelos interessados como jurisdição voluntária. Neste caso, logo se vê, não haveria jurisdição. Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, vol. III, p. 90-91, sustentou a possibilidade de celebração de acordo, com homologação judicial em conformidade com o art. 57 da lei 9.099/1995. Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1466, concedeu prestigiosa adesão à tese de que a homologação judicial de divisões e demarcações seria exemplo de jurisdição voluntária: “A razão, a meu sentir, está com os que defendem a natureza de jurisdição voluntária, *in casu*. O que determina a contenciosidade ou não de um procedimento é o modo com que o juiz interfere no negócio jurídico disputado ou concluído entre as partes. Se é o magistrado quem dita, *ex autoritate*, a solução do conflito, a jurisdição se apresenta como contenciosa. Se, todavia, a participação do juiz é meramente integrativa, para apenas conferir eficácia ao negócio ultimado exclusivamente entre as partes, a hipótese é, sem dúvida, de jurisdição voluntária”. Todavia, a prevalecer esse entendimento, ter-se-ia de concluir que todas as demandas encerradas por acordo homologado judicialmente seriam exemplos de jurisdição voluntária, o que não é correto.

Cândido Rangel Dinamarco, *Ação demarcatória, coisa julgada, ação rescisória*, p. 1586, faz veemente defesa do caráter contencioso da demanda de demarcação: “Com o ato que nessa situação impõe imperativamente às partes o juiz não está simplesmente a *processualizar* algum negócio destas, ou mesmo a encampar formalmente a pretensão da parte autora. Ele decide uma causa autenticamente *contenciosa*, e não meramente voluntária. *Julga*, no sentido próprio em que esse verbo é empregado em direito processual, ou seja, *acolhe ou rejeita a demanda do autor* (CPC, art. 269, inc. I)”.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 33. O autor ainda destaca que a homologação judicial realizada com fundamento no art. 57 da Lei 9.099/1995 leva à formação de coisa julgada, instituto inexistente no âmbito da jurisdição voluntária.

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 256.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 417. No mesmo sentido, Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 27.

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. II, p. 102. Textualmente: “O ato de vir a juízo pedindo tutela jurisdicional, chamado *demanda*, tem por conteúdo uma *pretensão* de quem o realiza. Pretensão é a *exigência de subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio*”.

Poder-se-ia imaginar a cumulação de ações caso se utilizasse o conceito de “ação de direito material”, defendido por Pontes de Miranda e Ovídio Baptista. Haveria, então, cumulação de ações de direito material. Ocorre que esse conceito nunca gozou de unanimidade. Assim, é mais correto mencionar o cúmulo de demandas, não de ações. Para uma crítica ao conceito de ação de direito material, ver Ricardo Alexandre da Silva, *Condenação e cumprimento de sentença*, p. 53 e ss.

Os três elementos identificadores da demanda são indicados no art. 337, § 2.º, do CPC/2015: Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Para uma abordagem precisa sobre o cúmulo objetivo e subjetivo de demandas, com a categorização das espécies de cumulação, v. Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. II, p. 163 e ss. Araken de Assis, *Cumulação de ações*, p. 210 e ss, aborda a cumulação objetiva decorrente do cúmulo de causas de pedir.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 418: “Seria por outro lado desnecessário destacar que, não sendo os confrontantes partes na ação divisória, a legitimidade deles para contestar haverá de limitar-se à ação demarcatória, assim como, em princípio, os condôminos, citados como promovidos, terão legitimidade para contestar apenas a ação de divisão, não sendo réus na demarcatória”.

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 28, refere-se especificamente à atuação dos condôminos na demanda demarcatória: “Cientes da existência do feito, eles, se quiserem, poderão intervir como litisconsortes do autor, ou como coautores, podendo, se lhes aprouver, pleitear outra linha divisória para o imóvel, linha diferente da que o autor pediu”.

75

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 418, percebera essa situação com clareza ao comentar o CPC/1973: “A cumulação, num único processo, das duas demandas faz com que não se possa exigir, como seria necessário, que o promovente descreva detalhadamente as linhas perimétricas do imóvel dividendo, pois a ignorância a respeito de alguma porção desta linha é pressuposto para o cabimento da ação demarcatória, que servirá de procedimento preliminar ao juízo divisório”.

76

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 195; Lopes da Costa, *Demarcação, divisão, tapumes*, p. 43 e ss; Ernane Fidélis dos Santos, *Manual de direito processual civil*, v. III, p. 90-91, sustentou a possibilidade de celebração de acordo, com homologação nos termos do art. 57 da Lei 9.099/1995.

77

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.

78

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

79

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

80

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1646: “Se o caso se resolver por meio de acordo por instrumento particular, o que se torna viável em face dos arts. 842 e 2.015 do CC/2.002, bem como do art. 57 da Lei 9.099/1.995, o negócio jurídico deverá submeter-se à homologação judicial para que possa ser levado ao Registro de Imóveis (Lei 6.015/1.973, art. 167, i, 23)”.

81

Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: I – o registro: (...) 23) dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores.”

82

Art. 3.º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Art. 4.º. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I – os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 410: “Nem haverá, outrossim, necessidade de que os demais condôminos expressem seu assentimento para que o acordo entre aqueles condôminos que eventualmente pretendam permanecer em condomínio seja válido e eficaz”.

Ignorar que o preceito disciplina a hipótese de “cumulação” entre as demandas de demarcação e de divisão pode levar a equívocos graves na interpretação do dispositivo. O grande Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 201, ao analisar o art. 948 do CPC/1973, cuja redação era substancialmente idêntica à do art. 572, partiu da premissa de que o dispositivo se aplicaria às hipóteses em que o autor da demarcatória tivesse ocupado área que não lhe pertencesse. Assim, segundo sua leitura, o dispositivo permitiria que os confinantes que não tivessem cumulado sua resposta com pedido de reintegração de posse, cumulação expressamente prevista no art. 951 do CPC/1973, poderiam fazê-lo posteriormente. Textualmente: “Em sua aplicação, pode-se verificar que o autor da demarcatória ocupava área que não lhe pertencia, não tendo os réus, os confinantes, formulado a queixa de turbação ou esbulho, que se pode também cumular à ação demarcatória, sem lhe desnaturar o procedimento. Como se trata de *actio duplex*, essa possibilidade cabe tanto ao autor como ao réu; e não somente ao autor, como está expresso no art. 951 do CPC. (...) A 2ª parte do art. 948, que alguns autores têm como de difícil inteligência, é, todavia, de meridiana clareza, e se relaciona com o disposto no art. 951 do CPC. É que os confinantes e réus da ação demarcatória que não tiverem cumulado sua pretensão demarcatória com a queixa de esbulho, não perdem o direito de fazê-lo em outro procedimento. Esta ação, através da qual os confinantes vindicam ‘os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro’ tanto pode ser ação possessória como reivindicatória”. O dispositivo, contudo, não trata dessa hipótese, mas do prejuízo causado aos confinantes, ora terceiros, por conta da divisão. Padece de alguma ambiguidade a assertiva de Antonio Carlos Marcato, *Procedimentos especiais*, p. 192, para quem o prejuízo dos confinantes decorreria da demarcação em desconformidade com a sentença proferida na demarcatória: “Pode suceder de os confinantes serem despojados de terrenos em virtude da invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro, ou seja, pela demarcação diversa daquela fixada na sentença já proferida, caso em que a lei lhes ressalva o direito de *reivindicarem* os terrenos dos quais foram despojados pela invasão, ou *reclamarem uma indenização* pecuniária correspondente ao seu valor (art. 948, parte final)”. A passagem pode levar à incorreta conclusão de que os confinantes teriam direito a vindicar ou a pleitear indenização por força de demarcação incorreta, decorrente do desatendimento, no momento de fixação dos marcos, da linha de confrontação definida em sentença. É certo que os confinantes poderão ajuizar ação reivindicatória caso os marcos sejam incorretamente fixados, pois neste caso jamais exerceram posse sobre área que a sentença demarcatória lhes atribuiu. Todavia, o antigo art. 948, como seu congênere, o atual art. 572, não tratam de demarcação errônea, em descumprimento à linha de confrontação definida na sentença, mas da hipótese de prejuízo causado aos confinantes em decorrência da ação divisória que fora cumulado à demarcatória.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 420. O posicionamento do jurista é aplicável ao Código vigente, cujo art. 506 deixa claro que a sentença fará coisa julgada entre as partes, não podendo prejudicar terceiros.

87

Antonio Carlos Marcato, *Procedimentos especiais*, p. 192, refere-se à propositura de ação reivindicatória. Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 420, afirma, com base em Pontes de Miranda, o cabimento de ação possessória, reivindicatória ou, ainda, de embargos de terceiro. Entretanto, Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 423, ao se referir à possibilidade de ajuizamento dessas demandas, leva em consideração o prejuízo causado a terceiros que *não* tenham participado da demarcação: “Se, ao proceder-se à divisão ou à demarcação, se penetra em terreno de terceiro, ou se lhe ofende algum direito real, cabem embargos de terceiro, ou ação possessória, ou reivindicatória, que há de ser proposta contra os figurantes ou contra aqueles a quem coube a parte do terceiro em que se deu a ofensa. É isso o que havemos de entender: a ação de divisão ou de demarcação é *inter alios*, no que possa atingir terceiros”. Pontes de Miranda admitia a propositura de ação reivindicatória, como fica claro em passagem anterior constante na mesma página: “O art. 948 regula a propositura *quando* tenha havido a sentença, e não cerceia a propositura da reivindicatória antes, nem a propositura posterior por invasão que não foi oriunda da demarcação”. Como a invasão a que se refere o art. 572 não ocorreu na demarcação, mas na divisão, conclui-se que para Pontes de Miranda seria cabível a demanda reivindicatória.

88

É o entendimento esposado, com grande rigor técnico, em comentário ao art. 948 do código revogado, por Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 33: “O confrontante, para defender-se de turbação, ou de esbulho efetivo, ou da ameaça de um ou de outra, ocorrido no curso de uma ação de divisão, deverá valer-se dos embargos de terceiro”. Em outro passo, na mesma página, o autor explica que só seria possível intentar a demanda reivindicatória se o confrontante tivesse perdido a posse do imóvel: “É certo que o confinante não poderá ingressar em juízo com a ação reivindicatória, enquanto não perder a sua posse, pois a ação de reivindicação é a ação do dono para pedir a coisa a quem a possua sem justa razão, ou, em outras palavras, é a ação de quem tem domínio da coisa para retirá-la da posse injusta de outrem”. Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 39, afirma que o confinante deverá ajuizar embargos de terceiro, não sendo oportuna a propositura de reivindicatória senão quando o confinante jamais tiver exercido posse sobre o bem: “(...) a invasão praticada não deverá ser defendida por meio de ação reivindicatória (petitória), mas pela via possessória – no caso, a ação de embargos de terceiro – para fazer cessar o esbulho praticado. A ação petitória – reivindicatória – só deveria ser utilizada na hipótese de o confinante jamais ter tido posse da área supostamente invadida por ocasião da divisão de um dos terrenos confinantes; em outras palavras, aquela parte do terreno que deveria caber a um dos confinantes, por força da decisão proferida na ação demarcatória não foi entregue a ele, continuando na posse de um dos condôminos do terreno contíguo, que é o objeto da ação de divisão. Nessa hipótese, a discussão seria sobre o domínio, enquanto na outra, a questão seria de natureza possessória”.

89

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1.º Os embargos podem ser de terceiro

proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2.º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I – o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II – o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III – quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV – o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

90

TJSP, AgIn 0082766-96.2012.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Privado, rel. Percival Nogueira, *DJ* 13.11.2012: “Ação Demarcatória. Pedido de Divisão de Coisa Comum. Irrelevância do ‘Nomen Juris’. A natureza jurídica da ação é definida através do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o ‘*nomen iuris*’ atribuído pela autora. Apesar de a ação ter sido designada demarcatória, o pedido e a causa de pedir contém pretensão divisória. Inépcia da inicial afastada. Decisão mantida. Agravo desprovido”.

91

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 41-42. Na mesma passagem o autor salienta que não há conexão entre a demanda vindicatória e a divisória da qual ela se origina, pois inexistente identidade entre as causas de pedir e os pedidos.

92

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

93

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

94

Art. 125. É admissível a denúncia da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

95

Sob o CPC/1973, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 422, após advertir corretamente sobre a necessidade de denúncia da lide, sustentou equivocadamente a impossibilidade de exercício da demanda regressiva contra os demais condôminos no mesmo processo: “A sentença proferida nestas ações, perante o condômino aquinhado com alguma porção de imóvel pertencente ao proprietário lindeiro, somente valerá como título executivo a seu favor, contra os antigos condôminos, se estes forem chamados à lide como denunciados, nos termos do art. 70, inc. I ou III, conforme a demanda tenha sentido vindicatório ou indenizatório. Observe-se, no entanto, que o *chamamento* do condômino, nesta última hipótese, haverá de ser simples denúncia, para que a ação de regresso se dê em demanda posterior, de

modo que o denunciante se assegure, contra o denunciado, do *efeito de intervenção* (art. 55)”. O ilustre jurista cometeu mais de um erro na mesma passagem. A razão de ser da denunciação da lide é o exercício, no mesmo processo, do direito de regresso. Ademais, a eficácia interventiva, prevista no art. 55 do CPC/1973, relacionava-se, como ocorre ainda hoje (CPC, art. 123), com a figura do assistente simples, não com o denunciado. Por fim, a denunciação da lide, na hipótese em análise, decorre sempre de direito de regresso, o que não justificava a indicação do art. 70, I, do CPC/1973, referente à evicção.

96

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) inc. IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

97

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*, vol. II, p. 764: “Todavia, viu-se que a adequada interpretação do art. 139, inc. IV, do CPC, permite superar essa dicotomia injustificável, concluindo que todas as sentenças contêm executividade intrínseca e permitem a efetiva e plena realização do direito, pouco importando se se trata de prestação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar quantia. O dispositivo mencionado deve iluminar todo o sistema de tutela dos direitos, servindo como marco essencial para as técnicas de efetivação das decisões jurisdicionais. Assim, a técnica dos arts. 523 ss. (ou seja, a execução por expropriação patrimonial) passa a ser apenas uma das modalidades admitidas para a proteção de prestações pecuniárias, que não exclui, nem prefere, qualquer outra modalidade possível. Tudo deve reger-se pelos princípios da maior efetividade para o exequente e da menor onerosidade para o executado, na forma já estudada”. No mesmo sentido, Ricardo Alexandre da Silva, *Atipicidade dos meios executivos na efetivação das decisões que reconheçam o dever de pagar quantia no novo CPC*, p. 564: “O art. 139, inc. IV do NCPC caracteriza uma abertura do sistema à possibilidade de aplicação, inclusive no âmbito da tutela jurisdicional pecuniária, de mecanismos de indução e de sub-rogação, à semelhança do que ocorre em relação aos provimentos proferidos para a tutela das obrigações de fazer ou não fazer por força do art. 536, § 1.º”.

98

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 43. Em sentido contrário, defendendo a possibilidade de exercício de regresso contra o adquirente, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 422.

99

Art. 167, § 3.º Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1.º será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. § 4.º A identificação de que trata o § 3.º tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder

100

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1.467: “Além disso, mesmo existindo ele, pode o conflito surgir por divergência de títulos dos confinantes, tornando, muitas vezes, insuficiente o georreferenciamento para o deslinde da disputa. Portanto, em situações da espécie, somente a prova técnica judicial será o caminho útil para a composição do litígio. É de se pensar também no caso em que os marcos referidos no georreferenciamento tenham desaparecido, o que reclamaria trabalho técnico para aviventá-los ou reconstruí-los”.

101

Desde que tenha havido quitação, imissão na posse, o contrato esteja registrado e contenha as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, conforme assinala Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 29.

102

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

103

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

104

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 258, traz importante distinção sobre a natureza do imóvel e seu reflexo na descrição que cabe ao autor: “Se for rural, indicar-se-á o distrito e município de sua situação. Se for urbano, o nome do logradouro e a numeração do prédio, ou lote, se houver”.

105

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 424: “Diz a lei, neste artigo, que o promovente da ação demarcatória deverá descrever os ‘limites por constituir’, supondo que ele deva sempre saber qual o traçado por onde se cravarão os marcos da futura linha de estremação dos imóveis. Ora, isso, como já vimos, nem sempre é possível e, com frequência, a ignorância a respeito dessa linha é precisamente o pressuposto para o cabimento da demarcatória”.

106

Idem, p. 428: “Nesses casos, o que deverá constar da petição inicial será a minuciosa descrição da área litigiosa, sobre a qual inexistente posse efetiva com utilização econômica de qualquer dos lindeiros, ou haja

posse duvidosa por ambas exercida; nunca a descrição dos ‘limites por constituir’, já que isto seria uma exigência absurda e contraditória: se a demarcatória é promovida *para constituir* os limites, não seria razoável exigir que o promovente os descrevesse na petição inicial”. Nesse sentido se manifestou o TJRS, ApCiv 597053917, 5ª Câmara Cível, rel. Araken de Assis, j. 12.06.1997: “Civil. Demarcatória. Falta de descrição da linha demarcanda. Irrelevância. 1. Admite-se a demarcatória mesmo quando o autor não descrever, minuciosamente, a linha demarcanda (CPC, art. 950), mas indique a área litigiosa, cujos limites devem ser estabelecidos. 2. Apelação provida”.

107

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 258-259: “Realmente, sendo fim do processo a assinalação material de uma linha de divisa entre dois prédios, é necessário que o autor indique qual é a linha que pretende seja traçada materialmente”. E prossegue o jurista, nas páginas 260-261, acrescentando que a inicial não poderá ser totalmente omissa na descrição da linha de confrontação, podendo o autor se limitar ao apontamento dos pontos onde os limites estão confusos: “Se for possível, em função dos títulos ou da posse, indicar pontos da linha, tanto melhor; mas, se não dispuser o autor de elementos para tanto, inepta não será sua petição, desde que dúvida não deixe quanto à sede da disputa de limites. O que não pode é a petição inicial apresentar-se totalmente lacunosa ou ausente quanto à descrição da linha demarcanda. Não se tolera que peça o autor a demarcação apenas indicando o confrontante, deixando ao arbítrio do agrimensor o levantamento de toda a divisa, sem indicar em que ponto está a confusão de limites e em que consiste essa confusão”. Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 431, manifestava idêntico entendimento: “Tem de precisar uma linha divisória, que lhe parece a mais pertinente, para que a contestação e os trabalhos do agrimensor e dos arbitradores se refiram a ela”.

108

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 55-56: “A grande exigência da inicial da demarcatória é a de apresentar o promovente, descrevendo-a, a linha divisória que pretende seja a certa e pede que a sentença a consagre. Não o exime desse dever o fato de ser a ação demarcatória exatamente para fixar a linha entre os dois prédios. Inconformado com a confusão de limites, interessado em desfazê-la, bem como em assegurar a definição de propriedade e a posse plena e exclusiva de tudo o que é seu, é de esperar-se que o promovente, ao pedir a demarcação do seu imóvel, ofereça uma solução para a hipótese, solução que é a colocação da linha divisória nas extremas que lhe convém, ou que lhe pareçam as corretas e legítimas, em conformidade com seus títulos”. O jurista aduzia que a importância da indicação da linha demarcatória era tal, que a omissão do autor ensejaria o indeferimento da inicial: “Essa linha divisória proposta pelo promovente é de grande relevo processual. É tão importante indicá-la e descrevê-la o autor, que a sua falta torna inepta a inicial. É certo que o juiz pode mandar que o autor complete ou emende a inicial (art. 284), mas desatendido, terá de indeferi-la (art. 284, parágrafo único)”. Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 430, também entendia que a omissão do autor levaria ao indeferimento da inicial: “Pode haver dúvidas para o próprio autor ou os autores, mas, de qualquer modo, é necessário que se descreva a linha divisória que parece mais acertada, de acordo com os títulos. Se não a descreve, há inépcia da petição”.

109

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 47: “Caso o autor efetivamente não saiba, não tenha ideia dos limites, deverá indicar como meta para tal demarcação aqueles indicados no respectivo título de

aquisição”.

110

TJRS, ApCiv. 70021835913, 18ª Câmara Cível, rel. Nelson José Gonzaga, *DJ* 23.05.2008: “Apelação cível. Ação demarcatória. Necessidade de citação dos confinantes do imóvel, bem como de individualização dos limites a serem constituídos. Impossibilidade de estabelecimento dos marcos sem observância dos requisitos específicos do procedimento. O procedimento previsto no art. 950 do CPC pressupõe, para o cabimento da ação demarcatória, a realização da citação de todos os confinantes, a fim de lhes possibilitar a apresentação de contestação, no caso de divergirem dos motivos expostos pelo autor. Na petição inicial deverá haver, ainda, indicação do imóvel pela situação e denominação, descrevendo os limites por constituir, aviventar ou renovar. Sem o preenchimento de tais condições, não se mostra possível a demarcação requerida. Negaram provimento ao recurso. Unânime”. No mesmo sentido: TJPR, ApCiv. 465.963-8, rel. José Carlos Dalacqua, *DJ* 04.04.2008: “Apelação cível. Ação demarcatória. Petição inicial. Ausência da descrição dos limites por constituir, aviventar ou renovar. Inépcia. Art. 950, do CPC. 1. A petição inicial da ação demarcatória deve conter a descrição dos limites dos limites a serem constituídos, avivados ou renovados, sob pena de sua inépcia (art. 950, do CPC). 2. Apelação conhecida e não provida”.

111

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 47-48: “Todavia, tal regra não pode ser tida por absoluta, isso porque existem títulos de propriedade registrados nos cartórios imobiliários competentes – notadamente aqueles muito antigos, que não apresentam, ainda que minimamente, a descrição de limites ou de confrontações, ou mesmo de medidas – que muitas vezes indicam somente a metragem quadrada e os principais pontos de referência, como acidentes geográficos, tornando impossível a indicação de uma linha divisória, de forma séria, pelo autor da ação. Nesses casos, é a própria lei que indica os caminhos que deverão ser seguidos para a fixação dos limites e, portanto, da linha divisória: insuficientes que sejam os títulos, marcos ou rumos, os peritos deverão se valer ‘da fama da vizinhança’, das informações de antigos moradores do lugar e de outros elementos que coligirem’ (artigo 957 do Código de Processo Civil). Nessa hipótese, seria impossível indicar, na petição inicial, uma possível linha divisória, uma vez que ela dependeria de elementos que somente serão obtidos no curso do processo. Dessa forma, o requisito previsto como regra para a correção da petição inicial da ação demarcatória seria, na espécie, dispensável, de sorte a garantir o acesso à justiça, e não acarretaria a sua ausência a extinção do processo sem o julgamento do mérito”.

112

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 261: “A divisa, como é lógico, entre dois prédios só pode ser única; absurdo, portanto, seria pretender postular mais de uma linha de confrontação, para uma só divisa”.

113

Ovidio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 424, advertia sobre a impropriedade terminológica contida no art. 950 do Código revogado, substancialmente reproduzido no art. 574 do Código em vigor: “Os confinantes da linha demarcanda são partes, e devem ser citados como réus ou, se quisermos, tendo em vista a natureza dúplice das ações de demarcação e divisão, haverão de ser citados como ‘promovidos’. De

modo que a ‘nomeação’ dos confinantes a que se refere o art. 950 é exigência para a integração do litisconsórcio necessário que se haverá de formar, sob pena de nulidade do processo. Mais compreensivelmente se teria dito que ‘todos os confinantes’ deveriam ser citados e não apenas ‘nomeados’ na petição inicial”.

114

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 13, deixava claro que se a demarcatória fosse parcial não seria necessário demandar contra todos os confrontantes: “Se as divisas estão confusas tão-somente quanto aos prédios de A e de B, não há porque trazer ao processo os outros confinantes com os quais não há problemas de limites”.

115

Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV – o pedido com as suas especificações; V – o valor da causa; VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

116

Art. 319. A petição inicial indicará: (...) VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

117

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil.

118

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. §1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

119

Art. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo preventivo estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.

120

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1473: “Se, durante a pendência da causa, o imóvel passar a pertencer a outra comarca, por redivisão territorial da justiça, ou outro qualquer motivo, a competência também se deslocará, por se tratar de competência *ratione materiae*, não sujeita ao princípio da *perpetuatio*

121

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 618: "Inexistindo interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas, a competência é da Justiça Estadual". No mesmo sentido se manifesta Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1.473: "O juízo divisório, versando sobre terras particulares, é da competência da Justiça dos Estados. Quando, entretanto, a demarcação se dá entre imóvel privado e terrenos públicos, do domínio da União, a competência se desloca para a Justiça Federal (CF, art. 109, I)".

122

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) IV – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.

123

Juliana Cordeiro de Faria, *Breves comentários ao novo código de processo civil*, p. 766, aponta a admissibilidade do valor venal quando inexistirem outros critérios objetivos para a apuração do valor da causa: "O CPC/2015 não reproduziu o mesmo texto. Reputou como sendo a expressão econômica do imóvel e, portanto, aquela a ser observada para indicação do valor da causa, o valor de avaliação do bem ou área objeto do pedido. Todavia, se a parte não dispuser de outros elementos objetivos para definir o valor de avaliação do imóvel, entendemos que ainda continua sendo admissível a adoção da avaliação feita pelo ente tributante. Não há que se exigir da parte a contratação de laudos de avaliação para instruir a inicial, pois a tanto seria onerá-la em demasia diante dos custos envolvidos, além de ser formalismo que dificulta e burocratiza o acesso à jurisdição, contrariando o modelo constitucional de processo". Considerando absolutamente inadequado exigir a avaliação do bem para que haja propositura da demanda, parece que o valor venal segue sendo o elemento objetivo por meio do qual o autor deve se pautar para valorar a causa.

124

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 49-50, demonstrou com grande precisão as dificuldades que decorreriam da valoração da causa em conformidade com o proveito econômico ou com a proporcionalidade em relação à linha demarcanda, na hipótese de demarcação parcial: "Calcular a proporção do valor do imóvel demarcando em função da inclusão de alguns imóveis lindeiros na demarcação parcial se afigura extremamente difícil, do mesmo modo que vincular o valor da causa à totalidade dos imóveis envolvidos na demarcação. Muito menos se poderia falar em benefício econômico que, além de ser difícil de mensurar, não foi o critério adotado pelo legislador".

125

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 434: "Devemos entender que o pedido de restituição do terreno invadido – que se supõe, equivocadamente, pretensão independente e cumulada à demarcatória –, integra a própria ação de demarcação. A alusão a esbulho ou turbação possessória feita pelo art. 951 tem por fim possibilitar a cumulação da ação condenatória de indenização pelos prejuízos decorrentes da ofensa à

posse”.

126

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1468: “O novo Código silenciou-se sobre a matéria, o que não equivale ao veto da cumulação em causa. Continua ela possível dentro das regras comuns de cumulação de ações, já que a demarcatória segue o procedimento comum em seu primeiro estágio”. Concorde-se com o jurista sobre a possibilidade de cumulação de demandas, no âmbito da ação de demarcação, em razão da adoção do procedimento comum, mas a demarcatória já concede a restituição, de modo que não haveria interesse processual em cumular os pedidos.

127

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 199, destacava que a cumulação entre as ações de divisão e de demarcação significava a vitória da prática sobre a teoria processual: “A cumulação da ação divisória com a demarcatória é uma vitória da praxe sobre a processualística brasileira do início do século”.

128

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 223: “Sendo ordinário o rito que a demarcação segue, em sua primeira fase (a fase dita ‘contenciosa’), onde se pode discutir qualquer questão ligada ao domínio ou à posse do imóvel demarcando, natural é que se possa formular pedidos outros, cumulativamente ao de demarcação”.

129

Idem, p. 155, faz referência a processo em que se postulava conjuntamente a demarcação e a nulidade parcial de título do confrontante.

130

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

131

Cândido Rangel Dinamarco, *Litisconsórcio*, p. 85, indica com grande precisão o fundamento do litisconsórcio unitário: “Há situações, dependendo da natureza da relação jurídica controvertida (*res in iudicium deducta*), em que não se pode conceber, mesmo em tese, que os litisconsortes recebam soluções diferentes, no julgamento do mérito; por isso, já no curso do processo, é preciso que eles sejam tratados de forma unitária, para que o instrumento de atuação do direito material não conduza por caminhos diferentes aqueles que não podem chegar a destinos diversos”. O mesmo autor, em *Instituições de direito processual civil*, vol. II, p. 350-351, enfatizou: “Quando todos os litisconsortes estão em defesa de uma só relação jurídica *incindível*, não é possível endereçar a cada um deles um julgamento de mérito diferente. (...) A homogeneidade no tratamento de todos é a essência do regime do *litisconsórcio unitário*”.

132

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

133

Art. 246, § 3.º. Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

134

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 436, sustentava que o litisconsórcio entre os condôminos não seria unitário, pois um deles poderia contestar a necessidade de demarcação ou propor outra linha a ser demarcada.

135

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 619, invocam a incindibilidade da relação jurídica e a consequente uniformidade de tratamento como elementos conducentes à caracterização da unitariedade no litisconsórcio ativo em demanda demarcatória: “O que interessa é que a decisão tem de ser uniforme para todos os litisconsortes – para todos os condôminos –, por conta da incindibilidade da relação jurídica de direito material afirmada em juízo. O litisconsórcio é ativo, necessário e unitário”.

136

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 62: “A disposição deste art. 953 é das mais infelizes do Código. Rompendo com seu próprio sistema de segurança dos processos, com atenção à regularidade e eficácia da relação processual, manda que se faça a citação edital do réu pela exclusiva razão de não residir na comarca. Se o imóvel demarcando se achar situado em mais de uma comarca ou Estado, pode a demarcação ser promovida em qualquer delas, à escolha do autor (art. 107). Basta lembrar isso, para ver-se a quanta maquinação se prestará o preceito”.

137

Art. 246, § 1.º. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

138

Art. 4.º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

139

Art. 5.º, inc. LXXVIII – A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

140

Art. 73, § 1.º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I – que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

141

Art. 256. A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III – nos casos expressos em lei.

142

Art. 259. Serão publicados editais: III – em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos.

143

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

144

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio.

145

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

146

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.

147

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: IV – o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital.

148

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V – o dia útil seguinte

à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.

149

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 263: “Quando a citação ou intimação for eletrônica, corre o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou a partir do término do prazo para que a consulta se dê. É contado a partir do primeiro dia útil subsequente”. No mesmo sentido, Teresa Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo código de processo civil*, p. 399: “Ocorrendo a citação ou a intimação por meio eletrônico, será tida por concluída no dia seguinte à consulta, pela parte, do ato citatório no sistema do tribunal, ou no dia seguinte ao término do prazo para que a consulta ocorra (inciso V do art. 231 do NCPC)”.

150

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1469.

151

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 64-65.

152

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 64.

153

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1476: “No mérito, a contestação pode versar sobre: a) Inexistência do *ius in re* do promovente, ou seja, ausência do domínio ou de outro direito real que autorize a pretensão demarcatória; b) Inocorrência da *confusão de limites*, por estar o imóvel demarcando já perfeitamente discriminado, através de sinais visíveis que o delimitam junto aos confinantes; c) Discordância apenas quanto à descrição dos limites a serem assinalados; d) Ocorrência de *prescrição aquisitiva* sobre a área que se pretende demarcar, de forma a eliminar o direito de propriedade sobre ela, ou a fazer cessar a confusão sobre limites (...)”. Note-se que o jurista insere a titularidade do direito real como matéria concernente ao mérito da demarcatória. Contudo, parece mais adequado relacionar o tema à legitimidade *ad causam*. A questão ilustra a complexidade do assunto e demonstra como são tênues os limites entre a legitimidade para a causa e o mérito.

154

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 65, apreciou o tema com precisão: “É preciso deixar claro que a alegação do réu de que não seria caso de ação demarcatória, sob o fundamento de que os limites então existentes seriam precisos e os terrenos já estariam devidamente demarcados – desde que, obviamente, o autor tenha manifestado, na petição inicial, dúvida quanto a estes mesmos limites – traduz defesa de mérito, até porque, se após a tramitação regular do processo, com a realização da perícia

prevista para a primeira fase (artigo 956 do Código de Processo Civil), o juiz verificar que a alegação do réu é correta, deverá julgar improcedente o pedido de demarcação, ao invés de julgar o processo extinto sem julgamento do mérito por carência da ação. Na realidade, a procedência da ação demarcatória, na sua primeira fase, depende, evidentemente, da necessidade de fixar o traçado da linha demarcanda, seguindo-se, na segunda fase, a concretização, na prática, de tal traçado, com a colocação dos respectivos marcos. Não havendo necessidade de realização da segunda fase, uma vez que a situação do terreno já contempla aquilo que se pretende na prática, a hipótese será de improcedência do pedido, e, portanto, de julgamento de mérito”.

155

Súmula 237. O usucapião pode ser arguído em defesa.

156

STJ, REsp 761.911/PR, 3.^a Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, *DJ* 12.02.2007, p. 259: “Ação demarcatória. Usucapião como matéria de defesa. Momento em que pode ser alegada. 1. A prescrição extintiva pode ser arguida em qualquer fase do processo, mas a prescrição aquisitiva somente tem pertinência como matéria de defesa se arguida na contestação, momento próprio para tanto, sob pena de preclusão. 2. Recurso especial não conhecido”. Há um equívoco no julgado, pois a prescrição extintiva é matéria irrelevante nas demandas demarcatórias, as quais, como já visto, são imprescritíveis.

157

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 66, já advertia, corretamente, para a necessidade de propositura de demanda para que a usucapião ensejasse a declaração de propriedade, sendo insuficiente a defesa alegada no âmbito da ação demarcatória: “Qualquer dos réus de uma ação demarcatória poderá alegar em defesa a prescrição aquisitiva ou a usucapião. Deverá, todavia, promover, por conexão, a ação de usucapião, não bastando a demarcatória, nesse ponto, para que ele possa obter, do ponto de vista legal e formal, o título de domínio da área que sustenta ser seu, com registro próprio junto ao registro geral de imóveis”. Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 211, indicou com precisão os efeitos da usucapião alegada como defesa no âmbito da demanda demarcatória: “A sentença será pela improcedência da ação demarcatória e pelo reconhecimento da existência de usucapião; ou pela procedência em parte da ação demarcatória e da ação de usucapião, se o perímetro demarcado for diverso ou maior do que o da área da qual se arguiu a exceção de usucapião”.

158

Art. 259. Serão publicados editais: I – na ação de usucapião de imóvel.

159

TJRS, ApCiv 70061424156, 17.^a Câmara Cível, rel. Giovanni Conti, *DJ* 23.10.2014: “Apelação Cível. Divisão e Demarcação de Terras Particulares. Ação Demarcatória. Arguição de Exceção de Usucapião. Acolhimento. Em que pese demonstrado através de prova pericial que os réus efetivamente ocupam parte do imóvel dos autores, tal situação fática há muito já se consolidou no tempo, não havendo, pois, ser modificada. Acolhimento da exceção de usucapião arguida como tese defensiva na contestação, considerando a

comprovação por prova oral que os réus exercem sobre parte da área de propriedade dos autores, há mais de 20 anos, posse mansa, pacífica, com animus domini, sem interrupção ou oposição formal, na forma exigida pelo art. 550 do Código Civil de 1916. Manutenção da sentença de improcedência do pedido demarcatório e a extinção quanto aos demais réus. Recurso de Apelação Desprovido”. Colhe-se da fundamentação do acórdão a ideia de que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, mas não possui “força mandamental”, o que inviabiliza a aquisição de propriedade: “(...) Cumpre ressaltar que o acolhimento da exceção de usucapião não possui efeito mandamental, podendo servir como prova emprestada para eventual ação de usucapião, devendo, no bojo desta última, haver angularização plúrima do processo e intervenção do Ministério Público (art. 944 do CPC), considerado que o modo de aquisição da propriedade é originário e, portanto, não há princípio de continuidade dos registros”. No mesmo sentido, destacando que a usucapião é questão prejudicial à demanda demarcatória e exige a propositura de ação específica para suscitar a transmissão da propriedade, TJPR, ApCiv 1300236-7, 17.^a Câmara Cível, rel. Luis Sérgio Swiech, *DJ* 06.04.2015: “Ação demarcatória. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (artigo 269, I, do CPC).1. Adequação da via eleita. Presença de interesse processual dos autores. Ação demarcatória. Cabimento. Existência de controvérsia quanto à linha divisória de três terrenos vizinhos. Impossibilidade de ajuizamento de ação reivindicatória.2. Arguição de usucapião como matéria de defesa. Possibilidade. Questão prejudicial da ação demarcatória. Indispensabilidade de ação autônoma para eventual declaração de usucapião e transcrição no registro imobiliário. Réus que não produziram provas em tal sentido e não alegaram a ocorrência de cerceamento do direito de defesa. Aplicação do artigo 333, II, do CPC.3. Manutenção da distribuição do ônus de sucumbência. Recurso conhecido e desprovido”.

160

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 452: “Pode ser proposta ação de reconvenção, mas há de ser respeitado o prazo legal”. No mesmo sentido se manifestou Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 67: “Além da contestação, a resposta do réu pode conter ainda a reconvenção e exceções (art. 297)”. Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 457, afirmava que a reconvenção poderia ocorrer apenas quando se relacionasse ao pedido de indenização por perdas e danos decorrente de posse injusta: “A não ser nesta hipótese, em que a reconvenção proporia uma demanda condenatória decorrente da situação da posse a ser decidida com a determinação da linha de demarcação, não nos parece admissível o pedido reconvenicional”.

161

Nesse sentido já se manifestava a jurisprudência construída sob o Código revogado, como se vê no seguinte julgado: TJPR, ApCiv 803425-5, 17.^a Câmara Cível, rel. Fabian Schweitzer, *DJ* 22.03.2012. Reza a ementa: “Apelação cível. Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse. Reconvenção. Pedido de usucapião em defesa. Art. 1238 c/c 2028 do Código Civil. Requisitos legais preenchidos. Presença de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Comprovação documental e com conjunto testemunhal idôneo e convincente. Recurso conhecido e desprovido”. No mesmo sentido, TJPR, ApCiv 1019555-0, 17.^a Câmara Cível, rel. Tito Campos de Paula, *DJ* 03.02.2014: “Apelação cível. Ação Demarcatória. Pedido Contraposto de Usucapião Julgado Procedente. Recurso do Autor. Manutenção da Sentença. Preenchimento dos Requisitos do Artigo 1.238 do Código Civil. Comprovado o exercício de posse mansa e pacífica por mais de quinze anos. Linha demarcatória que não foi alterada pela requerida. Negado provimento ao recurso”. Em sentido contrário, sustentando a inviabilidade do reconhecimento de usucapião em reconvenção, TJSP, ApCiv 0002215-91.2011.8.26.0315, 2.^a Câmara de Direito Privado, rel. Neves Amorim, *DJ* 27.01.2014: “Propriedade. Ação

Demarcatória. Autora que alega invasão de seu terreno pela ré. Divergência esclarecida por perícia técnica que conclui que há diferença entre a metragem constante nos registros junto à prefeitura e o alegado pela autora, contudo, a área final do terreno se mantém praticamente mesma, tendo, inclusive, acréscimo. Constatação de que, de fato, a ré utiliza-se de área pertencente à autora, contudo, presentes os requisitos do art. 1238, do CC, acolhido o pedido contraposto da usucapião. Sentença que reconheceu a usucapião e determinou a retificação das matrículas. Impossibilidade. Matéria que só pode ser utilizada para afastar o direito da autora, não podendo ser reconhecida a usucapião e determinada a alteração dos registros, pois necessita das providências adstritas ao processo de usucapião. Sentença modificada para julgar improcedente a ação. Recurso improvido”.

162

Art. 313. Suspende-se o processo: V – quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. § 4.º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

163

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 67, apontava entendimento idêntico sob o Código revogado: “A ação de usucapião, quando promovida concomitantemente com a ação demarcatória, funcionará como prejudicial desta última, pouco importando qual tenha sido proposta em primeiro lugar. Assim, se promovida em juízo distinto, a ação demarcatória deverá ser suspensa até que ocorra o julgamento da usucapião, observado, quanto a isso, o prazo máximo de suspensão previsto no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil”.

164

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; (...).

165

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

166

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (...) II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

167

Paulo Cézar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 68.

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 211, definia a natureza especial da ação demarcatória de forma semelhante: “Dois aspectos específicos denotam o procedimento especial da demarcatória: primeiro, é a inexistência de *actio judicati*, ou seja, a citação para a ação abrange todo o procedimento. E a segunda é a perícia, que se realiza, haja ou não contestação, por um agrimensor e dois arbitradores”. Note-se que o Código vigente, contrariamente ao revogado, não faz especificação sobre a quantidade de peritos.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 443, destacou a possibilidade de produção de prova pericial para o esclarecimento de outras questões: “Não se deve, porém, perder de vista que as operações técnicas encomendadas aos arbitradores limitam-se ao levantamento do traçado da linha demarcanda e pode haver necessidade de produção de prova pericial comum, a ser realizada na fase ordinária da ação, para o esclarecimento de outras questões litigiosas”. Há de se notar que o CPC/1973 exigia, no art. 956, a designação de um arbitrador e de dois agrimensores. A supressão, no novo Código, do número mínimo de auxiliares do juízo, nomeados especificamente para o levantamento da linha demarcanda, reforça a ideia de que sob o Código processual vigente o juiz pode determinar a produção de prova pericial para a resolução de outros pontos controversos. Basta que o perito nomeado para a verificação da linha de confrontação não tenha habilitação técnica para trazer subsídios sobre as outras questões controvertidas, para que o juiz nomeie outro auxiliar com capacidade para tanto.

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I – mostrar-se incontroverso;

Ricardo Alexandre da Silva, *Breves comentários ao novo código de processo civil*, p. 961: “Pedido incontroverso é aquele que não foi especificamente impugnado pelo réu. Haverá pedido incontroverso quando, em caso de cumulação, o réu deixar de impugnar um dos pedidos ou quando o único pedido for passível de fracionamento e o réu impugnar somente parte dele”.

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

175

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

176

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...).

177

Devo essa solução a Anissara Toscan, que apontou com correção e clareza o equívoco do texto original, no qual se defendia a possibilidade de antecipação de efeitos da tutela para o fim de se tutelar a posse. É certo que a restituição da parcela do imóvel esbulhada é um dos efeitos do acolhimento da demanda demarcatória. Entretanto, havendo certeza sobre a propriedade de determinada fração do imóvel, essa área poderá ser tutelada por meio dos interditos possessórios, inexistindo interesse processual na demarcação, justamente porque não há dúvida sobre a titularidade. O desconhecimento do proprietário sobre os exatos limites do imóvel não lhe impede de saber, com precisão, que a partir de determinado marco o bem lhe pertence. Nesse caso, poderá o titular, para repelir a agressão à posse, ajuizar o interdito possessório pertinente.

178

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I – havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

179

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 283-282, apresenta breve descrição das atividades que incumbem a cada um desses peritos: “O trabalho pericial é dividido da seguinte maneira: a) Aos *arbitradores* competirão os estudos de todos os elementos materiais e documentais que possam contribuir para definir o traçado da linha demarcanda, tais como os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros dados que coligirem. (...) b) Ao *agrimensor* compete a elaboração da *planta* da região em que se levantou a linha demarcanda, bem como de *memorial* das operações de campo, onde se descreverá, segundos as regras próprias da agrimensura, o traçado do limite investigado, consoante a conclusão dos arbitradores”.

180

O CPC/1973, no art. 145, § 1.º exigia que os peritos tivessem nível universitário. O art. 156, § 1.º, do CPC não reproduz essa exigência. É certo, contudo, que os peritos deverão ter o conhecimento técnico ou científico necessário para a produção da prova pericial.

Art. 465, § 2.º. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: II – currículo, com comprovação de especialização.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 440, manifestava-se contrariamente à possibilidade de nomeação de assistentes técnicos e indicação de quesitos pelas partes: “O argumento de ser a tarefa de levantamento da linha demarcanda uma espécie de exame pericial não é suficiente para fundar a conclusão de que seu procedimento deva obedecer às regras gerais editadas para a prova pericial”. Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 70, em sentido contrário, defendia a possibilidade de nomeação de assistentes técnicos e de formulação de quesitos: “As partes poderão apresentar assistentes técnicos no prazo do art. 421, §1º. O Código não diz, mas pode haver assistente técnico ao agrimensor e assistente técnico aos arbitradores. Tendo eles funções diferentes no processo e, para exercê-las, sendo reclamadas capacitações díspares, não se pode pretender ou exigir estejam tais capacitações reunidas em um só auxiliar”.

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 282: “Embora nomeados precipuamente para a missão de proceder ao levantamento do traçado da linha demarcanda, aos arbitradores também competirão as funções de fornecer ao juiz quaisquer outros dados técnicos necessários à solução da lide, como os pertinentes à caracterização da área esbulhada, ao cálculo de frutos e rendimentos a restituir, ou prejuízos a indenizar. Tudo, enfim, que se relacione com exames técnicos sobre o imóvel litigioso, deve, em princípio, ficar a cargo do agrimensor e dos peritos nomeados pelo juiz, não havendo razão que justifique a intervenção de outros peritos e a realização de perícias paralelas”.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 444: “Todo o processo de demarcação, assim como as informações geodésicas realizadas na ação divisória, devem compatibilizar os títulos com as dimensões verdadeiras dos imóveis correspondentes”.

Lopes da Costa, *Demarcação, divisão, tapumes*, p. 42.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 441: “Ao distinguir o Código as informações de ‘antigos moradores’ daquelas que possam ser obtidas através da ‘fama da vizinhança’, permitiu que os arbitradores se valham de informações prestadas por pessoas que não mais residam na vizinhança, mas que, por seu especial conhecimento dos imóveis e por sua idoneidade, possam prestar esclarecimentos valiosos sobre os fatos e circunstâncias pretéritas relativamente aos limites entre os prédios e a situação das respectivas posses”.

Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I – a exposição do objeto da perícia; II – a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III – a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV – resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1.º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Art. 1.298. Sendo confusos, os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa; e, não se achando ela provada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles, mediante indenização ao outro.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 74, destaca com acuidade a primazia dos títulos de domínio na definição da linha demarcatória: “A eventual posse por um dos confinantes, quando dissociada do título, não gera qualquer influência na fixação da linha demarcanda, salvo direito próprio à usucapião. É certo, todavia, que a posse poderá ter relevância, caso os títulos não contenham elementos para o traçado da linha demarcanda e não existam, também, outros elementos que possam caracterizar tal traçado”.

Marco Aurélio S. Viana, *Comentários ao novo código civil*, vol. XVI, p. 288. O autor utiliza expressamente a locução “demarcação por partilha da zona disputada”.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 75.

Marco Aurélio S. Viana, *Comentários...*, p. 289. O autor emprega a locução “demarcação por zona disputada”.

195

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 441.

196

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 295: “A sentença pode, é natural, também ser negativa, ou seja, de extinção do processo, o que ocorre quando faltam pressupostos ou condições da ação, ou quando o pedido, no mérito, é improcedente”.

197

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 214.

198

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 439 assinalou que seriam sentenças executivas, apresentando ainda as eficácias declaratória e constitutiva, dependendo do caso: “As ações de divisão e de demarcação são executivas, com eficácias declaratória e constitutiva de menor intensidade, conforme o caso”. Em outra passagem da mesma obra, na página 448, o autor afirmou que a sentença poderia ser declaratória ou constitutiva: “A sentença que encerra a primeira fase da ação demarcatória é preponderantemente declaratória, salvo quando, sendo impossível o estabelecimento da linha de estremação, adjudique o magistrado a um dos prédios o terreno contestado, caso em que o elemento constitutivo passa a preponderar”. Para Humberto Theodoro Jr., *Terras...*, p. 295, a sentença seria declaratória quando se baseasse nos títulos ou na posse do autor, sendo constitutiva quando houvesse demarcação por zona disputada ou demarcação por partilha da zona disputada: “Essa sentença, quando se apoia nos títulos ou na posse dos confinantes, para definir o traçado da linha de divisa, tem natureza predominantemente *declarativa*. Quando, porém, à falta de dados precisos nos títulos e quando ausente a posse, tiver o juiz de resolver o conflito de limites pela partilha ou adjudicação da zona contestada, sua sentença será *constitutiva*, por criar limites novos e impor uma situação jurídica distinta daquela que prevalecia antes do processo”. Também Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 462, sustentava a eficácia declaratória da sentença de demarcação, opinião secundada por Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 18.

199

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 432.

200

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 621: “Como efeito anexo da sentença proferida na ação demarcatória ela determinará a restituição de eventual área invadida e declarará o domínio e/ou a posse da parte prejudicada. Trata-se de efeito anexo da sentença e, portanto, independe de pedido expresso da parte”.

201

Art. 1.258. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção não

superior à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente, também, o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à vigésima parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção.

202

Marco Aurélio S. Viana, *Comentários...*, p. 163: “Se for possível é intuitivo que a indenização do remanescente terá em conta a perda da área que poderia ser construída no lote antes da invasão, e a metragem admitida após a ocorrência desse fato, ou seja, o aproveitamento do espaço. E vamos um pouco mais longe: se o lote não mais admitir utilização pelo dono, porque suas dimensões estão fora das exigências impostas pela legislação respectiva, a indenização deve ser cabal”.

203

Art. 1.259. Se o construtor estiver de boa-fé, e a invasão do solo alheio exceder a vigésima parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido, e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente; se de má-fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro.

204

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.

205

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

206

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

207

Art. 89. Nos juízos divisórios, não havendo litúgio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 177.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 50, formula hipótese esclarecedora sobre o tema: “Assim, caberá a cada confinante o pagamento proporcional da testada da área de sua propriedade por onde passou a linha demarcanda, rateando tal despesa com o autor da ação, e assim por diante. Imagine-se que a linha demarcanda ocupou uma área, em linha reta, de 1.000 m², definindo a propriedade do autor *vis-à-vis* com os demais dez confinantes, cada qual com uma testada de 100 m², nessa mesma linha. Nesse exemplo, caberia ao autor da ação o pagamento de 50% do valor das custas, e às demais partes confinantes, o percentual de 5% para cada”. No mesmo sentido se manifestara Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, 168: “Na demarcação, a partilha dos gastos é em partes iguais para cada um dos confrontantes. Se a linha de divisa compreender, de um lado, diversos confinantes, cada um destes pagará proporcionalmente à sua testada”.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 80: “Dessa forma, se não houver oposição à realização da demarcação, mesmo que cada parte tenha a sua posição própria quanto ao traçado da linha demarcanda, as despesas serão rateadas proporcionalmente à área de cada uma das partes, quando for de demarcação a ação, ou ao quinhão de cada condômino, se for caso de ação de divisão”.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1.º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I – homologa divisão ou demarcação de terras.

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I – corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 81-82, afirmava que a coisa julgada atingia as questões dominiais, restringindo-se às partes do processo: “Mais do que isso, a ação demarcatória possui carga declaratória da propriedade, restrita, obviamente, às partes do processo, e autoriza a restituição da área eventualmente invadida, independentemente de cumulação de pedido reivindicatório. Seria um contrassenso, a brigar com a lógica e com o princípio de acesso à Justiça, que após a fase contenciosa da ação demarcatória – na qual são apresentados os títulos de propriedade de cada uma das partes passíveis de questionamento e, mediante ampla dilação probatória, com a possibilidade de pesquisa à cadeia dominial anterior, oitiva de testemunhas e outros meios, fixados os limites entre duas ou mais

propriedades, com a colocação de marcos, estremando uma da outra, de sorte a caracterizar de forma precisa a propriedade de cada qual –, a decisão não produzisse qualquer tipo de efeito com relação às propriedades demarcadas e às partes que participaram do conflito, ficando a coisa julgada limitada à fixação da linha divisória”. Segundo Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 414, a coisa julgada só atingiria a questão dominial se ela tivesse sido debatida e a sentença decidisse sobre o tema: “É importante observar que a coisa julgada que se formará, seja nas ações demarcatórias, seja nas ações de divisão, em regra não abrange a questão de domínio, salvo se esta for explicitamente controvertida na causa e sobre ele se houver pronunciado a sentença”. No mesmo sentido se manifestava Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 297: “Se a questão dominial foi aventada, se a força do título foi debatida, essas questões, uma vez solucionadas pela sentença de demarcação, ficarão sob o manto da intangibilidade da coisa julgada. Mas, ordinariamente, o que se pede e se discute é tão apenas a fixação dos limites. Posta a causa nestes termos, a *res judicata* emanada do processo demarcatório ficará restrita à linha assinalada nas divisas dos imóveis confinantes. O domínio e outras questões relacionadas com o imóvel demarcado continuarão discutíveis em ações futuras”. Sob o CPC/1939, já assinalava Lopes da Costa, *Demarcação, divisão, tapumes*, p. 145, que a coisa julgada só recairia sobre o domínio quando tivesse ocorrido discussão sobre a matéria: “A sentença que homologa a demarcação faz coisa julgada sobre esta, não, porém, sobre o domínio. Sobre o domínio haverá coisa julgada na sentença proferida na primeira fase, quando tenha havido contestação sobre a propriedade”.

214

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1.º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I – dessa resolução depender o julgamento do mérito; II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. § 2.º A hipótese do § 1.º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

215

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

216

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 78, descrevia os marcos: “Os marcos são pilastras ou postes de ferro, de cimento armado, de pedra lavrada, ou de madeira de lei. São cravados ao solo”.

217

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 301.

218

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 288, traz o conceito de “planta” e de “memorial descritivo”: “A *planta* é a representação gráfica do terreno medido, com indicação de sua posição geográfica e dos acidentes da região. Nela figuram o perímetro e a área do imóvel. Além disso, devem constar da planta

registros de desníveis do solo e de natureza do terreno, bem como construções, valos, cercas, muros, veios d'água e tudo mais que interesse possa ter para caracterizar e assinalar a linha de limites. O *memorial descritivo* é o relatório em que o agrimensor descreve discursivamente o resultado do seu trabalho técnico e explica como procedeu para alcançá-lo, descrevendo, ainda, todos os elementos e dados que esquematicamente ficam registrados na planta”.

219

Art. 4.º. Para os efeitos desta Lei, definem-se: I – “Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;

220

Art. 176, § 1.º A escrituração do Livro n.º 2 obedecerá às seguintes normas: (...) inc. II – são requisitos da matrícula: (...) item 3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação: “a”: se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área.

221

Art. 176, § 3.º. Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1.º será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais.

222

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 288, traz a definição das “cadernetas de operação de campo”: “As *cadernetas de campo* são os cadernos apropriados que o agrimensor utiliza para ir anotando as operações de campo, ao longo de seu trabalho. Representam o histórico fiel e vivo de toda a perícia planimétrica”.

223

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 451, faz crítica incisiva ao excesso de requisitos previstos para o memorial descritivo, afirmando que a minuciosa previsão do conteúdo decorre da disciplina conjunta das ações demarcatória e de divisão: “É evidente que tais indicações serão úteis e mesmo imprescindíveis em certas circunstâncias a uma ação de divisão, mas serão supérfluas para uma ação demarcatória onde se pretenda, apenas, restaurar marcos antigos, já estabelecidos em demarcação anterior. A disciplina comum para as ações de demarcação e divisão, que tem sido uma tradição em nosso direito e que o Código preservou, é a responsável por esses excessos”. No mesmo sentido se pronunciara Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 469: “Algumas das exigências são demasiadas, supérfluas, se a questão se restringe, por exemplo, a se saber por onde passa uma linha de limite”.

224

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 87.

225

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

226

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 450, destaca que o meridiano verdadeiro é obtido a partir do marco primordial: “O *meridiano verdadeiro* é estabelecido, em relação a um determinado lugar – no caso, o lugar onde será fixado o marco primordial –, tirando-se de tal lugar uma linha vertical em direção ao ponto mais alto da esfera celeste, relativa a esse ponto do globo terrestre, e unindo o ponto de incidência dessa vertical aos dois polos da terra, de modo que o meridiano de um determinado lugar é o plano perpendicular à terra que, indo de um polo ao outro, passe por esse lugar”.

227

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 84.

228

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 474.

229

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 90, descreve as possibilidades de atuação das partes: “Nada impede que as partes, por ocasião da impugnação, requeriam diligências complementares, como a inspeção judicial, um novo pronunciamento dos peritos, ou até mesmo a realização de audiência, para a oitiva dos peritos e dos assistentes técnicos”.

230

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 87.

231

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 90.

232

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1.º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas

contrarrazões.

233

Art. 1.015, parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

234

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 623, assinalam expressamente o cabimento de agravo de instrumento: “Eventuais questões suscitadas pelas partes a respeito da correção do trabalho do agrimensor e dos peritos são decididas por decisão interlocutória (art. 203, §2º, CPC). O recurso cabível é o de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC)”. Ao comentarem o art. 592, §§ 1.º e 2.º, na página 625 da mesma obra, dispositivo análogo nas ações divisórias, os autores reiteram o cabimento de agravo de instrumento. Nos comentários ao art. 590, parágrafo único, referem-se expressamente à deflagração de cumprimento de sentença (op. cit. p. 625). Concorde-se com a posição dos autores ao defenderem o cabimento de agravo de instrumento contra as impugnações no âmbito da segunda fase da ação de demarcação, mas isso decorre do art. 1.015, parágrafo único, não do art. 1.015, II.

235

Humberto Theodoro Jr., *Breves...*, p. 1484: “No substituir, porém, a situação de confusão de limites, por uma situação nova, de certeza a respeito dos confins dos dois prédios, o que muitas vezes se faz por meio de partilha e adjudicação, é de se considerar também como constitutiva a sentença que homologa a demarcação, como bem observa Lopes da Costa”.

236

Cândido Rangel Dinamarco, *Ação demarcatória, coisa julgada, ação rescisória*, p. 1589, pronunciando-se sobre o tema à luz do Código revogado, destacou as características da sentença de homologação, enfatizando que se trata de provimento de mérito, rescindível: “Daí a conclusão já adiantada de que a homologação judicial do auto de demarcação (CPC, art. 966) é sentença que julga o próprio litígio entre os proprietários de fundos confinantes. Trata-se portanto de sentença de mérito, de natureza contenciosa e por isso *capaz de obter a auctoritas rei judicatae* (art. 467). Será suscetível, quando presentes os demais requisitos de lei, ao combate pela via da ação rescisória (art. 485)”. Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 478, já havia assinalado que a sentença não seria meramente homologatória, o que traria como consequência sua rescindibilidade.

237

O tema é abordado com maior profundidade nos comentários ao art. 569 do CPC.

238

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 26-30.

239

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 114: “De outro lado, o caráter universal do juízo divisório exige a presença de todos os condôminos. Anula-se o feito se deixar de integrar a relação processual um só condômino, ou o cônjuge de um deles”.

240

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 95: “Nada impede que o autor formule na petição inicial, se estiver munido de elementos suficientes para tanto, o pedido do quinhão que pretende obter com a divisão, expondo as razões para o referido pleito”.

241

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 114, afirmava que a comunhão poderia ter como origem “o direito hereditário, a compra em comum, a permuta em comum, a doação em comum”.

242

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 481: “Têm-se de indicar a causa e a origem da comunhão, porque então se pode saber se existe a pretensão a destacar ou dividir, se depende de algum ato gerador, se depende de alguma cláusula negocial, ou se está sujeita aos efeitos de alguma disposição de última vontade”.

243

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 115: “O inventário das benfeitorias – as comuns e as de cada condômino – tem por fim esclarecer e fundamentar o plano da partilha, permitindo adjudicar ao condômino a benfeitoria que já seja sua e considerar as comuns na composição dos quinhões”.

244

TJSP, ApCiv 0022636-93.2010.8.26.0006, 10.^a Câmara de Direito Privado, rel. Coelho Mendes, *DJ* 16.01.2014: “Coisa comum. Arbitramento de aluguel. Possibilidade. Condomínio. Fruição exclusiva por apenas dois dos coproprietários. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos desprovidos”. No mesmo sentido, também do TJSP, Ap. Cív. 0000907-56.2007.8.26.0607, 10.^a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Garbi, *DJ* 24.10.2013: “Divisória. Imóvel. Condomínio. Uso Exclusivo pelos Réus. Aluguéis Desde a Citação Até Efetiva Divisão. Parcial Provimento do Recurso. O condômino de coisa comum que não exerce posse sobre o bem tem direito de ser indenizado pelo uso exclusivo dos demais coproprietários. Incidência do art. 1.319 do CC/02. A autora tem direito de receber aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pelos réus desde a citação até a efetiva divisão. Precedente desta Câmara. Recurso parcialmente provido”.

245

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 457: “Em tais casos, a jurisprudência tem decidido que o

condômino que possua sozinho o imóvel condominial deve aos demais aluguel pelo tempo da ocupação. Não se deve, porém, equiparar a aluguel a retribuição que o condômino, em tais casos, haja de prestar aos outros consortes. Para que de aluguel ou renda se tratasse, seria mister a existência de uma relação de locação ou arrendamento, o que, por hipótese, inexistente. Além disso, a natureza indenizatória dessa prestação é indiscutível, de modo que, mesmo que se denomine ‘aluguel’ a essa retribuição, o que se concede aos demais condôminos, privados da posse, terá sentido eminentemente ressarcitório, sem qualquer relação ou origem contratual”.

246

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

247

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 620: “O prazo para contestação dos réus começa a fluir da data de juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido (art. 231, I e II, c/c seu § 1º, CPC)”.

248

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 66, analisou a questão sob o CPC/1973, em entendimento que pode ser mantido à luz do Código vigente: “Se forem cumuladas as ações de divisão e de demarcação, posto que esta última deva ser processada antes da primeira como determina o art. 947, a contestação dos réus da ação de divisão, ou seja, dos condôminos, tem de vir aos autos neste prazo de vinte dias do art. 954, que é comum para todos os promovidos em todas as ações”.

249

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 457, restringe a reconvenção à pretensão indenizatória: “A não ser nesta hipótese, em que a reconvenção proporia uma demanda condenatória decorrente da situação a posse a ser decidida com a determinação da linha de demarcação, não nos parece admissível o pedido reconvenicional”. Essa restrição não é correta. Poderá o condômino requerer proteção possessória além do pedido indenizatório.

250

Para maior aprofundamento sobre o tema, remete-se o leitor aos comentários ao art. 569. Na ocasião foi visto que, além do proprietário, poderão ajuizar demanda divisória e figurar como réus o fiduciário, o enfiteuta com consentimento do senhorio direto, o promissário comprador e o herdeiro único.

251

TJPR, ApCiv 1409361-3, 17.ª Câmara Cível, rel. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, DJ 24.11.2015. Nos comentários ao art. 569 foi citada a ementa deste julgado.

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 105. Expõe incisivamente o autor, em texto escrito sob a vigência do Código Civil de 1916 e do Código de Processo Civil de 1973: “O condômino que ocupa, total ou parcialmente, usa e frui. Tem posse, porque tem domínio. Sua presença é normal, é em uso de direito seu. Ele pode, como explicita o Código Civil, art. 623, I, usar livremente da coisa, conforme o seu destino, e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão. Sendo legítima a sua posse e gozo da coisa, para os outros condôminos isso até é uma tranquilidade e uma segurança. Sabem que a propriedade não está abandonada, no sentido de estar despolicada, e que não sofrerá atentados nem usurpações, eis que alguém, com bom direito, a possui e explora, alguém em quem se confia. O que nenhum condômino espera e ninguém admite, é que o consorte possuidor inverta ou altere os títulos de sua posse, pretendendo ampliar ou fazer exclusivo o domínio. Aqui também, como no Direito penal, sua posse era e é legítima, mas a apropriação é indébita, trai a confiança. Não poderia nunca o Direito sancionar tal mudança de títulos”.

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 76, argumenta com grande precisão em favor da possibilidade de arguição da prescrição aquisitiva: “Em outras palavras, enquanto o condômino se funda na sua condição de condômino para possuir o imóvel, jamais poderá haver prescrição aquisitiva perante seus consortes. Se, contudo, o condômino passa a exercer posse exclusiva sobre o bem comum, a título próprio, contrário ao da comunhão, possível será, então, a prescrição aquisitiva, nada obstante a existência jurídica de condomínio. A razão disso está em que, para perfazer o usucapião extraordinário, a lei prescinde do justo título e de boa-fé do prescribente (CC, art. 550)”. Importante destacar que o posicionamento do autor foi externado durante a vigência do Código Civil de 1916.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

258

Marco Aurélio S. Viana, *Comentários...*, p. 97, é enfático ao sustentar que a área de 250 m² pode estar inserida em área maior: “É possível que, em área maior, esteja contida a área de duzentos e cinquenta metros quadrados. Nada impede que a usucapião seja deferida em relação à área menor, embora contida em área maior”.

259

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

260

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 99: “A usucapião ordinária, evidentemente, será incabível, haja vista que o ‘justo título’ que a lei exige revela a sua posição de co-proprietário e, portanto, inconciliável com a pretensão de usucapião, uma vez que a boa-fé não estaria presente. Diversa será a hipótese, se a alegação for de usucapião extraordinário, pois a lei dispensa a existência de justo título e da boa-fé como elementos necessários para autorizar a declaração da usucapião”.

261

STJ, REsp 50.220/GO, 4.^a Turma, rel. Min. Barros Monteiro, *DJ* 10.03.1997, p. 5972: “Ação de usucapião. Divisória anterior, em que não se alegou a ocorrência de prescrição aquisitiva. Coisa julgada inexistente. Não constitui empecilho ao ajuizamento da ação de usucapião o fato de o condomínio haver deixado de arguir, na primeira fase da ação divisória, a prescrição aquisitiva em seu favor. Aplicação do art. 468 do CPC. Recurso especial conhecido e provido”. O aresto não é direto, mas dele se pode depreender a possibilidade de alegação de usucapião no âmbito da demanda divisória. Tanto isso é verdade que se afirma que a omissão do condomínio em alegar usucapião na primeira fase da ação divisória não inviabiliza a propositura de demanda usucapicional. Reconheceu expressamente a admissibilidade da alegação de usucapião o TJSP, ApCiv 0121716-19.2008.8.26.0000, 7.^a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, *DJ* 09.12.2013: “Ação Divisória. Alegação de usucapião em contestação. Admissibilidade. Inteligência da Súmula 237/STF. Réus, entretanto, que não demonstraram estarem presentes os requisitos legais para tanto Apelo desprovido”. No mesmo sentido, admitindo a arguição de usucapião no âmbito de demanda divisória, TJRS, ApCiv 70061496444, 20.^a Câmara Cível, rel. Dilso Domingos Pereira, *DJ* 02.10.2014: “Apelação Cível. Ação Divisória de Condomínio. Exceção de Usucapião. Preenchimento dos Requisitos Elencados no Art. 550 do CC/1916. Ausência de Comprovação de Precariedade da Posse, em Razão da existência de Usufruto Averbado na Matrícula. Em se tratando de posse datada de 1972 e de usucapião extraordinário, aplicável o art. 550 do diploma civil de 1916, mediante o qual devem ser atendidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: posse sem oposição

e ininterrupta sobre o imóvel usucapiendo, com ânimo de dono, por 20 anos. Não obstante se trate de imóvel adquirido em condomínio entre familiares, é incontroverso, nos autos, que o exercício da posse deu-se sempre por um só deles, que realizou benfeitorias na totalidade da área. A tese autoral de que inexistiria posse com *animus domini*, em razão de usufruto gravado em favor de um dos adquirentes originários, não obsta de maneira alguma a exceção de usucapião, mormente porquanto o usufrutuário jamais usufruiu, de fato, do bem. Outrossim, ante o falecimento do usufrutuário em 2006, o que ocasionou a extinção do usufruto. Hipótese em que, à época da arrematação em hasta pública, na qual os demandantes embasam sua propriedade, os requeridos já haviam atingido o prazo prescricional aquisitivo, o que impõe a manutenção da sentença fustigada, que acolheu a exceção de usucapião dos demandados e julgou improcedente o pedido divisório dos autores. Negaram provimento ao apelo. Unânime”. O julgado é interessantíssimo, pois reconheceu a prescrição aquisitiva apesar de haver cláusula de usufruto em favor de um dos adquirentes. Como, *in casu*, o usufrutuário jamais usufruiu do bem, considerou-se, corretamente, que o possuidor exclusivo poderia adquirir propriedade pela usucapião. Também admitindo a alegação de usucapião em ação divisória, indica-se aresto do TJMG, Ap. Cív. 1.0686.06.187068-5/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Lucas Pereira, *DJ* 16.09.2010: “Admite-se a alegação da usucapião como matéria de defesa em uma gama de ações, como na ação reivindicatória, divisória, demarcatória, imissão de posse e até nas ações possessórias, quando nestas a *exceptio domini* é permitida”.

262

Art. 313. Suspende-se o processo: V – quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. § 4.º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

263

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 67. O autor se manifestou, à luz do Código revogado, sobre a ação demarcatória, mas seu entendimento pode ser transposto sem dificuldade para a ação de divisão.

264

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 100.

265

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 461, analisou o tema com grande correção sob o Código revogado: “Ao contrário da ação demarcatória, como vimos ao examinar o artigo anterior, no processo divisório as operações de divisão terão início depois de encerrada, com a sentença de procedência, a primeira fase da ação. Enquanto na demarcatória a sentença do art. 958 já determina a linha de demarcação, reservadas para a segunda fase apenas as operações de campo que irão dar cumprimento ao julgado, lançando no imóvel os marcos determinados pela sentença, no juízo divisório, segundo se depreende dos arts. 968 e 969, os trabalhos de campo, a terem início com a medição do imóvel, começarão tanto que transite em julgado a sentença de procedência da ação”. Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 106-107, afirmava que a decisão de encerramento da primeira etapa da ação de divisão

seria interlocutória, conquanto fizesse coisa julgada: “A decisão proferida na primeira fase da ação de divisão julga parte do mérito da ação de divisão; produz, portanto, coisa julgada material quanto às questões decididas, mencionadas no parágrafo anterior, alcançando as partes do processo, e desafia agravo de instrumento, por ser interlocutória”.

266

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I – mostrar-se incontroverso;

267

TJMG, ApCiv 1.0377.11.001907-4/001, 9^a Câmara Cível, rel. Moacyr Lobato, *DJ* 08.10.2012: “Ação divisória. Pedido da autora acolhido. Pretensão não resistida. Sucumbência. Art. 20 do CPC. Recurso a que se nega provimento. Demonstrada a resistência por parte do réu, bem como o total acolhimento do pedido da parte autora, incontestes serem devidas as verbas sucumbenciais e a condenação em honorários de advogado”. No mesmo sentido, TJSP, ApCiv 0001595-67.2010.8.26.0201, 9.^a Câmara de Direito Privado, *DJ* 03.12.2012: “Ação de divisão. Primeira Fase. Procedência. Inconformismo. Sucessão processual deferida. Adquirente da fração ideal de 85% do imóvel que passou a integrar o polo passivo da demanda. Recurso conhecido. Petição inicial que não é inepta. Apelados que comprovaram a propriedade de 15% do imóvel. Delimitação da área a ser conferida a cada proprietário que constitui objeto da segunda fase da ação de divisão. Correta condenação em honorários advocatícios. Possibilidade de o sucessor processual buscar a composição de interesses com o apelado. Sentença mantida. Recurso desprovido”.

268

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 458: “A relação dominial, na demarcatória, quando controvertida, assim como a relação condominial na ação divisória, integram a *res deducta* das respectivas demandas”.

269

Idem, p. 461: “Embora o Código não mande aplicar à ação divisória o disposto no art. 956, a nomeação dos arbitradores e agrimensor deverá ser feita na sentença que julgar a ação procedente, de modo que, uma vez transita ela em julgado, possam os *experts* prestar o respectivo compromisso”. Observe-se que não há qualquer vantagem na nomeação na sentença se o compromisso somente será prestado no início da segunda fase, depois de esgotado o prazo para as arguições de impedimento ou de suspeição, ou após a rejeição delas. Ademais, como indicado no texto, teria de haver manifestação das partes sobre os honorários periciais. Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 119, na mesma linha, assinalava que a intimação das partes para que formulassem seus pedidos de quinhões poderia ocorrer na sentença: “O provimento de que trata este art. 970, tanto pode estar na sentença que julgar procedente a ação, pondo fim à primeira fase, a fase contenciosa, como em simples despacho ordenatório, ou de movimento. De qualquer modo, é providência posterior à sentença, pois que é o início da sua execução, continuando o procedimento divisório”. Ora, precisamente porque se trata de “providência posterior à sentença”, não faz sentido que seja determinada no ato que finaliza a primeira fase. É bastante claro que jamais caberia às partes, junto com eventual apelo, apresentar pedido de quinhão. Para evitar tumulto processual e assegurar a marcha do processo, há de se entender que a decisão que intima as partes para a

apresentação de títulos, prevista no art. 591, deve abrir a fase executiva da demanda divisória.

270

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 625: “É recomendável que o juiz determine prova pericial – vistoria – no imóvel comum antes de encerrar a primeira fase da ação divisória”. Sob o CPC/1973, Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 460, manifestava o mesmo alvitre.

271

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 420-421, disserta sobre o tema com grande precisão: “O cálculo da divisão, muitas vezes, terá que se ater a essas particularidades, atribuindo benfeitorias indivisíveis, como casa-sede, engenhos, armazéns, currais, pocilgas etc., a um só dos co-dividentes, mediante compensação em terra para os demais, ou mediante reposição em dinheiro. Enfim, o que não se pode deixar de fazer é a partilha igual do ponto de vista econômico, pois, o que, em última análise, se divide, não é a superfície apenas do imóvel, mas principalmente o seu valor econômico”. No mesmo sentido se manifestou o TJSP, ApCiv 0016421-86.2004.8.26.0564, 4.^a Câmara de Direito Privado, rel. Francisco Loureiro, *DJ* 14/07/2011: “Ação Divisória. Sentença que não só reconheceu a divisibilidade do bem como determinou sua partilha. Divisão que, acertadamente, observou o valor dos quinhões, e não apenas suas áreas. Impugnação à partilha baseada no número de condôminos e demais critérios usados pelo perito para avaliação do valor do imóvel e delimitação dos quinhões que não merece prosperar. Agravo retido não conhecido e recurso de apelação improvido”.

272

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 104: “A apresentação de pedido sobre a constituição de quinhão também não é obrigatória. É importante, do ponto de vista prático, que as partes formulem tal pedido, juntamente com as razões que possam sustentar tal pleito, tais como estarem residindo naquele trecho da área, terem efetuado benfeitorias, culturas, etc., de sorte que os peritos, na falta de acordo entre as partes, possam levar em consideração esses argumentos, quando da realização da segunda fase da perícia”.

273

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 462-463, fazia crítica contundente ao art. 970 do CPC/1973, cuja redação era substancialmente idêntica à do art. 591 do Código vigente: “Esta disposição é manifestamente incongruente e tem-se mantido em nossa legislação exclusivamente por força da inércia que seguidamente determina que os legisladores se limitem a copiar as disposições das leis anteriores, sem atentar para seus defeitos e até mesmo para as críticas e restrições que a doutrina lhes tenha oposto”.

274

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 120, demonstra de forma habilidosa que o dispositivo não pode se referir aos títulos dominiais: “Os títulos poderão ser outros, diversos dos títulos de domínio que instruem obrigatoriamente o pedido de divisão e as eventuais oposições a ela. (...) Trata-se, ainda, de provar e de explicitar fatos outros, que não o domínio, eis que esse já foi examinado e resolvido na

primeira fase, a contenciosa. Assim, tem lugar a exibição, agora, por exemplo, dos títulos de aquisição das benfeitorias; a invocação de eventual disposição do testador, ou do doador, ou mesmo do ato de aquisição, mandando se observe determinada localização. A própria posse do condômino é de atender-se, como critério de localização”.

275

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 420: “Se há revéis, o valor será apenas das cotas dos comunheiros que se interessaram pela partilha. O restante continuará em comunhão sobre o que remanescer dos quinhões delimitados para os consortes presentes”.

276

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 625: “Não havendo colisão entre os pedidos, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel; existindo colisão, decidirá, observando os critérios postos no art. 595, CPC. Cuida-se de decisão interlocutória (art. 201, § 2.º, CPC), cujo recurso é o de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC)”. Nos comentários ao art. 590, parágrafo único, os autores fazem expressa referência ao cumprimento de sentença.

277

Clóvis do Couto e Silva, *Comentários...*, p. 237: “Há, no particular, uma certa falta de simetria, pois não se dividem posses, onde este artigo teria sua razão de ser, mas ação divisória tem por finalidade a partição da propriedade, sua transformação em propriedade individual, em nada devendo importar, para esse efeito, a existência de benfeitorias dos confinantes”.

278

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 110: “Nenhum dos condôminos aceitaria, em princípio, ficar com o quinhão que compreendesse benfeitoria levantada por confinante, em razão de todas as consequências que daí podem decorrer, inclusive a eventual perda da área onde a benfeitoria haja sido edificada”.

279

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 465-466: “Como é evidente, todavia, a exclusão da área ocupada por algum confrontante do processo divisório não importa em extinção do direito de propriedade dos condôminos sobre o terreno ocupado por essas benfeitorias. Caberá a eles recuperarem-no em ação própria e, depois, sobrepartilharem a porção que ficou de ficara fora do processo divisório entre os antigos comunheiros”.

280

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 125: “Os quinhões afastados poderão não ter continuidade geográfica, até a área respeitada e reservada. A posterior divisão dessa área até então usurpada, terá de fazer-se pelo seu valor em dinheiro, quando a partilha geodésica se mostrar desaconselhável. Nesse caso,

o condômino que obtiver a área, indenizará os demais quinhoeiros”.

281

Para a análise minudente sobre a inadequação das ações possessórias e da reivindicação, com indicação de doutrina, vide, neste texto, os comentários ao art. 572 do CPC/2015.

282

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*, vol. II, p. 764. No mesmo sentido, Ricardo Alexandre da Silva, *Atipicidade dos meios executivos na efetivação das decisões que reconheçam o dever de pagar quantia no novo CPC*, p. 547 e ss.

283

Sobre o tema, consultar os comentários ao art. 572, § 2.º, neste texto.

284

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 133-134: “Nas divisões, atender-se-á ao valor econômico das coisas partilhadas. Pode-se dizer que a divisão é cada vez menos geométrica, para ser mais econômica. Deixa de ser de áreas, de porções geográficas, para se fazer de valores”.

285

Art. 1.321. Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha de herança (arts. 2.013 a 2.022).

286

Art. 2.017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível.

287

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 117, faz menção aos dispositivos citados do Código Civil, enfatizando ainda a necessidade de que não somente a igualdade econômica oriente a proposta de divisão, mas também a comodidade dos condôminos.

288

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 118: “É evidente que a observância do princípio da comodidade não poderá conduzir a uma absoluta desigualdade entre as áreas e, portanto, entre os futuros quinhões. O referido princípio deverá privilegiar a maioria dos condôminos, e não um ou outro individualmente. Nessa linha, não há como sobrepor um princípio ao outro. O caso concreto determinará aquele que deva prevalecer, caso haja antagonismo entre os princípios a serem observados”.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 123-124: “Feitas as impugnações, o juízo deverá determinar a oitiva dos peritos para, se for o caso, promover as devidas retificações. Em seguida, o juiz poderá permitir novo pronunciamento das partes, ou, ainda, determinar de ofício as provas que entenda necessárias para o seu perfeito esclarecimento, não estando afastada, inclusive, a realização de nova perícia”.

Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 477, ao tratar do tema sob o CPC/1973, afirmou: “O art. 979, I, prevê a hipótese de não comportarem divisão cômoda as ‘benfeitorias comuns’, ordenando que sejam elas adjudicadas a um dos condôminos, mediante compensação. A compensação natural, em tais casos, é a que se dá em terras, atribuindo aos demais condôminos uma área correspondente ao valor das benfeitorias incluídas por inteiro no quinhão de um deles. Mas poderia haver compensação pecuniária”. No mesmo sentido se manifesta Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 122-123. Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 138, afirmava que a compensação deveria ocorrer em dinheiro: “Para compensar o valor de uma benfeitoria, temos a reposição, que será feita em dinheiro, salvo se, de outro modo, dispuserem as partes”.

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 138: “Se couber no seu quinhão, nele ficará, nada tendo de pagar por ela, eis que já era sua. Mas, se, no plano de divisão, deve tocar a outro quinhoeiro, porque não cabe na gleba que tocou a seu dono, terá este direito à reposição. Pagará o quinhoeiro que, em adjudicação, receber a benfeitoria”.

Ovídio Baptista da Silva. *Comentários...*, p. 477: “Havendo a localização dos quinhões criado encravamento a um deles, de modo que seu proprietário necessite transitar pelo interior de outro para atingir a via pública, fonte ou porto, o que a sentença haverá de reconhecer e instituir será o direito de passagem forçada. Servidão de trânsito haverá, por exemplo, se a passagem tiver por finalidade permitir que o dono de um determinado quinhão possa atingir outra gleba que lhe pertença, seja no interior do antigo condomínio, seja em imóvel a este contíguo”.

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 433-434, tratou do tema sob o CPC/1973, com clareza e precisão, apontando o escoamento de águas de um quinhão ao outro como exemplo de servidão natural: “Não se tratando de servidão natural, como a de águas correntes que nascem num quinhão e escoam naturalmente para o de baixo, o quinhoeiro que ficar prejudicado pelas obras e utilização da servidão, instituída sobre suas terras, terá direito a ser compensado pelo respectivo valor, no orçamento da divisão

295

Pontes de Miranda, *Comentários...*, p. 503, afirmava, sob o CPC/1973, que a compensação haveria de ser em dinheiro quando as partes não convencionassem de modo diverso: "O que se há de ressarcir pode ser em terras ou outros bens. Se não chegaram a acordo as partes interessadas, entende-se que a prestação há de ser em dinheiro". Contudo, no tocante às benfeitorias comuns a compensação deverá ser feita preferencialmente por meio de distribuição de terras. O condômino beneficiado com a benfeitoria receberá um quinhão menor, a fim de que seja preservada a igualdade entre os quinhões.

296

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*p. 127.

297

Humberto Theodoro Jr., *Terras Particulares...*, p. 447: "As folhas de pagamento, como o auto, são termos processuais lavrados pelo escrivão, e que devem ser assinados pelo juiz, agrimensor e arbitradores".

298

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 141, enfatizou, sob o CPC/1973, a necessidade de minúcia nas informações presentes nas folhas de pagamento: "Também a folha de pagamento de cada condômino deve conter declarações que ao escrivão não é lícito omitir, sob pena de torná-la imprestável ao fim a que se destina. Devem, por isso, ser organizadas com minuciosa e completa descrição dos limites do quinhão, menção expressa da área atribuída, menção da qualidade das terras, a enumeração dos marcos fincados no terreno, e a declaração de eventuais servidões, onde se dirá em que e como o quinhão é prédio serviente ou dominante".

299

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 448, demonstrou a insuficiência dos requisitos exigidos no art. 980, § 2.º, do CPC/1973, dispositivo reproduzido no art. 597, § 4.º, do Código vigente: "Além dos requisitos do art. 980, § 2º, do Código de Processo Civil, as folhas de pagamento, para atender as exigências do Estatuto da Terra e da Lei dos Registros Públicos, deverão transcrever: 1) o certificado de matrícula do imóvel no INCRA; 2) o número do registro anterior da cota ideal do condômino no Registro de Imóveis; 3) quitações fiscais pertinentes ao imóvel; 4) completa identificação do comunheiro (...)".

300

Pontes de Miranda, *Comentários...*p. 506: "A sentença é executiva e tem efeito constitutivo. Tem força de executividade, à semelhança das outras resoluções adjudicatórias, além da força da coisa julgada formal". No mesmo sentido se manifestou Ovídio Baptista da Silva, *Comentários...*, p. 479: "A sentença que homologa a divisão é preponderantemente executiva, com relevante eficácia constitutiva e declaratória, a ponto de produzir coisa julgada e só poder ser desconstituída por ação rescisória. Quando se diz que a sentença é executiva, está claro que não se pretende significar que ela seja condenatória, a exigir um

posterior processo ‘de execução para entrega de coisa certa’, como frequentemente vem afirmado nos acórdãos”.

301

Humberto Theodoro Jr., *Terras particulares*, p. 450: “A sentença que homologa a divisão é, no plano essencial do procedimento divisório, de natureza *constitutiva*, pois faz extinguir a comunhão, substituindo-a por uma nova situação jurídica para os ex-comunheiros (a de proprietários exclusivos sobre os respectivos quinhões)”. Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 129, também defende a eficácia constitutiva da sentença que encerra a segunda fase do processo de divisão.

302

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 130: “Na segunda fase da ação de divisão em que ocorrerá a formação dos quinhões dos condôminos, salvo se uma das partes provocar incidentes protelatórios ou infundados (artigo 31 do Código de Processo Civil), as custas serão rateadas, não incidindo honorários advocatícios, pois todos terão interesse na partilha do imóvel. Eventuais divergências quanto à formação dos respectivos quinhões não mudarão tal panorama”.

303

Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.

304

Art. 1.316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal.

305

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, *Comentários...*, p. 128-129: “Um dos efeitos que homologa a partilha, entretanto, não poderá ser efetivado desde logo, qual seja, o cancelamento da matrícula da área anteriormente existente e a abertura das novas matrículas correspondentes aos respectivos quinhões dos condôminos. Isso porque a Lei dos Registros Públicos (art. 250, I) só permite o cancelamento do registro após o trânsito em julgado da decisão que tenha autorizado tal medida”.

306

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 628: “Como a sentença homologatória reflete o conteúdo das decisões definitivas de mérito anteriores em que se decretou a extinção do condomínio e se determinou a divisão do bem, em sendo o caso, cabe ação rescisória (art. 966, CPC)”.

307

Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários...*, p. 143: “Estamos diante de uma repetição inútil do legislador”.

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

CAPÍTULO V DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE

1. Introdução

Os sócios permanecem sócios pela vontade. Logo, o sócio não é obrigado a permanecer indefinidamente na sociedade. À vontade de estar e permanecer em sociedade dá-se o nome de *affectio societatis*.¹

Quando a *affectio* termina, encerra-se o elo substancial que existia entre os sócios. Ocorre que o seu término necessita ser formalmente pronunciado ou reconhecido, a fim de que se estabeleça o fim da sociedade, mesmo que de forma parcial, acontecimento imprescindível ao mundo do direito.

Além dos instrumentos adequados para as dissoluções consensuais, a existência de litígio sobre os termos da dissolução pode ser resolvida em juízo, por meio de sentença que ajuste a situação jurídica da sociedade, extinguindo-a total ou parcialmente, e apure adequadamente os respectivos haveres.

A distinção entre a extinção *total* e *parcial* das sociedades é importante.

Quando a quebra da *affectio societatis* engloba a totalidade dos sócios e se extingue totalmente o ânimo de permanecer em sociedade, não há solução senão desconstituir completamente a pessoa jurídica e apurar os haveres devidos a cada um dos ex-sócios. Nesse caso, se dá a dissolução total. O respeito à *affectio societatis* assim é explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.192.726.²

Se conduzida em juízo, a dissolução total se dá por meio de simples proposição de ação constitutiva (e condenatória, na parcela que se refira à apuração dos haveres), que tramita pelo procedimento comum.

O CPC de 2015 não prevê procedimento especial para a dissolução total de sociedade. Trata-se de relevante mudança em relação ao CPC de 1973, que, sem distinguir entre a dissolução total e parcial, remetia expressamente ao procedimento especial de “dissolução e liquidação de sociedade”, então ainda regido pelo CPC de 1939. Tal procedimento, da forma como previsto em lei, visava unicamente a dissolução total da sociedade.³

Agora, por previsão legislativa expressa, não restam dúvidas de que apenas a dissolução total se dará pelo procedimento comum (art. 1.046, § 3.º, do CPC/2015). Para a dissolução parcial, o legislador criou o procedimento especial ora comentado.

Na dissolução parcial de sociedade, há a retirada apenas de um dos sócios, sem que isso implique o encerramento da sociedade. Há uma série de motivos que justificam a dissolução parcial: a saída voluntária de um dos sócios, decorrente da quebra unilateral da *affectio societatis*, ou a exclusão de sócio por falta grave, ou o falecimento. Independentemente do motivo, dissolução parcial resulta no desligamento de um dos sócios, extinguindo sua ligação jurídica com a sociedade, sem a extinção da pessoa jurídica. O termo “dissolução”, aqui, não se refere ao fim da sociedade, mas ao desfazimento do vínculo existente entre a pessoa jurídica e o sócio retirante.

Essa hipótese não encontrava previsão no regramento do CPC de 1939. A lacuna prosseguiu no CPC de 1973, que não inovou na matéria, limitando-se a remeter ao procedimento do CPC de 1939,

novamente sem distinguir entre dissolução total e parcial. A falta foi sentida com mais força a partir de 2002, quando o recém-promulgado Código Civil criou normas de direito material reguladoras da dissolução parcial, que continuava sem correspondência legislativa no âmbito processual. A nova legislação civil não permitia a resolução integral da sociedade em razão da saída de apenas um sócio (CC, arts. 1.033⁴ e 1.034).⁵ Por isso, era inaplicável o procedimento do CPC de 1939, que só fazia extinguir a sociedade como um todo.

Visando sanar essa lacuna, prática jurisprudencial construiu gradualmente a ideia de “ação de dissolução parcial de sociedade”, que tramitava pelo procedimento comum e recebia aplicação subsidiária de algumas disposições daquela ação de dissolução e liquidação de sociedade do CPC de 1939. A “nova” ação era, na verdade, uma roupagem distinta dada a uma ação de rito comum, com posterior fase de liquidação de sentença. A petição inicial continha um pedido constitutivo, de dissolução parcial da sociedade, e um pedido condenatório ilíquido. A liquidação desse pedido se dava com o estabelecimento dos critérios de apuração de haveres, via de regra aqueles definidos no contrato social, e dos marcos inicial e final da apuração. Estabelecidos estes critérios, a próxima etapa era a liquidação dos haveres por arbitramento, com a nomeação de perito. Essa estrutura básica, que se afastava do rito especial previsto no CPC/1939, permitia o cálculo dos valores a serem recebidos pelo sócio retirante sem prejuízo do prosseguimento da sociedade.

Essa evolução jurisprudencial⁶ não passou despercebida pelo legislador. Enquanto a dissolução *total* passou a ser regulada pelo procedimento comum, a dissolução *parcial* de sociedade transformou-se num procedimento especial, criando pequenas adaptações que permitiram a “especialização” do procedimento da dissolução parcial. Em larga medida, a lógica estrutural do procedimento especial se mantém intacta: resolve-se primeiro o pedido constitutivo, nomeando-se perito para calcular o montante exato do pedido condenatório ilíquido.

A previsão de um procedimento especial exclusivamente para a dissolução parcial da sociedade, quando não há equivalente no âmbito da dissolução total, está relacionada à necessidade de conjugar o respeito ao fim da *affectio societatis* ao princípio da *preservação da empresa*, especialmente quando a sociedade em dissolução tem natureza comercial.⁷

A continuidade do exercício da atividade comercial, pela sociedade organizada na forma de empresa, é de interesse geral, por garantir a geração de empregos, a circulação de mercadorias, a arrecadação tributária, o mercado de consumo – enfim, o conjunto de relações a que se dá o nome de função social da empresa. Por isso, quando a quebra da *affectio* se dá em relação a apenas um sócio, não há motivo para encerrar definitivamente as atividades comerciais da empresa. Mais do que isso: se possível for, a dissolução *parcial* da sociedade é sempre preferível à dissolução total, como já decidiu o STJ, no Recurso Especial 1.303.284.⁸

É adequado e recomendável a existência de ferramenta jurídica que possibilite a retirada do sócio de forma rápida e indolor, com a apuração dos haveres do retirante e a continuidade das atividades comerciais. Na dissolução total, por outro lado, esse cuidado é desnecessário, já que a extinção da sociedade é o próprio objetivo da ação.

Apesar dessa importante diferença entre a dissolução total e parcial, alguns juízes, balizados pelo CPC de 1973, não costumavam ver separação conceitual entre as duas, afirmando que a segunda encontrava-se englobada na primeira; assim, não estaria errado o juiz que deferisse uma pela outra, enxergando fungibilidade da dissolução total pela parcial.⁹

Por evidente, o contrário não é aceito – não se pode deferir a dissolução *total* se a parte pediu apenas a dissolução *parcial*. Aí haveria sentença *ultra petita*. O pedido maior engloba o menor, mas não o contrário; ademais, são pedidos diferentes, com causas de pedir distintas (recorde-se que a dissolução total exige pleno desfazimento da *affectio societatis*, enquanto o requisito da dissolução parcial é mais brando).

Assim, o legislador optou por remeter a dissolução total ao procedimento comum, mas criou procedimento especial para regular a dissolução parcial da sociedade. A fim de privilegiar a continuidade da existência da empresa, ao mesmo tempo em que se discutem os termos da saída

do sócio retirante, bem como a apuração dos haveres a ele devidos, desenhou-se um procedimento de natureza bifurcada, que visa resolver parcialmente a sociedade e apurar os haveres, prestigiando a continuidade da empresa.

Essa bifurcação é a principal característica do procedimento especial, cujo objetivo é a resolução parcial da sociedade, num primeiro momento, procedida pela apuração de haveres. Prestigia-se, assim, a liberdade de associação de todas as partes, resolvendo a sociedade – estancando o sangramento por assim dizer, permitindo que tanto o sócio retirante quanto a sociedade continuem exercendo suas atividades de forma independente. Aí sim, num segundo momento, quando resguardados os interesses societários, discute-se o pedido condenatório, de apuração de haveres.

Como é natural em qualquer procedimento especial, há grande proximidade entre as disposições processuais e o direito material tutelado. Por isso, o estudo deste procedimento depende de leitura conjunta do Código Civil, especialmente os dispositivos que se referem à retirada ou exclusão de sócio individual (por exemplo, os arts. 1.028,¹⁰ 1.029,¹¹ 1.030,¹² 1.031¹³ e 1.032¹⁴ do CC, que compõe a seção denominada “*Da resolução da sociedade em relação a um sócio*”). Mesmo assim, percebe-se que o legislador processual acabou criando também disposições de direito material, complementando a lei civil, como nos arts. 605, 606 e 608, dentre outros. Tais disposições não refletem a melhor técnica legislativa, pois confundem o *direito material tutelado* com a *tutela do direito material*. Por isso, diversos dispositivos, especialmente entre os atinentes à fase de liquidação de sentença, nada mudam em relação ao procedimento; seu lugar não é na lei processual.

De fato, afastadas as disposições de direito material, um olhar mais atento à estrutura procedimental da ação de dissolução parcial de sociedade revela as grandes semelhanças que ela guarda com o procedimento comum, a ponto de confundir-se com ele. Despidas todas as disposições legislativas de caráter meramente procedimental, bem como aquelas que se referem apenas ao direito material, o que se revela, no momento da propositura da petição inicial, é uma ação *constitutiva e condenatória*, com a peculiaridade de que o pedido condenatório é ilíquido, por faltarem os parâmetros necessários à sua definição exata. Se a ação tramitasse pelo procedimento comum, a sentença de procedência dissolveria a sociedade (pedido constitutivo) e a condenaria ao pagamento dos haveres ao sócio retirante. A condenação precisaria ainda ser liquidada por arbitramento, por demandar prova pericial (CPC, art. 510),¹⁵ pelo que a sentença deveria obrigatoriamente determinar os requisitos mínimos para a adequada realização da prova – especificamente a data em que houve a dissolução e os critérios a serem utilizados nos cálculos, não por acaso exatamente os requisitos do art. 604.

E o que acontece no procedimento especial? Praticamente a mesma coisa. Há apenas pequenos ajustes procedimentais, como a possibilidade de que os ex-sócios concordem desde logo com a dissolução parcial, permitindo que se avance logo à fase de liquidação, nos termos do art. 603 (o que também seria plenamente possível no procedimento comum, já que as partes podem transigir a qualquer tempo), bem como a *sanção premiativa* do art. 603, *caput* e § 1.º, que incentiva as partes a encerrarem de forma antecipada a etapa dissolutória. Além disso, na fase de liquidação há ordem expressa para que o juiz *determine*, obrigatoriamente, o depósito adiantado dos valores incontroversos (art. 604, § 1.º), bem como permissão expressa para que o juiz modifique, a qualquer tempo, os parâmetros a serem utilizados na feitura da prova pericial, especialmente a data de saída e os critérios de apuração dos haveres (art. 608).

Todas as demais disposições – que, supostamente, construiriam a liquidação de sentença específica do procedimento especial mencionada no art. 603, § 2.º – na verdade são dispositivos de direito material: a obrigação imposta ao juiz de definir quando o retirante saiu da sociedade (art. 605), o critério de apuração (art. 606), a composição da indenização (art. 608). São, certamente, questões aplicáveis unicamente à ação de dissolução parcial de sociedade, mas não por terem caráter processual que as distinga. Obrigatoriamente teriam de ser levadas em contas pelo juiz e pelo perito, mesmo que a ação tramitasse pelo procedimento comum.

Assim, a dissolução parcial de sociedade e o procedimento comum são mais parecidos do que

uma análise superficial levaria a crer. Tal observação é importantíssima, não para criticar a escolha do legislador pela especialização do procedimento, mas para não tratar esta ação como se fosse algo mais complicado do que realmente é – exatamente em razão de sua semelhança com o procedimento comum. A dissolução parcial é composta pela inserção de técnicas processuais diferenciadas dentro do esquema do procedimento comum.

Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I – a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

1. Objetos da ação de dissolução parcial

No art. 599 do CPC/2015, ao tratar do *objeto* da ação de dissolução parcial de sociedade, o legislador definiu os dois tipos de tutela jurisdicional que podem ser obtidos através dessa ferramenta processual. A intenção do legislador é clara: o procedimento deverá ter duas etapas independentes. Primeiro, dissolve-se a sociedade; a seguir, liquidam-se e apuram-se os haveres. Prova de que essas duas etapas foram projetadas para serem independentes é a possibilidade de que a ação contenha só um dos pedidos (art. 599, III).

O inc. I do art. 599 do CPC/2015 delimita desde logo o *objeto* da ação de dissolução de sociedade, suas *hipóteses de cabimento* e a *estrutura bipartida* do procedimento. Cada uma dessas facetas merece ser comentada em separado, sendo que as hipóteses de cabimento merecerão comentário específico em conjunto com o art. 600, que define, de forma mais detalhada, a legitimidade para propositura da ação.

A ação de dissolução parcial se aplica apenas às sociedades *contratuais* e às sociedades *simples*. Neste conceito estão abarcadas as sociedades civis em geral, incluindo a sociedade limitada (um dos tipos mais comuns) e as sociedades não comerciais (associações simples), assim como as sociedades em comandita simples e as sociedades em nome coletivo.

Os outros tipos de sociedade, especialmente aquelas de capital aberto, têm procedimentos específicos, regulados por legislação especial – por exemplo, o regime de dissolução das sociedades anônimas é regulada por lei específica, que não prevê a dissolução parcial. O STJ já havia se manifestado no sentido de que, nessa circunstância, prevalece a disposição da lei específica.¹⁶

Em relação especificamente às sociedades anônimas, porém, tal entendimento veio se metamorfoseando. Anos depois do julgamento originário, o próprio Recurso Especial enumerado acima foi modificado em sede de embargos de divergência, pacificando no STJ o entendimento sobre a possibilidade de dissolução parcial das sociedades anônimas.¹⁷

Esta evolução jurisprudencial encontrou respaldo na jurisprudência. As sociedades anônimas, apesar de possuírem regramento específico, agora podem ser objeto da ação de dissolução parcial na hipótese do § 2.º deste dispositivo (que será comentado com mais profundidade logo a seguir).

A resolução da sociedade é o pedido *constitutivo*, que modifica a situação jurídica da sociedade com a retirada do sócio. É a dissolução parcial propriamente dita. Por se tratar de pedido constitutivo, seus efeitos são *ex nunc*, impactando o mundo real sem retroagir sobre situações jurídicas consolidadas no passado.¹⁸

Esta primeira etapa do procedimento se encerra com a sentença, que define os parâmetros a serem utilizados pelo perito durante a fase de liquidação da sentença.

Além de regular a estrutura e condições do pedido condenatório, o dispositivo em comento também regula as hipóteses de cabimento da ação de dissolução parcial – falecimento de sócio, exclusão do sócio pelos demais, ou retirada da sociedade por interesse pessoal do sócio. Tais hipóteses estão intimamente ligadas à legitimidade para propositura da ação – por óbvio, dependendo da hipótese que conduziu à dissolução parcial, será diferente a parte legitimada para

a propositura da ação. Por isso, e por uma questão de organização, e para evitar repetição desnecessária, preferiu-se realizar os comentários sobre as hipóteses de cabimento juntamente aos comentários ao art. 600, que regula a legitimidade para propositura da ação. Neste momento, o que se estuda é a estrutura bifásica do procedimento.

II – a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

A previsão deste dispositivo deixa claro que sob o manto de “dissolução parcial de sociedade” há uma cumulação de duas ações distintas. Além da dissolução parcial propriamente dita, também tramita pelo procedimento especial o pedido de condenação ao pagamento dos haveres societários devidos ao sócio retirante.

Trata-se de cumulação *própria* e *sucessiva*, quer dizer, o pedido condenatório (de apuração de haveres) só pode ser analisado se julgado procedente o pedido constitutivo. Há impedimento lógico na análise do pedido de apuração de haveres enquanto não for regularmente dissolvida a sociedade; o sócio que não retirou não tem haveres pendentes.

Na verdade, a apuração de haveres resulta do pedido condenatório, necessariamente ilíquido, formulado pela parte autora. A sentença de procedência desconstituirá a sociedade e julgará desde logo procedente o pedido condenatório, ainda ilíquido. Assim, embora à primeira vista o CPC aparente tratá-la como uma etapa processual autônoma, a “fase” de apuração de haveres tem efetiva natureza de *liquidação de sentença*, realizada através da produção de prova pericial, nos termos do art. 510 do CPC.

Como fica a apuração de haveres, porém, na hipótese em que a ação é movida pela sociedade? Pode acontecer nos próprios autos da ação de dissolução, ou a sociedade deverá necessariamente formular apenas o pedido resolutório, aguardando que o sócio retirante exerça a pretensão condenatória, por conta própria, num segundo momento? Esta é, talvez, uma das questões *processuais* mais interessantes propostas pelo presente dispositivo. Via de regra, não se cogita de hipótese em que alguém mova uma ação visando a própria condenação, resultando num título judicial que possa ser executado pelo réu. Esta ação pode configurar exceção a tal regra.

Perceba-se que há duas hipóteses em que a ação de dissolução parcial pode ser movida *pela própria sociedade*, não pelo sócio retirante (incs. III e V do art. 600, comentados a seguir). Claro, nada impede que a sociedade, nestas situações, formule tão somente o pedido resolutório, requerendo a exclusão de sócio da sociedade sem indenizá-lo de imediato. Tal repartição de pedidos é permitida pelo inc. III do presente dispositivo, comentado a seguir; nesse caso, caberá ao sócio retirante pleitear a apuração de seus haveres em ação apartada. É certo, porém, que há situações em que a sociedade preferirá discutir a apuração dos haveres imediatamente. Afinal, não há dúvidas de que o sócio retirante faz jus ao recebimento destes valores, e fatalmente moverá ação autônoma para cobrá-los. Atenta à importância de ter maior controle sobre a situação, a sociedade pode optar por adiantar o inevitável, buscando desde já acertar os haveres na ação de dissolução movida por ela própria. Pode ser mais vantajoso, para a pessoa jurídica, ajustar desde logo os valores devidos, ao invés de aguardar incerta cobrança da dívida em juízo, num futuro distante. Ademais, a inicial acompanhada do pedido de apuração pode vir, inclusive, a facilitar a autocomposição.

Ora, se a apuração de haveres, como já dito, tem natureza de pedido condenatório, o que se pode concluir deste cenário? Poderia a sociedade entrar em juízo para postular a própria condenação?

Esta inusitada situação pode, aparentemente, esbarrar na dicção do art. 18 do CPC,¹⁹ já que a sociedade estaria entrando em juízo para pleitear direito de terceiro. Acredita-se, porém, que esta não é a melhor interpretação, já que a sociedade não está pleiteando direito de terceiro *em nome próprio*, mas adiantando pedido que será fatalmente formulado pelo próprio terceiro, por força da disposição legal. Para evitar a questão processual aparentemente insanável, o paradoxo do litigante que busca a própria condenação, basta enxergar o dito “pedido de apuração de haveres”,

na hipótese, como simples proposta de autocomposição. Esta parece ser a situação mais adequada e alinhada, inclusive, ao *princípio da cooperação* que deve orientar a leitura do novo Código (art. 6.º).²⁰

Adotada tal solução, fica evidente a natureza *dúplice* da ação de dissolução parcial de sociedade, a justificar sua inclusão dentre os procedimentos especiais, por se tratar de cenário incompatível com o rito comum do CPC. Assim, o resultado final da ação poderia ser um título executivo formulado contra a parte autora, permitindo ao réu que prossiga ao cumprimento da sentença em seu favor, se não houver adimplemento voluntário.²¹

Registra-se, porém, ser possível entendimento distinto, que aproxime o rito especial do rito comum: a sociedade não poderia requerer a apuração de haveres na inicial. Caberia ao sócio excluído pleiteá-la, seja por meio de ação autônoma, seja por meio de reconvenção.²² Neste caso, ficaria reafirmada a similitude da ação de dissolução parcial com o procedimento comum, exposta linhas acima.

Destaque-se que este inciso menciona os conceitos de *retirada* ou *recesso*, que serão estudados mais a fundo nos comentários ao art. 600.

III – somente a resolução ou a apuração de haveres.

A primeira parte deste inciso não suscita maiores problemas. Evidentemente, pedir ou não pedir a apuração de haveres é uma decisão estratégica da parte. Ninguém pode ser obrigado a estar em juízo. Se o sócio retirante acreditar que não precisa, ou se não quiser, cumular os pedidos de resolução parcial da sociedade e de apuração de haveres, nada impede que seja formulado apenas o pedido constitutivo. Resolve-se a sociedade num primeiro momento e, respeitados os prazos prescricionais, os haveres poderão ser discutidos em ação condenatória apertada.

Além do mais, o art. 600 prevê diversas situações em que a ação de dissolução parcial pode ser movida pelos sócios remanescentes, e não pelos sócios retirantes (a quem faltaria legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, segundo o art. 18 do CPC). Nesses casos, a ação conterà apenas o pedido de dissolução parcial, cabendo ao sócio excluído buscar seu próprio direito à apuração de haveres em ação autônoma.

É curioso, porém, que o CPC, no inc. III, permita que a ação tenha por objeto *somente* a apuração de haveres. É o caso do sócio cuja retirada foi consensual, devidamente registrada, mas não foi sucedida pela regular apuração de haveres. Tal ação é composta, na verdade, por simples pedido condenatório ilíquido. Tramitava, sob o regime anterior, pelo procedimento comum.²³

Como se percebe do precedente, o manejo de apuração de haveres pelo rito especial ensejaria nulidade (embora, no caso concreto, o STJ tenha – corretamente – entendido se tratar de vício sanável, determinando o aproveitamento dos atos processuais anteriores). Sob o novo regime, o pedido meramente condenatório será submetido também ao procedimento especial. Assim, surgiu a estranha figura da “ação de dissolução parcial” de sociedade já dissolvida, onde se resolve apenas o pedido condenatório.

Quais as diferenças práticas dessa mudança legislativa, para a parte que buscar ingressar com ação de apuração de haveres? Primeiro, é necessário destacar que a “etapa” de apuração de haveres, quando os pedidos dissolutivo e condenatório são cumulados, tem caráter muito semelhante ao de uma simples liquidação de sentença – aliás, o art. 603 fala expressamente na “*fase de liquidação*”, referindo-se à apuração de haveres.

Exatamente por isso, o fato de o CPC lhe permitir autonomia não afasta a necessidade de que haja decisão judicial que defina os critérios de direito material elencados no art. 604 (data da dissolução, critério de apuração de haveres e nomeação do perito), que, independentemente de previsão legislativa, são requisitos lógicos para a realização dos cálculos contábeis indispensáveis à apuração dos haveres. Assim, ao invés de cumular ao pedido condenatório um de natureza constitutiva, o autor que buscar apenas a apuração de haveres deverá realizar pedido declaratório,

a fim de que sejam definidos aqueles marcos enumerados no art. 604 do CPC, sem os quais a realização de prova pericial será absolutamente inócua.

Assim, enquanto a ação que busca a resolução parcial da sociedade somada à apuração de haveres é de natureza constitutiva e condenatória, a ação que busca apenas a dissolução tem natureza apenas constitutiva, e aquela que pretende apenas apurar os haveres devidos terá caráter *declaratório e condenatório*.

É claro que o *nomen iuris* dado à ação é irrelevante; o caráter da tutela requerida pela parte dependerá dos pedidos formulados. Se o pedido for condenatório, pouco importa se o nome dado à ação for “dissolução parcial” ou “apuração de haveres”; a ação continuará sendo uma ação condenatória, e tramitará pelo procedimento especial. Trata-se, porém, de pequena atecnia; melhor seria chamar de *ação de apuração de haveres* ou simplesmente *ação condenatória*, para que, por uma questão de clareza, haja correspondência entre o nome da ação e o resultado final pretendido pela parte. De qualquer forma, essa pequena atecnia não implicaria o não conhecimento da petição inicial, já que são os pedidos que definem a natureza jurídica da ação.

§ 1.º A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado.

O contrato social é documento essencial para a compreensão adequada da lide. Embora a lei traga algumas disposições gerais para a dissolução, a constituição e a desconstituição de uma sociedade são, em último nível, um ato de vontade das partes, regulado por disposição contratual.

O contrato social é o ato constitutivo originário, radiografia da sociedade. Suas disposições regulam e descrevem os termos em que a sociedade foi formada, bem como os critérios que devem ser respeitados quando de sua dissolução. A própria lei, em diversos momentos, remete aos critérios definidos em contrato social para a apuração de haveres do sócio retirante. Para o pagamento dos haveres, o contrato social é a regra a ser seguida; só se admite exceções em casos excepcionais, de manifesta injustiça ou inadequação dos critérios contratualmente definidos.

Em importante precedente, o Min. Luis Felipe Salomão, do STJ, analisou exaustivamente a questão da definição dos critérios de rescisão em contrato social, no Recurso Especial 1.444.790.²⁴

A questão levantada pelo precedente, perceba-se, gira em torno dos requisitos necessários para se afastar a regra do contrato social. Não basta simples desconforto das partes, ou do julgador, com as cláusulas lá manifestadas; até segunda ordem, o contrato social faz lei entre as partes. Qualquer circunstância que possa conduzir ao afastamento das regras do contrato social *depende de comprovação específica*.

Assim, sem a juntada deste documento o juiz não terá condições de julgar a causa adequadamente. Não significa dizer que a inicial que não seja instruída com o contrato social vá ser considerada inepta, ou resultar em julgamento sem resolução de mérito; tal posição seria contrária à principiologia do CPC de 2015, especialmente a vedação à decisão surpresa (art. 10) e a primazia da decisão de mérito (art. 4.º). Trata-se de hipótese clara de aplicação do art. 321: se a inicial não for instruída com o documento essencial, o juiz deverá intimar a parte para que apresente emenda em 15 dias, regularizando a petição inicial e permitindo o regular seguimento do feito.

A previsão de ser o contrato social documento essencial não significa que as partes estejam dispensadas de trazer outros documentos que permitam a adequada instrução da causa. Especialmente importante para a realização da prova pericial relativa à apuração de haveres é a juntada dos documentos contábeis da sociedade, que serão a base para a liquidação do pedido condenatório, de apuração dos haveres.

§ 2.º A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim.

Conforme disposição do inc. I deste artigo, só são passivas de dissolução parcial, via de regra, as

sociedades *contratuais* e *simples*. Já se percebe, aí, grande limitação da aplicabilidade do procedimento, que não serve para regular a dissolução de nenhum outro tipo de empresa, especialmente aquelas de capital aberto. É que a “pedra fundamental” deste procedimento é a ideia de preservação da *affectio societatis*; ora, nos casos em que a estrutura societária se dá de tal forma a dispensar a *affectio*, é evidente que não há o que preservar. Nestes casos, os regimes de dissolução societária são regidos por legislação especial, a depender do tipo de sociedade.

A exceção reside na situação exposta neste dispositivo, que na verdade é reprodução quase literal do art. 206, II, *b*, da Lei das Sociedades Anônimas (6.404/1976), que admite a dissolução judicial de sociedade anônima requerida por acionista(s) que represente(m) mais de 5% do capital social, desde que provem que a sociedade não mais exerce seu fim. Aquele dispositivo era limitado apenas à dissolução total, porém; o CPC de 2015, neste dispositivo, inova por expandir tal hipótese de cabimento também para a dissolução *parcial*.

A configuração do requisito proposto por esse artigo (titularidade de cinco por cento do capital social), segundo o STJ, deve ser auferida na data da propositura da ação. Mudanças no capital social durante o trâmite do litígio, para mais ou para menos, não têm relevância.²⁵

Interessante anotar, como questão paralela ao objeto deste dispositivo, a possibilidade de dissolução parcial das sociedades anônimas de capital fechado estruturadas como entidades familiares, que foi também uma construção jurisprudencial. Acontece que a jurisprudência vinha admitindo a dissolução parcial dessas sociedades, se demonstrada a existência de *affectio societatis* e o funcionamento da sociedade como um núcleo familiar.²⁶

A situação demonstrada nos precedentes aqui relacionados não é a exceção, mas a regra. Embora, na teoria, o modelo de sociedade anônima tenha sido pensado para permitir a operacionalização de grandes empresas, na prática é muito comum ver sociedades que são anônimas apenas no nome, estruturando-se, em todo o resto, como verdadeiras sociedades limitadas.

Nestas situações, a realidade dos fatos – quer dizer, as efetivas condições da organização societária – deve ter prevalência sobre o acerto jurídico dado pelas partes. Se devidamente comprovada, a sociedade fica excepcionada da regra do art. 599, § 2.º. Por óbvio, tal reconhecimento depende de prova específica, e de reconhecimento judicial expresso (decisão com eficácia *declaratória*).²⁷

Trata-se de exceção expressa à regra do dispositivo em comento, pois bastaria provar o fim da *affectio societatis* para acarretar a dissolução parcial, independentemente da participação do sócio retirante, ou de descumprimento do fim social. Acredita-se que o CPC de 2015 não é em nada incompatível com esta construção jurisprudencial, que continuará admitindo tal exceção à regra do dispositivo.

Art. 600. A ação pode ser proposta:

1. Legitimidade

A legitimidade para a propositura da ação de dissolução parcial de sociedade está intrinsecamente ligada à forma do direito material que se visa tutelar.

Assim, os diversos incisos do art. 600 tratam de cada uma das situações possíveis, relacionando a hipótese de cabimento da ação – a *causa de pedir* que deu ensejo ao pedido dissolutivo – com a respectiva legitimação ativa.

Exatamente por isso, falar sobre a legitimidade para propor a ação de dissolução parcial de sociedade exige, também, que se comente o direito material aplicável a cada situação. Como dito nos comentários ao art. 599, serão aqui analisadas, em paralelo à legitimidade ativa, as próprias hipóteses de cabimento da ação de dissolução parcial de sociedade, para então dizer quem é a parte legítima em cada situação. Recorde-se, segundo a redação do art. 599, I, que a ação de

dissolução parcial é cabível quando há falecimento de sócio (legitimidade discutida nos incs. I a III do art. 600), retirada ou recesso (inc. IV) e exclusão de sócio (incs. V e VI).

I – pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade;

II – pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido;

III – pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social;

Os incs. I a III tratam de direito sucessório; relacionam-se, todos eles, às hipóteses do art. 1.028 do CC. Diante do falecimento de sócio, a legislação civil estabelece como *regra geral* a liquidação das cotas societárias do sócio falecido, desfazendo-se o vínculo societário em relação ao espólio do falecido. Em três hipóteses, porém, a legislação material admite solução diversa: na existência de previsão contratual específica (art. 1.028, I); se os sócios restantes optarem pela dissolução total da sociedade (art. 1.028, II); e, por fim, no caso de os sócios sobreviventes negociarem com os herdeiros a substituição do sócio falecido (art. 1.028, III).

As situações que podem convidar a dissolução parcial da sociedade são aquelas descritas no *caput* do art. 1.028 e no seu inc. I; o caso do inc. II é de dissolução total, e na situação do inc. III não há nada a dissolver, pois a sociedade segue hígida. Aliás, o primeiro inciso do dispositivo em comento faz menção direta à situação do art. 1.028, III, do CC: diante da possibilidade de substituição do sócio falecido pelos seus herdeiros, a dissolução parcial só se opera se menos do que a totalidade dos herdeiros optar por ingressar na sociedade. Neste caso, a resolução societária se dará apenas em relação às cotas sociais herdadas pelos sócios que não tiverem interesse em permanecer.

A ação de dissolução, quando não houver previsão em contrário no contrato social, seguirá a regra geral do *caput*: simples dissolução societária com a retirada do sócio falecido e liquidação das cotas em favor dos herdeiros. O procedimento especial se enquadra como uma luva à tal situação; basta uma decisão que desfaça o vínculo jurídico que segue ligando o espólio à pessoa jurídica (dissolução parcial), e defina os critérios para a liquidação das cotas, cuja efetiva apuração dependerá, como de praxe, da produção de prova pericial (apuração de haveres). Na hipótese do inc. I – previsão contratual específica – não há mudanças procedimentais relevantes; subsiste, apenas, a obrigação de que o julgador se atenha aos critérios definidos em contrato social para a apuração dos haveres, salvo se houver prova específica de circunstância extraordinária (abusividade do contrato social, vício do negócio jurídico, ou qualquer nulidade que afaste a regra contratual).

Como nas demais hipóteses, a ação pode ser proposta pelos titulares das cotas sociais retirantes, ou pelos titulares das remanescentes.

Se proposta pelos representantes do sócio falecido, a legitimidade dependerá do estágio em que se encontra a partilha dos bens do *de cujus*: se houver ação de inventário em trâmite, a legitimidade para propositura da dissolução parcial é do próprio espólio, representando pelo inventariante nomeado pelo juízo sucessório. Por outro lado, se já esgotado o inventário e efetivada a partilha, a legitimidade para pleitear a dissolução parcial da sociedade caberá a cada um dos herdeiros, que deverão mover a ação de dissolução em seu próprio nome – seja individualmente, seja em litisconsórcio ativo.

A legitimidade da sociedade, hipótese do inc. III, se inaugura quando os sócios sobreviventes “não admitem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social”. A segunda parte do dispositivo é necessária em virtude da regra geral do *caput* do art. 1.028 do CC – via de regra, o espólio ou os sucessores do falecido não terão direito de ingresso na sociedade, tendo de se contentar com a liquidação das cotas em seu favor. Na hipótese, porém, de tal direito lhes ser assegurado pelo contrato social, caberá aos sócios sobreviventes litigar pela dissolução parcial da sociedade, se não tiverem interesse nessa

substituição societária. Inaugura-se, assim, sua legitimidade, nos termos do inc. III do dispositivo comentado.

Processualmente, de toda forma, questão que suscita interesse – especialmente na hipótese do inc. I, quando a dissolução parcial é manejada pelo espólio, representado pelo inventariante – diz respeito à competência para o manejo da ação de dissolução parcial de sociedade, tendo em vista a existência de inventário judicial. Haveria prevenção para o juízo sucessório julgar a dissolução, que diz respeito aos interesses do espólio?

Tem-se que a limitação horizontal da cognição na ação de inventário, limitada à descrição e partilha dos bens do espólio, não permite maior aprofundamento nas questões societárias. Assim, em virtude da limitação procedimental, o juiz que despacha o inventário não se torna prevento para julgar a dissolução parcial de sociedade, que exige extensa dilação probatória, especialmente para a liquidação da sentença.²⁸

Ultrapassada a questão da legitimidade, a situação não traz maiores peculiaridades; seja movida pelo espólio, pelos sucessores ou pela sociedade, a ação de dissolução seguirá o rito especial.

IV – pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito;

No dia a dia das relações societárias, é natural que a *affectio societatis* se rompa, como dito linhas acima. Os direitos de *retirada* ou de *recesso*, a que se refere o dispositivo, são institutos de direito material que regulam hipóteses de rompimento da *affectio*. À primeira vista, poderiam ser vistos como sinônimos; a luz da disposição específica do art. 605, II e III, porém, é possível concluir que o legislador diferenciou os conceitos tendo por base a existência ou inexistência de motivação legal para a saída da sociedade: a *retirada* seria a saída imotivada, regulada pela primeira parte do art. 1.029 do CC, enquanto o *recesso* representaria a saída motivada, regulada pelo art. 1.077 (ambos os dispositivos serão reproduzidos e comentados a seguir).

O direito de retirada, na verdade, advém da própria Constituição. Vincula-se à previsão do art. 5.º, XX, da CF, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.²⁹ Tal direito foi inicialmente regulado pela Lei 6.404/1976, cujo art. 137³⁰ regulava a hipótese de saída de acionista de sociedade anônima, mediante reembolso das ações, quando o sócio em questão discordava de determinadas decisões tomadas pelos demais acionistas. As decisões que ensejam o direito de retirada vinham expressamente previstas no art. 136, I a VI e IX, da mesma lei: a criação de ações preferenciais (I), alterações nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de classes de ações preferenciais (II), redução do dividendo obrigatório (III), fusão da companhia (IV), participação em grupo de sociedades (V), mudança do objeto da companhia (VI) ou cisão da companhia (IX).

Todas as hipóteses representam decisões administrativas importantes. Se forem tomadas por maioria do capital social, à revelia de determinado sócio que tenha boas razões para discordar delas, é bem possível que gerem a quebra da *affectio societatis* em relação ao sócio discordante, que deixa de ver bons motivos para continuar em sociedade sob as novas condições ajustadas. Dessa circunstância decorre o direito de recesso, que nada mais é do que uma *retirada motivada* do sócio que discorde de determinadas decisões administrativas tomadas pela sociedade.

A lei das sociedades anônimas inspirou o legislador reformista durante a elaboração do Código Civil, que trouxe o direito de retirada como uma possibilidade para todos os tipos de sociedade. Acresceu-se as hipóteses de retirada motivada, da lei da sociedade anônima, também a retirada simples, sem motivo expresso. Está nos arts. 1.029³¹ e 1.077³² do Código Civil, que preveem a possibilidade de retirada, com ou sem motivo.

A retirada sem motivo é aquela prevista no art. 1.029. Possibilita ao sócio que comunique sua intenção de sair do grupo societário por meio de simples notificação aos demais sócios, devendo

respeitar prazo mínimo de sessenta dias entre a data da notificação e a efetiva saída. Esta é a *retirada motivada* a que o legislador se refere no art. 605, II. Enviada a notificação aos demais sócios, a regra do parágrafo único permite que a sociedade, em até trinta dias do recebimento da notificação, opte pela dissolução *total* da sociedade.

A exceção são as sociedades por prazo determinado, em relação às quais não se tolera a saída imotivada sem que haja comprovação judicial da ocorrência de justa causa – conceito que é deixado propositalmente em aberto pelo legislador, devendo ser preenchido à luz de cada caso concreto.³³ O art. 605, IV, chama esta hipótese de *retirada por justa causa*.

Já o art. 1.077 prevê situação análoga àquela da lei das sociedades anônimas: a saída de sócio em decorrência de discordância com decisão administrativa. É o que acontece quando há modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra. O sócio dissidente poderá, nos trinta dias subsequentes à reunião, retirar-se da sociedade. O art. 605, III, chama este direito de *direito de recesso*. A saída e liquidação e suas cotas se darão na forma do art. 1.031 do CC.³⁴ Aqui, o direito de recesso é *motivado*, sendo prescindível o prazo de sessenta dias entre a comunicação da intenção de retirada e a efetiva dissolução parcial. A data de saída coincidirá com a manifestação da vontade de retirada motivada.

A partir do momento em que efetivada a saída do sócio da sociedade – ou seja, sessenta dias após a notificação, no caso de saída imotivada de sociedade com prazo indeterminado, ou no momento em que se efetiva a saída motivada – o CPC concede aos sócios remanescentes o prazo de dez dias para protocolar, no órgão competente, a alteração do contrato social que efetive juridicamente a retirada. Desrespeitado esse prazo, e apenas nessa hipótese, surge a possibilidade do manejo da ação de dissolução parcial de sociedade.

Assim, em qualquer caso a ação será manejada pelo sócio retirante. Aqui não faz sentido pensar em legitimidade da sociedade, pois a própria hipótese de cabimento pressupõe ter havido desinteresse da sociedade no protocolo tempestivo da documentação que daria efetividade à retirada. Cabe ao sócio, que pretende afirmar juridicamente sua intenção de saída da sociedade, afirmar tal direito através do manejo da ação de dissolução parcial.

Importante perceber que, nesta situação, a data de saída da sociedade não tem qualquer relação com a sentença da ação de dissolução. Na verdade, a ordem judicial deverá retroagir até o momento em que efetivamente se deu a retirada, no passado. A apuração de haveres deverá ser acrescida de encargos moratórios, desde a data real da retirada ou recesso, até o efetivo pagamento; e, para a base de cálculo dos haveres, deverá se adotar como critério a situação financeira da sociedade no momento em que efetivamente ocorreu a retirada. Do contrário, qualquer flutuação financeira posterior, para mais ou para menos, poderia beneficiar indevidamente alguma das partes (o sócio retirante ou a própria sociedade, respectivamente), configurando seu enriquecimento ilícito.

V – pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou

VI – pelo sócio excluído.

Situação diametralmente oposta à anterior. Aqui igualmente há um conflito de vontades que tem como consequência a quebra da *affectio societatis*; a diferença é que a iniciativa da dissolução parcial parte não do sócio que pretende se retirar, mas da própria sociedade, que pretende excluí-lo.

Assim como a retirada, a exclusão é instituto de direito material. Não pode a sociedade excluir sócio a seu bel prazer; as hipóteses em que tal situação é possível estão exaustivamente previstas em lei, embora configurem cláusulas abertas. É preciso que se observem determinadas condições. Para que possa se dar a exclusão, é preciso, primeiro, que haja previsão contratual sobre as razões que a ensejam, e o procedimento a ser tomado neste caso. Se for verificada prática de atos que prejudicam a continuidade da empresa, é possível falar em exclusão do sócio. Para tanto, deve haver reunião ou assembleia extraordinária, convocada especificamente para o fim de deliberar a

exclusão, para a qual o sócio cuja exclusão será deliberada deve ser convocado especialmente. Nesta reunião, a exclusão só será efetivada de mais de metade do capital social deliberar nesse sentido.

Todo esse procedimento é previsto nos arts. 1.004, parágrafo único,³⁵ 1.030,³⁶ 1.031³⁷ e 1.085³⁸ do CC. Chama atenção, claro, a abertura do conceito de “falta grave” que dá ensejo à exclusão. Trata-se de cláusula propositalmente aberta, que dependerá do contexto societário e da deliberação dos sócios. Mesmo assim, há algumas previsões específicas: por exemplo, o parágrafo único do art. 1.004 classifica como falta grave a mora no pagamento das contribuições estabelecidas em contrato social, dizendo expressamente que seu descumprimento poderá resultar na exclusão.

Não sendo possível a via administrativa, a exclusão do sócio poderá ser feita judicialmente, na forma do art. 1.030 do CC, que institui como requisito a necessidade de que a ação seja proposta pela maioria dos sócios, que deverão comprovar o cometimento da falta grave (a mesma “falta grave” que ensejaria a exclusão administrativa), ou a capacidade superveniente do sócio a ser excluído. Este pedido costumava tramitar pelo rito comum, mas agora será submetido ao rito especial em discussão.

Quando se fala em “falta grave”, tanto para fins da exclusão administrativa quanto a judicial, quer-se dizer que há mais em jogo aqui do que simplesmente a *affectio societatis*. Um sócio não pode ser excluído simplesmente porque os demais perderam interesse em sua continuidade na sociedade; é preciso que o comportamento do sócio excluído seja tão grave que esteja colocando em risco a própria existência da sociedade.³⁹ A diferença sutil entre os dois conceitos já foi tratada pela jurisprudência do STJ, no Recurso Especial 1.129.222.⁴⁰

O STJ vem tratando a exclusão de sócio como situação distinta da dissolução parcial. Tal distinção, pelo menos no aspecto processual, não sobrevive ao novo Código, que submete todas essas situações ao mesmo rito especial, indistintamente. Obviamente as situações continuam sendo diferentes do ponto de vista do direito material, mas o tratamento processual da matéria segue hígido. Como exemplo do antigo entendimento, observe-se o REsp 917.531.⁴¹

De toda forma, é importante perceber que a exclusão do sócio não lhe retira o direito de que sejam apurados e recebidos os haveres societários. Tais haveres poderão ser compensados de eventuais dívidas que o retirante tenha para com a sociedade; mas os direitos patrimoniais do sócio excluído não são simplesmente desconsiderados em razão do cometimento de falta grave. É o que diz o art. 1.031, que regula a apuração de haveres no caso da exclusão de sociedade.

O sócio excluído continua tendo direito a haveres de todas as naturezas, incluindo o fundo de comércio societário.⁴²

Destaque-se que, assim como acontece na retirada, a exclusão de sócio não pode retirar em enriquecimento ilícito para nenhuma das partes, pelo que se considera como data da exclusão o exato momento em que a sociedade se resolve para o sócio retirante. Os haveres deverão ser calculados a partir de um *retrato* exato do patrimônio da sociedade neste momento, não apenas no momento em que realizada a liquidação. Assim, será possível garantir que eventuais flutuações patrimoniais não beneficiem ilicitamente nenhuma das partes.

Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio.

A situação do parágrafo único do dispositivo não suscita maiores dúvidas; trata-se de inovação simples, mas bastante eficaz, do legislador codicista. Se ocorrer separação ou divórcio envolvendo um dos sócios, e se esta união fosse regulada por determinados regimes de bens em que há comunicação de propriedade, é possível que o ex-cônjuge, ou ex-companheiro, tenha direito a uma parcela das cotas sociais.

Nesses casos, o que o Código faz é permitir que a ação de dissolução parcial seja proposta diretamente pelo ex-companheiro, que buscará a liquidação das cotas que lhe pertencem, em seu favor. Nem sequer seria necessário, mas o CPC faz bem ao ressaltar o óbvio: na hipótese, o único sócio que terá de arcar com essas cotas será aquele que se separou. O restante dos sócios não tem qualquer relação com o autor da ação, neste caso.

Destaque-se que a propositura desta ação não retira competência do juízo de família. Não caberá ao juízo da ação de dissolução parcial declarar existência de união estável, declarar divórcio ou tomar qualquer outra medida que originalmente coubesse ao juízo de Família; por isso, é importante que tais questões já estejam devidamente resolvidas antes de ser proposta a ação de dissolução com base neste dispositivo.⁴³

Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação.

1. Litisconsórcio passivo necessário

Aqui o legislador determinou a obrigatoriedade de participação dos sócios e da sociedade no polo passivo da lide, tanto no que tange à dissolução parcial quanto no que tange à dissolução total, pois indivisível a relação jurídica analisada.

O importante, portanto, é que na dissolução parcial a sociedade participe do processo juntamente com os sócios. Trata-se de mudança que refletiu entendimento jurisprudencial antigo, no REsp 44.132.⁴⁴

Há décadas, portanto, os tribunais já reconheciam a necessidade de que a pessoa jurídica compusesse a relação processual. Afinal, é o patrimônio da sociedade que responderá integralmente pela dívida, salvo na excepcional hipótese de desconsideração da personalidade jurídica; necessário, assim, que lhe seja efetivado o contraditório.

Mais recentemente, tal entendimento já havia evoluído no sentido de enxergar mesmo a ocorrência de efetivo litisconsórcio passivo necessário entre a sociedade e todos os sócios remanescentes.⁴⁵

A falta de citação de qualquer um dos sócios, ou da própria sociedade, implicaria a formação de decisão judicial contrária aos interesses de pessoa – física ou jurídica – que não teve a oportunidade de participar de sua formação, com o exercício do contraditório. Trata-se, portanto, de caso de nulidade absoluta do feito.⁴⁶

Diante de nulidade absoluta como esta, abre-se espaço para a propositura de *querela nulitatis*, com requerimento de declaração da nulidade de todo o processo, desde o ato citatório. A *querela*, como se sabe, é ação meramente declaratória, e não está sujeita a prazo decadencial, diferentemente da ação rescisória; por isso, é medida de economia processual o cuidado com a adequada formação do polo passivo, que deverá ser composto pelos sócios e pela própria sociedade.

Uma última questão suscitada por este dispositivo diz respeito à sua localização topológica dentro da estrutura do CPC. Não há qualquer peculiaridade na ação de dissolução parcial de sociedade que torne o dispositivo aplicável a apenas esta situação. Na verdade, sua lógica fundamental – a de que todas as partes cujo patrimônio será possivelmente comprometido pela decisão devem compor a relação processual – se aplica a qualquer ação, seja de rito comum, seja de rito especial. Assim, apesar de situado entre a regulamentação do procedimento especial de dissolução parcial de sociedade, não parece haver qualquer bom motivo jurídico para deixar de aplicar o dispositivo a quaisquer outras situações em que haja comprometimento simultâneo do patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios.

Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada.

Exatamente em razão das disposições do *caput*, que chama atenção para a importância da adequada composição da relação processual, o teor deste parágrafo único chama atenção por ser, aparentemente, contraditório à disposição do *caput*.

Primeiramente, é preciso consignar que a hipótese é mais um exemplo de entendimento jurisprudencial consolidado que acabou positivado na nova lei processual.⁴⁷

Assim, a matéria pode – e deve – ser interpretada à luz dos fundamentos determinantes das decisões que inspiraram o legislador. Tendo isso em mente, o que quis dizer o CPC quando afirmou que a sociedade “não será citada”? Há uma série de problemas com esse dispositivo, cujas intenções são nobres, mas de execução questionável. De fato, se todos os sócios forem citados, o ato de citação da sociedade não servirá para informar ninguém da existência da ação. Se estão citados todos os sócios, o CPC considerou desnecessário citar a pessoa jurídica da sociedade, enquanto entidade coletiva.

Tal ato, apesar de carregar significado formal, não serve para cumprir a finalidade concreta de uma citação. Alinhando-se, talvez, à ideia de privilegiar o conteúdo dos atos no lugar da forma, o CPC tornou desnecessária a citação da sociedade nesta hipótese, privilegiando a celeridade processual. Mesmo assim, é preciso estar atento ao fato de que a personalidade jurídica da sociedade é apartada das pessoas físicas, e é possível que haja matérias de defesa que aproveitam à sociedade, mas não aos sócios.

Este novo cenário inevitavelmente faz despontar diversas dúvidas, que podem ser respondidas se o dispositivo for lido em conjunto com as demais disposições processuais e princípios orientadores do CPC. Antes de tudo, importa esclarecer que a citação que se dê na forma do dispositivo ora em comento não implica dizer que a sociedade deixa de ser parte, só por não ter sido formalmente citada. Isso seria inovação indevida na lei processual, e seria contraditória ao litisconsórcio passivo necessário estabelecido pelo *caput* deste mesmo dispositivo.

Exatamente por isso, acredita-se que a presente inovação deve ser vista como uma *técnica alternativa de citação*, espécie de citação implícita ou tácita da pessoa jurídica, tida a partir do momento em que são citados os seus demais sócios. A sociedade continuará sendo parte, mesmo que não citada diretamente. O excesso de zelo do dispositivo, ao ressaltar que a sociedade “ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada”, não deve ser lido como equiparando a pessoa jurídica a mero terceiro juridicamente interessado na decisão. A sociedade é efetivamente parte, que pode exercer seu direito de defesa e deverá ser intimada de todos os atos processuais, regularmente, na pessoa de seu advogado.

Não se pode negar, porém, que a redação da lei, neste ponto, carrega certa dose de ambiguidade – a redação do dispositivo seria mais coerente se dele constasse que “*a pessoa jurídica se considera citada se todos os seus sócios o forem*”, pois a dispensa da citação pode facilmente ser confundida com dispensa da participação na lide – e não é este o caso, como se viu.

Outra dúvida possível diz respeito ao efetivo marco inicial da citação. Sem a juntada do aviso de recebimento cumprido e assinado por representante da sociedade, ou mesmo sem a juntada do mandado do oficial de justiça, em que momento a sociedade será considerada citada, inaugurando o prazo para contestação? Ora, toda a razão de ser deste dispositivo reside na ideia de que, uma vez tendo sido citados todos os sócios, há ciência inequívoca da existência da ação por parte da sociedade, pois todas as pessoas juridicamente interessadas já tiveram acesso à informação. Mas essa ciência só se torna absolutamente inequívoca quando são citados absolutamente todos os sócios; assim, acredita-se que essa citação “tácita” da pessoa jurídica se perfectibiliza no momento em que citado o último sócio remanescente.

Segundo Humberto Theodoro Jr., “o sentido da regra em cogitação é o de que, estando todos os sócios presentes no processo, a sociedade *ex vi legis*, será havida como parte, independentemente ser diretamente citada”.⁴⁸ Destaque-se que o autor nada diz sobre a possibilidade de decretação da revelia da sociedade que, diretamente citada, não comparece aos autos.

Por fim, a modalidade “tácita” de citação aqui descrita tem impactos sobre a legitimidade da sociedade para defender-se em eventual fase de cumprimento de sentença. Antigamente, era comum que se entendesse inexistir legitimidade da sociedade para embargar execução de título judicial (ou *impugnar cumprimento de sentença*, na terminologia moderna) de cuja formação não tivesse participado.⁴⁹

Recorde-se, porém, que havia entendimento expresso no sentido da existência do litisconsórcio passivo necessário, pelo que a ação só tramitaria sem a participação da sociedade por força de erro judiciário que não fosse atacado pelas partes interessadas.

Ora, diante da disposição legal que anuncia expressamente a existência desse litisconsórcio passivo necessário, parece inquestionável que a sociedade deverá ter legitimidade para defender-se na fase da execução na qualidade de executada, não de mero terceiro, mesmo no caso em que sua citação se der na forma descrita neste dispositivo. Afinal, trata-se de mudança procedimental, não processual – a sociedade não deixa de ser parte só porque sua citação se dá de forma tácita.

Art. 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar.

1. Pedido de indenização compensável com o valor dos haveres

A possibilidade de que a sociedade formule pedido de indenização talvez seja, pelo aspecto processual, a característica mais interessante da ação de dissolução parcial. O CPC não faz qualquer observação sobre o fato de a sociedade figurar no polo ativo ou passivo, para os fins de formulação deste pedido indenizatório. Supõe-se que o dispositivo esteja tratando da situação em que a ação é movida pelo sócio retirante e a sociedade figura no polo passivo, caso em que o pedido assumirá característica de pedido contraposto.⁵⁰

A redação limitada do art. 602, que menciona apenas a formulação de pedido contraposto pela sociedade, pode suscitar dúvidas no sentido de implicar o não cabimento de reconvenção por parte do sócio retirante, se for ele o réu (hipóteses do art. 600, V e VI). Não é esse o caso, porém. Da mesma forma, também não impede que a sociedade formule outro pedido, além do indenizatório, por meio da via reconvenicional, desde que estejam cumpridos os requisitos do art. 343 do CPC.

Na ação de dissolução parcial de rito comum, que existiu sob a égide do CPC/1973, não se questionava tal possibilidade.⁵¹

Assim, o art. 602 não enumera a única possibilidade de haver pedido formulado pelo réu contra o autor nos autos da dissolução parcial. Além do pedido mencionado no dispositivo, há a possibilidade de se propor reconvenção, desde que haja conexão entre os fatos, como exige o art. 343 do CPC.

Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

§ 1.º Na hipótese prevista no *caput*, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.

1. Concordância com a dissolução

Esta redução nos honorários e nas custas é denominada *sanção premiativa*. Ao invés de castigar os litigantes que não alcançarem um consenso quanto à dissolução, o legislador optou por premiar aqueles que o fizeram, incentivando a autocomposição parcial do feito. Configurada a situação descrita no dispositivo, encerra-se a primeira fase da ação, permitindo o seguimento da liquidação. A ausência de honorários e o rateio das custas serve como um incentivo para a solução consensual, que agiliza o procedimento.

O CPC estabeleceu litisconsórcio passivo necessário entre sócios e sociedade. Entretanto, a solução para esta questão dependerá da resposta jurisprudencial, pois o regime adotado pelo código é diferente do que vinha sendo feito pelo STJ até então.⁵²

A solução adotada no precedente não se alinha, portanto, exatamente com aquilo que o STJ vinha decidindo até então.

§ 2.º Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo.

2. Contestação e procedimento comum

A maior diferença procedimental, na fase de conhecimento, está nesta sanção premiativa, aliada à inexistência da audiência de conciliação obrigatória. Se o desconto nos honorários e custas processuais não for suficiente para que as partes cheguem a um consenso, a ação se processará pelo procedimento comum deste momento até a sentença.

O *caput* incentiva a autocomposição; o parágrafo segundo regula o procedimento a ser tomado se houver contestação. Nesse caso, a ação segue o procedimento comum, devendo ser proferida a decisão saneadora prevista no art. 357⁵³ e produzida toda a prova necessária para o adequado deslinde do feito. É lícito ao julgador, inclusive, designar audiência conciliatória, embora o procedimento especial não a preveja de forma expressa.⁵⁴

Nessa hipótese, apenas depois de alcançada a decisão dissolutória é que o feito voltará a ser regulado pelo rito especial, observando-lhe as disposições referentes à liquidação dos haveres societários.

Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

1. Medidas com vistas à apuração de haveres

Como dito acima, o legislador inseriu, dentro das disposições procedimentais específicas da dissolução parcial, diversos dispositivos cujo conteúdo, na verdade, é exclusivamente de direito material. Este é o caso do art. 604, que regula exclusivamente o *conteúdo* da sentença, direcionando a matéria que deverá ser abordada pela decisão. Não há, porém, qualquer peculiaridade procedimental, que impedisse a matéria de ser regulada pelo procedimento comum.

Não se trata da melhor técnica legislativa, pois todas as disposições aqui contidas podem ser abstraídas logicamente da própria natureza do direito material que se está sendo tutelado – os critérios elencados nos incs. I a III representam o mínimo necessário para a adequada apuração dos haveres: a definição da data em que a sociedade se resolveu, os critérios segundo os quais deverão ser calculados os haveres, e a nomeação de um perito responsável por tais cálculos. Não são *técnicas processuais* distintas, portanto, mas exigências para um julgamento adequado do mérito, mesmo que a ação tramite pelo rito comum (afinal, mesmo sob a égide do CPC/1973, quando o rito era o ordinário, o julgador já se via na obrigação de fixar os requisitos aqui mencionado, como exigência lógica do adequado julgamento de mérito).

I – fixará a data da resolução da sociedade;

É essencial que o juiz defina a data em que efetivamente se deu a resolução da sociedade, pois é esse o marco inicial para o cálculo dos haveres. Evidentemente, não se trata da data em que a questão foi judicializada, mas do efetivo marco da saída, cuja definição dependerá das circunstâncias que conduziram à dissolução da sociedade, nos termos da legislação civil.

A importância de se fixar, com exatidão, a data em que a sociedade efetivamente se dissolveu é o fato de que tal data, necessariamente, servirá como base para o cálculo dos haveres societários. Até a data da saída, o sócio retirante fará jus ao recebimento de todos os valores, incluindo os

lucros e o fundo de comércio; a partir da saída, o valor se consolida, sendo modificado apenas pela incidência dos juros de mora e da correção monetária.⁵⁵

Além deste dispositivo, o legislador dedicou o art. 605 integralmente para enumerar qual seria o marco da retirada do sócio em cada uma das hipóteses de cabimento da ação. Por isso, a questão temporal receberá comentários mais detidos logo a seguir.

II – definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

A apuração dos haveres deverá, via de regra, se dar de acordo com os critérios previstos no contrato social. Só se concebe definição de critério distinto se houver alguma circunstância extraordinária, imprevista no contrato social.⁵⁶

Tal “peculiaridade”, vale repetir, dependerá de alegação e comprovação específica; do contrário, prevalecerá a regra do contrato social. Mas é fato, de toda forma, que o critério de vinculação ao contrato social nem sempre é absoluto, especialmente em relação ao critério de apuração de haveres. Importante precedente de 1979 do STF – num dos raros casos, na prática jurídica brasileira, de um efetivo *precedente* que se firmou como regra geral vinculante, efetivamente seguida por anos subsequentes – definiu o Recurso Extraordinário 89464.⁵⁷

O trecho negrito da ementa é, até hoje, rotineiramente usado como parte da fundamentação de acórdãos que apreciam situações semelhantes no STJ.

O fato de a sociedade se estar dissolvendo apenas parcialmente nada modifica em relação aos direitos do sócio retirante; por isso, os critérios definidos pelo juiz para a apuração de haveres (art. 604, II), deverão, ao mesmo tempo, privilegiar a continuidade da pessoa jurídica e resguardar os direitos do sócio retirante a receber o mesmo que receberia se o caso fosse de dissolução *total* da sociedade. Caso o critério previsto no contrato social comprovadamente não contemple esses dois critérios, vindo a causar desnecessária ruína à sociedade ou aos direitos de compensação do sócio retirante, é lícito ao juiz definir um outro critério, distinto daquele previsto literalmente no contrato.⁵⁸

Para todos os efeitos, então, a única diferença entre a apuração de haveres na dissolução parcial, em relação à total, é a exigência de que seja preservado o fim social da empresa, que não pode ser levada à ruína; de resto, a apuração deverá ser realizada do mesmo modo que seria se a dissolução fosse total, sendo possível relevar até mesmo as disposições do contrato social, se elas não forem suficientes para tanto.⁵⁹

Trata-se, portanto, de outro exemplo de entendimento antigo dos tribunais pátrios – referendado pelo CPC de 2015.

III – nomeará o perito.

O verbo no imperativo não deixa espaço para discussão: o juiz deve, necessariamente, nomear perito para realizar a apuração dos haveres, em razão da complexidade da prova. Não será dado ao julgador, portanto, determinar a liquidação por simples cálculo, por exemplo, mesmo que entenda que a prova dos autos o permitiria.

A perícia será de natureza contábil, em razão da natureza da matéria.

§ 1.º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

§ 2.º O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores.

§ 3.º Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.

Os parágrafos regulam mudança que certamente terá impactos positivos: se ambas as partes concordarem sobre uma parcela dos haveres, não há motivo para que tais valores sejam pagos apenas ao final da ação. Não há necessidade de prolongar a discussão processual em situação onde, a bem da verdade, não há mais lide; isso representaria apego desnecessário à forma, implicando postergação da atividade satisfativa que seria contrária aos princípios basilares do novo Código (em especial o art. 4.º).⁶⁰

Assim, constatada a incontrovérsia parcial, o juiz intimará a sociedade (seja ela autora, seja ela ré) para depositar em juízo os valores – ressalvadas as disposições do contrato social, que não podem ser afastadas de automático simplesmente por ter a questão sido judicializada. Uma vez depositados os valores, o levantamento pode se dar de imediato, prosseguindo a demanda apenas em relação à apuração dos demais.

Art. 605. A data da resolução da sociedade será:

1. Termo inicial para resolução da sociedade

Não se trata de dispositivo processual. Os incisos influenciam o conteúdo da decisão que deverá ser tomada pelo juiz, a depender das circunstâncias do caso concreto. A questão é de direito material, e não faz mais do que elencar, em um só lugar, as disposições esparsas já presentes no Código Civil.

Percebe-se, ao analisar cada uma das hipóteses, que o legislador – corretamente, diga-se de passagem – reconheceu a primazia da situação de fato, não do acerto do direito pelo julgador. Afinal, a dissolução parcial é situação de direito material, que ocorre não quando o juiz determina, mas quando configurados os requisitos da legislação; nessas situações, a sentença dissolutória pode ter efeitos *ex nunc*, declarando que a dissolução da sociedade já ocorreu, num momento passado.

Isso significaria emprestar natureza declaratória a uma decisão que, via de regra, seria constitutiva.

I – no caso de falecimento do sócio, a do óbito;

Considera-se retirado o sócio no exato momento do seu falecimento. Não há, portanto, substituição automática do falecido pelo seu espólio, ou pelos seus sucessores. Qualquer apuração de haveres em liquidação de cota social deverá retroagir ao momento da morte, desde o qual incidirão juros e multa.

II – na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante;

III – no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente;

IV – na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e

Da mesma forma, nos casos de saída do sócio por ato de vontade – o direito de retirada ou recesso, cujo significado e estruturação foram explicados nos comentários ao art. 600, IV – a data da saída será regulamentada pelo direito material, não pelo direito processual. O CC prevê expressamente as circunstâncias e o momento em que se operacionaliza a saída do sócio na espécie, e os incs. II, III e IV do art. 605 repetem a previsão daqueles dispositivos.

Destaque-se que este dispositivo é o único momento em que a lei processual distingue com alguma clareza os direitos de “retirada” e de “recesso”, pelo que se conclui que o legislador entendeu, pela *retirada*, a saída voluntária sem motivo, ou por justa causa; e, pelo *recesso*, a saída voluntária baseada em alguma das hipóteses legais, em que há discordância do retirante com decisões administrativas importantes.

Na *retirada imotivada*, em que a lei civil exige sessenta dias entre a notificação e a efetiva saída do sócio, a dissolução se operacionaliza assim que ultrapassado esse marco (inc. II).

No *recesso*, a saída se consolida no exato momento em que a sociedade é notificada da saída do sócio, sendo desnecessária a passagem do prazo sexagesimal (inc. III).

Por fim, se a retirada for por justa causa, e portanto decorrer de decisão judicial, a saída se consolidará no momento em que transitada em julgado tal decisão (inc. IV).

V – na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado.

A última hipótese do art. 605 é a exclusão de sócio pela sociedade, a terceira hipótese de cabimento da ação de dissolução parcial. Aqui, o marco adotado como a ata de saída é a reunião ou assembleia, onde se deliberou para a saída do sócio. Recorde-se, nos termos da legislação civil, que esta reunião ou assembleia deve ser designada na forma do contrato social, com o fim específico de deliberar para a exclusão do sócio, que deve ser intimado para comparecer e exercer seu direito à ampla defesa.

Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.

Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades.

1. Critérios para a apuração de haveres

Antes de iniciar a fase de apuração de haveres, é preciso definir os critérios que o perito deverá seguir. Se houver disposição contratual expressa, os critérios deverão seguir aqueles estabelecidos em contrato – salvo, como dito acima, se ficar comprovado que a regra do contrato social é manifestamente injusta ou causaria enriquecimento ilícito a alguma das partes.

É preciso ter em mente, para entender o regime adotado pelo legislador, qual a finalidade da ação de dissolução parcial de sociedade. Para o sócio retirante, não deve haver diferença entre retirar-se por meio da ação de dissolução parcial ou da dissolução total. Com o fim da *affectio societatis*, pouco importa para o sócio retirante se a sociedade vai continuar a exercer suas atividades mercantis. Os haveres lhe devem ser pagos como se a sociedade estivesse sendo extinta.

É evidente, porém, que essa apuração não pode ser feita com precisão quando a sociedade não está se encerrando; seria impossível, do ponto de vista contábil. Essa é a importância da figura do *balanço de determinação*. Tal balanço não é estritamente contábil, porque não reflete a realidade societária; trata-se, na verdade, de uma ficção jurídica, que busca responder a seguinte pergunta: se, na data de saída do sócio retirante (definida de acordo com os critérios do art. 605), a sociedade tivesse sido completamente extinta, quanto ele teria recebido?

Para responder a essa pergunta, realiza-se uma simulação. Atribui-se aos bens da sociedade o valor de mercado, desconta-se os valores referentes a compromissos por haver e cobram-se todos os débitos. A isso, soma-se a quantificação de todo o patrimônio líquido (corpóreo e incorpóreo). Por fim, realiza-se uma dissolução fictícia da sociedade, apurando os haveres que seriam devidos a cada sócio nesse cenário.⁶¹ Esse exercício contábil, baseado num balanço imaginário, é que denomina o balanço de determinação.

Destaque-se que o fundo de comércio integra os haveres a serem apurados, devendo ser considerado durante essa apuração contábil.⁶²

Vale destacar, por fim, que o cálculo dos haveres deve, necessariamente, ser realizado por meio

da produção de prova pericial, realizada por perito da área contábil, nos termos do art. 604, III.

Art. 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia.

1. Revisão da data de resolução e de critérios para a apuração de haveres

A possibilidade de revisão revela que a decisão que define a dissolução, na verdade, não tem natureza de sentença, apta a transitar em julgado. Os critérios definidos pelo julgador nessa decisão não são perenes, e podem ser revistos à luz de circunstâncias relevantes. A única restrição a estas modificações é o efetivo início do trabalho pericial; se o laudo já estiver em elaboração, não é dado às partes tentar protelar o feito por meio de medidas constantes nos critérios de tal apuração.

Art. 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador.

Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais.

1. A data da resolução e os créditos que integram o valor devido ao ex-sócio

O conteúdo do art. 608, *caput* e parágrafo único, é integralmente de direito material. São, na verdade, afirmação da natureza constitutiva e dos efeitos *ex nunc* da sentença que resolve o efeito dissolutivo, e ressaltam a importância de que o julgador defina com clareza o marco da dissolução societária.

Como dito anteriormente, é possível que haja flutuações patrimoniais, para mais ou para menos, durante o período compreendido entre a saída do sócio e o fim da liquidação dos haveres. Esses valores não compreendem a apuração de haveres, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito do sócio retirante (se a flutuação for para mais) ou da sociedade (se a flutuação for para menos).

Na verdade, o que o dispositivo pretende é orientar o perito a basear seus cálculos num *retrato* daquilo que era o patrimônio societário na data em que efetivamente ocorreu o desligamento do sócio retirante, não do que o patrimônio é hoje. Esta será a base de cálculo para a apuração de haveres, que respeitará os critérios definidos pelo contrato social e/ou pelo juízo da dissolução parcial.

Nada disso representa novidade trazida pela lei processual. Novamente, trata-se de mero esclarecimento de uma situação que, na verdade, decorre do próprio direito material. Prova disso é que as circunstâncias aqui descritas já eram reconhecidas pelo STJ quando inexistia o rito especial.⁶³

Por óbvio, os valores serão acrescidos de correção monetária e juros de mora equivalentes ao período em que os haveres, devidos desde a retirada, não foram pagos; assim, o valor final da indenização será equivalente ao resultado da liquidação, acrescido dos encargos moratórios e correção desde a data em que efetivamente se deu a saída do sócio até o momento em que realizado o pagamento.

Art. 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos do § 2.º do art. 1.031 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1. O pagamento dos haveres do sócio retirante

Bastante autoexplicativo, o art. 609 se limita a remeter ao contrato social para disciplinar a *forma de pagamento* dos haveres. Não havendo previsão contratual específica, aplica-se a regra do Código Civil, segundo a qual o pagamento se realizará em dinheiro, em até noventa dias contados da data em que for encerrada a liquidação.

Como é inquestionavelmente aplicável à espécie o art. 1.031, 2.º, do CC, o dispositivo em comento sequer precisaria existir. Aparentemente, trata-se de outro exemplo da tendência do CPC de 2015 de dizer o óbvio, supostamente por amor à clareza e ao didatismo.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Humberto Theodoro Junior, *Curso De Direito Processual Civil: Procedimentos Especiais*. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 50. ed. p. 217.

2

Recurso especial. Ação de rescisão de contrato cumulada com perdas e danos. Extensão da obrigação. Interpretação de cláusulas contratuais. Reexame de provas. Súmulas 5 e 7/STJ. Affectio societatis. Ruptura. Inexequibilidade do contrato social. Obrigação de fazer. Ingresso em sociedade limitada. Determinação judicial. Não cabimento. (...) 3. Em contrato preliminar destinado a ingresso em quadro de sociedade limitada, a discussão passa pela affectio societatis, que constitui elemento subjetivo característico e impulsionador da sociedade, relacionado à convergência de interesses de seus sócios para alcançar o objeto definido no contrato social. A ausência desse requisito pode tornar inexecutível o fim social. Inteligência do art. 1.399, inciso III, do Código Civil de 1916 ou 1.034, inciso II, do Código Civil de 2002, conforme o caso. (...) 5. Recurso especial provido em parte. Sentença restabelecida (STJ, 3.ª Turma, REsp 1.192.726-SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 17.03.2015, p. em 20.03.2015. Grifou-se).

3

Fernando Sacco Neto, Da Ação De Dissolução Parcial De Sociedade. In: Teresa Arruda Alvim Wambier, et al (org.). *Breves Comentários Ao Novo Código De Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 1495-1596.

4

Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I – o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; II – o consenso unânime dos sócios; III – a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; IV – a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; V – a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

5

Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios, quando: I – anulada a sua constituição; II – esaurido o fim social, ou verificada a sua inexecutibilidade.

Processo civil e direito societário. Ação de dissolução de sociedade. Trânsito em julgado da decisão que determinou a dissolução. Processo que tramitou perante os sócios, apenas, sem que a sociedade parcialmente dissolvida o tivesse integrado. Apuração dos haveres, no que o juízo convencionou chamar segunda fase da dissolução. Decisão que impôs o ônus de arcar com a perícia à sociedade dissolvida. Impugnação por agravo de instrumento interposto apenas pela autora. Tribunal que, entendendo ser, a dissolução parcial, hipótese de litisconsórcio necessário, negou provimento ao agravo e, de ofício, reformou a decisão recorrida, retirando o ônus da sociedade e impondo-o à autora. Ilegalidade. (...) – O procedimento na ação de dissolução parcial não é regulado por lei, porquanto representa criação pretoriana. Disso decorre que a ação se desenvolve pelo procedimento ordinário. O que o Tribunal a quo houve por bem denominar “segunda fase” do procedimento nada mais é que a liquidação da sentença proferida na ação principal. (...). Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (STJ, 3.^a Turma, REsp 613.629, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26.09.2006, p. em 16.10.2006, p. 364).

Apelação cível. Direito processual civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Rito especial aplicado corretamente. Direito empresarial. Dissolução parcial de sociedade. Rompimento do affectio societatis. Princípio da preservação da empresa. Honorários advocatícios. Majoração. Demonstrado através das provas contidas nos autos o rompimento do vínculo afetivo entre os sócios, com condutas incompatíveis de um deles, que integra o quadro societário de outra clínica, no mesmo bairro, com o mesmo objeto social, possui baixa produtividade no CTTB e se ausenta durante seus plantões, deixando o local sem qualquer assistência médica, caracterizam a ausência de affectio societatis e justificam a dissolução da sociedade em face do sócio faltoso, preservando a empresa em relação aos demais sócios. Verba honorária fixada aquém do devido, razão pela qual merece majoração para a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito ao disposto no art. 20, §§ 3.º e 4º., do CPC. Reforma parcial da sentença. Desprovimento do primeiro recurso. Provimento do segundo (TJRJ, 6.^a Câmara Cível, Apelação Cível 0183782-90.2009.8.19.0001, rel. Des. Teresa Castro Neves, j. em 06.04.2011 p. em 03.05.2011. Grifou-se).

Empresarial. Sociedade anônima fechada. Cunho familiar. Dissolução. Fundamento na quebra da affectio societatis. Possibilidade. Devido processo legal. Necessidade de oportunizar a participação de todos os sócios. Citação inexistente. Nulidade da sentença reconhecida. 1. Admite-se dissolução de sociedade anônima fechada de cunho familiar quando houver a quebra da affectio societatis. 2. A dissolução parcial deve prevalecer, sempre que possível, frente à pretensão de dissolução total, em homenagem à adoção do princípio da preservação da empresa, corolário do postulado de sua função social. 3. Para formação do livre convencimento motivado acerca da inviabilidade de manutenção da empresa dissolvenda, em decorrência de quebra da liame subjetivo dos sócios, é imprescindível a citação de cada um dos acionistas, em observância ao devido processo legal substancial. 4. Recurso especial não provido (STJ, 3.^a Turma, REsp 1.303.284, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 16.04.2013, p. em 13.05.2013. Grifou-se).

I – Recurso Especial. - Sociedade Anônima – Pedido de Dissolução Integral – Sentença que Decreta dissolução Parcial e Determina A Apuração de Haveres.- Julgamento Extra Petita – Inexistência. Não é extra petita a

sentença que decreta a dissolução parcial da sociedade anônima quando o autor pede sua dissolução integral. II – Participação societária do autor. Controvérsia. Definição postergada à fase de liquidação da sentença. Impossibilidade de exame da alegada ilegitimidade ativa (...) Não merece exame a questão decidida pelo acórdão recorrido com base em mais de um fundamento suficiente, se todos eles não foram atacados especificamente no recurso especial (STJ, 3.^a Turma, REsp 507.490, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 19.09.2006, p. em 13.11.2006. Grifou-se).

10

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I – se o contrato dispuser diferentemente; II – se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III – se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

11

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

12

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.

13

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. § 1.^o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. § 2.^o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

14

CC, Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

15

CPC, Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres

ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

16

Sociedade anônima. Dissolução parcial. Precedentes da Corte. 1. É incompatível com a natureza e o regime jurídico das sociedades anônimas o pedido de dissolução parcial, feito por acionistas minoritários, porque reguladas em lei especial que não contempla tal possibilidade. 2. Recurso especial conhecido e provido (STJ, 3.ª Turma, REsp 419.174, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 15.08.2002, p. em 28.10.2002. Grifou-se).

17

Comercial. Sociedade anônima familiar. Dissolução parcial. Inexistência de affectio societatis. Possibilidade. Matéria pacificada. I. A 2.ª Seção, quando do julgamento do EREsp 111.294/PR (Rel. Min. Castro Filho, por maioria, DJU de 10.09.2007), adotou o entendimento de que é possível a dissolução de sociedade anônima familiar quando houver quebra da affectio societatis. II. Embargos conhecidos e providos, para julgar procedente a ação de dissolução parcial (STJ, 2.ª Seção, EREsp 419.174, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 28.05.2008, p. em 04.08.2008).

18

Ação de dissolução de sociedade – Efeitos da decisão que a decreta - Interesse recursal reconhecido – Sentença constitutiva – efeitos ex nunc – litigância de má-fé – não reconhecimento. – A decisão judicial que decretada a dissolução da sociedade, possui natureza constitutiva, porquanto modificativa da situação jurídica da empresa, razão pela qual seus efeitos só se operam a partir do trânsito em julgado, ou seja, ex nunc. – Para que haja a condenação dos apelantes, por litigância de má-fé, com a consequente aplicação dos arts. 17 e 18, do CPC, como cediço, é imprescindível que se prove, de forma cabal, que a parte estava agindo imbuída de dolo processual (TJMG, 9.ª Câmara Cível, Apelação Cível 1.0024.03.943452-7/012, rel. Des. Osmando Almeida j. em 05.10.10, p. em 03.11.10).

19

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

20

Art. 6.º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

21

Situação semelhante ocorre com as demais ações dúplices presentes no CPC, como a ação de consignação de pagamento, que pode resultar em título judicial desfavorável ao autor caso se verifique que o depósito inicial é inferior ao valor efetivamente devido.

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Direito processual civil. Recurso especial. Ação de apuração de haveres. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ausência de pedido e impossibilidade de sua dedução a partir da causa de pedir. Julgamento extra petita. Ocorrência. Prescrição. Prazo decenal. Inocorrência. Rito processual. Ausência de regramento especial. Procedimento ordinário. Ausência de prejuízo concreto. Nulidade afastada. (...) 6. A apuração de haveres decorrente de dissolução parcial não é regulada especificamente por lei, porquanto a própria dissolução parcial representa criação doutrinária e jurisprudencial, aos poucos incorporada no direito posto. 7. Diante da inexistência de regras objetivas, aplica-se o procedimento ordinário à ação de apuração de haveres – ação de natureza eminentemente condenatória. (...) 9. Recurso especial parcialmente provido (STJ, 3.^a Turma, REsp 1.139.593, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 22.04.2014, p. em 02.05.2014. Grifou-se).

Societário. Recurso especial. Dissolução parcial. Apuração de haveres. Disposição contratual específica afastada. Balanço especialmente levantado. Apuração de haveres. Ação limitada à apuração do patrimônio contábil e cabedais do sócio egresso. Delimitação dos danos. Inocorrência. (...) 2. Na hipótese, apesar de reconhecer a existência de cláusula contratual específica, acabou o acórdão por afastar a sua incidência, justamente diante da situação peculiar do ingresso do autor na sociedade, de sua permanência por cerca de 3 anos como sócio, e os alegados desvios de valores, o que surtiria efeitos diretamente na apuração dos haveres. Chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súm. 7/STJ). (...) 4. A ação de dissolução parcial de haveres é contenda deveras específica, que se limita à superficialidade das questões atinentes a forma de apuração do patrimônio contábil e seus haveres – seja adotando o contrato social, seja em balanço especialmente levantado, o que sumariza o seu conhecimento, limitando sua extensão e/ou profundidade. (...) 6. No caso, eventual indenização por descumprimento contratual, concorrência desleal, uso indevido da firma social, desvio de capital, há de ser apurada, se for o caso, por meio de ação própria, permitindo ampla defesa e produção de provas aos réus e chamando à lide possíveis terceiros prejudicados, sob pena de desvirtuar a dissolução em comento. (...) 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, 4.^a Turma, REsp 1.444.790, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 26.08.2014, p. em 25.09.2014).

Direito societário. Ação de dissolução de sociedade anônima, proposta por acionistas minoritários. Quorum mínimo atendido na data da propositura da ação. Desistência da ação por um dos autores, no curso do processo. Homologação pelo juízo. Correspondente diminuição da participação detida pelos autores no capital social da companhia a ser dissolvida, para patamar inferior ao mínimo legal. Irrelevância. – A titularidade de 5% do capital social da companhia, em ações de dissolução proposta com base no art. 206 da Lei das S.A., é condição a ser preenchida na data da propositura da demanda, sendo irrelevantes as alterações nesse percentual ocorridas no curso do processo. – Na hipótese dos autos, a desistência de um dos litigantes não poderia prejudicar os demais. Sendo necessário o litisconsórcio formado por ocasião da propositura da ação, o consentimento dado pelo autor no início do processo não pode ser revogado em seu

curso. A desistência só pode ser admitida caso subscrita por todos os autores. Recurso especial conhecido e provido (STJ, 3.^a Turma, REsp 408.122/PR, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. em 20.06.2006, p. em 27.11.2006).

26

(...) III – Sociedade anônima. Dissolução parcial. Possibilidade jurídica. Requisitos. 1. Normalmente não se decreta dissolução parcial de sociedade anônima: a Lei das S/A prevê formas específicas de retirada – voluntária ou não – do acionista dissidente. 2. Essa possibilidade é manifesta, quando a sociedade, embora formalmente anônima, funciona de fato como entidade familiar, em tudo semelhante à sociedade por cotas de responsabilidade limitada. (...) (STJ, 3.^a Turma, REsp 507.490, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 19.09.2006, p. em 13.11.2006).

27

Embargos de divergência. Questões preliminares. Substabelecimento. (...) Ausência de habilitação dos sucessores. Nulidade dos atos praticados após o óbito. Descabimento. Observância do princípio da segurança jurídica. Mérito. Direito comercial. Sociedade anônima. Grupo familiar. Inexistência de lucros e distribuição de dividendos há vários anos. Quebra da affectio societatis. Dissolução parcial. Possibilidade. (...) III – É inquestionável que as sociedades anônimas são sociedades de capital (intuito pecuniae), próprio às grandes empresas, em que a pessoa dos sócios não têm papel preponderante. Contudo, a realidade da economia brasileira revela a existência, em sua grande maioria, de sociedades anônimas de médio e pequeno porte, em regra, de capital fechado, que concentram na pessoa de seus sócios um de seus elementos preponderantes, como sói acontecer com as sociedades ditas familiares, cujas ações circulam entre os seus membros, e que são, por isso, constituídas intuito personae. Nelas, o fator dominante em sua formação é a afinidade e identificação pessoal entre os acionistas, marcadas pela confiança mútua. Em tais circunstâncias, muitas vezes, o que se tem, na prática, é uma sociedade limitada travestida de sociedade anônima, sendo, por conseguinte, equivocado querer generalizar as sociedades anônimas em um único grupo, com características rígidas e bem definidas. Em casos que tais, porquanto reconhecida a existência da affectio societatis como fator preponderante na constituição da empresa, não pode tal circunstância ser desconsiderada por ocasião de sua dissolução. Do contrário, e de que é exemplo a hipótese em tela, a ruptura da affectio societatis representa verdadeiro impedimento a que a companhia continue a realizar o seu fim, com a obtenção de lucros e distribuição de dividendos, em consonância com o art. 206, II, “b”, da Lei 6.404/1976, já que dificilmente pode prosperar uma sociedade em que a confiança, a harmonia, a fidelidade e o respeito mútuo entre os seus sócios tenham sido rompidos. A regra da dissolução total, nessas hipóteses, em nada aproveitaria aos valores sociais envolvidos, no que diz respeito à preservação de empregos, arrecadação de tributos e desenvolvimento econômico do país. À luz de tais razões, o rigorismo legislativo deve ceder lugar ao princípio da preservação da empresa, preocupação, inclusive, da nova Lei de Falências – Lei 11.101/2005, que substituiu o Decreto-lei 7.661/1945, então vigente, devendo-se permitir, pois, a dissolução parcial, com a retirada dos sócios dissidentes, após a apuração de seus haveres em função do valor real do ativo e passivo. (...) Embargos de divergência improvidos, após rejeitadas as preliminares (STJ, 2.^a Seção, EREsp 111.294/PR, rel. Min. Castro Filho, j. em 28.06.2006, p. em 10.09.2007. Grifou-se).

28

Embargos de terceiro. Legitimidade. Herdeiro. Sócio. Pessoa jurídica. Constrição. Bens da empresa. 1 – Se a penhora recai sobre frutos civis da pessoa jurídica (alugueres), efetivamente a devedora na execução, não

tem legitimidade para opor embargos de terceiro um dos herdeiros de um dos sócios da empresa (de cujus), pois não se configura nenhuma das hipóteses legais. 2 – O fato de a herança ser um “todo indivisível” não tem nenhuma relação de pertinência com a constrição ou com a legitimação dos embargos de terceiro, pois a penhora é sobre bens da pessoa jurídica, que não se confunde com a figura dos sócios, mesmo porque a herança é das quotas sociais e somente depois de realizada a dissolução parcial ou total da empresa (STJ, 4.^a Turma, REsp 811.627, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 08.04.2008, p. em 22.04.2008).

29

Humberto Theodoro Junior, op. cit., p. 221.

30

Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas: I – nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas; II – nos casos dos incisos IV e V do art. 136, não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver: a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários; e b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação; III – no caso do inciso IX do art. 136, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar: a) mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida; b) redução do dividendo obrigatório; ou c) participação em grupo de sociedades; IV – o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembléia-geral; V – o prazo para o dissidente de deliberação de assembléia especial (art. 136, § 1.º) será contado da publicação da respectiva ata; VI – o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no § 3.º e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela assembléia-geral. § 1.º O acionista dissidente de deliberação da assembléia, inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital de convocação da assembléia, ou na data da comunicação do fato relevante objeto da deliberação, se anterior. § 2.º O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos IV ou V do *caput* deste artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se absterido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à assembléia. § 3.º Nos 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo de que tratam os incisos IV e V do *caput* deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da assembléia-geral ou da assembléia especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a assembléia-geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa. § 4.º Decairá do direito de retirada o acionista que não o exercer no prazo fixado.

31

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta

dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

32

Art. 1.077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031.

33

Humberto Theodoro Junior, op. cit., p. 223.

34

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. § 1.º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. § 2.º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

35

Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 1.º do art. 1.031.

36

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.

37

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. § 1.º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. § 2.º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Humberto Theodoro Junior, op. cit., p. 224.

Civil e comercial. Recurso especial. Dissolução parcial de sociedade. Exclusão de sócio. Quebra da affectio societatis. Insuficiência. 1. A ausência de decisão sobre o dispositivo legal supostamente violado, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Deficiência de fundamentação do recurso. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 5. Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra. 6. Recurso especial a que se nega provimento (STJ, 3.^a Turma, REsp 1.129.222, rel. Min. Nancy Andrichi, j. em 28.06.2011, p. em 01.08.2011).

Direito societário e empresarial. Sociedade anônima de capital fechado em que prepondera a affectio societatis. Dissolução parcial. Exclusão de acionistas. Configuração de justa causa. Possibilidade. Aplicação do direito à espécie. Art. 257 do RISTJ e Súmula 456 do STF. (...) 2. É bem de ver que a dissolução parcial e a exclusão de sócio são fenômenos diversos, cabendo destacar, no caso vertente, o seguinte aspecto: na primeira, pretende o sócio dissidente a sua retirada da sociedade, bastando-lhe a comprovação da quebra da affectio societatis; na segunda, a pretensão é de excluir outros sócios, em decorrência de grave inadimplemento dos deveres essenciais, colocando em risco a continuidade da própria atividade social. 3. Em outras palavras, a exclusão é medida extrema que visa à eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa, sendo imprescindível a comprovação do justo motivo.

(...) (art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). Precedentes (...) (STJ, 4.^a Turma, REsp 917.531, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 17.11.2011, p. em 01.02.2012).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Direito societário. Dissolução parcial de sociedade. Apuração de haveres. Inclusão do fundo de comércio. Violação ao art. 1.031, caput, do CC. Não ocorrência. Honorários advocatícios. Súmula 7/STJ. Agravo regimental não provido.

1. O fundo de comércio integra o montante dos haveres da sociedade empresária quando

da exclusão de sócio. Precedentes. 2. A revisão do critério adotado pelo Colegiado a quo, para a fixação dos honorários, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado em âmbito de especial, atraindo a incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, 4.^a Turma, AgRg no AREsp 78.175/MS, rel. Min. Raul Araújo, j. em 01.09.2015, p. em 24.09.2015).

43

Fernando Sacco Neto, op. cit., p. 1505.

44

Sociedade por cotas – retirada de sócios. Apuração de seus haveres, como se de dissolução se tratasse, sem prejuízo da permanência da sociedade. Sociedade – legitimidade para a causa. Embora a pretensão de retirada de sócio, enquanto envolve modificação do contrato, só possa ser atendida pelos remanescentes, o certo é que o pagamento dos haveres far-se-a com o patrimônio da sociedade. Justifica-se sua presença no processo. Recurso especial. Dele não se conhece quanto ao ponto que não foi objeto de exame pelo acórdão (STJ, 3.^a turma, REsp 44.132, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. Em 11.12.1995, p. Em 01.04.1996).

45

Recurso especial. Ação de dissolução de sociedade cumulada com indenizatória. Violação do art. 535 do CPC. Inexistência. Apelação. (...) Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Apuração de haveres. Legitimidade passiva. Existência. Produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Revisão. (...) 9. Consoante jurisprudência desta Corte, a retirada de sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada dá-se pela ação de dissolução parcial, com apuração de haveres, para qual têm de ser citados não só os demais sócios, mas também a sociedade. (...) 13. Recursos especiais a que se nega provimento (STJ, 3.^a Turma, REsp 1371843, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 20.03.2014, p. em 26.03.2014).

46

Agravo regimental. Dissolução parcial de sociedade comercial. Omissão do acórdão recorrido. Inexistência. Litisconsórcio passivo necessário com a sociedade comercial. Ausência de citação. Nulidade. Ausência de ofensa à coisa julgada. I – Consoante dispõe o art. 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejugamento da causa. II – Na ação para apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade empresarial e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário. III -A falta de citação do litisconsorte necessário inquina de nulidade, desde a origem, o processo originário, matéria a ser apreciada, inclusive, de ofício. Em casos que tais, “os atos nulos pleno iure jamais precluem, não se sujeitando à coisa julgada, porque invalidam a formação da relação processual, podendo ser reconhecidos e declarados em qualquer época ou via.” (REsp 147.769/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 14.2.00) IV – Agravo Regimental improvido (STJ, 3.^a Turma, AgRg no REsp 947.545/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 08.02.2011, p. em 22.02.2011. Grifou-se).

47

Processual civil. Comercial. Ação de dissolução parcial de sociedade limitada. Citação da pessoa jurídica.

Desnecessidade. Participação de todos os sócios. Alegação de ofensa a dispositivos de lei federal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Exclusão do sócio majoritário. Possibilidade no caso concreto. Princípio da preservação da empresa. Teoria do fato consumado. Alegação de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Impossibilidade. 1. Na ação de dissolução parcial de sociedade limitada, é desnecessária a citação da pessoa jurídica se todos os que participam do quadro social integram a lide. 2. A ausência de prequestionamento nas instâncias ordinárias inviabiliza o conhecimento de recurso especial fundado em violação de lei federal. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Em circunstâncias excepcionais, é possível a exclusão do sócio majoritário a pedido de minoritário, a fim de prestigiar o princípio da preservação da empresa. Teoria do fato consumado que se adota como fundamento para manter o sócio minoritário no quadro societário. 4. Não se conhece de recurso especial por violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, naturalmente vagos e imprecisos. Somente quando os princípios jurídicos se apresentam como norma de direito positivo é que se abre espaço para o conhecimento do recurso constitucional fundamentado na violação da lei que os abriga. 5. Recursos especiais não conhecidos (STJ, 4.ª Turma, REsp 1.121.530, rel. Min. Marco Buzzi, j. em 13.09.2011, p. em 26.04.2012. Grifou-se).

48

Humberto Theodoro Junior., op. cit., p. 227.

49

Dissolução parcial de sociedade. Apuração de haveres do sócio retirante. Execução. Assertiva de não-integração, no feito principal, da sociedade em questão. Matéria decidida naquela causa. Preclusão. Ilegitimidade da empresa para oferecer embargos à execução. Se a sociedade não foi parte na ação principal, não está sendo executada e não teve bens penhorados, falta-lhe legitimidade para oferecer embargos do devedor. Recurso especial não conhecido (STJ 4.ª Turma, REsp 329.307, rel. Min. Barros Monteiro, j. em 09.04.2002, p. em 10.06.2002).

50

Fernando Sacco Neto, op. cit., p. 1507.

51

Comercial. Sociedade anônima fechada. Cunho familiar. Quebra da affectio societatis. Dissolução parcial. Possibilidade. Pedido formulado por acionistas majoritários. Possibilidade. (...) 3. Nada impede os acionistas minoritários de apresentarem, em sede de defesa, reconvenção, caso concordem com a dissolução parcial mas entendam que os acionistas majoritários é que devem se afastar. (...) 4. Recurso especial não provido (STJ, 3.ª Turma, REsp 1.128.431, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 11.10.2011, p. em 25.10.2011).

52

Sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Retirada de sócio. (...) 4. Honorários advocatícios. Por eles não respondem os sócios, assistentes da sociedade. A responsabilidade é exclusivamente da sociedade. 5. Recurso especial conhecido e provido em parte (item 4) (STJ, 3.ª Turma, REsp 52.094, rel. Min. Nilson Naves, j. em 13.06.2000, p. em 21.08.2000. Grifou-se).

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I – resolver as questões processuais pendentes, se houver; II – delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III – definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV – delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V – designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Humberto Theodoro Junior, op. cit., p. 227-228.

Recurso especial. Ação de dissolução de sociedade cumulada com indenizatória. (...) Data base para apuração de haveres. Término do affectio societatis. (...) A data-base para apuração dos haveres coincide com o momento em que o sócio manifestar vontade de se retirar da sociedade limitada estabelecida por tempo indeterminado (STJ, 3.^a Turma, REsp 1.371.843, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 20.03.2014, p. em 26.03.2014).

Dissolução parcial. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Reconvenção. Pagamento dos haveres. Previsão contratual. Precedentes da Corte. (...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte, a regra geral é a de que os haveres do sócio que se retira da sociedade devem ser pagos na forma prevista no contrato, salvo se existente alguma peculiaridade com força para afastar este entendimento, o que não ocorre no presente caso. (...) 5. Recurso especial não conhecido (STJ, 3.^a Turma, REsp 450.129/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 08.10.2002, p. em 16.12.2002. Grifou-se).

Comercial. Dissolução de sociedade limitada. Pedida a dissolução total por sócio dissidente, não é possível, em princípio, decretar a dissolução parcial, com simples apuração contábil dos haveres do autor. Admitida que seja a dissolução parcial em atenção à conveniência da preservação do empreendimento, dar-se-á ela mediante forma de liquidação que a aproxime da dissolução total. Nesse caso, deve ser assegurada ao sócio retirante situação de igualdade na apuração de haveres, fazendo-se esta com a maior amplitude possível, com a exata verificação, física e contábil, dos valores do ativo (STF, 2.^a Turma, RE 89464, rel. Min. Cordeiro Guerra, rel. p/ acórdão Min. Décio Miranda, j. em 12.12.1978, p. em 04.05.1979. Grifou-se).

Direito empresarial. Dissolução parcial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Sócio dissidente. Critérios para apuração de haveres. Balanço de determinação. Fluxo de caixa. 1. Na dissolução parcial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, o critério previsto no contrato social para a apuração dos haveres do sócio retirante somente prevalecerá se houver consenso entre as partes quanto ao resultado alcançado. 2. Em caso de dissenso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o balanço de determinação é o critério que melhor reflete o valor patrimonial

da empresa. 3. O fluxo de caixa descontado, por representar a metodologia que melhor revela a situação econômica e a capacidade de geração de riqueza de uma empresa, pode ser aplicado juntamente com o balanço de determinação na apuração de haveres do sócio dissidente 4. Recurso especial desprovido (STJ, 3.^a Turma, REsp 1.335.619, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. em 03.03.2015, p. em 27.03.2015. Grifou-se).

59

Comercial – Sociedade constituída por sócios diversos – Dissolução parcial – Critério de apuração dos haveres. I – Na sociedade constituída por sócios diversos, retirante um deles, o critério de liquidação dos haveres, segundo a doutrina e a jurisprudência, há de ser, utilizando-se o balanço de determinação, como se tratasse de dissolução total. II – precedentes do STJ. III – recurso não conhecido (STJ, 3.^a Turma, REsp 35.702, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. em 27.09.1993 p. em 13.12.1993).

60

Art. 4.^o. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifou-se).

61

Fernando Sacco Neto, op. cit., p. 1512.

62

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Direito societário. Dissolução parcial de sociedade. Apuração de haveres. Inclusão do fundo de comércio. Violação ao art. 1.031, caput, do CC. Não ocorrência. Honorários advocatícios. Súmula 7/STJ. Agravo regimental não provido. 1. O fundo de comércio integra o montante dos haveres da sociedade empresária quando da exclusão de sócio. Precedentes. 2. A revisão do critério adotado pelo Colegiado a quo, para a fixação dos honorários, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado em âmbito de especial, atraindo a incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, 4.^a Turma, AgRg no AREsp 78.175/MS, rel. Min. Raul Araújo, j. em 01.09.2015, p. em 24.09.2015).

63

Direito societário. Recurso especial. Ação de dissolução parcial de sociedades. Exclusão de sócio. Justa causa. Apuração de haveres. Data-base. Efetivo desligamento. Forma de pagamento. Juros de mora. Termo inicial. Prazo nongesimal para pagamento. Artigos. Analisados: 1.030, 1.031, 1.044 e 1.085 DO CC/2002. (...) 5. Para que não haja enriquecimento indevido de qualquer das partes, a apuração deve ter por base para avaliação a situação patrimonial da data da retirada (art. 1.031, CC/2002), a qual, na hipótese dos autos, foi objeto de transação entre as partes ao longo da demanda. (...) 10. Recursos especiais parcialmente providos (STJ, 3.^a Turma, REsp 1.286.708, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 27.05.2014, p. em 05.06.2014).

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

CAPÍTULO VI DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA

Seção I

Disposições gerais

1. Inventário e partilha: considerações iniciais

Inventário¹ e partilha² são os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa que objetivam arrolar os patrimônios ativo e passivo da pessoa falecida *de cujos* bens se refere, pagar os tributos incidentes e os respectivos credores, se houver, bem como partilhar entre os herdeiros o eventual patrimônio ativo remanescente.³

Para tanto, a lei processual opta pela criação de um ente processual temporário e sem personalidade jurídica. Esse ente despersonalizado transitório, constituído pelo conjunto de direitos e obrigações decorrentes da existência do patrimônio ativo e passivo do *de cujos* denomina-se *espólio*. O administrador e representante legal desse ente despersonalizado, denominado espólio, é o inventariante.⁴

Durante o período em que o inventário tramita, tanto a administração quanto a representação dos bens que pertenciam ao *de cujos* competem ao inventariante, pessoa também responsável pelo cumprimento das obrigações decorrentes da existência desse patrimônio. Enquanto não houver inventariante, o espólio é representado pelo chamado administrador provisório,⁵ qual seja a pessoa que estiver na posse dos bens naquele momento.

Segundo o direito material, em razão do princípio da “saisine”⁶ previsto no art. 1.784,⁷ do Código Civil, no exato momento da morte se transmitem tanto a posse quanto a propriedade dos bens deixados pelo “*de cujos*”.⁸

Na hipótese de existirem vários herdeiros, se forma a partir desse momento um condomínio com todos os bens, de maneira que a cada herdeiro corresponderá uma fração ideal dessa massa, o qual será desfeito – na hipótese de inventário judicial – apenas por ocasião do trânsito em julgado da sentença de partilha.

Assim, mesmo que a transmissão da propriedade dos bens deixados aconteça no momento da morte, é imprescindível que se realize, judicial ou extrajudicialmente, tanto o procedimento do inventário quanto a respectiva partilha.⁹

Portanto, a herança¹⁰ constitui uma universalidade de bens, e o espólio consiste na massa ainda não partilhada desses bens. Por sua vez, o inventário consiste no procedimento especial pelo qual se definem os bens que integram o acervo hereditário, bem como qual quinhão pertencerá a cada um dos herdeiros.

Os principais objetivos do inventário e da partilha são, dentre outros: identificar e separar os bens que compõem a meação do cônjuge; analisar se a herança é suficiente para o pagamento das dívidas, desde já pagando os credores habilitados; decidir a maneira pela qual se realizará a partilha, e assim por diante.

É antiga a discussão¹¹ sobre a natureza jurídica¹² do procedimento ser de jurisdição voluntária ou contenciosa,¹³. Por sua vez, o CPC de 2015 explicita, em diversos momentos, que as questões que dependam de prova diversa da documental não merecem análise no inventário, devendo-se utilizar as vias ordinárias, qual seja o procedimento comum (arts. 612,¹⁴ § 3.º, 627,¹⁵ § 2.º e 643).¹⁶

Logo, não cabendo ao juízo do inventário analisar determinadas questões contenciosas de mérito e de forma exauriente, a ideia é a de que a discussão é potencial, mas não necessária entre os herdeiros. O fato é que em virtude da potencialidade litigiosa o CPC de 2015 manteve, a esse respeito, a localização topográfica do inventário e da partilha junto aos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa.

2. Alterações tímidas

O CPC de 2015 pouco modificou o ineficiente procedimento de inventário e partilha, até então disciplinado pelos arts. 982 a 1.054 do CPC de 1973, mantendo o mesmo modelo e estrutura do diploma anterior.¹⁷

Houve alterações bem-vindas, tais como: a impossibilidade de o juiz iniciar inventários de ofício, exceção essa até então prevista no art. 989¹⁸ do CPC de 1973, numa espécie de juiz auditor fiscal; a antecipação dos efeitos da sentença de partilha para deixar clara a possibilidade de imediata fruição de bens (CPC de 2015, art. 647, par. único);¹⁹ o estabelecimento de critérios mais claros para a elaboração do plano de partilha (CPC de 2015, art. 648);²⁰ a instrumentalização de garantias ao nascituro (CPC de 2015, art. 650),²¹ dentre outras.

Entretanto, as alterações patrocinadas pelo legislador foram incapazes de simplificar a essência do procedimento e o formalismo dos atos tradicionalmente inerentes ao rito, neste aspecto, não acompanhando o pulso inovador que o CPC de 2015 recebeu em diversos temas.

Fica claro que o legislador poderia ter se dedicado com mais afinco ao assunto do inventário e da partilha, aproveitando melhor a oportunidade do novo diploma processual para combater a morosidade, a ineficiência, o formalismo e as demais idiosincrasias deste procedimento especial.

Considerando o interesse que o estado possui no recolhimento do imposto de transmissão *mortis causa* e doação – ITCMD, a obtenção de certidões negativas e a definição do imposto a pagar, além de outros atos, poderiam e deveriam ser efetuadas pelo próprio estado, a fim de que o interesse público na arrecadação e no combate à ineficiência dos inventários fosse satisfeito.²² Não foi esse, entretanto, o entendimento do legislador.

O fato, enfim, é que impostos deixarão de ser devidamente recolhidos, bens continuarão a ser negligenciados, empresas continuarão a sofrer os riscos da morte de sócios, dentre vários outros aspectos dessa realidade nociva que foram mantidos pelo CPC de 2015.

3. Competência internacional e competência interna

A jurisdição brasileira, no que concerne à competência internacional, é competente de forma exclusiva para processar os feitos de inventário sempre que os respectivos bens (CPC, art. 23, II),²³ sejam móveis ou imóveis, estiverem situados em território brasileiro.²⁴

Por sua vez, no que diz respeito à competência interna, as regras atinentes ao inventário são normas de competência territorial, pois a regra geral é a de que o juízo competente é o do último domicílio do autor da herança, mesmo que este tenha falecido fora do país (CPC, art. 48).²⁵

Se o autor da herança não possuía domicílio certo, o CPC de 2015 alterou a infeliz regra de fixação da competência territorial no local do óbito, de modo que a partir de agora passa a ser competente o foro da situação dos bens imóveis.

Caso o *de cujus* tivesse bens em foros diversos, qualquer um deles passa a ser competente. Da

mesma forma, se o falecido não possuía domicílio certo e nem bens imóveis em seu nome, será competente o foro dos lugares onde quaisquer bens do espólio estejam situados.

De fato, não faria sentido manter a regra de competência no foro do óbito (art. 96²⁶ do CPC de 1973), pois na maioria das situações, não há conveniência para o processo e muito menos para os herdeiros, em estabelecer a competência segundo critério diverso dos domicílios ou do local onde se encontram os bens. Positiva a alteração, portanto.

Exceto nas hipóteses de competência fixada em decorrência de critérios exclusivos, tais como o direito real sobre bens imóveis (CPC, art. 47), é universal a competência interna territorial dos procedimentos de inventário e partilha, motivo pelo qual referido juízo, via de regra, atrai a competência das ações onde o espólio é demandado (CPC, art. 48).

Importa lembrar, ainda que as normas de competência no inventário se aplicam tanto para o inventário e a partilha propriamente ditos quanto para o cumprimento das disposições de última vontade, a arrecadação, a anulação e a impugnação de partilhas efetuadas extrajudicialmente (CPC, art. 48).²⁷

Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.

§ 1.º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2.º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

1. Procedimentos correlatos

O inventário e a partilha judiciais são os principais procedimentos pelo qual se efetua a delimitação dos bens objeto do espólio e a sua distribuição entre os herdeiros. Não constituem, entretanto, os únicos procedimentos com estas finalidades.

Nesse sentido, e com os mesmos objetivos gerais, o sistema jurídico brasileiro ainda dispõe do inventário extrajudicial (Resolução 35/2007 do CNJ e CPC, art. 610), do pedido de alvará judicial e do inventário negativo.

1.1. Inventário extrajudicial: opção das partes

A distinção central entre inventários e partilhas judiciais e extrajudiciais²⁸ foi mantida, conforme já era possível sob a égide do CPC de 1973 na modificação trazida pela Lei 11.441/2007,²⁹ em estrutura similar aos sistemas italiano e português, especialmente regulada pela Resolução 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça.

O inventário judicial continua sendo obrigatório apenas nos casos em que houver herdeiro incapaz ou em que o falecido tiver deixado testamento. Fora dessas hipóteses, as partes mantêm a opção de realizar o inventário e a partilha em cartório, extrajudicialmente, de modo simples e ágil (CPC, art. 610).³⁰

Embora o inventário extrajudicial seja efetuado em cartório, o tabelião³¹ somente lavrará a escritura se todos os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público,³²⁻³³ cujas assinaturas e qualificações necessitam, sob pena de invalidade, constar obrigatoriamente do ato notarial (CPC, art. 610, § 2.º).

Vale lembrar que a respeito da atuação profissional dos advogados nas escrituras públicas de divórcios, inventários e partilhas, o Conselho Federal da OAB emitiu o Provimento 118/2007, complementando a regulamentação iniciada pela Lei 11.441/2007 junto ao CPC então vigente, mas

cuja aplicação se manterá em face da ausência de maiores inovações pelo CPC de 2015 a respeito dessa estrutura procedimental.

Importa esclarecer que o acordo pode ser realizado inclusive fora do país,³⁴ mas para ter eficácia no Brasil deve respeitar os requisitos do art. 610 do CPC de 2015, o art. 221 e ss. da Lei de Registros Públicos – Lei 6015/1973. Em território nacional, o cartório a ser escolhido pelas partes não necessita respeitar as regras de competência estabelecidas para os feitos judiciais³⁵⁻³⁶ (CPC, art. 48 e Resolução 35/2007, art. 1.º).

Assim, o inventário extrajudicial³⁷⁻³⁸⁻¹⁰³ é feito por meio de escritura pública,

sendo que³⁹ tal documento⁴⁰ também é hábil tanto para efetuar atos de registro dos bens – Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas Comerciais, Instituições Financeiras, Detran – quanto para realizar o levantamento de valores havidos junto a instituições financeiras, independente do valor e mesmo havendo outros bens a serem inventariados (CPC, art. 610, § 1.º).

Logo, inova o CPC de 2015 ao fazer com que a escritura pública se transforme em documento hábil para qualquer registro – portanto, não apenas o imobiliário – bem como para obter quaisquer valores depositados em instituições financeiras (CPC, art. 610, § 1.º).

O fato do CPC de 2015 não afirmar expressamente que a escritura pública e os demais atos notariais são gratuitos, àqueles que não puderem pagar por suas custas⁴¹ não retira o direito à gratuidade do ato, o qual obviamente permanece nessa hipótese, pois mantêm-se as previsões dos arts. 6.º e 7.º⁴² da Resolução 35/2007 do CNJ, bem como do art. 5.º, LXXIV da CF e da Lei 1060/1950.⁴³⁻⁴⁴

1.2. Alvará judicial

O alvará judicial é um procedimento simplificado e autônomo que está previsto na Lei 6.858 de 1980. Trata-se de mero pedido feito por simples petição diretamente ao juízo das sucessões, e que pode ser realizado quando não há outros bens sujeitos a inventário (CPC, art. 664)⁴⁵ e que os saldos bancários, de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento sejam de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN.

Trata-se de um simples requerimento efetuado, via de regra, nas hipóteses em que os bens deixados pelo *de cujos* correspondem apenas a quantias monetárias havidas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, no PIS – Programa de Integração Social, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, em restituições de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF.

Importa lembrar que segundo a Súmula 161⁴⁶ do STJ,⁴⁷ a princípio não atingida pelo CPC de 2015, mesmo que o objeto do alvará seja o levantamento de valores atinentes ao PIS, PASEP e ao FGTS, a justiça competente para a realização do pedido é a comum estadual.

Além das restituições de IRPF, do FGTS e PIS/PASEP, também é possível utilizar o alvará judicial autonomamente para quantias depositadas em contas ou aplicações bancárias, desde que não existam outros bens sujeitos a inventário (CPC, art. 664) e que os saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento sejam de valor até 500 (quinhentas) OTN, havendo previsão legal específica com relação a esse propósito (Lei 6.858/1980, art. 2.º).

Caso os herdeiros assim prefiram, ao invés do pedido de alvará judicial, mesmo havendo outros bens sujeitos a inventário, e ainda que os saldos bancários, de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento sejam de valor superior a 500 (quinhentas) OTN, o CPC de 2015 permite que as quantias depositadas em contas ou aplicações bancárias sejam objeto de inventário extrajudicial por escritura pública, hipótese esta prevista no § 1.º do art. 610.

1.3. Inventário negativo: judicial e extrajudicial

O inventário negativo⁴⁸ judicial é uma ação cuja pretensão é comprovar que o falecido não deixou bens, possuindo efeitos especialmente em face dos herdeiros cujas relações jurídicas com terceiros possam ser afetadas caso não seja declarada a inexistência de bens do *de cujos*. Sua eficácia sentencial é, portanto, de natureza declaratória negativa.⁴⁹

Importa salientar, entretanto, que o inventário negativo pode ser tanto judicial quanto extrajudicial (Resolução 35/2007 do CNJ, art. 28). Poderá ser extrajudicial,⁵⁰ entretanto, apenas na hipótese de não haver herdeiros incapazes e de não haver sucessão por testamento. Sendo extrajudicial o inventário negativo, este se dará por escritura pública, em cartório, com a participação de advogados ou defensores públicos.

A competência para a sua propositura é a mesma do inventário positivo. Embora não seja previsto explicitamente na lei processual, o inventário negativo não constitui mera criação da prática forense, mas sim um importante instrumento para salvaguarda de direitos em hipóteses expressamente previstas no ordenamento.

Por isso mesmo, há claras remissões às hipóteses de inventário negativo junto ao Código Civil, tanto para proteger o patrimônio dos herdeiros nas hipóteses em que as dívidas do *de cujos* superarem o ativo deixado, eximindo-os desta reponsabilidade (CC, art. 1.792),⁵¹ quanto para permitir que o cônjuge supérstite venha a se casar novamente (CC, art. 1.523, I)⁵² em um regime diverso da separação legal (CC, art. 1.641, I).⁵³

2. *Conversibilidade dos procedimentos*

Assim como ocorria sob a égide do CPC de 1973, no CPC de 2015 continua sendo possível converter o inventário solene em arrolamento e o arrolamento em inventário solene, ou mesmo uma espécie de arrolamento em outra, desde que ao longo do trâmite haja modificação ou descoberta de falsa percepção sobre requisitos inerentes a cada procedimento.

Logo, em exemplos como a hipótese de um herdeiro capaz se tornar incapaz, ou vice-versa (hipótese em que um pressuposto processual de validade é alterado – art. 485, IV do CPC de 2015) ou, ainda, caso um testamento seja invalidado ou validado judicialmente, pode sim haver alteração no procedimento de inventário que está em curso (CPC, art. 610 § 1.º).⁵⁴

Ainda que não seja oriunda de determinação do juízo para que as partes se manifestem a respeito da modificação ou descoberta de falsa percepção sobre os requisitos do art. 610, referida conversão pode decorrer de requerimento das partes.

Seguindo o princípio da primazia do julgamento do mérito,⁵⁵ ao qual o CPC de 2015 é caro, a conversão procedimental também pode ser determinada de ofício pelo magistrado, caso perceba a modificação ou descoberta de falsa percepção sobre os mesmos requisitos.

Isto porque a finalidade dos procedimentos é uma só, não havendo nulidade na conversão de ofício, respeitando-se apenas a regra do art. 10⁵⁶ do CPC de 2015, para que as partes possam se manifestar a este respeito (o que não altera a iniciativa de ofício do juízo).

Em verdade, prejuízos só ocorrerão caso a partilha não se ultime eficientemente, não havendo motivo para extinção do feito sem resolução de mérito caso as partes não requeiram a conversão de procedimentos. Por isso, não merece ser aplicada à hipótese o art. 485, IV⁵⁷ do CPC de 2015.

Da mesma forma, segundo o art. 657,⁵⁸ sendo capazes os herdeiros e estando presentes os demais requisitos, durante o inventário judicial as partes continuam podendo efetuar acordo e requerer homologação pelo juízo, ou ainda, a teor do art. 2.º⁵⁹ da Resolução 35/2007 do CNJ, requerer a extinção do feito sem resolução de mérito para optarem pela via da escritura pública.

3. *Espécies reguladas pelo CPC: inventário, partilha e arrolamento*

No CPC de 2015, o inventário e a partilha podem seguir dois procedimentos diversos: a) inventário e partilha solenes (art. 615 a 658 do CPC de 2015) ou; b) arrolamento (CPC de 2015, art. 659 a 666).

Por sua vez, o arrolamento poderá ser: b1) arrolamento sumário, a teor do art. 660,⁶⁰ ou arrolamento simples, caso o valor da herança seja menor do que 1.000 (mil) salários mínimos. Tais procedimentos serão o objeto dos comentários a seguir.⁶¹

Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.

1. Prazo para instauração do inventário

O inventário deve ser instaurado no prazo de até 2 (dois) meses após o óbito da pessoa de cujo patrimônio trata o procedimento, momento esse em que ocorre a abertura da sucessão⁶² (CPC, art. 611).

O prazo,⁶³ até então vigente segundo o CPC de 1973, era de 60 (sessenta dias), de modo que a nova regra não traz inovação significativa.

Trata-se de prazo dilatatório, de modo que o inventário pode ser instaurado mesmo após o seu transcurso, sem que haja sanções internas ao processo.

Entretanto, na hipótese de não ser cumprido o prazo de 2 (dois) meses, as Fazendas Públicas Estaduais (CF, art. 155, I),⁶⁴ via de regra, cobram multa pelo atraso na propositura, dado o interesse público havido na arrecadação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD.⁶⁵ A ideia é que a multa puna a eventual má-fé demonstrada pela conduta de determinados herdeiros, na tentativa de evitar o pagamento do ITCMD.

Tal postura por parte dos estados membros está autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante a Súmula 542,⁶⁶ segundo a qual não se consideram inconstitucionais as multas instituídas como sanção pelo retardamento do início ou do término do procedimento de inventário.

No CPC de 1973, além da multa, o atraso na propositura do inventário também tinha a consequência de conceder legitimidade ao magistrado para iniciar o processo de ofício (art. 989⁶⁷ do CPC de 1973) – hipótese não mantida pelo CPC de 2015 – dispositivo esse pouquíssimo aplicado, constituindo vetusto resquício do antigo magistrado coletor de impostos.

2. Prazo para o término do inventário

O inventário deve ser terminado no prazo de até 12 (doze) meses contados da data da sua instauração (CPC, art. 611, 2.^a parte), mantendo-se, a este respeito, as disposições do art. 983⁶⁸ do CPC de 1973.

Trata-se de prazo não peremptório, voltado para o juiz, motivo pelo qual se trata de prazo impróprio, incapaz de gerar sanções ou ônus processuais. Seu objetivo é traçar apenas um prazo ideal para a ulatimação dos inventários.

Assim, o magistrado pode prorrogar tanto o prazo de instauração quanto o prazo de término do inventário, dado serem prazos dilatatórios.

Por sua vez, os demais atores do processo de inventário necessitam respeitar prazos sob pena de preclusão, com a conseqüente perda da oportunidade de recorrer, de produzir provas, e assim por diante.

Logo, tanto os advogados quanto o inventariante, além de outros atores, necessitam respeitar prazos no processo de inventário,⁶⁹ sob pena de sofrerem sanções processuais, inclusive eventual perda da inventariança (CPC, art. 622, II).⁷⁰

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

1. Fatos comprováveis documentalmente e questões de alta indagação

Os fatos que são analisados dentro do procedimento de inventário devem ser comprovados documentalmente.⁷¹ Essa regra exige que todos os fatos cuja demonstração necessite ser feita mediante dilação probatória sejam objeto de procedimento ou ação específicos.⁷²

Ao contrário do que pode dar a entender a redação do art. 612, a cognição exercida pelo juízo do inventário versa sobre fatos e sobre direitos, mas quando incidental ao seu procedimento propriamente dito, desenvolve-se de forma exclusivamente documental, embora exauriente e vertical.

Ainda que, ao final do inventário, sejam considerados no inventário os temas que demandam prova oral, pericial ou mesmo de inspeção judicial – imagine-se, por exemplo, a prova oral sobre a união estável, para que a companheira possa integrar o rol de herdeiros (CC, art. 1.790)⁷³ – estes são denominados *questões de alta indagação*,⁷⁴ a respeito das quais deve haver, portanto, ação autônoma.

O art. 612 do CPC de 2015 apenas busca confirmar o que a doutrina e a jurisprudência (STJ, REsp 114.524/RJ)⁷⁵ já afirmavam a respeito do conceito de questões de alta indagação⁷⁶ como sendo aquelas questões preponderantemente de fato, as quais não são demonstráveis por meio de prova documental.

Veja-se que a distinção entre questão de fato e questão de direito utilizada pelo CPC de 1973 (art. 984),⁷⁷ foi abandonada, pois não existe questão puramente de fato ou de direito. Toda questão é tanto de fato quanto de direito.

Há fatos de alguma complexidade, mas que podem ser demonstrados documentalmente, de modo que a remessa às vias ordinárias nessas hipóteses dependerá da situação havida em cada feito, sendo, a decisão de remessa às vias ordinárias, objeto de agravo de instrumento no CPC de 2015 (art. 1.015, parágrafo único).⁷⁸

Imagine-se a cobrança de aluguel referente a um imóvel do espólio efetuada por um herdeiro em relação a outro. Tal prova pode não estar nos autos do inventário, mas caso toda a documentação correspondente se encontre no feito, não será necessário remetê-lo às vias ordinárias (STJ, 4.^a T. REsp 19043/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.06.2001).

Por outro lado, as questões cuja preponderância é de direito, por mais complexas que possam parecer não necessitam de maiores elementos probatórios, devendo ser decididas no próprio procedimento de inventário, e em nada se relacionando à *alta indagação*.

2. Autoridade para reconhecer a questão de alta indagação e recurso cabível

A autoridade que possui competência para analisar se uma questão é de alta indagação é o Juízo do inventário, ainda em primeiro grau, o qual remeterá às vias ordinárias⁷⁹ o feito na hipótese de necessidade de prova diversa da documental.

Em face dessa decisão, o recurso cabível é o agravo de instrumento, uma vez que se trata de decisão interlocutória impugnável a teor do art. 1.015, parágrafo único do CPC de 2015, pelo qual, dependendo da situação, poderá ser requerida inclusive a suspensão do procedimento de

inventário até que a questão seja definida.

3. Litispendência entre inventário e ação de conhecimento

Na hipótese da propositura de ação que verse sobre a matéria de alta indagação, obviamente não há litispendência, mas sim complementariedade entre o seu objeto e o tema da ação autônoma cognitiva superveniente.

Entretanto, caso a ação cognitiva supervenientemente proposta não verse sobre questão de alta indagação, haverá extinção deste feito posterior, consoante o art. 485, V⁸⁰ do CPC de 2015, pois o tema será de competência do juízo do inventário e por ele deverá ser decidido (STJ, REsp 960.885/RS, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *Dje*. 08.06.2009).⁸¹

Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.

1. O administrador provisório do espólio

O espólio consiste no conjunto de bens e obrigações desprovidos de personalidade jurídica que pertenciam ao falecido, e cuja administração e partilha – mediante o pagamento dos respectivos impostos – é o objeto do inventário.

Em razão do princípio da “saisine”⁸² previsto no art. 1.784,⁸³ do Código Civil, no momento da morte se transmitem automaticamente aos herdeiros tanto a posse quanto a propriedade dos bens que compõem o espólio, servindo o inventário para que se divida esse monte patrimonial entre os herdeiros.

Durante o período em que o inventário tramita, tanto a administração quanto a representação dos bens que pertenciam ao *de cujos* competem ao inventariante, pessoa também responsável pelo cumprimento das obrigações decorrentes da existência desse patrimônio.

Entretanto, enquanto não existir inventário, ou ao menos enquanto não houver inventariante compromissado, o espólio é representado pelo chamado administrador provisório⁸⁴ (STJ, REsp 777.566/RS, 3.^a T. RL. Des. Conv. Vasco Della Giustina, *Dje* 13.05.2010).⁸⁵

Assim, o administrador provisório é a pessoa que estiver na posse dos bens naquele momento, podendo ser o cônjuge ou o companheiro, outro herdeiro, ou mesmo uma pessoa nomeada pelo juiz com essa finalidade, à qual se referem os arts. 613 do CPC de 2015 e 1.797⁸⁶ do CC.

Caso o administrador provisório seja o cônjuge, o companheiro ou o herdeiro do falecido – algo bastante frequente – não será necessário prestar compromisso por termos nos autos.

Veja-se que assim como ocorre com o inventariante, o administrador provisório também poderá representar o espólio e integrar a sua capacidade processual em juízo, seja como autor ou réu, a teor do art. 614 do CPC.

Importante considerar, ainda, que o administrador provisório também tem o dever de pedir a abertura do inventário caso esteja a cuidar diretamente dos bens a inventariar antes mesmo do falecimento do *de cujos*, consoante explicita o art. 615, *caput*⁸⁷ do CPC de 2015.⁸⁸

Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

1. Poderes do administrador provisório

Os poderes, os deveres e as demais atribuições do administrador provisório são disciplinados

pelo art. 614 do CPC de 2015, nos exatos termos do que dispunha o art. 986⁸⁹ do CPC de 1973.

Em verdade, a estrutura e os limites da atuação do administrador provisório são, essencialmente, as mesmas previstas para o inventariante (CPC de 2015, arts. 618⁹⁰ e 619),⁹¹ inclusive podendo responder por culpa ou dolo pelos eventuais danos a que der causa (CC, art. 927).⁹²

Assim, sob pena de responsabilização por culpa ou dolo, o administrador provisório deve velar pelo patrimônio e trazer à massa todos os haveres obtidos, tendo o direito de se ressarcir pelas despesas decorrentes das medidas necessárias à manutenção desses bens.

Nesse sentido, o STJ⁹³ tem decidido, por exemplo, que cabe ao administrador provisório representar de antemão o espólio nas execuções fiscais a ele direcionadas por ocasião da morte do executado.

Entretanto, nas hipóteses em que o inventário ainda não se iniciou, ou mesmo naquelas em que ele já se encerrou, o administrador provisório não é o único representante do espólio aceito pela jurisprudência.

Caso todos os herdeiros proponham ação referente a direito pertencente ao espólio, em respeito ao acesso à justiça, também existe legitimação da totalidade dos herdeiros, mas desde que estejam no polo ativo (STJ, MS 20.365/DF, 1.ª Seção, rel. Min Sérgio Kukina, j. 09.04.2014).⁹⁴

Vale considerar, ainda, que no tocante ao dano moral, o STJ uniformizou entendimento de que também é plausível a propositura de medida judicial pelos herdeiros, além da legitimidade conferida ao administrador provisório, para pleitear dano sofrido pelo falecido.⁹⁵

Seção II

Da legitimidade para requerer o inventário

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611.

Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança.

1. A abertura do inventário: rito solene e ritos de arrolamento

O rito solene do inventário é residual, devendo ser aplicado somente quando não houver um rito de arrolamento aplicável à espécie.⁹⁶ Logo, aplica-se o rito solene do inventário subsidiariamente aos procedimentos de arrolamento, inclusive no que tange à petição de abertura do inventário (CPC, art. 318, parágrafo único).⁹⁷

No rito solene, a fase de inventário começa com a petição que requer a sua abertura, terminando no ato que homologa o cálculo dos tributos que incidirão sobre a herança. Já na fase de partilha, os tributos são recolhidos e a partilha é apresentada a fim de ser julgada por sentença.

A abertura do inventário deve ser solicitada por aquele que estiver na posse ou administração⁹⁸ de parcela ou integralidade dos bens do espólio, fazendo-o no prazo de dois meses (CPC, art. 611),⁹⁹ sob pena de multa.

Caso o requerente não seja familiar do falecido – como, por exemplo o credor ou devedor do *de cujos*, ou mesmo o cessionário do herdeiro ou legatário – será importante demonstrar a sua ligação com o *de cujos* ou com o espólio (CPC de 2015, art. 616, V).¹⁰⁰

2. A petição inicial de inventário

A petição de abertura do inventário é uma inicial simples (CPC, art. 319¹⁰¹ e ss.), que deve requerer o início do procedimento, juntando a certidão de óbito do autor da herança, bem como declarando a existência de bens e de herdeiros e requerendo a nomeação de inventariante.

Devem constar da petição de abertura, tanto a certidão de óbito do autor da herança (CPC de 2015, art. 615, parágrafo único)¹⁰² quanto os documentos pessoais do falecido, além dos documentos de identificação do próprio requerente.

É claro que, caso ainda não estejam com o requerente, os documentos eventualmente faltantes poderão ser complementados, em prazo razoável, após o protocolo do pedido de abertura, não se exigindo maior complexidade formal.

Também é cediço que o requerente, caso queira se adiantar, já poderá trazer informações mais detalhadas sobre o patrimônio e os herdeiros desde a petição inicial, informações essas que irão delineando as futuras primeiras declarações.

Outras medidas já podem ser tomadas desde a petição inicial, tais como decisões acautelatórias do patrimônio, nomeação de curadores especiais, dentre outras medidas eventualmente urgentes e adequadas.

Como o inventário versa sobre uma universalidade de bens, nem sempre será possível saber já na abertura do procedimento todos os bens a inventariar e todos os herdeiros a habilitar, havendo dificuldade em avaliar e somar os valores de todos os bens que compõem o monte, a fim de valorar a inicial.

Por esse motivo, admite-se que a petição inicial do inventário tenha pedido genérico (CPC de 2015, art. 324, § 1.º, I),¹⁰³ bem como que o valor da causa seja indicado por estimativa (CPC de 2015, arts. 291,¹⁰⁴ 292¹⁰⁵ e 319, V).¹⁰⁶ Entretanto, caso já se conheça os valores dos bens correspondentes ao monte, a sua soma deverá corresponder ao valor da causa (STJ, REsp 459852/SP 3.ª T. Rel Min. Nancy Andrigli, *Dju* de 29.09.2003).^{107,108}

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I – o cônjuge ou companheiro supérstite;

II – o herdeiro;

III – o legatário;

IV – o testamenteiro;

V – o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI – o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

VII – o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes;

VIII – a Fazenda Pública, quando tiver interesse;

IX – o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

1. Legitimidade concorrente

O inventário pode ser proposto por qualquer dos legitimados ativos constantes do art. 616 do CPC de 2015, além do administrador provisório.

Uma vez aberto o inventário, os demais legitimados não podem propô-lo novamente em qualquer dos juízos competentes, havendo prevenção do juízo e induzindo-se litispendência.

Trata-se de uma legitimidade de caráter concorrente¹⁰⁹ em que não há ordem de preferência entre os legitimados, bem como de um rol incompleto por conta de o administrador provisório também possuí-la. As hipóteses do art. 616 não são, portanto, *numerus clausus*.

Por outro lado, o CPC de 2015 é didático ao inserir no sistema legal uma legitimidade que a jurisprudência já concedia ao companheiro supérstite, com fundamento no art. 1.790¹¹⁰ do CC (STJ, REsp 1.341.872, j. 08.10.2013, rel. Min. Luiz Felipe Salomão).

Outros legitimados, como o Ministério Público e a Fazenda Pública, também poderão propor o inventário, mas desde que haja a presença de determinados requisitos, quais sejam, respectivamente, a existência de herdeiros incapazes cujos interesses possam ser prejudicados¹¹¹ e o interesse do Estado.

No caso do Ministério Público, mesmo propondo o inventário, este também atuará no feito como fiscal da lei. Por sua vez, no âmbito da Fazenda Pública, o interesse do Estado é, essencialmente, o de arrecadação do ITCMD,¹¹² não se vislumbrando outras formas de interesse que justifiquem tal legitimidade. Não haveria legitimidade desta, por exemplo, para a propositura de inventário negativo.

Lembre-se, ainda, que o CPC de 2015 felizmente retira, enfim, a legitimidade do juiz para propor o inventário (CPC de 1973, art. 989).¹¹³ Tratava-se de regra ultrapassada e incoerente com o papel do Poder Judiciário a partir das premissas traçadas pela Constituição Federal de 1988.¹¹⁴

Seção III

Do inventariante e das primeiras declarações

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV – o herdeiro menor, por seu representante legal;

V – o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI – o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII – o inventariante judicial, se houver;

VIII – pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

1. O inventariante e a inventariança

Ao contrário do art. 616, o art. 617 do CPC de 2015 estabelece uma ordem de preferência. Entretanto, ao invés da legitimidade para a abertura do inventário, estabelece a ordem para a nomeação do inventariante.

A função do inventariante é administrar e representar o espólio, tanto em juízo, com legitimidade *ad processum* ativa e passiva (art. 77, VI¹¹⁵ do CPC de 2015), quanto fora dele, a teor das disposições constantes dos arts. 159¹¹⁶ a 161, 618¹¹⁷ e 619¹¹⁸ do CPC de 2015.

O inventariante é nomeado pelo Juízo do inventário para tomar conta dos bens do espólio e representá-lo, desde a data em que presta o compromisso de fielmente desempenhar o encargo, assinando o termo de inventariante, até o trânsito em julgado da sentença de partilha, momento esse em que os herdeiros (CPC de 2015, art. 655),¹¹⁹ separadamente ou em conjunto, representarão os interesses da parte da herança que lhe couber.

Decide-se quem será o inventariante, de maneira fundamentada (CPC de 2015, art. 489),¹²⁰ segundo os critérios da ordem do art. 617, e sendo, tal decisão, agravável por instrumento.

Por conseguinte, no prazo dilatatório – não peremptório, portanto – de 5 (cinco) dias, ocorrerá a prestação do compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, assim como a assinatura do termo de inventariante (parágrafo único do art. 617).

Importante lembrar, ainda, que além de ser um trabalho de grande responsabilidade, a inventariança não é uma função remunerada,¹²¹ podendo ter apenas as suas despesas ressarcidas. Trata-se, de fato, de uma missão árdua e frequentemente pouco compreendida, especialmente pelos demais herdeiros a serviço de quem o inventariante está.

Daí a proliferação dos prestadores de serviço que realizam a inventariança de forma dativa como atividade profissional, sendo remunerados pelo espólio ou pelo Estado. Isso porque apenas o inventariante dativo (617, VIII do CPC de 2015) possui direito a cobrar pelo seu trabalho, devendo receber do Estado na hipótese de justiça gratuita.

2. A nomeação do inventariante e a ordem de preferência

A nomeação do inventariante deve respeitar a ordem legal do art. 617 do CPC de 2015, preferências essas que agora constam expressamente do *caput* do dispositivo.

Trata-se de uma redação que aperfeiçoou o antigo art. 990¹²² do CPC de 1973, pois apenas no parágrafo único do art. 1.000 daquele diploma existia a previsão a respeito de uma ordem legal nos incisos do art. 990.

Veja-se que a ordem não é, e continuará não sendo, entretanto, absoluta. Isso em razão da diversidade das situações reais e da complexidade que envolve os mais variados contextos familiares.¹²³

Muito embora nem todas as decisões interlocutórias sejam impugnáveis mediante agravo no CPC de 2015, a teor do art. 1.015, parágrafo único,¹²⁴ as decisões interlocutórias proferidas em processos de inventário, dentre elas a decisão que nomeia o inventariante, serão imediatamente impugnáveis por meio do recurso de agravo de instrumento. Isso com todas as vicissitudes inerentes àquele recurso, inclusive a possibilidade de decisões monocráticas que suspendam ou alterem inventariantes nomeados em primeiro grau.

De qualquer forma, uma vez nomeado o inventariante, este deverá firmar, por termo nos autos, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Veja-se que é neste momento que se transfere do administrador provisório para o inventariante tanto a obrigação de gerir quanto a obrigação de representar o espólio em juízo ou fora dele, começando, a partir daí, o prazo para o oferecimento de uma das peças mais importantes do processo de inventário: as primeiras declarações.¹²⁵

No tocante à ordem do art. 617 propriamente dita, percebe-se, inicialmente, que os incs. I e II mantiveram a estrutura já traçada pelo art. 1.797¹²⁶ do CC, pouco importando o regime de convivência ou de casamento, mas sim o fato de o cônjuge ou companheiro estar ou não

convivendo com o *de cujos* na data da morte.

Por sua vez, os demais herdeiros só poderiam ser nomeados, em princípio, se não houver cônjuge ou companheiro supérstite ou se estes não puderem, não quiserem ou houver outro legitimado categoricamente disponível e claramente mais adequado para o desempenho da tarefa, exatamente por não ser absoluta a ordem do art. 617.

Da mesma maneira, o CPC de 2015 acrescentou o herdeiro menor, por seu representante legal, corretamente representado ou assistido, bem o cessionário do herdeiro ou legatário, como legitimados para exercerem a inventariança.¹²⁷

Dentre os herdeiros, entretanto, há preferência para aquele que se achar na posse e administração do espólio. Ainda nessa ordem, vem, após, o testamenteiro, o inventariante judicial, se houver, ou, na última hipótese, qualquer pessoa estranha nomeada pelo juiz. Nos dois últimos casos, os inventariantes são denominados dativos, enquanto em todos os demais, chamam-se inventariantes legítimos.

A ordem trazida pelo CPC de 2015 também inovou ao deixar clara a possibilidade de administradores judiciais, ou mesmo de qualquer pessoa idônea e da confiança do juiz exercer a inventariança como dativo.¹²⁸

Os inventários são feitos de trâmite pouco ágil, desgastantes e naturalmente intensos, mormente sob o prisma dos aspectos emocionais envolvidos. Nesse sentido, é frequente haver discussões, divergências e dificuldades de relacionamento entre os herdeiros.

Logo, a nomeação de inventariante dativo por vezes demonstra-se adequada nos casos em que o patrimônio é complexo e extenso. Assim, em meio ao cenário comum aos inventários, a realidade que permeia tais feitos indica ser muitas vezes bem vinda a nomeação de terceiro estranho aos herdeiros para o exercício da inventariança, cujo exercício da função estará menos influenciado pelos elementos pessoais que frequentemente o atrapalham.¹²⁹

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I – representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1.º;

II – administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III – prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV – exhibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V – juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI – trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII – prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII – requerer a declaração de insolvência.

1. Tarefas e espécies de inventariante

Os arts. 618 e 620¹³⁰ do CPC de 2015 reproduzem os arts. 991¹³¹ e 993¹⁹⁶ do

CPC de 1973.¹³² Segundo eles, a administração dos bens do espólio efetuada pelo inventariante é ordinária, isto é: corresponde a todos os atos necessários à representação e tutela dos bens do espólio.¹³³

O art. 618 dispõe, assim, sobre os deveres e os poderes que o inventariante possui com o objetivo de realizar a sua função. Todos esses deveres ensejam, um último dever consequente, de prestar contas aos demais herdeiros, objeto este cujo eventual procedimento é incidental ao inventário.

Deste modo, a prestação de contas¹³⁴ por parte do inventariante constitui uma ação incidental e conexa ao inventário, podendo ser determinada de ofício pelo Juízo, requerida pelo Ministério Público, requerida por qualquer herdeiro ou oferecidas por iniciativa da própria parte.

Além da prestação de contas o inventariante possui diversas outras atribuições. A primeira delas é representar o espólio ativa e passivamente, tanto em juízo quanto fora dele.

No que tange ao inventariante dativo, entretanto, o CPC de 2015 alterou a regra do CPC de 1973, pela qual, como o inventariante dativo não é herdeiro, ele não representava o espólio em juízo. Logo, na regra antiga, eram os próprios herdeiros que representavam em juízo o espólio nos feitos judiciais.

Entretanto, a alteração introduzida pelo art. 75, § 1.º¹³⁵ do CPC de 2015 fez com que os herdeiros deixassem de ser parte nas ações judiciais em que o inventariante é dativo e os interesses do espólio estão em jogo.

Assim, a atuação do inventariante dativo foi bastante incrementada no CPC de 2015, de modo que ele passou a também representar o espólio em juízo, criando-se apenas a necessidade de intimação dos herdeiros nos feitos nos quais o espólio seja parte, a teor do § 1.º do art. 75.

É importante lembrar, ainda, que segundo os arts. 1.314¹³⁶ e 1.791, parágrafo único¹³⁷ do CC, além do inventariante, o coerdeiro também possui legitimidade para propor, em seu nome, ação judicial visando reivindicar bens que eventualmente estejam em poder de terceiros, independente de litisconsórcio junto aos demais herdeiros.

Tal regra constitui uma hipótese de legitimação extraordinária (CPC de 2015, art. 18),¹³⁸ dado se tratar, em princípio, de direitos cuja titularidade, ainda que transitória, pertence ao espólio (STJ, REsp 1.192.027, 3.ª Turma, rel. Min. Massami Uyeda, DJ 06.09.2010),¹³⁹ motivo pelo qual o espólio, por seu inventariante, poderá intervir no feito como assistente litisconsorcial (CPC de 2015, art. 18, parágrafo único).

Também cabe ao inventariante, seja ele dativo ou não: administrar os espólio com todo zelo, como se o patrimônio fosse seu; prestar as declarações de bens, pessoalmente ou por procurador; exibir a documentação relativa ao espólio em cartório, permitindo seu exame pelas partes.

É dever do inventariante, ainda: juntar certidões de testamento, caso hajam; promover a colação¹⁴⁰ dos bens recebidos por herdeiros excluídos, renunciantes ou ausentes; prestar contas de sua gestão sempre que lhe for determinado, bem como ao deixar o cargo, além de requerer eventual declaração de insolvência (CPC de 2015, incs. II a VIII do art. 618).¹⁴¹

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I – alienar bens de qualquer espécie;

II – transigir em juízo ou fora dele;

III – pagar dívidas do espólio;

IV – fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

1. Demais incumbências do inventariante

As demais atribuições do inventariante são facultativas. Ao contrário daquelas previstas no art.

618, invariavelmente desempenhadas, as incumbências previstas no art. 619 podem ou não ocorrer, ficando na dependência da verificação dos seus pressupostos.

Assim, tais atribuições estão condicionadas à conveniência para o espólio na realização de determinadas operações de cunho financeiro ou negocial, tais como a alienação de bens do espólio (inc. I); a realização de acordo ou transação em juízo ou fora dele (inc. II); o pagamento das dívidas do espólio, se houver (inc. III); o dispêndio dos montantes necessários ao melhoramento e à conservação do patrimônio (inc. IV).

Veja-se que estas atribuições, ao contrário daquelas previstas no art. 618, dependem da ouvida dos demais interessados, bem como de anuência do juízo, requisitos esses sem os quais a prática dos atos constantes do art. 619 – tais como a venda dos bens do espólio antes da partilha, até para a obtenção da liquidez necessária ao pagamento dos respectivos tributos – seria nula.¹⁴²

No CPC de 1973 o inventariante também tinha o poder de requerer a declaração de insolvência do espólio (CPC de 1973, art. 759),¹⁴³ legitimidade essa não prevista pelo art. 619 do CPC de 2015.

Vale lembrar, a esse respeito, que o procedimento de insolvência civil não foi regulado pelo CPC de 2015, mantendo sua regulamentação de acordo com Livro II, Título IV, do CPC de 1973. Será, portanto, uma parte do CPC de 1973 que excepcionalmente continuará em vigor, embora seja, salvo raras exceções, pouquíssimo aplicada no cotidiano forense.

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

I – o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento;

II – o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável;

III – a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado;

IV – a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam;

b) os móveis, com os sinais característicos;

c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos;

d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância;

e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data;

f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores;

g) direitos e ações;

h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio.

§ 1.º O juiz determinará que se proceda:

I – ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual;

II – à apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima.

§ 2.º As declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, à qual o termo se reportará.

1. As primeiras declarações

As primeiras declarações constituem uma das peças mais importantes do inventário. O objetivo das primeiras declarações é trazer ao processo, da forma mais clara possível, o quadro de herdeiros e a delineação do patrimônio, além dos demais direitos e obrigações que compõem o espólio.

Para apresentar as primeiras declarações, o inventariante ou seu procurador com poderes especiais para prestar as declarações (§ 2.º do art. 620), têm o prazo de 20 dias – embora prorrogável pelo juiz, de ofício ou a requerimento – contados da data da assinatura do termo de compromisso da inventariança.

O fato de as primeiras declarações poderem ser prestadas por procurador com poderes especiais é uma evolução em relação ao sistema arquitetado pelo CPC de 1973. Proporciona agilidade ao processo, especialmente nas situações em que exista dificuldade de locomoção por parte do inventariante.

Uma vez efetuadas as declarações, será lavrado termo circunstanciado específico, o qual será assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante (CPC de 2015, art. 620, *caput*), sob pena de nulidade do ato.¹⁴⁴

A importância das primeiras declarações reside no fato de que as suas informações pautarão o desenvolvimento inicial do processo de inventário. Por meio delas, os demais herdeiros e interessados terão ciência de quais bens, direitos e obrigações até aquele momento serão considerados como patrimônio do espólio. Da mesma forma, serão elas que possibilitarão saber, neste primeiro momento, quais são os herdeiros já relacionados pelo inventariante.

Portanto, as primeiras declarações servem para que os demais herdeiros, assim como os demais interessados no cumprimento das obrigações do espólio possam participar do procedimento, inclusive impugnando inclusões ou ausências que considerem indevidas, tanto de herdeiros quanto de bens, direitos e obrigações que compõem o espólio.

Logo, tal manifestação será tão complexa quanto a extensão, a diversidade do patrimônio e a quantidade de herdeiros, servindo como referencial preliminar para o restante do procedimento e das discussões a ele inerentes.

Na peça de primeiras declarações, que poderão ou não se dar por petição de procurador com poderes especiais (§ 2º do art. 620), o inventariante deverá, a teor do *caput* do art. 620 do CPC de 2015, qualificar o autor da herança, o dia e lugar em que falece, bem como se este deixou testamento; informar a qualificação completa dos herdeiros, os respectivos regimes de casamento ou da união estável, se houver.

Deverá, ainda, informar a qualidade e o grau de parentesco dos herdeiros com o autor da herança; a relação completa e pormenorizadamente individualizada dos bens que compõem o espólio, considerando também os bens que necessitem ser conferidos à colação, além, da mesma forma, dos bens eventualmente alheios nele encontrados. Deve-se considerar e listar todos os bens móveis, imóveis e semoventes que compõem o ativo e o passivo, da forma mais detalhada possível: na dúvida insere-se o bem nas primeiras declarações.

Na hipótese de o *de cujus* ser sócio de empresa cuja sociedade não era anônima, o CPC de 2015 exige, assim como faz a Súmula 265 do STF,¹⁴⁵ que haja apuração de haveres nos próprios autos do

inventário, por meio de contador nomeado pelo Juízo.

Entretanto, na hipótese de contestação dos valores pelos demais herdeiros, haverá alta indagação e, por conseguinte, será necessário remeter o feito às vias ordinárias a fim de apurar os haveres. Nesse sentido: STJ, REsp 289.151/SP, 3.^a Turma, rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina, *Dje* 25.10.2010.¹⁴⁶

Art. 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar.

1. Sonegação de bens pelos demais herdeiros ou pelo inventariante

Havendo dúvida, o inventariante deve inserir todos os bens e obrigações desde as primeiras declarações. Por isso, o inventariante e os demais herdeiros são responsáveis por fazer constar nos autos do inventário tanto os ativos quanto os passivos do espólio.

A conduta de sonegação¹⁴⁷ a que se refere o art. 621 do CPC de 2015 pode ser praticada pelo inventariante ou por qualquer outro herdeiro. Consiste exatamente no desrespeito desse dever de cuidado em informar a integralidade do patrimônio, prejudicando a fixação dos quinhões hereditários e, por conseguinte, a partilha.¹⁴⁸

Veja-se que o conteúdo do dispositivo é o mesmo do art. 1.996¹⁴⁹ do CC. Tal norma enseja a responsabilidade do inventariante e constitui fundamento plausível inclusive para a sua remoção (CPC de 2015, art. 622, VI¹⁵⁰ e art. 1993¹⁵¹ do CC) além de possibilitar outra sanção, mais específica, após a apresentação das últimas declarações (CPC de 2015, art. 636)¹⁵² qual seja a perda do direito sucessório que poderia caber ao inventariante exatamente sobre esse bem sonegado (CC, art. 1.992).¹⁵³

Isso porque o STJ possui entendimento que, até a apresentação das últimas declarações, não há que se falar em bens sonegados, uma vez que até este momento ainda se admite que o inventariante possa trazer novos itens que componham o patrimônio.

Apenas depois das últimas declarações é que nasce o interesse processual, portanto, na propositura da denominada ação de sonegados,¹⁵⁴ cujo prazo para manejo é de 10 (dez) anos (CC, art. 205).¹⁵⁵

Portanto, uma vez configurada a sonegação, os herdeiros ou credores do espólio terão legitimidade para propor a medida judicial cabível, qual seja a ação de sonegados,¹⁵⁶ visando que o bem não arrolado seja devidamente trazido ao monte a ser sobrepartilhado (CC, art. 2.022¹⁵⁷ e CPC de 2015, art. 669, I).¹⁵⁸

A ação de sonegados também possui um segundo objeto, qual seja o de fazer com que se apliquem as penas ao sonegador.¹⁵⁹

Entretanto, se a sonegação estiver suficientemente documentada, poderá ser decidida no corpo da própria sobrepartilha, nessa hipótese tornando-se desnecessária a propositura da ação de sonegados (CPC de 2015, art. 612).^{160_161}

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I – se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II – se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III – se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV – se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou

se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V – se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI – se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

1. Remoção e destituição do inventariante

O novo dispositivo estabelece sanção, assim como fazia o art. 995¹⁶² do CPC de 1973, essencialmente, para as condutas de desrespeitar os prazos legais para as primeiras ou últimas declarações; atrapalhar o andamento do inventário ou causar tumulto procedimental no seu desenvolvimento; deixar, por sua responsabilidade, que se deteriore, danifiquem ou dilapidem os bens do espólio; não defender o espólio judicialmente; não cobrar seus créditos nem evitar o perecimento de direitos; não prestar contas ou não ter suas contas aprovadas; sonegar, esconder ou desviar ativos pertencentes ao espólio.

Portanto, o art. 622 do CPC de 2015 descreve hipóteses que, exemplificativamente, possibilitam a remoção¹⁶³ do inventariante. Esse rol não possui caráter exaustivo, *numerus clausus*, mas simplesmente modelar, mantendo-se a interpretação dada pelo STJ^{164,165} ao antigo art. 99¹⁶⁶ do CPC de 1973.

Isso porque a riqueza da realidade é muito maior do que a criatividade e a imaginação do legislador. Assim, a conduta do inventariante deve, como um todo, condizer com as suas funções e responsabilidades, sob pena de remoção, a qual pode ocorrer tanto de ofício quanto a requerimento.¹⁶⁷

A possibilidade de a remoção ocorrer tanto de ofício quanto a requerimento é explicitada pela redação do art. 622 do CPC de 2015, bem como da postura jurisprudencial que fundamentou a alteração legal.¹⁶⁸

Muito embora o texto legal (*caput* do art. 622 do CPC de 2015) utilize o termo *remoção*, ainda persiste a possibilidade e a cultura em falar-se também na situação de *destituição* do inventariante.

Ao contrário da remoção, no cotidiano forense costuma-se denominar como *destituição* as situações de substituição do inventariante que não decoram de falhas no cumprimento do seu dever (CPC de 2015, art. 552),¹⁶⁹ tais como a conveniência ou a necessidade de sua substituição por motivo de saúde, ou mesmo pela assunção de compromisso profissional em localidade distinta da comarca onde tramita o feito.

A hipótese de *destituição* do inventariante não foi prevista pelo CPC de 2015, mas justifica-se especialmente porque nela não há que se falar em hipóteses de responsabilização civil desse inventariante, ao contrário do que ocorre na *remoção*, cuja natureza jurídica de sanção por ato ilícito é evidenciada.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

1. Aspectos procedimentais na remoção do inventariante

Ainda que decidida de ofício, a remoção não poderá ocorrer sem que se respeite o contraditório (CF, art. 5.º LV),¹⁷⁰ ouvindo-se o inventariante a respeito da eventual prática das condutas que justificariam a perda do encargo.

Ao contrário do que uma interpretação literal, isolada e apressada do dispositivo poderia

concluir, não há que se falar, portanto, em respeito ao procedimento do art. 623 apenas nas hipóteses de remoção a requerimento.

Assim, em incidente que transcorrerá em apenso aos autos do processo originário, o inventariante será intimado para, no prazo de 15 dias – ampliado em relação aos 5 dias¹⁷¹ proporcionados pelo CPC de 1973 – defender-se e desde já produzir provas documentais, bem como especificar e requerer a produção de outras provas.

Tal procedimento possui natureza incidental, sendo resolvido por meio de decisão interlocutória, em face da qual caberá recurso de agravo de instrumento¹⁷² (CPC de 2015, art. 1.015, parágrafo único).¹⁷³

Além da possibilidade de suscitação do procedimento de ofício, a legitimidade para o requerimento do incidente de remoção do inventariante é concorrente entre os herdeiros, os legatários, os credores, o Ministério Público, bem como os demais indicados no rol do art. 616¹⁷⁴ do CPC de 2015.

Este procedimento não possui efeito suspensivo determinado por lei. Entretanto, conforme a fase em que o processo principal esteja é bastante usual que os magistrados aguardem a resolução do incidente de remoção para só então concluírem o inventário.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.

Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617.

1. Demais particularidades procedimentais do incidente de remoção

Exceto no que tange ao prazo para o inventariante se defender, o CPC de 2015 não estabelece exatamente um procedimento para o incidente de remoção. Deste modo, após a resposta do inventariante, caso as provas requeridas e produzidas sejam apenas as documentais, deve o juiz apenas julgar o incidente.

Por outro lado, ao contrário do que uma interpretação literal do art. 624 do CPC de 2015 – reprodução integral do art. 997¹⁷⁵ do CPC de 1973 – poderia indicar, na hipótese de o inventariante requerer a produção de outras provas cuja necessidade esteja efetivamente demonstrada, mormente de prova oral, deverá sim o magistrado designar audiência de instrução e julgamento.

Não se trata, portanto, de caso em que a instrução probatória necessite remeter tal objeto às vias ordinárias. Isso por que tal remeter do feito às vias ordinárias causaria maior tumulto ao processo, assim como provocaria uma complexidade processual desnecessária.

Ainda que o processo principal de inventário seja documental, seria, da mesma forma, uma afronta à ampla defesa e ao devido processo legal (CF, arts. 5.º LV¹⁷⁶ e 7.º¹⁷⁷ do CPC de 2015), a impossibilidade de produção de prova oral no incidente, o qual é proceduralmente autônomo. Isso até porque o art. 621, *caput*,¹⁷⁸ deixa claro que é possível a produção de prova, devendo-se interpretar a hipótese sistematicamente.

Caso remova o inventariante, o juiz deverá nomear outro, preferencialmente na mesma decisão, considerando sempre os critérios constantes da ordem estabelecida pelo art. 617¹⁷⁹ do CPC de 2015.

Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.

1. Ainda sobre a hipótese de remoção do inventariante

Processado o incidente, a decisão que determinar a remoção do inventariante, deve ser cumprida por meio de ordem – mediante mandado de imissão de posse de bens imóveis ou busca e apreensão de bens móveis – para o antigo inventariante entregar os ativos e demais bens do espólio ao novo inventariante.

Na hipótese de o juiz remover o inventariante, mas ainda não nomear novo detentor para o mister, o antigo deverá continuar administrando provisoriamente o patrimônio do espólio que estiver consigo (CPC de 2015, arts. 613¹⁸⁰ e 614),¹⁸¹ até que haja a nomeação e assinatura do termo de inventariança, exceto se na mesma decisão houver determinação para que os deposite.

A inovação trazida pelo art. 625 do CPC de 2015 está na sua parte conclusiva. Trata-se da previsão específica, junto ao ordenamento, de uma multa que a jurisprudência já previa com fundamento na regra geral do art. 461-A¹⁸² do CPC de 1973, para a hipótese de descumprimento da regra de entregar coisa (TJRS, AI 7004979550, Dec. Monocrática da rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, *Dje*. 06.07.2012).

Assim, caso o inventariante removido deixe de entregar os bens do espólio que estejam em sua posse ao novo inventariante no prazo fixado pelo juízo, o juiz deverá fixar multa, desta vez única – portanto, sem a periodicidade possibilitada pela regra do art. 461-A do CPC de 1973 – no montante de até 3% do valor declarado dos bens inventariados.

Seção IV

Das citações e das impugnações

Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento.

§ 1.º O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no art. 247, sendo, ainda, publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259.

§ 2.º Das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes.

§ 3.º A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações.

§ 4.º Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos.

1. Sobre as citações e as intimações

A relação processual formada na ação de inventário é composta pelos sucessores, quais sejam: o cônjuge, assim como os demais herdeiros e legatários (art. 626, *caput*, do CPC/2015), os quais, após as primeiras declarações serem apresentadas, serão citados para compartilhar o feito, sob pena de nulidade do processo (art. 239 do CPC/2015).¹⁸³ Apenas quem já estiver habilitado nos autos não precisará ser citado.

Ocorre que outros sujeitos também participam do procedimento, e por esse motivo necessitam ser intimados para tanto, como são os casos do Ministério Público, havendo herdeiro incapaz ou ausente; da Fazenda Pública e testamenteiro, caso tenha sido deixado testamento (art. 626, *caput*, segunda parte do CPC/2015).¹⁸⁴

Nesse sentido, ao contrário do que o CPC/1973 dispunha, o art. 626 do CPC/2015 deixa claro que,

após a apresentação das primeiras declarações, das quais todos os participantes do feito receberão cópias, apenas os sucessores serão *citados* para o inventário, devendo ser somente *intimados* os demais sujeitos ao contraditório.

Veja-se, entretanto, que a não participação do Ministério Público, por exemplo, numa hipótese em que o órgão devesse participar, ou mesmo a não citação de algum interessado na demanda, possibilitam inclusive a propositura de ação rescisória, quando detectadas depois do trânsito em julgado, fundada no art. 658, II e III¹⁸⁵ do CPC/2015.

Felizmente, a estrutura arquitetada pelo art. 626 do CPC/2015 extinguiu a norma que possibilitava a citação por edital dos demais participantes e interessados no inventário, ainda que estes possuíssem endereço conhecido, a teor do art. 999 § 1.º¹⁸⁶ do CPC/1973. A nova regra permite, assim, que a citação por edital aconteça apenas nas hipóteses de os interessados não terem endereço conhecido.

Assim agindo, o CPC/2015 extingue a inconstitucional possibilidade de o interessado ser citado por edital mesmo tendo o seu endereço conhecido (art. 999 § 1.º do CPC de 1973), regra essa que o pleno do STF, em 08.10.2008, havia julgado ser constitucional no Recurso Extraordinário 552.598/RN,¹⁸⁷ de forma contraditória com suas próprias posições noutros julgamentos sobre o assunto.

Veja-se, a este respeito, que contraditoriamente, na ADI 4264,¹⁸⁸ o STF entendeu ser inconstitucional a redação que a Lei 11.418/2007 deu ao art. 11 do Dec.-lei 9760/1946, a qual possibilitava a citação por edital dos interessados no processo de demarcação dos terrenos de marinha mesmo em face de interessados cujos endereços eram conhecidos, e que vinha sendo efetuado pela Secretaria do Patrimônio da União, órgão do Ministério do Planejamento.

Além disso, o CPC/2015 generalizou, ainda, no § 1.º do art. 626, a necessidade de publicação de edital para a chamada de eventuais interessados, mesmo que incertos ou desconhecidos (art. 259, III, do CPC/2015).¹⁸⁹

Tal inovação gera uma presunção legal de conhecimento a respeito do processo de inventário por parte de todos os interessados, publicação essa que, no entanto, não substitui a citação específica a ser eventualmente realizada por edital em relação aos herdeiros não localizados e sem endereço conhecido.¹⁹⁰

Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

I – arguir erros, omissões e sonegação de bens;

II – reclamar contra a nomeação de inventariante

III – contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

§ 1.º Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações.

§ 2.º Se acolher o pedido de que trata o inciso II, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal.

§ 3.º Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.

1. A impugnação às primeiras declarações

Tanto a nomeação do inventariante quanto o conteúdo das primeiras declarações poderão, no

prazo comum de 15 dias, ser impugnados pelos interessados após as respectivas citações, a teor do art. 627, *caput* do CPC/2015.

Tal impugnação se dá por petição escrita, através de advogado, contando-se o prazo de 15 dias – em substituição aos 10 dias sobre os quais dispunha o art. 1000¹⁹¹ do CPC/1973 – da data da citação do último interessado.

Veja-se que o tema da impugnação deve ser a conveniência daquele inventariante para o processo ou o conteúdo das primeiras declarações, pois alegações que versem sobre a atuação do inventariante devem ser efetuadas via incidente de remoção de inventariante, em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa.

Esse também é o momento para que os herdeiros aleguem falsidades (arts. 430¹⁹² a 433 do CPC/2015), tragam aos autos a relação dos bens eventualmente recebidos antes do óbito, colacionando-os, segundo as disposições dos arts. 639 a 641 do CPC/2015, ou ainda, oponham impedimentos e suspeições dos atores processuais, a teor dos arts. 146 a 150 do CPC/2015.

Em face dos objetivos comuns não categórica nem necessariamente, e até discutivelmente litigiosos do procedimento de inventário, embora haja autores como Felipe Borring Rocha,¹⁹³ que defendem, caso os herdeiros neste momento quedem inertes, existir efeitos preclusivos quanto à oportunidade de irrisignação quanto às circunstâncias do inventário, não nos parece ser acertada a posição.

Isto por que o CPC/2015 não estabelece efeitos preclusivos específicos, e como leciona Theotônio Negrão¹⁹⁴ percebe-se que a essência dos assuntos que são objeto das impugnações não merece sofrer preclusão neste momento ainda inicial do procedimento, especialmente no que tange a falhas nas relações de herdeiros e de bens a inventariar.

Caso seja aplicada a lógica de preclusão sem clareza quanto a quais poderiam receber efeito preclusivo nesta fase preliminar, haverá significativa inversão de prioridades e vitória da forma sobre o conteúdo, bem como sobre os próprios objetivos do processo; o que levará a novas e desnecessárias medidas judiciais, especialmente de sobrepartilha.

Se a impugnação não foi aceita, segue-se o procedimento. Por outro lado, na hipótese de a impugnação ser acolhida com fundamento no inc. I do art. 627 e respectivo § 1.º, determinará a retificação das primeiras declarações.

Por sua vez, caso o juízo acolha a impugnação com fundamento no inc. II do art. 627 e respectivo § 2.º, nomeará outro inventariante respeitando as preferências legais constantes do art. 617 do CPC/2015.

Já na hipótese de acolhimento da impugnação com fundamento no inc. III do art. 627 e respectivo § 3.º, o juízo excluirá o herdeiro caso considere suficiente a prova documental produzida.

Logo, caso a prova documental não seja considerada suficiente, o juízo remeterá o feito às vias ordinárias, sobrestando, cautelarmente, a entrega do quinhão que caberia ao herdeiro até o julgamento da referida ação.

O § 3.º do art. 627 inova, portanto, retirando a expressão *alta indagação*, cuja conceituação gerava insegurança ao intérprete, deixando claro ser a necessidade de produção de provas diversas da documental no tocante à qualidade do herdeiro, o critério a ser considerado para que se decida ou não pela remessa do feito às vias ordinárias.

Tal critério, inclusive, já vinha sendo amplamente adotado pela jurisprudência.¹⁹⁵

Veja-se, ainda, que a decisão a respeito da impugnação das primeiras declarações é interlocutória, desafiando, na sistemática do CPC/2015, o recurso de agravo de instrumento, segundo o art. 1015, parágrafo único,¹⁹⁶ desse diploma legal.¹⁹⁷

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

§ 1.º Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz decidirá.

§ 2.º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

1. Habilitações por iniciativa dos herdeiros ou legatários

O requerimento de habilitação no inventário possui uma amplitude temporal considerável. Deste o início do procedimento até a efetivação da partilha, poderá o herdeiro requerer a sua habilitação, mesmo não constando nas declarações apresentadas pelo inventariante (art. 628, *caput*, do CPC/2015). Após a realização da partilha, entretanto, apenas mediante ação rescisória poderá o herdeiro se incluir junto ao espólio (art. 658, III, do CPC/2015).¹⁹⁸

Em respeito ao contraditório, o juízo ouvirá os interessados no prazo de 15 dias – eram 10 dias no sistema do CPC/1973 – e decidirá de forma interlocutória, desafiando, a decisão, o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC/2015).

Sendo necessária a produção de provas diversas da documental, o juiz determinará que o requerente proponha ação autônoma, e determinará, de maneira acautelatória, seja reservado quinhão ao herdeiro não incluído até que se decida definitivamente a questão, patrimônio esse que continuará sob a administração do inventariante (art. 628, § 2.º, CPC/2015).

Art. 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

1. Fazenda Pública

Após ter sido intimada das primeiras declarações, a Fazenda Pública tem o prazo de 15 dias – eram 20 no sistema anterior (art. 1.002, CPC/1973)^{199 200} – tanto para informar o valor dos bens constantes das declarações, quanto para delimitar o valor a ser pago a título de tributos²⁶⁴ (Imposto de Transmissão *Causa Mortis*²⁰¹ e Doação – ITCMD).^{202_203}

Caso não concordem com os valores dados aos bens pelas próprias partes (art. 633, CPC/2015),²⁰⁴ é bastante comum que a fazenda pública requeira, para tanto, a nomeação de avaliador judicial.

Veja-se que não existe preclusão para a fazenda pública discordar dos valores informados pelas partes, até por que o interesse público está exatamente em velar pelo correto recolhimento (STF, RE 100.547-5, 2.ª T. rel. Min. Moreira Alves, DJ 02.03.1984; STJ, MC 14.509-SP, 3.ª T., rel. Min. Nancy Andrighi, Dj 21.08.2008).²⁰⁵

A Fazenda Pública passa, então, uma vez efetuada a comunicação a que se refere o art. 629, a participar de todos os atos do processo, devendo ser sempre intimada, sob pena de nulidade do feito, cuja partilha tem como condição o pagamento dos respectivos tributos (art. 654, CPC/2015).^{206_207}

Seção V

Da avaliação e do cálculo do imposto

Art. 630. Findo o prazo previsto no art. 627 sem impugnação ou decidida a impugnação que

houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no art. 620, § 1.º, o juiz nomeará perito para avaliação das quotas sociais ou apuração dos haveres.

1. A avaliação dos bens e o cálculo do imposto devido

O juízo necessita decidir as questões referentes às impugnações previstas no art. 627²⁰⁸ do CPC/2015 – caso haja impugnação – para que só então sejam avaliados os bens que compõem o espólio.

Veja-se que a avaliação judicial só precisará ocorrer, no entanto, nas hipóteses em que o valor dos bens não puder ser encontrado mediante consulta – como ações,²⁰⁹ veículos, e assim por diante – caso haja partes incapazes interessados, ou caso as partes e a Fazenda Pública não concordem com os valores já apontados, a teor do art. 633 do CPC/2015.

Assim, caso não haja avaliador vinculado ao juízo, ou na hipótese de ser necessária a atuação de um perito com conhecimentos específicos,²¹⁰ o juízo nomeará o perito respectivo (art. 1.003, CPC/2015).^{211,212}

Art. 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará, no que for aplicável, o disposto nos arts. 872 e 873.

1. Os atos de avaliação

No procedimento especial de inventário, os atos a serem realizados para a avaliação dos bens do espólio são os mesmos previstos no processo de execução do CPC/2015, embora originalmente visando à avaliação dos bens objeto de constrição executiva mediante penhora, depósito e avaliação (arts. 872²¹³ e 873, CPC/2015).²¹⁴

Consoante explicita o art. 631 do CPC/2015, o respeito à estrutura alinhavada no processo de execução é categórico, escolha essa que o CPC/1973 já havia efetuado, mantendo-se, portanto, a mesma filosofia de avaliar os bens do inventário da mesma forma como estes são avaliados no processo de execução.

O oficial necessita ser qualificado para efetuar avaliações (art. 870, CPC/2015),²¹⁵ sendo que um novo perito será nomeado caso seja necessário obter conhecimentos específicos, como, por exemplo, nas hipóteses de uma obra de arte ou de modelo de automóvel raro.²¹⁶

É importante que o avaliador descreva cada uma dos ativos que compõem o objeto de sua análise, bem como indique com clareza quais foram os critérios utilizados como base para a sua avaliação (art. 872, CPC/2015).

Uma vez protocolado o laudo de avaliação, as partes poderão se manifestar no prazo de 15 dias (art. 635, CPC/2015).²¹⁷ Caso impugnem, será dado direito ao avaliador para se manifestar, decidindo o juiz logo após, através de decisão interlocutória agravável por instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015), podendo ser, inclusive, repetida a avaliação, a teor do art. 873 do CPC/2015.

Dentro da sistemática do CPC/1973 havia a possibilidade de o juiz e o escrivão acompanharem a avaliação pessoalmente (art. 1.005²¹⁸ do CPC/1973), para sopesar da melhor forma os elementos considerados na avaliação, numa espécie de inspeção judicial, tal como a prevista no art. 480²¹⁹ e ss. do CPC/2015.

Ocorre que o dispositivo, como se poderia prever, caiu em desuso. Daí o fato de o CPC/2015 não prever essa possibilidade de forma específica no procedimento de inventário. Tal exclusão não

impede o magistrado, entretanto, de efetuar uma inspeção judicial a respeito do tema se assim desejar, utilizando como fundamento o art. 480 e ss. do CPC/2015, ou mesmo ouvir o perito em audiência, a teor do art. 477, § 3.^o²²⁰ do CPC/2015.²²¹

Art. 632. Não se expedirá carta precatória para a avaliação de bens situados fora da comarca onde corre o inventário se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado.

1. Avaliação dos bens que se encontram fora da comarca do inventário

A avaliação dos bens situados fora da comarca do processo de inventário acontece por meio da expedição de carta precatória (arts. 260²²² a 268, CPC/2015). Trata-se de reprodução efetuada pelo art. 632 do CPC/2015 em relação ao art. 1.006²²³ do CPC/1973.

Entretanto, a exceção que o próprio texto legal faz acontece na hipótese de os bens situados noutra comarca serem considerados de pequeno valor,²²⁴ ou serem perfeitamente conhecidos pelo perito, casos esses em que a carta precatória não será necessária.²²⁵

Tem se considerado bens de pequeno valor aqueles que, via de regra, não ultrapassariam cinco salários mínimos (parágrafo único do art. 1.027 do CPC/1973,²²⁶ e parágrafo único do art. 655²²⁷ do CPC/2015, por aplicação analógica).

A verdade é que o CPC/2015 novamente perdeu uma oportunidade, desta vez deixando de esclarecer, na hipótese, o sentido da expressão *pequeno valor*, cuidado esse que contribuiria significativamente para a tranquila aplicação da norma contida no art. 632.²²⁸

Art. 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.

1. Hipóteses em que a avaliação não será necessária

Os arts. 633 e 643²²⁹ do CPC/2015 repetem, inicialmente, a desnecessidade de avaliação caso as partes sejam capazes e concordem com o valor atribuído aos bens do espólio pelo inventariante.

Literalmente, o que o art. 633 do CPC/2015 dispõe é sobre a concordância da Fazenda Pública a respeito das primeiras declarações, não sendo necessária a avaliação, se os herdeiros e o Ministério Público também concordarem.

Veja-se que tal concordância pode se restringir, entretanto, ao valor dos bens, não havendo que se falar em concordância a respeito de todos os itens do processo. Assim dispondo, tais artigos repetem o conteúdo dos arts. 1.007²³⁰ e 1.008²³¹ do CPC/1973.

Havendo concordância dos herdeiros e do Ministério Público, também não precisará haver avaliação, caso o valor dos bens tenha sido indicado pela Fazenda Pública (arts. 629²³² e 665 do CPC/2015).²³³

O que provoca a necessidade de avaliação é a existência de desacordo a respeito do valor dos bens, ou ao menos a alta probabilidade de tal desavença vir a ocorrer em virtude de eventual rixa entre os herdeiros ou, ainda, a discordância entre estes, o Ministério Público e a Fazenda Pública a respeito do valor dos bens.²³⁴

Teria sido mais pragmático e cooperativo o texto do CPC/2015 caso não exigisse a concordância expressa para evitar a avaliação, consoante dispõem os arts. 633 e 634, mas sim a *discordância expressa* com a indicação clara de quais bens está a tratar – exatamente para que se delimite o objeto da discussão – tal como ocorre na hipótese do arrolamento, a teor do § 1.^o do art. 664²³⁵ do CPC/2015.

Da forma como restou o texto legal (arts. 633 e 643²³⁶ do CPC/2015), a mera ausência de acordo, infelizmente, já é uma justificativa plena e válida para a realização da avaliação. Daí acreditarmos que também as partes deveriam ter o dever de fundamentar a sua *não concordância*, sob pena de dispensa da avaliação judicial, exatamente a fim de avaliar a existência de uma razão suficiente à realização dessa avaliação por vezes demorada e custosa.

É importante deixar claro, ainda, que salvo evidente má-fé ou conluio das partes, tal como na hipótese do art. 520 § 1.º²³⁷ do CPC/2015, não caberá ao magistrado discutir o mérito da avaliação.²³⁸

Art. 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais.

1. Ainda sobre as hipóteses em que a avaliação não será necessária

O art. 634 do CPC/2015 repete a lógica do art. 633 do mesmo diploma legal, mas apenas inverte a sua ordem.

A literalidade do art. 634 do CPC/2015 apenas inverte a origem da avaliação não judicial, desta vez exigindo a concordância dos herdeiros com a avaliação efetuada pela Fazenda Pública.

Daí resulta, assim como foi explicitado nos comentários ao art. 633 acima efetuados, a conveniência em exigir-se dos herdeiros que sua eventual *não concordância* seja devidamente fundamentada, até para que se saiba com exatidão a respeito de quais bens não se estará concordando.

Assim, interpretando-se o tema em analogia com o § 1.º do art. 664²³⁹ do CPC/2015, mesmo em face das disposições que provocariam a avaliação judicial com a mera *não concordância* das partes (arts. 633²⁴⁰ e 643²⁴¹ do CPC/2015), não há dúvida de que em meio a um processo cooperativo, também as partes têm o dever de fundamentar a sua não concordância (arts. 9.º²⁴² e 10 do CPC/2015).²⁴³

O objetivo de exigir-se fundamentação pelas partes é avaliar a existência de uma razão suficiente à realização da avaliação, podendo o magistrado, na ausência desse motivo válido, simplesmente homologar o valor constante dos autos e dispensar a avaliação.

Art. 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, que correrá em cartório.

§ 1.º Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano, à vista do que constar dos autos.

§ 2.º Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão.

1. Impugnação ao laudo da avaliação e a realização de nova avaliação

Apresentado o laudo de avaliação por parte do perito, as partes deverão se manifestar no prazo de até 15 dias (estendendo o lapso previsto no art. 1.009²⁴⁴ do CPC/1973), prazo preclusivo esse, que correrá em cartório,²⁴⁵ portanto sem intimação das partes a respeito da entrega do laudo.

Como a natureza do laudo é de perícia judicial,²⁴⁶ as partes têm, também, a possibilidade de buscar esclarecimentos junto ao avaliador, desde que o façam no prazo de 5 dias, a teor do art. 218 § 3.º²⁴⁷ do CPC/2015.

Se não concordarem com os esclarecimentos – ou mesmo sem a provocação destes – as partes têm a faculdade de impugnar o laudo de avaliação, desde que o façam fundamentadamente, no

prazo preclusivo de 15 dias.

Na impugnação, visando embasar as suas alegações, a parte poderá juntar novos documentos e pedir a produção de outras provas, mediante audiência com o avaliador (art. 477, § 3º do CPC/2015),²⁴⁸ ou mesmo por meio de inspeção judicial (art. 480²⁴⁹ e ss. do CPC/2015).

A decisão judicial que acolhe ou rejeita a impugnação ao laudo de avaliação, possui natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento, consoante o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.

Por outro lado, entretanto, a decisão que o juízo, simplesmente, homologa a avaliação judicial não tem sido considerada como manifestação recorrível (TJRS, 2.ª CC, AI 543.997, rel. Des. Icaro Osório, j. 16.10.2002).

Quando o § 2.º do art. 635 do CPC/2015 afirma que o acolhimento da impugnação determinará que o avaliador retifique a avaliação, duas situações poderão ocorrer: a) o avaliador efetua a ratificação, sem maiores consequências para o feito; ou b) o motivo do acolhimento da impugnação foi tão significativo que deixa de haver confiança naquele avaliador, motivo pelo qual o perito deverá ser substituído e a perícia, refeita.

A segunda hipótese – de realização de uma nova avaliação – é exatamente aquela a que se referia o art. 1.010²⁵⁰ do CPC/1973, situação essa que foi incompreensivelmente retirada do CPC/2015.

Mesmo assim, é possível empreender a possibilidade de nova avaliação por meio da interpretação conjunta dos arts. 873²⁵¹ e 629²⁵² do CPC/2015, dada a determinação legal no sentido da aplicação subsidiária das disposições sobre a avaliação na execução civil à avaliação dos bens que compõem o espólio.²⁵³

Art. 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras.

1. Últimas declarações e eventual sonegação de bens

Aceitos os valores ou realizada a avaliação judicial, uma vez ultrapassada a respectiva fase de avaliação, caberá ao inventariante prestar as últimas declarações.

O inventariante poderá e deverá complementar nas últimas declarações tudo aquilo que deixou de ser informado nas primeiras declarações, emendando-as ou aditando-as. Não havendo o quê alterar, entretanto, poderá simplesmente ratificar as primeiras declarações.

Trata-se de fase que requer grande atenção por parte de todos os interessados. Isso por que o último momento em que a descrição dos bens pode ser efetuada sem alegação de sonegação de patrimônio pelo inventariante acontece exatamente nas últimas declarações (art. 1.996 do CC²⁵⁴ e art. 621 do CPC/2015).²⁵⁵

O CPC/2015 estabelece que os interessados terão 15 dias – eram 10 no art. 1.012²⁵⁶ do CPC/1973 – para impugnar as últimas declarações e demonstrar a ocorrência de eventual sonegação patrimonial, seja para o inventariante, seja para outros herdeiros.

Caso o juízo acolha tal alegação – mais uma vez por decisão interlocutória agravável por instrumento – o fato poderá resultar, para o inventariante, na perda de sua função (art. 622, VI, CPC/2015²⁵⁷ e art. 1.993 do CC).²⁵⁸

Para o herdeiro sonegador, inclusive se este for o próprio inventariante, o acolhimento da alegação de sonegados poderá levar à perda do direito hereditário sobre esses bens (art. 1.992 do CC).²⁵⁹

Art. 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum de 15 (quinze) dias, proceder-se-á ao cálculo do tributo.

1. Cálculo do imposto causa mortis

Apresentadas as últimas declarações, o processo será enviado para o Contador Judicial efetuar o cálculo do imposto *causa mortis* devido, considerando o valor dos bens na data da referida avaliação.

O contador judicial considerará, ainda: o número de herdeiros, o regime de bens do casamento da pessoa falecida, assim como eventuais renúncias.²⁶⁰ Precisar-se-á levar em conta, ainda, a legislação tributária federal (nacional) e estadual, estando atento, também, à jurisprudência já pacificada a respeito do tema.

A jurisprudência sobre o assunto compõe-se especialmente das súmulas do STF sobre o cálculo do imposto *causa mortis* – anteriores a 1988, época essa em que o tribunal também julgava matérias infraconstitucionais mediante o filtro denominado *arguição de relevância* – mas que não serão atingidas pelo CPC/2015, continuando a ser aplicadas.

As súmulas do Supremo Tribunal que interessam para o cálculo do imposto são as seguintes: Súmula do STF 112: *O impôsto de transmissão causa mortis é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão*; Súmula do STF 113: *O impôsto de transmissão causa mortis é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação*; Súmula do STF 114: *O impôsto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo*; Súmula do STF 115: *Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, não incide o impôsto de transmissão causa mortis*; Súmula do STF 331: *É legítima a incidência do impôsto de transmissão causa mortis no inventário por morte presumida*; Súmula do STF 590: *Calcula-se o imposto de transmissão causa mortis sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor*.

Especialmente em virtude de julgamento de Recurso Especial repetitivo ocorrido em 2010, nas hipóteses de isenção do imposto *causa mortis* não existe mais divergência a respeito de qual deve ser o juízo competente para reconhecê-la. O entendimento pacificado, portanto, tem sido o de que o mesmo juízo do inventário é também o competente para a declaração de isenção dos herdeiros sobre o pagamento do imposto, *a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo art. 179 do CTN*. Nesse sentido: STJ, REsp 238.161/SP, 2.^a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, DJ 09.10.2000;²⁶¹ STJ, REsp repetitivo 1.150.356/SP, 1.^a Seção, rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.08.2010).²⁶²

Embora a lei estabeleça que o pagamento do imposto deverá ocorrer antes da prolação da sentença de partilha (art. 654 do CPC/2015 e art. 192 do CTN), é bastante usual que os interessados satisfaçam o pagamento dos impostos tão logo sejam homologados os respectivos cálculos.²⁶³

Art. 638. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório, e, em seguida, a Fazenda Pública.

§ 1.º Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo.

§ 2.º Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo.

1. Impugnações ao cálculo do imposto causa mortis e a decisão que termina a fase do inventário

Apresentado o cálculo do imposto *causa mortis*, os interessados serão intimados – portanto não correndo esse prazo em cartório – para tomar ciência de seu conteúdo.

Terão, neste momento, os interessados e depois a Fazenda Pública, a oportunidade de efetuar

impugnação no prazo de 5 dias²⁶⁴ (art. 638 do CPC/2015), prazo esse que também era de 5 dias no art. 1.013²⁶⁵ do CPC/1973.

O cálculo será corrigido caso o juízo acolha a impugnação. Tal correção será dada pelo mesmo contador (art. 638 do CPC/2015), ou então por outro perito designado pelo juiz.

Além da impugnação aos critérios utilizados pelo contador, ou mesmo a eventuais erros aritméticos, na impugnação ao cálculo do imposto *causa mortis* é ainda possível efetuar-se a alegação de eventual isenção sobre o pagamento do imposto, tema esse a respeito do qual cada estado legisla de modo diverso.^{266_267}

Deve-se lembrar, ainda, que antes de fazer-se o pedido de isenção em juízo, é possível que este seja deferido administrativamente. De qualquer forma, entretanto, a competência jurisdicional para a análise do pedido de isenção do ITCMD é do juízo do inventário (REsp repetitivo 1.150.356/SP, 1.ª Seção, rel. Min. Luiz Fux, *Dje* 25.08.2010).

Uma vez decidido o valor a ser pago a título de imposto *causa mortis*, o juiz o homologará. Embora a prática forense por vezes denomine essa decisão como *sentença de homologação* do cálculo, a sua natureza em verdade é interlocutória, dado não julgar pretensões nem terminar o procedimento em primeiro grau.

Assim, neste momento termina-se apenas a fase de inventário, mas não o processo de inventário, motivo pelo qual a referida decisão não é uma sentença e, portanto, não desafia apelação, mas sim recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015).²⁶⁸

Seção VI

Das colações

Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor.

Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.

1. As colações: conceito e valores

A colação²⁶⁹ consiste no dever do inventariante e dos demais herdeiros, de especificar e demonstrar em juízo os bens doados a herdeiro necessário (art. 544 do CC)²⁷⁰ ainda em vida pelo falecido, devolvendo-os ao monte e possibilitando uma divisão isonômica dos quinhões (art. 2.003 do CC)²⁷¹ os ficarão com cada um dos herdeiros que estejam em condições idênticas uns aos outros.^{272_273}

Cada herdeiro necessário que houver recebido bens em vida do *de cujus* terá a responsabilidade de trazê-lo à colação, seja por petição, seja por termo nos autos, até o término do prazo para manifestação sobre as primeiras declarações, havendo sonegação de bens caso não o faça (art. 1.992 do CC).²⁷⁴ Caso, entretanto, o herdeiro não possua mais bens, deverá trazer o respectivo valor quando da abertura da sucessão.²⁷⁵

Já para o inventariante, o último momento em que a descrição dos bens pode ser efetuada sem alegação de sonegação de patrimônio pelo aconter-se nas últimas declarações (art. 1.996 do CC ²⁷⁶ e art. 621 do CPC/2015).²⁷⁷ Veja-se que o CPC/2015 estabelece que os interessados terão 15 dias – eram 10 no art. 1.012²⁷⁸ do CPC/1973 – para impugnar as últimas declarações e demonstrar a ocorrência de eventual sonegação patrimonial.

Em decorrência da sonegação, para o respectivo herdeiro, inclusive se este for o próprio inventariante, o acolhimento da alegação de sonegados poderá levar à perda do direito hereditário sobre esses bens (art. 1.992 do CC).

No tocante ao valor dos bens a colacionar, o parágrafo único do art. 639 do CPC/2015 fala em mensuração do valor das benfeitorias e das acessões efetuadas nos bens doados em vida pelo *de cujos*, considerando o valor do momento da abertura da sucessão; do momento da morte. Veja-se, entretanto, que ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a regra do parágrafo único do art. 639 do CPC/2015 só está mal colocada topograficamente, pois não conflita com o Código Civil, apenas complementando-o.

Segundo o Código Civil, o valor dos bens colacionados deverá ser aquele atribuído pelo doador no ato de liberalidade, ou pelo que se calcular valessem ao tempo da liberalidade, a teor dos arts. 2.003²⁷⁹ e 2.004²⁸⁰ daquele diploma legal, estabelecendo, ainda, que o valor das benfeitorias eventualmente acrescidas pelo donatário não entrará em colação, pertencendo a esse donatário.

Assim, enquanto o Código Civil fala do valor de colação²⁸¹ dos bens doados – considerando-se a época da liberalidade – o parágrafo único do art. 639 do CPC/2015 fala dos bens a serem partilhados como um todo, independente de colação. Fala, ainda, do valor das benfeitorias efetuadas pelo donatário junto aos bens colacionados – a ser considerado na época da abertura da sucessão – caso seja necessário calculá-lo; benfeitorias estas que já pertencerão ao herdeiro donatário e não necessitam ser colacionadas.

Não faz sentido algum o CPC/2015 revogar, em um Código instrumental, uma regra de direito material que garante a igualdade patrimonial entre os herdeiros (art. 2.004 do CC), devendo ser considerado o valor do bem à época da liberalidade, e sem as benfeitorias efetuadas pelo donatário. Apenas o valor dessas benfeitorias, caso seja necessário indenizar ao donatário, será calculado pelo critério do momento da abertura da sucessão (parágrafo único do art. 639 do CPC/2015).

Além disso, o STJ possui decisão que permite a realização de perícia²⁸² nas doações e no testamento para apuração do valor atual do patrimônio, desconsiderando tanto o valor à época da doação quanto o valor à época da abertura da sucessão (STJ, REsp 1.314.071/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.03.2013).²⁸³

Entretanto, não nos parece que o critério trazido pela decisão do STJ acima indicada – valor atual – mereça ser generalizado, até por não se tratar de Recurso Especial Repetitivo, e muito menos de entendimento sumulado.

Também não acreditamos, enfim, que em face da disposição trazida pelos parágrafos do art. 638²⁸⁴ do CPC/2015 – o qual não dispõe sobre o valor dos bens colacionados em si – a regra material prevista pelo Código Civil mereça ser desconsiderada, devendo ser efetuada interpretação que coadune os dispositivos e mantenha a igualdade patrimonial entre os herdeiros (art. 2.004 do CC).^{285_286}

Art. 640. O herdeiro que renunciou à herança ou o que dela foi excluído não se exime, pelo fato da renúncia ou da exclusão, de conferir, para o efeito de repor a parte inoficiosa, as liberalidades que obteve do doador.

§ 1.º É lícito ao donatário escolher, dentre os bens doados, tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros.

§ 2.º Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda a licitação entre os herdeiros.

§ 3.º O donatário poderá concorrer na licitação referida no § 2.º e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros.

1. Parte inoficiosa, prazos, legitimidades, renúncia e exclusão de herdeiro no tocante à colação

O art. 640 do CPC/2015 possui a mesma redação do art. 1.015²⁸⁷ do CPC/1973, bem como necessita ser considerado em conjunto com as disposições do Código Civil a respeito do tema.

A renúncia²⁸⁸ à herança, prevista nos arts. 1.806²⁸⁹ a 1.808²⁹⁰ do CC, ou mesmo a sua exclusão do inventário, não retiram do respectivo herdeiro o dever de repor ao espólio a parte doada que eventualmente exceder a legítima e mais a metade disponível, consoante o art. 2.008²⁹¹ do CC.²⁹²

A parte doada que eventualmente excede a legítima e mais a metade disponível, prevista no art. 2.008 do CC, é denominada *parte inoficiosa*,²⁹³ pois merece ser colacionada para que se garanta igualdade entre os herdeiros.

Em princípio, o prazo para a ação de declaração da nulidade da *parte inoficiosa* é decenal genérico do Código Civil, ante à inexistência de previsão legal específica (STJ, AgRg no AREsp 332.566/PR, 4.^a Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJe* 24.09.2014), mas há julgado do mesmo Tribunal Superior no sentido de que o prazo é vintenário (STJ, REsp 1.321.998/RS, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrichi, *DJe* 20.08.2014).²⁹⁴

Já no tocante à legitimidade para propositura da ação de nulidade da *parte inoficiosa* da doação realizada pelo autor da herança, tem-se entendido que o herdeiro cujos direitos hereditários foram cedidos também possui legitimidade (STJ, REsp 1.361.983/SC, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrichi, *DJe* 26.03.2014).²⁹⁵

É importante lembrar, ainda, que a renúncia constitui um ato de vontade que exige escritura pública, a teor do art. 1.806²⁹⁶ do CC, bem como que não pode se efetuar em relação a apenas parte da herança e nem sob condição ou termo (art. 1.808 do CC),²⁹⁷ também não podendo prejudicar credores (art. 1.813 do CC).²⁹⁸

Por sua vez, a eventual exclusão de herdeiro se dá por meio de decisão judicial (arts. 627, § 3.^o²⁹⁹ e 628, § 2.^o do CPC/2015),³⁰⁰ e é importante considerar que tanto a renúncia quanto a exclusão não eximem os respectivos herdeiros de repor a parte inoficiosa.

Cabe ao donatário – inclusive o excluído e o renunciante – o ônus de escolher entre os bens que serão revertidos em favor dos demais herdeiros, pelo fato de excederem a legítima e mais a metade disponível.

Se ao tempo do falecimento do doador, o donatário não mais possuir os bens doados, deverá trazer à colação o seu valor ao tempo da abertura da sucessão (art. 2.003 do CC),³⁰¹ descontando o valor das benfeitorias acrescidas, o que lhe pertence (art. 2.004, § 2.^o do CC).³⁰²

Também deverá ser revertido aos demais herdeiros o remanescente do pagamento das dívidas dos credores, após terem sido pagas as dívidas do renunciante, conforme dispõe o art. 1.813, § 2.^o³⁰³ do Código Civil.

Caso a *parte inoficiosa* da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que se proceda a uma licitação entre os herdeiros (art. 640, § 2.^o do CPC/2015).

Na licitação do bem imóvel indivisível trazido à colação, desde que em igualdade de condições, o donatário terá preferência sobre os demais. Por este motivo, o donatário precisará, necessariamente, ser intimado do ato licitatório, sob pena de nulidade (arts. 9.^o³⁰⁴ e 10 do CPC/2015).³⁰⁵ Nesse sentido: JT A. Cível. SP 62/174.³⁰⁶

Art. 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas.

§ 1.^o Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 (quinze)

dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir.

§ 2.º Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário, enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência.

1. A possibilidade de impugnação à colação

Segundo o art. 620, IV³⁰⁷ do CPC/2015, o inventariante trará, nas primeiras declarações, lista completa e devidamente atualizada dos bens que compõem o espólio.

Logo, o herdeiro que for intimado das primeiras declarações (art. 626 do CPC/2015),³⁰⁸ com a determinação de que deve trazer bens à colação, poderá impugnar a colação por termos nos autos (art. 639 do CPC/2015) ou por petição, no prazo de 15 dias (art. 641 do CPC/2015).

A mesma peça de impugnação também poderá cumular outras pretensões impugnativas, por motivo de economia processual e instrumentalidade (art. 627 do CPC/2015).³⁰⁹

Caso a matéria alegada em impugnação necessite de dilação probatória, o juízo deverá determinar remessa desta às vias ordinárias, por meio da propositura da denominada *ação de sonegados* (art. 1.994 do CC), preferencial e cautelarmente reservando a parte litigiosa dos bens para futura sobrepartilha ou autorizando seu levantamento mediante a prestação de caução (art. 669, I, do CPC/2015).³¹⁰

A impugnação naturalmente prejudica as demais etapas do processo, motivo pelo qual o CPC/2015 não afirmou se ela possui efeito suspensivo.

O fato é que se trata de uma decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015), que determinará ou não sejam trazidos os bens à colação, sob pena de sequestro ou imputação³¹¹ ao quinhão hereditário do respectivo valor, caso já não o possua. Caso sequestrados, os bens ficarão sob a responsabilidade do inventariante até a partilha.

Seção VII

Do pagamento das dívidas

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1.º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 2.º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

§ 3.º Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.

§ 4.º Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.

§ 5.º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que

haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades.

1. O pagamento das dívidas do espólio

A habilitação dos credores³¹² do espólio pode se dar desde o início do processo de inventário; desde o protocolo do pedido de abertura, mediante a apresentação de prova literal³¹³ da dívida, cujos autos serão apensos ao processo de inventário. Mesmo assim, o efetivo pagamento aos credores ocorre apenas na fase de partilha (art. 642 do CPC/2015).

Veja-se que os credores do espólio têm, inclusive, legitimidade para efetuar o pedido de abertura do inventário (art. 616, VI, do CPC/2015),³¹⁴ podendo, inclusive, promover a sua sucessão processual (art. 110 do CPC/2015).³¹⁵

O credor não está obrigado a se habilitar no inventário, também podendo simplesmente mover a medida judicial competente em face do espólio (STJ, 2.^a Seção, CC 96.042/AC rel. Min. Massami Uyeda, *DJe* 21.10.2010).³¹⁶ Veja-se que a Fazenda Pública, por sua vez, não necessita pedir a habilitação de seus créditos, além de ter preferência sobre os demais (art. 189 do CTN).³¹⁷

Para a habilitação, o importante é que o requerente seja credor do falecido ou do espólio. Caso seja credor de um dos herdeiros, poderá no máximo efetuar a averbação de penhora no rosto dos autos do inventário (art. 860 do CPC/2015),³¹⁸ limitando seu recebimento aos direitos hereditários do herdeiro devedor.

O CPC/2015 mantém, neste tema (arts. 642 a 646), a estrutura do CPC/1973 (arts. 1.017 a 1.021), a respeito do pagamento das dívidas líquidas, certas e vencidas do espólio.

O § 3.º do art. 642 do CPC/2015 modificou, entretanto, as regras a respeito da remissão realizada sobre os bens do espólio para o pagamento das dívidas, a qual tornou bastante curioso o § 4.º do mesmo dispositivo, especialmente em face do regime da adjudicação na execução civil traçado pelo CPC/2015 (arts. 876 a 878), pois nele a regra geral é a anuência do devedor para a adjudicação dos bens.

A inovação ficou por conta da necessidade de ouvida do donatário, uma vez que para o CPC/2015, devem ser ouvidos os donatários sempre que a habilitação dos créditos criar a possibilidade de redução das liberalidades a que teriam direito (art. 642, § 5.º, do CPC/2015).

A decisão que julga o pedido de habilitação do credor no inventário, teve reconhecida a sua natureza, mais do que nunca, como interlocutória. Tal natureza foi questionada em face da alteração efetuada pela Lei 11.232/2006 junto ao § 1.º do art. 162³¹⁹ do CPC/1973, havendo parcela considerável da jurisprudência a afirmar se tratava de sentença – pela natureza de julgamento da pretensão autônoma do credor – em face da qual o recurso cabível seria o de apelação.

Em face da celeuma, e considerando a proteção dos interesses envolvidos, o STJ chegou a decidir aplicando o princípio da fungibilidade entre a apelação e o agravo de instrumento, invocando como fundo, princípios constitucionais, especialmente o da razoabilidade, bem como a lógica do art. 810 do CPC/1939³²⁰ (STJ, REsp 1.107.400/SP, 4.^a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, *DJe* 13.11.2013).³²¹

O fato, enfim, é que o CPC/2015 põe fim à discussão e deixa claro se tratar de decisão interlocutória, em face da qual é cabível o recurso de agravo de instrumento, a teor do art. 1015, parágrafo único.³²²

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

1. A discordância com o pedido de habilitação do credor

A discordância das partes em relação ao pedido de habilitação do credor do espólio necessita de dilação probatória para ser avaliada, o que não se coaduna com um rito que admite prova essencialmente documental, como é o caso do inventário.

Por esse motivo, o CPC/2015, seguindo a regra que já existia na sistemática do CPC/1973, determina que na hipótese de discordância entre as partes a respeito do pedido de habilitação do credor do espólio, a resolução do assunto seja remetida às vias ordinárias.

Na hipótese em que a dívida conste de documento comprobatório da existência e validade da obrigação, e a impugnação à habilitação não se fundar em prova da quitação dessa obrigação, mesmo com a remessa às vias ordinárias o credor poderá requerer e obter, cautelarmente (art. 296³²³ e ss. do CPC/2015), a reserva de bens³²⁴ do espólio cujo valor seja proporcional ao suposto crédito.³²⁵

Considerando a oportunidade trazida pelo CPC/2015, mais uma vez nos parece que o legislador perdeu a chance de alterar uma regra que serve preponderantemente ao tumulto processual.

O fato, enfim, é que não faz sentido ter a concordância de todos os herdeiros com os pedidos de habilitação de credores do espólio, seja por que isto lhes dá uma legitimidade referente à relação jurídica que não lhes pertence, seja porque possibilita a efetuação de fraudes, seja porque permite a procrastinação do procedimento em função de um assunto proporcionalmente menos significativo do que o legítimo interesse dos próprios herdeiros.

Art. 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário.

Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no *caput*, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento.

1. Habilitação do crédito ainda não vencido

Mesmo que o crédito ainda não esteja vencido, mas seja líquido e certo (art. 644 do CPC/2015), também poderá o credor do espólio requerer a sua habilitação no inventário, por meio de petição acompanhada da prova literal da dívida, consoante a estrutura do art. 642 do CPC/2015.

Mais uma vez, exige-se a concordância de todas as partes para que o crédito seja habilitado. Havendo essa concordância, desde já serão separados, cautelarmente, quantias ou bens pertencentes ao espólio com vistas ao pagamento futuro, mantendo-se a estrutura do art. 1.019³²⁶ do CPC/1973.

Entretanto, caso não haja concordância das demais partes do inventário, uma interpretação literal do dispositivo poderia conduzir à conclusão de que essa discordância impossibilitaria a tomada de qualquer medida acautelatória na hipótese de dívida ainda não vencida.

Não concordamos com tal interpretação. Isso por que a generalidade e a flexibilidade das disposições do CPC/2015 a respeito da tutela de urgência (art. 296 e ss.) deixam claras as amplas possibilidades de tutela urgente de todos os direitos.

Mesmo havendo discordância, portanto, como uma dívida ainda não vencida não depende de condição, mas sim da mera verificação de seu termo inicial, ela merece ter a sua eficácia útil devidamente protegida, por meio da respectiva medida antecedente (art. 296 e ss. do CPC/2015), enquanto o credor aguarda o vencimento das dívidas o pleiteia o pagamento segundo a estrutura do art. 642 do CPC/2015.

Nessa hipótese, entretanto, ainda que o juízo entenda se tratar de medida cautelar, não fará sentido a eventual aplicação da regra da perda da eficácia da medida antecedente caso não seja

proposta em 30 dias a medida principal, pois o vencimento da dívida poderá demorar mais do que isso, e mesmo assim a situação merece a proteção da tutela urgente (art. 5.º, XXXV, da CF/1988),³²⁷ separando-se quantias ou bens pertencentes ao espólio com vistas ao pagamento futuro.³²⁸

Art. 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio:

I – quando toda a herança for dividida em legados;

II – quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados.

1. A posição dos legatários e a sua oitiva no inventário

Em princípio, as dívidas do espólio não são de responsabilidade do legatário, pois ele herda bens individualizados (art. 1.912 do CC),³²⁹ ao contrário dos herdeiros, cujos quinhões incluem tanto direitos quanto obrigações.

Isso por que o herdeiro, ao contrário do legatário, herda tanto os *bônus* quanto os *ônus* do espólio, patrimônio esse que apenas quando da partilha será individualizado.

Entretanto, caso o patrimônio deixado não seja suficiente para saldar as dívidas do espólio, a habilitação de credores pode sim atingir também os interesses do legatário (art. 1.912 do CC), hipótese essa em que o bem individualizado poderá ser atingido e este deverá ser ouvido (art. 645 do CPC/2015).

Assim, o art. 645 do CPC/2015 mantém as disposições do art. 1020³³⁰ do CPC/1973, determinando que o legatário seja ouvido sempre que toda a herança estiver dividida em legados, a fim de que os limites entre os legados sejam respeitados, ouvindo-se os legatários e respeitando-se o contraditório a este respeito.

Segundo o inc. II do mesmo dispositivo (CPC/2015, art. 645), os legatários serão ouvidos, ainda, quando a decisão que reconhecer os débitos do espólio importar ou, em nossa opinião, correr fundado risco de conduzir à redução dos legados, em analogia do disposto no art. 642 parágrafo quinto do CPC/2015.³³¹

Assim, pelo risco de redução dos legados e pela amplitude do termo *partes* – no qual está inserido o legatário no processo de inventário – constando tanto no parágrafo segundo do art. 642 (dívidas exigíveis) quanto no parágrafo único do art. 644 do CPC/2015 (dívidas ainda não exigíveis), nesses casos se insere, consoante se interpreta a hipótese do art. 645, II, a legitimidade do legatário³³² para concordar com o pagamento de dívidas.

Veja-se que as hipóteses previstas nos incs. I e II do art. 645 são alternativas e não cumulativas. Assim, não é necessário que as duas hipóteses estejam presentes, de maneira que cada uma delas, sozinha, já é suficiente para provocar a necessidade de manifestação do legatário.

Art. 646. Sem prejuízo do disposto no art. 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique à penhora no processo em que o espólio for executado.

1. Nomeação de bens à penhora pelo inventariante autorizado pelos herdeiros

Nas situações em que se pretenda efetuar quaisquer atos de disposição patrimonial, independente de se tratar de execução contra o espólio, deverá haver concordância das partes ou autorização judicial³³³ (CPC/2015, art. 619).³³⁴

Com o objetivo de otimizar o pagamento das dívidas, o art. 646 do CPC/2015 possibilita que o inventariante nomeie bens à penhora nas ações de execução movidas em face do espólio, desde que o faça mediante autorização das demais partes do inventário.³³⁵

Nessa hipótese, averbar-se-á tal penhora nos autos do processo de inventário, em respeito às disposições do art. 860³³⁶ do CPC/2015, o qual não utiliza mais a expressão *penhora no rosto dos autos*, mas sim a expressão *averbação* nos autos.

Veja-se que nesse caso – de execução em face do espólio – o CPC/2015 não exige autorização judicial. Por outro lado, o art. 646 do CPC/2015 repete o texto do art. 1021³³⁷ do CPC/1973 e complementa as disposições do art. 619³³⁸ do CPC/2015, indicando, sistematicamente, a possibilidade de a concordância judicial suprir a autorização das partes.

Por esse motivo, caso as partes não concordem com a nomeação à penhora em processo de execução movido contra o espólio, o juízo poderá suprir a anuência, especialmente caso tal negativa das partes seja juridicamente infundada.³³⁹

Seção VIII

Da partilha

Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, § 3.º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário.

Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

1. Segunda fase do procedimento: a partilha e suas vicissitudes

A fase de inventário propriamente dita termina com as últimas declarações, a definição dos sucessores, a individualização do patrimônio e a resolução dos incidentes de habilitações de crédito, colações e pedidos de pagamento. A partir deste momento, portanto, é hora de entregar ao conjugue supérstite a sua meação – se assim dispuser o regime de bens do casamento – entregar ao legatário o seu legado, pagar as dívidas e entregar o restante dos bens aos demais herdeiros habilitados.³⁴⁰

A partilha³⁴¹ poderá ser litigiosa ou amigável,³⁴² mediante o arrolamento sumário previsto nos arts. 659³⁴³ e segs. do CPC/2015 (anteriormente regulada pelos arts. 1031 e segs. do CPC/1973). Na partida amigável, caberão às partes entrar em acordo e apresentar acordo sobre a maneira de os bens a serem partilhados.

Caso seja litigiosa, caberá ao juiz³⁴⁴ definir a composição de cada quinhão, estando atento à eventual meação do conjugue sobrevivente, bem como aos valores devidos a cada herdeiro, encerrando-se quando não houver mais bens a serem partilhados.

Assim, o procedimento da partilha litigiosa³⁴⁵ se inicia com o despacho que abre prazo de 15 dias – em substituição aos 10 dias previstos no CPC/1973 – aos sucessores para formularem pedido para o respectivo quinhão (a serem contados segunda a sistemática do art. 219³⁴⁶ do CPC/2015, considerando-se apenas os dias úteis). Tal procedimento, repita-se, só necessitará acontecer se as partes não forem capazes de entrarem em acordo e apresentarem acordo sobre a maneira de os bens a serem partilhados.

Na partilha litigiosa existe a figura do partidor, a quem é determinada a elaboração do esboço da partilha. Trata-se de um auxiliar do juízo encarregado de apurar tanto a herança bruta, constituída pela soma de todos os bens do autor da herança, assim como de apurar a soma líquida do montante a ser partilhado após o pagamento das dívidas, das despesas e dos impostos, assim

como dos bens adicionados a este valor mediante colação.

A manifestação das partes por ocasião do art. 647 do CPC/2015 não é uma obrigação, mas sim uma faculdade pela qual cada herdeiro pode indicar os bens que pretende para si, a fim de que a partilha possa gerar o maior grau possível de satisfação. Um determinado imóvel, ou mesmo uma obra de arte, por exemplo, podem não ter maior significado para um herdeiro, mas possuírem importância ímpar para outro. É partindo das manifestações dos herdeiros, portanto, que o juiz inicia o trabalho de distribuição dos bens entre os herdeiros.

2. A natureza jurídica da decisão que resolve a partilha litigiosa

No regime do CPC/1973, chegou-se a discutir a natureza jurídica da decisão que resolve a partilha, após a manifestação das partes prevista no art. 647, *caput*, segunda parte, do CPC/2015, especialmente quanto a consistir em um mero despacho ou em uma decisão interlocutória.

Isso por que: a) o próprio texto legal do art. 1022³⁴⁷ do CPC/1973 utilizava o termo *despacho* para se referir à decisão; b) o fato de anteceder o esboço a ser efetuado pelo partidor, denotava provisoriamente e, consequentemente; c) a falsa percepção de que, em razão das características anteriores, seria esta uma manifestação judicial que não causaria dano às partes.³⁴⁸

Com o tempo, entretanto, a importância dessa manifestação judicial para as pretensões dos herdeiros gerou necessidade de impugnação específica e admissão de recursos, motivo pelo qual passou-se a reconhecer natureza interlocutória ao pronunciamento e a aceitar-se a interposição de agravos de instrumento contra tal decisão.

Há, realmente, conteúdo decisório pelo fato de a decisão acolher ou rejeitar os pedidos dos herdeiros no tocante à distribuição dos bens a partilhar. Atento a esse amadurecimento, o legislador do CPC/2015 substituiu a expressão *despacho* pelo termo *decisão*, pondo termo, definitivamente, à celeuma e pacificando tanto a sua natureza interlocutória quanto a recorribilidade via agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único).³⁴⁹

3. Utilização e fruição dos bens antes do término do processo

Trata-se de inovação do CPC/2015, promovida junto ao parágrafo único do art. 647.³⁵⁰ A utilização imediata de bens delimitados do espólio concedida à determinados herdeiros antes do final do processo de inventário empresta otimização e eficiência econômica ao inventário, em inteligente substituição ao mero condomínio anteriormente previsto.

Não se trata de julgamento antecipado (CPC/2015, art. 335, I),³⁵¹ mas sim de verdadeira espécie de tutela provisória antecipada (CPC/2015, art. 303³⁵² e ss.), pois satisfativa.

Constitui, portanto, tutela concedida a um herdeiro que muito provavelmente será o futuro destinatário do bem, aumentando-se a efetividade do feito, mas devendo-se atentar, no sistema do CPC/2015, à necessidade de consulta às demais partes (CPC/2015, art. 10),³⁵³ respeitando-se os princípios da cooperação e do contraditório substancial.

Entretanto, os requisitos necessários ao deferimento da utilização e fruição antecipada não são típicos da tutela de urgência, possuindo mais caráter de evidência do que de urgência.³⁵⁴ Tal situação, entretanto, não exclui a possibilidade de haver urgência na espécie, especialmente para que o próprio bem possa ser protegido, como seria o caso, por exemplo, da utilização antecipada de um automóvel, também com o objetivo de não deixá-lo parado.

Mesmo assim, na maioria das vezes a demora inerente ao inventário já é suficiente para o deferimento da medida ao herdeiro que, com maior probabilidade, deverá ficar com determinado bem.

Muito embora a literalidade do dispositivo mencione apenas o termo *herdeiros*, faria pouco

sentido não aplicá-lo também aos legatários, pois se o juiz pode conceder uso e fruição ao herdeiro que tem a mera expectativa de obter o bem, mais do que nunca poderá deferi-la àquele que já o seu proprietário.

Contra as pretensões do legatário existe apenas uma regra geral – aqui excepcionada por decisão judicial fundamentada segundo o caso concreto (CPC/2015, art. 489³⁵⁵ e parágrafo único do art. 647) – segundo a qual, apenas em princípio, a posse do legado não se concede imediatamente ao legatário (CC, art. 1923, parágrafo primeiro).³⁵⁶

Ainda que o dispositivo conste, topograficamente, na seção que disciplina a partilha, nada impede que, respeitados os princípios da cooperação e do contraditório, a utilização e a fruição antecipada de bens seja deferida antes mesmo das últimas declarações e da fase de partilha.

A decisão que defere ou indefere o pedido de uso ou fruição antecipada de bem do espólio é interlocutória. Assim, o recurso cabível em face de tal decisão é, mais uma vez, o agravo de instrumento, a teor do art. 1015, parágrafo único, do CPC/2015.

Art. 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras:

I – a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens;

II – a prevenção de litígios futuros;

III – a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.

1. Outras regras da partilha

O art. 648 do CPC/2015 não possui equivalentes no CPC/1973, mas é descendente direto e inquestionável do art. 505³⁵⁷ do CPC de 1939, cuja redação era praticamente idêntica.³⁵⁸

A *ressureição* é bem vinda, em primeiro lugar, por que o critério da maior igualdade³⁵⁹ possível é indispensável ao respeito do princípio da isonomia, especialmente entre os herdeiros de idêntica situação jurídica; que possuam os mesmos quinhões (CPC/2015, art. 648, I).

Tal igualdade não diz respeito apenas ao valor dos bens, mas também à sua natureza e qualidade (aí consideradas também a localização do bem, o seu potencial de valorização e a utilidade de cada bem para cada sucessor).

Como se trata de uma norma principiológica, a função do dispositivo é ser respeitado na maior medida possível, pois de antemão o próprio texto legal já admite que a igualdade absoluta não poderá ser sempre atingida, ante as peculiaridades de cada patrimônio e de cada grupo de herdeiros.

Outro critério previsto no art. 648, desta vez no seu inc. II, é a busca pela prevenção a eventuais litígios futuros tanto em face de terceiros quanto entre os próprios herdeiros.

Assim, não deve o juiz decidir a partilha de forma que ela possa gerar conflitos futuros pela partilha de cotas de uma sociedade a herdeiros que estejam em conflito, pela partilha de bens circunvizinhos a herdeiros que estejam em conflito, ou mesmo por uma partilha que obrigue a criação de eventuais servidões, dentre tantas outras situações de conflito que o dispositivo busca evitar.

Deve-se considerar, ainda, a maior comodidade³⁶⁰ possível dos cônjuge supérstite, dos coerdeiros e do companheiro, se houver (CPC/2015, art. 648, III). Tal comodidade se afere pelo critério da utilidade dos bens partilhados em relação a cada herdeiro.

Deve-se considerar as características tanto dos bens quanto dos herdeiros. Não faria sentido, por exemplo, num espólio de dois herdeiros que envolva um imóvel na praia e um imóvel na

cidade, partilhar-se o imóvel de praia ao herdeiro a quem o mar agrada menos, ou ao herdeiro cuja situação financeira ou familiar evidentemente necessite de um imóvel para moradia na cidade.³⁶¹

Art. 649. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos.

1. Demais regras inerentes à partilha

Os bens não suscetíveis de divisão cômoda ou que não couberem na parte de um dos herdeiros serão licitados entre os interessados ou serão alienados judicialmente. O valor resultante da venda judicial será apurado e dividido entre os herdeiros, salvo se houver acordo para que sejam atribuídos a todos.

O art. 649 do CPC/2015 possui correspondência com o art. 503³⁶² do CPC de 1939. Embora o dispositivo possua o conteúdo essencial do art. 1117³⁶³ do CPC/1973, o fato é que resgata essencialmente o dispositivo do CPC de 1939.

Os bens não suscetíveis de divisão cômoda que não couberam na meação do cônjuge³⁶⁴ sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro serão vendidos na forma dos arts. 704 e 706 do CPC/2015, partilhando-se o preço, salvo quando os interessados preferiram arrendá-los, possuí-los em condomínio ou se qualquer herdeiro, ou cônjuge sobrevivente, requerer a respectiva adjudicação, repondo, em dinheiro, a diferença.

Como o CPC/2015 trata de forma bastante simples o procedimento que visa as alienações judiciais no art. 730,³⁶⁵ dentro do procedimento de partilha foi necessário recolocar o inc. I do art. 1117 do CPC/1973, trazendo exatamente para o capítulo que trata da partilha junto ao artigo 649.³⁶⁶

Ora, são considerados não suscetíveis de divisão cômoda³⁶⁷ aqueles bens que ultrapassam o valor da meação ou o quinhão de um único herdeiro. O dispositivo tem o objetivo de evitar a formação de condomínios entre as partes, o que frequentemente gera potenciais litígios futuros. Dessa forma, o artigo dispõe, em princípio, que os bens serão vendidos para que o resultado dessa alienação possa ser dividido entre os herdeiros.

Desde que se iguale os quinhões, o bem insuscetível de divisão cômoda poderá ser adjudicado pelo conjugue supérstite ou pelo herdeiro. O art. 2.019 § 1.º³⁶⁸ do CC de 2002 explicita tal possibilidade. É imprescindível, entretanto, que não haja objeção por parte da fazenda pública, especialmente no que diz respeito a possível sonegação fiscal. Independente de um novo ato de avaliação, a proposta de adjudicação poderá ser autorizada por todas as partes do inventário, a teor do art. 190³⁶⁹ do CPC/2015.

Caso o bem insuscetível de divisão cômoda interesse a mais de uma das partes do processo de inventário realizar-se-á uma licitação entre esses interessados. Referido bem será, então, adjudicado à parte que se dispuser a pagar o maior valor. A menos que todas as partes aceitem, esse valor não poderá ser inferior à avaliação do bem, conforme determina o art. 876³⁷⁰ do CPC/2015.

Os herdeiros também podem buscar a adjudicação do bem insuscetível de divisão cômoda estando em conjunto. A última parte do art. 649 do CPC/2015 deixa claro que estando *todos* de acordo poderá ser feita adjudicação a grupos de herdeiros. Uma interpretação literal do dispositivo poderia levar à equivocada conclusão de que todos os herdeiros necessitarão adjudicar o bem insuscetível de divisão cômoda nessa hipótese.

No entanto, para nós está claro que o termo *todos*, que consta do dispositivo legal, refere-se apenas a todos aqueles que estiverem de acordo com a adjudicação em condomínio; não se refere

necessariamente a todos os herdeiros. Não há que se falar, portanto, em uma alteração trazida pelo CPC/2015 ao sistema do art. 1117 inc. I³⁷¹ do CPC/1973.

Isto porque não há razão em obrigar a constituição de um condomínio entre todos os interessados do inventário quando, em verdade o bem poderá ser destinado somente a um, dois ou mais herdeiros que estiverem plenamente de acordo e aceitarem a realidade de condomínio.³⁷²

Interpretação em sentido diverso atrapalharia a partilha e poderia impedir a maior comodidade possível prevista no inc. III do art. 648³⁷³ do CPC/2015, além de gerar a probabilidade de discussões futuras. Logo, só haverá retrocesso em razão do art. 649 do CPC/2015 se os tribunais não tiverem bom-senso ao interpretá-lo, e o fizerem estritamente por meio do critério literal.

Como os bens destinados a cada herdeiro por meio da partilha não possuem valores idênticos, os bens de difícil divisão não precisam ser obrigatoriamente divididos integralmente entre as partes; não precisam ser divididos igualmente para cada quinhão. O importante é que determinados bens sejam transformados em dinheiro, visando a partilha mais adequada possível.³⁷⁴

Art. 650. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento.

1. Medida acautelatória em favor do nascituro

Especialmente caso tenha sido concebido antes da morte do *de cujus*, a teor do art. 1.798³⁷⁵ do Código Civil de 2002, não há dúvida de que o nascituro³⁷⁶ também possuirá direitos sucessórios.³⁷⁷

O CPC/2015, em seu art. 650, se preocupou em trazer disposições a respeito do tratamento processual dos direitos hereditários do nascituro, especialmente aqueles previstos no art. 1.798 do CC, tema esse a respeito do qual até então não havia maior regulamentação.

Logo, em virtude do art. 650 do CPC/2015, caso um dos herdeiros possa vir a ser o nascituro, a parte que lhe couber na herança será – cautelarmente – desde logo reservada e administrada pelo inventariante até o nascimento.

Tal decisão, cujo caráter é provisório, poderá ser dar de ofício – havendo informações nos autos a este respeito – ou a requerimento das partes ou do Ministério Público.

Veja-se, entretanto, que o CPC/2015 não explicita em qual momento necessitaria ocorrer a fecundação, não se limitando apenas à hipótese prevista no art. 1.798 do CC, na qual o nascituro teria sido concebido antes da morte do genitor.

Trata-se, portanto, de uma iniciativa sem precedentes no âmbito do sistema processual traçado pelo Código de 1973, e sem precedentes no âmbito do sistema jurídico brasileiro.

Isso porque o CPC/2015 não explicita se o nascituro necessita ter sido fecundado antes da morte do *de cujus* para que se lhe apliquem e garantam direitos processuais acautelatórios. Ora, se a garantia processual criada por Lei Federal é ampla, porque o direito material não seria?

Assim, o CPC/2015 também abrange processualmente um tema que ainda está longe de ser pacificado no âmbito do direito material: garante o acautelamento patrimonial na sucessão legítima do filho fecundado ou implantado no útero da mulher mesmo após a morte do marido ou companheiro.

Como se trata de uma medida acautelatória, fica claro que o mérito a respeito do direito sucessório do nascituro em cada caso ainda poderá ser debatido independente das disposições do art. 650 do CPC/2015, mas não há dúvida que o dispositivo traz novos ares o tema.

De qualquer forma, esta é uma situação que mais cedo ou mais tarde necessitará ser prevista

pelo direito material. Assim como a jurisprudência não conseguiria, o legislador não poderá se esquivar do tema no âmbito do direito substancial, necessitando se adequar às alterações da sociedade e à dinâmica da evolução científica favorável ao ser humano.

Art. 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem:

- I – dívidas atendidas;
- II – meação do cônjuge;
- III – meação disponível;
- IV – quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho.

1. O partidor e a Ordem da partilha

O partidor é um sujeito processual secundário, um auxiliar do juízo que atua em determinados processos de inventário, especialmente nas hipóteses de dissenso entre os herdeiros quanto à partilha.

Caso não haja acordo entre os herdeiros – ou mesmo na hipótese de requerimento destes – caberá ao magistrado nomear curador judicial com o objetivo de estruturar o esboço de partilha, com fulcro no art. 651 do CPC/2015. Aqui, mais uma vez, o CPC/2015 reproduz dispositivo do CPC/1973, qual seja o art. 1.023.³⁷⁸

O partidor judicial deverá observar as pretensões apresentadas pelas partes, bem como as diretrizes constantes do art. 651, dando prioridade, nessa ordem, ao pagamento das dívidas do espólio, considerando logo depois a meação do cônjuge, bem como passando, após, à partilha da meação disponível, para só então versar sobre os quinhões hereditários, começando pelo herdeiro de mais idade.

Após a manifestação das partes a respeito do esboço efetuado pelo partidor, é que se considera feita a partilha, a teor do art. 652, a seguir comentado.

Art. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 (quinze) dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos.

1. O esboço de partilha e a manifestação das partes

Uma vez realizado o esboço de partilha pelo partidor judicial, as partes devem se manifestar em um prazo comum, o qual agora se estende, passando a ser não mais de cinco, mas de quinze dias.

Tais manifestações, denominadas como *reclamações* pelo CPC/2015 ao manter a nomenclatura do art. 1.024³⁷⁹ do CPC/1973, são quaisquer impugnações que as partes possam efetuar em relação ao esboço da partilha, visando oferecer elementos para o juízo corrigi-la ou aperfeiçoá-la.

Possuem, assim, significado bastante diverso da *reclamação* prevista no art. 988³⁸⁰ do CPC/2015, a qual aumentou significativa e estrategicamente a importância daquele meio processual, não apenas junto aos tribunais superiores, mas também junto aos tribunais locais. Foi infeliz, assim, o legislador, ao utilizar termos idênticos para manifestações processuais absolutamente diversas.

No feito de inventário, entretanto, uma vez resolvidas as questões eventualmente impugnadas, tal resolução ocorrerá por meio de decisão interlocutória, de modo que a versão final da partilha será, então, lançada aos autos (CPC/2015, art. 652, 2.ª parte).

Como se trata de decisão interlocutória, mais uma vez o recurso cabível em face do aresto que

resolve as reclamações opostas contra o esboço da partilha será o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 parágrafo único do CPC/2015.

Art. 653. A partilha constará:

I – de auto de orçamento, que mencionará:

a) os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos;

b) o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações;

c) o valor de cada quinhão;

II – de folha de pagamento para cada parte, declarando a quota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam.

Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão.

1. Os requisitos da partilha

O art. 653 do CPC/2015 possui texto similar ao do art. 1.025³⁸¹ do CPC/1973. Sua maior novidade diz respeito à previsão do companheiro supérstite junto à alínea “a” de seu inc. I, junto ao rol dos demais herdeiros e interessados.

Assim, a auto da partilha deverá prever o nome do autor da herança, dos herdeiros, dos legatários, dos credores, assim como nome do inventariante e do cônjuge ou companheiro sobrevivente.

A partilha deverá, então, constar de uma peça, assinada tanto pelo escrivão quanto pelo juiz contendo não apenas a qualificação dos interessados, mas também a descrição pormenorizada do patrimônio ativo e passivo do espólio, além da descrição do quinhão de cada herdeiro, detalhadamente efetuada.

Isto significa que os nomes e a descrição sobre cada bem, eventualmente existente, também deverão constar do auto. Segundo inc. II do art. 653, da partilha constará ainda, folha de pagamento para os tributos referente ao recebimento de herança de cada uma das partes.

Deve constar, ainda, uma folha de pagamento do quinhão de cada parte, com a razão do pagamento dos referidos tributos, e com a sua respectiva fundamentação legal, além da relação dos itens atribuídos a cada uma das partes.

Tanto o auto de partilha quanto cada uma de suas folhas deverão, ainda, serem assinados tanto pelo juiz quanto pelo escrivão sob pena de invalidade, segundo se depreende do parágrafo único do art. 653 do CPC/2015.

Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha.

Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido.

1. A sentença que homologa a partilha

O próximo ato do procedimento diz respeito à sentença homologatória da partilha. Portanto, pago o imposto de transmissão *mortis causa* e juntadas as respectivas guias comprobatórias do pagamento e certidões negativas de débito para com a fazenda pública, o juízo deverá homologar a

sentença de partilha.

Ao contrário do que dispunha o art. 1.026³⁸² do CPC/1973, o art. 654 CPC/2015 traz uma inovação, desvencilhando a homologação da partilha por meio do pagamento dos respectivos tributos sucessórios ao pagamento de qualquer outro débito para com a fazenda pública.

Assim, a pretensão de condicionar a homologação da partilha cai por terra. Logo, o condicionamento³⁸³ do recebimento da herança à satisfação de outros débitos para com a fazenda pública é proibido pelo CPC/2015.

Como a partilha divide o espólio e termina a essência do procedimento em primeiro grau, tal decisão possui natureza jurídica de sentença. É ela que acaba com o espólio e desobriga o inventariante de suas funções. Logo, o recurso cabível em face da sentença de partilha é, portanto, o recurso de apelação (CPC/2015, art. 1.009).³⁸⁴

Tal recurso será recebido, via de regra, no duplo efeito, já que decorre da discordância de um ou de alguns dos herdeiros em relação à sentença de partilha, havendo risco significativo em simplesmente dar aos herdeiros acesso irrestrito a um patrimônio ainda não confirmado.

Via de regra, assim, apenas depois do trânsito em julgado da sentença de partilha³⁸⁵ é que os herdeiros terão acesso à herança por meio da emissão dos formais de partilha.³⁸⁶

Art. 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no art. 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças:

- I – termo de inventariante e título de herdeiros;
- II – avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro;
- III – pagamento do quinhão hereditário;
- IV – quitação dos impostos;
- V – sentença.

Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 (cinco) vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado.

1. A efetivação da sentença de partilha

Uma vez transitada em julgado a sentença de partilha, serão emitidos os denominados formais de partilha.

Trata-se de documentos necessários à transcrição das propriedades no registro de imóveis em nome de cada herdeiro, da transcrição dos registros perante o Detran, por exemplo, no que concerne aos automóveis partilhados, bem como perante as demais instituições de registro de posse ou propriedade de bens, sempre com a finalidade de transmitir a cada herdeiro o patrimônio devido.

O formal de partilha não possui, portanto, conteúdo decisório para o processo, mas sim conteúdo declaratório construtivo para transmissão de direitos aos herdeiros.

Do conjunto de documentos formado pelo formal de partilha deverá constar o termo de inventariante e o título de cada herdeiro, a avaliação dos bens que compõem o quinhão daquele herdeiro, o pagamento do quinhão e a quitação dos respectivos impostos, assim como uma cópia da sentença de partilha.

Nas hipóteses de herança de menor montante, o formal de partilha poderá não ser necessário.

Nesse caso, o parágrafo único do art. 655 do CPC/2015, mantendo a regra do parágrafo único do art. 1.027³⁸⁷ do CPC/1973, possibilita que o formal de partilha seja substituído por uma certidão que transcreva a sentença de partilha transitada em julgado, bem como o pagamento ou entrega do quinhão hereditário, mas desde que este quinhão não supere o valor correspondente a cinco salários mínimos.

Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.

1. A possibilidade de correção dos vícios da partilha, mesmo após o trânsito em julgado

Eventuais erros de fato ou inexatidões materiais constantes da sentença de partilha poderão ser corrigidos pelo juízo mesmo após o trânsito em julgado dessa decisão, com ou sem requerimentos das partes, conforme o caso.

A correção na hipótese de erro de fato – erro sobre as circunstâncias fáticas que envolvem o patrimônio e os herdeiros – exige a concordância de todas as partes e a observância do respectivo contraditório (CPC/2015, arts. 9.^o³⁸⁸ e 10), não podendo ser efetuada de ofício.

Por sua vez, entretanto, a correção da sentença de partilha na hipótese de erro ou inexatidão material – também conhecido como mero *erro de tinta* – pode ocorrer, da mesma forma, a requerimento das partes, mas também pode, ao menos em tese, se dar por decisão que o juiz tome de ofício. Exemplos são as grafias de nomes e eventuais zeros a mais ou a menos.

Mesmo assim tais correções devem, como também acontece com os erros de fato, respeitar sempre o contraditório substancial necessário em decorrência da necessidade de proibição à decisão surpresa, a teor do art. 10³⁸⁹ do CPC/2015.

Art. 657. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4.^o do art. 966.

Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 (um) ano, contado esse prazo:

- I – no caso de coação, do dia em que ela cessou;
- II – no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato;
- III – quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade.

1. A ação anulatória de partilha

A partilha amigável³⁹⁰ que houver sido homologada pelo juízo nos autos do inventário, ou em decorrência de homologação em juízo de instrumento particular havido entre os herdeiros, ou ainda a partilha lavrada em instrumento público, poderá ser objeto de ação anulatória³⁹¹ cuja fundamentação legal é vinculada às hipóteses do art. 657 do CPC/2015.

Nesses casos, o fundamento da pretensão anulatória deverá ser a comprovação de dolo ou erro essencial a respeito de circunstância que certamente teria levado o herdeiro a ter comportamento diverso, ou mesmo a ausência de incapaz que deveria ter participado do feito, a qual impediria a própria realização da partilha amigável, respeitando-se as disposições do parágrafo § 4.^o do art. 966³⁹² do CPC/2015.

Justifica a propositura da ação, portanto, tanto o defeito de negócio jurídico decorrente da

ocorrência de um acordo de vontades viciado, quanto a indevida participação ou ausência de incapazes.

Tal ação, de eficácia constitutiva negativa, deve ser proposta perante o juízo do inventário, no prazo decadencial de um ano. Felizmente, em respeito aos precedentes dos tribunais superiores a este respeito (STJ, 4.^a T. Resp 168399/RS, rel. Min. Aldir Passarinho, j. 03.05.2001),³⁹³ o CPC/2015 não fala mais em prazo *prescricional* – como fazia o art. 1029³⁹⁴ do CPC/1973 – mas sim em *extinção* do direito, reconhecendo a sua natureza decadencial.

O prazo decadencial de um ano será contado, na hipótese de coação, da data em que esta cessou. Nas hipóteses de erro essencial ou de dolo, o prazo de um ano conta-se da data em que o ato ocorreu.

Para o incapaz, por sua vez, o prazo decadencial de um ano para a propositura da ação se conta da data em que terminar a sua incapacidade (CPC/2015, art. 657, III).

A anulação da sentença de partilha trará a necessidade da prolação de nova sentença com este objetivo, desta vez atentando-se para a falha que gerou a necessidade de anulação da sentença anterior.

Tal anulação obviamente não impede, entretanto, que preenchidos os respectivos requisitos legais, possa ocorrer nova partilha amigável, desde que se faça de forma válida.³⁹⁵

Art. 658. É rescindível a partilha julgada por sentença:

I – nos casos mencionados no art. 657;

II – se feita com preterição de formalidades legais;

III – se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.

1. As hipóteses de ação rescisória da sentença de partilha

As hipóteses de rescisão³⁹⁶ do art. 658 do CPC/2015 não dizem respeito a partilhas amigáveis,³⁹⁷ mas sim a partilhas proferidas em inventários contenciosos. Não tratam de nova espécie de ação rescisória,³⁹⁸ mas sim de mera complementação ao rol das hipóteses autorizadoras da ação rescisória (CPC/2015, art. 966),³⁹⁹ assim como o art. 1030⁴⁰⁰ do CPC/1973 já fazia em relação ao art. 485 daquele diploma legal.

Os defeitos que justificam a propositura de ação rescisória perante o tribunal de justiça respectivo são tanto os vícios do art. 657 do CPC/2015 – dolo, erro essencial ou intervenção de incapaz, mas desta vez ocorridos em partilha não amigável – quanto o desrespeito às formalidades legais da partilha.

Justifica, ainda, a propositura da ação rescisória em face da sentença de partilha não amigável, o fato de haver comprovada preterição⁴⁰¹ ou mesmo a inclusão indevida de herdeiro, entendendo-se aqui o termo herdeiro de forma ampla, como qualquer sucessor, portanto.

Nesse sentido, importa ressaltar que conforme o enunciado 137 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: *Contra a sentença que resolve a partilha não amigável, caberá ação rescisória*. Trata-se, portanto, de complementações efetuadas pelo art. 658 ao rol do art. 966 do CPC/2015.

Logo, ao contrário da ação anulatória do art. 657 – cujo prazo é de um ano – o prazo para a propositura da ação rescisória cujas hipóteses constam do art. 658 será decadencial de dois anos, a teor do art. 975⁴⁰² do CPC/2015.

Problema não resolvido pelo CPC/2015, no entanto, é o do herdeiro que simplesmente não participou do inventário e da partilha, em face de quem não faz sentido algum aplicarem-se os

efeitos da coisa julgada material, muito menos contar-se o prazo decadencial para a ação rescisória.

Caso ainda não seja reconhecido, tal herdeiro poderá propor a respectiva ação de reconhecimento de paternidade cumulada com petição de herança.⁴⁰³ Caso se trate de herdeiro já reconhecido, será necessário formular apenas a pretensão referente à petição de herança.

O fato, entretanto, é que concordamos com aqueles para quem a não participação desses herdeiros no inventário faz com que sequer corra em face destes o prazo de dois anos para a propositura da ação rescisória da partilha (Alexandre Câmara, 2012, p. 492).

Acreditamos, assim, que tais herdeiros poderão sempre propor a ação rescisória do art. 658,⁴⁰⁴ mas também terão a opção de formular, a qualquer tempo, especialmente para escapar a interpretações que lhes neguem acesso à rescisória em face do decurso do tempo, ação de petição de herança em primeiro grau cuja decisão final, caso julgada procedente, também possuirá sim, em nossa opinião, o poder de modificar a coisa julgada da sentença de partilha.

Interpretar o sistema de forma diversa seria duplamente cruel, retirando efetividade e interesse da ação de petição herança e aplicando-se diretamente os efeitos da coisa julgada a pessoa que não participou do processo apenas para lhe negar direitos sucessórios.⁴⁰⁵

Seção IX

Do arrolamento

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1.º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2.º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2.º do art. 662.

1. O arrolamento e seu procedimento

O CPC/2015 manteve além do procedimento solene de inventário, o procedimento de arrolamento. O arrolamento⁴⁰⁶ é um procedimento simplificado que combina em uma única fase tanto as atividades de inventariança quanto as atividades de partilhamento dos bens.

A natureza jurídica do arrolamento é, portanto, de um procedimento de jurisdição voluntária. O procedimento de arrolamento é utilizado quando não existe conflito entre sucessores capazes, conforme escrito particular ou termos nos autos ou, da mesma forma, quando só existe um herdeiro ou legatário, hipótese esta em que basta adjudicar a um herdeiro único os ativos deixados pelo falecido.

Nessas duas hipóteses, a lei denomina o procedimento como arrolamento sumário, disciplinado no art. 660 do CPC/2015.

Ao lado do arrolamento sumário, entretanto, o art. 664⁴⁰⁷ do CPC/2015 regula também o denominado arrolamento comum ou simples, aplicável nas situações em que for pequeno o valor dos bens a serem partilhados, ainda que não se trate de partilha amigável, correspondendo a montante de até 1000 salários mínimos.

A teor do art. 665⁴⁰⁸ do CPC/2015, também será cabível o arrolamento comum ou simples quando as partes e o Ministério Público estiverem de acordo sobre a partilha, mesmo havendo herdeiro incapaz.

O arrolamento comum e o arrolamento sumário possuem praticamente o mesmo rito. Daí a postura de Antonio Carlos Marcatto, 2005 p. 243, por exemplo, que prefere desconsiderar a distinção de ritos. Parece-nos, entretanto, que os procedimentos não são exatamente idênticos, por haver diferença nos critérios provocadores dos atos de avaliação dos bens.

Enquanto no arrolamento sumário só haverá avaliação caso haja credor habilitado que discorde dos valores apresentados, a teor do art. 661⁴⁰⁹ do CPC/2015, no arrolamento simples será necessária a avaliação num espectro maior de situações, pois esta se dará sempre que qualquer das partes ou o Ministério Público decidam impugnar a estimativa efetuada, conforme se depreende do parágrafo primeiro do art. 664 do CPC/2015.

Tal distinção de ritos já existia no art. 1.036⁴¹⁰ do sistema antigo, mas poderia muito bem ter sido extinta pelo CPC/2015, cuja estrutura no tocante a avaliação consta dos arts. 630 a 635 do Novo diploma legal. Tal mudança acabaria com a necessidade de realizar a audiência para julgamento das reclamações prevista no parágrafo segundo do art. 664 do CPC/2015.

As disposições referentes ao rito de arrolamento são praticamente as mesmas constantes dos arts. 1.031 a 1.036 do CPC/1973.

A primeira diferença, entretanto, é de que, o parágrafo segundo do art. 659 a partir de agora prevê a possibilidade de, com o trânsito em julgado da sentença que homologa o arrolamento, ser desde já determinada a expedição do formal de partilha ou a expedição da carta de adjudicação, intimando-se, a fazenda pública, logo após, para efetuar o lançamento dos tributos incidentes.

No regime do CPC/1973, só seria possível tal prática após terem sido comprovados os pagamentos dos respectivos atributos, a teor do parágrafo segundo do antigo art. 1031.⁴¹¹

Logo, o CPC/2015 excepciona, no tocante ao procedimento de arrolamento, o art. 192⁴¹² do Código Tributário Nacional, segundo o qual nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem a prova da quitação de todos os tributos relativos aos bem estou espólio, ou as suas rendas.

A segunda alteração de conteúdo efetuada pelo CPC/2015 foi a substituição das extintas obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional ao RTN pelo salário mínimo, a fim de definir a alçada do rito do rolamento comum ou simples.

Se algum dos requisitos legais das hipóteses de arrolamento não for respeitado o juízo deverá determinar a conversão do procedimento de arrolamento em procedimento de inventário e partilha solenes, como, por exemplo, na hipótese de uma incapacidade superveniente de herdeiro. Poderá o juízo, também, transformar o inventário ou partilha solenes em arrolamento, sempre respeitando a presença dos respectivos requisitos legais.

O fato é que o art. 659 do CPC/2015 recebeu uma redação bastante diferente daquela que o art. 1031 CPC de 73 possuía, tanto no que concerne a forma quanto no que diz respeito ao conteúdo, seguindo a tendência de simplificar os procedimentos de arrolamento e reduzindo a importância da participação da fazenda pública no procedimento.⁴¹³

Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros:

- I – requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem;
- II – declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630;
- III – atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha.

1. O arrolamento sumário

O pedido de inventário que se processa por meio de arrolamento sumário deve ser efetuado em juízo por meio de acordo entre todos os interessados, ainda que representados por advogados diversos.

Nessa petição,⁴¹⁴ os sucessores requererão ao juízo seja nomeado o inventariante que designarem, assim como declararão a que título correspondem os herdeiros, desde já descrevendo também os itens que compõem o espólio e respeito ao art. 630⁴¹⁵ do CPC/2015. Ao final, atribuirão, ainda, valor a cada um dos bens do espólio afim de que sejam partilhados. Tudo deve estar acompanhado pelos documentos e pelas certidões pertinentes.

Como no arrolamento sumário o inventariante terá sido nomeado em decorrência de pedido de todos os sucessores e interessados, o inventariante estará dispensado de prestar compromisso.

Convém lembrar, ainda, que só haverá inventariante se existir mais de um herdeiro. Se não houver impugnação sobre a estimativa de valor dos bens, os tributos serão pagos.

O juiz dará vista à fazenda pública e estando esta de acordo, homologará a partilha ou plano de adjudicação e expedirá os formais de partilha e alvarás. Tal procedimento não possibilita a discussão a respeito do mérito dos tributos relativos a essa transmissão de propriedade (STJ, 4.^a T. REsp 36909/SP, Min. Sálvio F. Teixeira, j. em 12.11.96).⁴¹⁶

Eventuais informações deverão ser realizadas apenas administrativamente para, só depois, concretizar-se a averbação do formal de partilha (STJ, 2.^a T. REsp 434483/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 03.08.2006).⁴¹⁷

Via de regra, atribuição do valor dos bens do espólio será efetuada pelas próprias partes, tanto na homologação de partilha amigável quanto na adjudicação a herdeiro único, salvo na hipótese de impugnação pelo credor habilitado prevista no parágrafo único do art. 663 ou na hipótese de reclamação a que se refere o parágrafo segundo do art. 664.⁴¹⁸

Art. 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade.

1. Regra da não avaliação

Por força do art. 661 do CPC/2015, nos procedimentos de arrolamento, ao contrário do inventário solene, a regra, portanto, é a de não se proceder à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade, tanto na partilha amigável quanto na adjudicação a herdeiro único, mesmo que haja herdeiro menor (RT 590/85).

É conveniente, mesmo assim, que os interessados lancem as suas estimativas acompanhadas dos documentos pertinentes, prática esta que já era adotada no regime do CPC/1973, por ocasião da aplicação do seu art. 1.033.⁴¹⁹

Existem duas exceções, entretanto, em que a avaliação necessitará ocorrer.

A primeira delas é na hipótese de impugnação pelo credor⁴²⁰ habilitado prevista no parágrafo único do art. 663 do CPC/2015.

A segunda exceção está prevista na hipótese da reclamação por parte de qualquer interessado, a que se refere o parágrafo segundo do art. 664 do CPC/2015.⁴²¹

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1.º A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2.º O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

1. O pagamento dos tributos

O pagamento dos tributos no arrolamento é regulado pelo art. 662 do CPC/2015. O art. 662 do CPC/2015 reproduz integralmente o art. 1.034⁴²² do CPC/1973, explicitando que o procedimento de arrolamento não é a sede adequada para discutir se o mérito do pagamento de taxas judiciárias e nem de tributos.

Logo, os tributos necessitarão ser adimplidos de acordo com os valores constantes dos autos; quaisquer diferenças eventuais necessitarão ser calculadas e posteriormente cobradas e discutidas em processo administrativo.

Assim, caso a fazenda pública entenda que os valores declarados pelos sucessores não correspondem à realidade, não ficará adstrita aos valores atribuídos pelos herdeiros e deverá efetuar o lançamento administrativo em separado (parágrafos primeiro e segundo do art. 662 do CPC/2015), sendo que o julgamento e a decisão de partilha não dependerão da respectiva cobrança.

Haverá, portanto, uma fiscalização tributária *a posteriori*. Sendo verdade, no entanto, que sem o pagamento dos respectivos impostos não será possível, a título de exemplo, averbar, junto ao registro imobiliário, o formal de partilha.

Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.

Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados.

1. Credores do Espólio

O texto do art. 663 do CPC/2015 versa sobre a hipótese de existência de credores do espólio no procedimento de arrolamento. Seu conteúdo é idêntico ao do art. 1035⁴²³ do CPC/1973.

Segundo ele, o fato de existirem credores do espólio não é suficiente para impedir a homologação da partilha ou da adjudicação, desde que sejam devidamente reservados bens em valor suficiente para que essa dívida seja paga.

Como a estimativa dos valores de cada bem é efetuada pelos próprios sucessores, a discussão que pode acontecer é a de os credores, que deverão ser regularmente notificados, impugnarem tal estimativa, hipótese esta em que será necessário, a teor do parágrafo único do art. 663 do CPC/2015, promover-se a avaliação dos bens a serem reservados.

Durante o processo, caso seja apurado que os bens reservados não são suficientes para a quitação das obrigações com os credores, tal reserva deverá ser substituída ou complementada.

É imprescindível, entretanto, que os credores se habilitem no procedimento também demonstrando possuir direito líquido e certo a teor dos arts. 642⁴²⁴ e 644⁴²⁵ do CPC/2015, bem como apresentem a respectiva prova literal da dívida, consoante o parágrafo primeiro do art. 642 do CPC/2015, sendo que obviamente tal exigência também se aplica ao arrolamento, não sendo razoável impor ao herdeiro tamanha restrição patrimonial se não houver comprovada possibilidade de a dívida existir.

Além disto, também poderá haver a recusa de pagamento por parte dos herdeiros caso esta esteja fundada em prova de quitação da respectiva dívida ou fundada na inexigibilidade do crédito, caso, por exemplo, ainda não esteja vencido.

Nesta hipótese, não havendo concordância das partes na habilitação do credor, este poderá aguardar o vencimento da dívida e requerer o seu pagamento com fulcro no art. 642 do CPC/2015.

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

§ 1.º Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) dias.

§ 2.º Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas.

§ 3.º Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes ou por seus advogados.

§ 4.º Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 5.º Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.

1. O arrolamento simples

O art. 664 versa sobre o procedimento de arrolamento simples, assim como fazia o art. 1036⁴²⁶ do CPC/1973.

A essência do procedimento de arrolamento simples é a mesma do procedimento de arrolamento sumário dos arts. 659 e seguintes do CPC/2015, com a diferença de que no arrolamento simples ocorrerá avaliação sempre que qualquer uma das partes ou o próprio Ministério Público impugnarem a estimativa lançada nos autos pelos sucessores, conforme reza o parágrafo primeiro do art. 664 do CPC/2015.

Como aqui já se explicitou, a avaliação só acontecerá quando um dos credores habilitados se insurge contra a estimativa lançada pelo sucessores, conforme explícita o art. 661 do CPC/2015. Trata-se de uma distinção que o CPC/1973 também já efetuava em seus arts. 1033⁴²⁷ e 1036 parágrafo primeiro e que poderia ter sido extinta pelo CPC/2015.

A efetiva inovação constante do art. 664 do CPC/2015 é a substituição do índice utilizado para fixação da alçada do procedimento de arrolamento simples ou comum. O critério utilizado pelo CPC/1973 era o das obrigações e ajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, que foram inseridas no CPC/1973 por meio da Lei 7019 de 1982.

Entretanto, as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional foram extintas pelo decreto-lei 2284 de 1986, provocando junto ao intérprete a necessidade de investigar variados índices de conversão a fim de atingir o valor atualizado da disposição legal.

O *caput* do art. 664 deixa claro entretanto, que o salário mínimo passa a ser o critério para mensuração, como também fazem os arts. 77 parágrafo quinto,⁴²⁸ 81, parágrafo segundo,⁴²⁹ 85 parágrafos terceiro e quarto,⁴³⁰ 202⁴³¹ e 258,⁴³² dentre outros, sendo cabível o rolamento simples nas hipóteses em que o valor do espólio for inferior ou igual a 1000 salários mínimos.

Importa registrar, com efeito, que o texto do parágrafo quarto do art. 664 possui evidente erro de digitação. O objetivo do parágrafo era aplicar ao arrolamento simples as mesmas disposições do arrolamento sumário no tocante a simplicidade do lançamento, do pagamento e dar quitação tanto das taxas judiciais quanto dos impostos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens que compõem o espólio, realizando-se fiscalização tributária *a posteriori* do imposto de transmissão.

Assim, não são as disposições do art. 672⁴³³ do CPC/2015 referentes à cumulação de inventários que se aplicam ao arrolamento simples, mas sim as disposições do art. 662 a respeito da simplicidade no pagamento de tributos, as quais se aplicam tanto arrolamento sumário quanto ao arrolamento simples.

Por esse motivo discordamos de que o pagamento dos tributos relativos aos pés do espólio deva ocorrer de forma diversa nos procedimentos de arrolamento sumário de arrolamento simples, haja vista o erro de digitação ocorrido no texto legal.

Veja-se que o pagamento de dívidas no arrolamento comum ou simples também segue a mesma sistemática da quitação das dívidas prevista para o rolamento sumário, devendo o credor apresentar prova literal de obrigação líquida certa e exigível, bem como de vendo as partes anuía o pagamento.

Na hipótese de não haver anuência, desde que tal recusa não esteja fundamentada em prova de quitação da dívida, deverão ser reservados bens para o respectivo pagamento.

Tanto a deliberação sobre a partilha quanto a decisão a respeito do pagamento de dívidas⁴³⁴ precisaram ser proferidas em audiência, o que em nossa opinião não contribui para dar maior celeridade ao arrolamento simples. O legislador facilitaria o procedimento caso tivesse eliminado audiência constante do parágrafo segundo do art. 664.⁴³⁵

Art. 665. O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público.

1. O incapaz no arrolamento simples

O art. 665 do CPC/2015 não possui correspondência em qualquer dispositivo do CPC/1973. De acordo com art. 665, sendo inferior ou igual a 1000 salários mínimos o valor do espólio, também será adotado o rito do arrolamento simples previsto no art. 664 na hipótese de haver interessados incapazes.

Nesse caso, entretanto, será imprescindível a concordância não apenas das partes, mas também do Ministério Público. O CPC/2015 cria, portanto, uma nova situação para o incapaz, ao mesmo tempo em que o protege condicionando a aplicação do rito de arrolamento simples à aceitação do representante do Ministério Público.

Existe assim, um conjunto de dispositivos do CPC/2015 que buscam facilitar o trâmite dos inventários em que haja a presença de interessado incapaz, tanto no art. 665 quanto no art. 671, II,⁴³⁶ perquirindo sempre o interesse do incapaz a eventual colisão de seus interesses com os interesses de seu representante.

Art. 666. Independência de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858, de 24 de novembro de 1980.

1. O alvará judicial

O art. 666 regula o procedimento de alvará judicial e repete o art. 1.037⁴³⁷ do CPC/1973.

A redação do art. 1.037 havia sido modificada pela Lei 7.109 de 1982, deixando claro não ser

necessário proceder-se ao inventário e a partilha para o pagamento de valores que possam ser obtidos através do procedimento especial de jurisdição voluntária denominado alvará judicial, previsto na Lei 6.858 de 1980.

Trata-se de simples pedido efetuado em juízo. Far-se-á, assim, por meio do procedimento simplificado de alvará judicial, o pagamento direto aos dependentes ou sucessores do falecido, dos créditos relativos ao fundo de garantia do tempo de serviço e do Fundo de participação PIS-PASEP, independentemente de inventário solene ou de qualquer espécie de arrolamento.

Art. 667. Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII e VIII deste Capítulo.

1. Aplicação subsidiária do procedimento solene

O art. 667 do CPC/2015 determina aplicação subsidiária do procedimento de inventário e partilha solenes aos procedimentos de arrolamento, Como já fazia o art. 1.038⁴³⁸ do CPC/1973, O que se quis foi manter a lógica de subsidiariedade do procedimento solene aos procedimentos de rolamento.

Entretanto, as disposições do art. 1.038 a respeito dessa subsidiariedade era o mais amplas do que as do art. 667 do CPC/2015. Isso porque o art. 1.038 determinava a aplicação de todas as disposições do inventário solene subsidiária mente aos rolamentos, sem restringir quais conteúdos do inventário solene deveriam ser aplicados os rolamentos.

Por sua vez, entretanto, o art. 667 do CPC/2015 restringe a aplicação subsidiária às seções VII e VIII deste capítulo, as quais versam apenas sobre o pagamento das dívidas do espólio e sobre a partilha.

Parece-nos um tanto implícito ao sistema, mesmo assim, que as demais regras que se fizerem pertinentes, reguladas pelo procedimento solene, continuaram sendo aplicáveis arrolamento, ainda que por interpretação analógica uma vez que o rito solene é uma espécie de rito comum do inventário e da partilha, enquanto a rolamentos são ritos especiais, seguindo o modelo do art. 318⁴³⁹ o CPC/2015.

Melhor teria sido, desta forma, que o art. 667 do CPC/2015 tivesse mantido a amplitude da aplicação subsidiária prevista pelo art. 1.038 do CPC/1973.

Seção X

Disposições comuns a todas as seções

Art. 668. Cessa a eficácia da tutela provisória prevista nas Seções deste Capítulo:

I – se a ação não for proposta em 30 (trinta) dias contados da data em que da decisão foi intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido;

II – se o juiz extinguir o processo de inventário com ou sem resolução de mérito.

1. Medidas provisórias no inventário

O art. 668 do CPC/2015 altera e aprimora o texto do art. 1039⁴⁴⁰ do CPC/1973, dispondo até qual momento cessa o efeito das medidas provisórias deferidas durante os inventários.

Para tanto, o dispositivo segue a lógica do art. 309⁴⁴¹ do CPC/2015, segundo a qual a eficácia da medida cautelar⁴⁴² depende de ainda estar presente o risco efetivo ao direito acautelado.

Nas hipóteses dos incisos I e II do art. 668 o CPC/2015 descreve situações, portanto, em que a extinção do processo de inventário com ou sem, resolução do mérito bem como a não propositura da medida principal no prazo de até 30 dias contados da data em que o impugnando foi intimado da decisão, o herdeiro for excluído, o credor não for admitido, não haveria mais dano a ser acautelado.

O que o novo dispositivo faz, assim, é aprimorar elementos de redação do antigo art. 1.039 do CPC/1973, retirando o advérbio várias, retirando as referências remissivas a artigos, e substituindo o termo julgamento do mérito pela expressão mais acertada resolução de mérito, que já havia sido inserida no sistema processual por meio da Lei 11.232 de 2005.

A tutela provisória aqui se refere o art. 668 consiste na reserva de quinhões e créditos de possíveis herdeiros assim como credores do espólio, até que seja em processo próprio, apurada definitivamente a situação de herdeiro ou adequação da cobrança pelos credores.

São três, portanto as situações protegidas, quais sejam, a reserva de quinhão do herdeiro inserido nas primeiras declarações mas contestado por outro sucessor, a teor do art. 627 parágrafo terceiro,⁴⁴³ a reserva de quinhão daquele que se considera herdeiro mas que foi preterido, tendo a sua inclusão no inventário contestada a teor do art. 628 parágrafo segundo,⁴⁴⁴ e a reserva de bens com vistas ao pagamento a credor cujo crédito está comprovado documentalmente, mas cuja dívida não teve pagamento aceito por todas as partes do inventário, consoante o parágrafo único do art. 643⁴⁴⁵ do CPC/2015.

Muito embora o sistema de tutela provisória no CPC/2015 tenha sido simplificado, continua sendo necessário que o beneficiário da medida proponha a medida principal no prazo de até 30 dias após a efetivação da tutela cautelar, como determina o art. 309⁴⁴⁶ do CPC/2015.

O prazo de 30 dias contará no caso de contestação da qualidade de herdeiros, da data em que este for intimado da decisão que remeteu a controvérsia aos meios ordinários.

No caso de discordância de pagamento a credor, contará da data da intimação da decisão que remete os interessados aos meios ordinários. Por sua vez no caso de pedido de admissão no inventário, contará da data em que este for intimado da decisão de indeferimento.⁴⁴⁷

Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I – sonegados;

II – da herança descobertos após a partilha;

III – litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV – situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.

1. Sobrepartilha

O art. 669 CPC/2015 mantém as situações previstas pelo art. 1040⁴⁴⁸ do CPC/1973. O dispositivo versa sobre a possibilidade de sobrepartilha de determinados bens pertencentes ao espólio, permitindo que bens conhecidos e facilmente partilhados assim o seja rapidamente, e deixando aqueles de difícil divisão para o momento posterior.⁴⁴⁹

A sobrepartilha⁴⁵⁰ consiste na realização de um procedimento de inventário e partilha dentro do mesmo processo, a teor do art. 670 do CPC/2015, sempre que se verificar a existência de determinadas situações, as quais impediram sua partilha em um primeiro momento.⁴⁵¹

A primeira dessas situações é a existência de bens sonegados pela inventariante ou demais herdeiros.

Havendo bens sonegados os herdeiros que não houverem colacionado tais bens ao espólio deverão perder os direitos sucessórios sobre essa parcela do patrimônio, a teor dos arts. 1.992 a 1.996 do CC, dividindo-se tais bens entre os demais herdeiros, circunstância essa que será considerada no julgamento da sobre partilha.

É verdade que a sobrepartilha de bens sonegados não é, entretanto, uma regra absoluta. Competirá ao juízo decidir a respeito da colação do bem no próprio processo de inventário sempre que as provas já estiverem pra constituídas a teor do art. 641⁴⁵² do CPC/2015, desde que não haja ação dos demais herdeiros visando à aplicação da pena de sonegação, com fulcro no art. 1994 do CC.

A sobrepartilha será aplicável, portanto, sempre que a sua ligação foi descoberta pelos demais herdeiros após o término do processo de inventário ou, ainda, quando a análise da sonegação exigir uma dilação probatória e diversa da documental, consoante dispõe o parágrafo segundo do art. 641⁴⁵³ do CPC/2015.

Mesmo que as partes precisem ser remetidas as vias ordinárias, nada impede que a questão seja resolvida a tempo de inventariar e partilhar o bem sonegado com os demais herdeiros, dependendo, da iniciativa destes a aplicação da pena de sonegação, consoante o art. 1.994⁴⁵⁴ do CC.

Também haverá sobrepartilha caso se verifique a existência de bens de difícil liquidação ou de liquidação morosa, a existência de bens litigiosos ou mesmo de bens situados em lugares remotos em relação à sede do juízo onde se desenvolveu o inventário.

Embora ocorra dentro do mesmo processo a sobre partilha é uma nova demanda possuindo caráter autônomo. Mesmo assim, é importante lembrar que a sobre partilha não possui como pressuposto a necessidade de anulação da partilha anterior (STJ, 3.ª T. REsp 770709/SC, rel. Min. Ari Pargendler j. Em 20.05.2008).⁴⁵⁵ Trata-se de uma complementação e não da nova realização da parte anterior.

Deve se considerar ainda que caso inventário tenha sido realizado em cartório a teor da Resolução 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça, a sobre partilha também poderá seguir a mesma forma, desde que se respeite também os requisitos legais previstos no art. 610⁴⁵⁶ do CPC/2015.

O parágrafo único do art.1.045⁴⁵⁷ do CPC/1973 previa a possibilidade de se descrever e partilhar submetidos ao inventário do cônjuge pré-morto quando se fosse realizar um inventário do cônjuge sobrevivente. Isso para que não fosse necessário realizar o procedimento de sobre partilha em relação aos bens omitidos no inventário do cônjuge pré-morto.

Tal dispositivo não impedia a realização de sobre partilha na hipótese, mas funcionava apenas para não obrigá-la, possibilitando uma solução posterior que estava de acordo com os princípios da Instrumentalidade e da economia processual, aplicando-se tais princípios tanto as nulidades combinadas quanto as nulidades não cominadas (CPC/2015, art. 277⁴⁵⁸ e STJ, 1.ª T. REsp 796594/SP rel. Min Denise Arruda, j em 19.03.2007; STJ, REsp 1219329/RJ Min João Otávio de Noronha, DJ de 29.04.2014).⁴⁵⁹

Entretanto, o art. 673 do CPC/2015 extinguiu a disposição do parágrafo único do art. 1.045 do CPC/1973 de modo que, a partir de agora, a sobre partilha terá de ser proposta, o que representa um verdadeiro retrocesso em relação ao sistema de nulidades previsto pelo próprio CPC/2015 em seus arts. 276⁴⁶⁰ a 283.⁴⁶¹

A sobrepartilha deve ser requerida no prazo prescricional geral concernente as ações pessoais. Na vigência do Código Civil de 1916, tal prazo era de 20 anos entre presentes e de 15 anos entre ausentes.

Por sua vez, na vigência do CC de 2002, o prazo é de 10 anos devendo ser contado a partir do momento em que a sobre partilha poderia ter sido requerida pelo interessado de forma a obedecer a regra da *Actio nata*.⁴⁶²

O fato de existirem bens conhecidos litigiosos, de difícil ou morosa liquidação ou mesmo sonegados mais relegados a sobre partilha impunha necessidade de manutenção do espólio e, por consequência a necessidade de manutenção do inventariante para administração desses bens, novamente respeitando-se a regra geral de nomeação constante do art. 617⁴⁶³ do CPC/2015.

Mesmo assim, caso seja verificada a transcrição dos deveres do inventariante ainda que contrariando a vontade da maioria dos sucessores, deverá o magistrado competente substituir o inventariante.

Como o CPC/2015 estabeleceu expressamente que as decisões proferidas em processo de inventário estão sujeitas a agravo de instrumento, consoante dispõe o parágrafo único do seu art. 1.015, a decisão que autoriza a sobrepartilha de bens deverá ser impugnada por meio desse recurso.⁴⁶⁴

Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.

Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.

1. Aplicação subsidiária das demais regras referentes a inventário e partilha

O art. 670 do CPC/2015 possui essencialmente o mesmo conteúdo do art. 1.041⁴⁶⁵ do CPC/1973. Aplica-se, portanto, subsidiária mente ao rito da sobre partilha todas as disposições compatíveis com os demais procedimentos de inventário e partilha.⁴⁶⁶

A sobrepartilha é um procedimento novo que deve se iniciar com a apresentação da petição inicial e terminar por meio da prolação da respectiva sentença de sobrepartilha, sendo que o juízo competente para o trâmite e o julgamento da sobre partilha é exatamente aquele onde se processou o inventário e a partilha.

É necessário, assim, o desarquivamento dos autos do inventário uma vez que a sobre partilha corre exatamente nestes autos (STJ, 2.ª seção, CC 54801/DF⁴⁶⁷, Min. Sidnei Beneti, j. Em 25.05.2009).

Veja-se, ainda, que a sonegação comissão de bens por parte de herdeiro ou terceiro, não estão entre as hipóteses autorizadoras da propositura de ação rescisória contra sentença de partilha, a teor do art. 966 e seguintes do CPC/2015. Em ambas as hipóteses tais bens de verão apenas serem objeto do procedimento de sobre partilha.

A legitimidade para requerer e protocolar inicial de sobrepartilha é idêntica à legitimidade para o pedido de inventário constante dos arts. 615⁴⁶⁸ e 616⁴⁶⁹ do CPC/2015. Como na sobre partilha permanece indivisos alguns bens conhecidos os pode continuará existindo, ainda que já tenha sido proferida a sentença de partilha dos demais bens (STJ, REsp 284669/SP⁴⁷⁰ 3.ª T. rel. Min. Nancy Andrigli, j. em 10.04.2001).

Art. 671. O juiz nomeará curador especial:

I – ao ausente, se não o tiver;

II – ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses.

1. Curador especial

Assim, como faz o art. 1.042⁴⁷¹ do CPC/1973, o art. 671 do CPC/2015 versa sobre a nomeação de

curador especial no âmbito do inventário. Assim, o juiz deve nomear curador especial para o feito de inventário ao ausente, caso este ainda não possua representante.

A segunda hipótese de nomeação de curador especial no processo de inventário é do curador ao incapaz, mas desde que o representante do incapaz também concorra na partilha e haja fundada suspeita da existência de colisão de interesses entre o incapaz e o seu representante legal.

No regime anterior, o texto legal dizia somente que seria dado curador especial ao incapaz quando o curador concorresse com o seu representante legal. Interpretada literalmente, essa regra levaria a participação do curador especial na maioria dos inventários em que houvesse interessado incapaz, além da participação necessária do Ministério Público.

Por esse motivo construiu-se ao longo dos anos de vigência do CPC/1973 a ideia de que a intervenção do curador especial somente deveria ser necessária se estivesse demonstrada eventual colisão de interesses entre o incapaz e o seu representante (STJ, 3.^a T. REsp 139237/MG⁴⁷² rel. Min. Waldemar Zveiter, j. em 15.02.2001).

Foi exatamente esse o entendimento⁴⁷³ que levou ao aperfeiçoamento do inc. II do art. 671 do CPC/2015, deixando claro que apenas na hipótese de conflito com os interesses do incapaz haverá a necessidade de designar curador especial no inventário.

Além das hipóteses dos incs. I e II do art. 671 do CPC/2015, também poderá ser nomeado curador especial aos sucessores e interessados citados por edital e que não apresentem manifestação no processo de inventário, nessa hipótese aplicando-se a analogicamente o art. 72 do CPC/2015, por meio da atuação da Defensoria Pública na hipótese.

Ainda que não se possa falar tecnicamente em revelia propriamente dita no processo de inventário segundo o art. 341, parágrafo único⁴⁷⁴ do CPC/2015, Uma vez que os interessados não contestam um inventário, tal aplicação analógica do inc. II do art. 72⁴⁷⁵ garantiria o exercício do direito de defesa e devido processo legal a todos os interessados.⁴⁷⁶

Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:

- I – identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;
- II – heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;
- III – dependência de uma das partilhas em relação à outra.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

1. Cumulação de inventários

Assim como fazia o art. 1.043⁴⁷⁷ do CPC/1973, o art. 672 do CPC/2015 também versa sobre a cumulação de inventários.⁴⁷⁸

As hipóteses de cumulação de inventários no CPC/1973 se resumiam a situação em que o sistema possibilitava que o inventário do cônjuge sobrevivente fosse realizado cumulativamente quando da sua morte com o inventário do cônjuge pré-morto, desde que os herdeiros de ambos fossem exatamente os mesmos, processando-se em apêto ao primeiro inventário.⁴⁷⁹

Por sua vez, o CPC/2015 não dedica três dispositivos ao tema, mas apenas dois quais sejam os arts. 672⁴⁸⁰ e 673,⁴⁸¹ os quais regulam o tema da acumulação de inventários de forma mais ampla e também alteram algumas de suas disposições procedimentais.

A abrangência das disposições do CPC/2015 a respeito do tema permite concluir que acumulação de inventários poderá ser tanto de caráter inicial, desde a petição inicial, portanto, quanto de caráter incidental, efetuando-se tal pedido de forma superveniente, durante o processo.

As hipóteses de cumulação previstas pelo CPC/2015 são 3, quais sejam: a simples identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens ainda que esses herdeiros não sejam filhos de um mesmo casal; as heranças deixadas tanto pelos dois com o juiz quanto pelos dois companheiros; e as situações em que uma partilha dependa da resolução de outra partilha.

Muito embora o § 2.º do art. 1.043⁴⁸² do CPC/1973 dissesse que o inventário sucessivo deveria ser autuado em apenso, a verdade é que a maioria dos juízos organizava o seu trâmite de forma incidental.

Por esse motivo, na hipótese de uma partilha depender da realização de outra partilha, o legislador do CPC/2015 determinou que a tramitação dos inventários cumulados poderá ocorrer em separado ou conjuntamente, conforme melhor convier ao interesse tanto das partes quanto do processo, a teor do parágrafo único do art. 672 do CPC/2015.

Fora da hipótese do inc. III do art. 672, em que existe uma dependência apenas parcial de uma parte em relação à outra, explicitada pelo parágrafo único do mesmo dispositivo. A intenção do legislador foi de que a acumulação superveniente de inventários continue a correr nos mesmos autos do processo de inventário original, como já vem sendo realizado pelo cotidiano forense.⁴⁸³

Art. 673. No caso previsto no art. 672, inciso II, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens.

1. Cumulação superveniente

Assim como faz o art. 1.045⁴⁸⁴ do CPC/1973 o art. 673 do CPC/2015 também estabelece e complementa as regras sobre a cumulação superveniente de inventários.

Enquanto o art. 673 reproduz o *caput* do art. 1.045 do CPC/1973, O legislador do novo Código preferiu retirar a hipótese de liberação da sobrepartilha do inventário do cônjuge sobrevivente em relação aos bens não partilhados no inventário do cônjuge pré-morto, anteriormente prevista no parágrafo único do art. 1.045.

A razão que se pode encontrar para a retirada da disposição no CPC/2015 e a preocupação em desde logo garantir aos demais herdeiros a possibilidade de partilhar os bens do cônjuge pré-morto, enquanto o cônjuge sobrevivente está vivo.

Mesmo assim, nas situações em que o cônjuge sobrevivente vem a falecer não faz sentido a necessidade de um novo procedimento de sobre partilha sobre o prisma dos princípios da celeridade e da economia processual constantes dos arts. 276⁴⁸⁵ e seguintes do CPC/2015, sendo que a sobre partilha sempre pode ir sempre poderá ser realizada se os demais herdeiros tiverem essa iniciativa desde logo, iniciativa essa que nunca foi impedida pelo parágrafo único do art. 1.045 do CPC/1973.

De qualquer forma, as disposições mantidas pelo *caput* do art. 673 são as de que na acumulação superveniente de inventários prevalecerão as informações das primeiras declarações de inventar inicial assim como o respectivo laudo de avaliação, sendo que assumir declarações só não prevalecerão se o laudo de avaliação se alterou o valor dos bens.

1

Em sua clássica obra Tratado de Direito Privado, Pontes de Miranda define o inventário como “*declaração de conhecimento, em que se descreve e enumera ou só se descreve o que se encontrou*” (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*. Atual. por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2011. T. LX. p. 279).

2

A partilha, a seu turno, é conceituada por Pontes de Miranda como a “*a operação processual pela qual a herança passa do estado de comunhão pro indiviso, estabelecido pela morte e pela transmissão por força de lei, ao estado de quotas ou pro diviso, por força de sentença*” (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*. Atual. por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2011. T. LX. p. 321).

3

Nas palavras de Humberto João Carneiro Filho: “*Através do inventário promovem-se o levantamento e a arrecadação de todos os bens e direito do de cujus, a fim de se chegar, pelo balanço, ao conhecimento da sua situação econômica, contemplando-se, inclusive, as obrigações e encargos vinculados àqueles bens. Os resultados apurados no inventário, por sua vez, constituirão o objeto da partilha*” (Humberto João Carneiro Filho, Inventário e Partilha Extrajudiciais no Código de Processo Civil de 2015: O Resultado de um Percurso Histórico-Dogmático. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, Porto Alegre, vol.12, n. 67, p. 59-73, jul./ago. 2015. p. 61).

4

“*Tem o inventariante suma importância em todo o procedimento a ser desenvolvido com a transmissão da herança. É ele quem dirige e organiza o espólio, arrecadando os bens, conservando-os e administrando-os até a entrega de cada porção aos herdeiros*” (Arnaldo Rizzardo, *Direito Das Sucessões*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 619).

5

Até que o inventariante preste compromisso, deve o administrador provisório “*representar ativa e passivamente o espólio, trazendo ao acervo hereditário os frutos que receberá desde a abertura da sucessão, além de responder por eventuais danos que, por dolo ou culpa, vier a causar. Por outro lado fará jus ao reembolso das despesas necessárias e úteis que trouxer ao monte*” (Luiz Paulo Vieira De Carvalho, *Direito Das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 844-850).

6

“*O morto agarra o vivo, é o que diz o famoso adágio francês. Esta é a origem do chamado droit de saisine, ou princípio de saisine, que traduz a própria essência ou fundamento do direito das sucessões, no sentido de que nem mesmo a morte do titular pode interromper ou nulificar o direito de propriedade, pois o domínio e a posse dos bens de alguém imediatamente transmitem-se aos herdeiros, ainda que estes desconheçam esta sua qualidade ou o fato da morte, eis que tal fato ocorre em razão de singela ficção jurídica*” (Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, *Morrer e Suceder*, São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 317).

7

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

8

Maria Berenice Dias assinala que: “São inegáveis as vantagens da adoção do princípio da saisine: evita o estado de acefalia do patrimônio, a jazer sem titular; dispensa a ficção jurídica de emprestar personalidade jurídica ao espólio; propicia a qualquer herdeiro o manejo das ações possessórias.” (Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 107).

9

A este respeito, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart acentuam a imprescindibilidade do procedimento especial em análise ao comentarem: “O procedimento de inventário, portanto, judicial ou extrajudicial, é instituto indispensável para que se possa determinar o destino do patrimônio da pessoa falecida. Sem ele, embora seja certa a sucessão aos herdeiros, não se sabe a quem tocará qual bem ou direito do de cujus” (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 126).

10

O direito à herança é constitucionalmente assegurado pelo inc. XXX do art. 5.º da Carta Magna de 1988. A este respeito, Sueli A. de Pieri pontua que “nas Constituições anteriores não existia a previsão do direito à herança, uma vez que se entendia que este estava implícito no direito de propriedade” (Sueli A. de Pieri, *Inventário Cumulativo No Novo Código De Processo Civil E A Busca Pela Celeridade Processual*. *Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões*, Porto Alegre, vol.2, n. 7, p. 82-99, jul./ago. 2015, p. 85).

11

Acerca da temática polêmica, lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “O inventário constitui medida de jurisdição contenciosa, já que admite plena controvérsia sobre os bens a serem partilhados e sobre a forma de partilha em si. Poderia, porém, ter sido este procedimento colocado entre os procedimentos de jurisdição voluntária, já que o litígio não é essencial à demanda, sendo certo que também nos procedimentos de jurisdição voluntária é possível o surgimento ocasional de lide” (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 127).

12

Caio de Sá Dal’Col e João Roberto de Sá Dal’Col sustentam que o inventário tem natureza contenciosa: “Inicialmente, cumpre esclarecer que o inventário, quando realizado em via judicial, deve ser considerado como de jurisdição contenciosa, e não de jurisdição administrativa. Tal ressalva há de ser feita, uma vez que parcela considerável da doutrina entende, erroneamente, que o processo de inventário carrega ares de voluntariedade. Assim sendo, caso se parta dessa equivocada (a nosso ver) premissa, muitos óbices serão encontrados para que ocorra a partilha dos bens da forma mais célere e igualitária possível. Presente o contraditório, mesmo que apareça em menor grau, o processo deve ser considerado como de jurisdição contenciosa. Portanto, é inegável que no processo de inventário está presente o elemento contraditório, uma

vez que as partes, muitas vezes com interesses divergentes, têm o condão de participar no processo e influenciar na decisão final do juiz, como, por exemplo, no momento de habilitação dos herdeiros, na apuração dos bens, no pagamento de tributos etc” (Caio de Sá Dal’Col; João Roberto de Sá Dal’Col, A (Des)Necessidade da Remessa de “Suposta” Questão de Dependente de Prova às Vias Ordinárias no Processo de Inventário: Uma Análise Sob O Enfoque do Artigo 627 da Redação Final do Novo CPC Aprovada Pela Câmara dos Deputados. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, vol. 62, n. 446, p. 31-44, dez./2014, p. 32-33).

13

Orlando Gomes, por exemplo, acreditava se tratar de procedimento especial de jurisdição contenciosa (Cf.: Orlando Gomes, *Sucessões*. 16. ed. Ver e atual. Por Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 300).

14

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

15

§ 3.º. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inc. III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.

16

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

17

Caio de Sá Dal’Col e João Roberto de Sá Dal’Col realizam sua crítica quanto às questões de alta indagação: *“Em que pese o (...) novo CPC projetado ter excluído a expressão “alta indagação” de sua redação, manteve o comando de que as partes devem ser remetidas para as vias ordinárias quando houver necessidade de produção de provas (provas não documentadas nos autos). Ora, pouco mudou, ou a mudança foi por demais tímida que, a nosso ver, incapaz de causar qualquer avanço no trato da matéria, haja vista que deixa ao arbítrio do juiz decidir quais questões demandam produção de outras provas. E, mesmo sendo ele o juiz competente para a instrução processual, recebe do artigo um comando normativo para se livrar o quanto antes da questão, remetendo-a para as vias ordinárias – mesmo, não custa repetir, sendo o juiz mais indicado para julgar qualquer incidente que surgir, haja vista o seu contato e a sua proximidade com a causa (sem esquecer a sua competência legal para julgá-la). Não faz sentido remeter às vias ordinárias questões que, importantes para o desfecho do inventário e para as partes envolvidas no inventário, ainda que seja*

como incidente processual em autos apartados. Incidente este, releva ponderar, que poderia – em homenagem à economia, celeridade e efetividade processuais e à razoável duração do processo – ser criado por determinação do próprio juiz do inventário. (...) Por oportuno, o magistrado, cuidando do inventário e das questões incidentes, poderia controlar melhor a distribuição do tempo dos processos (inventário e apenso(s)) sem que houvesse prejuízo ao direito material. (...) Com efeito, se o comentado artigo, ao invés de prever que as questões que dependerem de outras provas fossem remetidas para as vias ordinárias, afirmasse que tais questões deveriam ser discutidas em incidente processual apenas, cuja competência de decidir seria do mesmo juiz do inventário, o qual as questões derivam, ajudaria a conceder uma prestação jurisdicional mais eficiente e compatível com o direito das partes envolvidas” (Caio de Sá Dal’Col; João Roberto de Sá Dal’Col, A (Des)Necessidade da Remessa de “Suposta” Questão de Dependente de Prova às Vias Ordinárias no Processo de Inventário: Uma Análise sob o Enfoque do artigo 627 da Redação Final do Novo CPC Aprovada pela Câmara dos Deputados. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, vol.62, n. 446, p. 31-44, dez./2014. p. 38 e 40).

18

Art. 989. O juiz determinará, de ofício, que se inicie o inventário, se nenhuma das pessoas mencionadas nos artigos antecedentes o requerer no prazo legal.

19

Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

20

Art. 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras: I – a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II – a prevenção de litígios futuros; III – a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.

21

Art. 650. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento.

22

A este respeito, Giselle Borges Alves e Thaíza Ribeiro de Faria advertem que: “o modo da sucessão hereditária, com o passar dos anos, só viabilizou as proteções e garantias no que se refere aos sucessores e aos credores” (Giselle Borges Alves; Thaíza Ribeiro de Faria, Os Direitos Dos Credores Diante Do Inventário E Partilha Extrajudicial. *Revista IOB de Direito de Família*, São Paulo, vol. 16, n. 91, p. 97-115, ago./set. 2015, p. 101).

23

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: II – em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

24

Sentença estrangeira contestada. Inventário. Partilha. Imóvel localizado no Brasil. Impossibilidade. Art. 12, § 1.º, da LINDB e do art. 89 do CPC. 1. A partilha de bens imóveis situados no território brasileiro é da competência exclusiva da Justiça pátria, nos termos do art. 12, § 1.º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil) e do art. 89 do CPC. 2. Não é possível a homologação de sentença estrangeira que dispõe sobre partilha de bens na hipótese em que não há acordo na divisão de bem imóvel localizado no Brasil, mas sim determinação da justiça estrangeira da forma como o bem seria partilhado. Precedentes. 3. Pedido de homologação de sentença estrangeira indeferido (STJ, Corte Especial. SEC 9.531/EX, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 19.11.2014).

25

Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I – o foro de situação dos bens imóveis; II – havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III – não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

26

Art. 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União.

27

Bibliografia: Giselle Borges Alves; Thaíza Ribeiro de Faria, Os Direitos dos Credores Diante do Inventário e Partilha Extrajudicial. *Revista IOB de Direito de Família*, São Paulo, vol. 16, n. 91, p. 97-115, ago./set. 2015. Humberto João Carneiro Filho, Inventário e Partilha Extrajudiciais no Código de Processo Civil de 2015: O Resultado de um Percorso Histórico-Dogmático. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, Porto Alegre, vol. 12, n. 67, p. 59-73, jul./ago. 2015. Caio de Sá Dal'Col; João Roberto de Sá Dal'Col. A (Des)Necessidade da Remessa de “Suposta” Questão de Dependente de Prova às Vias Ordinárias no Processo de Inventário: Uma Análise sob o Enfoque do artigo 627 da Redação Final do Novo CPC Aprovada pela Câmara dos Deputados. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, vol. 62, n. 446, p. 31-44, dez./2014.

Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011. Orlando Gomes, *Sucessões*. 16. ed. Ver e atual. Por Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, *Morrer E Suceder*, São Paulo: Ed. RT, 2014. Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012. Sueli A. De Pieri, Inventário Cumulativo no Novo Código de Processo Civil e a Busca pela Celeridade Processual. *Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões*, Porto Alegre, vol. 2, n. 7, p. 82-99, jul./ago. 2015. Francisco Cavalcanti Pontes

de Miranda, *Tratado de Direito Privado*. Atual. por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2011. T. LX. Arnaldo Rizzardo, *Direito das Sucessões*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. Luiz Paulo Vieira De Carvalho, *Direito Das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014.

28

Humberto João Carneiro Filho prega que: “sendo o inventário procedimento de liquidação de herança, a opção do ordenamento de sê-lo judicial ou extrajudicial constitui mais aspecto de política legislativa do que propriamente jurídico” (Humberto João Carneiro Filho, *Inventário E Partilha Extrajudiciais No Código de Processo Civil de 2015: O Resultado De Um Percurso Histórico-Dogmático*. *Revista Magister De Direito Civil E Processual Civil*, Porto Alegre, vol. 12, n. 67, p. 59-73, jul./ago. 2015, p. 63).

29

Luiz Paulo Vieira de Carvalho defende que “mesmo se o de cujus tiver falecido antes da entrada em vigor da referida lei, sem dúvidas, esta pode ser aplicada se presentes os seus requisitos. Há a possibilidade, ainda, de o inventário e partilha judiciais estarem em curso, mas as partes, por atenderem aos pressupostos do procedimento extrajudicial, decidirem desistir do procedimento judicial, obviamente mais demorado e solene, para realizar o ato através de escritura pública.” (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 861).

30

Diante da notória morosidade do Poder Judiciário, observa-se um verdadeiro êxodo dos jurisdicionados às vias extrajudiciais, sendo oportuno salientar que: “sob a égide do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição adotado na sistemática da Constituição de 1988, não se torna necessário o esgotamento da via administrativa para que a matéria seja posta em apreciação pelo Judiciário. Vale dizer: o acesso à justiça é visto como direito fundamental, devendo ser incondicional e pleno.” (Daniel Pinheiro Longa; Andressa Moura dos Santos; Lorena Viana da Motta. Aspectos Práticos dos Cartórios de Títulos e Documentos: Procedimentos de Inventário e Divórcio Extrajudiciais. *Ciência Jurídica*, Belo Horizonte, vol. 29, n. 182, p. 345-363, mar./abr. 2015, p. 347). No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior assinala que “A utilização da via notorial, todavia, não é uma imposição da lei, mas uma faculdade aberta aos sucessores, que, se preferirem, poderão continuar a utilizar o procedimento judicial para obter a homologação do acordo de partilha” (Humberto Theodoro Júnior, *Inventário e Partilha e Separação e Divórcio por Via Administrativa: Reforma da Lei 11.441, de 04.01.2007*. *Revista IOB de Direito de Família*. São Paulo, vol. 9, n. 44, p. 33-47, out./nov. 2007, p. 34). Em contrário senso, convém registrar que parte da jurisprudência pátria dissoa desse entendimento, afirmando que, uma vez que atendidos os requisitos para a lavratura do ato em cartório, ausente se encontra o interesse processual.

31

Humberto Theodoro Júnior salienta que: “Como se passa com as escrituras em geral, o tabelião é responsável pelo controle do recolhimento do imposto de transmissão e pela exigência de comprovantes das quitações tributárias que digam respeito aos bens transmitidos e sem os quais a escritura de inventário e partilha não logrará registro no cartório imobiliário” (Humberto Theodoro Júnior, *Inventário e Partilha e Separação e Divórcio por Via Administrativa: Reforma da Lei 11.441, de 04.01.2007*. *Revista IOB de Direito de Família*. São Paulo, vol. 9, n. 44, p. 33-47, out./nov. 2007, p. 36).

32

Consoante a dicção do art. 9.º da Resolução 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça, é vedado ao tabelião indicar advogado às partes, podendo recomendar-lhes tão somente a Defensoria Pública ou a Seccional da Ordem dos Advogados.

33

A este respeito, Humberto João Carneiro Filho alerta que: *“Em face da especial proteção que se dá às pessoas desde o momento da concepção, inclusive para fins sucessórios, temos não ser possível escriturar o inventário em tabelionato de notas quando a viúva estiver grávida do falecido”* (Humberto João Carneiro Filho, Inventário e Partilha Extrajudiciais no Código de Processo Civil de 2015: O Resultado de um Percurso Histórico-Dogmático. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, Porto Alegre, v. 12, n. 67, p. 59-73, jul./ago. 2015, p. 69).

34

Humberto Theodoro Júnior destaca: *“A sucessão processada administrativamente não é privativa dos nacionais ou dos estrangeiros residentes ou domiciliados no País. Também os que aqui não vivem podem realizar o inventário e partilha dos bens situados no Brasil, desde que o façam perante tabelião brasileiro (...)”*. O mencionado autor ressalva ainda, a concordância com a legislação de regência. (Humberto Theodoro Júnior, Inventário e Partilha e Separação e Divórcio por Via Administrativa: Reforma da Lei 11.441, de 04.01.2007. *Revista IOB de Direito de Família*. São Paulo, v. 9, n. 44, p. 33-47, out./nov. 2007, p. 36).

35

Humberto João Carneiro Filho esclarece acerca da legislação material que: *“A regra do art. 1.785 do Código Civil, que estabelece que a sucessão há de se abrir no último domicílio do falecido, não é aplicável aos inventários extrajudiciais, prevalecendo o art. 8.º da Lei 8.935/1994, podendo o tabelião de notas ser escolhido livremente pelas partes interessadas”* (Humberto João Carneiro Filho, Inventário e Partilha Extrajudiciais no Código de Processo Civil de 2015: O Resultado de um Percurso Histórico-Dogmático. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, Porto Alegre, v. 12, n. 67, p. 59-73, jul./ago. 2015, p. 70).

36

Humberto Theodoro Júnior, com a propriedade habitual, sintetiza: *“Não há lugar para a figura do inventariante no inventário administrativo. Tudo se resolve de plano, no contato direto e imediato entre os interessados, seus advogados e o tabelião. A escolha do tabelião é feita pelas partes e não fica sujeita à vinculação ao último domicílio do de cujus, ao local do óbito, à situação dos bens ou ao domicílio dos sucessores”* (Humberto Theodoro Júnior, Inventário e Partilha e Separação e Divórcio Por Via Administrativa: Reforma da Lei 11.441, de 04.01.2007. *Revista IOB de Direito de Família*. São Paulo, v. 9, n. 44, p. 33-47, out./nov. 2007, p. 36).

37

Insta salientar, ainda, que a existência de inventário extrajudicial repercute em carência de ação por

ausência de interesse de agir, consoante entende o Superior Tribunal de Justiça: Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação de habilitação de crédito. Extinção do processo principal de arrolamento em razão de inventário extrajudicial. Carência da ação. Inércia da recorrente. Revisão de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Súmula 07/STJ. Agravo regimental acolhido para, em juízo de retratação, conhecer do agravo e negar seguimento ao recurso especial por outros fundamentos (STJ, 3.^a T. AgRg no AREsp 194.509/MA, rel. Min. Paulo de Tarso Severino, j. em 10.02.2015, grifo acrescido).

38

Gisele Borges Alves e Thaíza Ribeiro de Faria, citando Trindade e Bossardi, acrescentam importante alerta acerca do inventário extrajudicial: *“Os credores que se habilitam no inventário judicial recebem o total amparo para perceber seu crédito. No entanto, no que diz respeito à garantia dis credores no inventário extrajudicial, a Lei 11.441/2007 deixou de observar as garantias dos credores, tornando inviável o pedido dos credores na habilitação de recebimento de créditos na forma simples. No art. 27 da Resolução 35 do CNJ, há a menção de que a existência de credores do espólio não impedirá a realização de inventário e partilha, mas a resolução deixou obscura a forma como os credores poderão se habilitar no inventário administrativo. (...) Assim, caso os herdeiros conhecedores de débitos do falecido pretendam se esquivar do pagamento das dívidas, o procedimento extrajudicial está aí de alguma forma para ajuda-los, como meio a propiciar a fraude contra eventuais credores, pois além de poder ser processado em qualquer Ofício de Notas do país, os credores terão maior dificuldade em receber os créditos. Ademais, o inventário extrajudicial não goza da ampla publicidade que goza o judicial”*. Tentando solucionar o impasse gerado, sugerem as autoras: *“um dos meios para resguardar os credores seria a revogação do art. 1.^o da Resolução 35 do CNJ, e realizar nos casos concretos a aplicação subsidiária do art. 96 do Código de Processo Civil [1973], trazendo a aplicação da regra de competência para o processamento do inventário extrajudicial da mesma forma como ocorre no judicial, minorando, assim, as chances de ações ardilosas de herdeiros que estejam imbuídos de má-fé. Desta maneira, a restrição da competência tornaria mais acessível aos credores o conhecimento do local da realização do inventário extrajudicial para fins de recebimento seus créditos.”* (Gisele Borges Alves; Thaíza Ribeiro de Faria, Os Direitos dos Credores Diante do Inventário e Partilha Extrajudicial. *Revista IOB de Direito de Família*, São Paulo, v. 16, n. 91, p. 97-115, ago./set. 2015, p. 110-115).

39

Karin Regina Rick Rosa, por sua vez, adverte para outro risco: *“Veja-se, por exemplo, que a liberdade tal qual enunciada pode ensejar o inventário e a partilha em um notário por alguns herdeiros, quando, em outro município (quem sabe do autor da herança), esteja em discussão ação de investigação de paternidade, reconhecimento de união estável ou mesmo inventário judicial requerido pela afirmada companheira-viúva”* (Francisco José Cahali, *Escrituras Públicas: Separação, Divórcio, Inventário E Partilha Consensuais: Análise Civil, Processual Civil, Tributária E Notarial*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 62).

40

Curiosa a observação de Humberto Theodoro Júnior: *“Feita a partilha por ato notarial, não há que se pensar em formal de partilha e tampouco em execução de título judicial. A escritura pública, todavia, retratando obrigação, de entrega de coisa, de forma certa, líquida e exigível, configura, por si só, título executivo. (...) A diferença de efeitos manifesta-se na redução da área de discutibilidade do ato jurídico sucessório, pois, enquanto que na impugnação à execução do título judicial podem-se arguir apenas as poucas matérias que não afetam a coisa julgada, previstas no art. 475-L [CPC/1973], nos embargos à*

execução do título extrajudicial, a impugnabilidade é a mais ampla possível, podendo versar sobre qualquer matéria que seria lícito usar como defesa no processo de conhecimento (CPC, art. 745, V [1973]). Os interessados obtêm, pelo procedimento judicial, um título mais forte que o alcançado pelo ato notarial” (Humberto Theodoro Júnior, Inventário e Partilha e Separação e Divórcio Por Via Administrativa: Reforma da Lei 11.441, de 04.01.2007. *Revista IOB de Direito de Família*. São Paulo, v. 9, n. 44, p. 33-47, out./nov. 2007, p. 37-39).

41

“A base de cálculo das custas do preparo, em inventário, há de ser, efetivamente, o valor dos bens incluídos no monte-mor. A correção monetária faz-se devida, porquanto o valor se expressa em pecúnia, sofrendo, inelutavelmente, a deterioração ocasionada pelo processo inflacionário. Plausível, pois, que se opere a atualização do valor, a fim de que não suceda lesão ao erário”. (Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1483).

42

Art. 6. A gratuidade prevista na Lei 11.441/2007 compreende as escrituras de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais. Art. 7. Para a obtenção da gratuidade de que trata a Lei 11.441/2007, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído.

43

Cassio Scarpinella Bueno acrescenta que uma interpretação ampla da regra insculpida no inc. IX, § 1.º, art. 98, do CPC/2015 é suficiente para albergar a gratuidade dos atos notariais aos hipossuficientes (Cf.: BUENO, Cassio Scarpinella. *Novo Código de Processo Civil anotado*. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 399).

44

No mesmo sentido, Humberto João Carneiro Filho coloca: *“Inobstante o silêncio do CPC/2015 quanto à matéria, isto é, mesmo diante de texto diverso, o contexto da desjudicialização como forma de concretização do acesso à justiça permanece vivo a ponto de não se admitir uma interpretação restritiva da via administrativa, nos termos legais, às pessoas que não dispuserem de recursos para arcarem com as despesas pelos serviços notariais e de registro”* (Humberto João Carneiro Filho, Inventário e Partilha Extrajudiciais no Código de Processo Civil de 2015: O Resultado de um Percorso Histórico-Dogmático. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, Porto Alegre, v. 12, n. 67, p. 59-73, jul./ago. 2015, p. 72).

45

Art. 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concorrendo as partes com o pedido referido no *caput*, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento.

46

Súmula 161. É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao

47

Veja-se um dos precedentes a embasar a referida súmula: conflito de competência. Levantamento dos depósitos do fundo de garantia. Falecimento do titular da conta. Interesse dos herdeiros. Competência do juízo sucessório. Muito embora verse o pedido sobre o fundo de garantia e deve o alvará ser satisfeito pela caixa econômica, empresa pública federal, seja pela ausência de qualquer interesse da caixa, seja por se tratar de juízo sucessório, a competência é da justiça estadual (STJ, 1.^a S. CC 4.142/AL, rel. Min. Hélio Mosimann, j. em 20.04.1993).

48

Acerca dessa modalidade de inventário, assinala Júlio César Ballerini Silva: *“O escopo visado, nesses casos, para justificar a movimentação da máquina judiciária estatal será, justamente, a obtenção de uma declaração de que o extinto não deixou patrimônio a ser transmitido a qualquer herdeiro. Ou seja, satisfaz-se o requisito de reconhecimento de uma tutela meramente declaratória, qual seja, tutela que não possui senão elemento declaração. Basta, portanto, que se demonstre a necessidade e utilidade de se obter essa declaração negativa para que o inventário negativo se consubstancie na tutela adequada para tal finalidade. As hipóteses, portanto, não seriam de interpretação em numerus clausus (restritivas), mas, ao revés, seriam de interpretação em numerus apertus”* (Júlio César Ballerini Silva, *Algumas Questões Acerca do Inventário Negativo de Bens no Direito Brasileiro*. Juris Plenum, Caxias do Sul/RS, v. 9, n. 54, p. 105-114, nov./2013. p. 113).

49

Maria Berenice Dias tece sua crítica acerca do inventário negativo: *“O processo é de jurisdição voluntária e a decisão judicial tem eficácia meramente declaratória da inexistência de bens. Ou seja, o juiz se limita a repetir o que a parte disse, sem qualquer subsídio probatório. Afinal, não dá pra comprovar o que não existe, ou seja, ausência de bens a inventariar. Para isso não deveria ser utilizada a atividade jurisdicional”* (Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 535). Júlio César Ballerini Silva, por sua vez, entende que: *“(…) sob o prisma prático, muitas vezes surge a necessidade de disciplina dessas relações entre de cujus sucessiones agitur e seus herdeiros, mesmo não havendo patrimônio a ser partilhado, não podendo o Direito permanecer alheio a tais situações, ainda mais porque o advento da norma contida no art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal permite a qualquer pessoa residente ou domiciliada no território nacional demandar em casos de lesão ou ameaça de lesão a seus direitos”* (Júlio César Ballerini Silva, *Algumas Questões Acerca do Inventário Negativo de Bens no Direito Brasileiro*. Juris Plenum, Caxias do Sul/RS, v. 9, n.54, p. 105-114, nov./2013. p. 109).

50

Insta pontuar que: *“A omissão legal quanto à permissão de inventário negativo através de escritura pública permaneceu no CPC/2015, lacuna que merecia ser suprida pela via legal. A Resolução 35/2007 do CNJ, em interpretação sistemática, contempla no art. 28 a admissão dessa modalidade de inventário, no qual nada há para se partilhar e que tem por escopo a produção de provas de que o herdeiro nada herdou do finado”*. (Humberto João Carneiro Filho, *Inventário e Partilha Extrajudiciais No Código de Processo Civil de 2015: O Resultado de um Percorso Histórico-Dogmático*. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, Porto

51

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.

52

Art. 1.523. Não devem casar: I – o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros.

53

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I – das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento.

54

Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.

§ 1.º. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

55

“De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada – seja ela a demanda principal (veiculada na petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental. O art. 4.º, de modo bem assertivo, garante à parte o direito à solução integral do mérito” (Fredie Didier Jr., *Curso de Direito Processual Civil*, 17. ed, Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 136).

56

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

57

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

58

Art. 657. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário

ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4.º do art. 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 (um) ano, contado esse prazo: I – no caso de coação, do dia em que ela cessou; II – no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato; III – quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade.

59

Art. 2.º. É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial.

60

Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros: I – requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem; II – declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III – atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha.

61

Bibliografia: Giselle Borges Alves; Thaíza Ribeiro de Faria, os Direitos dos Credores Diante do Inventário e Partilha Extrajudicial. *Revista IOB de Direito de Família*, São Paulo, v. 16, n. 91, p. 97-115, ago./set. 2015. Cassio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil Anotado*. São Paulo: Saraiva, 2015. Francisco José Cahali, *Escrituras Públicas: Separação, Divórcio, Inventário e Partilha Consensuais: Análise Civil, Processual Civil, Tributária e Notarial*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2008. Humberto João Carneiro Filho, Inventário e Partilha Extrajudiciais no Código de Processo Civil de 2015: O Resultado de um Percorso Histórico-Dogmático. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, Porto Alegre, v. 12, n. 67, p. 59-73, jul./ago. 2015. Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011. Fredie Didier Jr., *Curso de Direito Processual Civil*, 17. ed, Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. Daniel Pinheiro Longa; Andressa Moura dos Santos; Lorena Viana da Motta, Aspectos práticos dos cartórios de títulos e documentos: procedimentos de inventário e divórcio extrajudiciais. *Ciência Jurídica*, Belo Horizonte, v. 29, n.182, p. 345-363, mar./abr. 2015, p. 347. Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. Júlio César Ballerini Silva, *Algumas Questões Acerca Do Inventário Negativo De Bens No Direito Brasileiro*. Juris Plenum, Caxias do Sul/RS, v. 9, n. 54, p. 105-114, nov./2013. Humberto Theodoro Júnior, Inventário e Partilha e Separação e Divórcio por Via Administrativa: Reforma da Lei 11.441, de 04.01.2007. *Revista IOB de Direito de Família*. São Paulo, v. 9, n. 44, p. 33-47, out./nov. 2007, p. 34. Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014.

62

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka alerta que: “a condição de legitimados a suceder é aferida no momento da abertura da sucessão, visto que nem mesmo lei posterior ao falecimento do autor da herança poderá afastar aquele que se encontrasse, naquele momento, legitimado a herdar” (Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, *Morrer e Suceder*. São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 320).

63

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart assinalam que: “A fixação desses prazos tem em vista a necessidade de rápida individualização da atribuição dos bens da sucessão – a par de permitir a pronta satisfação dos interesses da Fazenda Pública no recebimento do imposto causa mortis a que faz jus” (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 127).

64

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

65

Maria Berenice Dias ressalta que “O fato gerador não é a morte, mas a transmissão do acervo sucessório em face da morte do titular dos bens. (...) Quando da morte do titular da herança, ocorrem tantos fatos geradores quanto são os herdeiros ou legatários (CTN 35 parágrafo único). O encargo pelo pagamento do imposto não é do espólio nem do inventariante. A responsabilidade pelo pagamento do imposto é de cada um dos herdeiros sobre o quinhão recebido” (Maria Berenice Dias. *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 627).

66

Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como sanção pelo retardamento do início ou da ulatimação do inventário (Enunciado 542 do STF).

67

Art. 989. O juiz determinará, de ofício, que se inicie o inventário, se nenhuma das pessoas mencionadas nos artigos antecedentes o requerer no prazo legal.

68

Art. 983. O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 (sessenta) dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos, de ofício ou a requerimento de parte.

69

Impende ressalvar, contudo, que já no CPC de 1973 podia o magistrado prorrogar determinados prazos à requerimento do inventariante quando esse apresentar-lhe motivo justo, pelo qual “*entende-se o evento imprevisível, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato, por si ou através de mandatário*” (Antônio Ferreira Inocência, *Inventários E Partilhas: Ações De Herança*. 2. ed., São Paulo: Editora Jalovi Ltda, 1980, p. 17).

70

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: II – se não der ao inventário

andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

71

Humberto João Carneiro Filho sintetiza: “Ao juízo do inventário são levados aspectos sucessórios de direito e também de fato, desde que estes se achem comprovados por documentos, remetendo-se para as vias ordinárias questões que dependam de outras provas” (Humberto João Carneiro Filho, *Inventário e Partilha Extrajudiciais no Código de Processo Civil de 2015: O Resultado de um Percurso Histórico-Dogmático*. Revista *Magister de Direito Civil e Processual Civil*, Porto Alegre, v. 12, n. 67, p. 59-73, jul./ago. 2015, p. 65).

72

Caio de Sá Dal’Col e João Roberto de Sá Dal’Col tecem sua crítica: “Com muito mais razão, referidas questões deveriam ser decididas pelo próprio juiz do inventário – mais próximo dos fatos –, ainda que, por razões instrumentais e organizacionais, em autos apartados. (...) Considerando que o juiz do inventário seja competente para o julgamento das questões a serem enviadas para as vias ordinárias, assim como é o que já teve contato com aquele caso particular e, por conseguinte, o que possui a maior proximidade com a causa e suas respectivas peculiaridades, não se justifica o envio de qualquer questão incidente para ser processada e julgada por outro juiz” (Caio de Sá Dal’Col; João Roberto de Sá Dal’Col, A (Des)Necessidade da Remessa de ‘Suposta’ Questão de Dependente de Prova às Vias Ordinárias no Processo de Inventário: Uma Análise sob o Enfoque do artigo 627 da Redação Final do Novo CPC Aprovada pela Câmara dos Deputados. Revista *Jurídica*, Porto Alegre, v. 62, n. 446, p. 31-44, dez./2014. p. 34-36).

73

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II – se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III – se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

74

Orlando Gomes exemplifica enquanto questões de alta indagação: “questões a respeito da nulidade do testamento, da doação, da partilha em vida, da deserdação, da indignidade, do reconhecimento de filho, de sonegados, da venda de ascendente a descendente, entre outras” (Orlando Gomes, *Sucessões*. 16. ed. Ver e atual. Por Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 302).

75

Direito civil. Inventário. Doação em vida. Art. 1.776, CC/1916. Possibilidade de prejuízo da legítima. Arguição por um dos herdeiros. Questão de alta indagação. Inexistência. Discussão na sede do inventário. Recurso desacolhido. I – Na linha da doutrina e da jurisprudência desta Corte, questões de direito, mesmo intrincadas, e questões de fato documentadas resolvem-se no juízo do inventário e não na via ordinária. II – Eventual prejuízo da legítima em face de doação feita pelo pai aos filhos, ainda em vida (art. 1.776, CC/1916), sem haver fatos a provar, prescinde dos “meios ordinários”, podendo ser discutido no próprio

76

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart salientam que: “*entende-se por questão de alta indagação não aquela que seja complexa do ponto de vista da interpretação do direito, mas aquela que exige debate e interpretação próprios, que extrapolariam os limites do inventário*” (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 128).

77

Art. 984. O juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.

78

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

79

Caio de Sá Dal’Col e João Roberto de Sá Dal’Col defendem que: “*Nesse passo, não se deve olvidar que, em uma visão constitucional – adotada pelo projeto do novo Código de Processo Civil –, pode-se dizer que até o terceiro que anteriormente não fazia parte do processo de inventário poderá ser demandado neste incidente processual apartado, desde, é claro, que seja regularmente citado para participar do feito. Desta forma, ao mesmo tempo em que se respeitará o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, também será homenageada a efetividade processual, de modo que não haja dilações indevidas*” (Caio de Sá Dal’Col; João Roberto de Sá Dal’Col, A (Des)Necessidade da Remessa de “Suposta” Questão de Dependente de Prova às Vias Ordinárias no Processo de Inventário: Uma Análise sob o Enfoque do art. 627 da Redação Final do Novo CPC Aprovada pela Câmara dos Deputados. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, v. 62, n. 446, p. 31-44, dez./2014. p. 38-39).

80

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

81

Processo civil. Separação consensual. Posterior inventário e partilha. Subsequente ajuizamento de ação declaratória de sub-rogação de bens herdados. Litispendência. Existência. Alta indagação. Questão estranha ao processo. Litigância de má-fé que não pode ser presumida. – O art. 1.121, § 1.º, do CPC remete os cônjuges ao procedimento de inventário e partilha, que seguirá o rito dos arts. 982 e ss. do CPC, com as adaptações que se fizerem necessárias. Não se trata, portanto, de apenas partilhar o patrimônio comum,

mas, antes de tudo, de saber quais bens o compõem. – Iniciado o inventário, torna-se desnecessário o ajuizamento de ação declaratória na qual buscam identificar os bens que se sub-rogaram nos herdados e não comunicáveis. Deve-se reconhecer a identidade de pedidos, de partes e de causa de pedir entre os dois processos. – Cabe ao juiz do inventário indicar as questões de alta indagação que não podem ser resolvidas naquele processo. – Havendo dúvida sobre as causas que levaram a parte a adotar comportamento contraditório no curso do processo, não se deve presumir a existência de má-fé. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, 3.^a T. REsp 960.885/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 17.03.2009).

82

Em virtude do referido princípio “*a transmissão, num primeiro momento, aplicada como uma ficção jurídica, garante a continuidade do patrimônio do falecido e maior segurança aos herdeiros até que se efetive a partilha*” (Sueli A. De Pieri, Inventário Cumulativo no Novo Código de Processo Civil e a Busca pela Celeridade Processual. *Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões*, Porto Alegre, v. 2, n. 7, p. 82-99, jul./ago. 2015, p. 87).

83

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

84

“*É quem se acha legitimamente na posse da herança no momento da abertura da sucessão. Compete-lhe prosseguir no encargo e gerir os bens deixados pelo de cujus até que se instaure o processo de inventário e se compromisse o inventariante*” (Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 525).

85

Processo civil. Morte de uma das partes. Substituição processual.

Espólio. Representação pelo administrador provisório. Possibilidade. Inexistência de inventariante. Suspensão do feito. Desnecessidade. Nulidade processual. Inocorrência. Recurso parcialmente provido. 1. Não há a configuração de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 do CPC. 2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada

pessoalmente das praças do imóvel. 5. Recurso especial parcialmente provido (STJ, 3.^a T. REsp 777.566/RS, rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), j. em 27/04/2010).

86

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II – ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III – ao testamenteiro; IV – a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

88

Bibliografia: Humberto João Carneiro Filho, *Inventário e Partilha Extrajudiciais no Código de Processo Civil de 2015: O Resultado de um Percurso Histórico-Dogmático*. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, Porto Alegre, v. 12, n. 67, p. 59-73, jul./ago. 2015. Caio de Sá Dal'Col; João Roberto de Sá Dal'Col, a (Des)Necessidade da Remessa de “Suposta” Questão de Dependente de Prova às Vias Ordinárias no Processo de Inventário: Uma Análise sob o Enfoque do art. 627 da Redação Final do Novo CPC Aprovada pela Câmara dos Deputados. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, v. 62, n. 446, p. 31-44, dez./2014. Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011.

Orlando Gomes, *Sucessões*. 16. ed. Ver e atual. Por Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, *Morrer e Suceder*, São Paulo: Ed. RT, 2014. Antônio Ferreira Inocêncio, *Inventários e Partilhas: Ações de Herança*. 2. ed., São Paulo: Editora Jalovi Ltda, 1980. Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012. Sueli A. De Pieri, *Inventário Cumulativo no Novo Código de Processo Civil e a Busca pela Celeridade Processual*. *Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões*, Porto Alegre, v. 2, n. 7, p. 82-99, jul./ago. 2015.

89

Art. 986. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

90

Art. 618. Incumbe ao inventariante: I – representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1.º; II – administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III – prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV – exhibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V – juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI – trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII – prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII – requerer a declaração de insolvência.

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I – alienar bens de qualquer espécie; II – transigir em juízo ou fora dele; III – pagar dívidas do espólio; IV – fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Processual civil. Recurso especial. Execução fiscal. Dissolução irregular da pessoa jurídica. Pedido de redirecionamento formulado contra os herdeiros do sócio-gerente. 1. Conforme orientação desta Corte, é viável o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade, pois tal circunstância acarreta, em tese, a responsabilidade subsidiária dos sócios, que poderá eventualmente ser afastada em sede de embargos à execução. 2. Contudo, no caso dos autos, a Fazenda Nacional requer o redirecionamento do processo executivo fiscal para os herdeiros do representante legal da empresa executada. 3. Nos termos do art. 4.º, III, da Lei 6.830/1980, “a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio”. “O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário” (Cesar Fiuza, “Direito civil: curso completo”, 10. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexistente inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, “até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório”, de modo que este “representa ativa e passivamente o espólio” (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4.º, VI, da Lei 6.830/1980 (“a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título”), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), “cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube” (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no pólo passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de novo pedido de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido (STJ, REsp 877.359/PR, 1.ª T. Rel, Min Denise Arruda, *DJe* 12.05.2008).

Mandado de segurança. Militar. Anistia política. Direito líquido e certo decorrente do próprio ato de concessão. Pagamento retroativo aos herdeiros. Legitimidade do espólio. Ordem concedida. Precedentes. 1. – A jurisprudência desta Corte admite a legitimidade dos herdeiros para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido antes mesmo de inaugurado o inventário. Precedentes. 2. – O ato impugnado no presente mandamus é a omissão do Poder Público em pagar o que é devido. Por outras palavras: à autoridade coatora é imputada ilegalidade por não praticar ato de sua competência. Assim, não há evento

algun que se preste como marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias de que trata o art. 23 da Lei 12.016/2009, de modo que também não há a incidência da referida norma. Descabe, portanto, falar em decadência do direito à impetração. 3. – Enquanto não anulada a portaria concessória de anistia, permanece incólume a obrigação de pagar as parcelas indenizatórias retroativas, imposta ao Ministério da Defesa por força do disposto no art. 18, parágrafo único, da Lei 10.559/2002. 4. – A questão orçamentária não é obstáculo para a concessão da ordem, ante as sucessivas Leis anuais (11.451/2007; 11.647/2008; 11.897/2009; 12.214/2010 e outras) que reservaram verbas para o pagamento de indenizações retroativas em favor de anistiados políticos. Ademais, se eventualmente provada a falta de dotação orçamentária, cabe a execução contra a Fazenda Pública, por meio do competente precatório. 5. – O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar a obrigação da Administração em face do direito líquido e certo do espólio impetrante. Precedentes. 6. – A tese de inadequação da via eleita não encontra eco na jurisprudência desta Corte, que por diversas vezes tem afirmado ser o mandado de segurança ação adequada para combater omissão consistente na falta de pagamento dos valores retroativos devidos aos anistiados políticos. Ademais, como interpreta o próprio Supremo Tribunal Federal, quando se trata de valores dessa natureza, não se está diante de simples ação de cobrança, mas de cumprimento de obrigação de fazer, de onde não se aplicar ao caso a Súmula 269 daquela Corte. 7. – As Notas AGU/D-10/2003 e 1/2006 deram origem à determinação para revisão das portarias de concessão de anistia, levada a efeito por força da Portaria Interministerial 134, de 15 de fevereiro de 2011, mas não excluem a obrigação da autoridade impetrada. Quanto à referência à suspensão de pagamentos imposta pelo acórdão 2891/2008-Plenário, do Tribunal de Contas da União, trata-se de decisão revogada pela própria Corte de Contas, de modo que não é mais eficaz. Precedentes deste STJ. 8. – Nos termos do art. 18, parágrafo único, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, a reparação econômica deveria ser feita no prazo de sessenta dias após a comunicação do Ministério da Justiça, o que ainda não ocorreu quanto aos valores retroativos, objeto do presente mandado. Logo, não observando o prazo legal, a Administração constituiu-se em mora, pelo que também são devidos juros e correção monetária, a partir do sexagésimo primeiro dia, conforme precedentes desta Corte. 9. – A simples leitura da Portaria MJ 2.050, de 3 de dezembro de 2003, publicada no DOU de 4 de Dezembro de 2003, é suficiente para demonstrar que o espólio impetrante é credor da importância lá estipulada e, portanto, titular do direito líquido e certo de recebê-la, o que, somado à rejeição integral dos argumentos apresentados pela União e pela autoridade impetrada, impõe a concessão da ordem. 10. – Mandado de segurança concedido (STJ, MS 20.365/DF, 1.^a Seção, rel. Min Sérgio Kukina, j. 09.04.2014).

95

Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso especial. Dano moral. Falecimento do titular. Ajuizamento de ação indenizatória. Transmissibilidade do direito. Entendimento jurisprudencial consolidado. Súmula 168/STJ. A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. Incidência da Súmula 168/STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDiv em REsp 978.651/SP, Corte Especial, rel. Min. Félix Fischer, j. 15.12.2010).

96

“O arrolamento é o procedimento de inventário com a redução de atos, solenidades e prazos, exigindo-se, para tanto, que todos os herdeiros sejam maiores e capazes e celebrem a partilha amigável a ser

homologada pelo juízo mediante a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (...) O procedimento de inventário sob a forma de arrolamento comum ou simples exige como condição que os bens do espólio apresentem valor igual ou inferior a 2.000 (duas mil) OTNS's” (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 844-846).

97

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

98

No mesmo sentido, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, citando Mário Roberto de Carvalho Faria, defende a legitimidade “*de qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica, que esteja administrando os bens da herança*” (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 849).

99

Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.

100

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: V – o cessionário do herdeiro ou do legatário;

101

Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV – o pedido com as suas especificações; V – o valor da causa; VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1.º. Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2.º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3.º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

102

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança.

103

Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1.º. É lícito, porém, formular pedido genérico:

I – nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados.

104

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

105

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I – na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI – na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII – na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII – na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1.º. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2.º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3.º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

106

Art. 319. A petição inicial indicará: V – o valor da causa.

107

Processual civil. Recurso especial. Inventário. Valor da causa. – No processo de inventário, o valor da causa corresponde ao do monte-mor. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp 459.852/SP 3.ª T. Rel Min. Nancy Andrigli, *Dju* de 29.09.2003)

108

Bibliografia: Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014.

109

“A legitimidade concorrente para a abertura do inventário, porém, não se reflete nas sanções pela

desobediência ao prazo (...). A multa eventualmente incidente é de exclusiva responsabilidade daquele que esteja na posse e administração dos bens, não se estendendo aos outros colegitimados” (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 129).

110

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II – se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III – se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

111

Processo civil. Ministério Público. Custos legis. Inventário. Qualidade de parte. Incapaz. Competência relativa. Legitimidade do MP para arguir exceção de incompetência. – O Ministério Público, quando atua no processo como custos legis, o que acontece em inventário no qual haja menor interessado, em legitimidade para arguir a incompetência relativa do juízo. Para tanto, deve demonstrar prejuízo para o incapaz. Não demonstrado o prejuízo tal legitimidade não se manifesta (STJ, REsp 630.968/DF, 3.ª T. rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.03.2007).

112

Competência estadual atribuída pela Constituição Federal (art. 155, § 1.º, III).

113

Art. 989. O juiz determinará, de ofício, que se inicie o inventário, se nenhuma das pessoas mencionadas nos artigos antecedentes o requerer no prazo legal.

114

Bibliografia: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

115

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.

116

Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Art. 160. Por seu trabalho o

depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.

117

Art. 618. Incumbe ao inventariante: I – representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1.º; II – administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III – prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV – exhibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V – juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI – trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII – prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII – requerer a declaração de insolvência.

118

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I – alienar bens de qualquer espécie; II – transigir em juízo ou fora dele; III – pagar dívidas do espólio; IV – fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

119

Art. 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no art. 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças: I – termo de inventariante e título de herdeiros; II – avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro; III – pagamento do quinhão hereditário; IV – quitação dos impostos; V – sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 (cinco) vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado.

120

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1.º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta

àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2.º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3.º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

121

Já a do causídico, por sua vez, o é, sendo válido referendar o entendimento de Maria Berenice Dias, que defende que os honorários advocatícios constituem encargo do espólio, e não do inventariante. Veja-se: *“Como é indispensável a atuação de advogado no inventário judicial, seus honorários são encargo do espólio, mesmo que os herdeiros tenham procuradores. Somente na hipótese de o advogado não atuar em prol da sucessão, mas exclusivamente atentando aos interesses do inventariante, é exclusivamente deste o ônus pelo pagamento dos seus honorários”* (Maria Berenice Dias, Manual das Sucessões, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 547). Cumpre referendar, contudo, que há entendimento doutrinário em sentido contrário.

122

Art. 990. O juiz nomeará inventariante: (Vide Lei 12.195, de 2010) I – o cônjuge sobrevivente casado sob o regime de comunhão, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; (Redação dada pela Lei 12.195, de 2010) Vigência II – o herdeiro que se achar na posse e administração do espólio, se não houver cônjuge supérstite ou este não puder ser nomeado; II – o herdeiro que se achar na posse e administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou estes não puderem ser nomeados; (Redação dada pela Lei 12.195, de 2010) Vigência III – qualquer herdeiro, nenhum estando na posse e administração do espólio; IV – o testamenteiro, se lhe foi confiada a administração do espólio ou toda a herança estiver distribuída em legados; V – o inventariante judicial, se houver; VI – pessoa estranha idônea, onde não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo.

123

Direito processual civil. Sucessões. Recurso especial. Nomeação de inventariante. Regra do art. 990 do CPC. Caráter não absoluto. Convicção do Juízo formada a partir dos elementos fáticos do processo. Vedado o reexame na via especial. – A ordem de nomeação de inventariante, prevista no art. 990 do CPC, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação de fato excepcional, quando tiver o Juiz fundadas razões para tanto, forte na existência de patente litigiosidade entre as partes. Evita-se, dessa forma, tumultos processuais desnecessários. – Se o Tribunal de origem atesta a ocorrência de situação de fato excepcional consubstanciada na existência de animosidade entre as partes, admite-se o temperamento da ordem legal de nomeação de inventariança, conforme firme convicção do Juiz que repousa na ponderada análise dos elementos fáticos do processo. – Esquadrinhar o convencimento motivado do Juízo calcado em circunstâncias fáticas constantes dos autos é procedimento vedado na via especial. Recurso especial não conhecido (STJ, REsp 1.055.633/SP, 3.ª Turma, rel. Min Nancy Andrighi, Dje 16.06.2009).

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart sintetizam a petição de primeiras declarações como “*a petição que inicia os procedimentos para a descrição do patrimônio e a identificação dos herdeiros do falecido. A sua finalidade é dar um esboço inicial da situação patrimonial do de cujus e dos sucessores e as dívidas por aquele deixados, a fim de que os interessados possam apurar eventuais omissões ou defeitos nesse panorama primeiro*”. (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 133).

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II – ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III – ao testamenteiro; IV – a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

Restou vencido, portanto, o seguinte entendimento jurisprudencial do STJ: “Herdeiro menor ou incapaz não pode ser nomeado inventariante, pois é impossibilitado de praticar ou receber diretamente atos processuais; sendo que para os quais não é possível o suprimento da incapacidade, uma vez que a função de inventariante é personalíssima” (REsp 658.831/RS, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006).

“*Por vezes, o estado de dissensão entre os herdeiros, o cônjuge supérstite e demais interessados na herança, é tão grande que desaconselha a obediência à ordem, podendo o juiz, em casos extremos e para evitar maiores problemas futuros com coisas da herança nomear um estranho (...)*” (Silvio Salvo Venosa, *Direito Civil: Direito Das Sucessões*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 51).

Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011. Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012. VENOSA, Silvio Salvo. *Direito civil: direito das sucessões*. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2003.

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: I – o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança,

o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento; II – o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável; III – a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado; IV – a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam; b) os móveis, com os sinais característicos; c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos; d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância; e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data; f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores; g) direitos e ações; h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio. § 1.º. O juiz determinará que se proceda: I – ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual; II – à apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. § 2.º. As declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, à qual o termo se reportará.

131

Art. 991. Incumbe ao inventariante: I – representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 12, § 1.º; II – administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência como se seus fossem; III – prestar as primeiras e últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV – exhibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V – juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI – trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII – prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII – requerer a declaração de insolvência (art. 748).

132

Art. 993. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, fará o inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado. No termo, assinado pelo juiz, escrivão e inventariante, serão exarados: (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º. 10.1973). I – o nome, estado, idade e domicílio do autor da herança, dia e lugar em que faleceu e bem ainda se deixou testamento; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º. 10.1973) II – o nome, estado, idade e residência dos herdeiros e, havendo cônjuge supérstite, o regime de bens do casamento; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973). III – a qualidade dos herdeiros e o grau de seu parentesco com o inventariado; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973). IV – a relação completa e individuada de todos os bens do espólio e dos alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973) a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das transcrições aquisitivas e ônus que os gravam; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973). b) os móveis, com os sinais característicos; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973).c) os semoventes, seu número, espécies, marcas e sinais distintivos; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973) d) o dinheiro, as jóias, os objetos de ouro e prata, e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973). e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, cotas e títulos de sociedade,

mencionando-se-lhes o número, o valor e a data; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973). f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, títulos, origem da obrigação, bem como os nomes dos credores e dos devedores; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973). g) direitos e ações; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973). h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio. (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973). Parágrafo único. O juiz determinará que se proceda: (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973) I – ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era comerciante em nome individual; (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973); II – a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973)

133

Agravo de instrumento – Pedido de remoção de inventariante – Indícios de conduta omissa ao regular andamento do processo – Acolhimento – Responsabilidade da inventariante em razão do munus da inventariança – Recurso desprovido. 1. Pois bem, de acordo com o art. 991 do Código de Processo Civil, ao inventariante, no exercício do múnus da inventariança, incumbe dentre outras coisas, a representação do espólio, em juízo ou fora dele, bem como a responsabilidade pela administração dos bens do espólio, devendo zelar pelos bens como se fossem seus, prestando contas de sua administração. 2. Apresentando os agravados motivos plausíveis para requererem a remoção da inventariante, mostra-se possível a sua remoção, cumprindo observar que as hipóteses de remoção do inventariante não se limitam a do art. 995 do Código de Processo Civil. (TJPR, AI 344571, rel Des. Costa Barros, j. 23.08.2006).

134

Recurso especial – Inventário – Incidente de prestação de contas do inventariante – Decisão de primeiro grau que julgou boa as contas apresentadas, remetendo parte delas para as vias ordinárias – *Decisum* confirmado pelo tribunal de origem – Possibilidade de cisão da prestação de contas do inventariante – Remessa às vias ordinárias de questões de alta indagação – Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (...) 4. Embora o art. 919 do CPC diga que as contas do inventariante serão prestadas em apenso aos atos do inventário, tal regra não se mostra suficiente para impedir o fracionamento da prestação de contas, quando houver questão de alta indagação a ser solucionada. Dessa forma, o referido dispositivo deve ter sua leitura conjugada com o preceito normativo do art. 984 do Código de Processo Civil, pois este artigo, além de inserido em tópico destinado a tratar do inventário e da partilha, encerra preceito norteador de todos os incidentes submetidos ao juízo inventariante, qual seja: a celeridade (REsp 1.111.301/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. em 08.10.2013).

135

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: § 1.º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.

136

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

Recurso especial – Ação reivindicatória – Tutela de bem deixado pelo de cujus – Partilha ainda não verificada – Coerdeiro – Legitimidade ativa reconhecida – Recurso especial provido. 1. Sendo a herança uma universalidade, é de rigor reconhecer-se que sobre ela os herdeiros detêm frações ideais não individualizadas, pois, até a partilha. 2. Aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (art. 1791, parágrafo único, do Código Civil). 3. Tal como ocorre em relação a um condômino, ao coerdeiro é dada a legitimidade ad causam para reivindicar, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais coerdeiros, a coisa comum que esteja indevidamente em poder de terceiro, nos moldes no art. 1314 da lei civil. 4. O disposto no art. 12, V, do Código de Processo Civil não exclui, nas hipóteses em que ainda não se verificou a partilha, a legitimidade de cada herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos a título de herança, porquanto, *in casu*, trata-se de legitimação concorrente. 5. Recurso especial provido.

“O instituto da colação tem por objetivo igualar a legítima, trazendo à partilha os bens ausentes ao acervo. Curial dizer-se que, em ciclo inflacionário, na conferência, se o bem doado já fora vendido antes da abertura da sucessão, seu valor há de ser atualizado na data desta, eis que a correção monetária tem por objetivo precípua elevar o valor nominal da moeda ao seu nível real”. (Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1483).

Bibliografia: Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

Recurso especial. Processual civil. Inventário. Venda de bem do espólio. Necessidade de oitiva prévia dos interessados. Objeção injustificada. Alienação autorizada. Interesses antagônicos dos herdeiros. Procuradores diferentes. Honorários de advogado. Pagamento pelo espólio. Impossibilidade. 1. Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas. 2. Existindo herdeiros

com interesses antagônicos, cada qual responde pelos honorários do seu advogado. 3. Recurso especial provido em parte (STJ, REsp 972.283/SP, 4.^a Turma, rel. Min. João Otávio Noronha, j. 07.04.2011, *Dje* 15.04.2011).

143

Art. 759. É lícito ao devedor ou ao seu espólio, a todo tempo, requerer a declaração de insolvência.

144

Agravo de instrumento Inventário solicitação da lavratura do termo de primeiras declarações/circunstanciado pelo Ministério Público pedido indeferido, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas procedimento determinado pelo art. 993 do CPC exigência legal expressa - Ausência de prejuízo à tutela do direito material ou celeridade e ao formalismo - recurso provido. Havendo expressa ordem legal a exigir a lavratura de termo circunstanciado das primeiras declarações, sua observância é obrigatória, devendo, portanto, ser reformada a decisão combatida (TJPR, Agravo de Instrumento 684152-1, 12.^a Câmara Cível, rel. Des. Costa Barros, j. 27.04.2011).

145

Segundo a qual: “Na apuração de haveres não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou”.

146

Processual civil. Recurso especial. Violação ao art. 535 do CPC. Não configurada. Inventário. Art. 993, parágrafo único, II, do CPC. Apuração de haveres. Inadequação da via, *in casu*. Existência de controvérsia entre o sócio remanescente e os demais herdeiros acerca da dissolução de sociedade limitada. Questão de alta indagação. Art. 984 do CPC. Remessa da questão às vias ordinárias. Possibilidade. 1. A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisor não se traduz em ofensa ao art. 535 do CPC. (STJ, REsp 289151/SP, 3.^a Turma, rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina, *Dje* 25.10.2010). 2. A ofensa ao art. 535 do CPC somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. O parágrafo único do art. 993 do CPC dispõe sobre as medidas postas ao alcance do julgador, que devem suceder às primeiras declarações do inventariante, em processo de inventário no qual era, o autor da herança, comerciante em nome individual ou sócio de sociedade que não anônima. Autoriza, assim, o inciso II do parágrafo único do referido dispositivo que, dentro do próprio processo de inventário, se proceda a apuração de haveres do falecido por sua participação, por exemplo, em sociedades civis e comerciais por cotas de responsabilidade limitada. Nesses casos, cumpre ao juiz da causa nomear contador (perito) para que realize referida apuração (CPC, art. 1003, parágrafo único). 4. Inexiste óbice, porém, a que o julgador remeta a apuração de haveres às vias ordinárias, na forma dos arts. 655 a 674 do CPC de 1939, a teor do que dispõe o art. 1.218, VII, do vigente diploma processual, quando questões relativas à dissolução da sociedade se apresentem como objeto de controvérsia entre sócios remanescentes e espólio ou herdeiros, máxime se estas se revelam de alta indagação (CPC, art. 984) 5. Na hipótese, entendendo o julgador que a apuração de haveres, nos moldes em que pretendida pelo ora recorrente, revela controvérsia existente entre ele (sócio-remanescente) e os demais herdeiros acerca da dissolução da sociedade, configurando,

ainda, questão de alta indagação, não há falar, in casu, em ofensa ao art. 993, parágrafo único, inc. II, do CPC, mesmo porque a revisão das referidas conclusões demandaria incursão deste Sodalício no conjunto fático probatório carreado aos autos, labor que, como de sabença, se encontra proscrito, na via especial, ao Superior Tribunal de Justiça (Súmula 07/STJ). 6. Recurso especial a que se nega provimento (STJ, REsp 289151/SP, 3.ª Turma, rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina, Dje 25.10.2010).

147

“Sonegação é a ocultação intencional da existência de bens que devem ser descritos no inventário ou levados à colação. Há, por conseguinte, duas modalidades de sonegação: a que se dá quando o herdeiro, ou o inventariante, oculta bens dolosamente, e a que ocorre quando não traz ao inventário bem recebido como adiantamento de legítima para conferi-los” (Orlando Gomes, *Sucessões*. 16. ed. Ver e atual. Por Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 300).

148

“Ocorre sonegação quando se verifica a ocultação maliciosa de bens do espólio, seja por ato do inventariante – que deixa de arrolar certos bens para o inventário –, seja por ato do herdeiro, que deixa de trazer à colação bens que estariam sujeitos a esse regime ou deixa de trazer aquele que, embora pertencentes ao espólio, estão em seu poder ou no de outrem (com o seu conhecimento)” (Luiz Guilherme, Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 137).

149

Art. 1.996. Só se pode arguir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui.

150

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: VI – se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

151

Art. 1.993. Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos bens, quando indicados.

152

Art. 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras.

153

Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou

que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

154

Direito civil. Ação de sonegados. Últimas declarações. Inventariante. Declaração de não haver outros bens a inventariar.

Inexistência. Condição da ação. Interesse processual. Falta de necessidade. Arts. 1784, CC/1916, 1996, CC/2002, e 994, CPC. Doutrina. Recurso desacolhido. I – A ação de sonegados deve ser intentada após as últimas declarações prestadas no inventário, no sentido de não haver mais bens a inventariar. II – Sem haver a declaração, no inventário, de não haver outros bens a inventariar, falta à ação de sonegados uma das condições, o interesse processual, em face da desnecessidade de utilização do procedimento (STJ, REsp 265.859/SP 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *Dju* de 07.04.2003).

155

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

156

“Vindo o herdeiro a perder o bem via ação de sonegados, tal não gera direito de representação dos seus descendentes. A hipótese não se iguala aos efeitos da indignidade, pois na sonegação não há exclusão do herdeiro. Ele somente perde o bem, que volta ao espólio e é sobrepartilhado entre os herdeiros legítimos. (...) Dispõem de legitimidade para propor a ação de sonegados os herdeiros e os credores da herança (CC 1.994). Trata-se de legitimidade concorrente. Assim, só um dos herdeiros ou um único credor pode propor a ação. Comparecendo mais de um legitimado, forma-se um litisconsórcio unitário facultativo. Como a sentença devolve ao espólio o bem sonegado, seus efeitos beneficiam a todos (CC 1.994, parágrafo único).” (Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 612).

157

Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.

158

Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I – sonegados;

159

Civil. Sucessão. Inventário e partilha. Ação de sonegados. Bem doado a herdeiro necessário. Ausência de colação. Finalidade do instituto. Igualação das legítimas. Alteração da parte indisponível do autor da herança. Ilegitimidade ativa do herdeiro testamentário. Recurso parcialmente provido. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 do CPC. 2. A finalidade da colação é a de igualar as legítimas, sendo obrigatório para os descendentes sucessivos (herdeiros

necessários) trazer à conferência bem objeto de doação ou de dote que receberam em vida do ascendente comum, porquanto, nessas hipóteses, há a presunção de adiantamento da herança (arts. 1.785 e 1.786 do CC/1916; arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002). 3. O instituto da colação diz respeito, tão somente, à sucessão legítima; assim, os bens eventualmente conferidos não aumentam a metade disponível do autor da herança, de sorte que benefício algum traz ao herdeiro testamentário a reivindicação de bem não colacionado no inventário. 4. Destarte, o herdeiro testamentário não tem legitimidade ativa para exigir à colação bem sonegado por herdeiro necessário (descendente sucessivo) em processo de inventário e partilha. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 400.948/SE, 3.^a Turma, rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina, *Dje* 09.04.2010).

160

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

161

Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2.^a ed. São Paulo: Ed. RT, 2011. Orlando Gomes, *Sucessões*. 16.^a ed. Ver e atual. Por Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3.^a ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

162

Art. 995. O inventariante será removido: I – se não prestar, no prazo legal, as primeiras e as últimas declarações; II – se não der ao inventário andamento regular, suscitando dúvidas infundadas ou praticando atos meramente protelatórios; III – se, por culpa sua, se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano bens do espólio; IV – se não defender o espólio nas ações em que for citado, deixar de cobrar dívidas ativas ou não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V – se não prestar contas ou as que prestar não forem julgadas boas; VI – se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

163

A perda da confiança do Juízo figura como uma das cláusulas genéricas a gerarem a remoção do inventariante: processual civil. Incidente de remoção de inventariante julgado procedente. Aventada a ilegitimidade das credoras do primeiro espólio para postular a destituição do inventariante do segundo. Insubsistência. Possibilidade de afastamento até mesmo de ofício. Cumulatividade de inventários que implica na nomeação de um só inventariante para ambos. Exegese do art. 1.043, § 1º do CPC. Preliminar afastada. Art. 995 do CPC. Rol exemplificativo. Inventariante que desconhece a relação exata de bens que ainda compõem o espólio e deixou de arrolar todos os herdeiros por representação. Desídia evidente. Perda da confiança do juízo. Remoção mantida. Nomeação de inventariante judicial determinada pelo juízo a quo. Divergência de interesses entre credores e herdeiros, que por si só, não dão ensejo à nomeação de terceiro. Inexistência de dissensões entre os herdeiros para que um deles exerça a inventariança. Interlocutório parcialmente reformado. Recurso parcialmente provido (TJSC, AI 2011.032725-4, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 13.09.2011).

Processual civil. Inventário. Remoção do inventariante. Rol do art.995 do CPC. Caráter não-exaustivo. 1. Como diretor do processo (art. 125/CPC), detém o magistrado a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a justificar a medida, que não aqueles expressamente catalogados no art. 995 do CPC. 2. Recurso especial não-conhecido. (STJ, REsp 1.114.096/SP, 4.^a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 29.06.2009).

civil e processual. Inventariança. Remoção. Nomeação de inventariante dativo. Beligerância entre as partes. Possibilidade de inviabilização do processo. Súmula 7 do STJ. Controvérsia afeta em parte à competência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não interposto. Súmula 126 do STJ. I. A remoção do inventariante, substituindo-o por outro, dativo, pode ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário pela animosidade manifestada pelas partes. II. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” – Súmula 7-STJ. III. Pretensão de reforma do julgado que ademais se sustenta na violação de dispositivos constitucionais sem que tenha sido interposto o recurso competente. IV. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 988.527/RS, 4.^a Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, *DJe* 11.05.2009).

Art. 99. O foro da Capital do Estado ou do Território é competente: I – para as causas em que a União for autora, ré ou interveniente; II – para as causas em que o Território for autor, réu ou interveniente. Parágrafo único. Correndo o processo perante outro juiz, serão os autos remetidos ao juiz competente da Capital do Estado ou Território, tanto que neles intervenha uma das entidades mencionadas neste artigo. Excetuam-se: I – o processo de insolvência; II – os casos previstos em lei.

Civil e processual. Inventariança. Remoção. Nomeação de inventariante dativo. Beligerância entre as partes. Possibilidade de inviabilização do processo. Súmula 7-STJ. Controvérsia afeta em parte à competência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não interposto. Súmula 126-STJ.

I. A remoção do inventariante, substituindo-o por outro, dativo, pode ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário pela animosidade manifestada pelas partes. (STJ, REsp 988.527/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 24.03.2009);

Remoção de inventariante. Ausência de cerceamento de defesa. 1. Não se configura o cerceamento de defesa no caso de remoção de inventariante quando está presente o contraditório, e pode o Juiz, constatado qualquer dos vícios do art. 995 do Código de Processo Civil, promover de ofício a remoção. 2. Recurso especial não conhecido (STJ, REsp 539.898/MA 3.^a Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, *DJU* 06.06.2005).

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

170

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

171

Processo civil. Agravo regimental no recurso especial. Tributário. ITCMD. Inventário. Remoção de inventariante. Necessidade intimação. 1. A remoção do inventariante pressupõe a sua intimação, no prazo de cinco dias, para se defender e produzir provas, conforme dispõe o art. 996 do CPC. 2. Agravo regimental não provido (STJ, 2.^a Turma, AgRg no REsp 1.461.526/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.10.2014).

172

Processo civil – Remoção de inventariante – Decisão interlocutória – Agravo – Interposição de recurso de apelação – Princípio da fungibilidade recursal – Dissídio jurisprudencial – Comprovação. 1 – A teor da jurisprudência pacífica desta Corte, não configura erro grosseiro a interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, contra decisão que remove inventariante, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde que observado o prazo para a interposição do agravo. 2 – Recurso conhecido e provido para que o recurso de apelação seja processado como agravo. (STJ, 4.^a Turma, REsp 714.035/RS, rel. Min. Jorge Scartezini, j. 01.07.2005).

173

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

174

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: I – o cônjuge ou companheiro supérstite;

II – o herdeiro; III – o legatário; IV – o testamenteiro; V – o cessionário do herdeiro ou do legatário; VI – o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; VII – o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; VIII – a Fazenda Pública, quando tiver interesse; IX – o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

175

Art. 997. Decorrido o prazo com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Se remover o inventariante, nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 990.

176

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

177

Art. 7.º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

178

Art. 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar.

179

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV – o herdeiro menor, por seu representante legal; V – o testamentário, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI – o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII – o inventariante judicial, se houver; VIII – pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

180

Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.

181

Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

182

Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. § 1.º Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha; cabendo ao devedor escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. § 2.º. Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 3.º. Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1.º a 6.º do art. 461.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1.º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2.º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I – conhecimento, o réu será considerado revel; II – execução, o feito terá seguimento.

“Em seu caput, o dispositivo também cuidou de corrigir a imprecisão terminológica do CPC/1973, no tocante a substituição, com relação à Fazenda Pública, ao Ministério Público e ao testamenteiro, da expressão “citação” por “intimação”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1532).

Art. 658. É rescindível a partilha julgada por sentença: II – se feita com preterição de formalidades legais; III – se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.

Art. 999. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se o finado deixou testamento. (Redação dada pela Lei 5.925, de 1.º.10.1973) § 1.º Citar-se-ão, conforme o disposto nos arts. 224 a 230, somente as pessoas domiciliadas na comarca por onde corre o inventário ou que aí foram encontradas; e por edital, com o prazo de 20 (vinte) a 60 (sessenta) dias, todas as demais, residentes, assim no Brasil como no estrangeiro.

“Citação por edital. Inventário. Art. 999, § 1.º, do Código de Processo Civil. 1. A citação por edital prevista no art. 999, § 1.º, do Código de Processo Civil, não agride nenhum dispositivo da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (STF, RE 552.598/RN, Pleno, rel. Min. Menezes Direito, *DJe* 21.11.2008).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Art. 11 do Decreto-lei 9.760/1946, na redação dada pela Lei 11.481/2007. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ocorrência. Medida cautelar deferida. I Ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa o convite aos interessados, por meio de edital, para subsidiar a Administração na demarcação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831, uma vez que o cumprimento do devido processo legal pressupõe a intimação pessoal. II – Medida cautelar deferida, vencido o Relator”. (STF, MC em ADI 4264, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 30.05.2011).

Art. 259. Serão publicados editais: III – em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos.

Bibliografia: Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

Art. 1.000. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 10 (dez) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações. Cabe à parte: I – argüir erros e omissões; II – reclamar contra a nomeação do inventariante; III – contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Parágrafo único. Julgando procedente a impugnação referida no n.º I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Se acolher o pedido, de que trata o n.º II, nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro, a que alude o n.º III, constitui matéria de alta indagação, remeterá a parte para os meios ordinários e sobrestará, até o julgamento da ação, na entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.

Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo.

Art. 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada.

Em seu *Código de Processo Civil e Legislação Especial em Vigor*, São Paulo, Saraiva, 2010, p. 973.

In *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. (Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Orgs.). Rio de Janeiro, Forense, 2015, p. 960.

Agravo de instrumento. Sucessões e processual civil. Procedimento de inventário. Ação de reconhecimento de paternidade. Tramitação em paralelo – Interlocutório de suspensão do inventário. Qualidade de herdeiro. Discussão na via ordinária. Art. 1.001 do CPC. Reserva de quinhão. Direitos resguardados. Suspensão, ademais, contraproducente. Art. 5.º, LXXVIII, da CF. Celeridade e razoável duração do processo. – Descabida é a suspensão (não pleiteada) do curso do inventário a fim de aguardar o término de ação em que se discute a condição de herdeiro, já que os direitos deste, se preenchidos os requisitos da medida cautelar, podem ser resguardados pela reserva do quinhão correspondente (art. 1.001, parte final, do CPC), providência, aliás, em conformidade com a celeridade e razoável duração do processo (art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal). Decisão reformada. Recurso provido. (TJSC, AgIn 2012.088418-0, 5.ª Câmara de Direito Civil, rel. Des. Henry Petry Jr. j. 05.03.2014).

196

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

197

Bibliografia: Felipe Borring Rocha, *Código de Processo Civil e Legislação Especial em Vigor*, São Paulo, Saraiva, 2010. Theotônio Negrão, *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. (Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Orgs.). Rio de Janeiro, Forense, 2015.

198

Art. 658. É rescindível a partilha julgada por sentença: III – se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.

199

Art. 1.002. A Fazenda Pública, no prazo de 20 (vinte) dias, após a vista de que trata o art. 1.000, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

200

“Importante, para fins de incidência de imposto, distinguirmos renúncia e desistência da herança. No primeiro caso, o herdeiro abre mão da herança sem preocupação com a destinação que vai ter. No segundo, desistência, que importa dizer que inicialmente aceitou a herança, a recebe e aí depois lhe dá a destinação que pretender. Na desistência ocorre a incidência do imposto “causa mortis” e “inter vivos”, enquanto que no caso de renúncia a incidência do imposto “causa mortis”. (José Reinaldo Coser, *Direito das sucessões, do inventário e da partilha: anotações e prática*. 3. ed., rev. e ampl. Leme/SP: Edijur, 2014, p. 452). Nesse aspecto, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Tributário – Direito a herança – Renúncia – Imposto de transmissão – C. Civil (arts. 1.582 e 1.589). – Se todos os filhos do autor da herança renunciam a seus respectivos quinhões, beneficiando a viuva, que era a herdeira subsequente, e incorreto dizer que a renúncia foi antecedida por aceitação tacita da herança. – Não incidência do imposto de transmissão”. (STJ, REsp 20.183/RJ, 1.ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 07.02.1994). Colhe-

se, ainda, excerto do voto do Min. César Asfor Rocha, que acompanhou o voto relator vencedor: “há uma diferença entre renúncia e desistência, e o principal ponto está em que, na renúncia, o herdeiro abre mão da herança sem se preocupar com a destinação que os bens vão ter. Já na desistência, que importa em uma prévia aceitação, os herdeiros recebem os bens deixados pelo *de cujus* e, posteriormente, dão a eles a destinação que quiserem. Na desistência, há, evidentemente a incidência de dois impostos: o primeiro *causa mortis*, que é decorrente na transferência dos bens do falecido para eles herdeiros, e segundo o *inter vivos*, que é quando os herdeiros transferem os bens por não quererem mais ficar com eles para uma outra pessoa, que pode ser um outro herdeiro ou um terceiro qualquer; normalmente é feito através da cessão de direitos hereditários. Já com relação à renúncia há apenas uma transferência de bens, estes se transferem do *de cujus* diretamente para quem vai ficar com eles”.

202

Silvia Maria Benedetti Teixeira alerta: “Existem muitas discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a possibilidade das alíquotas serem progressivas no imposto de transmissão. A constituição Federal não admite a progressividade de alíquotas, salvo nas situações expressamente especificadas. Todavia, o art. 145, § 1.º, diz que os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte e, precisamente neste artigo, estaria presente uma autorização genérica para a progressão dos impostos. (...) Embora a Constituição Federal não tenha previsão expressa para a progressividade do imposto de transmissão, deixou para o Senado Federal a competência para fixação das alíquotas máximas do imposto. Em 5 de maio de 1992, o Senado Federal, por meio da Resolução 9/1992, tratou especificamente das alíquotas do ITCD, e fixou como máxima a alíquota de 8%, na mesma Resolução, o art. 2.º prevê que possam ser progressivas as alíquotas”. (Silvia Maria Benedetti Teixeira, A tributação no inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual com a vigência da Lei 11.441/2007. *Revista IOB de Direito de Família*. São Paulo, v. 9, n. 44, p. 82-93, out./nov. 2007, p. 87-88).

203

“A base de cálculo é o valor real dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito transmitidos, entendendo-se por valor real o valor corrente de mercado, sendo ainda devido o pagamento do imposto incidente na doação de dinheiro, sob qualquer forma que se efetiva, seja em espécie, em cheque, transferência bancária etc”. (Silvia Maria Benedetti Teixeira, A tributação no inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual com a vigência da Lei 11.441/2007. *Revista IOB de Direito de Família*. São Paulo, v. 9, n. 44, p. 82-93, out./nov. 2007, p. 87).

204

Art. 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.

205

“Medida cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Inventário. *De cujus* que, após o falecimento de sua esposa, com quem tivera uma filha, vivia, em união estável, há mais de trinta anos com sua companheira, sem contrair matrimônio. Incidência, quanto à vocação hereditária, da regra do art. 1.790 do CC/2002. Alegação, pela filha, de que a regra é mais favorável para a convivente que a norma do

art. 1829, I, do CC/2002, que incidiria caso o falecido e sua companheira tivessem se casado pelo regime da comunhão parcial. Afirmação de que a Lei não pode privilegiar a união estável, em detrimento do casamento. Medida liminar parcialmente deferida, apenas para determinar a partilha, no inventário, da parcela incontroversa do patrimônio, promovendo-se reserva de bens. – O art. 1.790 do CC/2002, que regula a sucessão do “de cujus” que vivia em união estável com sua companheira, estabelece que esta concorre com os filhos daquele na herança, calculada sobre todo o patrimônio adquirido pelo falecido durante a convivência. Trata-se de regra oposta à do art. 1.829 do CC/2002, que, para a hipótese de ter havido casamento pela comunhão parcial entre o ‘de cujus’ e a companheira, estabelece que a herança do cônjuge incida apenas sobre os bens particulares. – A diferença nas regras adotadas pelo código para um e outro regime gera profundas discrepâncias, chegando a criar situações em que, do ponto de vista do direito das sucessões, é mais vantajoso não se casar. – A discussão quanto à legalidade da referida diferença é profundamente relevante, de modo que se justifica o deferimento da medida liminar pleiteada em ação cautelar, para o fim de reservar os bens controvertidos no inventário ‘sub judice’, admitindo-se a partilha apenas dos incontroversos. Medida liminar parcialmente deferida”. (STJ, MC 14.509-SP, 3.^a T., rel. Min. Nancy Andrigli, *Dj* 21.08.2008,).

206

Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido.

207

Bibliografia: José Reinaldo Coser, *Direito das sucessões, do inventário e da partilha: anotações e prática*. 3. ed., rev. e ampl. Leme/SP: Edijur, 2014.

Silvia Maria Benedetti Teixeira, A tributação no inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual com a vigência da Lei 11.441/2007. *Revista IOB de Direito de Família*. São Paulo, v. 9, n. 44, p. 82-93, out./nov. 2007.

208

Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes: I – arguir erros, omissões e sonegação de bens; II – reclamar contra a nomeação de inventariante III – contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. § 1.º Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. § 2.º Se acolher o pedido de que trata o inciso II, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. § 3.º Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.

209

“Quando o bem se tratar de título da dívida pública, de ações das sociedades e dos títulos de crédito

negociáveis em bolsa, o seu valor será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial". (José Reinaldo Coser, *Direito das sucessões, do inventário e da partilha: anotações e prática*. 3. ed., rev. e ampl. Leme/SP: Edijur, 2014, p. 448).

210

O espólio será o responsável em custear o perito, exceto se houver divergências entre os herdeiros, circunstância que implicará a oneração da(s) parte(s) interessada(s). A este respeito, colhe-se da jurisprudência do STJ: "Civil e processual. Inventário. Partilha judicial por divergência entre herdeiros. Despesas com a avaliação. Inexistência de litigiosidade nesta fase. Custeio pelo espólio. Princípio da igualdade. CC, arts. 1.724 e 1.725. CPC, arts. 33 e 1.003. Questão, todavia, prejudicada em face da ulterior realização da partilha, não nulificada em processo conexo. I – O pedido de partilha judicial efetuado por herdeira que não deseja que os bens permaneçam em condomínio com as demais irmãs, não configura, em si, pretensão contenciosa, de sorte que a avaliação dos bens para a apuração do seu valor real, interesse de todos e acobertada pelo princípio da igualdade inscrito no art. 1.725 do Código Civil, deve ser custeada pelo Espólio e não pela herdeira requerente, afastada, na espécie, a incidência da regra prevista no art. 33 do CPC. II – Inobstante a procedência da tese recursal, resta prejudicada a irresignação em face da ulterior partilha dos bens e da conclusão, tomada em processo conexo (REsp 20.782/SP), de que a mesma não padecia de nulidade ao determinar a incidência do quinhão hereditário sobre o todo do patrimônio inventariado, em condomínio. III – Recurso não conhecido". (STJ, REsp 11.570/SP, 4.^a T., rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 10.03.2003).

211

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 1.º Os sujeitos previstos no *caput* considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. § 2.º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. § 3.º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. § 4.º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5.º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6.º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

212

Bibliografia: José Reinaldo Coser, *Direito das sucessões, do inventário e da partilha: anotações e prática*. 3. ed., rev. e ampl. Leme/SP: Edijur, 2014.

213

Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II – o valor dos bens. § 1.º Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de

memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2.º Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.

214

Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do *caput* deste artigo.

215

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

216

“A admissão de assistentes técnicos e o deferimento dos quesitos formulados pelas partes não contrariam as normas do CPC, uma vez que o Código faculta às partes tais procedimentos, daí porque importarem em cerceamento de defesa, capaz de invalidar a avaliação anterior e de justificar a realização de nova avaliação a preterição da manifestação dos assistentes técnicos e a não-submissão dos quesitos aos peritos”. (José Reinaldo Coser, *Direito das sucessões, do inventário e da partilha: anotações e prática*. 3. ed., rev. e ampl. Leme/SP: Edijur, 2014, p. 449).

217

Art. 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, que correrá em cartório. § 1.º Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano, à vista do que constar dos autos. § 2.º Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão.

218

Art. 1.005. O herdeiro que requerer, durante a avaliação, a presença do juiz e do escrivão, pagará as despesas da diligência.

219

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1.º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexactidão dos resultados a que esta conduziu. § 2.º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3.º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

220

§ 3.º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

221

Bibliografia: José Reinaldo Coser, *Direito das sucessões, do inventário e da partilha: anotações e prática*. 3. ed., rev. e ampl. Leme/SP: Edijur, 2014.

222

Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: I – a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; II – o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; III – a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; IV – o encerramento com a assinatura do juiz. § 1.º O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. § 2.º Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. § 3.º A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o *caput* e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função.

223

Art. 1.006. Não se expedirá carta precatória para a avaliação de bens situados fora da comarca por onde corre o inventário, se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado.

224

O digesto de 1973 já continha essa regra no art. 1.006, vindo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart a assinalarem: “Essa precatória, porém, é dispensada em relação aos bens de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos pelo perito nomeado (art. 1.006 do CPC), pois o custo da carta, nesse caso, não justificaria o benefício resultante”. (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 138).

225

Consoante Rafael Knorr Lippmann: “A dispensa de avaliação de bens de pequeno valor ou conhecidos do perito, quando situados em local distinto do foro no qual tramita o inventário, vai ao encontro dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo (CF, art. 5.º, LXXVIII)”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1535).

226

Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão do pagamento do quinhão hereditário, quando este não exceder 5 (cinco) vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo; caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado.

227

Idem.

228

Bibliografia: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012. Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

229

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

230

Art. 1.007. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação, se a Fazenda Pública, intimada na forma do art. 237, I, concordar expressamente com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.

231

Art. 1.008. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais”.

232

Art. 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

233

Art. 665. O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público.

234

A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery referenciam que o dispositivo, em verdade, retrata um negócio jurídico processual, assinalando que esse: “*só se aperfeiçoa com a concordância expressa da Fazenda Pública*”. Mais adiante, pregam que: “*É insuficiente a disposição contratual ou legal para suprimir o inventário ou arrolamento, como também a partilha. Essencial a*

*instauração do processo adequado para que a passagem por sucessão se formalize. Por conseguinte, os herdeiros têm a necessidade de vir a juízo, o que revela o interesse de agir. E, havendo bens em nome do falecido, inclusive para efeitos tributários da transmissão causa mortis, o procedimento do inventário se justifica”. (Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1457 e p. 1483).*

235

§ 1.º Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) dias.

236

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

237

§ 1.º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525.

238

Bibliografia: Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

239

§ 1.º Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) dias.

240

Art. 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.

241

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

“Art. 9.º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos. II e III; III – à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 1.009. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que sobre ele se manifestem as partes no prazo de 10 (dez) dias, que correrá em cartório.

§ 1.º Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano, à vista do que constar dos autos.

§ 2.º Julgando procedente a impugnação, determinará o juiz que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão.

Rafael Knorr Lippmann acentua: “Ao estabelecer que o prazo correrá em cartório, o dispositivo vedou a possibilidade de carga dos autos por qualquer das partes, que deverão manifestar-se em 15 (quinze) dias sobre o laudo de avaliação dos bens”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1536).

Caio de Sá Dal’Col e João Roberto de Sá Dal’Col defendem que: “Com efeito, não há razão para que seja tolhido o direito de indicação de assistente técnico sob o argumento de que a referida matéria não está regulada na parte de inventário no Código de Processo Civil ou que o referido rito não comportaria assistência técnica em virtude da suposta demora deste tipo de prova. Nesse ponto, deve-se ter ciência da indispensabilidade de uma análise sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro. Não obstante a existência de um procedimento especial de inventário, este não é completo em si mesmo. Quando preciso, deve se valer das regras gerais do Código, sobretudo se observada a aplicação subsidiária da parte geral, no sentido de garantir a máxima efetividade processual, protegendo o direito das partes. De mais a mais, o auxílio de assistente técnico para a realização da perícia não terá o condão de atrapalhar o andamento do feito; pelo contrário, auxiliará a garantir mais meios para que o juiz profira uma melhor decisão em tempo hábil.” (Caio de Sá Dal Col; João Roberto de Sá Dal Col. A (des)necessidade da remessa de ‘suposta’ questão de dependente de prova às vias ordinárias no processo de inventário: uma análise sob o enfoque do art. 627 da redação final do novo CPC aprovada pela câmara dos deputados. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, v. 62, n. 446, p. 31-44, dez./2014. p. 40)

247

Art. 218, § 3.º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

248

Art. 477, § 3.º São suspeitos: I – o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo; II – o que tiver interesse no litígio.

249

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1.º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2.º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3.º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

250

Art. 1.010. O juiz mandará repetir a avaliação: I – quando viciada por erro ou dolo do perito;
II – quando se verificar, posteriormente à avaliação, que os bens apresentam defeito que lhes diminui o valor.

251

Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do *caput* deste artigo.

252

Art. 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

253

Bibliografia: Caio de Sá Dal Col,; João Roberto de Sá Dal Col. A (des)necessidade da remessa de ‘suposta’ questão de dependente de prova às vias ordinárias no processo de inventário: uma análise sob o enfoque do art. 627 da redação final do novo CPC aprovada pela câmara dos deputados. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, v. 62, n. 446, p. 31-44, dez./2014.

Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

254

Art. 1.996. Só se pode argüir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como argüir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui.

255

Art. 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar.

256

Art. 1.012. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum de 10 (dez) dias, proceder-se-á ao cálculo do imposto.

257

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: VI – se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

258

Art. 1.993. Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos bens, quando indicados.

259

Art. 1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

260

Consoante ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “*O patrimônio destinado à satisfação das dívidas do falecido, bem como as dívidas da herança, não se sujeita ao ITCM, justamente por visar o adimplemento de dívidas pretéritas, assumidas pelo de cujus em vida, ou de dívidas atuais adquiridas em virtude da morte do autor da herança (...). Não é objeto de transmissão aos herdeiros em virtude da morte do de cujus – hipótese de incidência do ITCMD –, por isso é que não ocorre, na hipótese, sucessão causa mortis. Ou seja, por não se configurar sobre essa quota patrimonial o fato gerador da obrigação tributária, ela deve, destarte, ser reduzida ao monte-mor no momento da avaliação do imposto*”. (Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1461).

261

Tributário – Imposto de transmissão *causa mortis* (art. 179 DO CTN). 1. Cabe ao juiz do inventário à vista

da situação dos herdeiros, miseráveis na forma da lei, por isto ao apanágio da Justiça Gratuita, declará-los isentos do pagamento do imposto de transmissão causa mortis. 2. Providência que independe de burocrático requerimento na esfera administrativa para o reconhecimento judicial. 3. Recurso especial provido. (STJ, 2.^a Turma, REsp 238161/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 12.09.2000).

262

Processo civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543-C, do CPC. Arrolamento sumário post mortem. Reconhecimento judicial da isenção do ITCMD. Impossibilidade. Artigo 179, do CTN.

1. O juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN, *verbis*: “Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. (...)”

2. Como cediço, a abertura da sucessão (morte do autor da herança) reclama a observância do procedimento especial de jurisdição contenciosa denominado “inventário e partilha”, o qual apresenta dois ritos distintos: “um completo, que é o inventário propriamente dito (arts. 982 a 1.030) e outro, sumário ou simplificado, que é o arrolamento (arts. 1.031 a 1.038)” (Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil: Procedimentos Especiais”, Vol. III, 36.^a Ed., Ed. Forense, pág. 240).

3. O artigo 1.013, do CPC, rege o procedimento para avaliação e cálculo do imposto de transmissão causa mortis no âmbito do inventário propriamente dito, assim dispondo: “Art. 1.013. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório e, em seguida, a Fazenda Pública. § 1.^o Se houver impugnação julgada procedente, ordenará o juiz novamente a remessa dos autos ao contador, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. § 2.^o Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do imposto.”

4. Conseqüentemente, em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN (Precedentes do STJ: REsp 138.843/RJ, rel. Ministro Castro Meira, 2.^a Turma, julgado em 08.03.2005, DJ 13.06.2005; REsp 173.505/RJ, rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 19.03.2002, DJ 23.09.2002; REsp 143.542/RJ, rel. Ministro Milton Luiz Pereira, 1.^a Turma, julgado em 15.02.2001, DJ 28.05.2001; REsp 238.161/SP, rel. Ministra Eliana Calmon, 2.^a Turma, julgado em 12.09.2000, DJ 09.10.2000; e REsp 114.461/RJ, rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 09.06.1997, DJ 18.08.1997).

5. É que a prévia oitiva da Fazenda Pública, no inventário propriamente dito, torna despiendo o procedimento administrativo, máxime tendo em vista o teor do artigo 984, do CPC, *verbis*: “Art. 984. O juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.”

6. Por seu turno, os artigos 1.031 e seguintes, do CPC, estabelecem o procedimento a ser observado no âmbito do arrolamento sumário, cujo rito é mais simplificado que o do arrolamento comum previsto no artigo 1.038 e o do inventário propriamente dito, não abrangendo o cálculo judicial do imposto de transmissão *causa mortis*.

7. Deveras, o caput (com a redação dada pela Lei 7.019/82) e o § 1.^o (renumerado pela Lei 9.280/96) do artigo 1.031, do CPC, preceituam que a partilha amigável (celebrada entre partes capazes) e o pedido de adjudicação (formulado por herdeiro único) serão homologados de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

8. Entrementes, o artigo 1.034, do CPC (com a redação dada pela Lei 7.019/82), determina que, “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio” (*caput*), bem como que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros” (§ 2.º). 9. Outrossim, é certo que, antes do trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha ou adjudicação (proferida no procedimento de arrolamento sumário), inexistia intervenção da Fazenda Pública, a qual, contudo, condiciona a expedição dos respectivos formais, à luz do disposto no § 2.º, do artigo 1.031, do CPC, *verbis*: “Art. 1.031. § 2.º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos. (Incluído pela Lei 9.280, de 30.5.1996)” 8. Consectariamente, nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da partilha ou da adjudicação), revela-se incompetente o Juízo do inventário para reconhecer a isenção do ITCMD, por força do disposto no artigo 179, do CTN, que confere, à autoridade administrativa, a atribuição para aferir o direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral. 9. Ademais, prevalece o comando inserto no artigo 192, do CTN, segundo o qual “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”, impondo-se o sobrestamento do feito de arrolamento sumário até a prolação do despacho administrativo reconhecendo a isenção do ITCMD. 10. Assim, falecendo competência ao juízo do inventário (na modalidade de arrolamento sumário), para apreciar pedido de reconhecimento de isenção do ITCMD, impõe-se o sobrestamento do feito até a resolução da quaestio na seara administrativa, o que viabilizará à adjudicatária a futura juntada da certidão de isenção aos autos. 12. Recurso especial fazendário provido, anulando-se a decisão proferida pelo Juízo do inventário que reconheceu a isenção do ITCMD. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp repetitivo 1.150.356/SP, 1.ª Seção, rel. Min. Luiz Fux, *Dje* 25.08.2010).

263

Bibliografia: Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

264

“O julgamento de qualquer impugnação porventura feita deverá levar em consideração também manifestação do contador sobre essa mesma impugnação”. (Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1462).

265

Art. 1.013. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório e, em seguida, a Fazenda Pública.

266

No Estado de Santa Catarina, por exemplo, Lei 13136/2004 estabelece o seguinte: Art. 10. São isentos do pagamento do imposto: I – o testamentário, com relação ao prêmio instituído pelo testador, desde que o

valor deste não exceda à vintena testamentária; II – o beneficiário de seguros de vida, pecúlio por morte e vencimentos, salários, remunerações, honorários profissionais e demais vantagens pecuniárias decorrentes de relação de trabalho, inclusive benefícios da previdência, oficial ou privada, não recebidos pelo de cujus; III – o herdeiro, o legatário ou o donatário que houver sido aquinhoadado com um único bem imóvel, relativamente à transmissão *causa mortis* ou à doação deste bem, desde que cumulativamente: *a)* o imóvel se destine à moradia própria do beneficiário; *b)* o beneficiário não possua qualquer outro bem imóvel; e *c)* o valor total do imóvel não seja superior a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); IV – o herdeiro, o legatário ou o donatário, quando o valor dos bens ou direitos recebidos não exceder ao equivalente a R\$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o disposto no parágrafo único do art. 9.º; V – o donatário ou o cessionário, qualquer que seja o valor dos bens ou direitos, em se tratando de sociedade civil sem fins lucrativos, devidamente reconhecida como de utilidade pública estadual; e VI – o donatário ou o cessionário de bens móveis ou imóveis destinados à execução de programa oficial de moradias para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos ou ao assentamento de agricultores sem-terra, abrangendo a doação do bem: *a)* à entidade executora do programa; ou *b)* aos beneficiários, pela entidade executora, se for o caso.

267

Já no Estado de São Paulo, também a título de exemplo, a Lei 10.705/2000, estabelece as seguintes isenções: Art. 6.º – Fica isenta do imposto: (Redação dada ao artigo 6.º pelo inciso I do art. 1.º da Lei 10.992 de 21.12.2001; DOE 22.12.2001; efeitos a partir de 01-01-2002) I – a transmissão “causa mortis”: *a)* de imóvel de residência, urbano ou rural, cujo valor não ultrapassar 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESPs e os familiares beneficiados nele residam e não tenham outro imóvel; *b)* de imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 (duas mil e quinhentas) UFESPs, desde que seja o único transmitido; *c)* de ferramenta e equipamento agrícola de uso manual, roupas, aparelho de uso doméstico e demais bens móveis de pequeno valor que guarneçam os imóveis referidos nas alíneas anteriores, cujo valor total não ultrapassar 1.500 (mil e quinhentas) UFESPs; *d)* de depósitos bancários e aplicações financeiras, cujo valor total não ultrapassar 1.000 (mil) UFESPs; *e)* de quantia devida pelo empregador ao empregado, por Institutos de Seguro Social e Previdência, oficiais ou privados, verbas e prestações de caráter alimentar decorrentes de decisão judicial em processo próprio e o montante de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participações PIS-PASEP, não recebido em vida pelo respectivo titular; *f)* na extinção do usufruto, quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor;

268

Bibliografia: Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

269

“O instituto da colação ou conferência (*collatum*, do verbo *confere*, isto é, *conferir*, *ajuntar*, *reunir*) fincou suas raízes nos primórdios do Direito Romano”. Luiz Paulo Vieira de Carvalho. *Direito das sucessões*. São Paulo: Atlas, 2014, p. 882).

270

Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do

que lhes cabe por herança.

271

Art. 2.003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuem os bens doados.

Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade.

272

“É de se destacar que a colação sucessória, com o prefalado objetivo de igualar as quotas-partes integrantes da legítima dos herdeiros necessários, está igualmente disseminada em inúmeras legislações estrangeiras, embora com diferentes matizes quanto aos sucessores aos quais cabe tal dever”. (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das sucessões*. São Paulo: Atlas, 2014, p. 885).

273

“A sucessão causa mortis é um dos campos em que foi mais viva – e diremos quase dramática – a luta entre o fator germânico e o romano, eis que os dois partiam de concepções absolutamente opostas, seja da família seja da relação jurídica sucessória. E, de fato, enquanto o primeiro conhecia e reconhecia somente os ‘Bluterbe’, isto é, os herdeiros de sangue, de forma que o indivíduo não podia testar, o segundo, pelo contrário, a alargava a todo o patrimônio do defunto”. (Emílio Bussi apud Antônio Junqueira de Azevedo, O espírito de compromisso do direito das sucessões perante as exigências individualistas de autonomia da vontade e as supra-individualistas da família: herdeiro e legatário. *Revista Brasileira de Direito de Família*, Porto Alegre, Síntese v. 4, jan. 2000, p. 56-63, p. 56).

274

Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

275

Pertinente pontuar, no que concerne à sucessão, que a legislação material atribui a ela natureza de bem imóvel para efeitos legais, consoante disciplina o inc. II do art. 80 do Código Civil, *in verbis*: Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: II – o direito à sucessão aberta.

276

Art. 1.996. Só se pode argüir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como argüir o herdeiro,

depois de declarar-se no inventário que não os possui.

277

Art. 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar.

278

Art. 1.012. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum de 10 (dez) dias, proceder-se-á ao cálculo do imposto.

279

Art. 2.003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade.

280

Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1.º Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. § 2.º Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem.

281

“É de se fazer também a indispensável distinção entre colação e redução das doações, de vez que a primeira, ancorada na vontade presumida do falecido, objetiva garantir a observância do equilíbrio entre as quotas-partes dos sucessores descendentes e do cônjuge sobrevivente, enquanto a segunda, de ordem pública, pretende reverter ao doador ou à sua herança os bens doados em vida relativamente à parte indispensável, com o fito de integrar a legítima dos sucessores forçados”. (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das sucessões*. São Paulo: Atlas, 2014, p. 891).

282

“A redução das doações inoficiosas, em princípio, deve ser feita nos autos do inventário, sítio onde as questões que envolvem os aspectos da herança devem ser decididas, salvo se o magistrado orfanológico entender, no caso concreto, se traduzir em questão de alta indagação, a demandar provas insuscetíveis de verificação no procedimento em questão, como perícias, testemunhas etc., caso em que o assunto deve ser resolvido através de ação própria”. (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das sucessões*. São Paulo: Atlas, 2014, p. 893).

Recurso especial. Testamento. Ação de redução de disposições testamentárias. Colação. Prova. Perícia para avaliação de bens doados pelo testador aos herdeiros necessários. Liberdade do juiz na condução da prova. Alegação de desnecessidade da perícia afastada. Não violação dos arts. 544, 1789, 1846, 1847, 1976, 2002, § único, e 2004 do Cód. Civil/2002. Recurso especial improvido. 1.– Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, nos termos da jurisprudência pacífica do tribunal, no sentido de que, se os fundamentos adotados bastam para justificar a conclusão, não é preciso que o julgado rebata, um a um, os argumentos deduzidos pela parte. 2.– Em ação movida por herdeiros necessários, que receberam doações em vida do “de cujus”, visando à redução de disposições testamentárias em prol da viúva, para preservação da legítima (CC, art. 1789), pode o Juízo, visando à formação do livre convencimento, determinar a realização de perícia, para verificação dos valores envolvidos no patrimônio, nas doações e no testamento. 3.– Recurso Especial improvido. (STJ, REsp 1.314.071/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, J. em 26.02.2013).

Art. 638. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório, e, em seguida, a Fazenda Pública. § 1.º Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. § 2.º Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo.

Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1.º Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. § 2.º Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem.

Bibliografia: Antônio Junqueira de Azevedo, O espírito de compromisso do direito das sucessões perante as exigências individualistas de autonomia da vontade e as supra-individualistas da família: herdeiro e legatário. Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, Síntese v. 4, jan. 2000, p. 56-63. Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014.

Art. 1.015. O herdeiro que renunciou à herança ou o que dela foi excluído não se exime, pelo fato da renúncia ou da exclusão, de conferir, para o efeito de repor a parte inoficiosa, as liberalidades que houve do doador. § 1.º É lícito ao donatário escolher, dos bens doados, tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. § 2.º Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel, que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda entre os herdeiros à licitação; o donatário poderá concorrer na licitação e, em igualdade de condições, preferirá aos herdeiros.

“A renúncia é o ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro abre mão de sua posição jurídica. A forma da renúncia é pública, e poderá se efetivar por termo judicial ou por instrumento público. Em ambos os casos, é imprescindível que conste a vontade de abdicar do acervo ou da porção que competia ao renunciante. A renúncia somente pode ser feita após a abertura da sucessão (óbito do autor da herança), sob pena de nulidade, por força da norma jurídica que veda a realização de negócio jurídico que tenha por objeto herança de pessoa viva (art. 426 do Código Civil). A declaração de vontade do renunciante poderá constar na própria escritura pública de inventário. Entretanto, fica dispensada a presença do renunciante caso seja apresentada declaração de renúncia por instrumento público ou judicial. A renúncia diz respeito à totalidade da herança a que teria direito o renunciante, operando-se, nos termos do art. 1.810 do Código Civil, sempre em favor do monte. O herdeiro não renuncia aos direitos sobre o seu quinhão em favor de alguém. A chamada renúncia imprópria ou renúncia translativa, na verdade, é uma cessão de direitos e não uma renúncia. O ordenamento jurídico não admite a renúncia condicional ou a termo, sendo vedado ao renunciante fixar um momento no futuro para a produção dos efeitos do ato, ou estabelecer qualquer condição para que se opere a eficácia imediata. A distinção é importante, pois no caso de renúncia não há incidência de imposto, o que não ocorre se houver cessão”. (Francisco José Cahali, *Escrituras públicas: separação, divórcio, inventário e partilha consensuais: análise civil, processual civil, tributária e notarial*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 92-93).

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.

Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. § 1.º O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. § 2.º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia.

Art. 2.008. Aquele que renunciou a herança ou dela foi excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas, para o fim de repor o que exceder o disponível.

“O herdeiro pode renunciar à herança ou dela ser excluído, sem que, por isso, venha a perder o direito advindo de doação anterior, porquanto o bem objeto da liberalidade inter vivos não faz parte da herança, só vindo, entretanto, a ser colacionado com o fito de repor eventual parte inoficiosa, isto é, a parte que exceder a legítima e mais a metade disponível, apuradas no momento da doação”. (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das sucessões*. São Paulo: Atlas, 2014, p. 889).

Direito civil e processual civil. Ação declaratória de nulidade de doação e partilha. Bens doados pelo pai à

irmã unilateral e à ex-cônjuge em partilha. Doação inoficiosa. Prescrição. Prazo decenal, contado da prática de cada ato. Arts. Analisados: 178, 205, 549 e 2.028 do CC/16. 1. Ação declaratória de nulidade de partilha e doação ajuizada em 7.5.2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16.11.2011. 2. Demanda em que se discute o prazo aplicável a ação declaratória de nulidade de partilha e doação proposta por herdeira necessária sob o fundamento de que a presente ação teria natureza desconstitutiva porquanto fundada em defeito do negócio jurídico. 3. Para determinação do prazo prescricional ou decadencial aplicável deve-se analisar o objeto da ação proposta, deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na inicial. 4. A transferência da totalidade de bens do pai da recorrida para a ex-cônjuge em partilha e para a filha do casal, sem observância da reserva da legítima e em detrimento dos direitos da recorrida caracterizam doação inoficiosa. 5. Aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de previsão legal específica. Precedentes. 6. Negado provimento ao recurso especial. (STJ, REsp 1.321.998/RS, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 20.08.2014).

295

Civil e processo civil. Imóveis doados pelos ascendentes aos descendentes comuns. Herdeira necessária preterida. Legitimidade para pleitear a nulidade do ato de liberalidade. Doação universal não demonstrada. Patrimônio transferido que ultrapassa a metade disponível mais a legítima dos donatários. Inoficiosidade. Nulidade parcial do negócio jurídico. Arts. Analisados: 1.171, 1.175, 1.795, CC/16. 1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico distribuída em 2000, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25.01.2013. 2. Discute-se a legitimidade de herdeiro, que cedeu seus direitos hereditários, para pleitear a declaração de nulidade da doação realizada pelo ascendente aos demais coerdeiros necessários, bem como a validade desse negócio jurídico. 3. A cessão de direitos hereditários não retira da cedente a qualidade de herdeira, que é personalíssima, e, portanto, não afasta a sua legitimidade para ajuizar a presente ação, porque apenas transferiu ao cessionário a titularidade de sua situação, de modo a permitir que ele exija a partilha judicial dos bens que compõem a herança. 4. A doação universal, como apregoa o art. 1.175 do CC/16, é caracterizada quando, doados todos os bens, o doador não faz a reserva de parte ou renda suficiente para a própria subsistência, razão pela qual o reconhecimento da nulidade absoluta não prescinde da demonstração de ter ele se reduzido à miséria, em decorrência do negócio jurídico realizado. 5. A melhor interpretação do art. 1.171 do CC/16 é a de que a doação feita de ascendente para descendente, por si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação protraída no tempo, de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à colação, para igualar as legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro necessário (art. 1.785 do CC/16). 6. À luz do que dispõe o art. 1.795 do CC/16 (art. 2.012 do CC/02), se ambos os cônjuges doam bens aos filhos comuns, no inventário de cada um deles devem ser conferidos pela metade. 7. O ato de liberalidade do falecido de doar todos os seus bens aos filhos que possuía com a esposa, preterindo a filha, fruto de outro relacionamento, torna inoficiosa (nula) a doação no tocante ao que excede a parte disponível do patrimônio mais as respectivas frações da legítima, porque caracterizado o indevido avanço da munificência sobre a legítima da herdeira preterida. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1.361.983/SC, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 26.03.2014).

296

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.

Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. § 1.º O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. § 2.º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia.

Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. § 1.º A habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias seguintes ao conhecimento do fato. § 2.º Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros.

§ 3.º Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.

§ 2.º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

Art. 2.003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuem os bens doados.

§ 2.º Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem.

§ 2.º Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros.

Art. 9.º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de

tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III – à decisão prevista no art. 701.

305

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

306

Bibliografia: Francisco José Cahali, *Escrituras públicas: separação, divórcio, inventário e partilha consensuais: análise civil, processual civil, tributária e notarial*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2008. Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014.

307

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: IV – a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: *a)* os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam; *b)* os móveis, com os sinais característicos; *c)* os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos; *d)* o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância; *e)* os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data; *f)* as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores; *g)* direitos e ações; *h)* o valor corrente de cada um dos bens do espólio.

308

Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. § 1.º O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no art. 247, sendo, ainda, publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259. § 2.º Das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes. § 3.º A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. § 4.º Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos.

309

Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes: I – arguir erros, omissões e sonegação de bens; II – reclamar contra a nomeação de inventariante; III – contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. § 1.º Julgando procedente a impugnação referida no

inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. § 2.º Se acolher o pedido de que trata o inciso II, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. § 3.º Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.

310

Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I – sonegados.

311

Recurso especial. Civil. Direito das sucessões. Processo de inventário. Distinção entre colação e imputação. Direito privativo dos herdeiros necessários. Ilegitimidade do testamenteiro. Interpretação do art. 1.785 do CC/16. 1. O direito de exigir a colação dos bens recebidos a título de doação em vida do *de cujus* é privativo dos herdeiros necessários, pois a finalidade do instituto é resguardar a igualdade das suas legítimas. 2. A exigência de imputação no processo de inventário desses bens doados também é direito privativo dos herdeiros necessários, pois sua função é permitir a redução das liberalidades feitas pelo inventariado que, ultrapassando a parte disponível, invadam a legítima a ser entre eles repartida. 3. Correto o acórdão recorrido ao negar legitimidade ao testamenteiro ou à viúva para exigir a colação das liberalidades recebidas pelas filhas do inventariado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5. Recursos especiais desprovidos. (STJ, REsp 167.421/SP, 3.ª Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2010).

312

Francisco José Cahali e Karin Regina Rick Rosa ressaltam que: “A existência de credores não impede a partilha extrajudicial”. (Francisco José Cahali, *Escrituras públicas: separação, divórcio, inventário e partilha consensuais: análise civil, processual civil, tributária e notarial*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 106).

313

“Por prova literal da dívida entende-se a demonstração documental de que a dívida efetivamente existe. As exigências relativas a tal prova literal são similares àquelas da prova escrita que autoriza a propositura de ação monitória (art. 1.102 do CPC/1973; art. 700 do NCPC): embora não deva comprovar peremptoriamente a existência do débito, é preciso que dela se presuma de maneira satisfatoriamente clara, o direito do credor. Em síntese, o credor deve ser capaz de demonstrar a provável existência do crédito, o valor devido e a exigibilidade do pagamento. A comprovação da dívida mediante documento escrito é indispensável ao requerimento e, na sua ausência, o pedido será indeferido de ofício, independentemente de manifestação das partes e interessados”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1543).

314

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: VI – o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1.º e 2.º.

Conflito positivo de competência – Justiça do trabalho e juízo de órfãos e sucessões – Execução de crédito trabalhista – Bem integrante do inventário – Habilitação de crédito trabalhista – Desnecessidade – Natureza alimentícia – Prosseguimento da execução trabalhista – Possibilidade – Competência da Justiça do Trabalho. I – A habilitação de crédito nos autos de inventário do devedor não é uma obrigatoriedade da parte, mas sim consiste em uma faculdade a teor do disposto no artigo 1.017, *caput*, do Código de Processo Civil. II – Os herdeiros só receberão a herança depois de solucionadas as pendências com os credores. Assim, é perfeitamente possível que a execução tenha prosseguimento, inclusive com reserva de bens suficientes, se o débito não puder ser solucionado no inventário. III – Não há, de fato, que se falar em habilitação do crédito trabalhista no inventário. É possível, pois, ao credor, em especial aquele oriundo de crédito trabalhista, o prosseguimento da execução. IV – Não se justifica a suspensão da execução trabalhista, tendo em vista que esta busca a satisfação de créditos de natureza alimentícia. V – Conflito Positivo de Competência conhecido para reconhecer a competência da 3.ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC. (STJ, 2.ª Seção, CC 96.042/AC rel. Min. Massami Uyeda, *DJe* 21.10.2010).

Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do *de cujus* ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no § 1.º do artigo anterior.

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

Art. 810. Salvo a hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, devendo os autos ser enviados à Câmara, ou turma, a que competir o julgamento.

Recurso especial – Habilitação de crédito em inventário – Pedido deferido, com determinação de reserva de bens suficientes a saldar o débito do espólio perante o credor habilitante – Manejo de agravo de instrumento – Não conhecimento pelo tribunal de origem, por reputar cabível apelação – Decisão de

natureza interlocutória – Reconhecimento – Controvérsia na doutrina e na jurisprudência – Verificação – Recurso especial provido. Pedido de habilitação de crédito em inventário deferido pelo magistrado de piso, para determinar a reserva de bens suficientes a fazer frente ao débito do espólio perante o credor habilitante. *Decisum*, que ensejou o manejo de agravo de instrumento pelo espólio. Agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal de origem, por reputar cabível recurso de apelação, não se afigurando possível aplicar, à espécie, o princípio da fungibilidade recursal ante a verificação de erro grosseiro. 1. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito no inventário, pois o provimento judicial atacado, embora processado em apenso aos autos principais, tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que não encerra o processo de inventário. Não obstante, mesmo que o ora recorrente tivesse intentado recurso de apelação, o conhecimento da insurgência seria de rigor, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, a considerar a existência de dúvida objetiva no âmbito da doutrina, assim como da jurisprudência (identificada, ao menos, em dois precedentes desta Corte de Justiça). 2. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. A fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia é clara e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 3. Decisão judicial sobre a habilitação de crédito no inventário. Provimento jurisdicional que não encerra o procedimento perante o Juízo de Direito, mas mantém o processo de inventário em curso, relegando eventual discussão sobre o crédito para as vias ordinárias ou determinado a separação de bens para o pagamento da dívida em momento posterior. 4. A mera autuação em apenso do pedido não tem o condão de desnaturar a essência da decisão proferida, pois a forma de processamento do pleito se refere à disciplina da marcha processual, a fim de se alcançar a boa prestação jurisdicional, sem tumultos processuais ou sem dilações indevidas. 5. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito no inventário, pois o provimento judicial atacado, embora processado em apenso aos autos principais, tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que não encerra o processo de inventário. 6. Recurso especial provido, para afastar o óbice apresentado pelo Tribunal de origem e determinar que este prossiga no julgamento do agravo de instrumento como bem entender de direito. (STJ, REsp 1.107.400/SP, 4.^a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, *Dje* 13.11.2013).

322

Bibliografia: Francisco José Cahali, *Escrituras públicas: separação, divórcio, inventário e partilha consensuais: análise civil, processual civil, tributária e notarial*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2008. Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

323

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

324

“Importante distinguir separação e reserva de bens. Enquanto a separação de bens pressupõe a dívida não impugnada, com o escopo de indicar os bens do espólio que se destinam ao pagamento da dívida do credor, a reserva pressupõe a dívida impugnada que conste de documento comprobatório da obrigação”. (Luiz Paulo

325

“Trata-se de medida assecuratória de natureza cautelar (...) garantindo que o suposto credor receberá o seu crédito caso ele se confirme judicialmente. Aqui, mais uma vez, nota-se a razão pela qual se deve exigir do credor que apresente prova literal de uma dívida líquida. Sem saber o valor da obrigação, não é possível nem ao juiz nem ao inventariante proceder à reserva de bens suficientes ao pagamento”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1545).

326

Art. 1.019. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento.

327

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

328

Bibliografia: Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014.

329

Art. 1.912. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão.

330

Art. 1.020. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio: I – quando toda a herança for dividida em legados; II – quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados.

331

Nesse sentido: Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, T. XIV. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 183-185.

332

Rodrigo Ramina de Lucca, embasado em lição de Pontes de Miranda, aponta que: *“A legitimidade do legatário não está limitada à prévia demonstração de que o pagamento da dívida reduzirá o seu legado. Deve-se reconhecer a legitimidade do legatário sempre que o pagamento puder, em tese, importar a redução”*. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São

333

“Como a venda de bem do espólio depende de prévia autorização judicial (CC 1.793 § 3.º), é comum o pedido de venda de algum bem do espólio para atender às despesas do inventário e pagamento dos tributos, caso em que é dispensável a concordância dos herdeiros”. (Maria Berenice Dias, Manual das Sucessões, 2.ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 538)

334

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I – alienar bens de qualquer espécie; II – transigir em juízo ou fora dele; III – pagar dívidas do espólio; IV – fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

335

Interessante pontuar, nesse aspecto, que a jurisprudência admite, inclusive, que essas vendas autorizadas destinem-se ao pagamento de despesas processuais, incluindo os honorários de peritos. Veja-se: Processo de inventário. Reavaliação dos bens do espólio. Honorários do perito. Ausência de elementos capazes de convencer acerca do excesso. Valor proposto mantido. No inventário, decorrido longo período da avaliação, presente uma realidade econômica corrosiva da moeda, e considerando a igualdade na partilha, prevista no art. 1.775 do Código Civil, não agride a nenhum dispositivo de lei federal o comando judicial para que nova avaliação seja feita (STJ, Resp 34880 / PR, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 13.9.2001). Por outro lado, tratando-se de comarca pequena, carente de corretores de imóveis, ainda sem provas de que o valor pedido pelo experto é abusivo em confronto com o mercado, mormente devido ao extenso estudo a realizar, deve ser rejeitada a impugnação aos honorários pedidos pelo experto. Alienação de imóvel da herança. Possibilidade de emprego do valor para cobertura das despesas processuais, inclusive a prova técnica. Recurso parcialmente provido. A venda de imóvel integrante do acervo do espólio é perfeitamente possível, bastando verificar a concordância dos demais herdeiros e a satisfação de tributos, *ex vi* do art. 992 do CPC (Cf. Agravo de Instrumento n. 2006.021268-9, de Blumenau, de minha relatoria). Além disso, o produto pode servir ao pagamento de despesas processuais, no que se inclui a perícia técnica, mormente num contexto em que o elemento vem em proveito dos herdeiros, e nem poderia ser quitado pela pessoa física da inventariante, mera administradora da herança (art. 991 do CPC). (AI n. 2010.075821-2, rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. em 22-03-2011).

336

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

337

Art. 1.021. Sem prejuízo do disposto no art. 674, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os nomeie à penhora no processo em que o espólio for executado.

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I – alienar bens de qualquer espécie; II – transigir em juízo ou fora dele; III – pagar dívidas do espólio; IV – fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Bibliografia: Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2.^a ed. São Paulo: Ed. RT, 2011. Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

Luiz Paulo Vieira de Carvalho, ao abordar a temática da partilha, assinala: “*Trata-se de direito potestativo do interessado na sucessão, e pelo fato de antes dessa divisão de bens estes se encontrarem em uma situação de comunhão, é também um direito que possui a natureza, os caracteres e a estrutura do poder conferido ao condômino de promover a extinção do condomínio*”. (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 919).

“Quando, porém, a devolução hereditária apanha diversas pessoas, passam-se os fatos, por outro modo, e faz-se necessário determinar, com exatidão, qual a verdadeira posição jurídica em que, então, se acham elas, por força da vocação hereditária. [...] É necessário, portanto, fazer a divisão dos bens comuns entre esses consenhores, segundo os direitos respectivos. Essa operação toma, em direito, o nome de partilha, que consiste na divisão dos bens da herança segundo o direito hereditário dos que sucedem, e na consequente e imediata adjudicação dos quocientes assim obtidos, aos diferentes herdeiros. Seu escopo foi claramente indicado pelos romanos numa frase tão simples quanto suficiente – *singulas res singulis heredibus adjudicare*”. (Clovis Bevilacqua, *Direito das sucessões*. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978, p. 373-374).

“A partilha amigável se sustenta em uma base contratual e está atrelada à manifestação de vontade dos herdeiros capazes, que podem livremente estabelecer as condições da divisão do acervo patrimonial deixado pelo autor da herança. (...) Se todos os herdeiros forem capazes e houver consenso, a partilha amigável poderá ser efetivada por três modos distintos, que conduzem ao mesmo resultado final: a escritura pública, o termo nos autos do inventário e o escrito particular”. (Francisco José Cahali, *Escrituras públicas: separação, divórcio, inventário e partilha consensuais: análise civil, processual civil, tributária e notarial*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 104-105).

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1.º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2.º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2.º do art. 662.

344

Em voto vencido, a Min^a. Nancy Andrighi realça os limites de cognição horizontal do juiz: “o Juiz do inventário somente deve processar e julgar questões inerentes ao objeto do inventário e da partilha. Outras questões, notadamente aquelas caracterizadas como sendo de alta indagação ou que dependam de outras provas, estão fora da competência do juízo do inventário”. (STJ, REsp 1438576/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2014).

345

“Não havendo acordo entre os sucessores, ou havendo sucessor incapaz, que não possa manifestar sua concordância em relação à divisão dos bens, impõe-se a atividade jurisdicional para distribuir os bens. Tem-se aí a partilha judicial, consistente na atividade do juiz, substituindo a vontade ou a atuação dos interessados, tendente a distribuir entre eles os bens do falecido. Essa partilha ocorrerá no curso do procedimento judicial de inventário ou, dependendo do caso, no rito abreviado do arrolamento comum”. (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Procedimentos Especiais. 3.^a ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 141)

346

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

347

Art. 1.022. Cumprido o disposto no art. 1.017, § 3.º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 10 (dez) dias, formulem o pedido de quinhão; em seguida proferirá, no prazo de 10 (dez) dias, o despacho de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário.

348

Pontes de Miranda, por esse motivo, chegou a afirmar que a decisão ser denominada determinação de partilha (Comentários ao Código de Processo Civil, T XIV, Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 199).

349

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

350

Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

351

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

352

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

353

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

354

Rodrigo Ramina de Lucca tece sua crítica: “Os requisitos legais para o deferimento são apenas dois: o bem deve integrar o quinhão do herdeiro ao final da partilha e o herdeiro deverá responsabilizar-se integralmente pelos ônus inerentes à sua conservação. O legislador poderia ter disciplinado melhor a matéria em artigo próprio, especificando as hipóteses em que o uso e fruição podem ser concedidos antecipadamente. Da forma como o dispositivo está redigido, não se exige do herdeiro demonstração de necessidade ou comprovação do periculum in mora para concessão do uso e da fruição antecipados. Entretanto, não está claro se as faculdades podem ser concedidas mesmo quando houver disputa pelo bem entre mais de um coerdeiro. Uma interpretação apressada poderia levar à conclusão de que essa é uma hipótese concreta de julgamento antecipado parcial do mérito por incontrovérsia do pedido (art. 355, I, do NCPC), i.e., uma partilha antecipada parcial. Ocorre que o julgamento antecipado parcial do mérito possui eficácia imediata e, se fosse esse o caso do dispositivo em análise, o herdeiro teria condições de obter a pronta transferência da propriedade ao seu nome. A hipótese, porém, limita-se à concessão antecipada de uso e fruição, permanecendo o bem no acervo hereditário. Também é difícil de caracterizar o instituto como autêntica tutela antecipada por se tratar de decisão taxativa: apenas se concedem o uso a fruição se o bem integrar futuramente o quinhão do herdeiro. Há, portanto, uma situação híbrida. O uso e fruição são concedidos antecipadamente, mas a partir de uma decisão definitiva de quem será o destinatário do bem. Sendo assim, diante da omissão legislativo, parecem aceitáveis duas conclusões distintas. O uso e fruição são concedidas ao herdeiro, independentemente de demonstração do periculum in mora, quando não houver disputa sobre o bem. E, havendo disputa, as faculdades podem ser concedidas como tutela de urgência, obedecendo-se aos requisitos legais (art. 300 do NCPC)”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1548-1549).

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2.º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3.º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

§ 1.º Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria.

Art. 505. Na partilha serão observadas as seguintes regras: I – a maior igualdade possível, seja quanto ao valor, seja quanto à natureza e qualidade dos bens; II – a prevenção de litígios futuros; III – a maior comodidade dos coerdeiros.

Segundo dispõe o art. 505 do CPC de 1939: “Na partilha serão observadas as seguintes regras: I – a maior igualdade possível, seja quanto ao valor, seja quanto à natureza e qualidade dos bens; II – a prevenção de litigious futuros; III – a maior comodidade dos coerdeiros;

Rodrigo Romina de Lucca diferencia a igualdade da partilha da igualdade de quinhões: “A maior igualdade possível é o critério básico e indispensável da partilha do acervo hereditário entre os herdeiros. Não se deve confundir, porém, a igualdade da partilha com a igualdade dos quinhões. Nem sempre os sucessores possuem quinhões idênticos. A igualdade a que o inc. I se refere é a igualdade material da partilha, de forma a proporcionar a maior correspondência possível entre o quinhão do sucessor e os bens que lhe foram destinados. Como muito bem aponta o dispositivo, o valor do bem não é o único critério a nortear a partilha. Liquidez, perspectiva de valorização, localização, utilidade ao sucessor etc, são características que aumentam ou reduzem a desejabilidade do bem e que devem ser considerados em uma partilha isonômica”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1550).

Rodrigo Ramina de Luca define: “A maior comodidade das partes está relacionada com a utilidade do bem àquele que se o destinou. [...] A partilha deve buscar a maior satisfação possível das partes e, para isso, deve atentar-se à utilidade do bem destinado a cada uma delas”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1550).

Bibliografia: Clovis Bevilacqua, *Direito das sucessões*. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978. Francisco José Cahali, *Escrituras públicas: separação, divórcio, inventário e partilha consensuais: análise civil, processual civil, tributária e notarial*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2008. Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, T XIV, Rio de Janeiro: Forense, 1977. Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

Art. 503. Os bens não susceptíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos na forma dos arts. 704 a 706, partilhando-se o preço, salvo quando os interessados preferiram arrendá-los, administrá-los ou possuí-los em comum, ou si qualquer herdeiro, ou o cônjuge sobrevivente, requerer a respectiva adjudicação, repondo, em dinheiro, a diferença. Parágrafo único. Requerida a adjudicação por dois (2) ou mais interessados, sem que seja possível acordo entre eles, o juiz marcará dia e mandará citar os interessados para proceder-se à licitação entre o cônjuge sobrevivente e os coerdeiros, incluindo-se os bens no quinhão de quem oferecer maior lance.

Art. 1.117. Também serão alienados em leilão, procedendo-se como nos artigos antecedentes: I – o imóvel que, na partilha, não couber no quinhão de um só herdeiro ou não admitir divisão cômoda, salvo se adjudicando a um ou mais herdeiros acordes; II – a coisa comum indivisível ou que, pela divisão, se tornar imprópria ao seu destino, verificada previamente a existência de desacordo quanto à adjudicação a um dos condôminos; III – os bens móveis e imóveis de órfãos nos casos em que a lei o permite e mediante autorização do juiz.

Benedicto de Vasconcellos Luna Gonçalves Patrão entende que no “caso especial de concorrência com prole híbrida do falecido, devemos reconhecer que a solução para eventual conflito interpretativo está na compreensão do atual sistema jurídico, inserido dentro de um determinado contexto, permeado pela irradiação dos valores constitucionais, dentre eles, em especial, o princípio da afetividade. Portanto, não há dúvidas de que a melhor solução para a partilha dos bens da herança é conceder ao cônjuge a garantia à reserva mínima. Afinal, conforme exposto, diante da elevação do cônjuge à categoria de herdeiro necessário,

é evidente a primazia da afetividade como valor constitucional, principalmente se for considerada que, ao se adotar o presente entendimento, ambas as facetas do afeto serão concomitantemente prestigiadas: a igualdade entre os filhos e a valorização do cônjuge”. (Benedicto de Vasconcellos Luna Gonçalves Patrão, A concorrência sucessória entre o cônjuge sobrevivente e os descendentes na partilha de bens. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 10, n. 39, p. 43-60, jul./set. 2009, p. 59).

365

Art. 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.

366

Art. 649. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos.

367

Luiz Paulo de Vieira Carvalho assinala: *“Em havendo bens indivisíveis, ou, como prefere denominar a lei, insuscetíveis de divisão cômoda (por exemplo uma casa residencial), o legislador impõe a feitura dos seguintes procedimentos: (i) se os bens indivisíveis não couberem na meação do cônjuge ou no quinhão do herdeiro, deverão ser vendidos, mediante determinação judicial, em hasta pública, partilhando-se o produto entre eles (art. 2.019, caput, do CC/2002; (ii) a torna ou reposição, na hipótese de haver requerimento pelo cônjuge ou por um herdeiro para que sejam adjudicados os bens indivisíveis, desse modo repondo o sucessor o excesso do valor avaliado previamente de seu quinhão aos demais coerdeiros; (iii) a licitação, quando a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, a ser realizada mediante a venda em hasta pública do bem que não pode ser comodamente partilhado ou que não caiba no quinhão de um só herdeiro”*. (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 923).

368

§ 1.º Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada.

369

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. § 1.º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido: I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II – por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos; III – por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1.º do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos. § 2.º Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no art. 274, parágrafo único. § 3.º Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1.º. § 4.º Se o valor do crédito for: I – inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado; II – superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. § 5.º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incs. II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. § 6.º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. § 7.º No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.

Art. 1.117. Também serão alienados em leilão, procedendo-se como nos artigos antecedentes: I – o imóvel que, na partilha, não couber no quinhão de um só herdeiro ou não admitir divisão cômoda, salvo se adjudicando a um ou mais herdeiros acordes;

Rodrigo Ramina de Lucca tece sua crítica: “*Além disso, a adjudicação em condomínio a apenas algumas das partes do inventário não implica, necessariamente danos às demais, tratando-se de situação a ser dirimida concretamente. De qualquer forma, havendo consenso entre todas as partes do inventário, será possível adjudicar o bem a apenas alguns dos sucessores em condomínio (art. 190 do NCPC). A alienação judicial será impositiva, contudo, quando houver disputa sobre o bem por grupos de sucessores ou desaprovação de algum sucessor à adjudicação a apenas alguns herdeiros – configurando grave retrocesso do NCPC*”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1552).

Art. 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras: I – a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II – a prevenção de litígios futuros; III – a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.

Bibliografia: Benedicto de Vasconcellos Luna Gonçalves Patrão, A concorrência sucessória entre o cônjuge

sobrevivente e os descendentes na partilha de bens. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, v. 10, n. 39, p. 43-60, jul./set. 2009. Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014. Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

375

Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão.

376

Maria Berenice Dias chama a atenção para o seguinte aspecto: “*Em face das novas técnicas de reprodução assistida, há toda uma nova discussão sobre o conceito de nascituro. Tratando-se de fecundação in vitro, realizada em laboratório, questiona-se se há necessidade de implementação do embrião, no útero materno, para que se possa falar em nascituro: pessoa por nascer*”. (Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 121).

377

“*O nosso legislador expressamente confere ao nascituro (nasciturus), isto é, ao ser já concebido (conceptus), mas ainda não nascido, capacidade ou legitimação especial para ser contemplado com herança legal ou testamentária, ou, então, com legado (parte final do art. 1.798 do CC), ou seja, capacidade para ser sucessor hereditário, independentemente da discussão acerca da ausência ou não de personalidade ao mesmo, dentro do princípio extraído das fontes romanas conceptus pro jam nato habetur quoties de eius commodo agitur (o nascituro é tido como já nascido quando se tratar de seus interesses)*”. (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 163).

378

Art. 1.123. É lícito às partes, a qualquer tempo, no curso da separação judicial, lhe requererem a conversão em separação consensual; caso em que será observado o disposto no art. 1.121 e primeira parte do § 1.º do artigo antecedente.

379

Art. 1.124. Homologada a separação consensual, averbar-se-á a sentença no registro civil e, havendo bens imóveis, na circunscrição onde se acham registrados.

380

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV

– garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1.º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2.º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3.º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4.º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5.º É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. § 5.º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei 13.256, de 2016). I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6.º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

381

Art. 1.125. Ao receber testamento cerrado, o juiz, após verificar se está intacto, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença de quem o entregou. Parágrafo único. Lavrar-se-á em seguida o ato de abertura que, rubricado pelo juiz e assinado pelo apresentante, mencionará: I – a data e o lugar em que o testamento foi aberto; II – o nome do apresentante e como houve ele o testamento; III – a data e o lugar do falecimento do testador; IV – qualquer circunstância digna de nota, encontrada no invólucro ou no interior do testamento.

382

Art. 1.126. Concluídos os autos, o juiz, ouvido o órgão do Ministério Público, mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento, se lhe não achar vício externo, que o torne suspeito de nulidade ou falsidade. Parágrafo único. O testamento será registrado e arquivado no cartório a que tocar, dele remetendo o escrivão uma cópia, no prazo de 8 (oito) dias, à repartição fiscal.

383

Enunciado 71 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “(art. 654; art. 300, § 1.º) Poderá ser dispensada a garantia mencionada no parágrafo único do art. 654, para efeito de julgamento da partilha, se a parte hipossuficiente não puder oferecê-la, aplicando-se por analogia o disposto no art. 300, § 1.º. (Grupo: Procedimentos Especiais; redação revista no III FPPC-Rio)”.

384

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1.º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2.º Se as questões referidas no § 1.º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3.º O disposto no *caput* deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

385

“(…) é possível que, em havendo vício de consentimento (ou inexistência de consentimento, no caso de participação de incapaz no acordo), a partilha amigável seja anulada por meio de ação própria. (...) Do mesmo modo, a partilha judicial – que decorre não da vontade das partes, mas de decisão judicial – pode ser anulada se houver dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, se não forem obedecidas as formalidades legais ou se houve preterimento de herdeiro ou inclusão de quem não seja”. (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 144).

386

Bibliografia: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

387

Art. 1.127. Feito o registro, o escrivão intimará o testamenteiro nomeado a assinar, no prazo de 5 (cinco) dias, o termo da testamentaria; se não houver testamenteiro nomeado, estiver ele ausente ou não aceitar o encargo, o escrivão certificará a ocorrência e fará os autos conclusos; caso em que o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. Parágrafo único. Assinado o termo de aceitação da testamentaria, o escrivão extrairá cópia autêntica do testamento para ser juntada aos autos de inventário ou de arrecadação da herança.

388

Art. 9.º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos. II e III; III – à decisão prevista no art. 701.

389

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

390

Estabelece o enunciado 138 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis que: 138. “(art. 657; art. 966, § 4.º; art. 1.068) A partilha amigável extrajudicial e a partilha amigável judicial homologada por decisão ainda não transitada em julgado são impugnáveis por ação anulatória. (Grupo: Coisa Julgada, Ação Rescisória e Sentença)”.

391

No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart lecionam: *“Esta ação, embora atinja sentença homologatória, porque se dirige mais especificamente contra a partilha realizada, não segue o rito da rescisória, mas sim da ação anulatória”.* (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart,

392

§ 4.º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

393

Civil e processual. Inventário. Partilha amigável. Vício de vontade. Erro. Ação anulatória. Prescrição anual. Termo inicial. Homologação por sentença. CPC, art. 1.029. Exegese. I. Ainda que decorrente de acordo, como ele somente produz efeitos jurídicos quando da sua homologação pelo juízo, é dessa data que deve ser contado o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 1.029, II, do CPC. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e improvido. (STJ, 4.ª T. Resp 168399/RS, rel. Min. Aldir Passarinho, j. 03.05.2001).

394

Art. 1.029. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada, por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz. (Redação dada pela Lei 5.925, de 1º.10.1973). Parágrafo único. O direito de propor ação anulatória de partilha amigável prescreve em 1 (um) ano, contado este prazo:

I – no caso de coação, do dia em que ela cessou; II – no de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato; III – quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade.

395

Bibliografia: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

396

Consoante o enunciado 137 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “(art. 658; art. 966, § 4.º; art. 1.068) Contra sentença transitada em julgado que resolve partilha, ainda que homologatória, cabe ação rescisória. (Grupo: Coisa Julgada, Ação Rescisória e Sentença)”. O enunciado 183, por sua vez, estabelece: “(art. 658) A ação rescisória de partilha com fundamento na preterição de herdeiro, prevista no inc. III do art. 658, está vinculada à hipótese do art. 628, não se confundindo com a ação de petição de herança (art. 1.824 do Código Civil), cujo fundamento é o reconhecimento do direito sucessório e a restituição da herança por aquele que não participou, de qualquer forma, do processo de inventário e partilha. (Grupo: Procedimentos Especiais)”.

397

Em caso de se verificar algum dos vícios de consentimento a macular a partilha amigável, ter-se-á hipótese para anulação da mesma. No que concerne ao prazo para a propositura de ação visando a anulação,

esclarece José Miguel Garcia Medina: “Trata-se de prazo decadencial, em razão da natureza desconstitutiva da ação que deverá ser movida na hipótese. No caso de nulidade absoluta da partilha, porém, se está diante de vício que não se convalida, e que, por constituir matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício pelo juiz. Neste caso, o ajuizamento da ação não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial. Tais vícios incidem no plano da validade do ato jurídico. Nada impede, no entanto, que se esteja diante de vício que afete a própria existência jurídica da partilha amigável. É o que ocorre, por exemplo, quando a partilha é realizada sem a presença de um dos herdeiros”. Mais adiante, o autor tece a sua crítica a respeito da estipulação de qualquer prazo prescricional referente a herdeiro que não participou da partilha: “(...) é duvidoso que a partilha realizada possa produzir algum efeito em relação ao herdeiro que dela não participou. Por tal razão, sua pretensão não deveria se sujeitar a tal prazo, porquanto a partilha realizada será juridicamente inexistente, não produzindo efeitos em relação ao herdeiro preterido”. (José Miguel Garcia Medina, Desconstituição da partilha: aspectos controvertidos. *Revista Jurídica Consulex*, Brasília, CONSULEX v. 173, mar. 2004, p. 48-49, p. 48).

398

“A ação rescisória, julgamento de julgamento como tal, não se passa dentro do processo em que se proferiu a decisão rescindenda. Nasce fora, em plano pré-processual, desenvolve-se em torno da decisão rescindenda, e, somente ao desconstituí-la, cortá-la, rescindi-la, é que abre, no extremo da relação jurídica examinada, se se trata de decisão terminativa do feito, com julgamento, ou não, do mérito, ou desde algum momento dela, ou no seu próprio começo [...] a relação jurídica processual”. Mais adiante, define o autor em sua clássica obra: “há julgamento de julgamento. É, pois, processo sobre outro processo. Nela, e por ela, não se examina o direito de alguém, mas a sentença passada em julgado” (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Tratado da Ação rescisória*. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1998, p. 84 e p. 135).

399

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV – ofender a coisa julgada; V – violar manifestamente norma jurídica; VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1.º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2.º Nas hipóteses previstas nos incisos do *caput*, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I – nova propositura da demanda; ou II – admissibilidade do recurso correspondente. § 3.º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4.º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5.º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do *caput* deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei

13.256, de 2016) § 6.º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5.º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei 13.256, de 2016).

400

Art. 1.030. É rescindível a partilha julgada por sentença: I – nos casos mencionados no artigo antecedente; II – se feita com preterição de formalidades legais; III – se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.

401

“Assim, como sucede em relação à partilha amigável, também a sentença proferida em partilha judicial pode ser atingida por vício que alcance no plano de existência, tal como acontece quando da não-participação de um dos herdeiros. Neste caso, como já se disse, se estará diante de inexistência jurídica, podendo o herdeiro preterido impugnar a partilha judicial a qualquer tempo. A sentença juridicamente inexistente pode ter tal condição reconhecida em ação meramente declaratória, também chamada de querela nullitatis insanabilis”. (José Miguel Garcia Medina, Desconstituição da partilha: aspectos controvertidos. *Revista Jurídica Consulex*, Brasília, CONSULEX v. 173, mar. 2004, p. 48-49). Necessário apontar, contudo, que há orientação jurisprudencial em sentido diverso ao defendido pelo autor.

402

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1.º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2.º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3.º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.

403

Nessa situação, José Miguel Garcia Medina sustenta que: *“(...) mostra-se dispensável até mesmo o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de partilha, na hipótese. O vício é de tal envergadura que pode ser conhecido pelo juízo que proferiu a sentença sobre a partilha mediante provocação da parte realizada por simples petição. Corretamente tem-se decidido, em tais situações, que, jugado procedente o pedido em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança, ao herdeiro preterido em partilha realizada anteriormente basta a apresentação de requerimento ao juiz para que se proceda a retificação da partilha. Neste caso, pode ocorrer os bens que integram o quinhão hereditário já tenham sido alienados a terceiros de boa-fé pelos herdeiros que participam da partilha. Orienta-se a jurisprudência, na hipótese, no sentido de que os herdeiros de boa-fé não podem ser atingidos pela anulação ou retificação da partilha. O herdeiro que não participou da partilha deverá buscar, assim, contra os demais herdeiros a indenização respectiva”.* José Miguel Garcia Medina, Desconstituição da partilha: aspectos controvertidos. *Revista Jurídica Consulex*, Brasília, CONSULEX v. 173, mar. 2004, p. 48-49, p. 49). Com efeito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Processo civil. Ação de investigação de paternidade

cumulada competição de herança. Procedência de ambos os pedidos. Partilha realizada sem a presença e participação do autor, reconhecido filho-herdeiro. Nulidade *pleno iure*. Desnecessidade de que seja proclamada expressamente em ação própria. Execução. Lição doutrinária. Ação ajuizada com intuito de haver a respectiva quota-parte. Possibilidade de aproveitá-la. Instrumentalidade do processo e a forismo *pas de nullite sans grief*. Interesse de agir. Prazos prescricionais. Inaplicabilidade do disposto no art. 1.805 c/c 178, par. 6., v, cc. inoponibilidade da exceção de coisa julgada. Recurso desacolhido. i – julgados procedentes os pedidos formulados em sede de ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança, disso resulta lógica e automática a nulidade da partilha realizada sem a presença e participação do autor vitorioso, afigurando-se dispensável a propositura de ação específica que tenha por objeto apenas ve-la reconhecida expressamente. ii – a execução da decisão de procedência proferida em autos de petição de herança faz-se, como regra, por meio de simples pedido de retificação de partilha, uma vez que a sentença homologatória de partilha não faz coisa julgada em relação ao herdeiro não convocado ao processo de inventário (art. 472, CPC). (STJ, REsp 16137/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 21.02.1995.

404

Art. 658. É rescindível a partilha julgada por sentença: I – nos casos mencionados no art. 657; II – se feita com preterição de formalidades legais; III – se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.

405

Bibliografia: José Miguel Garcia MEDINA, Desconstituição da partilha: aspectos controvertidos. *Revista Jurídica Consulex*, Brasília, CONSULEX v. 173, mar. 2004, p. 48-49.

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, Procedimentos Especiais. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Tratado da Ação rescisória*. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1998.

406

“O rito de arrolamento é previsto como uma abreviação do inventário, para causas menos complexas, em que seriam exageradas as exigências formais – de cálculos e complexa interação entre as partes”. (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 144).

407

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. § 1.º Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) dias. § 2.º Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3.º Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4.º Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da

propriedade dos bens do espólio. § 5.º Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.

408

Art. 665. O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público.

409

Art. 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade.

410

Art. 1.036. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente da assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição do valor dos bens do espólio e o plano da partilha. § 1.º Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará um avaliador que oferecerá laudo em 10 (dez) dias. § 2.º Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3.º Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz e pelas partes presentes. § 4.º Aplicam-se a esta espécie de arrolamento, no que couberem, as disposições do art. 1.034 e seus parágrafos, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 5.º Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.

411

§ 2.º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos.

412

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

413

Bibliografia: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, Procedimentos Especiais. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

414

“No arrolamento, não há a figura das primeiras (ou das últimas) declarações. Nomeado o inventariante (segundo a indicação dos próprios herdeiros, em comum acordo), cumpre apresentar o plano de partilha

(*previamente acordado pelos herdeiros*), ou o *pedido de adjudicação (no caso de um único herdeiro)*". (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 145).

415

Art. 630. Findo o prazo previsto no art. 627 sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no art. 620, § 1.º, o juiz nomeará perito para avaliação das quotas sociais ou apuração dos haveres.

416

Processual civil. Arrolamento de bens. Direito sucessório. Discussão a respeito do valor do imposto de transmissão pago por ausência de correção monetária. Impossibilidade. Lei 9.280/1996 que alterou o art. 1.031, CPC. Recurso desacolhido. Merece prestígio, mesmo na vigência da lei 9.280/1996, que alterou o art. 1.031, CPC, a jurisprudência deste tribunal no sentido de não se admitir, no arrolamento, questionamentos acerca do pagamento de tributos relativos a transmissão. (STJ, 4.ª T. REsp 36909/SP, Min. Sálvio F. Teixeira, j. em 12.11.96).

417

Processual civil. Recurso especial. Falta de prequestionamento. Arrolamento. Discussão sobre o pagamento de impostos. Impossibilidade. Suspensão. Expedição do formal de partilha. Quitação dos tributos. Precedentes. 1. O prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados constitui requisito indispensável à admissibilidade do recurso especial. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 1.034 do CPC, firmou entendimento de que não é possível a discussão de questões relativas a lançamento, pagamento e quitação de tributos no âmbito do arrolamento sumário. 3. A teor do que dispõe o art. 1.031, § 2.º, do CPC, somente após a juntada aos autos da prova do pagamento dos tributos é que o juiz homologará e expedirá o formal de partilha. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ, 2.ª T. REsp 434483/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. Em 03.08.2006).

418

Bibliografia: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

419

Art. 1.033. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.035 desta Lei, não se procederá a avaliação dos bens do espólio para qualquer finalidade.

420

"No arrolamento, não há avaliação dos bens, salvo no caso de impugnação por credor da estimativa dada aos bens arrolados (...). Também, nesse rito, é vedada a discussão sobre lançamento, pagamento e quitação de taxas judiciárias e tributos". (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*.

421

Bibliografia: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

422

Art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1.º A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2.º O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

423

Art. 1.035. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados.

424

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1.º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2.º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3.º Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4.º Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5.º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades.

425

Art. 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no *caput*, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento.

426

Art. 1.036. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante

nomeado, independentemente da assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição do valor dos bens do espólio e o plano da partilha. § 1.º Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará um avaliador que oferecerá laudo em 10 (dez) dias. § 2.º Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3.º Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz e pelas partes presentes. § 4.º Aplicam-se a esta espécie de arrolamento, no que couberem, as disposições do art. 1.034 e seus parágrafos, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 5.º Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.

427

Art. 1.033. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.035 desta Lei, não se procederá a avaliação dos bens do espólio para qualquer finalidade.

428

§ 5.º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2.º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo.

429

§ 2.º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo.

430

§ 3.º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2.º e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4.º Em qualquer das hipóteses do § 3.º: I – os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV – será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

431

Art. 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo.

432

Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando.

433

Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I – identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II – heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III – dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

434

“Antes de iniciada a partilha dos bens entre os sucessores, é necessário quitar eventuais dívidas deixadas pelo falecido. Isso porque o espólio continua responsável pelos débitos do falecido, ao passo que os herdeiros, depois de efetuada a partilha, não respondem por essas dívidas, a não ser até o limite da força da herança, ou seja, até o montante recebido como quinhão hereditário (art. 1.997 do CC/2002). Por isso, eventuais credores existentes do falecido podem habilitar seus créditos junto ao inventário, a fim de receber a importância a que têm direito antes de efetuada a partilha. Em princípio, somente dívidas exigíveis e vencidas podem ser pretendidas, havendo, entretanto, algumas espécies de crédito que não se sujeitam a esse regime para obter satisfação. Em caso de dívidas ainda não vencidas, mas certas, poderá ser requerida a reserva de valor suficiente para saldar a dívida, mas não o pronto pagamento”. (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 139-140).

435

Bibliografia: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

436

Art. 671. O juiz nomeará curador especial: II – ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses.

437

Art. 1.037. Independência de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Art. 1.038. Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das seções antecedentes, bem como as da seção subsequente.

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Art. 1.039. Cessa a eficácia das medidas cautelares previstas nas várias seções deste Capítulo: I – se a ação não for proposta em 30 (trinta) dias, contados da data em que da decisão foi intimado o impugnante (art. 1.000, parágrafo único), o herdeiro excluído (art. 1.001) ou o credor não admitido (art. 1.018); II – se o juiz declarar extinto o processo de inventário com ou sem julgamento do mérito.

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I – o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; II – não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; III – o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

“Ao examinar o procedimento, viu-se que o juiz pode, no curso do procedimento de inventário, determinar a adoção de medidas cautelares, especialmente para o fim de preservar os interesses de eventuais herdeiros preteridos ou de credores do espólio. Caberá, assim, a reserva de bens em favor dessas pessoas – ou de todas as que devam valer-se das vias ordinárias para demonstrar seus interesses legítimos –, a fim de assegurar-lhes a plena e pronta satisfação de seus direitos, se existentes”. (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 146).

§ 3.º Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. § 1.º Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz decidirá. § 2.º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I – o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; II – não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; III – o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

Bibliografia: Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

Art. 1.040. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens: I – sonegados; II – da herança que se descobrirem depois da partilha; III – litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV – situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos ns. III e IV deste artigo serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e administração do mesmo ou de diverso inventariante, a aprazimento da maioria dos herdeiros.

“Para dar celeridade à partilha, admite a lei que a divisão dos bens de difícil partição seja deixada para depois. Dividem-se os bens existentes e desembaraçados. Quando alguns estão situados em lugar remoto, ou são alvo de litígio ou de demorada e difícil liquidação, é possível realizar a partilha em momento posterior. Isso também ocorre quando surgem bens outros depois de ultimada a partilha. Em todos esses casos impõe-se a sobrepartilha (CC 2.021 e 2.022). Nada mais do que um complemento da partilha anteriormente feita, por ter havido omissão de bens que deveriam ser atribuídos aos sucessores”. (Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 585).

“Também estão sujeitos à sobrepartilha os bens reservados – para pagamento de créditos ou para satisfação de possível herdeiro – sempre que, depois da ação própria por este ajuizada, for ele derrotado, demonstrando que a reserva era desnecessária”. (Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 147).

“Nessa situação, ocorre uma complementação da partilha, partilha adicional ou nova partilha, com o objetivo de dar o destino aos bens inventariados não constantes de anterior divisão entre os herdeiros, podendo existir tantas sobrepartilhas quanto forem necessárias à contemplação da integralidade do falecido”. (Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 931).

Art. 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. § 1.º Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. § 2.º Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário, enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência.

Art. 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. § 1.º Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. § 2.º Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário, enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência.

Art.1.994. A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Parágrafo único. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados.

CIVIL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. BENS SONEGADOS. SOBREPARTILHA. Os bens sonegados na separação judicial sujeitam-se à sobrepartilha; se a finalidade visada é a de integrar no patrimônio comum bens que nela deixaram de ser arrolados, não há necessidade de anular a partilha. Recurso especial não conhecido. (STJ, 3.ª T. REsp 770709/SC, rel. Min. Ari Pargendler j. em 20.05.2008).

Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1.º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. § 2.º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as

partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

457

Art. 1.045. Nos casos previstos nos dois artigos antecedentes prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se se alterou o valor dos bens. Parágrafo único. No inventário a que se proceder por morte do cônjuge herdeiro supérstite, é lícito, independentemente de sobrepartilha, descrever e partilhar bens omitidos no inventário do cônjuge pré-morto.

458

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

459

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA E REGISTRADA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 486 DO CPC. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO EM EXECUÇÃO APARELHADA POR CREDOR QUIROGRAFÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 698 DO CPC. INEFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO EM RELAÇÃO AO CREDOR HIPOTECÁRIO (ART. 619 DO CPC), E NÃO SUA NULIDADE. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o acórdão impugnado examina e decide, de forma motivada e suficiente, as questões relevantes para o desate da lide. 2. É inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil se os embargos declaratórios não tiveram o propósito manifesto de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula 98STJ. 3. Não se configura o julgamento extra petita quando, após interpretação lógico-sistemática das questões suscitadas pela parte, o julgador chega a conclusão diversa daquela expressamente consignada no capítulo “dos pedidos”, da peça inaugural. 4. Uma vez expedida a carta de arrematação e transferida a propriedade com o registro no cartório imobiliário, não é possível a desconstituição do ato nos próprios autos da execução, sendo necessário o ajuizamento da ação anulatória (art. 486 do CPC). 5. Conquanto o art. 698 do CPC determine a prévia intimação do credor hipotecário para a adjudicação ou alienação do bem gravado, não traz cominação de nulidade para o caso de sua inobservância. Tal circunstância atrai a regra do art. 244 do CPC, que, aliada à ausência de prejuízo, induz à aplicação do princípio do aproveitamento racional dos atos processuais, evitando a declaração de nulidade da arrematação. 6. A ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia. Interpretação do art. 698 do CPC que melhor se coaduna com os arts. 619 do CPC e 826 do CC16 (equivalente ao art. 1.501 do CC2002). Fica assegurado o direito de regresso do arrematante contra o devedor. 7. Recursos especiais parcialmente providos. (STJ, REsp 1219329/RJ Min João Otávio de Noronha, DJ de 29.04.2014).

460

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

461

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

462

Maria Berenice Dias apresenta posicionamento divergente, sustentando: “*Não há limitação quanto ao número de sobrepartilhas, tampouco limite temporal para que ocorram. Quando é preterida a partilha de bens litigiosos e dos situados em lugares remotos, persistem as atribuições do inventariante mesmo depois de ultimado o inventário*”. (Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 585-586).

463

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV – o herdeiro menor, por seu representante legal; V – o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI – o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII – o inventariante judicial, se houver; VIII – pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

464

Bibliografia: Maria Berenice Dias, *Manual das Sucessões*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011. Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos Especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012. Luiz Paulo Vieira de Carvalho, *Direito das Sucessões*, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014.

465

Art. 1.041. Observar-se-á na sobrepartilha dos bens o processo de inventário e partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.

466

“*A legitimidade para pedir a sobrepartilha é idêntica àquela para pedir o inventário*”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1569).

467

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SOBREPARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. Conforme o

disposto no parágrafo único do art. 1.041 do Código de Processo Civil, a sobrepartilha deve correr nos autos do inventário do autor da herança, assim, compete ao juízo que processou e julgou inventário processar e julgar ação de sobrepartilha. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA ÓRFÃOS E SUCESSÕES INFÂNCIA E JUVENTUDE E PRIMEIRO CÍVEL DE PLANALTINA – GO. (STJ, 2.ª seção, CC 54801/DF, Min. Sidnei Beneti, j. Em 25.05.2009).

468

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611.

Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança.

469

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: I – o cônjuge ou companheiro supérstite;

II – o herdeiro; III – o legatário; IV – o testamentário; V – o cessionário do herdeiro ou do legatário; VI – o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; VII – o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; VIII – a Fazenda Pública, quando tiver interesse; IX – o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

470

Recurso especial – Processual Civil – Dissídio jurisprudencial – Comprovação – Espólio – Sentença que homologa a partilha – Trânsito em julgado – Art. 1.040, III e IV, do CPC – Bens sujeitos à sobrepartilha. I – Não se conhece o Recurso Especial pela divergência se inexistente a confrontação analítica exigida nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § 2.º, do RISTJ. II – Na hipótese de existirem bens sujeitos à sobrepartilha por serem litigiosos ou por estarem situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário, o espólio permanece existindo, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens do espólio. Recurso Especial a que se dá provimento, na parte em que foi conhecido. (STJ, REsp 284669/SP 3.ª T. rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 10.04.2001).

471

Art. 1.042. O juiz dará curador especial: I – ao ausente, se o não tiver; II – ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante.

472

PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE INVENTÁRIO – MENORES – DEFESA PROMOVIDA POR CURADOR – HONORÁRIOS. I – Incorre intempestividade, quando o recurso, à luz dos fatos certificados nos autos, é interposto no prazo legal. II – Em inventário, somente se nomeia curador para defesa de menores, quando houver colisão de interesses, não se fazendo necessário quando os infantes, representados pela genitora inventariante, esta exerce o pátrio poder. Tratando-se de *munus* público, não há pagamento de honorários. III – Matéria de prova (Súmula 07/STJ). IV – Recurso não conhecido (STJ, 3.ª T. REsp 139237/MG rel. Min. Waldemar Zveiter, j. em 15.02.2001).

473

No mesmo sentido: INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO. NULIDADE. HERDEIRO PRETERIDO. PRESCRIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. – Somente se justifica a nomeação de Curador Especial quando colidentes os interesses dos incapazes e os de seu representante legal. Precedentes do STJ. – “É de vinte anos o prazo da prescrição da ação de nulidade do herdeiro que não foi parte no ato de partilha” (REsp 45.693-2SP). Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 114.310-SP, rel. Min. Barros Monteiro, j. 17.10.2002).

474

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

475

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: II – réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

476

Bibliografia: Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

477

Art. 1.043. Falecendo o cônjuge meeiro supérstite antes da partilha dos bens do pré-morto, as duas heranças serão cumulativamente inventariadas e partilhadas, se os herdeiros de ambos forem os mesmos. § 1.º Haverá um só inventariante para os dois inventários. § 2.º O segundo inventário será distribuído por dependência, processando-se em apenso ao primeiro.

478

Sueli A. de Peri confere especial ênfase ao parágrafo único do art. 672 do novo diploma processual, o qual amplia a possibilidade de inventário cumulativo para além daquela contida no art. 1.044 do Código de Processo Civil de 1973, no qual somente era admissível a cumulação de inventários quando o herdeiro falecido na pendência do inventário primitivo não possuísse outros bens além de seu quinhão na herança. Leciona a autora que a referida alteração “*reflete a busca pelo processo mais dinâmico e enfatiza o princípio constitucional da celeridade processual, notadamente quando uma partilha depender da outra*”. (Sueli A. de Pieri, Inventário cumulativo no novo Código de Processo Civil e a busca pela celeridade processual. *Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões*, Porto Alegre, v. 2, n. 7, p. 82-99, jul./ago. 2015, p. 83).

479

Acentua Rodrigo Ramina de Lucca que: “*De maneira um pouco lacônica, o NCPC consolida tal entendimento ao retirar a referência a “cônjuge meeiro” e prever genericamente a cumulação de inventários de heranças*

deixadas por cônjuges ou companheiros, independentemente de confundirem-se, ou não, os bens”. Mais adiante o autor observa que: “Apesar de a expressão ‘É lícita a cumulação’ presente no caput do art. 672, é de se concluir que a cumulação de inventários é uma imposição legal. Se assim não fosse, não haveria razão para estabelecer uma exceção expressa à cumulação de inventários em caso de dependência meramente parcial (parágrafo único). Desse modo, sempre que verificadas as hipóteses legais, os inventários deverão ser cumulados, salvo quando houver dependência parcial entre as partilhas e os bens adicionais puderem tumultuar indevidamente o andamento do processo”. (Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1571).

480

Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I – identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II – heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III – dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

481

Art. 673. No caso previsto no art. 672, inciso II, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens.

482

Art. 1.043. Falecendo o cônjuge meeiro supérstite antes da partilha dos bens do pré-morto, as duas heranças serão cumulativamente inventariadas e partilhadas, se os herdeiros de ambos forem os mesmos. § 1.º Haverá um só inventariante para os dois inventários. § 2.º O segundo inventário será distribuído por dependência, processando-se em apenso ao primeiro.

483

Bibliografia: Sueli A. de Pieri, Inventário cumulativo no novo Código de Processo Civil e a busca pela celeridade processual. *Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões*, Porto Alegre, v. 2, n. 7, p. 82-99, jul./ago. 2015. Teresa Arruda Alvim Wambier et al. *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

484

Art. 1.045. Nos casos previstos nos dois artigos antecedentes prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se se alterou o valor dos bens.

Parágrafo único. No inventário a que se proceder por morte do cônjuge herdeiro supérstite, é lícito, independentemente de sobrepartilha, descrever e partilhar bens omitidos no inventário do cônjuge pré-morto.

485

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

87

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611.

201

Consoante determina a Súmula 112 do Supremo Tribunal Federal: “o impôsto de transmissão *causa mortis* é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão”.

293

Civil – Doações inoficiosas – Doação antenupcial e testamento – Violação da legitima. I – A parte inoficiosa, porque excedente da disponível, tem-se como nula a título de violação da legitima dos herdeiros necessários, por isso cabível e trazer a colação todos os bens da doação antenupcial e do testamento, para efeito do calculo do que fica como liberalidade (disponível) e do que vai para o acervo partilhavel (para os herdeiros necessários). II – Recurso não conhecido. (STJ, REsp 5325/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 20.11.1990).

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. IX - Marinoni - Ed. 2018

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albuquerque, Ana Rita Vieira. *Da função social da posse*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
- ALVES, Giselle Borges; FARIA, Thaíza Ribeiro de. Os direitos dos credores diante do inventário e partilha extrajudicial. *Revista IOB de Direito de Família*, n. 91. vol. 16. São Paulo: IOB, 2015.
- Alves, José Carlos Moreira. *Posse estudo dogmático*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. vol. II. t. I.
- ALVIM, Agostinho Neves de Arruda. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. São Paulo: Saraiva, 1949.
- ALVIM, Arruda; COUTO, Mônica Bonetti. *Comentários ao Código Civil brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2009. vol. XI. t. II.
- _____. *Manual de direito processual civil*. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. II.
- Amaral, Paulo Osternack. *Provas*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- ANTUNES VARELA, João de Matos. *Das obrigações em geral*. Rio de Janeiro: Forense, 1978. vol. II.
- Arenhart, Sérgio Cruz. *Perfis da tutela inibitória coletiva*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- _____; MARINONI, Luiz Guilherme. *Procedimentos especiais*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.
- ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa, et al (Org.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- Assis, Araken de. *Cumulação de ações*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O espírito de compromisso do direito das sucessões perante as exigências individualistas de autonomia da vontade e as supra-individualistas da família: herdeiro e legatário. *Revista Brasileira de Direito de Família*, vol. 4. Porto Alegre: Síntese, jan. 2000.
- BARBI, Celso Agrícola. Ação de consignação em pagamento e renovatória na nova Lei do Inquilinato. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). *Doutrinas essenciais obrigações e contratos*. São Paulo: Ed. RT, 2011. vol. V.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *O novo processo civil*. 21. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
- Barbosa, Ruy. *Posse de direitos pessoais*. São Paulo: Saraiva, 1986.
- BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de; TEPEDINO, Gustavo. *Código Civil*

interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. vol. I.

BARROS, Hamilton de Moraes e. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1977. vol. IX.

Batista, Francisco de Paula. *Compêndio de teoria e prática do processo civil*. Campinas: Russell, 2002.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Efetividade do processo e técnica processual*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

Bessone, Darcy. *Direitos reais*. São Paulo: Saraiva, 1988.

Beviláqua, Clóvis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado*. 9. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1953.

_____. *Direito das coisas*. 5. ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, sd.

_____. *Direito das sucessões*. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978.

BORTOLAI, Edson Cosac. *Da ação de prestação de contas*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1984.

BUENO, Cassio Scarpinella. *Novo Código de Processo Civil anotado*. São Paulo: Saraiva, 2015.

CAHALI, Francisco José. *Escrituras públicas: separação, divórcio, inventário e partilha consensuais: análise civil, processual civil, tributária e notarial*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2008.

CALDEIRA, Jorge. *História do Brasil com empreendedores*. São Paulo: Mameluco, 2009.

Calmon de Passos, José Joaquim. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 6. ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 1991. vol. III.

Camara Filho, Roberto Mattoso. *Posse e ações possessórias*. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

CARNEIRO, Athos Gusmão. *Intervenção de terceiros*. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001.

CARNEIRO FILHO, Humberto João. Inventário e partilha extrajudiciais no Código de Processo Civil de 2015: o resultado de um percurso histórico-dogmático. *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, n. 67, vol. 12., p. 59-73. Porto Alegre: Magister, jul./ago. 2015.

CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2006. vol. IX. t. II.

CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. *Direito das sucessões*. São Paulo: Atlas, 2014.

Casconi, Francisco Antonio. *Tutela antecipada nas ações possessórias*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.

COSER, José Reinaldo. *Direito das sucessões, do inventário e da partilha: anotações e prática*. 3. ed. rev. e ampl. Leme/SP: Edijur, 2014.

COUTO E SILVA, Clóvis do. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 1977. vol. XI. t. I.

DAL COL, Caio de Sá; DAL COL, João Roberto de Sá. A (des)necessidade da remessa de “suposta” questão de dependente de prova às vias ordinárias no processo de inventário: uma análise sob o enfoque do artigo 627 da redação final do novo CPC aprovada pela Câmara dos Deputados. *Revista Jurídica*, n. 446, vol. 62. Porto Alegre, p. 31-44, dez. 2014.

Delfino, Lúcio. A desnecessidade de demonstração da urgência para o deferimento de tutela antecipada possessória (posse nova). In: _____. *Direito processual civil : artigos e pareceres*. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011.

DIAS, Maria Berenice. *Manual das sucessões*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011.

DIDIER JUNIOR, Fredie. *Curso de direito processual civil*. 18. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. vol. I.

_____. *Curso de direito processual civil*. 17. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015.

_____. *Pressupostos processuais e condições da ação*. São Paulo: Saraiva, 2005.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Ação de prestação de contas, ação condenatória e litispendência. In: _____. *Fundamentos do processo civil moderno*. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. II.

_____. Ação demarcatória, coisa julgada, ação rescisória. In: _____. *Fundamentos do processo civil moderno*. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. t. II.

_____. *Instituições de direito processual civil*. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005. vol. II.

_____. *Litisconsórcio*. 2. ed. rev. São Paulo: Ed. RT, 1986.

_____; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. *Teoria geral do novo processo civil*. São Paulo: Malheiros, 2016.

Espínola, Eduardo. *Posse, propriedade, compropriedade ou condomínio. Direitos autorais*. Campinas: Bookseller, 2002.

Fabício, Adroaldo Furtado. Artigos 554-568. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JUNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; e DANTAS, Bruno (Coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 7. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 1995. vol. VIII. t. III.

FACHIN, Luiz Edson. *A função social da posse e a propriedade contemporânea*. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1988.

Faria, Juliana Cordeiro de. Artigos 284-293. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JUNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; e DANTAS, Bruno (Coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

FARIA, Werter. *Mora do devedor*. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1981.

Figueira Jr., Joel Dias. A exceção de domínio nos Código Civil e Processual Civil após o advento da Lei 6.820 de 16.9.80. *Revista de Processo*, n. 33. São Paulo: Ed. RT, jan./mar. 1984.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2001. vol. IV. t. I.

_____. *Liminares nas ações possessórias*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 1999.

Freyesleben, Luiz Eduardo Ribeiro. *A usucapião especial urbana*. 2. ed. rev. e ampl. Florianópolis: Obra Jurídica, 1998.

Fulgêncio, Tito. *Da posse e das ações possessórias*. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2000. vol. I.

GOMES, Fábio. *Carência da ação*. São Paulo: Ed. RT, 1999.

- GOMES, Orlando. *Direitos reais*. 19. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: 2004.
- _____. *Sucessões*. 16. ed. rev. e atual. por Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- HAYEK, Friedrich von. *Direito, legislação e liberdade*. São Paulo: Visão, 1985. vol. III.
- HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. *Morrer e suceder*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- Ihering, Rudolf von. *Teoria simplificada da posse*. São Paulo: Saraiva, 1986.
- INOCÊNCIO, Antônio Ferreira. *Inventários e partilhas: ações de herança*. 2. ed. São Paulo: Editora Jalovi Ltda., 1980.
- Karpat, Ladislau. *Tutela antecipada na defesa da posse e da propriedade imóvel*. Rio de Janeiro, 2003.
- Lamy, Eduardo de Avelar. *Princípio da fungibilidade no processo civil*. São Paulo: Dialética, 2007.
- Leite, Eduardo de Oliveira. *Comentários ao novo Código Civil*. 5. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2009. vol. XXI.
- LONGA, Daniel Pinheiro; SANTOS, Andressa Moura dos; MOTTA, Lorena Viana da. Aspectos práticos dos cartórios de títulos e documentos: procedimentos de inventário e divórcio extrajudiciais. *Ciência Jurídica*, n.182, vol. 29, p. 345-363. Belo Horizonte: Edições Ciência Jurídica, mar./abr. 2015.
- Lopes da COSTA, Alfredo de Araújo. *Demarcação, divisão, tapumes*. Belo Horizonte: Editora Bernardo Álvares S.A., 1963.
- Malachini, Edson Ribas. As ações (e sentenças) condenatórias, mandamentais e executivas. *Revista de Processo*, n. 125. São Paulo: Ed. RT, jul. 2005.
- Maranhão, Clayton. *Tutela jurisdicional do direito à saúde*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- MARCATO, Antônio Carlos. *Ação de consignação em pagamento*. 6. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 2001.
- _____. *Procedimentos especiais*. 13. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2008.
- Marinoni, Luiz Guilherme. *Tutela inibitória*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- _____. *A ética dos precedentes*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. *Antecipação da tutela*. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- _____. Da exceção de domínio no direito brasileiro (arts. 505 do CC e 923 do CPC). *Revista de Processo*, n. 53. São Paulo: Ed. RT, jan./mar. 1989.
- _____. *Técnica processual e tutela dos direitos*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- _____. *Tutela contra o ilícito*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. Arenhart, Sérgio Cruz. *Procedimentos especiais*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- _____; _____. Mitidiero, Daniel. *Novo curso de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. vol. II.
- _____; _____. MITIDIERO, Daniel. *Novo Código de Processo Civil comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

- Marmitt, Arnaldo. *Consignação em pagamento*. Rio de Janeiro: Aide, 1990.
- MARTINS-COSTA, Judith. *Comentários ao novo Código Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2003. vol. V. t. I.
- MEDINA, José Miguel Garcia. Desconstituição da partilha: aspectos controvertidos. *Revista Jurídica Consulex*, vol. 173. Brasília: Consulex, mar. 2004.
- Mitidiero, Daniel. *Antecipação da Tutela*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. *Colaboração no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- MONTEIRO, João Baptista. *Ação de reintegração de posse*. São Paulo: Ed. RT, 1987.
- MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de direito civil*. 34. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1998. vol. III.
- _____. *Curso de direito civil*. 29. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1997. vol. IV.
- MOTTA, Lorena Viana da; SANTOS, Andressa Moura dos; LONGA, Daniel Pinheiro. Aspectos práticos dos cartórios de títulos e documentos: procedimentos de inventário e divórcio extrajudiciais. *Ciência Jurídica*, n. 182, vol. 29, p. 345-363. Belo Horizonte: Edições Ciência Jurídica, mar./abr. 2015.
- NEGRÃO, Theotonio. *Comentários ao Novo Código de Processo Civil* [(CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.)]. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- NONATO, Orosimbo. *Curso de obrigações*. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Jurídica/Universitária, 1971.
- OLIVEIRA, Francisco Cardozo. *Hermenêutica e Tutela da posse e da propriedade*. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
- OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. *Ações possessórias enfoque sobre a cognição*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.
- OSNA, Gustavo. *Direitos individuais homogêneos*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- PACHECO, José da Silva. *Tratado das locações, ações de despejo e outras*. 9. ed. São Paulo: Ed. RT, 1994.
- PATRÃO, Benedicto de Vasconcellos Luna Gonçalves. A concorrência sucessória entre o cônjuge sobrevivente e os descendentes na partilha de bens. *Revista de Direito Privado*, n. 39, vol. 10, p. 43-60. São Paulo: Ed. RT, jul./set.2009.
- PEREIRA, Lafayette Rodrigues. *Direito das coisas*. Brasília/Senado Federal: Ed. Fac-Similar, 2004. vol. I.
- Pereira, Paula Pessoa. *Legitimidade dos precedentes*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- PIERI, Sueli A. de. Inventário cumulativo no novo Código de Processo Civil e a busca pela celeridade processual. *Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões*, n. 7, vol. 2, p. 82-99. Porto Alegre: Magister, jul./ago. 2015.
- Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1977. t. XIII.

- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1977. t. XIV.
- _____. *Tratado da Ação Rescisória*. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1998.
- _____. *Tratado das ações*. Campinas: Bookseller, 1999. t. I, II, VI e VII.
- _____. *Tratado de direito privado*. Atual. por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2011. t. LX.
- _____. *Tratado de direito privado*. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. t. X e XXIV
- PONTES, Tito Lívio. *Divisão, demarcação e tapume*. 2. ed. São Paulo: Editora Juriscred.
- RAMOS, Vitor de Paula. *Ônus da prova no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- RÁO, Vicente. *Posse de direitos pessoais: segundo o Código Civil*. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1980.
- REZENDE, Astolpho. *A posse e sua proteção*. 2. ed. São Paulo: Lejus, 2000.
- RIBAS, Antônio Joaquim. *Da posse e das ações possessórias*. Rio de Janeiro: H. Laemmert & Livreiros Editores, 1883.
- RIZZARDO, Arnaldo. *Direito das sucessões*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- ROCHA, Felipe Borring. *Código de Processo Civil e Legislação especial em vigor*. São Paulo: Saraiva, 2010.
- ROCHA, José de Moura. Anotações sobre a consignação em pagamento. *Revista de Processo*, n. 32. São Paulo: Ed. RT, out./dez. 1983.
- Rocha, Manoel Antônio Coelho da. *Instituições de direito civil*. São Paulo: Saraiva, 1972.
- SACCO NETO, Fernando. Da ação de dissolução parcial de sociedade. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa, et al (Org.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- SANTOS, Andressa Moura dos; LONGA, Daniel Pinheiro; MOTTA, Lorena Viana da. Aspectos práticos dos cartórios de títulos e documentos: procedimentos de inventário e divórcio extrajudiciais. *Ciência Jurídica*, n. 182, vol. 29, p. 345-363. Belo Horizonte: Edições Ciência Jurídica, mar./abr. 2015.
- Santos, Ernane Fidélis dos. *Manual de direito processual civil*. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. vol. III.
- SANTOS, Evaristo Aragão. Artigos 550-553. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JUNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- SATO, Priscila Kei. Artigos 539-549. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JUNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- SILVA, Júlio César Ballerini. Algumas questões acerca do inventário negativo de bens no direito brasileiro. *Juris Plenum*, n. 54, vol. 9, p. 105-114. Caxias do Sul: Editora Plenum, nov. 2013.
- Silva, Ovídio Araújo Baptista da. *Ação de imissão de posse*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. XIII.

- _____. *Curso de processo civil*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. II.
- SILVA, Ricardo Alexandre da. Atipicidade dos meios executivos na efetivação das decisões que reconheçam o dever de pagar quantia no novo CPC. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (Coord.). *Execução*. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016.
- _____. *Condenação e Cumprimento de Sentença*. São Paulo: Conceito, 2011.
- _____. Artigos 355-356. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JUNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- STAUT JÚNIOR, Sérgio Said. *A posse no direito brasileiro da segunda metade do século XIX ao Código Civil de 1916*. Tese de doutorado, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2009.
- TALAMINI, Eduardo. *Coisa julgada e sua revisão*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- TEIXEIRA, Silvia Maria Benedetti. A tributação no inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual com a vigência da Lei n. 11.441/2007. *Revista IOB de Direito de Família*, n. 44, vol. 9, p. 82-93. São Paulo: IOB, out./nov. 2007.
- TESSER, André Luiz Bäuml. *Tutela cautelar e antecipação de tutela*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- Theodoro Jr., Humberto. Artigos 569-598. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JUNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. *Curso de direito processual civil: procedimentos especiais*. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- _____. Inventário e partilha e separação e divórcio por via administrativa: reforma da Lei n. 11.441, de 04.01.2007. *Revista IOB de Direito de Família*, n. 44. vol. 9. p. 33-47. São Paulo: IOB, out./nov. 2007.
- _____. *Terras particulares*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
- TOSCAN, Anissara. *Preclusão processual civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- VENOSA, Sílvio de Salvo. *Direito civil parte geral*. 7. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2007.
- _____. *Direito civil: direito das sucessões*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- Viana, Marco Aurélio S. *Comentários ao novo Código Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2003. vol. XVI.
- VIEIRA DE CARVALHO, Luiz Paulo. *Direito das sucessões*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014.
- WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. *Curso avançado de processo civil*. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2013. vol. III.
- WATANABE, Kazuo. *Da cognição no processo civil*. 2. ed. atual. Campinas: Bookseller, 2000.
- WEBER, Max. *A ética protestante e o espírito do capitalismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
- _____. *A gênese do capitalismo moderno*. São Paulo: Ática, 2006.
- _____. *Economia e sociedade*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999.

Ação de consignação de pagamento

- Art. 539, 1 a 9
- Art. 540, 1 e 2
- Art. 541, 1 a 3
- Art. 542, 1 a 6
- Art. 543, 1 a 4
- Art. 544, 1 a 10
- Art. 545, 1 a 6
- Art. 546, 1 a 3
- Art. 547, 1 e 2
- Art. 548, 1 a 5
- Art. 549, 1 a 3

Ação de demarcação

- Art. 569, 1, 2, 3, 7, 8, 9
- Art. 570, 1, 2
- Art. 571, 1
- Art. 572, 1, 2
- Art. 574, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Art. 575, 1, 2
- Art. 576, 1, 2
- Art. 577, 2, 3
- Art. 578, 1, 2
- Art. 579, 1, 2, 3, 4
- Art. 580, 1, 2
- Art. 581, 1, 2, 3, 4
- Art. 582, 1, 2, 3, 4, 5

Ação de divisão

- Art. 569, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Art. 570, 1, 2
- Art. 572, 2
- Art. 588, 1, 2, 3, 4
- Art. 589, 1 a 6
- Art. 592, 1
- Art. 597, 4

Ação de Exigir Contas

- Art. 550, 1 a 13
- Art. 551, 1, 2, 3
- Art. 552, 1, 2
- Art. 553, 1, 2

Ações de força nova

- Art. 558, 3, 4
- Art. 561, 1
- Art. 566, 1 e 3

Ação de imissão de posse

- Das ações possessórias, 12

Ação de manutenção de posse

- Art. 558, 2

Ação de reconhecimento de domínio

- Art. 557, 1, 2

Ação de reintegração de posse

- Art. 558, 1, 2
- Art. 560, 2, 3
- Art. 566, 6
- Art. 572, 2
- Art. 593, 2

Ação petítória na pendência de demanda possessória

- Art. 557, 1

Ações de força velha

- Art. 558, 1, 3, 4
- Art. 562, 3
- Art. 565, 1
- Art. 566, 3

Ações dúplices

- Art. 556, 1
- Art. 569, 7
- Art. 589, 3
- Art. 599, 1

Ações possessórias

- Art. 554, 1, 2
- Art. 555, 1, 2, 3
- Art. 556, 1, 3
- Art. 557, 1, 3, 4
- Art. 558, 1, 3, 4
- Art. 559, 1

Ações possessórias e tutela de urgência

- Art. 558, 3

Ações possessórias para a tutela de bens imateriais

- Introdução, 1.5

Ações reivindicatórias

- Das ações possessórias , 12
- Art. 557, 1, 2, 3

Adimplemento

- Art. 539, 1
- Art. 540, 1

Adimplemento por consignação

- Art. 539, 1, 1.9

- Art. 540, 1

Aforamento e/ou enfiteuse

- Art. 549, 1, 2, 3

Agravo de instrumento

- Art. 539, 8
- Art. 548, 2

Ano e dia nas ações que envolvem posse

- Art. 558, 1, 2, 3

Apresentação das contas

- Art. 550, 8
- Art. 551, 1

Aquisição da posse

- Introdução, 7

Atipicidade dos meios executivos

- Art. 555, 3

Audiência Prevista no art. 334 do CPC

- Art. 542, 4
- Art. 550, 3
- Art. 562, 3
- Art. 577, 3

Audiência justificatória

- Art. 562, 2, 3

Auto de demarcação

- Art. 586, 2, 3
- Art. 587, 1, 2

Autotutela na Posse

- Introdução, 11

Caução nas ações que envolvem posse

- Art. 559, 1, 2

Citação na ação consignatória

- Art. 542, 3
- Art. 543, 2
- Art. 544, 3
- Art. 547, 2

Citação na ação de exigir contas

- Art. 550, 5

Citação nas ações de manutenção ou reintegração de posse

- Art. 562, 3
- Art. 564, 1

Citação na ação divisória e demarcatória

- Art. 570, 2
- Art. 574, 4
- Art. 576, 1
- Art. 589, 1
- Art. 594, 4

Citação na ação de dissolução parcial de sociedade

- Art. 601, 4

Cognição sumária e exauriente

- Art. 539, 7

Coisa indeterminada

- Art. 543, 1

Coisa julgada

- Art. 582, 3

Complementação do depósito

- Art. 539, 6
- Art. 545, 1

Composse

- Introdução, 3

Condições da ação

- Art. 541, 2

– Art. 569, 3

– Art. 577, 3

Consignação de aluguéis

– Art. 539, 1.8

Consignação em pagamento

– Art. 549, 3

Contestação

– Art. 548, 2

– Art. 550, 7

– Art. 556, 1, 3

– Art. 577, 3

– Art. 603, § 2.º, 2

Continuidade da posse

– Art. 561, 5

Convenções processuais

– Art. 558, 4

– Art. 566, 4

Cumulação de ações

– Art. 570, 1

Cumulação de pedidos

– Art. 542, 5

– Art. 549, 3

– Art. 550, 4

Cumulação de pedidos nas ações

possessórias

– Art. 555, 1, 6

Cumulação objetiva

– Art. 570, 1

Curador especial

– Art. 539, 1.3

– Art. 671, 74

Danos morais

– Art. 539, 8

Declaração de ausência

– Art. 539, 1.3, 3

Defesa na ação de consignação de pagamento

– Art. 548,4 e 5

Demanda e ação

– Art. 539, 1

Demarcação e divisão extrajudiciais

– Art. 571, 2 a 4

Denúnciação da lide

– Art. 560, 3

– Art. 572, 4

– Art. 594, 5

Depositário

– Art. 542, 3

– Art. 553, 1

Depósito

– Art. 541, 1 a 3

– Art. 542, 1, a 5

– Art. 544, 6e 7

Depósito da coisa litigiosa

– Art. 559, 3

Depósito extrajudicial

– Art. 539, 1 e 9

– Art. 542, 1

Depósito insuficiente

- Art. 544, 7

Depósito liberatório

- Art. 539, 1.1, 4 e 5

Depósito prévio

- Art. 542, 5

Desforço *incontinenti*

- Introdução, 11

Direito de ação

- Introdução, 1
- Art. 557, 1
- Art. 570, 1

Dissolução parcial de sociedade

- Introdução, 1
- Art. 599, 2
- Art. 600, 3
- Art. 601, 4
- Art. 604, 8
- Art. 606, 10
- Art. 608, 12

Dissolução parcial de sociedades anônimas

- Art. 599, 2

Dívida portátil

- Art. 539, 1.3
- Art. 540, 1
- Art. 541, 1
- Art. 544, 6

Dívida quesível

- Art. 539, 1.2, 1.3 e 3
- Art. 540, 1

Domicílio do credor

- Art. 539, 1.2

– Art. 540, 1

– Art. 544, 4

Domicílio do devedor

– Art. 539, 1.2

– Art. 540, 1

– Art. 544, 4

Economia processual

– Art. 541, 3

– Art. 581, 3

– Art. 599, 2

– Art. 601, 4

– Art. 641, 4.2

– Art. 669, 72

– Art. 673, 76

Eficácia da sentença

– Art. 539, 5

– Art. 549, 3

– Art. 566, 5 e 6

– Art. 581, 2

– Art. 582, 2

– Art. 587, 2

– Art. 597, 4

Embargos de terceiro

– Introdução, 12

– Art. 554, 1

– Art. 572, 2, 3, 4

– Art. 594, 2 a 5

– Art. 600, 3

Esbulho

- Introdução, 1.4, 8
- Art. 553, 3
- Art. 555, 4, 5, 6
- Art. 556, 1, 2
- Art. 558, 1, 2
- Art. 560, 2
- Art. 561, 4, 5
- Art. 565, 1

Estado de necessidade

- Art. 542, 5

Etapas da ação de dissolução parcial de sociedade

- Introdução, 1.
- Art. 599, 2
- Art. 600, 3
- Art. 601, 4
- Art. 602, 5
- Art. 603, 6
- Art. 604, 8
- Art. 605, 9
- Art. 606, 10
- Art. 608, 12

Execução por sub-rogação

- Art. 545, 5
- Art. 552, 1
- Art. 553, 2
- Art. 555, 3
- Art. 572, 4

Fases da ação de exigir contas

- Art. 550, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12

Função social da posse

- Introdução, 1.4

Fungibilidade das ações possessórias

- Art. 554, 1

–

- Art. 594, 2

Georreferenciamento

- Art. 573, 1.2

Herança

- Art. 595, 2
 - Art. 609, 1, 3
 - Art. 610, 6
 - Art. 615, 14, 15
 - Art. 617, 17
 - Art. 620, 21
 - Art. 640, 41
 - Art. 645, 46
 - Art. 647, 48
 - Art. 653, 56
 - Art. 654, 57
 - Art. 655, 58
- Art. 658, 61
 - Art. 672, 75

Impedimento e/ou suspeição

- Art. 542, 3
 - Art. 544, 2
 - Art. 548, 2
 - Art. 550, 7
 - Art. 579, 3
 - Art. 585, 1
 - Art. 590, 1
 - Art. 599, 2

- Art. 627, 28

Impugnação às contas

- Art. 550, 9

Inadimplemento

- Art. 539, 1.1, 3, 4
- Art. 540, 2
- Art. 541, 2
- Art. 543, 3
- Art. 544, 6

Incapacidade

- Art. 539, 1.1, 1.3, 3
- Art. 577, 3
- Art. 657, 60
- Art. 659, 62

Incidente de remoção do inventariante

- Art. 623, 24

Indenização por perdas e danos

- Art. 555, 2, 3, 4, 5, 6

Interdito proibitório

- Art. 556, 2
- Art. 567, 1, 4
- Art. 568, 2, 3

Interpretação conforme a Constituição

- Art. 557, 1, 2

Intervenção do Ministério Público

- Art. 565, 3

Intervenção de terceiros

- Art. 560, 3
- Art. 594, 5

Inventário e partilha

- Introdução, 1, 2, 3

- Art. 610, 6
- Art. 659, 62
- Art. 667, 70
- Art. 669, 72
- Art. 670, 73

Inventário extrajudicial

- Art. 610, 4.1

Inventário negativo

- Art. 410, 4.3

Julgamento antecipado do mérito

- Art. 550, 9
- Art. 555, 6
- Art. 566, 3

Julgamento antecipado parcial do mérito

- Art. 539, 8
- Art. 589, 5
- Art. 566, 2

Juros moratórios e/ou compensatórios

- Art. 540, 2
- Art. 541, 2

Justa recusa

- Art. 544, 5

Justo título

Introdução, 2.3

Legitimação ordinária e extraordinária

- Art. 539, 2, 3, 4
- Art. 569, 4
- Art. 575, 1, 2
- Art. 618, 19

Legitimidade para a ação demarcatória

– Art. 575, 1 e 2

Legitimidade para a ação divisória

– Art. 569, 1

Levramento do depósito

– Art. 546, 3

Liminar possessória

– Art. 563, 1

Limites objetivos da coisa julgada

– Art. 539, 7

– Art. 582, 3

Litígios coletivos por propriedade

– Art. 565, 6

Litisconsórcio

– Art. 547, 1

– Art. 554, 2

– Art. 560, 2

– Art. 574, 1, 4

– Art. 575. 2

– Art. 601, 4

Litispendência

– Art. 550, 4

– Art. 612, 11

– Art. 616, 16

Mandado citatório

– Art. 540, 1

– Art. 542, 3

– Art. 543, 4

– Art. 562, 3

– Art. 577, 2

Memorial descritivo

– Art. 597, 1, 3

Mora do Credor

- Art. 539, 1, 2

Mora do devedor

- Art. 539, 1.1
- Art. 540, 1
- Art. 544, 6

Natureza das ações possessórias

- Introdução, 10

Nomeação à autoria

- Art. 560, 3

Objeto da Posse

Introdução, 1.5

Obrigações alternativas

- Art. 539, 1.6

Obrigações de gênero

- Art. 543, 1, 2

Obrigações líquidas, certas e/ou exigíveis

- Art. 539, 6

Obrigações tributárias

- Art. 539, 1.7, 9
- Art. 597, 3

Ônus da prova

- Art. 539, 1.2, 7

Parcela incontroversa

- Art. 545, 4

Perda da posse

- Introdução, 8

Perdas e danos nas ações possessórias

- Art. 555, 2, 3

Petição inicial

- Art. 542, 1
- Art. 550, 3
- Art. 554, 2
- Art. 588, 1
- Art. 615, 15

Posse de boa-fé e de má-fé

- Introdução, 2.3

Posse direta e indireta

- Introdução, 2.1

Posse e detenção

- Introdução, 4

Posse e propriedade

- Introdução, 5

Posse e servidões

- Introdução, 6

Posse justa e injusta

- Introdução, 2.2

Preclusão *pro judicato*

- Art. 563, 3

Pressupostos processuais

- Art. 539, 2

Primeiras declarações

- Art. 617, 18
- Art. 620, 21
- Art. 626, 27
- Art. 627, 28

Princípio da ampla defesa

- Art. 624, 25
- Art. 627, 28

Princípio da fungibilidade

– Art. 572, 2

– Art. 594, 2

Princípio de *saisine*

– Inventário e partilha, 1

– Art. 613, 12

Princípio do contraditório

– Art. 541, 3

– Art. 559, 1

– Art. 592, 1

Prova da posse

– Art. 561, 4

Prova pericial

– Art. 573, 1, 2

– Art. 579, 1, 2, 3, 4

Quitação

– Art. 539, 1.1

– Art. 546, 3

Reconhecimento jurídico do pedido

– Art. 550, 9

Reconvenção

– Art. 539, 1.8

– Art. 544, 2, 9

– Art. 550, 6

– Art. 556, 3

– Art. 557, 3

Revelia

– Art. 544, 9

– Art. 550, 6

– Art. 555, 6

– Art. 562, 3

- Art. 579, 1
- Art. 582, 3
- Art. 589, 5
- Art. 601, 4
- Art. 671, 74

Saneamento compartilhado

- Art. 550, 9
- Art. 558, 3, 4
- Art. 566, 4

Sentença declaratória

- Art. 540, 1

Sentença mandamental

- Art. 539, 1.5

Sobrepartilha

- Art. 669, 72

Tapumes

- Art. 569, 1

Teoria da asserção

- Art. 550, 2

Teorias objetivas e subjetivas

Introdução à posse, 1.3

Terceiro interessado

- Art. 539, 2

Turbação e esbulho possessório

- Art. 555, 5
- Art. 561, 4, 5

Tutela antecipada em caráter antecedente

- Art. 578, 2

Tutela de evidência

- Art. 566, 3

Tutela de urgência

– Art. 542, 5

– Art. 558, 3

Tutela ressarcitória específica e pelo equivalente

– Art. 555, 4

Valor da causa

– Art. 542, 6

– Art. 550, 3

– Art. 560, 4

– Art. 574, 6

– Art. 615, 15

Vindicação ou indenização decorrente de ação divisória

– Art. 572, 2

© desta edição [2018]